제1강 행정의 의의와 법치행정

♣ 학습목표

행정의 의의에 대하여 정확히 이해하여 입법, 사법과 구별할 수 있다.
통치행위의 사법심사 가능성에 대해 설명할 수 있다.
법치행정의 내용으로 법률의 법규창조력, 법률우위, 법률유보를 각각 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

행정의 의의
통치행위의 의의 및 사법심사가능여부
법치행정
행정법의 법원의 의의 및 종류

♣ 사전테스트

1. 대통령의 시행령제정행위는 실질적 의미의 행정이다.
   정답 : X

2. 통치행위라는 관념을 부정하는 것이 우리나라 대법원의 입장이다.
   정답 : X

3. 국민의 기본권을 침해하는 통치행위에 대하여 헌법소원의 대상이 된다는 것이 헌법재판소의 입장이다.
   정답 : O

♣ 돌발퀴즈

대법원은 남북정상회담의 개최는 물론 남북정상회담의 과정에서 관련부서에 대한 신고 또는 승인 등의 법적 절차를 거치지 아니하고 북한으로 송금한 행위도 사법심사의 대상으로 보기 어렵다고 하였다.

[정답] ×

[해설] 남북정상회담의 개최과정에서 재정경제부장관에게 신고하지 아니하거나 통일부장관의 협력사업승인을 얻지 아니한 채 북한 측에 사업권의 대가 명목으로 송금한 행위 자체는 헌법상 법치국가의 원리와 법 앞에 평등원칙 등에 비추어 볼 때 사법심사의 대상이 된다(대판 2004.3.26, 2003도7878).

♣ 강의내용

제1 행정의 의의

Ⅰ. 행정관념의 성립

권력분립제도를 채택한 근대입헌국가가 성립됨으로써 오늘날 행정법의 규율대상으로서의 행정이라는 관념이 성립되었다.

Ⅱ. 형식적 의미의 행정

행정부에 속하는 행정기관이 행하는 모든 활동을 말한다. 국무총리가 국무총리령이라는 법규명령을 제정하는 행위(실질적 의미의 입법행위)도 국무총리라는 행정기관의 행위인 바 형식적 의미의 행정이다.

Ⅲ. 실질적 의미의 행정[1)]

학설로는 소극설, 목적실현설, 양태설, 기관양태설 등의 대립한다.

실질적 의미의 행정의 특징은 ① 공익[2)]실현, ② 장래 사회형성활동, ③ 법아래서 구체적인 사실에 대한 법집행작용이다.

Ⅳ. 국가의 타작용과의 구별

1. 입법과의 구별

입법은 일반적·추상적 법규를 정립하는 작용이나, 행정은 정립된 법규 아래에서 법규의 기속을 받으면서 그를 구체적으로 집행하는 작용이라는 점에서 양자는 구별된다(행정은 구체적, 입법은 추상적이다[3)]).

2. 사법과의 구별

'사법'이란 과거 발생한 법률상 쟁송[4)]에 관하여 당사자의 소송제기가 있는 경우에 원고와 피고[5)]로부터 독립한 지위에 있는 심판기관인 법원이 법령을 적용하여 그 분쟁을 해결하는 소극적 국가작용이나, 행정은 장래 사회형성작용이라는 점에서 양자는 구별된다.

3. 통치와의 구별

통치작용은 정치적 성격이 강하여 법에 의한 기속이 약하나, 행정은 기본적으로 법의 집행작용으로서 법에 의한 기속이 강하다는 점에서 차이가 있다고 할 수 있다.

---

1) 일반적으로 행정이라고 하면 실질적 의미의 행정을 지칭하는 것이다.
2) 사회전체의 이익 또는 모든 국민의 이익을 의미한다.
3) 구체적 규율과 추상적 규율의 판단기준은 고유한 이름에 대하여 규율하는가이다. 예컨대 '모든 아파트에서 강아지를 키우지 말아야 한다'는 고유한 이름에 대한 규율이 없는 바 추상적 규율이고, '서울대학교를 폐지하겠다'는 서울대학교라는 고유한 이름에 대한 규율인 바 구체적 규율이다. 교수님들은 구체적 규율은 1회적 규율이고 추상적 규율은 장래 반복적으로 계속 적용될 규율이라고 하신다.
4) 법률상 쟁송이라는 사람과 사람간의 구체적인 권리의무다툼을 의미한다. 법원은 사법심사의 대상(소송의 대상)은 개별법률에 특별규정이 없는 한 오로지 법률적 쟁송이다. 따라서 법률적 쟁송이 아닌 것에 대하여 법원에 소송을 제기하면 개별 법률에 특별규정이 없는 한 법원은 법률적 쟁송이 아닌 것에 대해선 사법심사를 할 수 없다고 하여 각하판결을 내리게 된다.
5) 민사소송과 행정소송에서 소송을 제기한 자를 원고라 하고 소송을 제기받은 자를 피고라 한다. 형사소송에서는 형사소송(공소, 기소)을 제기한 자를 검사라 하고 형소소송을 제기받은 자를 피고인이라 한다.

제2 통치행위

Ⅰ. 서 설

고도의 정치적인 국가행위에 있어 그 법적 판단이 가능함에도 불구하고 사법심사의 대상에서 제외되거나 제한되는 행위를 말한다.

국가권력이 입법·사법·행정으로 구분되는 3권분립체계상 통치행위의 위치가 문제되나 최상위의 국가지도(통치)는 3권하에 놓이는 것이 아니라 3권의 영역에 속하지 않는 제4의 권력으로 불린다.

Ⅱ. 각국의 실태

각국에서 통치행위의 예로 드는 것으로는 주로 대통령과 국회의 고도의 정치행위로서 의회소집, 의회해산, 계엄선포, 조약체결, 선전포고 등이 있다.

Ⅲ. 통치행위에 대한 항고소송가능성(통치행위 인정여부)

1. 통치행위 부정설

실질적 법치주의가 확립되고 국민의 재판청구권이 일반적으로 인정되고 있으며 행정소송상 개괄주의가 채택된 현대국가에서는, 비록 고도의 정치적 행위라 하더라도 그것이 국민과의 관계에서 법률적 쟁송을 발생시켰다면 당연히 사법심사가 가능하다고 보아야 한다는 견해이다.

2. 통치행위 긍정설

①재량행위이므로 사법심사가 불가하다는 재량행위설, ②고도의 정치적 행위는 정치적 책임을 지는 것은 별론으로 법원이 심사하기 부적당하다는 내재적 제약설(권력분립설), ③통치행위도 사법심사가 가능하나 더 큰 위해방지를 위해 사법부가 사법심사를 자제한다는 사법자제설, ④통치행위에 대한 사법심사는 사법부의 헌법상 권한밖에 있다는 헌법적 한계설 등이 대립하고 있다.

3. 대법원의 입장

통치행위와 관련하여 대법원은 대통령의 계엄선포와 관련된 재판권재정신청에 대한 결정에서 대통령의 비상계엄선포는『고도의 정치적 군사적 성격을 지니고 있는 행위로서 그것이 누구나 일견 헌법이나 법률에 위반되는 것이 명백하게 인정될 수 있는 것이라면 몰라도 그렇지 아니한 이상 당연 무효라고는 단정할 수 없다』라 판시하여(대판 1964. 7. 21, 64초6), 한정적 긍정론을 펴고 있다.

4. 검토

먼저 재량행위설은 오늘날에는 재량행위에 일탈·남용이 있는 경우에 위법한 행위로서 당연히 사법심사가 된다는 점에서, 사법자제설은 헌법에서 부여받은 사법부의 권한을 행사하지 않는 것은 헌법위반이라는 점과 사법부의 자제 자체가 어느 한쪽의 정치적 입장을 대변하는 것이라는 점에서 문제가 있다.

결국 국민에게 재판청구권이 보장되어 있으며 행정소송에 있어서 개괄주의가 채택되어 있고 헌법재판소의 헌법소원심사권이 인정되고 있는 이상 법률적 판단이 가능하고, 또한 이를 통하여 개인의 권리에 관한 구체적 분쟁을 해결할 수 있는 사항이라면 사법심사의 대상이 된다고 할 것이다. 다만, 정부나 국회의 권한행사가 법원의 심판대상이 되기에 부적절한 고도의 정치적 행

위에 대해서는 사법심사의 대상으로 하기 보단 정치적 심판의 대상으로 하는 것이 권력분립원칙이나 사법권의 본질에 적합할 것이다.

Ⅳ. 헌법소원의 가능성

통치행위성을 인정하더라도 당해 행위가 기본권과 관련되는 행위인 때에는 헌법소원의 대상성을 인정하고 당해 행위가 국민의 기본권과 직접적인 관련성이 없는 행위인 때에는 헌법소원의 대상성을 부정하는 것이 타당하다.

헌법재판소는 대통령의 긴급재정명령에 관한 헌법소원에서 통치행위성이 인정되더라도 당해 행위가 기본권과 관련되는 행위인 때에는 헌법소원의 대상이 된다고 판시하였으나(헌재 1996.02.29, 93헌마186), 일반사병 이라크파병 헌법소원에서는 헌법소원의 대상성에 대하여 사법자제설적인 입장을 취하고 있다(헌재 2004.04.29, 2003헌마814).

Ⅴ. 통치행위의 범위

현행 헌법상 제64조 제4항은 국회의원의 자격심사, 징계, 제명처분에 대해서는 법원에 제소할 수 없다고 규정하고 있는 바, 이에 대해서는 당연히 사법심사가 배제된다.

그러나 명문규정이 없는 경우 재판통제에서 배제되는 통치행위의 범위와 관련하여 주로 헌법에 규정되어 있는 대통령의 국가원수 또는 행정부수반으로서의 행위와 의회의 일정한 행위를 통치행위로 인정하고 있다.

Ⅵ. 통치행위의 한계와 국가배상책임문제

1. 통치행위의 한계 - 헌법에 의한 제한, 국회의 통제, 여론의 비판

2. 국가배상책임의 문제

위법한 통치행위로 인해 사인이 손해를 입은 경우 국가는 그에 대한 배상책임을 지는지에 대해 다음과 같이 견해가 대립한다.

제3 법치행정

Ⅰ. 의의

행정은 법률의 근거하에서 법률에 구속되서 행하여져야 하며, 이를 위반하여 개인에게 피해가 발생하면 이에 대해 재판을 통한 구제가 주어져야 한다는 헌법상 원칙을 말한다. 이러한 법치행정은 행정의 자의를 방지하고 예측가능성을 제공하여 국민의 기본권을 보장하기 위한 것이다.

Ⅱ. 법치행정의 내용

1. 법률의 법규창조력

법률의 법규창조력이라 함은 법규의 정립은 국회의 전속적 권한에 속하므로 행정부는 법률에 의한 수권(위임, 즉, 식품위생법이라는 법률에서 '유흥주점영업허가의 세부적 기준은 대통령령으로 정한다'라고 규정하는 것을 말한다)이 없는 한 스스로 법규를 창조할 수 없다는 것을 말한다(헌법 제40조, 제75조).

다만, 법률의 법규창조력의 원칙에 대한 예외로서 헌법 제76조에 의한 긴급명령 등이 있다.

2. 합헌적 법률우위원칙

⑴ 의의

법률의 우위란 국가의 행정작용은 헌법에 부합하는 법률에 위반되어서는 안 된다는 것이다. 즉 이것은 법률의 형식으로 표현된 국가의사는 법적으로 다른 모든 국가작용(행정이나 사법)보다 상위에 있는 것이므로, 특히 행정에 있어서 행정작용은 법률에 저촉될 수 없다는 것을 의미한다. 이 원칙은 법치행정원리의 최소한 또는 불가결의 요소를 이루는 것이다.

⑵ 적용범위

법률유보원칙과는 달리 모든 행정작용에 적용된다. 법률우위의 한계를 넘은 경우에는 법률우위원칙 위반으로 당해 행정작용은 위법하게 된다. 법률우위원칙의 위반여부 판단시에는 성문법 위반은 물론 행정법의 일반원리 등의 불문법원리 위반여부도 판단한다.

3. 법률유보원칙 : 후술

Ⅲ. 행정통제제도의 확립

위법·부당한 공권력행사에 의해 국민의 권익이 침해된 경우, 침해된 국민의 권익을 구제해 주는 제도가 보장되어야만 법치행정의 원칙이 실질적으로 실현된다고 말할 수 있다.

Ⅳ. 법치행정의 한계 및 예외

1. 입법에 있어서 행정의 역할 증대

행정의 전문화, 복잡화 및 사회의 급격한 변화로 인해 의회의 입법능력의 한계가 드러나고 있다. 그리하여 행정입법이 날로 증대하고 있고, 법률의 제정에 있어서도 행정부가 매우 큰 역할을 하고 있다.

2. 재량 및 판단여지

재량권과 판단여지가 인정되는 경우에는 행정권의 행사는 일정한 한계를 넘지 않는 한 위법한 것으로 되지 않으며 사법적 통제의 대상이 되지 않는다.

3. 특별권력관계

오늘날 민주주의·법치주의 국가에서는 특별권력관계에도 당연히 법치주의가 적용된다.

4. 통치행위

통치행위란 고도의 정치적 행위로서 사법심사를 하기에 부적당한 행위를 말한다. 따라서 통치행위는 법치국가가 확립되고 국가작용의 합법성에 대한 사법통제가 일반적으로 인정되고 있는 오늘날에 있어서는 예외적 현상에 해당된다.

제4 법률유보

Ⅰ. 개 설

1. 의 의

법률유보의 원칙이란 행정부가 일정영역의 행정작용을 할 때는 법률에 근거하여 행해져야 함을 의미한다. 법률유보에서 「법률」의 개념은 국회에서 일정한 제정절차에 의하여 만들어진 형식적 의미의 법률을 의미하는 것이다. 단, 형식적 의미의 법률의 근거만 있으면 되는 것이므로 법률에 의해 수권(위임)받아 제정된 법규명령(위임명령)에 근거가 있는 경우도 포함된다. 또, 법률유보에서 「법률」은 작용법을 의미한다[6].

2. 문제점

실질적 법치주의 내용 중 법률유보 범위의 확대와 관련하여 어느 범위까지 법적 근거를 요하게 하느냐가 문제된다. 이는 전문성을 지닌 행정의 자율적 활동의 증대라는 측면과 국민의 대표기관인 국회에서 제정되는 법률에 의해 행정권의 독단적 활동으로부터 국민의 기본권을 보장하려는 측면의 비교형량에 의하여 결정되어야 할 것이다.

3. 근거

⑴ 이론적 근거

법률의 유보는 헌법상 기본원리인 민주주의 원리, 법치국가 원리, 그리고 기본권보장원리에서 나온다.

⑵ 실정법적 근거

현행 헌법상 법률유보의 원칙을 선언하고 있는 명문의 규정은 보이지 않는다. 다만 헌법은 여러 조문에서 법률사항을 규정하고 있는 바, 그러한 규정은 효과에 있어 법률유보를 정하고 있는 것으로 새길 수 있다[7].

문제는 헌법에서 법률사항으로 규정하고 있지 아니한 행정영역에서 법률유보가 적용되는가 여부이다. 법률우위의 원칙은 모든 행정영역에 적용되지만, 법률유보 원칙의 적용범위는 불분명하다. 이에 대하여 다음과 같은 학설이 있다.

Ⅱ. 법률유보의 범위

1. 학설

침해유보설, 급부행정유보설, 전부유보설, 권력행정유보설, 중요사항유보설 등이 대립

2. 검토

침해유보설은 입헌군주제 하에서 타협의 소산이었다는 점에서, 급부행정유보설과 전부유보설은 실제 적지 않은 급부작용이 법률의 근거 없이 행하여지고 있는데 이런 급부작용에도 반드시

---

6) 정부조직법은 형식적 의미의 법률이나 작용법이 아닌 조직법이기 때문에 법률유보에서 말하는 '법률'에 해당되지 않는다.

7) 그러한 규정을 살펴보면 기본권제한(제37조 제2항), 재산권의 내용과 한계(제23조 제1항, 제2항), 재산권의 수용·사용·제한 및 보상(제23조 제3항), 공무담임(제25조), 교육제도(제31조), 국방의무(제39조), 행정각부조직(제96조), 조세법률주의(제59조) 등이 있다.

법적 근거가 있어야 한다는 것은 오히려 국민에게 불리한 결과만을 야기한다는 점에서 문제점이 있다.

결국 법률유보가 필요한 영역인가에 대하여는 본질성설(중요사항유보설)의 입장에서 구체적인 사안별로 검토하는 것이 필요하다. 즉, 침해행정에 대해서 법률유보원칙이 적용되어야 한다는 데에는 이론이 없다. 문제는 침해행정이외의 급부행정이나 기타 행정영역에 대한 것이다. 이에 관해서는 그것이 논해지는 행정영역과 행정작용 자체의 성질, 기본권관련성, 규율사항이 국민생활에서 갖고 있는 실제적 중요성 등을 고려하여 개별적으로 정해야 할 것이다.

3. 판례

헌법재판소는 TV수신료는 의회유보영역으로서 의회가 결정하여야 할 사항인 바 TV수신료를 한국방송공사가 결정하도록 규정한 구 한국방송공사법 제36조 제1항은 법률유보원칙위반이라고 판시하였다(의회유보영역으로 봄).

제5 행정법의 법원

Ⅰ. 개 설

1. 의 의

행정법의 법원이란 행정부의 조직과 작용 및 구제에 관한 실정법의 존재형식을 말한다. 그런데 여기에서의 실정법을 어느 범위로 이해하느냐에 따라, ① 대외적 구속력있는 협의의 법규만을 법원으로 보려는 견해(협의설)와 ② 그보다 넓게 행정부 내부간의 구속력(대내적 구속력)이 있는 모든 법규범을 법원으로 보려는 견해(광의설)가 있다(대외적 구속력이란 국민에게 구속력이 있는 것을 말하고 대내적 구속력이란 행정부 내부간, 즉 행정기관에게 구속력이 있는 것을 말한다. 위'법'하다고 할 때 '법'은 대내적 구속력과 대외적 구속력이 모두 있는 협의의 법규만이다. 따라서 대외적 구속력은 없고 대내적 구속력만 있는 행정규칙을 위반한 경우에는 위법한 것이 아니다).

2. 성문법주의

3. 단일법전 또는 통칙의 결여

Ⅱ. 성문법원

1. 헌 법

헌법은 국가의 기본법으로서 행정작용·행정구제·행정조직 등 행정에 관한 근본적 사항을 규율하는 많은 규정들을 가지고 있다. 따라서 그 범위 내에서 헌법은 행정법의 최고법원이 될 수 있다.[8)]

8) 구체적 기본권(자유권, 평등권, 재산권 등)은 직접 행정법상 개인적 공권이 된다. 추상적 성질을 갖는 기본권(환경권, 주거권, 사회권 등)은 법률에 의하여 구체화되어야 행정법상 개인적 공권으로 된다고 본다.

2. 법률

3. 조약 및 일반적으로 승인된 국제법규(헌법 제6조 및 제60조 참조)

4. 법규명령과 행정규칙

5. 자치법규

Ⅲ. 불문법원

행정법은 성문법주의를 취하지만, 성문법이 정비되지 않은 분야에 대하여는 불문법도 보충적 법원이 된다. 불문법원에는 관습법, 판례법, 행정법의 일반원칙, 조리가 있다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 행정의 개념에 관한 개념징표설에 의한 행정의 개념징표로 볼 수 없는 것은?

① 행정은 행정주체의 작용이다.
② 행정은 공동체에 있어서 사회형성을 담당한다.
③ 행정은 다양한 법형식에 의한다.
④ 행정은 공익실현을 목적으로 한다.
⑤ 행정은 추상적 사안에 대한 규율을 행한다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

입법은 일반적·추상적 규율인 법(규범)정립작용에 해당하지만 행정은 개별적·구체적 규율로서 법집행작용에 해당한다.

정답 ⑤

2. 대통령은 금융실명제도의 개선을 위하여 '금융실명거래에관한긴급재정경제명령'을 발하였다. 이로 인하여 甲소유 주식의 시가가 폭락하게 되었다. 이에 甲은 위 재정경제명령을 법적으로 다투려고 한다. 이와 관련된 아래의 서술 중 옳지 않은 것은? (제36회 외무고시 2차 문제 변형)

① 통치행위란 고도의 정치성을 가진 국가기관의 행위로서 법적 구속을 받지 않으며 그에 대한 법적 판단이 가능함에도 불구하고 재판통제에서 제외되는 행위를 말하는데 사안의 금융실명거래에관한긴급재정경제명령'의 발령행위는 통치행위에 해당된다.
② 통치행위의 인정 여부와 관련하여 대법원은 통치행위를 부정하나, 헌법재판소는 통치행위를 긍정한다.
③ 사안의 행위에 대해서 법적으로 다투기 위해서 사법심사 가능성이 인정되어야 하는데 대법원과 헌법재판소 모두 예외적으로 사법심사가능성을 인정하고 있다.
④ 사안의 발령행위는 처분성이 인정되어서 행정소송의 대상적격이 인정되고, 공권력 행사에 해당되어서 헌법소원의 대상적격이 인정된다.
⑤ 위법성심사가 배제되는 통치행위에 대해서 국가배상청구가 부정된다는 것이 대법원의 입장이고, 이에 대한 손실보상청구가 부정된다는 것이 대법원의 입장이다.

해설 & 정답

유형 사례형

① 대통령의 긴급재정경제명령은 국가긴급권의 일종으로서 고도의 정치적 결단에 의하여 발동되는 행위이고 그 결단을 존중하여야 할 필요성이 있는 행위라는 의미에서 이른바 통치행위에 속한다고 할 수 있으나, 통치행위를 포함하여 모든 국가작용은 국민의 기본권적 가치를 실현하기 위한 수단이라는 한계를 반드시 지켜야 하는 것이고, 헌법재판소는 헌법의 수호와 국민의 기본권 보장을 사명으로 하는 국가기관이므로 비록 고도의 정치적 결단에 의하여 행해지는 국가작용이라고 할지라도 그것이 국민의 기본권 침해와 직접 관련되는 경우에는 당연히 헌법재판소의 심판대상이 된다(헌재 1996.2.29, 93헌마186).

② 대법원은 대통령의 계엄선포와 관련된 재판권재정신청에 대한 결정에서 대통령의 비상계엄선포는 "고도의 정치적 군사적 성격을 지니고 있는 행위로서 그것이 누구나 일견 헌법이나 법률에 위반되는 것이 명백하게 인정될 수 있는 것이라면 몰라도 그렇지 아니한 이상 당연 무효라고는 단정할 수 없다(대판 1964.7.21, 64초6)"라고 판시하여 사법자제설과 권력분립설의 관점에서 통치행위를 긍정했다. 헌법 재판소는 ①에서 적시한 헌법재판소 결정문에서 통치행위를 인정하고 있다.

③ 대법원은 "남북정상회담의 개최는 고도의 정치적 성격을 지니고 있는 행위라 할 것이므로 특별한 사정이 없는 한 그 당부를 심판하는 것은 사법권의 내재적·본질적 한계를 넘어서는 것이 되어 적절하지 못하지만, 남북정상회담의 개최과정에서 재정경제부장관에게 신고하지 아니하거나 통일부장관의 협력사업 승인을 얻지 아니한 채 북한측에 사업권의 대가 명목으로 송금한 행위 자체는 헌법상 법치국가의 원리와 법 앞에 평등원칙 등에 비추어 볼 때 사법심사의 대상이 된다(대판 2004.3.26, 2003도7878)"고 판시하여 원칙적으로 사법심사 부정설의 입장을 취하고 있다. 헌법재판소는 ①에서 적시한 헌법재판소 결정문에서 제한적으로 사법심사를 인정하고 있다.

⑤ 대법원은 "외교관계에관한비엔나협약이 대사관저에 대한 명도집행뿐만 아니라 공관 내의 재산에 대한 강제집행을 직접적으로 금하고 있다고 하더라도, 협약규정 자체가 직접적으로 외국대사관과 어떠한 법률행위를 강제하는 등으로 국민의 재산권을 침해하는 것은 아니고, 협약규정의 적용을 받는 외국대사관과 어떠한 법률행위를 할 것인지의 여부는 전적으로 국민의 자유의사에 맡겨져 있다고 할 것이므로 협약규정의 적용에 의하여 어떠한 손해가 발생하였다고 하여 그것이 국가의 공권력행사로 말미암은 것이라고 볼 수 없고 나아가 외국 대사관이 사전에 승소판결에 기한 강제집행을 거부할 의사를 명시적으로 표시하였으므로 손해가 집달관의 강제집행 거부를 직접적인 원인으로 하여 발생한 것이라고 볼 수 없으므로 손실보상의 대상이 되지 아니한다(대판 1997.4.25, 96다16940)"라고 판시하여 손실보상청구를 기각하였고, 또한 "국가가 보상입법을 하지 아니하였다거나 집달관이 협약의 관계 규정을 내세워 강제집행을 거부하였다고 하여 이로써 불법행위가 되는 것은 아니다(대판 1997.4.25, 96다16940)"라고 판시하여 국가배상청구를 부정하였다.

정답 ②

3. 통치행위에 관한 판례의 내용으로 옳은 것은?

① 대통령의 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 긴급재정·경제명령'은 국가긴급권의 일종으로서 고도의 정치적 결단에 의하여 발동되는 행위이고 그 결단을 존중하여야 할 필요성이 있는 행위라는 의미에서 통치행위이므로 그것이 국민의 기본권침해와 직접 관련되는 경우라 하더라도 헌법재판소의 심판대상이 되지 아니한다.

② 외국에서의 국군의 파견결정은 파견군인의 생명과 신체의 안전뿐만 아니라 국제사회에서의 우리나라의 지위와 역할, 동맹국과의 관계, 국가안보문제 등 궁극적으로 국민 내지 국익에 영향을 미치는 복잡하고도 중요한 문제로서 국내 및 국제정치관계 등 제반 상황을 고려하여 미래를 예측하고 목표를 설정하는 등 고도의 정치적 결단이 요구되는 사안이다.

③ 남북정상회담의 개최는 고도의 정치적 성격을 지니고 있는 행위라 할 것이므로, 회담의 개최과정에서 구 재정경제부장관에게 신고하지 아니하거나 통일부장관의 협력사업 승

인을 얻지 아니한 채 북한 측에 사업권의 대가 명목으로 송금한 행위 자체는 사법심사의 대상이 되지 아니한다.

④ 대통령의 비상계엄의 선포나 확대 행위는 고도의 정치적·군사적 성격을 지니고 있는 행위라 할 것이므로, 그 계엄선포의 요건구비 여부나 선포의 당·부당을 판단할 권한이 사법부에는 없다고 할 것이고, 비상계엄의 선포나 확대가 국헌문란의 목적을 달성하기 위하여 행하여진 경우에라도 법원은 그 자체가 범죄행위에 해당하는지의 여부에 관하여 심사할 수 없다.

⑤ 행정소송에 대한 개괄주의를 취하게 되면 통치행위를 부정할 수밖에 없다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 헌법재판소는 헌법의 수호와 국민의 기본권보장을 사명으로 하는 국가기관이므로 비록 고도의 정치적 결단에 의하여 행해지는 국가작용이라고 할지라도 그것이 국민의 기본권침해와 직접 관련되는 경우에는 당연히 헌법재판소의 심판대상이 된다(헌재 1996.2.29, 93헌마186).

② 이 사건 파견결정은 그 성격상 국방 및 외교에 관련된 고도의 정치적 결단을 요하는 문제로서, 헌법과 법률이 정한 절차를 지켜 이루어진 것임이 명백하므로, 대통령과 국회의 판단은 존중되어야 하고 우리 재판소가 사법적 기준만으로 이를 심판하는 것은 자제되어야 한다(헌재 2004.4.29, 2003헌마814).

③ 남북정상회담의 개최과정에서 구 재정경제부장관에게 신고하지 아니하거나 통일부장관의 협력사업승인을 얻지 아니한 채 북한 측에 사업권의 대가 명목으로 송금한 행위 자체는 헌법상 법치국가의 원리와 법 앞에 평등원칙 등에 비추어 볼 때 사법심사의 대상이 된다(대판 2004.3.26, 2003도7878).

④ 대통령의 비상계엄의 선포나 확대 행위는 고도의 정치적·군사적 성격을 지니고 있는 행위라 할 것이므로, 그것이 누구에게도 일견하여 헌법이나 법률에 위반되는 것으로서 명백하게 인정될 수 있는 등 특별한 사정이 있는 경우라면 몰라도, 그러하지 아니한 이상 그 계엄선포의 요건구비 여부나 선포의 당·부당을 판단할 권한이 사법부에는 없다. 비상계엄의 선포나 확대가 국헌문란의 목적을 달성하기 위하여 행하여진 경우에는 법원은 그 자체가 범죄행위에 해당하는지의 여부에 관하여 심사할 수 있다(대판 1981.9.22, 81도1833).

⑤ 개괄주의는 행정소송의 대상에 대해 원칙적으로 특별한 규정이 없으면 소송대상에서 제외되지 않는다는 입법주의인데 개괄주의를 취하는 대부분의 나라에서 통치행위를 인정하고 있다.

정답 ②

♣ 학습내용 정리

1. 형식적 의미 행정이란 행정부가 행하는 모든 활동이고 실질적 의미 행정에 대해서는 학설의 대립이 있으나 보통 공익을 목적으로 하고 구체적 사실에 대한 규율로서 장래 사회형성활동을 의미한다.
2. 통치행위란 고도의 정치적 행위로서 사법심사의 대상으로 삼기 부적당한 행위를 말한다.
3. 법률의 법규창조력은 국회만이 법을 만들 수 있다는 원칙으로 오늘날에는 예외가 인정되고 있다.
4. 법률우위원칙은 모든 행정영역에 적용된다.
5. 법률유보원칙의 적용범위에 대해 여러 가지 학설이 대립한다.
6. 행정법의 법원에 대해 광의설과 협의설이 대립한다.
7. 행정규칙의 행정법의 법원에 해당하는지에 대하여 학설의 대립이 있다.

제2강 행정법의 일반원칙

♣ 학습목표

행정법의 일반원칙으로 평등원칙과 자기구속원칙, 비례원칙과 부당결부금지원칙, 신뢰보호원칙과 신의성실원칙의 의의, 근거, 적용요건, 한계 등을 이해하고 이에 대한 판례를 분석할 수 있다.

♣ 학습내용

평등원칙
자기구속원칙
비례원칙
부당결부금지원칙
신뢰보호원칙
신의성실원칙

♣ 사전테스트

1. 평등원칙은 무조건적인 차별금지를 의미한다.
   정답 : ×

2. 위법한 선행관행이 있는 경우에도 평등원칙(자기구속원칙)이 적용된다.
   정답 : X

3. 자기구속원칙이 적용되기 위하여 선행관행이 필요한가에 대하여 학설의 대립이 있다.
   정답 : ○

♣ 돌발퀴즈

서울대학교가 특별전형에서 외교관, 공무원의 자녀에 대하여만 획일적으로 과목별 실제 취득점수에 20%의 가산점을 부여한 것은 교육에 관한 전문적 판단으로서 평등원칙 위반이 아니다.

[정답] ×

[해설] 자유재량에 있어서도 그 범위의 넓고 좁은 차이는 있더라도 법령의 규정뿐만 아니라 관습법 또는 일반적 조리에 의한 일정한 한계가 있는 것으로서 위 한계를 벗어난 재량권의 행사는 위법하다고 하지 않을 수 없으므로, 대학교 총장인 피고가 해외근무자들의 자녀를

대상으로 한 교육법 시행령 제71조의2 제4항 소정의 특별전형에서 외교관, 공무원의 자녀에 대하여만 획일적으로 과목별 실제 취득점수에 20%의 가산점을 부여하여 합격 사정을 함으로써 실제 취득점수에 의하면 충분히 합격할 수 있는 원고들에 대하여 불합격처분을 하였다면 위법하다(대판 1990.8.28 89누8255).

♣ 강의내용

제1 평등원칙

Ⅰ. 의 의

평등의 원칙이란 동일한 사안에서 특별히 합리적인 사유가 존재하지 않는 이상 행정기관은 차별적 행정작용을 하지 말아야 한다는 것을 의미한다.

Ⅱ. 법적 근거

일부견해는 평등원칙을 헌법 제11조에 직접 근거하는 성문법원으로 본다.

이에 대해 일부견해는 평등원칙을 헌법 제11조로부터 도출되는 불문법원으로 보는 것이 타당하다고 본다.[9)]

Ⅲ. 요건

어떠한 행정작용이 평등원칙에 위반되었다고 보기 위해서는, 첫째, 동일한 사안일 것, 둘째 행정작용이 차별에 해당될 것, 셋째, 그러한 차별에 합리적 이유가 없을 것 등의 요건을 갖추어야 한다.

Ⅳ. 한계

사익적 요청으로서의 평등 내지 자기구속원칙과 공익적 요청으로서의 행정의 법률적합성이 충돌하는 국면으로, 만약 위법작용에 있어 사인의 평등대우를 인정한다면 국가 스스로 법치주의를 붕괴시키는 결과가 되므로 이 경우에는 평등원칙 및 자기구속원칙은 적용되지 않는다.

Ⅴ. 효 과

평등원칙은 헌법적 효력을 갖는다. 따라서 평등원칙에 위반한 행정작용은 위법하고, 평등원칙에 반하는 법률[10)]은 위헌이다.

제2 행정의 자기구속의 원칙

Ⅰ. 개 설

1. 행정의 자기구속원칙의 의의

---

9) 박균성, 전게서, 제47면.

10) 여기서 말하는 법률은 법률효과를 기속적으로 규정한 법률을 말한다. 만약 법률효과를 재량으로 규정한 법률이라면, 법률요건 자체가 평등원칙에 위배되지 않는 한 효과측면에서 평등원칙에 위반될 여지는 없다.

행정의 자기구속의 법리란 행정의 자유영역에서 일정한 관행이 형성되어 있는 경우 행정청은 동일한 사안에 대하여 선행관행과 동일한 행정작용을 하도록 스스로 구속당한다는 원칙을 말한다.

2. 구별개념

자기구속원칙은 대외적 구속력이 있는 협의의 법규로서, 행정기관의 내부만 구속하는 행정규칙 등 대내적 구속과는 구별된다.

3. 기 능

국민의 권리보호기능(행정의 재량권행사에 대한 사후적 사법통제의 확대).

Ⅱ. 법적 근거

신뢰보호의 원칙에서 구하는 견해와 평등의 원칙에서 찾는 견해(통설) 대립하고 있다. 다만, 헌법재판소와 대법원은 평등의 원칙이나 신뢰보호의 원칙을 종합하여 행정의 자기구속의 법리를 인정하고 있다(대판 2009. 12. 24, 2009두7967 참조).

Ⅲ. 요 건

1. 행정부의 자유영역(재량행위 등)일 것

행정의 자기구속원칙은 행정의 자유영역, 즉 법으로부터 자유로운 영역이나 재량영역 및 판단여지 영역에 적용된다.

2. 행정선례의 존재요부

필요설과 불요설이 대립하나, 재량준칙을 예기된 행정관행으로 파악하여 대외적 구속력을 인정하게 되면 행정규칙의 법규성을 인정하게 되는 결과가 되어 부당하므로 행정선례가 필요하다는 견해가 타당하다. 판례도 마찬가지다.

3. 선례와 동일한 사안일 것

Ⅳ. 효 과

행정의 자기구속의 원칙에 반하는 행정행위 등은 위법하다. 따라서 위 원칙에 반하는 행정행위는 항고쟁송의 대상이 되며, 그로 인해 손해가 발생할 경우 국가의 손해배상책임을 발생시킨다.

Ⅴ. 한 계

1. 위법한 선행관행과 자기구속

선행관행이 위법한 경우 자기구속원칙은 적용되지 않는다.

2. 사정변경

선행관행과 동일한 사안이라 하더라도 사정변경으로 다른 결정을 해야 할 공익상 필요가 심히 큰 경우에는 자기구속원칙이 적용되지 않는다.

제3 비례원칙

Ⅰ. 의 의

비례원칙이란 행정주체가 구체적인 행정목적을 실현함에 있어서 그 목적과 수단간에 합리적인 비례관계가 유지되어야 한다는 원칙을 말하며, 과잉금지의 원칙이라고도 한다.

Ⅱ. 법적 근거

헌법 제37조 제2항, 경찰관직무집행법 제1조 제2항, 행정대집행법 제2조 등이 있다.

Ⅲ. 내 용

1. 적합성의 원칙

행정작용을 하고자 할 때에는 이로 인하여 달성하고자 하는 목적에 적합하여야 한다는 원칙이다.

2. 필요성의 원칙(최소침해의 원칙)

행정목적의 달성에 적합한 다수의 수단이 있는 경우에, 행정기관은 상대방과 일반국민에 대하여 가장 적은 부담을 주는 수단을 선택해야 한다는 것이다.

3. 상당성의 원칙(협의의 비례원칙)

행정기관의 어떤 조치가 행정목적 달성을 위해 필요한 경우라고 하여도, 그 조치를 취함에 따른 불이익이 그 조치로 인해 발생하는 이익보다 큰 경우에는 그 조치를 취해서는 안된다는 것을 의미한다.

Ⅳ. 효과

비례의 원칙에 위반한 법률은 위헌이 되며, 이에 위반한 행정작용은 위법성이 인정된다.

위 원칙에 반하는 행정행위는 항고쟁송의 대상이 되며, 그로 인해 손해가 발생할 경우 국가의 손해배상책임을 발생시킨다.

제4 부당결부금지 원칙

Ⅰ. 의 의

부당결부금지 원칙은 행정작용을 함에 있어서 이와 실질적인 관련이 없는 상대방의 반대급부를 결부시켜서는 안된다는 원칙을 말한다.

Ⅱ. 근거 및 효력

① 부당결부금지원칙은 법치국가의 원칙과 무관하지 않지만 직접적인 근거는 권한법정주의와 권한남용금지의 원칙에 있다고 보면서 법률적 효력을 갖는 법원칙으로 보는 견해와 ② 부당결부금지원칙은 법치국가의 원리와 자의금지의 원칙으로부터 도출된다고 보면서 헌법적 효력을 갖는 원칙이라는 견해(다수설)가 대립한다. ③ 생각건대 법률의 내용이 부당결부금지원칙에 위반되는 경우 ①설에 따르면 해결할 방법이 없다. 따라서 ②설이 타당하다. ②설에 따르면 부당결부금지원칙에 위반된 법률은 위헌인 법률이며 그에 따른 처분도 위법한 처분이 된다.

Ⅲ. 요 건

1. 행정기관의 권한행사
예컨대, 부관부 행정행위의 경우 주된 행정행위가 그것이며, 새로운 의무이행확보수단에서는 공급거부나 관허사업의 제한(허가나 특허의 거부)등이 그것이다.

2. 행정청의 권한행사와 상대방의 반대급부와 결부 또는 의존되어 있을 것.
예컨대, 조건부 특허의 경우 조건의 성취와 특허가 결부되어 있다는 점 등이다.

3. 공권력의 행사와 반대급부사이에 실실적인 관련성이 없을 것.
실질적인 관련성의 의미에 대해서 다음 두 가지가 검토되고 있다.

⑴ 원인적 관련성
원인적 관련성은 행정작용과 상대방의 반대급부사이에는 직접적인 인과관계가 있을 때 정당한 내적 관계가 존재함을 의미한다.

⑵ 목적적 관련성
이는 행정권한의 수권목적의 범위 내에서 반대급부가 부과되어야 한다는 것을 말한다.

Ⅳ. 효과
부당결부금지의 원칙도 행정법의 일반원칙인 바, 부당결부금지원칙에 위반한 행정행위는 위법하게 된다. 따라서 부당결부금지의 원칙을 위반한 행정행위에 대하여 항고쟁송 및 그로인한 손해에 대하여 행정상 손해배상을 청구할 수 있다.
판례도 그 주택사업과는 아무런 관련이 없는 토지를 기부체납하도록 하는 부관을 주택사업계획승인에 붙인 경우 당해 부관 및 도로기부채납의무불이행을 이유로 한 건축물준공거부처분은 각 부당결부금지의 원칙에 위반되어 위법하다고 판시하였다.

제5 신뢰보호의 원칙

Ⅰ. 의 의
신뢰보호의 원칙이란 행정기관의 적극적 또는 소극적 행위의 정당성 또는 존속성에 대한 개인의 보호가치 있는 신뢰를 보호해 주는 원칙을 말한다.

Ⅱ. 근 거
법적 근거로 행정절차법 제4조, 국세기본법 제18조 제3항 등이 있다. 이론적 근거로 신의칙설과 법적 안정성설이 대립하나. 법적 안정성설이 다수설이고 타당하다.

Ⅲ. 요 건[11)]

11)「일반적으로 행정상의 법률관계에 있어서 행정청의 행위에 대하여 신뢰보호의 원칙이 적용되기 위하여는, 첫째 행정청이 개인에 대하여 신뢰의 대상이 되는 공적인 견해표명을 하여야 하고, 둘째 행정청의 견해표명이 정당하다고 신뢰한 데에 대하여 그 개인에게 귀책사유가 없어야 하며, 셋째 그 개인이 그 견해표명을 신뢰하고 이에 상응하는 어떠한 행위를 하였어야 하고, 넷째 행정청이 위 견해표명에 반하는 처분을 함으로써 그 견해표명을 신뢰한 개인의 이익이 침해되는 결과가 초래되어야 하며, 마지막으로 위 견해표명에 따른 행정처분을 할 경우 이로 인하여 공익 또는 제3자의 정당한 이익을 현저히

1. 행정청의 선행조치

법령·규칙·처분·확약·행정지도 등 모든 행정작용이 해당하며 명시적·적극적 언동뿐만 아니라 묵시적·소극적 언동도 해당한다.

다만, 판례는 행정기관의 선행조치를 행정기관의 공적인 견해표명으로 제한하고 있다. 이에 추상적 질의에 대한 일반론적인 견해표명이나 공무원의 사적인 견해표명은 선행조치에 포함시키지 않고 있다.

2. 보호가치 있는 신뢰

보호가치가 있는 신뢰는 상대방에게 고의 또는 과실, 즉 귀책사유가 없어야 하는 것을 의미한다. 상대방의 귀책사유로는 사기, 강박, 뇌물, 허위기재 등과 행정작용의 위법성에 대하여 알고 있었거나 중대한 과실로 알지 못한 경우이다.

3. 상대방의 조치

4. 인과관계

5. 선행조치에 반하는 행정작용

Ⅳ. 한계

신뢰보호의 한계는 ㉠ 사정변경, ㉡ 행정의 법률적합성의 원칙과의 관계 ㉢ 제3자 등과의 이익형량 등에서 발생한다. 위와 같은 경우 공익 또는 제3자의 이익이 상대방의 신뢰이익보다 더 큰 경우에는 신뢰보호원칙의 적용이 제한된다.

단 판례는 ‘ 위 견해표명에 따른 행정처분을 할 경우 이로 인하여 공익 또는 제3자의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 있는 경우가 아니어야 한다’를 신뢰보호원칙이 적용되기 위한 소극적 요건으로 보고 있으나 이는 이익형량문제로 한계문제로 보는 것이 타당하다.

Ⅴ. 효과

신뢰보호원칙도 행정법의 일반원칙인 바, 신뢰보호원칙에 위반한 행정행위는 위법하게 된다. 따라서 신뢰보호원칙을 위반한 행정행위에 대하여 항고쟁송 및 그로인한 손해에 대하여 행정상 손해배상을 청구할 수 있다.

제6 신의성실의 원칙

Ⅰ. 의의

신의성실의 원칙은 모든 사람은 공동체의 일원으로서 상대방의 신뢰를 헛되이 하지 않도록 성의있게 행동하여야 한다는 원칙이다. 신의성실원칙은 민법만의 원칙이 아니며 모든 법의 일반원칙이다. 따라서 신의성실의 원칙은 행정법의 일반원칙이기도 하다.

Ⅱ. 법적근거

행정절차법 제4조 제1항, 국세기본법 제15조[12] 등.

해할 우려가 있는 경우가 아니어야 한다」(대판 2001. 9. 28, 2000두8684; 대판 2002. 11. 8, 2001두1512).

12) “제15조 (신의·성실) 납세자가 그 의무를 이행할 때에는 신의에 따라 성실하게 하여야 한다. 세무공무원이 직무를 수행할 때에도 또한 같다.”

Ⅲ. 적용요건

① 상대방에게 신의를 주었거나 상대방이 그러한 신의를 가짐이 정당한 상태에 이르러야 하고, ② 상대방의 신의에 반하여 권리를 행사하는 것이 정의관념에 비추어 용인될 수 없어야 한다. 즉, 합법성의 원칙을 희생하여서라도 상대방의 신뢰를 보호함이 정의의 관념에 부합하는 것으로 인정되어야 한다.

Ⅳ. 적용영역

신의성실의 원칙이 직접 행정행위의 위법의 근거가 되는 경우는 많지 않으나, 예컨대 행정청이 허가신청을 수리하고도 정당한 이유 없이 처리를 늦추어 그 사이에 법령 및 허가기준이 변경된 경우 행정청이 변경된 법령 및 허가기준에 따라 한 불허가처분은 신의성실원칙위반으로 위법하다고 볼 수 있다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 평등의 원칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 대법원은 유예기간 없이 개인택시운송면허기준을 변경하고 그에 기하여 면허신청을 거부한 처분은 신뢰보호원칙에는 반하지 않지만 평등의 원칙에는 반한다고 판시하였다.
② 평등의 원칙은 우리 헌법이 명문으로 규정한 원칙으로서 재량권행사의 한계원리로 중요한 의미를 갖는다.
③ 행정법의 일반법원칙으로서 평등의 원칙은 행정작용에 있어서 특별한 합리적 사유가 없는 한 행정객체인 국민을 공평하게 처우하여야 한다는 원칙을 말한다.
④ 대법원은 동일한 징계사유(당직근무 대기 중 화투놀이를 한 사실)에 대해서 3명은 견책을 하고 1명에 대해서는 파면을 한 것은 평등(공평)의 원칙에 반하는 것이라고 판시하였다.
⑤ 행정관청이 이룩되게 되면, 평등의 원칙이나 신뢰보호의 원칙에 따라 행정기관은 그 상대방에 대한 관계에서 그 규칙에 따라야 할 자기구속을 당하게 되고, 그러한 경우에는 대외적인 구속력을 가지게 된다 할 것이다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 매년 그때의 상황에 따라 적절히 면허 숫자를 조절해야 할 필요성이 있는 개인 택시면허제도의 성격상 그 자격요건이나 우선순위의 요건을 일정한 범위 내에서 강화하고 그 요건을 변경함에 있어 유예기간을 두지 아니하였다 하더라도 그러한 점만으로는 행정청의 면허신청접수거부처분이 신뢰보호의 원칙이나 형평의 원칙, 재량권의 남용에 해당하지 아니한다(대판 1996.7.30, 95누12897).
④ 대판 1972.12.26, 72누194
⑤ 헌재 1990.9.3, 90헌마13

정답 ①

2. A행정청은 법위반행위에 대한 재제처분기준과 관련하여 '제재금산정방법 및 부과기준을 부령으로 작성하여 이를 관보 및 인터넷상에 공표하였다. 그 후에 당해 행정청은 위 기준에 의거하여 甲에게 500만원의 제재금을 부과하였다. 그런데 당해 행정청은 동일하게 법위반을 한 乙에 대해서는 위 제재금산정기준에도 불구하고 근거법률에서 정한 범위에서 800만원의 제재금을 부과하였다. 이런 사정을 알게 된 乙이 자신에 대한 제제금부과처분의 위법성을 주장하고 있는데 이와 관련된 다음의 설명 중 타당하지 않은 것은? (제49회 행정고시 2차 문제 변형)

① 사안의 부령형식의 재량준칙은 판례의 태도에 의할 경우 대외적 구속력이 인정되지 않는다.

② 판례의 태도에 의할 경우 제재금 부과처분은 재량행위에 해당된다.
③ 재량권 일탈남용 여부 판단기준으로 문제되는 자기구속의 법리를 헌법재판소는 명시적으로 인정하고 있고, 대법원은 자기구속의 법리를 인정하는 취지의 판시를 하고 있다.
④ 자기구속의 법리가 적용되기 위해서는 ㉠ 재량의 영역일 것, ㉡ 동종의 사안일 것, ㉢ 선례가 존재할 것 등을 요하는데 사안은 ㉠, ㉡요건은 충족되나, ㉢의 요건과 관련하여 판례가 부령형식의 재량준칙을 행정규칙으로 봄으로 자기구속의 법리의 위배가 있을 수 없다.
⑤ 자기구속의 법리의 적용한계는 사안에 존재하지 않는다.

해설 & 정답

유형 사례형

① 대법원은 "식품위생법시행규칙 제53조에서 별표 15로 같은 법 제58조에 따른 행정처분의 기준을 정하였다 하더라도, 이는 형식은 부령으로 되어 있으나 성질은 행정기관 내부의 사무처리준칙을 규정한 것에 불과한 것으로서 보건사회부장관이 관계행정기관 및 직원에 대하여 직무권한행사의 지침을 정하여 주기 위하여 발한 행정명령의 성질을 가지는 것이지 같은 법 제58조 제1항의 규정에 의하여 보장된 재량권을 기속하는 것이라고 할 수 없고, 대외적으로 국민이나 법원을 기속하는 힘이 있는 것은 아니다(대판 1993.6.29, 93누5635)"라고 판시하여 법규명령형식의 재량준칙의 법적 성질에 대해서 행정규칙설의 태도를 취하였다.
② 문제 설문에서 근거법률에서 정한 범위에서 800만원의 제재금을 부과하였다고 적혀 있으므로 근거 법률에서 일정한 재량을 명시적으로 인정하고 있다고 보이므로 부과처분은 재량행위가 된다.
③ 헌법재판소는 평등의 원칙과 신뢰보호원칙에 따라 자기구속의 원칙을 인정하고(헌재 1990.9.3, 90헌마13), 대법원은 명시적인 근거를 밝히지 않고는 있으나 자기구속의 법리를 일반적인 재량권 행사의 한계로 인정하고 있다(대판 2009.6.25, 2008두13132).
④ 대법원은 "같은법시행규칙 제53조에 따른 별표 15의 행정처분기준은 행정기관 내부의 사무처리준칙을 규정한 것에 불과하기는 하지만 규칙 제53조 단서의 식품 등의 수급정책 및 국민보건에 중대한 영향을 미치는 특별한 사유가 없는 한 행정청은 당해 위반사항에 대하여 위 처분기준에 따라 행정처분을 함이 보통이라 할 것이므로, 행정청이 이러한 처분기준을 따르지 아니하고 특정한 개인에 대하여만 위 처분기준을 과도하게 초과하는 처분을 한 경우에는 재량권의 한계를 일탈하였다고 볼 만한 여지가 충분하다(대판 1993.6.29, 93누5635)"라고 판시하여 이 판례의 해석과 관련하여 쟁송상 위법성 추정설은 원칙적으로 재량권의 일탈·남용에 대한 입증책임은 쟁송법상 원고에게 있으나, 행정규칙에 위반한 처분임을 원고가 입증한다면 특별한 사정이 없는 한 재량권행사의 일탈·남용을 쟁송상 추정하여 피고 행정청의 반대 입증이 없는 경우 행정법상 일반원칙(비례 또는 평등원칙)에 위반되어 위법하게 된다. 위법성 추정설에 의할 경우에는 행정규칙 위반이 있어서 자기구속위반이 인정되어 쟁송상 비례원칙 및 평등원칙의 위반이 추정되어 입증책임이 전환되어 행정청이 일탈·남용이 없음을 입증하지 못하는 한 당해 처분은 위법하게 된다. 판례의 문구에 의할 경우에도 처분기준인 500만원보다 과다한 800만원을 부과하였으므로 재량권의 한계를 일탈하였다고 할 수 있으므로 부과처분은 위법하게 된다.
⑤ 자기구속의 법리의 적용 한계로 ㉠ 중대한 사정 변경, ㉡ 불법의 선례 등이 있는데 사안에는 중대한 사정 변경도 불법의 선례도 존재하지 않는다.

정답
④

3. 행정의 자기구속의 원칙에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? (2005 관세사)

① 동 원칙은 간혹 행정의 탄력적인 운용에 저해를 가져올 수 있다.
② 동 원칙은 평등원칙을 근거로 한다.
③ 동 원칙은 재량권행사에 있어서 행정권의 자의방지의 의미를 갖는다.
④ 동 원칙에 위반된 행위는 위법한 행위가 아니라 부당한 행위가 된다.
⑤ 동 원칙은 부담적 행위에도 적용될 수 있다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

자기구속의 원칙은 평등원칙에 근거한 헌법원리로서 위반시 부당이 아니라 위헌·위법이 된다.

정답 ④

♣ 학습내용 정리

1. 평등원칙은 합리적 차별사유없는 경우의 차별금지를 의미한다.
2. 자기구속원칙은 행정의 자유영역에서 선행관행과 동일한 사안에서는 선행관행과 동일하게 하여야 한다는 원칙이다.
3. 비례원칙은 적합성, 필요성, 상당성 원칙으로 구성되면 단계적 구조를 이룬다.
4. 부당결부금지원칙은 실질적 관련성이 없는 것을 결부시켜서는 안된다는 원칙을 말한다.
5. 신뢰보호원칙은 공무원의 선행조치에 대하여 국민에게 신뢰가 형성된 경우 선행조치에 반하는 조치를 하지 말아야 한다는 원칙이다.
6. 신의성실원칙은 특히 정당한 사유없이 처리를 지연하다 법령이 개정되어 개정된 법령을 적용한 경우에 적용된다.

제3강 행정법의 효력 및 행정법관계

♣ 학습목표

행정법 중 성문법이 언제부터 법으로서 효력을 발생하고 소멸하는지 검토하고 이미 완료된 사실에 대한 소급을 금지하는 소급금지원칙에 대하여 설명할 수 있다.

공법관계와 사법관계의 구별기준과 구별실익 및 행정상 법률관계의 종류와 행정법관계의 당사자로서 행정주체에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

행정법의 시행일과 소멸일
소급금지원칙
공법관계와 사법관계의 구별기준과 구별실익
행정주체

♣ 사전테스트

1. 행정법의 시행일은 부칙에서 정한 바 없으면 공포 후 30일 이후이다.
   정답 : ×

2. 부진정소급입법도 원칙적으로 소급입법금지원칙위반으로 위헌이다.
   정답 : X

3. 이미 완료된 사실에 대하여 소급적용하도록 규정한 법령을 진정소급입법이라 한다.
   정답 : ○

♣ 돌발퀴즈

「5·18 민주화운동 등에 관한 특별법」 제2조가 부진정소급효를 갖는 경우에만 법적 안정성과 신뢰보호의 원칙을 포함하는 법치주의 정신에 위반되거나 평등의 원칙에 위배되지 않는다.

[정답] ×

[해설] 이 사건 반란행위 및 내란행위자들은 우리 헌법질서의 근간을 이루고 있는 자유민주적 기본질서를 파괴하였고, 그로 인하여 우리의 민주주의가 장기간 후퇴한 것은 말할 것도 없고, 많은 국민의 그 생명과 신체가 침해되었으며, 전 국민의 자유가 장기간 억압되는 등 국민에게 끼친 고통과 해악이 너무도 심대하여 공소시효의 완성으로 인한 이익은 단순한 법률

적 차원의 이익이고, 헌법상 보장된 기본권적 법익에 속하지 않는 반면, 집권과정에서 헌정질서파괴범죄를 범한 자들을 응징하여 정의를 회복하여 왜곡된 우리 헌정사의 흐름을 바로 잡아야 할 뿐만 아니라, 앞으로는 우리 헌정사에 다시는 그와 같은 불행한 사태가 반복되지 않도록 자유민주적 기본질서의 확립을 위한 헌정사적 이정표를 마련하여야 할 공익적 필요는 매우 중대한 반면, 이 사건 반란행위자들 및 내란행위자들의 군사반란죄나 내란죄의 공소시효완정으로 인한 법적 지위에 대한 신뢰이익이 보호받을 가치가 별로 크지 않다는 점에서, 이 법률조항은 위 행위자들의 신뢰이익이 보호받을 가치가 별로 크지 않다는 점에서, 이 법률조항은 위 행위자들의 신뢰이익이나 법적 안정성을 물리치고도 남을 만큼 월등히 중대한 공익을 추구하고 있다고 평가할 수 있어, 이 법률조항이 위 행위자들의 공소시효완성에 따르는 법적 지위를 소급적으로 박탈하고, 그들에 대한 형사소추를 가능하게 하는 결과를 초래하여 그 합헌성 인정에 있어서 엄격한 심사기준이 적용되어야 한다고 하더라도, 이 법률조항은 헌법적으로 정당화된다고 할 것이다(헌재 1996.2.16, 96헌가2・96헌바7・96헌바13).

♣ 강의내용

제1 행정법의 효력

행정법의 효력이란 행정법이 그 관계자를 구속하는 힘을 말한다. 성문행정법은 그 효력범위에 있어 시간적·지역적·대인적 한계가 있다.

Ⅰ. 시간적 효력

1. 효력발생시기

⑴ 공포 - 관보 또는 일간신문에 게재

⑵ 공포일 - 최초구독가능시설

⑶ 시행일

성문법은 부칙(성문법 맨 끝에 규정되어 있음)에서 그 시행일에 관하여 특별한 규정이 없으면 공포한 날로부터 20일을 경과함으로써 효력을 발생한다. 다만, 국민의 권리제한 또는 의무부과와 직접 관련되는 법령 등은 공포일로부터 원칙적으로 30일이 경과한 후에 시행하도록 되어 있다(그런데 대부분 부칙에서 시행일을 정하고 있다).

제2 법령개정과 신뢰보호

Ⅰ. 소급입법금지원칙

1. 의의

소급입법금지의 원칙이란 법령을 이미 종결된 사실관계 또는 법률관계에 적용하는 것으로 입법하는 것을 금지하는 헌법원칙을 말한다. 소급입법금지원칙은 개인의 신뢰보호와 법적 안정성을 내용으로 하는 법치국가원리에 근거한 헌법적 효력을 갖는다.

2. 소급입법의 종류 및 위헌여부

소급입법에는 이미 종결된 사실관계 또는 법률관계에 소급적용하도록 하는 진정소급입법과 아직 종결되지 않은 사실관계 또는 법률관계에 소급적용하도록 하는 부진정소급입법이 있다.

3. 구체적인 경우

⑴ 진정소급입법

진정소급입법은 원칙적으로는 소급입법금지원칙위반으로 위헌이나 예외적으로 i) 국민이 소급입법을 예상할 수 있었거나, ii) 신뢰보호 요청에 우선하는 심히 중대한 공익상 사유가 소급입법을 정당화하는 경우 및 iii) 진정소급입법이 국민에게 유리한 경우에는 합헌으로 인정한다.

⑵ 부진정소급입법

부진정소급입법은 아직 완료되지 않은 사실에 적용되므로 원칙적으로 합헌이나, 예외적으로 그로 인해 침해되는 신뢰이익이 부진정소급입법을 통해 달성하고자 하는 공익보다 더 크면 헌법상 신뢰보호원칙위반으로 위헌이다.

제3 공법관계와 사법관계

Ⅰ. 개 설

1. 문제점

우리나라는 영미법계와는 다르게 공법과 사법의 이원적 구조를 취하고 있으므로 그 구별이 필요하다.

2. 구별실익

⑴ 적용법규

공법관계에서는 원칙적으로 공법만이 법으로 적용되고 사법관계에서는 원칙적으로 사법만이 법으로 적용된다. 따라서 국가와 국민간에 체결된 철거계약이 평등원칙이라는 공법에 위반된 경우 위 철거계약이 공법상 계약이면 위법한 계약이 되고, 사법상 계약이면 적법한 계약이 된다.

⑵ 재판관할 및 재판절차의 결정기준

행정주체와 행정객체간에 공법관계에 대한 다툼이 생긴 경우에는 행정소송법이 정한 절차에 따라 행정법원에 행정소송을 제기하나, 대등한 사인 상호간에 사법관계에 대한 다툼이 생긴 경우에는 민사소송을 제기하여야 한다.

⑶ 행정강제 - 공법상 의무불이행시 행정주체가 강제력(자력강제, 제재력)가능 / 사법상 의무불이행시 자력강제불가

Ⅱ. 구별기준

1. 학 설

주체설, 이익설, 성질설 등이 대립.

2. 검 토

공사법관계의 구분은 논리 필연의 소산이 아니고 각국에 특유한 정치적 현실적 고려의 소산이며 어떠한 이론에도 경계선상의 문제가 남으므로, 위에서 논의한 모든 학설을 종합적으로 고려하여 판단하는 것이 타당할 것이다.

이러한 기준에 의할 때, 공법관계라고 하기 위해서는 우선 한쪽 당사자가 행정주체여야 하고 공익을 목적으로 하여야 한다. 다음으로 그 행위의 근거로 된 법령이 행정주체에게 사법상 용인되지 않는 우월적 지위가 인정하는 경우이어야 할 것이다.

Ⅲ. 공법관계와 사법관계의 구별방법

1. 명문의 규정이 있는 경우

실정법이 행정상 강제집행, 행정벌, 행정상 손해배상, 손실보상, 행정쟁송, 형법상 공무원에 관한 죄(수뢰죄 등)의 성립을 인정하는 명문의 규정을 두고 있는 경우에는 그 법에 의하여 발생된 법률관계는 공법관계로 보아야 할 것이다.

2. 명문의 규정이 없는 경우

실정법이 위와 같은 명문의 규정을 두고 있지 아니한 경우에는 부득이 공법과 사법의 구별필요성에 비추어 위 학설을 종합적으로 고려하여 공법관계 또는 사법관계를 결정하여야 한다.

제4 행정상 법률관계의 종류

Ⅰ. 서 설

국가 등과 국민간의 법률관계를 말한다.

Ⅱ. 행정조직법적 관계 - 권한관계

Ⅲ. 행정작용법관계

1. 공법관계(행정법관계)

⑴ 권력관계

권력관계란 국가 기타의 행정주체가 우월적 지위에서 행정객체에게 공권력을 행사하는 관계를 말한다. 권력관계를 총론적으로 규율한 것이 행정행위(행정처분)이다. 따라서 행정법상 여러 가지 특수한 법률효과를 인정하고 있는 권력관계는 전형적인 행정행위의 법률관계와 일치한다.

효력상의 특질로는 1)구속력, 2)공정력 및 구성요건적 효력, 3)확정력(불가쟁력과 불가변력), 4)강제력(자력집행력과 제재력) 등을 들 수 있다.

⑵ 단순권력관계(비권력관계)

단순권력관계는 행정이 그 책무를 실현하기 위하여 공법에 근거하여 활동하지만 권력행정의 규율수단에 의하지 아니하고 행정작용을 하는 관계이다. 공법상계약(공중보건의채용계약)이나 행정지도(시정권고) 등의 사실행위가 주로 이에 해당한다.

2. 행정상의 사법관계

행정기관이 사법적인 수단을 사용하여 활동하는 법률관계를 의미하며, 행정상의 사법관계는 행정주체가 직접적인 행정목적을 달성하기 위하여 활동하는가의 여부에 따라 다시 국고관계와 행정사법으로 나누어진다.

제5 행정법관계의 당사자

Ⅰ. 행정주체와 행정청의 구별

1. 행정주체 - 공법에 의해 공법작용하는 人

행정법관계에 있어 행정청의 권한행사의 법적 효과, 즉 권리의무가 궁극적으로 귀속되는 당사자(人)를 행정주체라고 한다(예컨대 서울시장이 갑이라는 서울시민에게 천만원 지방세부과처분을 한 경우 그에 따라 갑으로부터 천만원을 받을 수 있는 권리는 서울시장이 아닌 서울시에게 귀속된다).

행정주체와 행정기관은 구분되어야 한다. 행정주체는 권리의무가 자신에게 귀속되는데 반하여, 행정기관은 행정주체를 위해 권한을 행사하고 그 권한행사에 따른 법적 효과가 행정주체에게 귀속된다는 점에서 양자의 차이가 있다(즉, 행정기관은 人이 아니므로 권리의무를 가질 수 없다).

2. 행정청

국가와 지방자치단체의 행정에 관한 의사를 결정하고 이를 외부에 표시할 수 있는 권한을 가진 행정기관이다(조직법상 의미의 행정청).

Ⅱ. 행정주체

1. 국 가

국가는 시원적 행정주체이다. 우리 헌법상 대통령은 행정수반이기 때문에 행정권은 대통령을 정점으로 하는 국가행정조직을 통하여 행사된다.

2. 공공단체

⑴ 지방자치단체

지방자치단체는 국가의 영토의 일부를 자기구역으로 해서 구역 내 주민을 국법이 허용하는 범위에서 지배하는 공법인이다. 지방자치단체는 구역과 주민을 가진다. 이점에서 기타 공법상 법인과 구별된다.

이러한 지방자치단체는 크게 보통지방자치단체(광역지방자치단체인 특별시, 광역시, 특별자치시, 도, 특별자치도와 광역지방자치단체에 소속된 기초 지방자치단체로서 시·군·자치구)와 특별지방자치단체(지방자치단체조합)이 있다.

⑵ 공법상 사단(공공조합)

특정한 행정목적을 위해 일정한 자격을 가진 사람의 결합체에 공법상 법인격이 부여된 것으로, 이에는 농지개량조합·도시재개발조합·상공회의소·변호사회·각종 공단(근로복지공단, 공무원연금관리공단 등) 등이 있다.

⑶ 영조물법인

일정 행정목적 달성을 위해 설립된 인적 물적시설의 결합체로서 공법상 법인격이 부여된 것으로, 서울대학병원, 적십자병원, 과학기술원 등이 있다.

⑷ 공법상재단

국가 지자체의 출연재산을 관리하기 위해 설립된 재단법인인 공공단체로, 한국학술진흥재단·한국정신문화연구원 등이 있다.

3. 공무수탁사인 : 후술함

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 법령의 효력에 관한 설명 중 옳은 것은? (2006 관세사)

① 모든 법령은 관보에 게재하여 공포하므로 관보를 최초로 구독 가능한 시점부터 효력을 발생한다.

② 법령은 시행일로부터 장래에 향하여 효력을 발생하며, 어떠한 경우에도 시행일 이전으로 소급적용하는 것은 금지된다.

③ 시행일 이전부터 계속되는 사실에 대한 이른바 부진정소급효는 허용된다는 것이 판례의 입장이다.

④ 부과된 조세가 납부되지 않고 있는 동안 그 조세의 근거 법규가 개정되어 당해 부과세목이 폐지된 경우에는 종전의 규정에 의하여 징수할 수 없다는 것이 판례·학설의 일치된 견해이다.

⑤ 법률이 개정되면 구법에 따른 집행명령도 소멸하므로, 새로운 집행명령이 제·개정되지 않은 동안에는 신법이 시행될 수 없다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 대통령령·총리령 및 부령은 특별한 규정이 없는 한 공포한 날로부터 20일을 경과함으로써 효력을 발생한다(법령등공포에관한법률 제13조). 조례와 규칙은 특별한 규정이 없는 한 공포한 날로부터 20일을 경과함으로써 효력을 발생한다(지방자치법 제26조 제7항). 그러나 행정규칙은 수명기관에 도달한 날부터 효력을 발생한다.

② 진정소급효의 경우에도 법령을 소급적용하더라도 일반국민의 이해에 직접 관계가 없는 경우, 오히려 그 이익을 증진하는 경우, 불이익이나 고통을 제거하는 경우 등의 특별한 사정이 있는 경우에 한하여 예외적으로 법령의 소급적용이 허용된다(대판 2005.5.13, 2004다8630).

③ 부진정소급효의 경우는 소급입법금지원칙의 적용이 없으므로 원칙적으로 허용된다.

④ 부과된 조세가 납부되지 않고 있는 동안 그 조세의 근거 법규가 개정되어 당해 부과세목이 폐지된 경우에는 종전의 규정에 의하여 징수할 수 있다(대판 1993.5.11, 92누18399).

⑤ 법률이 폐지되면 집행할 필요가 없으므로 집행명령이 실효되지만, 법률이 개정됨에 그칠 경우에는 여전히 집행의 필요가 있으므로 집행명령도 실효되지 않고 존속한다. 또한 법률은 특별한 규정이 있으면 그 기간이 경과한 후, 특별한 규정이 없으면 공포한 날로부터 20일이 경과하면 시행할 수 있는 것이지, 집행명령이 제정되어야 시행할 수 있는 것은 아니다.

정답 ③

2. 다음 설명 중 옳은 것은?

① 영주권을 가진 재일동포는 준외국인으로 보아 외국인토지법을 준용하여야 한다.

② 헌법재판소의 위헌결정은 장래효주의를 취하고 있다는 것이 헌법재판소법과 우리 대법원의 입장이다.

③ 국민의 기득권에 영향을 주거나 국민에게 권리이익을 부여하는 것인 때에도 소급할 수 없다.
④ 개정법령의 시행일 이전에 사실관계가 이미 발생하였다면 그 종료 여부와 관계없이 개정법령을 적용하는 것은 소급적용으로 위법하다.
⑤ 장애등급결정에 있어서는 등급결정시가 아니라 장애급여지급시의 법령을 적용한다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 대한민국 국민이 일본국에서 영주권을 취득하였다 하여 우리 국적을 상실하지 아니하며, 영주권을 가진 재일교포를 준외국인으로 보아 외국인토지법을 준용하여야 하는 것도 아니다(대판 1981.10.13, 80다2435).

② 헌법재판소법 제47조 제2항은 "위헌으로 결정된 법률 또는 법률의 조항은 그 결정이 있는 날로부터 효력을 상실한다. 다만, 형벌에 관한 법률 또는 법률의 조항은 소급하여 그 효력을 상실한다"고 규정함으로써 원칙적으로 장래효를 취하고 있다. 그러나 대법원은 "헌법재판소의 위헌결정의 효력은 위헌제청을 한 당해 사건, 위헌결정이 있기 전에 이와 동종의 위헌 여부에 관하여 헌법재판소에 위헌여부심판제청을 하였거나 법원에 위헌여부심판제청을 한 동종사건과 따로 위헌제청신청은 아니하였지만 당해 법률 또는 법률 조항이 재판의 전제가 되어 법원에 계속 중인 병행사건뿐만 아니라, 위헌결정 이후에 위와 같은 이유로 제소된 일반사건에도 미친다고 할 것이나, 위헌결정의 효력은 그 미치는 범위가 무한정일 수는 없고 다른 법리에 의하여 그 소급효를 제한하는 것까지 부정되는 것은 아니라 할 것이며, 법적 안정성의 유지나 당사자의 신뢰보호를 위하여 불가피한 경우에 위헌결정의 소급효를 제한하는 것은 오히려 법치주의의 원칙상 요청되는 바라 할 것이다(대판 2005.11.10, 2005두7570)"라고 판시함으로써 소급효를 넓게 인정한다. 다만, 대법원은 "이미 취소소송의 제기기간을 경과하여 확정력이 발생한 행정처분의 경우에는 위헌결정의 소급효가 미치지 않는다(대판 2002.11.8, 2001두3181)"라고 판시함으로써 불가쟁력이 발생한 행정처분에는 위헌결정의 소급효를 부정한다.

③ 진정소급입법은 원칙적으로 부정되지만, 국민에게 유리한 경우나 혁명적인 상황에서는 예외적으로 허용된다는 것이 다수설・판례이다.

④ 개정법령 시행 전에 발생한 사실관계라 하더라도 개정시 종료되지 않고 계속 진행 중인 사실관계에 적용하는 부진정소급효는 원칙적으로 허용된다.

⑤ 산업재해보상보험법상 장해급여는 근로자가 업무상의 사유로 부상을 당하거나 질병에 걸려 치료를 종결한 후 신체 등에 장해가 있는 경우 그 지급사유가 발생하고, 그때 근로자는 장해급여지급청구권을 취득하므로, 장해급여지급을 위한 장해등급결정 역시 장해급여지급청구권을 취득할 당시, 즉 그 지급사유 발생 당시의 법령에 따르는 것이 원칙이다. 개정된 산업재해보상보험법 시행령의 시행 전에 장해급여지급청구권을 취득한 근로자의 외모의 흉터로 인한 장해등급을 결정함에 있어, 위 개정이 위헌적 요소를 없애려는 반성적 고려에서 이루어졌고 이를 통하여 근로자의 균등한 복지증진을 도모하고자 하는 데 그 취지가 있으며, 당해 근로자에 대한 장해등급 결정 전에 위 시행령의 시행일이 도래한 점 등에 비추어, 예외적으로 위 개정 시행령을 적용하여야 한다(대판 2007.2.22, 2004두12957).

정답 ⑤

3. 다음 중 소급효금지원칙에 반하는 것은? (2001 입법고시)

① 1999년 10월 1일의 법률로 1998년도의 세율을 인상
② 1999년 10월 1일의 법률로 외국부동산 소유에 대하여 과세하면서, 그 이전에 취득한 경우에도 과세를 하되 2000년 1월 1일 이후부터 과세
③ 1999년 10월 1일의 법률로 1999년도의 세율을 인상
④ 1999년 3월 1일에 입학한 학생에 대하여 1999년 6월 1일 개정된 학칙을 적용하여 1999년 6월 19일 시행한 1학기말 시험성적불량을 이유로 1999년 8월 징계
⑤ 환경규제를 위한 시설 기준을 강화하면서, 기존에 허가를 받아 운영하고 있는 공장에 대하여도 새로이 강화된 기준을 적용

해설 & 정답

유형 준사례형

① 새로운 입법으로 이미 종료된 사실관계에 작용케 하는 진정소급입법은 헌법적으로 허용되지 않는 것이 원칙이며 특단의 사정이 있는 경우에만 예외적으로 허용한다(헌재 1998.11.26, 97헌바 58). 설문의 경우 1999년 10월 1일을 기준으로 할 경우 1998년도의 세금은 과거에 종결된 사실에 적용하는 진정소급효이기 때문에 허용되지 않는다.

②③④⑤ 부진정소급효이기 때문에 원칙적으로 허용된다.

정답 ①

♣ 학습내용 정리

1. 성문행정법의 효력은 부칙에서 달리 정한 바가 없으면 공포한 날로부터 20일 후에 발생한다.
2. 이미 완료된 사실에 대하여 소급적용하는 진정소급입법은 원칙적으로 금지되고 아직 완료되지 않은 사실에 대하여 적용되는 부진정소급입법은 원칙적으로 허용된다.
3. 공법관계와 사법관계의 구별실익으로 적용법리, 쟁송절차, 강제력 등이 있다. .
4. 공법관계와 사법관계의 구별기준으로 주체설, 이익설, 성질설, 신주체설 등이 대립하나 현재 일반적 견해는 위 학설을 모두 종합하여 판단하고 있다.
5. 행정상 법률관계에는 행정법관계로서 권력관계, 비권력행정관계가 있고 사법관계로서 행정사법관계와 협의의 국고관계가 있다.
6. 행정법관계의 당사자로서 행정주체에는 국가, 공공단체, 공무수탁사인이 있다.

제4강 개인적 공권

♣ 학습목표

국민이 국가 등 행정주체에 대하여 가지는 공권의 의의 및 공권의 성립요건으로서 강행법규성과 사익보호성의 의미에 대하여 설명할 수 있다.

공권의 확대화 경향을 이해하고 무하자재량행사청구권과 협의의 행정개입청구권에 대해 구별하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

개인적 공권의 의의
공권의 성립요건으로서 강행법규성과 사익보호성
공권의 확대화 경향
무하자재량행사청구권과 협의의 행정개입청구권

♣ 사전테스트

1. 국민에게는 공권이 성립될 수 없다.
   정답 : ×

2. 공권과 반사적 이익의 구별기준은 강행법규성이다.
   정답 : X

3. 공권은 점차 확대되어 가고 있다.
   정답 : ○

♣ 돌발퀴즈

헌법규정만을 근거로 하는 기본권도 권리보호의 소구가 가능한 것은 개인적 공권이라고 할 수 있다.

[정답] ×

[해설]기본권고려설에 의하면 헌법에 의한 개인적 공권의 성립이 가능하다. 다만 기본권의 성격상 자유권·평등권·재산권은 직접 개인적 공권이 성립가능하나, 청구권적 기본권은 구체적 현실적 권리로 보기 어려워 개인적 공권이 성립된다고 보기는 어렵다. 판례는 환경권에 관한 규정만으로는 원고적격을 인정하기 어렵다고 한 바 있다(대판 2006.3.16, 2006두330). 헌재는 법률상 이익으로 기본권인 경쟁의 자유를 들기도 하였다(헌재 1998.4.30, 97헌마141).

♣ 강의내용

제1 행정법관계의 내용

Ⅰ. 국가적 공권

Ⅱ. 개인적 공권

Ⅲ. 공의무

제2 행정법관계에서의 개인적 공권

Ⅰ. 의 의

개인이 자기의 이익을 위해 국가 등에 일정한 행위를 요구할 수 있는 공법상 개인에게 부여되어 있는 법적인 힘이다.

Ⅱ. 공권의 성립요건

1. 강행법규[13]에 의한 의무부과

2. 강행법규의 사익보호성

강행법규에 의하여 행정주체에게 일정한 법적 행위의무가 부과되어 있고 그러한 법규의 목적·취지가 적어도 특정된 범위의 사인의 이익도 보호하고자 하는 경우에만 당해 이익은 공권으로 인정된다. 이에 반하여 당해 법규의 목적·취지가 전적으로 공익추구에 있는 때에는 그로부터 개인이 일정한 이익을 받더라도 그것은 법규가 공익목적을 위하여 행정주체에게 의무를 부과한 반사적 효과로서 받는 이른바 반사적 이익에 불과하다.

Ⅲ. 공권과 반사적 이익

1. 반사적 이익의 의의

반사적 이익이란 행정법규가 공익목적을 위하여 국가나 개인의 작위, 부작위의무 등을 규정하고 있는 결과 그 반사적 효과로서 국민이 사실상 받는 것에 불과한 이익을 말한다. 이는 그 침해의 경우에도 소송에 의하여 보호를 받지 못한다는 점에서 공권과 구별된다.

2. 공권과 반사적 이익의 구별의 실익

공권이 침해된 자는 행정소송에서 원고적격(취소소송을 제기할 자격, 행정소송법 제12조 제1문 법률상 이익)이 인정되지만 반사적 이익이 침해된 자는 원고적격이 인정되지 않는다. 원고적격은 소송요건이므로 원고적격이 인정되지 않는 경우는 당해 소송은 부적법 각하된다.

3. 양자의 관계

⑴ 공통점 : 강행법규의 존재

---

13) 대내적 구속력과 대외적 구속력이 모두 있는 협의의 행정법의 법원(협의의 법규)을 의미한다.

⑵ 차이점

1) 사익보호성의 인정

2) 원고적격의 인정

⑶ 양자의 접근 : 공권의 확대화 현상

1) 등장배경

2) 새로운 공권의 등장(강행법규성 확대)

최근에는 무하자재량행사청구권, 협의의 행정개입청구권 및 행정과정의 절차적 권리(주민참여) 등이 새롭게 논의되고 있다.

3) 사익보호성의 확대 - 제3자 공권인정

㈎ 해석에 의한 확대

㈏ '근거법률의 범위'확대

근거법규의 범위를 직접적인 요건규정에 국한시키지 않고 처분을 함에 있어서 적용되는 관련 법규까지 포함시키고, 마지막으로 위와같은 방법으로도 제3자에게 법률상 이익이 인정되지 않는 경우로서 제3자의 이익침해가 중대하고 참을 수 없을 정도에 이른다면 예외적으로 헌법상 기본권조항에 직접 근거하여 제3자는 공권을 가질 수 있다는 견해가 있다.

판례는『당해 처분의 근거법률에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익』을 법률상 이익으로 보면서, 종전에 비해 관계법률의 취지를 목적론적으로 새김으로써 인근주민의 원고적격을 너그럽게 인정하려는 태도를 보이고 있다(연탄공장설치허가취소소송사건). 또한 처분의 직접적인 근거규정뿐만 아니라 처분시 준용되는 규정을 근거법률에 포함시키고(공설화장장설치허가취소소송사건),[14] 처분의 실체법적 근거법률 이외에 처분을 함에 있어서 적용되는 절차법규정의 취지에 비추어 원고의 법률상 이익을 인정하였으며(국립공원개발사업시행허가처분 등 취소소송사건), 처분의 근거법규 및 관련법규의 취지에 비추어 처분전과 비교하여 수인할 수 없는 환경피해를 받거나 받을 우려가 있는 환경영향평가대상지역외의 인근주민들에게 원고적격을 인정하는 등[15], 근거법률의 범위를 확대하는 경향을 보이고 있다.

다만, 대법원은 환경영향평가 대상지역도 아닌데다가 공유수면매립면허처분 등으로 인하여 그 처분 전과 비교하여 수인한도를 넘는 환경피해를 받거나 받을 우려가 있다는 점을 입증하지 못한 제3자에게 헌법상 환경권을 근거로 원고적격을 인정할 수는 없다고 하였다.

⑷ 제3자의 공권확대화에 대한 구체적인 예 - 자세한 판례는 후술 원고적격 참조

14) 대판 1995. 9. 26, 94누14544

15) 대판 2006. 3. 16, 2006두330(새만금 간척사업)

Ⅴ. 공권과 기본권

1. 자유권적 기본권[16], 평등권, 재산권

1,2유형에서는 방어권으로서 구체적 공권인 바, 소송상 주장가능(원고적격으로서의 공권인정됨). 단, 제3자소송(3, 4유형 등)에서는 원칙적으로 인정되지 않으나 독일판례와 우리나라 다수설과 헌재입장은 당해 처분의 실체법규, 절차법규, 관련법규가 제3자가 침해받았다고 주장하는 이익을 보호한다고 해석되지 않으나 제3자가 당해 처분으로 침해받았다고 주장하는 이익이 중대하고 참을 수 없는 이익인 경우에는 보충적으로 헌법상 자유권적 기본권, 평등권, 재산권조항에 의하여 제3자에게 공권을 인정할 수 있다고 한다.

2. 청구권적 기본권, 생존권적 기본권[17]

모든 유형에서 추상적 공권으로 밖에 인정되지 않는 바, 법률에 의하여 구체적 공권이 인정되지 않는 한 소송상 주장불가

Ⅵ. 적극적 청구권

1. 행정개입청구권

⑴ 의 의

협의로는 행정청의 거부나 부작위로 인하여 권익을 침해당한 자가 당해 행정청에 대하여 타인에 대한 행정권의 발동을 청구할 수 있는 권리라 하고, 광의로는 사인이 행정청에 대하여 행정권 발동을 요구할 수 있는 권리라고 한다. 광의의 행정개입청구권은 행정행위발급청구권과 협의의 행정개입청구권을 포함한다.

이하에서는 협의의 행정개입청구권에 대하여 검토하도록 하겠다.

행정개입청구권은 건축 경찰법 분야에서 무하자재량행사청구권과 재량권의 수축의 법리가 적용된 결과 인정되기 시작하여 환경오염방지법과 같은 환경법영역 등의 분야에서도 확대되어 가고 있다.[18]

⑵ 법적 성질 - 실체적 공권

⑶ 인정여부

① 행정권발동은 행정청의 재량이라는 점 및 쟁송수단미비 등을 이유로 부정하는 학설도 있으나, ② 재량권의 영으로 수축 및 공권의 확대화경향 등을 이유로 긍정하는 것이 다수설이고 타당하다.

⑷ 성립요건

1) 강행법규에 의한 개입의무 존재

이 공권이 성립하기 위하여는 행정기관에 대하여 특정한 행정행위를 하도록 하는 법적의무가 존재하여야 한다. 이러한 의무는 기속행위인 경우에는 당해 성문법규에 의해서 인정되나 재량행

16) 신체의 자유, 직업선택의 자유(영업의 자유, 경쟁의 자유 포함), 언론출판의 자유, 집회결사의 자유, 양심의 자유, 통신의 자유, 사생활의 자유, 종교의 자유 등
17) 인간다운생활권, 환경권 등
18) 이재화, 전게서, 49면.

위인 경우에는 행정기관의 객관적인 개입의무의 존재, 즉 행정기관의 재량이 0으로 축소되는 경우로 나타나게 된다.

이 때 행정기관에게 부여되는 개입의무존재의 판정은 개별적 구체적으로 검토하여야 한다. 따라서 생명 신체 등 중대한 법익에 대한 구체적 위해가 존재하고 행정기관이 다른 동가치적 법익을 소홀함이 없이 구체적 위해를 제거할 수 있는 경우에는 재량이 0으로 수축하여 행정개입의무가 발생한다고 할 수 있다.

2) 사익보호성의 존재

⑸ 청구권의 실현방법

1) 거부한 경우

의무이행심판, 거부처분취소소송, 무명항고소송으로서 의무이행소송인정여부

2) 부작위 한 경우

의무이행심판, 부작위위법확인소송, 무명항고소송으로서 의무이행소송인정여부

3) 이미 종료된 경우

항고쟁송을 제기할 협의의 소익이 없으므로 항고쟁송을 제기할 수 없다. 이러한 경우에는 그로인해 발생한 손해에 대해 국가배상청구소송을 제기하여야 한다.

2. 행정행위발급청구권

Ⅶ. 무하자재량행사청구권

1. 개념

무하자재량행사청구권이란 개인이 행정청에 대하여 하자 없는 적법한 재량행위를 해달라고 요구하는 공권을 말한다.

2. 인정여부

⑴ 학설

① 민중소송화 등을 이유로 부정하는 견해, ② 절차적 공권으로 독자성을 인정하는 견해, ③ 형식적 공권으로 독자성을 인정하는 견해, ④ 실체적 공권으로 독자성을 인정하는 견해, ⑤ 개념자체는 긍정하나 원고적격으로서 독자적 공권성은 부정하는 견해 등이 대립한다.

⑵ 판 례

판례는 검사임용거부처분취소소송에서 거부처분의 처분성인정여부와 관련하여 '적어도 재량권의 한계 일탈이나 남용이 없는 위법하지 않은 응답을 할 의무가 임용권자에게 있고 이에 대응하여 임용신청자로서도 재량권의 한계 일탈이나 남용이 없는 적법한 응답을 요구할 권리가 있다'라고 판시하였다(대판 1991. 2. 12, 90누5825).

위 판례에 대하여 다수설은 판례가 무하자재량행사청구권의 법리를 인정하였다고 평가한다. 이에 대해 일부견해는 판례가 언급한 응답받을 권리는 헌법 제10조 인간의 존엄과 가치권, 헌법 제15조의 직업선택의 자유, 헌법 제25조의 공무담임권에서 나오는 실질적인 권리이지, 재량행사의 하자 그 자체를 대상으로 하는 형식적인 권리가 아니라고 한다.

3. 성립요건

재량행위의 영역에서 권리가 인정되기 위해서는 첫째, 그 전제로서 무하자재량행사의무가 존재하여야 하고, 둘째, 관련법규범이 공익뿐만 아니라 관련사인의 이익을 보호하도록 의도하고 있어야 한다.

4. 행사의 내용 - 하자없는 재량행사청구

5. 권리구제

무하자재량행사청구권은 보통 수익적 행정행위를 대상으로 하나, 부담적 행정행위에도 인정된다.

⑴ 부담적 행정행위인 경우 - 취소심판, 취소소송

⑵ 수익적 행정행위인 경우

1) 거부처분일 경우 - 의무이행심판, 무명항고소송으로 의무이행소송, 거부처분취소소송

2) 부작위일 경우 - 의무이행심판, 무명항고소송으로 의무이행소송, 부작위위법확인소송

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 다음 중 행정법상의 개인적 공권(법률상의 이익)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 판례에 의하면 처분의 직접적 근거규정만으로 공권의 성립요건의 충족 여부를 판단한다고 한다.
② 현행 행정소송법상으로 행정개입청구권이 완전하게 관철되기란 어렵다.
③ 공권의 성립요건 가운데 의사력(법상의 힘)의 존재의 중요성은 많은 문헌에서 감퇴되고 있다.
④ 판례에 의하면 인근주민이 위법건축물에 대한 건축허가의 취소 등의 조치를 행정청에 요구할 수 있는 권리가 부정된다고 한다.
⑤ 공권은 본인의 포기의사에 의하여 언제든지 포기될 수 있는 것은 아니다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 행정처분의 직접 상대방이 아닌 제3자라 하더라도 당해 행정처분으로 인하여 법률상 보호되는 이익을 침해당한 경우에는 그 처분의 무효확인을 구하는 행정소송을 제기하여 그 당부의 판단을 받을 자격이 있다 할 것이며, 여기에서 말하는 법률상 보호되는 이익이라 함은 당해 처분의 근거 법규 및 관련 법규에 의하여 보호되는 개별적·직접적·구체적 이익이 있는 경우를 말하고, 공익보호의 결과로 국민 일반이 공통적으로 가지는 일반적·간접적·추상적 이익이 생기는 경우에는 법률상 보호되는 이익이 있다고 할 수 없다(대판 2006.3.16, 2006두330 全合).

② 왜냐하면 행정개입청구권을 행사하는데 행정청이 거부를 하거나 부작위를 한 경우에 대한 직접적·실효적인 구제수단은 의무이행소송인데, 현행 소송법상 의무이행소송은 인정되지 않고, 간접적·우회적 수단인 거부처분취소소송과 부작위위법확인소송만 인정되기 때문이다.

④ 구 건축법 및 기타 관계법령에 국민이 행정청에 대하여 제3자에 대한 건축허가의 취소나 준공검사의 취소 또는 제3자 소유의 건축물에 대한 철거 등의 조치를 요구할 수 있다는 취지의 규정이 없고, 같은 법 제69조 제1항 및 제70조 제1항은 각 조항 소정의 사유가 있는 경우에 시장·군수·구청장에게 건축허가 등을 취소하거나 건축물의 철거 등 필요한 조치를 명할 수 있는 권한 내지 권능을 부여한 것에 불과할 뿐, 시장·군수·구청장에게 그러한 의무가 있음을 규정한 것은 아니므로 위 조항들도 그 근거 규정이 될 수 없으며, 그 밖에 조리상 이러한 권리가 인정된다고 볼 수도 없다(대판 1999.12.7, 97누568).

⑤ 공권은 공익적 성격으로 인해 포기가 제한되는 것이 보통이다.

정답 ①

2. 행정상 법률관계에 있어 개인적 공권을 잘못 설명한 것은?

① 재량행위영역에는 개인적 공권이 성립될 수 있다.
② 법규의 취지가 기본적으로 공익추구에 있고 부수적으로 사익을 보호하고자 하는 경우에도 공권은 성립한다.
③ 헌법상의 모든 기본권이 행정상 법률관계에 있어 개인적 공권이 되는 것은 아니다.
④ 공권이 인정되기 위해서는 강행법규에 의하여 행정청에 일정한 행위의무가 부과되어 있어야 한다.
⑤ 행정개입청구권은 행정청에 대하여 특정한 처분을 요구할 수 있는 실체적 공권이고 무하자재량행사청구권도 위법한 처분의 배제를 구하는 실체적 권리이다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 재량행위의 경우에도 최소한 무하자재량행사청구권이 인정되고 재량권이 '0'으로 수축하는 예외적인 경우에는 행정개입청구권이 인정된다.
③ 모든 기본권이 원고적격이 인정되는 구체적인 개인적 공권은 아니라는 의미, 즉 자유권적 기본권만 원고적격이 인정되는 구체적 권리라고 해석하면 옳은 지문이 된다.
⑤ 무하자재량청구권은 적극적으로 하자 없는 재량권의 행사를 청구하는 적극적 공권이지, 위법한 처분의 배제를 청구하는 소극적 권리가 아니다. 또한 하자 없이 '어떠한' 처분을 해달라고 청구하는 형식적 권리이지, '특정처분'을 요구하는 실체적 권리가 아니다.

정답 ⑤

3. 무하자재량행사청구권에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (2000 행정고시)

① 재량한계론의 발전에 따라 재량통제 법리의 하나로 등장하였다.
② 재량행위의 영역에서 공권의 성립을 인정한 점에서 큰 의미를 갖는다.
③ 행정청에 대하여 적법한 재량처분을 구하는 적극적 공권이 아니라, 단순히 위법한 처분을 배제하는 소극적·방어적 권리이다.
④ 재량권이 '0'으로 수축되는 경우에 개인은 행정청에 대하여 특정처분을 청구할 수 있게 된다는 점에서 행정개입청구권이 인정된다.
⑤ 다수견해에 의하면 무하자재량행사청구권의 침해를 이유로 처분의 위법성을 소송으로 다툴 수 있다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

무하자재량행사청구권은 재량행위의 상대방 기타 이해관계인은 행정청에 대해 특정한 행위를 구하는 권리를 갖지 못하지만, 재량행사를 하자 없이 행사해 줄 것을 청구하는 권리이므로 단순히 위법한 처분을 배제하는 소극적 또는 방어적 권리에 그치는 것이 아니라, 행정청에 대하여 적법한 재량처분을 할 것을 구하는 적극적 공권성도 갖는다.

정답 ③

♣ 학습내용 정리

1. 공권의 성립요건으로 강행법규성과 사익보호성이 있다.
2. 특히 제3자 보호와 관련하여 공권의 확대화 경향이 있다.
2. 재량영역에서도 무하자재량행사청구권이 성립할 수 있으며 재량이 0으로 수축할 경우 협의의 행정개입청구권이 인정된다.

제5강 행정법상 법률요건과 법률사실

♣ 학습목표

행정법상 법률요건과 법률사실의 의미에 대하여 설명할 수 있다.
공법상 부당이득반환청구권의 법적 성질, 사인의 공법행위에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

공법상 부당이득반환청구권의 법적 성질
사인의 공법행위

♣ 사전테스트

1. 공법상 부당이득반환청구권은 당사자소송의 대상이라는 것이 판례의 태도이다.
   정답 : ×

2. 공법상 사건으로 사인의 공법행위가 있다.
   정답 : X

3. 사인의 공법행위 중 자기완결적 신고는 행정청의 수리처분 없이도 신고의 효과가 발생한다.
   정답 : ○

♣ 돌발퀴즈

행정행위의 취소사유에 해당하는 위법이 있다면 바로 부당이득이 성립되지 않는다.

[정답] ○

[해설] 행정행위에 취소사유인 하자가 있는 경우 행정행위에는 공정력이 있기 때문에 권한 있는 기관에 의해 취소되기 전까지는 효력이 부인되지 않으므로 부당이득의 문제는 성립하지 않는다.

♣ 강의내용

제1 행정법상 법률요건과 법률사실의 의의 및 종류

Ⅰ. 의 의

행정법상의 법률요건이라 함은 행정법관계의 발생·변경·소멸이라는 법률효과를 발생시키는 원인이 되는 사실을 말하며, 이러한 법률요건을 이루는 개개의 사실을 법률사실이라 한다.

Ⅱ. 종 류

행정법상의 법률사실은 민법에서와 같이 사람의 정신작용을 요소로 하는 『용태』와 그렇지 아니한 『사건』으로 나누어진다.

1. 행정법상의 사건

사람의 정신작용을 요소로 하지 아니하는 행정법상의 『사건』에는, 사람의 생사(사망함으로써 운전면허가 실효되는 것 또는 의사면허가 실효되는 것등), 시간의 경과(허가의 유효기간 만료로 허가의 효력이 소멸되는 것), 일정한 연령에의 도달 등이 있으며, 모두 일정한 외부적·객관적 사실의 존재 자체만으로 일정한 법률효과를 발생한다.

2. 행정법상의 용태

사람의 정신작용을 요소로 하는 법률사실로서, 외부적 용태와 내부적 용태로 구분된다

⑴ 외부적 용태

외부에 표시된 정신작용에 의하여 일정한 행정법상의 법률효과를 발생시키는 것으로서, 공범행위가 그 중심을 이루고 있다. 공법행위에는 사인의 공법행위(허가 신청, 행정소송의 제기 등)도 있지만, 대부분은 행정주체의 공법행위로서 행정입법·공법상 계약·행정행위 등이 있다.

⑵ 내부적 용태

외부에 표시되지 아니한 내부적 정신상태만으로 행정법상의 법률효과를 발생시키는 것을 말한다(예 : 선의·악의·고의·과실 등).

제2 공법상 사건

Ⅰ. 시간의 경과

Ⅱ. 주소·거소

Ⅲ. 부당이득

1. 의 의

부당이득제도는 법률상 원인없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이득을 얻고 타인에게 손해를 가한 자에게 그 이득의 반환을 요구하는 제도이다(민법 제741조).

2. 부당이득반환청구권의 성질

⑴ 학설

1) 사권설

① 행정행위에 의한 부당이득인 경우에도 그것이 처음부터 무효이거나 취소된 후에 성립하므로 아무런 법률상 원인이 없는 상태이며 ② 또한 부당이득반환청구권 자체가 원래 형평의 이념에서 확립된 사권이므로, 이에 관한 소송도 민사소송에 의하여야한다는 견해이다.

2) 공권설

공법상 원인에 의하여 발생된 결과를 시정하기 위하여 인정된 권리는 공법상 원인 유무의 탐구와 밀접한 관련이 있으므로 공권이며 이에 관한 소송도 「공법상의 법률관계에 관한 소송」인 공법상의 당사자소송(행정소송법 제3조 제2호[19])에 의하여야 한다는 견해이다.

⑵ 판례

판례는 원칙적으로 과오납금반환청구권을 사권으로 보아 민사소송의 대상으로 삼고 있다. 다만, 부가가치세법령에 의한 환급금반환청구권에 대하여는 부가가치세법령에 의해 발생하는 공권으로 보아 당사자소송의 대상으로 삼고 있다.

3. 성립요건

⑴ 재산적 이익과 손실 및 인과관계

⑵ 법률상의 원인없는 이익의 발생

제3 행정법상 용태

Ⅰ. 사무관리

Ⅱ. 공법행위

1. 의 의

공법행위란 일반적으로 공법관계에 있어서의 행위, 즉 공법적 효과를 발생·변경·소멸시키는 모든 행위를 가리키는 것으로서, 사법행위에 대응되는 관념이다.

---

19) "제3조 (행정소송의 종류) 행정소송은 다음의 네가지로 구분한다.

1. 항고소송 : 행정청의 처분등이나 부작위에 대하여 제기하는 소송
2. 당사자소송 : 행정청의 처분등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송 그 밖에 공법상의 법률관계에 관한 소송으로서 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송
3. 민중소송 : 국가 또는 공공단체의 기관이 법률에 위반되는 행위를 한 때에 직접 자기의 법률상 이익과 관계없이 그 시정을 구하기 위하여 제기하는 소송
4. 기관소송 : 국가 또는 공공단체의 기관상호간에 있어서의 권한의 존부 또는 그 행사에 관한 다툼이 있을 때에 이에 대하여 제기하는 소송. 다만, 헌법재판소법 제2조의 규정에 의하여 헌법재판소의 관장사항으로 되는 소송은 제외한다."

2. 행정주체의 공법행위

3. 사인의 공법행위 :

제4 사인의 공법행위

Ⅰ. 사인의 공법행위의 의의 및 성질

사인의 공법행위는 행정법관계에서의 사인의 행위로서 공법적 효과를 발생시키는 행위를 총칭한다.

Ⅱ. 종 류

자기 완결적 공법행위	1. 신고 ⑴ 의사표시로서의 신고 : 퇴거신고 ⑵ 통지행위로서의 신고 : 호적법상 신고(출생신고, 사망신고 등), 질서행정법상 신고(도난신고, 숙박신고 등), 조세법상 신고(납세신고, 폐업신고 등) 2. 합동행위 : 농지개량조합·토지구획정리조합 등의 설립행위 3. 선거에서의 투표행위
행위 요건적 공법행위	1. 신청 ⑴ 행정청의 단독행위에 관한 단순한 희망의 의사표시 : 국·공립학교의 수업료납부연기신청 ⑵ 쌍방적 행정행위를 요구하는 경우 : 사직원제출·허가신청·특허나 인가신청 ⑶ 공법상 계약에 있어서 청약의 의사표시 : 입학원·임의적 공용부담신청·지원에 의한 입대 ⑷ 행정청의 법률적·사실적 판단을 청구하는 경우 : 행정쟁송의 제기, 청원의 제출 2. 동의(협의) ⑴ 쌍방적 행정행위의 요건이 되는 동의 : 공무원의 임명에 있어서의 상대방의 동의, **공무원전출명령에서 상대방동의** ⑵ 공법상 계약의 당사자로서 하는 행위 : 토지수용의 협의성립 3. 수리를 요하는 신고 수산업법상 어업신고, 건축법상 건축주명의변경신고, 각종 등록신청, 건축법 제14조 제2항에 의해 인허가가 의제되는 건축신고

Ⅲ. 자기완결적 공법행위

1. 신 고 : 다음절

2. 투표행위

3. 합동행위

Ⅳ. 행정요건적 공법행위

1. 신 청

신청이란 행정청에 대하여 자기의 권리 또는 이익을 위하여 어떤 사항을 청구하는 의사표시를 말한다.

2. 동의·승낙·협의 등

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 다음 중 공법상 부당이득에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (2003 입법고시)

① 대법원은 공법상 부당이득반환청구권을 공법상 권리로 파악하면서도 민사소송으로 다루어진다는 입장이다.
② 취소할 수 있는 행정처분이라도 취소되지 않는 한 부당이득이 성립되지 아니한다는 견해가 유력하다.
③ 연금수령자격이 없는 자가 수령한 연금은 공법상 부당이득에 해당한다.
④ 무효인 법령에 근거한 조세부과처분에 따라 납부한 세금은 공법상 부당이득이다.
⑤ 개인의 공법상 부당이득도 성립될 수 있다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 다수설은 공법상 부당이득반환청구권은 공법상 원인에 의해 발생한 것이므로 공권이며 이에 관한 분쟁은 행정소송법상의 당사자소송에 의한다고 주장한다. 그러나 판례는 "조세부과처분이 무효임을 전제로 하여 이미 납부한 세금의 반환을 청구하는 것은 민사상의 부당이득반환청구로서 민사소송절차에 따라야 한다(대판 1995.12.22, 94다51253)"라고 판시하여 사권·민사소송설의 입장이다.
② 하자가 취소사유인 경우에는 당해 행정행위가 취소된 연후에야 비로소 정당한 법률상의 원인 없는 부당이득이 성립하게 된다. 당해 행정행위에 대한 제소기간이 경과하여 불가항력이 발생한 후에는 부당이득반환청구가 사실상 불가능하다.
③ 연금수령자격이 없는 자가 수령한 연금은 행정주체의 행정행위로 인해 부당이득이 발생한 경우이다(개인의 부당이득 유형이다).
④ 행정주체의 부당이득 유형이다.
⑤ 부당이득의 유형으로는 행정주체의 부당이득, 개인의 부당이득을 들 수 있다. 개인의 부당이득도 그 원인이 행정행위에 근거한 경우에는 그 행정행위가 무효 또는 취소된 경우에 부당이득이 성립한다. 행정행위와 무관하게 사인이 부당이득을 취하는 경우도 가능하다(예 사인의 국유지 무단사용시).

정답 ①

2. 다음 중 사인의 공법행위에 관한 설명으로 타당하지 아니한 것은? (2001 입법고시)

① 사인의 공법행위에는 부관을 붙일 수 없음이 원칙이다.
② 판례는 여군의 전역지원의 의사표시가 진의 아닌 의사표시라면 민법 제107조 단서의 적용에 의하여 무효가 된다고 보았다.
③ 권리·의무에 직접적인 영향을 미치는 수리거부행위는 취소소송의 대상이 된다.
④ 투표행위와 같은 합성행위는 그 집단성·형식성이 중시되므로 착오를 이유로 취소를 주장할 수 없다.
⑤ 건축법상 신고사항에 관하여는 건축을 하고자 하는 자가 적법한 요건을 갖춘 신고만하면 별다른 행정처분 없이 건축할 수 있다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 사인의 공법행위에는 행정법관계의 명확성과 신속한 확정을 위해 부관을 붙일 수 없음이 원칙이다.
② 전역지원의 의사표시가 진의 아닌 의사표시라 하더라도 그 무효에 관한 법리를 선언한 민법 제107조 제1항 단서의 규정은 그 성질상 사인의 공법행위에는 적용되지 않는다 할 것이므로 그 표시된 대로 유효한 것으로 보아야 한다(대판 1994.1.11, 93누10057).
⑤ 대판 1999.4.27 97누6780

정답 ②

3. 사인의 공법행위에 대한 적용법규에 관한 설명 중 잘못된 것은? (2003 관세사)

① 사인의 공법행위에서도 의사능력이 필요하고, 의사능력이 없으면 무효이다.
② 행위능력에 관하여는 공법상 특별한 규정이 있어 민법규정을 그대로 적용할 수 없는 경우가 있다.
③ 사인의 공법행위에 있어서 법규정에 의해 또는 행위의 성질상 대리가 허용되지 않는 경우가 많다.
④ 사인의 공법행위는 행위의 존재나 내용이 명확해야 하기 때문에 반드시 일정한 형식이 요구된다.
⑤ 사인의 공법행위에는 부관을 붙일 수 없는 것이 원칙이다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

② 특별한 규정이 없는 경우에는 민법의 규정이 유추적용된다.
③ 사인의 공법행위에 대해서는 대리가 명문으로 허용되지 않는 경우가 많다. 이러한 규정이 없는 경우에는 행위의 성질상 일신 전속적인 것이 아니면 대리가 인정된다고 본다. 대리가 인정된 경우에는 민법의 규정을 준용할 수 있다.
④ 행위의 형식에 대한 일반적 규정이 없으므로 불요식의 행위로 보는 것이 다수설이다. 그런데 행위의 존재와 내용을 명백히 하기 위해 요식행위에 의할 것을 규정한 경우가 많다(행정심판법 제19조).
⑤ 사인의 공법행위에는 행정법관계의 명확성과 신속한 확정을 위해 부관을 붙일 수 없음이 원칙이다.

정답 ④

♣ 학습내용 정리

1. 행정법상 법률사실에는 사람의 정신요소가 있느냐에 따라 사건과 용태로 나누어 진다.
2. 공법상 부당이득반환청구권의 법적성질에 대하여 학설과 판례의 대립이 있다.

제6강 사인의 공법행위

♣ 학습목표

사인의 공법행위의 적용법리와 하자의 효과 및 신고의 의의 및 종류에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

사인의 공법행위의 적용법리
사인의 공법행위의 하자의 효과
신고의 의의와 종류

♣ 사전테스트

1. 사인의 공법행위에는 민법이 절대 적용될 수 없다.
   정답 : ×

2. 사인의 공법행위에는 부관을 붙일 수 있다.
   정답 : X

3. 신고에는 자기완결적 신고와 수리를 요하는 신고가 있다.
   정답 : ○

♣ 돌발퀴즈

판례는 사인의 공법행위에도 민법의 비진의 의사표시에 관한 규정이 적용된다고 판시하였다.

[정답] ×

[해설] 이른바 1980년의 공직자숙정계획의 일환으로 일괄사표의 제출과 선별수리의 형식으로 공무원에 대한 의원면직처분이 이루어진 경우, 사직원 제출행위가 강압에 의하여 의사결정의 자유를 박탈당한 상태에서 이루어진 것이라고 할 수 없고 민법상 비진의 의사표시의 무효에 관한 규정은 사인의 공법행위에 적용되지 않는다는 등의 이유로 그 의원면직처분을 당연무효라고 할 수 없다(대판 2000.11.14, 99두5481).

♣ 강의내용

제1 사인의 공법행위의 적용법리 및 하자의 효과

I. 사인의 공법행위에 대한 적용법규

1. 서 - 개별법에 특별규정없을 때 사법규정 적용가능한지

2. 의사무능력·행위무능력
   - 의사무능력 : 적용 / 행위무능력 : 공법에 특별한 규정없으면 재산적 행위에만 적용

3. 대 리
   일신전속적 행위(선거 등)가 아닌 한 민법의 대리규정 적용

4. 형 식

5. 효력발생시기 - 원칙 : 도달주의

6. 하자있는 의사표시
   법에 특별한 규정이 없는 한 민법 제107조부터 제110조가 원칙적으로 유추적용된다. 다만, 그 행위의 단체적 정형적 성질이 강하여 사인간의 거래와 다른 특수성이 인정되는 경우에는 민법총칙의 적용에 수정을 가할 필요가 있다. 예를 들어 영업재개신고는 행위의 정형화가 요구되는 사인의 공법행위이므로 진의 아닌 의사표시라도 민법 제107조 단서는 적용되지 않는다.
   한편 대법원은 이른바 1980년의 공직자숙정계획의 일환으로 일괄사표의 제출과 선별수리의 형식으로 공무원에 대한 의원면직처분이 이루어진 경우, 사직원 제출행위가 강압에 의하여 의사결정의 자유를 박탈당한 상태에서 이루어진 것이라고 할 수 없고 민법상 비진의 의사표시의 무효에 관한 규정은 사인의 공법행위에 적용되지 않는다는 등의 이유로 그 의원면직처분을 당연무효라고 할 수 없다고 판시하였다.[20]

7. 부관 - 불가

8. 철회, 보정
   사법관계에 있어서는 의사표시가 상대방에게 도달한 경우에는 그것을 철회할 수 없다. 그러나 행정법관계에서는 사인의 공법행위에 근거하여 행정행위가 행하여지기 전에는 아직 법률관계에 변동이 일어난 것이 아니므로 철회할 수 있다.
   공무원에 의해 제출된 사직원은 그에 터잡은 의원면직처분이 있을 때까지는 철회될 수 있고, 일단 면직처분이 있고 난 이후에는 철회나 취소할 여지가 없다(대판 2001. 8. 24, 99두9971).

---

20) 대판 2000. 11. 14, 99두5481.

Ⅱ. 사인의 공법행위의 하자의 효과

1. 학설

일단 사인의 공법행위가 행정행위의 단순한 동기인 경우에는 사인의 공법행위 하자가 행정행위에 어떠한 영향도 미치지 않는다는 것에 대해서는 학설이 일치한다. 다만 사인의 공법행위가 행정행위의 요건인 경우,

① 사인의 공법행위에 단순한 위법사유가 있으면 행정행위는 유효하나 사인의 공법행위가 무효인 경우에는 행정행위도 무효가 된다는 견해, ② 법적 안정성을 위해 사인의 공법행위에 하자가 있을 경우 행정행위는 원칙상 취소정도의 하자밖에 없고, 단 상대방의 동의나 신청을 요하는 행정행위에서 동의나 신청이 명백히 결여되면 행정행위도 무효가 된다는 견해, ③ 사인의 공법행위가 무효나 부존재하면 행정행위도 무효가 되고, 사인의 공법행위가 취소할 수 있는 행위인 경우 사인이 행정행위가 행해지기 전에는 사인의 공법행위를 취소 또는 철회되지 않았다면 행정행위에 취소정도의 하자를 인정할 수 있다는 견해 등이 대립한다.

2. 판례

하자있는 사인의 공법행위에 따른 행정행위의 효력에 대한 대법원의 일반적인 입장은 없고, 개개의 사안별로 해결하고 있다. 즉 강요에 의한 의사표시에 이르지 않은 경우는 행정행위에 영향이 없지만 공포심에 따른 사직서의 교부에 따른 의원면직처분은 위법하고, 허가신청없이 한 허가처분은 무효라고 하였다.[21)]

공무원에게 단지 비리에 따른 객관적 상황을 고지하면서 사직을 권고·종용한 것에 지나지 않은 경우에는 강박을 한 것으로 볼 수 없으므로 사표제출에 하자가 없다는 판례(대법원 1997. 12. 12. 선고 97누13962 판결).

구타 및 위협에 의해 사표제출을 받아 한 의원면직처분은 위법하다는 판례

허가신청행위가 무효이면 그에 따른 허가처분도 무효라는 판례(대판 1974.8.30, 74누168).

3. 검 토

사인의 공법행위의 하자로 인한 행정행위의 효력은 행정행위의 하자에 관한 일반이론에서와 같이 사인의 권리보호와 행정법관계의 안정의 보장이라는 두 요청을 조화하는 해결을 도모하여야 한다는 점에서 3설이 타당하다.

제2 신 고

Ⅰ. 신고의 의의

신고란 사인이 공법적 효과발생을 목적으로 행정기관에게 일정한 사항을 알리는 행위를 말한다.

---

21) 홍정선, 행정법특강, 제109면

Ⅱ. 신고의 종류

1. 자기완결적 신고와 수리를 요하는 신고

⑴ 의의

자기완결적 신고는 신고의 요건을 갖춘 신고만 하면 법령에 의해 일정한 법적 효과가 발생하는 신고를 말한다.

수리를 요하는 신고는 법령 등에서 행정청에 대하여 일정한 사항을 통지하고 행정청이 이를 수리함으로써 법적 효과가 발생하는 신고를 말한다.

⑵ 영업양도 등의 신고

근거법령에서 영업양도시 양수인이 신고하도록 규정한 경우, 이 지위승계신고의 법적 성질에 대하여 종래의 다수설은 수리를 요하는 신고라고 본 판례를 인용하면 수리를 요하는 신고라고 보았다.

그러나 지위승계신고는 양도대상인 영업의 종류에 따라 달리 판단하여야 한다고 하면서 허가영업의 양도의 경우에 나타나는 신고는 허가신청의 일종으로, 등록영업의 양도의 경우에 나타나는 신고는 등록신청의 일종으로, 자기완결적 공법행위로서의 신고를 요하는 영업의 양도의 경우에 나타나는 신고는 자기완결적 공법행위로서의 신고로 이해되어야 한다는 견해가 유력하다. 이 견해에 따를 때 지위승계신고의 법적성질은 허가영업인 경우 양도인에 대한 허가취소와 양수인에 대한 신규허가로 이해하여야 한다.

판례도 유력설의 입장에서 “사업양수에 의한 지위승계신고를 수리하는 허가관청의 행위는..... 실질에 있어서 양도자의 사업허가를 취소함과 아울러 양수자에게 적법히 사업을 할 수 있는 법규상 권리를 설정하여 주는 행위로서.....”라고 판시하였다(91누11544 판결)

⑶ 구별실익

자기완결적 신고에 대한 수리는 사실행위에 불과하나 수리를 요하는 신고에 대한 수리는 행정행위이다. 단 수리거부가 항고소송의 대상인 처분인가에 대해서는 후술하는 바와 같이 학설과 판례의 논의가 있다.

⑷ 구별기준

1) 학 설

학설은 ① 일반적으로 신고요건의 내용을 구분기준으로 하여 원칙상 신고요건이 형식적 요건만인 경우에는 자기완결적 신고이고, 신고요건에 형식적 요건이외에 실질적 요건도 포함되는 경우에는 수리를 요하는 신고로 보아야 한다는 견해[22]와 ② 개별법령이 신고와 등록을 구분하여 규정하고 있는 경우(예 : 석유및석유대체연료사업법, 체육시설의설치이용에관한법률 등)가 아니라면 당해 법령의 목적과 당해 법령에서 나타나고 있는 관련조문에 대한 합리적이고도 유기적인 해석을 통해 양자를 구분할 수 밖에 없다는 견해[23]가 대립한다.

---

22) 박균성, 전게서, 81면.

23) 홍정선, 행정법특강 제109면.

2) 판 례

대법원은 건축물 양수인의 건축대장상의 건축주 명의변경신고[24], 수산업법 제47조 소정의 어업신고[25]의 수리거부를 처분으로 보고 있다. 그러나 체육시설의설치이용에관한법률 제18조에 의한 골프장이용료 변경신고[26]는 자기완결적 신고로 보고 있다.

Ⅲ. 신고의 수리

자기완결적 신고의 경우에 적법한 신고가 있으면 행정청의 수리 여부에 관계없이 신고서가 접수기관에 도달할 때에 신고한 것으로 본다(행정절차법 제40조 제2항). 따라서 행정청이 신고서를 접수하지 않고 반려하여도 신고의무는 이행된 것으로 본다.

그러나 수리를 요하는 신고에서 법령이 정한 요건을 구비한 적법한 신고가 있으면 행정청은 의무적으로 수리하여야 한다.

Ⅳ. 수리거부의 처분성

1. 자기완결적 신고

⑴ 학설

① 자기완결적 신고는 수리에 의하여 아무런 법적 효과도 발생하지 않으므로 수리거부가 처분이 아니라는 견해, ② 자기완결적 신고에 있어서도 금지해제의 의미를 갖는 신고라면 형사처벌이 과태료 등 제재를 받을 위험성을 제거한다는 의미에서 수리거부의 처분성을 인정하여야 한다는 견해 등이 대립한다.

⑵ 판례

종전 판례는 건축법상 건축신고반려처분에 대하여 처분성이 부정하였다. 그러나 최근 판례는 전원합의체 판결로 종전 판례를 파기하고 건축신고반려행위로 인한 법률상 지위불안이 야기되는 경우 그러한 법률상 지위불안을 제거하여 분쟁을 조기에 근본적으로 해결하기 위해 건축신고반려처분의 처분성을 인정하였다(대판 전원합의체 2010. 11. 18, 2008두167).

2. 수리를 요하는 신고

수리를 요하는 신고의 경우, 수리에 의하여 비로소 법적 효과가 발생하므로 수리 및 수리거부가 항고소송의 대상이 되는 처분이 된다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 사인의 공법행위에 관한 설명으로 옳은 것은? (2009 관세사)

① 행정행위와 마찬가지로 구속력·집행력 등과 같은 행정우월적 효력을 가진다.

② 공법적 효과가 발생되기 때문에 부관을 붙일 수 있음이 원칙이다.

---

24) 대판 1992. 3. 31, 91누4911

25) 대판 2000. 5. 26, 99다37382

26) 대결 1993. 7. 6, 93마635

③ 적법한 출생·사망의 신고와 같이 자기완결적 공법행위의 경우 접수와 무관하게 신고의 의사표시와 동시에 효력이 발생한다.
④ 적법한 신청이 있는 경우에 행정청은 상당한 기간 내에 신청한 내용대로 처분할 의무가 있다.
⑤ 행정청에 대하여 처분을 구하는 신청은 원칙적으로 문서로 하여야 하며, 특히 전자문서로 하는 경우에는 행정청의 컴퓨터 등에 입력된 때에 신청한 것으로 본다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 사인의 공법행위는 공법행위라는 점에서 행정행위와 같지만, 주체가 사인이라는 점 및 공정력, 집행력 등이 인정되지 않는다는 점에서 행정청의 공권력발동작용으로서 공정력 등이 인정되는 행정행위와 구별된다.
② 행정법관계의 명확성·신속한 확정의 필요상 특별한 규정이 없는 한 부관을 붙일 수 없다.
③ 도달주의가 원칙이나, 법률에서 예외적으로 발신주의를 규정하고 있는 경우도 있다(예 국세기본법 제5조의2).
④ 적법한 신청이 있으면 행정청은 상당한 기간 내에 신청에 대한 응답의무를 진다. 응답의무는 신청된 내용대로 처분할 의무(인용의무)와는 다르다. 인용의무의 내용은 신청에 대한 행정행위가 재량행위냐 기속행위냐에 따라 다르다. 즉, 당해 행정행위가 기속행위인 경우에는 행정청은 신청이 된 특정한 행정행위를 발급할 의무가 있으나, 재량행위의 경우에는 행정청은 재량의 한계 내에서 행정행위를 거부 또는 발급할 수 있다.
⑤ 행정청에 대하여 처분을 구하는 신청은 문서로 하여야 한다. 다만, 다른 법령 등에 특별한 규정이 있는 경우와 행정청이 미리 다른 방법을 정하여 공시한 경우에는 그러하지 아니하다(행정절차법 제17조 제1항). 처분을 신청함에 있어 전자문서로 하는 경우에는 행정청의 컴퓨터 등에 입력된 때에 신청한 것으로 본다(동조 제2항).

정답 ⑤

2. 신고에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? (2001 행정고시)

① 신고요건을 갖추지 못한 신고서가 제출된 경우 행정청은 즉시 거부할 수 있다.
② 적법한 건축신고를 한 자는 행정청이 이를 수리하지 않은 경우에도 적법하게 건축행위를 할 수 있다.
③ 수리를 요하는 신고의 수리거부는 처분이며 항고소송의 대상이 된다.
④ 행정절차법은 수리를 요하지 않은 신고에 대하여 규정하고 있다.
⑤ 신고의무를 위반한 경우에 벌금이 부과되는 경우도 있다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

신고가 신고의 요건을 충족하지 않는 경우에 신고는 부적법한 신고가 된다. 부적법한 신고의 경우에 행정청은 요건을 갖추지 못한 신고서가 제출된 경우 지체 없이 상당한 기간을 정하여 신고인에게 보완을 요구하여야 한다(행정절차법 제40조 제3항). 행정청은 신고인이 보완기간 내에 보완을 하지 아니한 때에는 그 이유를 명시하여 당해 신고서를 되돌려 보내야 한다(동조 제4항).

정답 ①

3. 개인이 행정기관에 하는 신고와 관련하여 가장 타당한 것은? (2002 관세사)

① 행정기관은 신고서의 기재사항에 하자가 있는 등 형식적 요건을 갖추지 못한 경우에는 신고서를 지체 없이 반려한다.
② 행정절차법 규정에 의하면 행정기관이 수리를 거부하여도 요건을 갖춘 한 신고의 법적 효력은 발생하는 것이 원칙이다.
③ 혼인신고에서와 같이 사법적 효과만 발생하는 것이 원칙이다.

④ 우편으로 신고하는 경우 효력발생시기는 발송한 때이다.

⑤ 신고도 의사표시이므로 부관을 붙일 수 있는 것이 원칙이다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 행정청은 상대방의 신고서에 형식상의 흠이 있는 때에는 지체 없이 상당한 기간을 정하여 그 보완을 요구하여야 하고, 신고인이 이 기간 내에 보완을 하지 아니하는 경우에는 그 이유를 명시하여 당해 신고서를 되돌려 보내야 한다(행정절차법 제40조 제3항・제4항).

② 동법 제40조 제2항 참조

③ 신고의 효과는 공법적 효과뿐만 아니라 사법적 효과도 발생한다.

④ 신고의 효과발생시기는 신고서 도달시에 발생한다.

⑤ 행정법관계의 명확성・신속한 확정의 필요상 특별한 규정이 없는 한 부관을 붙일 수 없다.

정답 ②

♣ 학습내용 정리

1. 사인의 공법행위에는 개별법에 특별한 규정이 없는 한 사법규정이 적용될 수 있다.
2. 신고는 자기완결적 신고와 수리를 요하는 신고로 나누어 지며 자기완결적 신고는 수리처분 없이도 효과가 발생하고 수리를 요하는 신고는 수리처분에 의해 비로소 효과가 발생한다.

제7강 법규명령

♣ 학습목표

법규명령의 의의 및 종류와 법규명령의 한계, 위법한 법규명령에 대한 통제수단에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

법규명령의 의의 및 종류
법규명령의 한계
법규명령의 통제

♣ 사전테스트

1. 법규명령은 법률과 동위의 효력이 있다.
   정답 : ×

2. 감사원규칙은 행정규칙이라는 것이 다수설이다.
   정답 : X

3. 법규명령은 원칙적으로 항고소송의 대상이 아니다.
   정답 : ○

♣ 돌발퀴즈

헌법재판소의 결정에 의하면 벌칙의 위임에 있어서는 법률에서 형벌의 종류만 명백히 규정하면 가능하다고 한다.

[정답] ×

[해설] 형벌의 종류만이 아니라 범죄구성요건도 구체적으로 규정해야 하고 보충성도 요구된다. 형벌법규에 대하여도 특히 긴급한 필요가 있거나 미리 법률로써 자세히 정할 수 없는 부득이한 사정이 있는 경우에 한하여(보충성) 수권법률(위임법률)이 구성요건의 점에서는 처벌대상인 행위가 어떠한 것일 거라고 이를 예측할 수 있을 정도로 구체적으로 정하고, 형벌의 점에서는 형벌의 종류 및 그 상한과 폭을 명확히 규정하는 것을 조건으로 위임입법이 허용되며 이러한 위임입법은 죄형법정주의에 반하지 않는다(헌재 1996.2.29, 94헌마213).

♣ 강의내용

제1 법규명령의 의의와 종류

Ⅰ. 개 설

1. 법규명령의 의의

법규명령은 “상위 법령의 수권에 근거하여 행정부가 정립하는 일반적 추상적 규범으로서 대외적 구속력이 있는 성문의 법규범”이라고 정의된다. 따라서 법규명령의 필수적 요소로 ① 행정입법이고, ② 상위법령의 수권과 ③ 대외적 구속력이 있어야 한다.

2. 법규명령의 종류

⑴ 법형식 및 권한의 소재에 의한 분류

1) 헌법상 인정되고 있는 법규명령
① 대통령의 긴급명령과 긴급재정·경제명령
② 대통령령(헌법 제75조[27])
③ 총리령·부령(헌법 제95조[28])

2) 관련문제

① 법률에 의한 행정입법형식의 인정여부

감사원규칙은 헌법에 근거가 없고 감사원법 제52조에 근거하여 제정된다. 여기에서 헌법에 규정되지 않은 법규명령의 형식을 법률로 인정할 수 있는가 하는 문제가 제기된다.

이에 대해 국회입법원칙을 엄격히 해석하여 헌법에 규정되지 않은 법규명령을 부정하는 부정설과 헌법이 인정한 법규명령형식을 예시적으로 해석하여 인정하는 긍정설(다수설, 헌재입장)이 대립한다.

② 법령보충규칙 : 후술 참조

⑵ 수권의 범위·근거에 의한 분류

1) 비상명령

현행 헌법에서는 헌법적 효력을 가지는 법규명령은 인정되고 있지 아니하다.

2) 법률대위명령 - 헌법 제76조의 대통령의 긴급명령·긴급재정경제명령

3) 법률종속명령 - 법률보다 하위의 성문법

---

27) 헌법 제75조 “대통령은 법률에서 구체적으로 범위를 정하여 위임받은 사항과 법률을 집행하기 위하여 필요한 사항에 관하여 대통령령을 발할 수 있다”.

28) 헌법 제95조 “국무총리 또는 행정각부의 장은 소관사무에 관하여 법률이나 대통령령의 위임 또는 직권으로 총리령 또는 부령을 발할 수 있다”.

ⅰ) 위임명령

법률 또는 상위명령에 의하여 위임된 사항에 관하여 발하는 명령으로서 위임의 범위 안에서 국민의 권리·의무사항을 새로이 정할 수 있다.

ⅱ) 집행명령

법률의 집행을 위하여 필요한 구체적·기술적 사항을 규율하기 위하여 발하는 명령으로서 법률의 명시적 위임근거가 없더라도 발할 수 있으나 새로운 국민의 권리·의무에 관한 사항을 규율할 수는 없다.

Ⅱ. 근거

1. 위임명령의 근거

⑴ 구체적 위임

위임명령은 헌법 제75조와 헌법 제95조에 따라 법률이나 상위명령에서 구체적으로 범위를 정한 개별적인 수권이 있는 경우에만 가능하다.

⑵ 수권법령의 적법성

법규명령의 근거를 제공하는 수권법률은 법규명령의 제정시점에 유효한 것이어야 한다.

그러나 판례는 수권법령이 없어 무효인 위임명령도 후에 수권법령이 제정되면 그 때부터 유효한 법규명령이 된다고 한다(대판 1995.6.30, 93추83).

⑶ 수권법령의 명시 - 반드시 명시필요없다는 것이 판례

2. 집행명령의 근거 - 상위 법률이나 법규명령의 구체적 수권 불필요

제2 법규명령의 한계

Ⅰ. 법규명령의 한계

1. 위임명령의 한계

위임명령의 한계는 크게 법률의 위임명령에 대한 수권의 한계와 수권에 따른 위임명령 제정상의 한계로 나누어진다.[29]

⑴ 수권의 한계

1) 서

법률의 명령에 대한 입법권의 수권은 권력분립의 원칙 및 국회입법의 원칙의 예외를 이루는 것이기 때문에 무한정으로 인정될 수 없으며 국회입법의 원칙이 기본적으로 유지될 수 있는 한도 내에서 인정되어야 한다.

2) 포괄적 위임의 금지

29) 박균성, 전게서 138면.

헌법 제75조는 '구체적으로 범위를 정하여 위임받은 사항'에 대해서만 위임명령을 발할 수 있다고 하여 법률에 의한 포괄적·일반적인 위임은 허용하지 않고 개별적·구체적 위임이 있어야 한다고 규정하고 있다. 개별적이고 구체적인 위임이기 위하여 요구되는 규율대상의 한정성과 기준의 명확성 정도는 일률적으로 정할 수 없고, 여러 가지 요소를 고려하여 다양한 관점에서 구체화하여야 한다.

판례는 "적어도 법률의 규정에 의하여 이미 대통령령으로 규제될 내용 및 범위의 기본사항이 구체적으로 규정되어 있어 누구라도 당해 법률로부터 대통령령에 규정될 내용의 대강을 예측할 수 있으면 족하고, 이 경우에 있어 그 예측가능성의 유무는 당해 특정조항 하나만을 가지고 판단할 것이 아니고 관련 법조항 전체를 유기적·체계적으로 종합 판단하여야 하며, 각 대상법률의 성질에 따라 구체적·개별적으로 검토하여야 할 것이다"라고 판시하였다(헌재 1994. 7. 29, 93헌가12; 대결 1995. 7. 2, 94마125).

단, 헌법재판소는 대상의 한정성과 기준의 명확성의 정도는 규율대상의 종류와 성격에 따라 달라질 것이므로 급부행정 영역의 경우에는 포괄위임금지의 원칙이 다소 완화될 수 있다고 판시하였(헌재 1991. 2. 11, 90헌가27).

3) 의회유보사항의 위임금지

의회유보원칙은 의회유보사항은 모든 내용을 법률로 정해야 하며 구체적 범위를 정하여 법규명령에 위임할 수 없다는 헌법상 원칙이다. 따라서 의회유보사항에 대하여 구체적 범위를 정하여 법규명령으로 정하도록 규정한 법률은 의회유보원칙위반으로 무조건 위헌인 법률이 된다. 병역복무기간은 의회유보사항이라고 보아야 할 것이다.

4) 수권의 한계 위반의 효과

수권의 한계를 넘는 법률은 위헌인 법률이 된다. 수권법률이 헌법재판소의 위헌법률심판에서 위헌으로 결정된 경우에 당해 수권법률에 의해 제정된 위임명령은 대세적으로 법규성이 상실된다. 그리고 그러한 위임명령에 근거하여 내려진 처분은 원칙상 취소할 수 있는 처분이 된다.

⑵ 위임명령의 제정상 한계

법령으로 새로운 입법사항을 정하기 위하여는 상위 법령의 위임이 있어야 한다. 상위 법령의 위임에 의해 위임명령이 제정될 때에도 다음과 같은 한계가 있다.

2. 집행명령의 한계 - 국민의 권리의무사항 규율 불가

Ⅱ. 법규명령의 성립·적법·효력요건[30]

1. 성립요건

⑴ 주　체

⑵ 형　식 - 조문형식

⑶ 공　포

30) 박균성, 행정법특강

2. 효력요건 - 시행일

3. 적법요건
① 위임명령은 상위법령의 수권이 있어야 제정될 수 있으며 수권의 범위내에서 제정되어야 한다. 집행명령은 위임없이 직권으로 제정할 수 있다.
② 상위법령에 위반한 법규명령은 위법한다.
③ 입법예고제 등 행정입법절차를 위반하여서는 안된다.

제3 법규명령에 대한 통제

I. 법규명령에 대한 통제

1. 입법적 통제

2. 행정적 통제

3. 사법적 통제

⑴ 문제점

⑵ 법원에 의한 통제

1) 서
법원에 의한 법규명령의 통제로는 헌법 제107조에 의한 구체적 규범통제와 항고소송에 의한 통제가 있다.

2) 구체적 규범통제
구체적 규범통제란 추상적인 법규명령의 위헌·위법여부가 재판의 전제가 되는 경우 선결문제로서 법규명령의 위헌 위법여부를 다투는 것을 의미한다. 이에 헌법 제107조 제2항도 “명령·규칙 또는 처분이 헌법이나 법률에 위반되는 여부가 재판의 전제가 된 경우에는 대법원은 이를 최종적으로 심사할 권한을 가진다”라고 규정하고 있다.

3) 법규명령이 항고소송의 대상인 처분에 해당하는지

① 학설
① 법규명령형식을 취하지만 행정행위의 개념징표인 규율사건의 구체성을 가짐으로써 행정행위의 성질을 갖는 처분적 법규명령만을 항고소송의 대상인 처분으로 인정하는 협의설, ② 협의설에서의 처분적 법규명령뿐만 아니라 집행행위의 매개없이 국민의 권리의무변동을 직접 일으키는 집행적 법규명령도 항고소송의 대상인 처분으로 인정하는 중간설, ③ 별도의 집행행위 없이 국민의 권익에 직접 영향을 미치는 법규명령은 항고소송의 대상인 처분으로 인정하는 광의설이 대립한다.

② 판례

중간설과 광의설은 과거 판례는 협의설을 취하였으나 최근에는 판례가 중간설이나 절충설을 취하여 항고소송의 대상이 되는 법규명령의 범위를 넓히고 있다고 주장한다.

그러나 판례는 최근에도 집행행위의 매개없이 국민의 권리의무변동을 직접 일으키는 법규명령에 대하여 처분성을 부정하고 있다.

⑶ 헌법재판소에 의한 통제 - 법규명령에 대한 헌법소원 가능여부

1) 문제점

법규명령에 대한 헌법소원을 인정한 명문의 규정이 없고 헌법 제107조 제2항의 규정취지상 법규명령이 헌법소원의 대상이 되는지 견해의 대립이 있다.

2) 학설

① 헌법 제107조 제2항은 법규명령의 위헌위법여부가 재판의 전제가 된 경우에 한하여 법원이 심판한다는 것일 뿐, 법규명령 그 자체에 의하여 기본권이 직접 침해되었을 때 그 법규명령 자체를 다투는 제도가 아니다. 따라서 법규명령으로 직접 국민의 기본권침해받았을 때는 다른 권리구제수단이 없으므로 헌법소원으로 기본권침해를 구제하여야 한다는 긍정설과, ② 법규명령에 대하여 헌법소원을 인정하는 것은 헌법 제107조에 반한다는 점, 법규명령에 대한 헌법소원은 헌법소원의 요건으로서 기본권침해의 직접성이 없거나 보충성원칙에 반한다는 점 등을 논거로 법규명령에 대한 헌법소원을 부정하는 부정설이 대립한다.

3) 판례

헌법재판소는 법규명령이 집행행위의 매개없이 국민의 기본권을 직접 침해하는 경우에는 헌법소원의 대상이 된다고 판시하여 긍정설의 입장을 취하고 있다.

4. 국민의 의한 통제

법규명령을 제정하는 과정에서 청문 등에 의해 국민의 의사를 반영하거나, 매스컴 혹은 압력단체의 활동 등 여론에 의한 통제를 말한다. 우리나라도 행정절차법에 의하여 입법예고제를 채택하고 있다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 법규명령의 성립・발효요건의 설명으로 옳지 않은 것은? (2005 관세사)

① 상위법의 근거가 있어야 한다.
② 대통령령은 법제처의 심사와 국무회의의 심의를 거쳐야 한다.
③ 법규명령의 예고는 관보・공고나 인터넷, 신문, 방송 등의 방법으로 할 수 있다.
④ 예고된 입법안에 대해서 누구든지 그 의견을 제출할 수 있다.
⑤ 대통령령・총리령 및 부령은 특별한 규정이 없는 한 공포한 날로부터 효력이 발생한다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

대통령령, 총리령 및 부령은 특별한 규정이 없으면 공포한 날부터 20일이 경과함으로써 효력을 발생한다(법령등공포에관한법률 제13조). 다만, 국민의 권리 제한 또는 의무 부과와 직접 관련되는 법률, 대통령령, 총리령 및 부령은 긴급히 시행하여

야 할 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 공포일부터 적어도 30일이 경과한 날부터 시행되도록 하여야 한다(동법률 제13조의2).

정답 ⑤

2. 현행 실정법상 행정입법에 관한 통제로 볼 수 없는 것은? (2001 입법고시)

① 긴급명령, 긴급재정·경제명령에 대한 국회의 승인
② 국회의 국정조사 및 감사
③ 국회의 국무총리 및 국무위원에 대한 해임건의
④ 국회법상 법규명령의 국회에의 송부
⑤ 행정입법에 대한 국회의 동의유보

해설 & 정답

유형 법률지식형

의회에 의한 통제는 법규명령의 민주적 정당성을 확보하고 사전에 그 권리침해를 시정한다는 점에서 가장 실효성 있는 통제수단으로 인정되고 있다. 그럼에도 불구하고 우리의 경우 아직 제도적으로 법규명령에 대한 의회의 관여장치가 제대로 도입되지 못하고 있는 점은 문제가 아닐 수 없다. 현재 우리나라는 독일과는 달리 입법부에 의한 동의유보는 원칙적으로 부인되고, 예외적으로 대통령의 긴급명령권 발동시 국회에 보고하여 승인을 얻도록 하는 규정(헌법 제76조 제3항)만 있다.

정답 ⑤

3. 다음 중 법규명령의 통제에 관한 설명으로 틀린 것은? (2007 국회8급)

① 의회에 의한 통제로는, 법규명령의 성립·발효에 대한 동의 또는 승인권이나 일단 유효하게 성립한 법규명령의 효력을 소멸시키는 권한을 의회에 유보하는 방법에 의한 통제인 직접적 통제와 의회가 법규명령의 성립이나 효력발생에 직접적으로 관여하는 것이 아니라 국정감사권과 같은 방법을 이용한 간접적 통제가 있다.
② 사법적 통제에 있어 우리나라는 추상적 규범통제제도를 취하고 있기 때문에 행정청의 '처분 등'에 의하지 않는 일반적인 법규명령에 대해서도 규범통제를 할 수 있다.
③ 헌법재판소는 법령자체에 의한 직접적인 기본권침해 여부가 문제가 되었을 경우 그 법령의 효력을 직접 다투는 것을 소송물로 하여 일반 법원에 구제를 구할 수 있는 절차는 존재하지 아니하므로 바로 헌법소원의 대상이 된다고 하였다.
④ 행정적 통제수단으로는, 상급행정청의 하급행정청에 대한 지휘·감독권과 같은 행정감독권에 의한 통제와 일정한 절차를 거쳐 법규명령을 발하도록 하는 절차적 통제가 있다.
⑤ 오늘날에는 언론이나 시민단체 활동 등을 통하여 법규명령을 통제하는 것도 가능하며, 이를 국민에 의한 통제라고도 한다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

헌법은 "명령·규칙 또는 처분이 헌법이나 법률에 위반되는 여부가 재판의 전제가 된 경우에는 대법원은 이를 최종적으로 심사할 권한을 가진다(제107조 제2항)"라고 함으로써 구체적 규범통제를 취하고 있다.

정답 ②

♣ 학습내용 정리

1. 법규명령에는 위임명령과 집행명령이 있다.
2. 위임명령의 한계로 수권의 한계와 제정상 한계가 있다.
3. 법규명령에 대하여 원칙적으로 구체적 규범통제(간접통제)를 하여야 하고 예외적으로 처분적 법규에 대하여는 항고소송을 제기할 수 있다.

제8강 행정규칙

♣ 학습목표

행정규칙의 의의 및 법적성질을 이해하고 법규명령형식의 행정규칙과 법령 보충적 행정규칙의 법적 성질에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

행정규칙의 의의 및 법적 성질
법규명령형식의 행정규칙과 법령 보충적 행정규칙의 법적 성질

♣ 사전테스트

1. 행정규칙을 위반하면 위법하다.
   정답 : ×

2. 부령형식의 행정규칙은 법규명령이라는 것이 판례이다.
   정답 : X

3. 법령 보충적 행정규칙은 법규명령으로서 성질이 인정된다는 것이 판례이다.
   정답 : ○

♣ 돌발퀴즈

재량준칙인 경우에는 행정청에 의하여 반복되어 시행되더라도 이는 행정법상 일반원칙에 따른 대외적인 구속력을 가지는 것은 아니다.

[정답] ×

[해설] 행정규칙은 일반적으로 행정조직 내부에서만 효력을 가지는 것이나, 행정규칙이 법령의 규정에 의하여 행정관청에 법령의 구체적 내용을 보충할 권한을 부여한 경우나 재량권 행사의 준칙인 규칙이 그 정한 바에 따라 되풀이 시행되어 행정관행이 이룩되게 되면, 평등의 원칙이나 신뢰보호의 원칙에 따라 행정기관은 그 상대방에 대한 관계에서 그 규칙에 따라야 할 자기구속을 당하게 되는 경우에는 대외적인 구속력을 가지게 되는바, 이러한 경우에는 헌법소원의 대상이 될 수도 있다(헌재 1990.9.3, 90헌마13).

♣ 강의내용

제1 행정규칙

Ⅰ. 의의

행정조직내부에서 상급행정기관이 상위 법령의 수권없이 그 독자적 권한으로 하급행정기관에게 그의 임무수행과 조직에 관하여 제정한 일반적·추상적 규율이라고 정의된다(훈령·예규·지침 등의 형식).

Ⅱ. 종 류(협의의 행정규칙)

1. 형식에 따른 분류

행정규칙은 훈령·지시·예규·일일명령 등의 형식으로 구분된다.

2. 내용에 따른 분류

⑴ 조직규칙

⑵ 행위지도규칙(근무규칙) : 행정기관의 대외적 활동의 지침을 정한 규칙

1) 규범해석규칙

2) 재량준칙

3) 간소화지침

⑶ 법률대위규칙

3. 고 시[31]

⑴ 의의

고시는 행정청이 결정한 사항 및 기타 일정한 사항을 일반인에게 알리는 행위를 말한다.

⑵ 법적성질

고시의 내용에 비추어 고시의 법적 성질을 정하여야 한다. 즉, 고시가 일반적·추상적 규율을 가질 때에는 상위법령의 수권여부에 따라 법령보충규칙(다수설과 판례는 법규명령으로 봄) 또는 행정규칙에 해당하고, 구체적 규율을 가질 때에는 일반처분에 해당한다고 보아야 한다.

Ⅲ. 행정규칙의 성질 및 효력

1. 문제점

행정규칙에 법규성이 있는가의 문제로, 이러한 논의는 결국 행정규칙이 대외적으로 국민이나 법원을 구속하는 힘이 있는지, 이에 위반한 행정처분이 위법한지에 모아진다.

---

31) 장태주, 행정법개론, 제335면.

2. 행정규칙의 내부적 효력 - 대내적 구속력 있음

3. 행정규칙의 외부적 효력(법규성의 인정여부)에 관한 견해대립

⑴ 학설

① 행정규칙을 광의의 법규로 보나 대외적 구속력을 부정하는 견해, ② 대외적 구속력이 없으므로 비법규로 보는 견해, ③ 행정부의 시원적 입법권을 인정하여 법규로 보아 대외적 구속력을 인정하는 견해, ④ 재량준칙 등은 평등원칙 등과 결합하여 준법규로 효력이 있다는 견해, ⑤ 행정규칙의 종류에 따라 대외적 구속력여부를 결정하는 견해 등이 대립한다.

⑵ 판례

판례는 원칙적으로 행정규칙은 행정청 내부의 사무처리 기준 등을 정한 것으로서 행정조직 내에서 적용되는 행정명령의 성격을 지닐 뿐 국민에 대한 대외적 구속력은 없다고 보아야 한다고 판시하고 있다.

제2 법규명령형식의 행정규칙과 법령보충적 행정규칙

Ⅰ. 개 설

Ⅱ. 법규명령 형식의 행정규칙

1. 의 의

법규명령형식의 행정규칙이란, 당해 규범의 내용은 행정사무처리기준(재량권행사의 기준)에 불과하지만 그것이 대통령령이나 부령 등 법규명령의 형식을 취하는 경우를 말한다(영업정지처분 등 제재처분의 기준이나 과징금액수의 기준을 정한 시행령 및 시행규칙).

2. 법적 성질

⑴ 학 설

1) 형식설(법규명령설)

① 법규명령으로 정해야 될 사항과 행정규칙으로 정해야 될 사항이 구별되는 것은 아니라는 점, ② 법규명령은 행정규칙과 달리 엄격한 제정절차를 거친다는 점, ③ 오늘날 법규는 형식에 의해 그 규범력이 결정된다는 점 등을 논거로 한다.

2) 절충설(수권여부에 따라 구별하는 견해)

상위 법령의 수권여부에 따라 법규명령인지여부가 결정된다고 주장한다.

3) 실질설(행정규칙설)

① 법규명령으로 보게 되면 재량통제의 범위가 축소된다는 점, ② 행정규칙으로 보는 것이 구체적으로 타당한 해결을 가능하게 해준다는 점 등을 논거로 한다.

⑵ 판 례

판례는 일관하여 그 형식이 부령이지만 그 내용이 행정기관 내부의 사무처리준칙을 규정한 것에 불과한 경우에는 대외적 구속력을 부정하여 행정규칙으로서의 성질을 인정하였다.

그러나 그 형식이 대통령령 인 경우에는 이와는 달리 법규명령으로 인정하고 있다.[32]

Ⅲ. 법령보충규칙

1. 의의

① 다수설은 법령보충규칙을 고시, 공고, 훈령, 지침 등의 행정규칙 형식을 갖추고 있으나 상위 법령의 위임에 의해 법규사항(국민의 권리의무에 관한 사항)을 규율하는 규범으로 정의한다. ② 이에 비해 일부견해는 행정기관이 고시 훈령 등의 형식으로 상위법령을 구체화한 규범이라는 정의한다. 이에 따르면 상위 법령의 위임이 없더라도 상위법령을 구체화한 내용을 규정하면 법령보충규칙에 해당한다. ③ 생각건대 상위 법령의 위임 없이 제정된 규범은 내용과 상관없이 행정규칙으로 보아야 하므로 다수설이 타당하다. 이하에서는 다수설에 따라 검토하도록 하겠다.

2. 법적 성질

⑴ 학설

① 수권법령과 결합하여 대외적 구속력을 가지므로 법규명령이라는 견해, ② 규범구체화행정규칙으로 대외적 구속력을 인정하는 견해, ③ 헌법에 규정된 법규명령형식이 아니므로 행정규칙이라는 견해, ④ 헌법위반으로 위헌무효라는 견해, ⑤ 수권법령과 결합하여 대외적 구속력을 가지나 법규명령 제정절차를 거치지 않았고 행정규칙의 형식이므로 행정규칙으로 보는 견해 등이 대립한다.

⑵ 판례

판례는 '훈령형식으로 되어 있더라도 소득세법시행령(수권법령)의 위임에 따라 그 내용을 보충하는 기능을 가지면서 그와 결합하여 대외적으로 구속력이 있는 법규명령으로서 효력을 가지는 것이므로'라고 판시하여 법령보충규칙의 대외적 구속력을 인정하고 있다. 그리고 이러한 대외적 구속력을 인정하는 이유에 대하여 "이는 행정규칙이 갖는 일반적 효력이 아니라 행정기관에 법령의 구체적 내용을 보충할 권한을 부여한 법령 규정의 효력에 근거하여 예외적으로 인정되는 것이다"라고 판시하였다.

즉, 판례는 ① 상위 법령의 위임이 있고 ② 그 내용이 상위 법령의 내용을 보충하는 경우에는 ③상위 법령의 위임한계를 벗어나지 않는 한 대외적 구속력을 인정하고 있다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 다음은 행정입법에 대한 설명이다. 옳지 못한 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

(변호사 모의시험 문제)

① 넓은 의미의 행정입법에는 법규명령 외에 행정규칙도 포함된다고 볼 수 있으나, 행정규칙은 원칙적으로 대외적 구속력을 갖지 못한다는 점에서 법규명령과 구분된다.

② 법률에 위반된 시행령은 무효이므로 이러한 시행령에 근거한 행정처분은 그 시행령이 법원에 의해 무효로 선언되기 이전에 행하여졌다 하더라도 특별한 사정이 없는 한 무효임이 원칙이다.

---

32) 대판 1997.12.26, 97누15418

③ 개별·구체성을 갖는 처분적 법규명령은 항고소송의 대상이 된다.
④ 행정규칙 중 법령보충적 행정규칙은 대외적 구속력을 갖는다.
⑤ 재량준칙은 행정규칙에 불과하여 대외적 구속력이 없으나, 그에 위반된 행정처분은 구체적 사정에 따라 평등원칙에 반하는 위법한 처분으로 될 수 있다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 훈령이란 행정조직 내부에 있어서 그 권한의 행사를 지휘감독하기 위하여 발하는 행정명령으로서 훈령, 예규, 통첩, 지시, 고시, 각서 등 그 사용명칭 여하에 불구하고 공법상의 법률관계 내부에 관한 준칙 등을 정하는데 그치고 대외적으로는 아무런 구속력도 가지는 것이 아니다(대판 1983.2.22, 82누324).

② [대법원의 태도] 행정청이 법률에 근거하여 행정처분을 한 후에 헌법재판소가 그 법률을 위헌으로 결정하였다면 그 행정처분은 결과적으로 법률의 근거가 없이 행하여진 것과 마찬가지가 되어 하자가 있다고 할 것이나, 하자 있는 행정처분이 당연무효가 되기 위하여는 그 하자가 중대할 뿐만 아니라 명백한 것이어야 하는데, 일반적으로 법률이 헌법에 위반된다는 사정은 헌법재판소의 위헌결정이 있기 전에는 객관적으로 명백한 것이라고 할 수 없으므로 특별한 사정이 없는 한 이러한 하자는 위 행정처분의 취소사유에 해당할 뿐 당연무효 사유는 아니라고 보아야 한다(대판 2000.6.9, 2000다16329).

[헌법재판소의 태도] 행정처분 자체의 효력이 쟁송기간 경과 후에도 존속 중인 경우, 특히 그 처분이 위헌법률에 근거하여 내려진 것이고 그 행정처분의 목적달성을 위하여서는 후행 행정처분이 필요한데 후행 행정처분은 아직 이루어지지 않은 경우와 같이 그 행정처분을 무효로 하더라도 법적 안정성을 크게 해치지 않는 반면에 그 하자가 중대하여 그 구제가 필요한 경우에 대하여서는 그 예외를 인정하여 이를 당연무효사유로 보아서 쟁송기간 경과 후에라도 무효확인을 구할 수 있는 것이라고 봐야 할 것이다(헌재 1994.6.30, 92헌바23).

[사안의 경우] 대법원, 헌법재판소 중 어느 견해에 의하더라도 법률에 위반된 시행령에 근거한 행정처분은 취소사유에 불과한 하자를 가진다.

③ 조례가 집행행위의 개입 없이도 그 자체로서 직접 국민의 구체적인 권리의무나 법적 이익에 영향을 미치는 등의 법률상 효과를 발생하는 경우 그 조례는 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하고, 이러한 조례에 대한 무효확인소송을 제기함에 있어서 행정소송법 제38조 제1항, 제13조에 의하여 피고적격이 있는 처분 등을 행한 행정청은, 행정주체인 지방자치단체 또는 지방자치단체의 내부적 의결기관으로서 지방자치단체의 의사를 외부에 표시한 권한이 없는 지방의회가 아니라, 구지방자치법(1994.3.16. 법률 제4741호로 개정되기 전의 것) 제19조 제2항, 제92조에 의하여 지방자치단체의 집행기관으로서 조례로서의 효력을 발생시키는 공포권이 있는 지방자치단체의 장이다(대판 1996.9.20, 95누8003).

④ 대법원은 "보건사회부장관이 정한 1994년도 노인복지사업지침은 노령수당의 지급대상자의 선정기준 및 지급수준 등에 관한 권한을 부여한 노인복지법 제13조 제2항, 같은법 시행령 제17조, 제20조 제1항에 따라 보건사회부장관이 발한 것으로서 실질적으로 법령의 규정내용을 보충하는 기능을 지니면서 그것과 결합하여 대외적으로 구속력이 있는 법규명령의 성질을 가지는 것으로 보인다(대판 1996.4.12, 95누7727)"라고 판시하여 행정규칙 중 법령보충적 행정규칙은 대외적 구속력을 갖는다는 입장이다.

⑤ 재량준칙도 직접적인 외부적 효력을 갖는다고 할 수 없다. 그러나 행정청이 재량준칙에서 벗어난 결정을 하는 경우에는 재량권의 공정한 행사의 확보, 평등취급의 원칙, 신뢰보호의 요청에서 준칙과 다른 판단을 하는 합리적인 이유가 있어야 한다. 헌법재판소도 재량준칙의 경우에 행정의 자기구속의 법리에 의하여 외부적 효과를 갖는다고 판시한다(헌재 1990.9.3, 90헌마13).

※ 참조판례

> 행정규칙이 법령의 규정에 의하여 행정관청에 법령의 구체적 내용을 보충할 권한을 부여한 경우, 또는 재량권행사의 준칙인 규칙이 그 정한 바에 따라 되풀이 시행되어 행정관행이 이룩되게 되면, 평등의 원칙이나 신뢰보호의 원칙에 따라 행정기관은 그 상대방에 대한 관계에서 그 규칙에 따라야 할 자기구속을 당하게 되고, 그러한 경우에는 대외적인 구속력을 가지게 된다 할 것이다(헌재 1990.9.3, 90헌마13).

정답 ②

2. 행정입법에 관한 판례의 입장과 다른 것은? (2003 행정고시)

① 식품제조영업허가기준에 관한 고시는 구 식품위생법 제23조의3 제4호에 따라 구 보건사회부장관이 발한 것으로서, 실질적으로 법의 규정을 보충하는 기능을 지니면서 그것과 결합하여 대외적으로 구속력을 발한다.

② 부령상의 제재처분기준에 관한 규정에서 위반 횟수에 따라 가중처분하게 되어 있는 경우에도, 제재적 처분의 제재기간 경과 후에 행정처분의 취소를 구할 법률상 이익은 없다.

③ 구 주택건설촉진법 제7조 제2항의 위임규정에 터잡은 시행령(대통령령) 제10조의3 제1항 [별표1]에 근거한 영업정지처분을 함에 있어, 처분청은 모법이 정한 범위 내에서 위 시행령상의 기준에 구애받지 않고 정지기간을 정할 재량권이 있다.

④ 구 청소년보호법 제49조에 따른 시행령(대통령령) 제40조 [별표6]의 위반행위의 종별에 따른 과징금처분기준은 법규명령이기는 하나, 사안에 따라 적정한 과징금의 액수를 정하여야 하므로 그 기준에 명시된 수액은 정액이 아니라 최고한도액으로 보아야 한다.

⑤ 구법의 위임에 의해 유효했던 법규명령이 법개정으로 위임의 근거가 없어지게 되면 그때부터 무효인 법규명령이 된다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 대판 1994.3.8, 92누1728

② 대판 1995.10.17, 94누14148 全合

③ 시행령 제10조의3 제1항 [별표1]은 법 제7조 제2항의 위임규정에 터잡은 규정형식상 대통령령이므로 그 성질이 부령인 시행규칙이나 또는 지방자치단체의 규칙과 같이 통상적으로 행정조직 내부에 있어서의 행정명령에 지나지 않는 것이 아니라 대외적으로 국민이나 법원을 구속하는 힘이 있는 법규명령에 해당한다고 할 것이다. 따라서 이 사건 처분이 재량행위인지 여부를 결정함에 있어서는, 먼저 그 근거가 된 시행령 제10조의3의 규정과 같은 조 제1항 [별표1]의 규정형식이나 제체 또는 문언을 살펴야 하는바, 이들 규정들은 영업의 정지처분에 관한 기준을 개개의 사유별로 그에 따른 영업정지기간을 일률적으로 확정하여 규정하는 형식을 취하고 있고 다만 영업정지 사유가 경합되거나(시행령 제10조의3 제2항 제2호) 사업실적미달로 인하여 영업정지처분사유에 해당하게 된 경우(같은 조 제3항)에 한하여 예외적으로 그 정지기간 결정에 재량의 여지를 두고 있을 뿐이므로, 이 사건의 경우와 같이 등록을 마친 주택건설사업자가 '법 제38조 제14항의 규정에 의한 하자보수를 정당한 사유 없이 사용검사권자가 지정한 날까지 이행하지 아니하거나 지체한 때'에는 관할관청으로서는 위 [별표1]의 제2호 (타)목 ⑴의 규정에 의하여 3개월간의 영업정지처분을 하여야 할 뿐 달리 그 정지기간에 관하여 재량의 여지가 없다고 할 것이다(대판 1997.12.26, 97누15418).

④ 대판 2001.3.9, 99두5207

⑤ 일반적으로 법률의 위임에 의하여 효력을 갖는 법규명령의 경우, 구법에 위임의 근거가 없어 무효였더라도 사후에 법개정으로 위임의 근거가 부여되면 그 때부터는 유효한 법규명령이 되나, 반대로 구법의 위임에 의한 유효한 법규명령이 법개정으로 위임의 근거가 없어지게 되면 그 때부터 무효인 법규명령이 되므로, 어떤 법령의 위임 근거 유무에 따른 유효 여부를 심사하려면 법개정의 전·후에 걸쳐 모두 심사하여야만 그 법규명령의 시기에 따른 유효·무효를 판단할 수 있다(대판 1995.6.30, 93추83).

정답 ③

3. 다음은 행정입법에 관하여 설명하고 있다. 옳지 않은 것은? (2003 입법고시)

① 현대 행정에서는 여러 가지 면에서 의회입법의 한계성이 나타남에 따라 행정입법의 중요성이 증대되었다고 할 수 있다.

② 행정입법권의 확대가 불가피함에도 불구하고 의회입법권의 중요성은 여전히 크다고 할 수 있다.

③ 행정입법의 종류로는 대국민적 구속력을 가지는가의 여부에 따라 크게, 법규명령과 행정규칙으로 나뉜다.

④ 행정입법 중 법규명령에 위반한 행정행위는 원칙적으로 위법한 행정행위로 된다.

⑤ 현대 행정의 유동성에 효과적으로 대처하기 위하여 의회입법이 더욱 골격 입법화되는 것은 시대적인 요청이기도 하다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

대통령은 법률에서 구체적으로 범위를 정하여 위임받은 사항과 법률을 집행하기 위하여 필요한 사항에 관하여 대통령령을 발할 수 있다(헌법 제75조)라고 헌법에서 규정하여 개별적・구체적 위임만 가능하므로, 일반적・포괄적・전면적 위임이나 백지위임・골격입법 등은 허용되지 않는다.

정답 ⑤

♣ 학습내용 정리

1. 행정규칙은 대외적 구속력이 없다는 것이 판례이다.
2. 법규명령형식의 행정규칙의 법적성질에 대하여 다수설은 법규명령으로 인정한다.
3. 법령보충적 행정규칙의 법적성질에 대하여 다수설과 판례는 법규명령으로 인정한다.

제9강 행정계획

♣ 학습목표

행정계획의 법적성질을 이해하고 행정계획의 한계로서 계획재량과 형량명령원칙 및 계획보장청구권에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

행정계획의 법적성질
계획재량과 형량명령원칙
계획보장청구권

♣ 사전테스트

1. 행정계획의 법적성질이 행정행위라는데 학설이 일치한다.
   정답 : ×

2. 일반재량이 계획재량보다 자유의 범위가 넓다.
   정답 : X

3. 계획존속청구권은 일반적으로 인정되지 않는다.
   정답 : ○

♣ 돌발퀴즈

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」상 도시관리계획은 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하지 않는다.

[정답] ×

[해설] 도시계획법(현 국토의계획및이용에관한법률) 제12조 소정의 고시된 도시계획결정은 특정 개인의 권리 내지 법률상의 이익을 개별적이고 구체적으로 규제하는 효과를 가져 오게 하는 행정청의 처분이라 할 것이고, 이는 행정소송의 대상이 된다(대판 1982.3.9, 80누105).

♣ 강의내용

제1 행정계획의 의의 및 법적 성질

Ⅰ. 의의

행정계획이란 행정주체가 장래의 질서있는 행정활동을 위한 목표를 설정하고 그 목표를 달성하기 위하여 관련된 행정수단을 종합·조정하는 것을 내용으로 하는 활동기준 또는 그 기준설정 행위를 말한다(대판 1996. 11. 22, 96누8567).

Ⅱ. 법적 성질

1. 문제점

구속적 행정계획에 관한 논의로, 특히 국토의계획및이용에관한법률에 의한 도시군관리계획결정에 처분성이 있는지가 문제된다.

2. 학 설

① 일반·추상적 규율이라는 점에서 입법행위로 보는 견해, ② 도시군관리계획결정은 국민에게 직접적으로 권리제한의 효과를 발생시키므로 행정행위라는 견해, ③ 행정계획에는 여러 종류의 계획이 있다는 사실에 유의할 필요가 있다고 하면서 개별적으로 검토하여야 한다는 견해, ④ 행정계획은 입법행위도 행정행위도 아닌 특수한 법제도이지만 구속력을 가진 점에서 항고소송의 대상인 처분에 해당한다는 견해 등이 대립한다.

3. 판례의 태도

판례는 구 도시계획법상 도시계획결정의 처분성을 긍정하고 있다.

Ⅲ. 절 차

우리나라에는 행정계획의 책정절차에 관한 일반적 규정은 없고, 개별법에 단편적으로 규정되어 있을 뿐이나 보통 심의회의 조사·심의, 관계기관간의 조정, 이해관계인의 참여, 공고의 단계를 거쳐 책정된다.

도지사가 시장 또는 군수로부터 신청받은 당초의 도시관리계획안을 변경하고자 하는 경우 그 내용을 시장 또는 군수에게 송부하여 주민의 의견을 청취하는 절차를 거쳐야 한다는 판례

구 국토의 계획 및 이용에 관한 법률(2009. 3. 25. 법률 제9552호로 개정되기 전의 것, 이하 '법'이라 한다) 제28조 제1항, 제2항, 제3항, 제4항, 구 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령(2010. 4. 20. 대통령령 제22128호로 개정되기 전의 것, 이하 '시행령'이라 한다) 제22조 제5항이 관할 행정청으로 하여금 도시관리계획을 입안할 때 해당 도시관리계획안의 내용을 주민에게 공고·열람하도록 한 것은 다수 이해관계자의 이익을 합리적으로 조정하여 국민의 권리에 대한 부당한 침해를 방지하고 행정의 민주화와 신뢰를 확보하기 위하여 국민의 의사를 그 과정에 반영시키는 데 그 취지가 있다.

이러한 주민의견청취 절차의 의의와 필요성은 시장 또는 군수가 도시관리계획을 입안하는 과정에서뿐만 아니라 도시관리계획안이 도지사에게 신청된 이후에 내용이 관계 행정기관의 협의 및 도시계획위원회의 심의 등을 거치면서 변경되는 경우에도 마찬가지이고, 도지사가 도시관리계획의 결정 과정에서 신청받은 도시관리계획안의 중요한 사항을 변경하는 것은 그 범위에서 시장 또는 군수에 의하여 신청된 도시관리계획안을 배제하고 도지사가 직접 도시관리계획안을

입안하는 것과 다르지 않다. 그러므로 도지사가 관계 행정기관의 협의 등을 반영하여 신청받은 당초의 도시관리계획안을 변경하고자 하는 경우 내용이 해당 시 또는 군의 도시계획조례가 정하는 중요한 사항인 때에는 다른 특별한 사정이 없는 한 법 제28조 제2항, 시행령 제22조 제5항을 준용하여 그 내용을 관계 시장 또는 군수에게 송부하여 주민의 의견을 청취하는 절차를 거쳐야 한다(대법원 2015.01.29. 선고 2012두11164 판결)

제2 계획재량과 형량명령원칙

I. 계획재량과 형량명령원칙

1. 개 설

⑴ 의 의

행정기관이 계획결정을 함에 있어서는 법적으로 그 내용을 미리 결정할 수 없을 정도의 넓은 범위의 형성여지를 갖는다. 이러한 넓은 형성여지를 계획재량이라고 한다.

⑵ 특수성

계획재량은 행정목표의 설정이나 행정목표를 효과적으로 달성할 수 있는 수단의 선택 및 조정에 있어서 인정된다. 이에 비해 일반 행정재량은 요건충족에 의한 효과결정 하는 것을 내용으로 한다.

2. 법적성질

⑴ 학설

① 계획재량의 수권규범은 통상적인 재량행위의 수권규범과 달리 목적과 수단의 형식을 취하고 있다는 점, 계획재량에는 형량명령원칙이라는 특유의 하자이론이 있다는 점을 논거로 계획재량과 통상적인 재량을 구별하는 견해와 ② 수권규범의 구조적 특성은 중요하지 않으며 형량명령은 그 내용이 재량의 남용사유인 비례원칙과 같다는 점 등을 논거로 계획재량과 통상적인 재량의 구별을 부정하는 견해가 대립한다.

⑵ 판례의 태도

판례는 행정계획에 있어 계획재량이라는 광범위한 형성의 자유가 인정된다고 하고 이러한 형성의 자유에 관한 한계원리로서 형량명령원칙을 반영하여 “형량하자”가 있으면 당해 행정계획결정은 위법하다고 판시하고 있다(대판 2007. 4. 12, 2005두1893).

3. 형량명령원칙과 형량의 하자

⑴ 형량명령원칙의 의의

형량명령원칙이란 행정계획을 수립함에 있어서 관련된 이익을 정당하게 형량하여야 한다는 원칙을 말한다. 형량명령원칙은 계획재량의 통제를 위하여 형성된 원칙이다.

⑵ 형량 하자

행정계획이 형량명령원칙의 내용에 반하는 경우에 형량하자가 있게 된다.

따라서 행정청이 행정계획을 결정함에 있어 첫째, 형량을 전혀 행하지 않은 경우(형량의 해태), 둘째, 형량을 함에 있어 반드시 고려하여야 할 사항을 빠뜨리고 형량을 한 경우(형량의 흠결), 셋째, 형량에 있어 공익과 사익의 가치를 잘못 평가한 경우(평가의 과오), 넷째 공익과 사

익의 조정이 객관적으로 보아 비례원칙을 위반한 것으로 판단되는 경우(오형량) 등의 경우에는 형량의 하자가 있는 것이 되어 당해 행정계획은 위법한 것이 된다.

제3 행정계획과 권리구제

1. 사전적 권리구제 - 행정절차법 규정 없음

2. 사후적 권리구제

⑴ 취소쟁송의 가능성

⑵ 형량명령원칙 - 전술 참조

⑶ 행정상 손실보상문제 - 자세한 것은 후술 손실보상 참조

3. 행정계획과 신뢰보호 : 계획보장청구권

⑴ 계획보장청구권의 의의

계획보장청구권의 의의에 대하여 다수설은 행정계획의 폐지 변경에 대하여 당사자가 자신에게 유리하게 당초 행정계획의 존속이나 준수를 청구하고, 그러한 청구를 할 수 없어 계획의 개폐를 저지할 수 없는 경우에는 경과조치 등 대상조치를 청구하며, 이 역시 인정되지 못하거나 인정되더라도 계획변경으로 인한 손해가 완전히 전보될 수 없는 경우에는 손해배상이나 손실보상을 청구할 수 있는 권리로 정의한다.

이에 비해 일부견해는 계획보장청구권이란 책정되어 시행중인 구체적인 계획을 폐지하거나 변경하는 경우, 이로 인해 손실을 입은 개인이 계획주체에 대해 그 손실보상을 청구할 수 있는 권리라고 정의한다.

⑵ 계획보장청구권의 내용

1) 계획존속청구권

행정계획의 변경이나 폐지에 대하여 그 행정계획의 유지와 계속적 존속을 요구할 수 있는 당사자의 권리를 의미한다. 계획존속청구권을 인정할 것인가에 대해, 통설과 판례는 이러한 청구권을 일반적인 형태로는 허용되지 않는다고 본다. 만약 일반적인 형태로 인정한다면, 너무 일방적으로 개인이 갖는 신뢰보호라는 이익만을 강조하여 행정계획이 추구하는 공익적 측면을 도외시하는 결과가 되기 때문이다.

그러나 개별적인 경우에는 구체적인 사안을 고려하여 계획변경이나 폐지를 통하여 달성하고자 하는 공익보다 당사자의 신뢰보호의 요청이 더 클 때에는 이를 인정할 수도 있을 것이다.

2) 계획이행(준수)청구권

이는 행정계획의 준수와 집행을 요구할 수 있는 청구권을 의미한다. 이 청구권도 일반적으로는 인정되지 않는다.

3) 계획변경청구권

계획변경청구권이란 사정변경 등을 이유로 사인이 기존계획의 변경을 청구할 수 있는 권리를 말한다. 일반적으로 사인이 계획의 변경을 구할 수 있는 청구권을 갖는다는 것은 행정계획의 공익관련성 등에 비추어 인정되기 힘들다.

그러나 예외적으로 법규상 또는 조리상 계획변경신청권이 인정되는 경우가 있다. 첫째 일정한 행정처분을 구하는 신청을 할 수 있는 법률상 지위에 있는 자의 국토이용계획변경신청을 거부하는 것이 실질적으로 당해 행정처분 자체를 거부하는 결과가 되는 경우, 둘째 도시계획구역내 토지 등을 소유하고 있는 주민이 도시계획입안권자에게 도시계획변경입안을 신청하는 경우, 셋째 문화재보호구역내의 토지소유자가 문화재보호구역의 지정해제를 신청하는 경우 등에는 신청인에게 계획변경신청권이 인정된다는 것이 판례의 입장이다.

4) 경과조치청구권

이는 계획에 따라 일정한 조치를 취하였으나 이후 계획이 변경 폐지되는 경우, 이로 인해 계획에 따른 처분을 행한 자가 입게 되는 재산상의 손실을 전보할 경과조치나 일정한 적응조치를 요구하는 권리를 말한다. 이러한 권리도 별도의 법적 근거규정이 없는 이상 일반적인 형태로는 인정되지 않는다고 할 것이다.

5) 손실보상청구권

가장 일반적인 의미에서 흔히 계획보장청구권의 내용은 행정계획의 폐지 변경에 따라 이를 신뢰한 개인에게 금전적인 보상을 행하는 것을 내용으로 하는 손실보상청구권이다.

6) 손해배상청구권

위법한 계획의 변경이나 폐지로 인하여 가해진 손해에 대해서는 국가배상법에 근거하여 국가배상청구가 가능하다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 행정계획에 관한 설명으로 옳은 것은? (2009 국회8급)

① 도시관리계획 결정의 법적 성질을 행정처분으로 보지 아니하는 것이 판례의 입장이다.
② 계획재량과 일반행정재량 사이에는 어떠한 양적·질적 차이도 존재하지 아니한다고 보는 것이 통설적 견해이다.
③ 판례에 따르면 도시관리계획을 입안·결정함에 있어 이익형량의 고려대상에 포함시켜야 할 중요한 사항을 누락한 경우에는 재량권을 일탈·남용한 것이다.
④ 도시관리계획의 원칙적인 결정권자는 관할구역을 담당하는 특별시장·광역시장·시장 또는 군수이다.
⑤ 도시관리계획 결정은 고시가 있은 날부터 1년 후에 그 효력이 발생한다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 도시계획법 제12조 소정의 고시된 도시계획결정은 특정 개인의 권리 내지 법률상의 이익을 개별적이고 구체적으로 규제하는 효과를 가져 오게 하는 행정청의 처분이라 할 것이고, 이는 행정소송의 대상이 된다(대판 1982.3.9, 80누105).
② 계획재량이 행정재량보다 넓으므로 양적 차이를 인정하는 것에는 이견이 없지만, 질적 차이까지 인정할지에 대해서는 일원설(구별부정설), 이원설(구별긍정설)의 견해가 대립한다.

③ 행정주체가 행정계획을 입안·결정함에 있어서 이익형량을 전혀 행하지 아니하거나 이익형량의 고려 대상에 마땅히 포함시켜야 할 사항을 누락한 경우 또는 이익형량을 하였으나 정당성·객관성이 결여된 경우에는 그 행정계획결정은 재량권을 일탈·남용한 것으로서 위법하다(대판 2006.4.28 2003두11056).

④ 도시관리계획의 입안권자는 원칙적으로 시장·군수·구청장이지만, 결정권자는 원칙적으로 시·도지사이다. 시·도지사는 도시관리계획을 결정하려면 관계행정기관의 장과 미리 협의하여야 하며, 국토해양부장관이 도시관리계획을 결정하려면 관계 중앙행정기관의 장과 미리 협의하여야 한다(국토의계획및이용에관한법률 제30조 제1항).

⑤ 도시관리계획 결정은 고시가 된 날부터 5일 후에 그 효력이 발생한다(동법률 제31조 제1항).

정답 ③

2. 다음 중 계획재량과 관계가 가장 먼 것은? (2005 관세사)

① 조건 프로그램 ② 새로운 질서형성
③ 형성의 자유 ④ 절차적 통제의 중요성
⑤ 계획법

해설 & 정답

유형 법률지식형

전통적인 재량행위 수권규범은 요건규정과 효과규정(가언 명령적 형식)으로 구성된 조건적 규범구조이다. 그러나 계획재량을 허용하는 계획규범은 수단을 통하여 달성하게 될 목표에 관하여 규율하는 형식(목적-수단의 형식)을 취하는 목적적 규범구조로 되어 있다는 점에서 양자는 구별된다.

정답 ①

3. 행정계획보장에 대한 다음의 기술 중 가장 타당하지 아니한 것은? (2001 입법고시)

① 계획보장청구권은 계획의 존속·준수뿐만 아니라 경과조치, 손해배상 등을 포함한다.
② 계획보장의 근거로는 법적 안정성과 신뢰보호를 들 수 있다.
③ 계획의 보장에 있어서는 개인의 신뢰와 계획의 가변성의 조정이 문제된다.
④ 계획일반의 존속을 구하는 청구권은 신뢰보호를 근거로 인정된다.
⑤ 계획은 비록 지침적 계획이라 해도 사실상 강제가 행하여지는 경우가 많다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 계획보장청구권은 좁은 의미로는 행정계획의 폐지·변경 및 그 내용의 불이행이 있는 경우 이로 인해 손실을 입은 개인이 행정계획의 주체에 대하여 그 손실의 보상을 청구할 수 있는 권리를 말한다. 그러나 넓은 의미로는 이와 같은 경우에 당사자가 주장할 수 있는 계획존속청구권·계획준수청구권·경과조치청구권·손해전보청구권 등의 다양한 청구권을 종합한 개념이다. 우리의 다수설은 계획보장청구권을 넓은 의미로 이해한다.

② 법적 안정성 및 그에 바탕을 둔 신뢰보호설이 다수설이다.

④ 일반적인 계획존속청구권은 개인의 신뢰보호가 공익에 대하여 일방적인 우선권을 가지는 경우를 전제로 하기 때문에 원칙적으로 인정되지 않는다는 것이 일반적인 견해이다.

정답 ④

♣ 학습내용 정리

1. 행정계획의 법적성질은 개별적으로 검토하여야 한다.
2. 행정계획에 형량의 하자가 있으면 위법하다.
3. 계획보장청구권은 행정계획에서 국민의 신뢰보호를 위한 것이다.

제10강 행정행위의 의의

♣ 학습목표

행정행위의 의의 및 개념징표를 이해하고 행정행위와 처분과의 관계에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

행정행위의 의의 및 개념징표
행정행위와 처분과의 관계

♣ 사전테스트

1. 행정행위는 일반적 추상적 규율이다.
   정답 : ×

2. 일반처분은 행정행위가 아니다.
   정답 : X

3. 행정행위와 처분이 동일한 개념인가에 대해 학설의 대립이 있다.
   정답 : ○

♣ 돌발퀴즈

상급자가 특정 공무원에 대해 발하는 직무명령은 행정행위에 해당하지 않는다.

[정답] ○
[해설] 직무명령은 행정내부에서만 구속력을 가지므로 행정행위가 아니다.

♣ 강의내용

제1 행정행위의 의의 및 개념징표

Ⅰ. 행정행위의 의의

행정청이 법 아래서 구체적 사실에 관한 법집행으로서 행하는 권력적 단독행위인 공법행위

Ⅱ. 행정행위의 개념요소

1. 행정청의 행위

행정청은 국가와 지방자치단체의 행정에 관한 의사를 결정하고 이를 외부에 표시할 수 있는 권한을 가진 행정기관이다(조직법상 의미의 행정청). 그러나 여기서 말하는 행정청은 기능적 의미의 행정청을 말한다. 기능적의미의 행정청이란 공법에 의해 외부관계에서 처분할 권한을 부여받은 모든 자를 의미한다.[33] 즉, 작용법상 처분할 권한을 가진 자를 말한다. 이러한 작용법상 처분권한은 우선적으로 조직법상 행정청이 가진다. 그 밖의 여러 행정기관이나 기타 공법상 법인도 작용법상 처분권한이 부여된 범위내에서 그러한 권한을 갖고 그러한 범위내에서 기능적 의미의 행정청이 된다(행정소송법 제2조 제2항 : "이 법을 적용함에 있어서 행정청에는 법령에 의하여 행정권한의 위임 또는 위탁을 받은 행정기관, 공공단체 및 그 기관 또는 사인이 포함된다").

2. 구체적 사실에 대한 집행행위

3. 외부에 대해 직접적인 법적 효과를 발생하는 행위

4. 공권력적 행위 - 공법작용과 권력적 단독행위

제2 행정행위와 처분과의 관계

1. 논의배경

행정심판법 제2조 제1호와 행정소송법 제2조 제1항 제1호는 행정심판과 항고소송의 대상으로 실체법상(작용법상) 개념인 행정행위가 아닌 처분의 개념을 사용하여 "행정청이 행하는 구체적 사실에 대한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 이에 준하는 행정작용"이라고 규정하고 있다. 따라서 행정심판법과 행정소송법의 처분 개념을 실체법적인 행정행위 개념과 일치된 것으로 볼 것인지 아니면 쟁송법적 의미의 고유한 개념으로 개편할 것인지에 대하여 학설상 격렬한 논쟁의 대상이 되고 있다.

2. 학설

⑴ 실체법적 개념설(일원설)

취소소송을 행정행위의 공정력을 깨기 위한 형성소송으로 보아, 취소소송의 대상인 처분을 공정력을 가지는 행정행위와 동일한 개념으로 파악하는 견해이다. 이 견해에 따르면 행정행위가

33) 홍정선, 행정법특강, 제756면.

아닌 행정작용은 당사자소송이나 국가배상청구소송 등 그에 상응하는 소송유형을 통해 권리구제를 도모해야 한다고 한다.

⑵ 쟁송법적 개념설(이원설)

행정소송법상 처분의 개념은 행정행위보다 넓은 행정쟁송법상의 독자적인 개념이라는 견해이다. 이 견해는 항고소송 중심주의를 취하는 현행법상 항고소송의 대상인 처분의 개념을 넓힘으로써 국민의 권리구제를 확대하여야 하고 행정소송법상 처분의 개념이 강학상 행정행위보다 넓게 규정되어 있음을 논거로 한다. 이 견해에 따르면 행정행위가 아닌 사실상 지배력를 미치는 비권력적 사실행위 등도 처분의 개념에 해당할 수 있다.

⑶ 제3설

행정심판법과 행정소송법의 문면상 “그 밖에 이에 준하는 행정작용”이라는 표현으로 인해 그리고 권력적 단독행위가 아니라 “공권력 행사”라는 표현으로 인해 행정소송법상 처분개념은 실체법상 행정행위개념보다 그 의미가 넓으나, 항고소송으로 취소소송, 무효등확인소송의 대상인 처분은 행정행위로 국한할 수 밖에 없다는 견해이다.

3. 판례

판례에 대하여 실체법적 개념설을 취하고 있다고 해석하는 견해도 있고 쟁송법적 개념설을 취하고 있다고 보는 견해도 있다.

판례는 기본적으로 실체법적 개념설의 입장을 취하고 있다. 다만 최근 판례는 “ 행정청의 어떤 행위가 항고소송의 대상이 될 수 있는지의 문제는 추상적·일반적으로 결정할 수 없고, 구체적인 경우 행정처분은 행정청이 공권력의 주체로서 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서 국민의 권리의무에 직접적으로 영향을 미치는 행위라는 점을 염두에 두고, 관련 법령의 내용과 취지, 그 행위의 주체·내용·형식·절차, 그 행위와 상대방 등 이해관계인이 입는 불이익과의 실질적 견련성, 그리고 법치행정의 원리와 당해 행위에 관련한 행정청 및 이해관계인의 태도 등을 참작하여 개별적으로 결정하여야 한다”라고 판시하여 행정행위가 아닌 행정작용도 국민의 권익구제를 위해 필요한 경우에는 처분성을 인정하고 있다.

제3 행정행위의 종류

Ⅰ. 개관

1. 법률효과의 발생원인에 따라
  - 법률행위적 행정행위와 준법률행위적 행정행위

2. 상대방의 협력이 필요한가에 따라
  - 쌍방적 행정행위와 일방적 행정행위

3. 효과결정에 있어서 자유가 있는가에 따라
  - 기속행위, 재량행위

4. 법률효과에 따라
  - 수익적, 침익적, 복효적 행정행위

5. 규율의 대상에 따라
   - 대인적, 대물적, 혼합적 행정행위인지

6. 행정행위의 효력발생에 따라
   - 수령을 요하는 행정행위와 수령을 요하지 않는 행정행위

7. 상대방에 따라
   - 개별적 행정행위와 일반적 행정행위

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 광주 지하상가(私法人)는 광주광역시의 시장과 지하도시설공사투자 협약을 체결하여 그 지하시설물 일체를 기부채납한 후 상가부분의 무상사용을 하도록 하는 도로점용허가를 받은 후 다른 민원인이 지하도의 자상에 횡단보도를 설차하여 달라고 민원을 전남지방경찰청장에 제출하자 전남지방경찰청장을 상대로 횡단보도설치행위의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 이와 관련된 설명 중 옳지 않은 것은?

① 취소소송의 대상적격과 관련하여 횡단보도행위의 처분성이 문제되는데 이와 관련하여 횡단보도 설치행위가 일반처분인지 여부가 문제된다.
② 일반처분이란 일반적·구체적 규율로서 특정사건에 대한 규율이지만 불특정다수인을 상대방으로 하여 그에 대해 법적 효과를 미치는 행정행위를 지칭한다.
③ 일반처분의 종류에는 ㉠ 대인적 일반처분, ㉡ 대물적 일반처분, ㉢ 물건의 이용규율로서 일반처분 등을 들 수 있는데 사안의 횡단보도 설치행위는 대물적 일반처분에 해당된다.
④ 판례는 횡단보도 설치행위에 대해서 일관되게 처분성을 인정하고 있다.
⑤ 판례는 횡단보도가 설치된 도로 인근에서 영업활동을 하는 자에게 원고적격을 인정하지 않는다.

해설 & 정답

유형 사례형

④ 횡단보도 설치행위의 처분성을 부정한 판례 : 경찰서장이 도로교통법에 따라 하는 횡단보도 설치 및 폐지결정은 행정기관 내부의 행위로서 직접 국민의 권리의무에 영향이 없으므로 항고소송의 대상이 되지 않는다(대판 2000.10.24, 99두1144).
횡단보도 설치 행위의 처분성을 인정한 판례 : 도로교통법의 취지에 비추어 볼 때, 지방경찰청장이 횡단보도를 설치하여 보행자의 통행방법 등을 규제하는 것은 행정청이 특정사항에 대하여 의무의 부담을 명하는 행위이고 이는 국민의 권리의무에 직접 관계가 있는 행위로서 행정처분으로 보아야 한다(대판 2000.2.27, 98두896).

⑤ 횡단보도 설치에 관한 도로교통법의 규정들은 일반 국민들의 도로상의 보행편의와 교통의 안정성의 보장 등을 그 목적으로 하고 있는 것이고, 횡단보도의 설치 또는 폐지로 인하여 지하상가의 임대인 또는 임차인이 누리는 인근 지하상가의 영업권활성화와 같은 이익은 도로교통법에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익이라고 할 수 없으므로 지하상가의 임대인 또는 임차인(횡단보도가 설치된 도로 인근에서 영업활동을 하는 자)은 횡단보도설치행위를 다툴 법률상의 이익이 없다(대판 2000.2.27, 98두896).

정답 ④

2. 행정행위의 개념에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (2009 관세사)

① 도로상의 교통표지판과 같이 직접 물건의 특성을 규율하는 행위는 행정행위에 해당한다.
② 특정장소에의 통행금지와 같은 불특정 다수인에 대한 규율행위는 행정행위에 해당한다.
③ 장래 일정한 행정처분을 하겠다고 약속하는 확약은 행정행위에 해당한다는 것이 대법원 판례의 입장이다.
④ 상급자가 특정 공무원에 대해 발하는 직무명령은 행정행위에 해당하지 않는다.
⑤ 기계적으로 부과되는 납세고지서와 같은 자동화된 행정결정은 행정행위에 해당한다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 대물적 일반처분(물적 행정행위)에 해당한다.
② 대인적 일반처분으로써 행정행위에 해당한다.
③ 처분성을 긍정하는 행정행위설과 처분성을 부인하는 독자적 행위설의 견해대립이 있다. 판례는 확약의 행정행위성・처분성을 부정한다(대판 1995.1.20, 94누6529 참조).
④ 직무명령은 행정내부에서만 구속력을 가지므로 행정행위가 아니다.

정답 ③

3. 다음 중 통설・판례에 의한 행정행위의 개념과 가장 거리가 먼 것은? (2004 전북9급)

① 행정행위의 개념에 관한 논의는 행정쟁송의 대상에 관한 논의와 밀접한 관련이 있다.
② 공법인 등 공공단체가 행하는 모든 행위는 행정청의 행위로서 행정소송의 대상이 된다.
③ 최협의의 개념으로서 행정행위란 행정청의 행위 중에서 법집행행위로서 권력적 단독행위를 말한다.
④ 군의관의 신체등위판정은 행정쟁송의 대상이 되는 행정처분이 아니다.
⑤ 당연퇴직 인사발령은 비록 행정청에 의하여 이루어질지라도 행정쟁송의 대상이 되는 행정행위가 아니다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

② 행정행위는 행정청이 하는 행위인데 행정청의 범위에는 조직법상의 행정청인 국가나 지방자치단체의 행정기관뿐만 아니라 공사 기타 공법인이나 공무수탁사인이라도 국가로부터 행정권을 부여 받은 범위 안에서 행정청에 포함된다. 공법인이라도 공무를 수행하는 한도에서는 행정청이 될 수 있다. 그런데 행정청이 행하는 모든 행위가 다 처분에 해당하는 것은 아니다. 행정청이 행하는 비권력적 사실행위나 공법상 계약 등은 처분성이 부정된다.
④ 병역법상 신체등위판정은 행정청이라고 볼 수 없는 군의관이 하도록 되어 있으며, 그 자체만으로 바로 병역법상의 권리의무가 정하여지는 것이 아니라 그에 따라 지방병무청장이 병역처분을 함으로써 비로소 병역의무의 종류가 정하여지는 것이므로 항고소송의 대상이 되는 행정처분이라 보기 어렵다(대판 1993.8.27, 93누3356).
⑤ 국가공무원법 제69조에 의하면 공무원이 제33조 각 호의 1에 해당할 때에는 당연히 퇴직한다고 규정하고 있으므로, 국가공무원법상 당연퇴직은 결격사유가 있을 때 법률상 당연히 퇴직하는 것이지 공무원관계를 소멸시키기 위한 별도의 행정처분을 요하는 것이 아니며, 당연퇴직의 인사발령은 법률상 당연히 발생하는 퇴직사유를 공적으로 확인하여 알려주는 이른바 관념의 통지에 불과하고 공무원의 신분을 상실시키는 새로운 형성적 행위가 아니므로 행정소송의 대상이 되는 독립한 행정처분이라고 할 수 없다(대판 1995.11.14, 95누2036).

정답 ②

♣ 학습내용 정리

1. 행정행위의 개념징표로 행정청, 구체적 규율, 공권력의 행사, 외부에 직접적인 법적 효과를 발생시키는 행위 등이 있다.
2. 행정행위와 처분과의 관계에 대해 학설과 판례의 대립이 있다.

제11강 기속행위와 재량행위

♣ 학습목표

기속행위와 재량행위의 구별기준과 구별실익을 이해하고 판단여지의 의의와 한계를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

기속행위와 재량행위의 구별기준과 구별실익
판단여지의 의의와 한계

♣ 사전테스트

1. 기속행위는 법적 근거없이 공익상 이유로 거부할 수 있다.
   정답 : ×

2. 재량의 0으로 수축은 인정되지 않는다.
   정답 : X

3. 재량행위도 재량의 일탈, 남용이 있으면 위법하다.
   정답 : ○

♣ 돌발퀴즈

행정법령의 법률요건에 불확정개념이 포함되어 있으면 판단여지가 인정되는 것이 원칙이다.

[정답] ×

[해설] 법률요건에 불확정개념이 사용된 경우에 원칙적으로는 판단여지가 인정되는 것이 아니고 고도의 전문적·기술적·정책적인 판단에 속하는 불확정개념일 경우에 판단여지가 인정된다.

♣ 강의내용

제1 기속행위와 재량행위의 의의 및 구별기준과 구별실익

Ⅰ. 개 설

1. 기속행위의 의의

기속행위란 법규상 요건충족후 행정청이 반드시 어떠한 행위를 발하거나 발하지 말아야 하는 행정행위를 말한다.

2. 재량행위의 의의

재량행위란 법규상 요건충족후 행정청이 복수행위 사이에 선택할 수 있는 자유가 부여되어 있는 행정행위를 말한다.

Ⅱ. 기속행위와 재량행위의 구별

1. 구별실익

⑴ 재판통제의 범위

⑵ 부관의 가부

⑶ 공권의 성립

⑷ 사법심사의 방식

2. 구별기준

⑴ 학 설

요건재량설, 효과재량설, 판단여지설, 종합설 등이 대립한다.

⑵ 판 례

우리 대법원 판례는 “어느 행정행위가 기속행위인지 재량행위인지, 나아가 재량행위라고 할지라도 기속재량행위인지 또는 자유재량에 속하는 것인지의 여부는 이를 일률적으로 규정지을 수 없는 것이고, 당해 처분의 근거가 된 규정의 형식이나 체제 또는 문언에 따라 개별적으로 판단하여야 한다”(94누12302판결)라고 판시하고 있다.

제2 불확정개념과 판단여지

1. 개 설

⑴ 판단여지의 의의

원칙적으로 요건판단은 법원의 전속적인 권한으로 행정부에게 자유가 인정되지 않으나 당해 요건이 불확정개념이고 고도의 전문영역이나 가치평가영역인 경우에는 법원보다 행정부가 전문성을 갖고 있는 바 행정부에게 요건판단에 있어서 일정한 범위의 자유를 인정된다. 이를 판단여지라 한다.

⑵ 판단여지의 인정근거 - 행정부의 전문성 존중

2. 판단여지와 재량의 구별에 관한 학설과 판례

⑴ 학설

① 재량은 효과선택에 있다는 점, 재량은 입법자가 부여하나 판단여지는 법원이 인정하는 것이라는 점에서 양자를 구별하는 견해와 ② 양자 모두 행정의 자유이고 그 범위내에서 법원의 재판통제가 미치지 않는다는 점에서 양자의 구별을 부정하는 견해가 대립한다.

⑵ 판 례

판례는 판단여지가 인정되는 요건판단을 재량으로 보아 판단여지와 재량을 구별하지 않고 있다.

3. 판단여지가 인정되는 영역

모든 불확정개념에 판단여지가 인정되는 것은 아니다. 즉 불확정개념은 원칙적으로 법개념이므로 예외적인 경우에만 판단여지가 인정된다.

이러한 판단여지는 그 근거에 비추어 불확정개념의 적용에 관한 객관적 기준이 결여되어 있어 법원의 판단으로 행정청의 신중한 판단을 대체하는 것이 타당하지 않은 경우, 즉 고도로 전문적이고 기술적인 판단이나 고도로 정책적인 판단에 속하는 불확정개념의 적용에 한하여 인정된다고 보는 것이 타당하다.[34]

4. 판단여지의 한계

판단의 여지가 인정되는 범위 내에서 내려진 행정청의 판단은 법원에 의한 통제의 대상이 되지 않는다.

다만, 판단여지가 인정되는 경우에도 ① 명확히 법을 위반하거나(예컨대, 절차규정 위반, 다른 법규정위반, 행정법의 일반원칙 위반), ② 사실의 인정을 잘못했거나, ③ 판단기관구성의 위법, ④ 법에 정한 절차규정 위반, ⑤ 명백히 판단을 잘못한 경우에는 위법이 된다고 보아야 한다.

판례도 행정기관의 판단(교과서 검정상의 판단)이 사회통념상 현저히 부당하다고 보여지는 경우는 그에 기초한 결정은 위법한 것으로 인정될 수 있다고 보고 있다.[35]

---

34) 박균성, 전게서, 235면

35) 구체적으로 판단여지에 관한 사항이 사법심사의 대상이 되는 경우에 법원은 먼저 법에 의해 판단여지가 인정되고 있는지를 심사하고, 판단여지 영역이라면 사실의 요건에의 포섭은 행정청의 판단을 존중하여 주되, 그 포섭과정에서 판단기관이 적법하게 구성되어 있었는지, 판단에 관한 적법한 절차를 준수하였는지, 판단에 있어 행정법의 일반원칙에 위배되지 않았는지, 판단의 기초가 된 사실을 오인하지 않았는지, 동기가 부정하거나 목적이 위배되지 않았는지 등에 관하여 심사한 후 그러한 흠이 없을 때에는 판단여지가 존재함을 이유로 기각판결을 하여야 할 것이다.

제3 재량행위의 한계와 통제

1. 재량행위의 한계

재량의 일탈은 행정청에게 부여된 재량권의 외적 한계를 넘어서는 경우로서 재량의 유월이라고도 한다. 또한 주로 비례의 원칙, 평등의 원칙과 같은 행정법의 일반원칙에 위배하여 행사하는 경우처럼 재량권의 내적 한계를 넘는 것을 남용이라 한다.

다만, 판례는 재량권의 일탈과 남용을 명확히 구분하지 않고 재량권의 행사에 '재량권의 일탈 또는 남용'이 있는지 여부를 판단한다. 또한 재량권의 한계가 재량권의 일탈에 속하는지 남용에 속하는지를 판단할 실익도 없다. 어떠한 재량권의 한계이든지 위반하게 되면 그 재량권 행사는 위법하게 되기 때문이다.

⑴ 재량의 하자

1) 재량의 일탈

2) 재량의 남용

3) 재량권의 불행사 또는 재량의 해태

⑵ 재량권의 0으로의 수축

2. 재량행위에 대한 통제

⑴ 입법적 통제

⑵ 행정적 통제

1) 직무감독에 의한 통제

2) 행정절차에 의한 통제

3) 행정심판에 의한 통제

행정심판법은 위법한 처분은 물론 '부당'한 처분에 대하여서도 행정심판의 제기를 인정함으로써, 행정심판의 방법에 의한 재량행위에 대한 통제를 인정하고 있다.

⑶ 사법적 통제

재량에도 한계가 있으며, 그 한계를 넘어서는 경우에는 위법이 된다. 행정소송법 제27조가 「행정청의 재량에 속하는 처분이라도 재량권의 한계를 넘거나 그 남용이 있는 때에는 법원은 이를 취소할 수 있다」고 규정한 것도 같은 취지이다. 따라서 재량의 한계를 넘은 재량행위는 취소소송에 의해 취소된다.

다만, 부당한 재량행위에 대해 소송이 제기된 경우에 법원은 이를 각하할 것이 아니라 행정행위의 성질을 실질적으로 심사한 후 기각판결을 하여야 한다고 본다.

또 재량의 일탈 남용으로 손해를 입은 국민은 국가배상을 청구할 수 있다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 재량행위에 관한 설명 중 옳은 것은? (2005 국회8급)

① 행정법령의 법률요건에 불확정개념이 포함되어 있으면 판단여지가 인정되는 것이 원칙이다.
② 재량행위에만 부관을 붙일 수 있고, 기속행위에는 어떤 경우에도 부관이 허용되지 않는다.
③ 재량은 반드시 행사해야 하는 의무이며, 이를 행사하지 않으면 안 된다.
④ 재량행위에 대한 사법심사는 허용되지 않는다.
⑤ 재량이 '0'으로 수축되면 의무로 되어 행정개입청구권이 성립되는데, 이는 자신의 이익과 관련 없이도 행사할 수 있다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 법률요건에 불확정개념이 사용된 경우에 원칙적으로는 판단여지가 인정되는 것이 아니고 고도의 전문적·기술적·정책적인 판단에 속하는 불확정개념일 경우에 판단여지가 인정된다.
② 판례는 기속행위에는 부관을 붙일 수 없고 가사 붙였다 하더라도 무효라는 입장이나, 새로운 견해는 원칙적으로 부관을 붙일 수 없으나 명문의 규정이 있는 경우뿐만 아니라 법률요건 충족적 부관의 경우에는 예외적으로 부관을 붙일 수 있다고 주장한다. 그러므로 기속행위에도 부관이 허용되는 경우가 있다. 명문의 규정이 있는 경우에는 판례의 태도에 의할 경우에도 부관의 부가가 가능하다.
③ 재량은 반드시 행사해야 하지만, 만일 행정청이 구체적인 사정을 고려하지 않고 일반적 기준에 따라 처분을 하는 경우 재량의 흠결이 된다. 재량행위는 특정행위를 해야 할 의무가 없다는 표현과, 재량 자체와는 구별되는 개념이다.
④ 기속재량행위이든 자유재량행위이든 일탈·남용에 해당하는 경우 사법심사의 대상이 된다.
⑤ 재량이 0으로 수축되어 행정청에게 행위의무가 있다고 해서 이것만으로 행정개입청구권이 성립될 수는 없고, 공권 성립의 다른 요건인 사익보호의 필요가 있어야 한다. 따라서 자신의 이익과 관련이 없는 경우 행정개입청구권 자체가 성립되지 않는다.

정답 ③

2. 재량행위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (2003 행정고시)

① 재량의 목적과 한계 내에서 행한 재량행사는 당·부당의 문제는 발생할 수 있어도 위법의 문제는 발생하지 아니한다.
② 판례상 자유재량개념이 긍정되고 있다.
③ 학설에 따라서는 재량의 소재를 규정의 효과부분에만 국한하여 판단하기도 한다.
④ 현행법상 재량하자의 사법심사에 관한 명문의 규정은 존재하지 않는다.
⑤ 경우에 따라서는 재량이 축소되어 하나의 선택만이 요구되는 경우도 있다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

③ 효과 재량설의 입장이다.
④ 행정청의 재량에 속하는 처분이라도 재량권의 한계를 넘거나 그 남용이 있는 때에는 법원은 이를 취소할 수 있다(행정소송법 제27조). 즉, 명문의 규정이 존재한다.
⑤ 재량권이 0으로 수축된 경우이다.

정답 ④

3. 행정청의 재량권행사를 통제하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은? (2003 입법고시)

① 재량권행사를 통제하기 위해서는 행정행위의 근거법률이 되는 법률상의 요건을 더욱 철저하게 규정하는 것이 가장 근원적인 조치이다.
② 입법부는 행정부에 대한 정치적 견제기능을 발휘하여 재량권을 통제할 수 있다.

③ 행정절차 내에서는 절차의 형식성으로 인하여 행정청의 재량행사를 통제할 수 있는 여지가 거의 없다고 할 수 있다.
④ 사법부는 재량권의 일탈·남용을 가리기 위하여 기속행위이건 재량행위이건 모두 사법심사의 대상으로 삼고 있다.
⑤ 재량권의 일탈·남용에 대한 사법적 통제의 가능성은 행정소송법에도 규정되어 있다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

③ 오늘날 재량권 행사에 대해서는 실체적 통제가 매우 어렵기 때문에 절차적 통제의 필요성이 강조된다. 따라서 재량권 행사에 있어서 고지·청문과 같은 사전절차가 보다 실효성이 있고 민주적이라고 할 수 있다. 우리 행정절차법이 의견제출·청문·공청회 등에 관한 규정(행정절차법 제2장 제2절)과 기준 공표(행정절차법 제20조) 및 이유제시(행정절차법 제23조)에 관한 규정을 두고 있는 것은 절차적 재량통제수단으로서 의의를 갖는다.
⑤ 행정소송법 제27조

정답 ③

♣ 학습내용 정리

1. 기속행위와 재량행위 구별기준에 대하여 학설과 판례의 대립이 있다.
2. 판단여지는 불확정개념에서 인정되는 행정부의 자유이다.

제12강 법률행위적 행정행위

♣ 학습목표

법률행위적 행정행위로서 강학상 하명과 허가에 대하여 검토한다.

♣ 학습내용

강학상 하명
강학상 허가

♣ 사전테스트

1. 강학상 하명은 형성적 행정행위이다.
   정답 : ×

2. 강학상 허가는 억제적 금지의 해제이다.
   정답 : X

3. 영업양도시 양도인의 위반행위는 양수인에게 승계된다는 것이 판례입장이다.
   정답 : ○

♣ 돌발퀴즈

건설업면허의 갱신은 기존 면허의 효력의 동일성을 유지하면서 장래에 향하여 지속시키는 데 그친다.

[정답] ○

[해설] 건설업면허의 갱신이 있으면 기존 면허의 효력은 동일성을 유지하면서 장래에 향하여 지속한다 할 것이고 갱신에 의하여 갱신 전의 면허는 실효되고 새로운 면허가 부여된 것이라고 볼 수는 없으므로 면허갱신에 의하여 갱신 전의 건설업자의 모든 위법사유가 치유된다거나 일정한 시일의 경과로서 그 위법사유가 치유된다고 볼 수 없다(대판 1984.9.11, 83누658).

♣ 강의내용

제1 하명

⑴ 의의 및 종류

하명이란 작위(철거명령), 부작위(금지, 영업정지처분), 급부(조세부과처분), 수인(강제격리)의 무를 명하는 행정행위를 말한다.

⑵ 성질 - 부담적 행정행위, 법적 근거 필요.

⑶ 상대방과 대상

⑷ 하명의 효과와 하명위반의 효과

① 하명은 그 내용에 따라 작위·부작위·수인·급부 등의 의무를 발생시킨다. ② 대인적 하명은 그 상대방에게만 효과가 발생하나, 대물적 하명의 경우에는 그 상대방의 지위를 승계하는 자에게도 미친다. ③ 하명에 의하여 과하여진 의무를 불이행한 자에 대하여는 행정상 강제집행이 행하여지고, 의무를 위반한 때에는 행정벌이 과하여지는 것이 보통이다. ④ 하명에 위반하여 법률행위가 행해지는 경우 법률이 무효를 규정할 수도 있으나, 반드시 무효가 되는 것은 아니다.

⑸ 하자있는 하명에 대한 구제

위법한 하명에 의하여 권리를 침해당한 자는 취소소송이나 무효등확인소송 등 항고소송을 제기하거나 손해배상청구소송의 제기를 통해 위법상태를 제거하거나 손해를 배상받을 수 있다.

제2 허 가

⑴ 기본권과 허가와의 관계

⑵ 허가의 개념

허가는 허가근거법규에 의한 일반적 상대적 금지(부작위의무)를 특정한 경우에 해제하여 적법하게 일정한 행위를 할 수 있게 하는 행정청의 행위를 말한다. 상대적 금지를 해제하여 준다는 점에서 후술할 억제적 금지를 예외적으로 시인하여 주는 예외적 허가와 구별된다.

⑶ 허가의 성질

1) 형성적 행정행위인지 여부

2) 기속행위인지 여부

허가가 재량행위인지 기속행위인지는 원칙적으로 근거법령의 문언에 의해 가려야 할 것이다.

그러나 근거법령의 문언이 불분명할 경우에 통설적 견해는 관계법령상의 허가요건이 충족된 경우에는 당해 기본권의 행사에 공익상 장애요인이 없다는 것을 의미하게 되므로, 행정청은 반드시 허가를 할 기속을 받는다고 해석하고 있다.

이에 비해 일부견해는 기속행위와 재량행위의 구별은 기본권의 최대한 보장과 공익의 실현을 기준으로 하여 판단하여야 할 것인 바, 기본권의 최대한 보장이 보다 중요한 경우라면 그리고

요건이 구비되었다면 기속행위로, 공익의 실현이 보다 중요한 경우라면 재량행위로 보아야 한다고 주장한다.

다만, 허가요건이 불확정개념으로 규정되어 있는 경우에 행정청에게 판단여지가 인정될 수 있는 경우가 있다.

판례는 허가를 기속행위로 본 경우도 있고, 중대한 공익상의 이유를 들어 재량행위로 본 경우도 있다.

3) 법률상 이익 여부

① 처분의 상대방이 누리던 이익 - 무조건 법률상 이익 있음

② 특정한 자에 대한 법적 규제로 누리던 기존허가업자의 이익

먼저 허가를 받은 자가 다른 자에 대한 관계 법규상의 법적 규제에 의해 사실상 독점적 이익을 누렸으나 행정청의 신규허가에 의하여 그 독점적 이익이 줄었다고 하여 그 허가처분의 취소를 구할 원고적격이 있는가가 문제된다.

㈎ 거리제한규정 등이 없거나 무효인 경우 - 원고적격부정

㈏ 거리제한규정 등이 법규성이 있는 경우 : 원고적격인정

⑶ 허가의 종류와 이전성

⑷ 영업양도에 따른 제재처분의 승계

1) 제재처분이 승계된다는 명문의 규정이 있는 경우 - 당연히 승계가능

2) 제재처분이 승계된다는 명문의 규정이 없는 경우

㈎ 학설

① 제재사유가 양도인의 자격상실, 부정영업 등 인적인 사유인 경우에는 행위책임인 바 이러한 행위책임은 양수인에게 승계되지 않는다는 점, 승계인정하면 양수인에게 침익적 효과를 가져오는 바 법률유보원칙상 별도의 법적근거가 있어야만 한다는 점 등을 근거로 승계를 부정하는 부정설, ② 행정목적달성 및 의도적인 책임회피수단으로서 양도 등의 악용가능성 방지, 지위승계규정이 제재처분승계의 법적근거가 된다는 점 등을 근거로 승계를 긍정하는 긍정설, ③ 양도인의 법위반행위로 인해 발령된 제재처분의 성질이 대물적 처분인지 대인적 처분인지 나누어 전자는 승계되나 후자는 승계되지 않는다는 견해 등이 대립한다.

㈏ 판례

판례는 이전성이 인정되는 대물적 또는 혼합적 행정행위의 경우 제재처분의 승계에 관한 명문규정이 없더라도 제재처분사유는 승계되는 것으로 보고 있다. 또 판례는 제재처분이 대물적 처분임을 이유로 제재처분사유의 승계를 긍정하기도 한다.

⑸ 허가와 출원

⑹ 허가의 효과

1) 기본적 효력 - 상대적 금지해제로 인한 자연적 자유회복

2) 관계법상의 제한 해제

3) 허가받지 아니한 행위의 효력

허가를 받아야 할 행위를 허가받지 않고 행한 경우에는 행정상 강제집행이나 행정벌의 대상은 되지만, 당해 무허가행위 자체의 효력은 원칙적으로 영향이 없다. 다만 예외적으로 법률이 무허가행위의 처벌 외에도 그 행위의 효력을 무효로 규정하는 경우가 있다.

⑺ 허가요건의 추가

허가가 기속행위인 경우 법령에 근거가 있어야만 허가요건의 추가가 가능하다. 따라서 법령에 근거 없이 허가요건을 추가하는 것은 허용되지 않는다(즉 법령에 근거없는 사유로 허가신청을 거부하는 것은 법률유보원칙위반으로 위법하다).

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 하명에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (2005 5급승진)

① 통상작위하명, 부작위하명, 급부하명, 수인하명으로 구분된다.
② 부작위하명은 금지라고도 하며, 어떠한 경우에도 부작위의무를 해제할 수 없는 절대적 금지와, 일정 요건을 갖춘 자에게는 부작위의무를 해제할 수 있는 상대적 금지로 구분할 수 있다.
③ 법령에서 직접 행하는 법규하명과, 법령에 근거하여 구체적으로 행하는 하명처분으로 구분할 수 있다.
④ 하명처분은 특정인에 대하여 행하는 행정행위이다.
⑤ 하명의 대상인 행위는 사실행위일 수도 있고, 법률행위일 수도 있다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

④ 하명의 상대방은 특정인인 경우가 일반적이지만, 불특정 다수인을 상대로 하는 일반처분도 있을 수 있다(예 도로통행금지).
⑤ 사실행위의 예로는 무허가 건물 철거를 들 수 있으며, 법률행위의 예로는 영업행위 금지를 들 수 있다.

정답 ④

2. 강학상의 허가에 관한 설명으로 틀린 것을 모두 고른 것은?

가. 허가의 효력은 언제나 허가관청의 관할구역 내에만 미친다.
나. 허가를 위반한 행위의 사법상 효력은 원칙적으로 부인된다.
다. 허가는 억제적(또는 제재적, 사후적) 금지를 해제하여 주는 행위인 점에서 예방적(또는 사전적) 금지를 해제하여 주는 행위인 예외적 승인과 구별된다.
라. 법이 정한 허가의 요건을 모두 갖추었다 하더라도 허가관청은 주민의 동의가 없음을 이유로 주유소설치허가를 거부할 수 있다는 것이 대법원 판례의 입장이다.
마. 허가신청이 있은 후 그에 대한 결정이 있기 전에 허가기준을 정한 법령이 개정된 경우에는 처분청은 원칙적으로 개정된 법령을 적용하여야 한다는 것이 대법원 판례의 입장이다.

① 가, 나
② 다, 라, 마
③ 나, 다, 마
④ 가, 나, 다, 라
⑤ 라, 마

해설 & 정답

유형 법률지식형

가. [×] 허가의 효과는 당해 허가행정청의 관할구역 내에서만 미치는 것이 원칙이다. 그러나 법령의 규정이 있거나 허가의 성질상 관할구역에 국한시킬 것이 아닌 경우(운전면허)에는 관할구역 외에까지 효과가 미친다.

나. [×] 허가를 받아야 할 행위를 허가받지 않고 행한 경우, 원칙적으로 행정상 강제집행이나 제재의 대상이 되고(적법요건), 행위 자체의 법률상 효력이 당연히 부정되는 것은 아니다. 다만, 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 무효인 경우도 있다.

다. [×] 허가는 법령에 의한 일반적·상대적·예방적 금지(부작위의무)를 일정한 경우에 해제하여 자연적 자유를 회복시켜 주는 행위인데, 예외적 승인은 절대적, 억제적(진압적), 사후적 금지의 해제라는 점에서 다르다.

라. [×] 주유소설치허가권자는 주유소설치허가신청이 석유사업법, 같은 법 시행령, 혹은 그 시행령의 위임을 받은 시·도지사의 고시 등 관계법규에서 정하는 어떠한 제한에 배치되지 않는 이상 당연히 같은 법령 소정의 주유소 설치허가를 하여야 하므로, 법령상의 근거 없이 그 신청이 관계법규에서 정한 제한에 배치되는지 여부에 대한 심사를 거부할 수 없고, 심사결과 그 신청이 법정요건에 합치하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이를 허가하여야 하며, 공익상 필요가 없음에도 불구하고 요건을 갖춘 자에 대한 허가를 관계법령에서 정하는 제한사유 이외의 사유를 들어 거부할 수는 없다(대판 1996.7.12, 96누5292).

마. [○] 대판 1998.3.27, 96누19772

정답 ④

3. 허가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (2005 5급승진)

① 예외적 허가는 재량행위의 성질을 갖는다.
② 총포화약류제조허가는 혼합적 허가이다.
③ 수정허가는 당연무효라는 것이 판례의 입장이다.
④ 허가는 행위의 적법요건이지 유효요건은 아니다.
⑤ 허가신청이 있은 후 그에 대한 결정이 있기 전에 허가기준을 정한 법령이 개정된 경우에는 원칙적으로 처분 당시의 법령을 적용하고, 예외적으로 허가신청 당시의 법령을 기준으로 한다는 것이 판례의 입장이다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

③ 수정허가가 가능하기 때문에 무효가 아니고, 이 점에서 수정특허는 인정되지 않는다는 점이 다르다. 유사사안에서 판례도 신청 없는 허가의 효력은 무효사유가 아니라 취소사유라고 판시하고 있다. 개축허가신청에 대하여 행정청이 착오로 대수선 및 용도변경허가를 하였다 하더라도 취소 등 적법한 조치 없이 그 효력을 부인할 수 없음은 물론(무효사유가 아닌 취소사유에 불과) 더구나 이를 다른 처분(즉, 개축허가)으로 볼 근거도 없다(대판 1985.11.26, 85누382).

⑤ 대판 1998.3.27, 96누19772

정답 ③

♣ 학습내용 정리

1. 강학상 하명은 국민에게 작위, 부작위, 급부, 수인의무를 부과하는 명령적 행정행위이다.
2. 강학상 허가는 상대적 금지를 해제시켜주는 명령적 행정행위이다.
3. 제재처분사유는 승계된다는 것이 판례의 입장이다.

제13강 법률행위적 행정행위 및 준법률행위적 행정행위

♣ 학습목표

법률행위적 행정행위로서 강학상 특허, 인가, 공법상 대리 및 준법률행위적 행정행위로서 확인, 통지, 수리, 공증에 대하여 구별하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

강학상 특허
강학상 인가
강학상 공법상 대리
준법률행위적 행정행위

♣ 사전테스트

1. 강학상 특허는 기속행위이다.
   정답 : ×

2. 기본행위에 하자가 있을 때 인가에 대하여 취소소송을 제기할 수 있다.
   정답 : X

3. 확인 중 준사법적 행정행위에는 불가변력이 발생한다.
   정답 : ○

♣ 돌발퀴즈

인가의 대상이 되는 기본행위는 법률적 행위 외에 사실행위도 포함된다.

[정답] ×

[해설] 인가는 법률행위의 효력을 보충하는 보충행위이므로 개념상 당연히 법률행위만을 대상으로 하고 사실행위를 대상으로 할 수는 없다. 이에 비해서 허가는 사실행위도 대상으로 한다.

♣ 강의내용

제1 법률행위적 행정행위 중 형성적 행정행위

1. 특 허

⑴ 의 의

특허란 특정 상대방을 위하여 새로운 권리·능력 또는 포괄적 법률관계(지위)를 설정하는 행위를 말하며, 이 중 권리를 설정하는 행위를 협의의 특허라고 한다. 특정인에게 재산상의 이익을 향유할 수 있는 「권리」설정행위의 예로서는 광업허가, 어업면허, 자동차·해상·항만·항공 등 각종 운수사업면허, 특허기업특허(이동통신사업면허 등), 공유수면매립면허, 어업면허, 공물사용권특허(도로점용허가, 하천점사용허가, 광업허가) 등이 있으며, 능력설정행위로는 재건축조합설립인가가 있고, 「포괄적 법률관계」설정행위로서는 공무원임명 ·귀화허가 등이 있다.

⑵ 성 질

1) 형성적 행정행위

2) 쌍방적 행정행위

3) 재량행위 여부

보세구역 설영특허는 공기업특허로서 재량행위라는 판례(대판 1989.5.9, 88누4188).

개인택시운송사업면허는 재량행위라는 판례(대판 1996.10.11, 96누6172).

공유수면매립면허는 특허인 바 재량행위라는 판례(대판 1989.9.12, 88누9206).

귀화허가는 재량행위라는 판례(대판 2010.7.15, 2009두19069)

⑶ 특허와 출원·형식·상대방

① 특허는 출원을 필요요건으로 하며, 출원이 없거나 그 취지에 반하는 특허는 완전한 효력을 발생할 수 없다. ② 여기서 특허란 행정행위로서의 특허를 말한다. ③ 특허는 언제나 특정인을 상대방으로 한다.

⑷ 효 과

1) 기본적 효력

특정상대방에 새로운 권리 능력 기타 법률상의 힘을 발생시킨다.

2) 특허의 이전성 : 강학상 허가 참조

3) 법률상이익 여부

① 상대방이 특허의 취소·정지처분에 원고적격 있음은 당연하고, 기존업자에게도 법률상이익이 인정되고 있다.

② 판례도 경업자소송에서 기존 특허업자에게 원칙적으로 법률상 이익이 있다고 보아 원고적격을 인정하였다.

2. 인 가

⑴ 의 의

인가라 함은 타인의 법률행위에 보충하여 그 법률행위의 효력을 완성시켜주는 행정행위를 말한다.

현행법상 인가의 예로서는 비영리법인 설립허가 및 정관변경인가, 특허기업(버스, 택시 등)의 운임 ·요금 인가, 사립학교법인 이사취임승인, 외국인 토지취득허가, 토지거래허가구역 내에서의 토지거래허가 등이 있다. 인가는 학문상의 개념이기 때문에 실정법상에서는 이처럼 허가·승인·인가 등의 용어로 사용되고 있다(판례 참조).

⑵ 성 질

인가는 법률행위의 효력발생요건이므로 인가받아야 할 행위를 인가받지 아니하고 행한 무인가행위는 원칙적으로 무효가 되며, 이 점에서 허가와 구별된다. 또한 인가의 기속성 여부는 근거법령의 법문언에 따라 판단하여야 한다. 법령에 특별한 규정이 없다면 인가의 대상이 공익적 견지에서 판단을 요하는 것인지 아니면 사익보호를 위한 것인지의 여부 등을 고려하여 판단하여야 한다.

⑶ 형 식

⑷ 대 상 - 법률행위

⑸ 신청과 수정인가

⑹ 기본행위와 인가상호간의 관계

1) 기본행위는 적법한데 인가에 하자가 있는 경우

첫째 기본행위는 적법한데 인가만 무효인 경우에는 무인가행위가 되고 기본행위의 효력이 완성되지 않는다. 둘째 기본행위는 적법한데 인가만 취소사유에 해당하는 하자가 있는 경우에는 인가가 유효한 바 기본행위의 효력을 무효로 만들기 위해선 인가 자체에 대한 취소쟁송을 제기하여야 한다.

2) 기본행위에 하자가 있는 경우

기본행위가 부존재하거나 무효인 경우 인가는 그 대상을 결여하므로 보충성에 비추어 무효이며 기본행위는 당연히 효력을 발생할 수 없다.

⑺ 인가의 하자에 대한 쟁송

1) 기본행위에 하자가 없고 인가에만 하자가 있는 경우

당연히 인가에 대해서 취소쟁송이나 무효확인쟁송을 제기할 수 있다.

2) 기본행위에 하자로 말미암아 인가에도 하자가 있는 경우

① 인가에 대한 항고쟁송은 협의의 소익이 없다는 견해

이 경우 기본행위에 하자가 있으므로 기본행위를 쟁송의 대상으로 삼아야 하고 보충행위인 인가에 대하여 취소소송이나 무효확인소송을 제기하는 것은 보다 용이한 구제방법이 있는 경우에 해당하여 소의 이익흠결로 각하되게 된다는 견해이다. 이 견해가 다수설이자 판례이다.

3. 공법상대리

⑴ 의 의

제3자가 행할 행위를 행정청이 대리하여 행하는 경우로 법률의 규정에 의한 공권력의 발동으로서 법정대리이다.

⑵ 종류

① 감독적인 목적 : 감독관청이 행하는 공법인의 정관작성·임원임면. 법인설립 등기신청.
② 당사자간의 협의 불성립시의 조정적 목적 : 사업시행자를 대신하여 토지수용위원회가 하는 수용재결.
③ 타인보호의 목적 : 연고 없는 사망자의 유품관리.
④ 국가 자신의 행정목적 달성 : 세금체납자에 대한 압류재산의 공매행위.

제2 준법률행위적 행정행위

Ⅰ. 준법률행위적 행정행위의 의의

준법률행위적 행정행위란 행위자인 행정청의 효과의사 이외의 정신작용 등을 구성요소로 하고 그 법적효과는 법규가 정하는 바에 따라 직접 발생하는 행정행위를 말한다.

Ⅱ. 준법률행위적 행정행위의 종류

1. 확 인

⑴ 의 의

확인이란 특정의 사실이나 법률관계에 관하여 의문이 있거나 다툼이 있는 경우에 공적 권위로써 그 존부나 정부를 확인하는 행정행위를 말한다. 확인에 해당하는 예로는 국가시험합격결정, 발명특허, 소득세부과를 위한 소득금액확인, 건축물의 준공검사, 행정심판의 재결, 교과서검정 등을 들 수 있다.

⑵ 법적 성질 - 근거법이 불분명하면 기속행위

⑶ 종 류

확인에는 행정분야에 따라 조직법상 확인(당선인의 결정·국가시험합격자결정), 급부행정법상 확인(도로구역결정·발명권특허·교과서검인정), 재정법상 확인(소득금액결정), 쟁송법상 확인(행정심판결정) 등으로 나눌 수 있다.

⑶ 법적 효과

확인행위의 효과는 개별법률이 정하는 바에 따라 정해진다. 또, 확인행위 중 준사법적 행위(행정심판의 재결 등)에는 처분청 스스로 직권취소 또는 철회 등을 할 수 없는 불가변력이 발생한다.

2. 통 지

⑴ 개 념

특정인 또는 불특정다수인에게 특정사실을 알리는 행위를 말한다. 행정행위로서의 통지의 예로는 대집행의 계고, 대집행영장의 통지, 국세징수법상의 독촉 등이 있다.

⑵ 법적 성질

통지도 준법률행위적 행정행위이기 때문에 당연히 항고소송의 대상인 처분성이 인정된다는 점에서 아무런 법적 효과도 결부되지 않는 사실행위로서의 통지와 구별된다.

3. 수 리

타인의 행정청에 대한 행위를 유효한 것으로 받아들이는 행위이다. 사직원수리, 혼인신고수리, 어업신고수리 등이 있다.

4. 공 증

⑴ 의 의

공증이란 특정사실이나 법률관계의 존부를 공적으로 증명하여 공적 증거력을 부여하는 행위를 말한다.

⑵ 성 질 - 근거법이 불분명하면 기속행위

⑶ 종 류 - 각종 공적 장부기재행위 / 각종 증명서발급행위

⑷ 법적 효과

공증의 공통적 효과는 공적증거력을 발생하는 데 있다[36].

또 공증은 공적 증거력 이외에 개별 법률이 정하는 바에 따라 법률효과가 부여되는 경우가 있다.

⑸ 공증의 처분성 인정여부

1) 문제점

공증이란 특정사실이나 법률관계의 존부를 공적으로 증명하여 공적 증거력을 부여하는 행위를 말하다. 그런데 이러한 공증의 법적효과인 공적 증거력이 권한있는 기관의 취소를 기다리지 않고서도 반증에 의해 번복이 가능하다는 점에서 공증의 처분성 여부가 문제된다.

2) 학 설

공증이 국민의 권리의무에 직접 영향을 미치는 경우에만 처분성이 인정된다는 것이 일반적인 견해이다.

---

36) 그러나 이러한 공증의 증거력은 그 증명된 것에 대한 반증이 있을 때까지는 일응 진실한 것으로 추정되는 효력을 가지는 데 그친다. 따라서 그에 대한 반증이 있는 때에는 행정청의 취소를 기다리지 아니하고, 그 증거력을 다투어 이를 번복할 수 있다.

3) 판 례

① 처분성을 부정한 경우

판례는 강학상 공증행위로 인정해온 것 중 행정사무의 편의나 사실증명의 자료를 얻기 위한 장부에의 기재행위나 그 기재내용의 수정요구를 거부하는 것 등은 모두 그 기재자체만으로 국민에게 어떤 권리를 제한하거나 의무를 명하는 등 법률적 효과를 발생시키는 것이 아니므로 항고소송의 대상이 되는 처분에 해당하지 않는다고 판시하고 있다.

② 처분성을 긍정한 경우

대법원은 지적공부에의 기재거부라 하더라도 토지분할신청 거부행위와 같이 국민의 권익에 직접적인 영향을 미치는 것은 항고소송의 대상이 된다고 판시하고 있다(대판 1992. 12. 8, 92누7542;대판 1993. 3. 23, 91누8968).

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 보건복지부장관 甲은 어느 의료법인의 乙에 대한 이사취임승인취소처분을 하였는데, 당해 처분은 위법한 것으로 밝혀졌다. 이와 관련한 다음 설명으로 옳지 않은 것은? (2007 관세사)

① 이사취임승인은 강학상 인가에 해당한다.
② 이사취임승인취소처분은 침익적 행정행위이다.
③ 乙을 甲과 당해 의료법인을 공동피고로 하여 이사취임승인취소처분에 대한 취소소송을 제기할 수 있다.
④ 甲은 직권으로도 이사취임승인취소처분을 취소할 수 있다.
⑤ 이사취임승인취소처분에 대한 취소가 있게 되면 乙의 이사로서의 지위는 소급적으로 회복하게 된다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

항고소송의 피고는 행정청인 보건복지부장관 甲이다(행정소송법 제13조 제1항).

정답 ③

2. 강학상의 인가에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 법규정이 없더라도 행정주체가 출원의 내용을 수정하여 인가할 수 있다고 봄이 일반적이다.
② 일반적으로 인가의 기본행위는 공법적 성질을 갖는 것에 한한다.
③ 기본행위가 무효인 경우, 인가처분만의 무효확인이나 그 취소를 구하는 것은 특단의 사정이 없는 한 분쟁해결의 유효적절한 수단이라 할 수 없으므로 인가처분의 무효확인이나 그 취소를 구할 법률상 이익이 없다.
④ 주택재건축조합이 재건축결의에서 결정된 내용과 다르게 사업시행계획을 작성하여 사업시행인가를 받았다면 인가처분이 근거조항상의 적법요건을 갖추고 있더라도 그 사업시행인가는 하자가 있는 것으로 보아야 한다.
⑤ 마약법상의 마약취급면허는 강학상 인가에 해당한다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 인가는 기본적 법률행위에 대한 당사자의 신청이 있는 경우에만 할 수 있다. 따라서 행정청은 인가의 신청에 대해 소극적으로 인가를 할 것인지의 여부만 결정할 수 있고, 적극적으로 수정인가를 할 수는 없다. 이에 비해서 허가는 수정허가가 있을 수 있다.

② 인가는 성질상 반드시 법률적 행위만을 대상으로 하므로 사실행위는 제외된다. 한편, 법률적 행위에는 공법상의 행위와 사법상의 행위가 포함된다. 또한 기본행위는 합동행위와 계약 모두 포함된다.

③ 기본행위는 적법유효하나 보충행위인 인가처분에만 하자가 있는 경우에는 그 인가처분의 취소나 무효확인을 구할 수 있을 것이지만 기본행위인 조합설립에 하자가 있는 경우에는 민사 쟁송으로써 따로 그 기본행위의 취소 또는 무효확인 등을 구하는 것은 별론으로 하고 기본행위의 불성립 또는 무효를 내세워 바로 그에 내한 감독청의 인가처분의 취소 또는 무효확인을 소구할 법률상 이익이 있다고 할 수 없다(대판 2000.9.5, 99두1854).

④ 구「도시 및 주거환경정비법」제16조 제2항의 가중된 의결정족수에 의한 찬성결의로 결정된 재건축결의사항은 대통령령이 정하는 경미한 사항의 변경에 해당하지 않는 한 위 법 제16조 제2항의 가중된 의결정족수에 의한 찬성결의에 의하지 아니하고는 변경될 수 없고, 따라서 조합의 사업시행계획도 원칙적으로 재건축결의에서 결정된 내용에 따라 작성되어야 하지만, 조합이 사업시행계획을 재건축결의에서 결정된 내용과 달리 작성한 경우 이러한 하자는 기본행위인 사업시행계획 작성행위의 하자이고, 이에 대한 보충행위인 행정청의 인가처분이 그 근거조항인 위 법 제28조의 적법요건을 갖추고 있는 이상은 그 인가처분 자체에 하자가 있는 것이라 할 수 없다(대판 2008.1.10, 2007두16691).

⑤ 강학상 허가에 해당한다.

정답 ③

3. 다음 중 나머지 것들과 성질이 다른 것은? (2007 서울9급)

① 체납처분절차에서의 압류재산의 공매처분
② 감독청에 의한 공법인의 임원임명
③ 당사자 간의 협의가 이루어지지 않는 경우의 수용재결
④ 행려병자, 사자의 유류품처분
⑤ 일반음식점 영업허가

해설 & 정답

유형 법률지식형

공법상 대리에는 ⅰ) 감독차원에서 이루어지거나(예 감독청에 의한 공공조합 등의 정관작성·임원의 임명, 행려병자, 사자의 유류품처분) ⅱ) 일반행정행위의 실효성을 도모하기 위하여(예 조세체납처분으로서의 공매처분) 또는 ⅲ) 당사자 사이의 협의가 이루어지지 않는 경우의 조정적 차원(예 건축법에 의한 특정가구정비지구 내에서의 건축에 대한 재정, 당사자 간의 협의가 이루어지지 않는 경우의 수용재결)에서 이루어진다. 그러므로 ①·②·③·④는 형성적 행정행위 중 제3자를 위한 행위로서 공법상 대리이다. ⑤는 명령적 행정행위 중 허가에 해당한다.

정답 ⑤

♣ 학습내용 정리

1. 강학상 특허는 보통 재량행위이고 상대방에게 독점적 권리를 부여한다.
2. 강학상 인가는 보충적 행위로서 법률행위만을 대상으로 한다.
3. 국민의 권리의무에 직접 영향을 미치는 장부기재행위 또는 그 거부만이 항고소송의 대상이 된다.

제14강 행정행위의 부관

♣ 학습목표

행정행위의 부관의 의의 및 종류, 부관의 가능성과 한계, 부관에 대한 쟁송과 관련하여 독립쟁송가능성과 독립취소가능성에 대한 학설을 이해하고 판례를 분석할 수 있다.

♣ 학습내용

부관의 의의 및 종류
부관의 가능성과 한계
부관의 독립쟁송가능성과 독립취소가능성

♣ 사전테스트

1. 법정부관도 강학상 부관이다.
정답 : ×

2. 기속행위에도 원칙적으로 부관을 붙일 수 있다.
정답 : X

3. 부관 중 부담만 취소소송의 대상이 될 수 있다는 것이 판례입장이다.
정답 : ○

♣ 돌발퀴즈

판례에 의하면 사정변경으로 인하여 당초에 부가한 부담의 목적을 달성할 수 없게 된 경우에는 목적 달성에 필요한 범위 내에서 그 부담을 사후 변경할 수 있다.

[정답] ○

[해설] 행정처분에 이미 부담이 부가되어 있는 상태에서 그 의무의 범위 또는 내용 등을 변경하는 부관의 사후변경은, 법률에 명문의 규정이 있거나 그 변경이 미리 유보되어 있는 경우 또는 상대방의 동의가 있는 경우에 한하여 허용되는 것이 원칙이지만, 사정변경으로 인하여 당초에 부담을 부가한 목적을 달성할 수 없게 된 경우에도 그 목적달성에 필요한 범위 내에서 예외적으로 허용된다(대판 1997.5.30, 97누2627).

♣ 강의내용

제1 부관의 의의 및 종류

Ⅰ. 개 설

1. 부관의 의의[37]

행정행위의 부관의 개념에 대하여 종래의 학설은 “행정행위의 효과를 제한하기 위하여 주된 의사표시에 붙여진 종된 의사표시”라고 정의하고 있다. 이에 반해 최근의 새로운 견해[38]는 행정행위의 부관을 “행정기관에 의하여 주된 행정행위에 부가되는 종된 규율”이라고 정의한다.

생각건대, 법률행위적 행정행위에만 부관을 붙일 수 있는 것이 아니라는 점, 법률요건충족적 부관 및 새로운 의무를 부과하는 부담을 모두 강학상 부관개념에 포함하기 위해서라도 새로운 견해가 타당하다고 생각된다.

2. 부관의 필요성

부관은 행정의 합리성·신축성·탄력성·경제성을 보장하는 의미를 갖는다.

3. 법정부관과의 구별

행정행위의 효과제한이 직접 법령에 규정된 경우 이를 법정부관이라 하여 여기서 말하는 행정행위에 부가되는 부관과는 구별하고 있다. 이러한 법정부관에 대한 다툼은 규범통제방식(위헌법률심판, 헌법소원, 위헌위법명령규칙심사)에 의하여야 한다.

Ⅱ. 부관의 종류

1. 조 건

조건이란 행정행위 효력의 발생, 소멸을 장래 발생이 불확실한 사실에 의존하게 하는 부관을 말한다. 이에는 조건의 성취에 의해 비로소 행정행위의 효력을 발생하는 정지조건과 조건의 성취에 의하여 그 법적 효과가 소멸하는 해제조건이 있다.

---

37) 1. 강학상 부관인가?

⑴ 법령에서 당해 조건이나 기한의 내용을 일의적으로 규정한 경우(근거법문언에 ‘광업허가의 유효기간은 20년이다’라고 규정된 경우) : 법정부관

⑵ 법령에서 조건이나 기한을 규정하고 있으나 그 내용을 일의적으로 규정하지 않은 경우(근거법문언에 ‘허가시 3년이내의 기한을 붙일 수 있다’라고 규정된 경우) : 강학상 부관

2. 강학상 부관의 종류

⑴ 기한부 행정행위에서의 기한

강학상 기한으로 종기다. 단 장기계속성있는 사업에서 부당히 짧은 기한이라면 허가조건의 존속기한이고 그렇지 않으면 허가의 존속기한이다.

⑵ 조건부 행정행위에서의 조건

강학상 조건, 철회권유보, 부담, 사후부담유보, 법률효과일부배제 중 어느 것인지를 써주면 된다. 히 당해 사안에서의 조건이 기한이나 철회권유보, 법률효과일부배제, 사후부담유보가 아니면 강학상 조건 아니면 부담인 바, 이에 대해선 조건과 부담의 구별기준에 대한 학설과 판례를 써주어야 한다. 그런데 일반적으로 요건보충적 부관은 정지조건으로 해석되고, '취소할 수 있다'는 조건은 강학상 철회권유보이고, 영업구역조건 및 격일제조건은 강학상 법률효과일부배제이고, ‘나중에 ~하면 기부채납조건을 부가할 수 있다’는 조건은 사후부담유보이고, 그 이외의 조건, 예컨대 기부채납조건은 강학상 부담이다

38) 박균성, 행정법강의 제3판, 제256면.

2. 기 한

이는 행정행위의 효력의 발생 또는 소멸을 장래 도래할 것이 확실한 사실에 의존시키는 부관을 말한다(2년기한부 도로점용허가에게 2년기한은 장래 도래가 확실한 사실로서 2년기한이 도래하면 당해 도로점용허가의 효력을 소멸시키는 강학상 기한이다).

3. 부 담

⑴ 의 의

부담이란 주된 행정행위에 부가하여 그 행정행위의 상대방에 대하여 작위·부작위·급부·수인의무를 명하는 부관을 말한다.

⑵ 법적 성질 - 부관임과 동시에 하명

⑶ 부담과 조건과의 구별

당해 부관이 조건인가 부담인가를 판단하는 기준은, ① 우선적으로 당해 부관에 표현된 행정청의 객관화된 법효과의사로 구별하되(예컨대 부가된 부관이 행정행위의 법률요건과 밀접한 관계에 있는 경우에는 당해 부관은 정지조건이라고 볼 수 있다), ② 그러한 기준에 의해도 불명확한 경우에는 당사자에게 침익성이 적은 부담으로 해석하여야 할 것이다.

판례는 '부관의 필요성, 행정청의 객관화된 의사, 행정관행' 등을 근거로 조건과 부담을 구별하고 있다.

4. 철회권 유보

⑴ 의 의

철회권유보란 장래의 일정한 사유가 발생하는 경우에는 그 행정행위를 철회할 수 있는 권리를 유보하는 부관을 말한다.

이러한 철회권 유보는 처분 상대방에게 사후에 철회의 가능성이 있음을 알게 하여 보호가치 있는 신뢰가 성립되지 않게 하려는 데 그 의의가 있다.

⑵ 법적 성질 - 별개의 부관

⑶ 법적 근거 - 법적근거 없어도 철회권유보가능(판례)

⑷ 철회권의 행사의 한계 - 이익형량(비례원칙), 단 신뢰보호원칙은 주장불가

5. 사후부담유보 및 부담의 변경권 유보

사후부담의 유보라 함은 행정행위를 발하면서 사후에 부담을 부가할 수 있는 권한을 유보하는 부관을 말한다. 부담의 변경권 유보란 행정행위에 붙인 부담을 장래에 추가 또는 변경할 권한을 미리 유보하는 부관을 말한다(예컨대 '나중에 이 지역이 주거지역으로 변경되면 소음방지시설건설조건을 부가할 수 있다'는 조건부 공장신축허가).

6. 수정부담

7. 법률효과의 일부배제

제2 부관의 가능성과 한계

1. 부관의 가능성

⑴ 준법률행위적 행정행위에 부관을 붙일 수 있는지 여부

종래의 통설은 의사표시가 없는 준법률행위적 행정행위에는 부관을 부가할 수 없다고 보았다. 그러나 부관의 가능성 문제는 개별적 행정행위의 성질에 따라서 고찰해야 하므로, 법률행위적 행정행위이면서도 부관을 붙일 수가 없는 경우가 있는 반면(예컨대, 귀화허가), 준법률행위적 행정행위이면서도 법률규정 자체에 의하여 허용되기 때문에 부관을 붙일 수 있는 경우도 있다(예컨대, 여권의 유효기간, 인감증명). 따라서 개별적으로 판단하는 견해가 타당하다.

⑵ 기속행위에 부관을 붙일 수 있는지 여부

1) 종래의 통설과 판례

종래의 통설은 재량행위에만 부관을 붙일 수 있고 기속행위에는 부관을 붙일 수 없다고 한다. 그 이유는 기속행위의 경우에는 행정청은 법규에 엄격하게 기속되고, 기계적으로 그것을 집행하는 데 그치며, 법규가 정한 법률효과를 임의로 제한할 수는 없다는 것이다.

2) 새로운 견해

행정행위에 부관을 붙일 수 있는지 여부는 재량행위인지 여부에 따라 일률적으로 결정할 것이 아니라 개개 행정행위의 목적 및 성질, 부관의 형태 등을 아울러 검토하여 결정하여야 한다는 견해이다. 기속행위라 할지라도 ①장래에 있어서 법률요건의 충족을 확보하는 요건충족적 부관은 붙일 수 있고 또한 ②법령에 부관을 붙이는 것이 허용되는 경우에는 부관을 붙일 수 있다고 한다.

2. 사후부관 및 부관의 사후변경의 가능성

⑴ 사후부관 및 부관의 사후변경의 의의

사후부관은 행정청이 주된 행정행위 발령시에는 부관을 부가하지 않고 나중에 부관을 부가하는 것을 말하고, 부관의 사후변경은 행정청이 처음 발령한 부관부 행정행위에서 부관의 내용을 사후에 변경하는 것을 말한다.

⑵ 사후부관 및 부관의 사후변경의 가능성에 대한 학설

① 부관의 부종성에 반하므로 불가하다는 부정설, ② 부담은 주된 행정행위와 독립된 별개의 행정행위이므로 사후부담 등이 가능하다는 긍정설, ③ 원칙적으로는 부관의 부종성 때문에 부정되나 예외적으로 법령에 근거가 있거나, 상대방의 동의가 있거나, 부담이 유보되어 있는 경우에는 가능하다는 제한적 긍정설(다수설)이 대립한다.

⑶ 판례

판례는 위 제한적 긍정설에서 든 사유 외에도 사정변경으로 인하여 당초에 부담을 부가한 목적을 달성할 수 없게 된 경우에도 그 목적달성에 필요한 범위 내에서 예외적으로 부담의 사후변경을 허용하고 있다.

3. 부관의 일반적 한계

⑴ 법령상의 한계

⑵ 목적에 의한 한계

⑶ 행정법의 일반원리상의 한계

⑷ 이행가능하고 명확해야 함

제3 부관의 독립쟁송가능성과 독립취소가능성

1. 부관의 독립쟁송가능성과 쟁송형태

⑴ 논의의 전제

이러한 논의는 부관부 행정행위의 전체를 대상으로 그 위법한 부관을 다툴 수 있다는 데에는 이견이 없으므로, 부관부 행정행위에 있어서 부관에만 하자가 있는 경우에 부관만의 취소를 구하는 것이 가능한가의 문제라고 할 수 있다.

⑵ 학 설

① 부담은 그 자체가 하명의 성질도 지니고 있어 처분성이 인정되므로 진정일부취소소송을 제기할 수 있고 기타 부관은 처분성이 인정되지 않는 바 부진정일부취소소송을 제기하여야 한다는 견해, ② 소의 이익이 있는 한 모든 부관에 대하여 독립쟁송이 가능하나 쟁송형태는 부진정일부취소소송이어야 한다는 견해, ③ 분리가능성있는 부관만 독립쟁송이 가능하다고 보고 쟁송형태는 분리가능성있는 부관 중 부담은 진정일부취소소송으로 기타부관은 부진정일부취소소송으로 다투고, 분리가능성없는 부관은 전제취소소송을 제기하여야 한다는 견해 등이 대립한다.

⑶ 판 례

판례는, 부담은 그 존속이 주된 행정행위의 존재를 전제로 하는 것일 뿐, 그 자체로서 하나의 행정행위(하명)가 되는 것이기 때문에 직접 행정소송의 대상이 될 수 있으나, 그 밖의 부관은 행정행위의 주된 의사표시 부분에 종속된 의사표시로서 양자는 합하여 하나의 행정행위를 이루는 것이므로 기타 부관만을 떼어 독립적인 쟁송의 대상으로 삼을 수 없다는 것이다.

따라서 판례에 의하면 부담에 대해선 부담만의 진정일부취소소송을 제기할 수 있으나, 기타 부관에 대해선 기타 부관만의 취소를 구하지 못하는 바 기타 부관부 행정행위 전체 취소소송 또는 부관없는 행정행위로 변경해달라고 신청한 후 거부되면 거부처분취소소송을 제기하여야 한다고 한다.

2. 부관의 독립취소가능성

⑴ 학 설

① 기속행위인 경우에는 요건충족적 부관을 제외한 나머지 부관은 독립취소가 가능하나 재량행위인 경우에는 당해 부관이 주된 행정행위에 본질적 요소인지에 따라 독립취소가능여부를 검토하는 견해, ② 소송물이론에 따라 부관만의 취소를 구하는 경우 모든 부관에 대하여 독립취소가능성을 인정하는 견해, ③ 일부취소가능성에 따라 부담만 독립취소가 가능하다는 견해, ④ 기

속행위인지 재량행위인지 구별없이 당해 부관이 주된 행정행위에 본질적 요소인지에 따라 독립취소가능여부를 검토하는 견해 등이 대립한다.

⑵ 판례

판례는 부담은 주된 행정행위와 독립된 행정행위로서 부담만 취소소송제기가 가능한 바 부담만 취소판결 가능하다는 입장이다. 그러나 기타 부관은 주된 행정행위와 분리될 수 없는 바 기타 부관만 취소를 구하는 것이 불가능한 바 기타 부관만 취소할 수 없다는 입장이다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 행정행위의 부관에 관한 설명 중 옳은 것은?

① 영업허가를 함에 있어 부담으로 상대방에게 영업상 준수하여야 할 의무를 명한 경우, 상대방의 의무불이행이 있으면 허가의 효력은 당연히 소멸한다.
② 하천점용허가를 함에 있어 철회권을 유보한 경우 행정청은 언제나 자유로이 철회권을 행사할 수 있다.
③ 판례에 의하면, 도로점용허가에서 부관인 점용기간을 정함에 있어서 위법사유가 있다하더라도 도로점용허가 전체가 위법하게 되지는 않는다.
④ 부담부 행정행위는 정지조건부 행정행위와 달리 처음부터 효력이 발생한다.
⑤ 부관이 무효인 경우 행정행위 전체가 무효로 된다는 것이 통설이다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 부담의 불이행으로 허가의 효력이 당연히 소멸하는 것이 아니라, 부담의 불이행을 이유로 행정청이 철회를 해야 효력이 소멸된다.
② 철회사유가 발생한 경우에도 행정청은 자유로이 철회할 수 있는 것은 아니고 철회권 제한법리가 적용된다. 그러나 철회권이 유보된 경우 상대방은 철회가능성을 예견할 수 있으므로 신뢰보호원칙의 주장에 제한되므로 철회의 제한이나 철회로 인한 손실보상을 청구할 수는 없게 된다는 점에서 존재의의가 있다.
③ 도로점용허가의 점용기간은 행정행위의 본질적인 요소에 해당한다고 볼 것이어서 부관인 점용기간을 정함에 있어서 위법사유가 있다면 이로써 도로점용허가처분 전부가 위법하게 된다(대판 1985.7.9, 84누604).
④ 정지조건부 행정행위는 조건 성취시 행정행위의 효력이 발생한다.
⑤ 부관의 하자 정도가 무효이면서 행정행위의 본질요소 즉 중요요소인 경우에만 행정행위 전체가 무효가 된다.

정답 ④

2. 행정행위의 부관에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 행정청은 법령에 명시적인 근거가 없으면 부관을 붙일 수 없다는 것이 판례의 태도이다.
② 철회권의 유보로서 그 철회사유는 법령에 규정이 있는 경우가 아니라고 하더라도 의무 위반이 있는 경우 또는 중대한 공익상의 필요가 발생한 경우 등에 가능하다.
③ 조건이 성취되어야 행정행위가 비로소 효력을 발생하는 조건을 해제조건이라 하고 행정행위가 일단 효력을 발생하고 조건이 성취되면 행정행위가 효력을 상실하는 조건을 정지조건이라 한다.
④ 행정행위에 조건을 붙이는 것은 행정법관계의 안정을 해치는 것으로 절대로 허용될 수 없다.
⑤ 부담은 주된 행정행위의 구성부분이지만, 조건은 주된 행정행위의 구성부분은 아니다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 법률의 명문규정이 없더라도 특허 등의 수익적 행정행위와 재량행위에 부관을 붙일 수 있다는 데에 이론이 없다. 판례도 같은 입장이다(대판 1997.3.11, 96다49650).

③ 행정행위의 효력의 발생을 장래의 불확실한 사실에 의존하게 하는 부관이 정지조건이고, 행정행위의 효력의 소멸을 장래의 불확실한 사실에 의존하게 하는 부관이 해제조건이다.

④ 조건이란 행정행위의 효력의 발생을 장래의 불확실한 사실에 의존하게 하는 부관을 말한다. 행정법관계를 오랫동안 불안정한 상태에 놓아두는 것은 공익상 적당하지 않기 때문에 조건부 행정행위는 많지 않지만, 전혀 허용되지 않는 것은 아니다.

⑤ 설명이 반대이다. 즉, 부담의 경우에는 다른 부관과는 달리 행정행위의 불가분적인 요소가 아니고 그 존속이 본체인 행정행위의 존재를 전제로 하는 것일 뿐이므로 부담 그 자체로서 행정쟁송의 대상이 될 수 있다(대판 1992.1.21, 91누1264).

정답 ②

3. 행정행위의 부관에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 따름)

① 기속행위의 경우에 실정법상 부관의 부과가능성은 존재하지 않는다.

② 부관의 사후변경은 법률에 명문의 규정이 있는 경우에 허용된다.

③ 모든 부관은 그 자체로서 독립적인 행정쟁송의 대상이 된다.

④ 독일연방행정절차법에 의하면 주된 법률행위의 법률요건을 보충하는 부관은 무효이다.

⑤ 부담은 주된 행정행위에 부가하여 상대방에게 의무를 부과하는 것이므로, 주된 행정행위가 효력을 발생하지 않더라도 부담으로 부과된 의무는 이에 영향을 받지 아니하고 효력을 발생한다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 다수설은 기속행위라 하더라도 ⅰ) 부관을 붙일 수 있다는 법적 근거가 있는 경우나, ⅱ) 법률요건 충족적 부관의 경우에는 부관을 붙일 수 있고, 귀화허가는 재량행위지만 성질상 부관을 붙일 수 없으므로, 획일적으로 부관의 가능성을 논함은 무의미하고 개별적으로 검토해야 한다는 견해이다. 다만, 이 견해에 의하더라도 기속행위의 경우 법효과제한적 부관에 대해서는 부관의 부가가 불가능하다.

② 행정처분에 이미 부담이 부가되어 있는 상태에서 그 의무의 범위 또는 내용 등을 변경하는 부관의 사후변경은 법률에 명문의 규정이 있거나 그 변경이 미리 유보되어 있는 경우 또는 상대방의 동의가 있는 경우에 한하여 허용되는 것이 원칙이지만, 사정변경으로 인하여 당초에 부담을 부가한 목적을 달성할 수 없게 된 경우에도 그 목적달성에 필요한 범위 내에서 예외적으로 허용된다(대판 1997.5.30, 97누27).

③⑤ 행정행위의 부관은 행정행위의 일반적인 효력이나 효과를 제한하기 위하여 의사표시의 주된 내용에 부가되는 종된 의사표시이지 그 자체로서 직접 법적 효과를 발생하는 독립된 처분이 아니므로 현행 행정쟁송제도 아래서는 부관 그 자체만을 독립된 쟁송의 대상으로 할 수 없는 것이 원칙이나 행정행위의 부관 중에서도 행정행위에 부수하여 그 행정행위의 상대방에게 일정한 의무를 부과하는 행정청의 의사표시인 부담의 경우에는 다른 부관과는 달리 행정행위의 불가분적인 요소가 아니고 그 존속이 본체인 행정행위의 존재를 전제로 하는 것일 뿐이므로 부담 그 자체로서 행정쟁송의 대상이 될 수 있다(대판 1992.1.21, 91누1264).

④ 독일연방행정절차법 제36조는 기속행위의 경우에 '법령에 의하여 허용되거나'라는 표현을 통하여 법령상 근거가 마련된다면 기속행위의 경우에 부관이 가능함을 명시하고 있다.

정답 ②

♣ 학습내용 정리

1. 강학상 부관은 행정청에 의해 주된 행정행위에 부가된 종된 규율로서 그 종류로는 부담, 조건, 기한, 철회권유보, 사후부담유보, 법률효과일부배제 등이 있다.
2. 부관의 가능성과 일반적 한계를 위반한 부관은 위법하다.
3. 판례는 부관 중 부담만 취소소송의 대상이 되고 법원도 부담만 취소판결 내릴 수 있다는 입장이다.

제15강 행정행위의 효력

♣ 학습목표

행정행위의 효력으로서 공정력, 구성요건적 효력 및 선결문제에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

공정력의 의의 및 근거
구성요건적 효력의 의의 및 근거
선결문제

♣ 사전테스트

1. 공정력은 무효인 행정행위에도 인정된다.
   정답 : ×

2. 구성요건적 효력은 처분상대방에게 미치는 효력이다.
   정답 : X

3. 권한없는 민사법원도 행정행위의 위법여부는 심리할 수 있다는 것이 다수설과 판례이다.
   정답 : ○

♣ 돌발퀴즈

행정소송법은 무효·부존재·취소사유에 대해서 선결문제에 대한 명문의 규정을 가진다.

[정답] ×

[해설] 처분 등의 효력 유무 또는 존재 여부가 민사소송의 선결문제로 되어 당해 민사소송의 수소법원이 이를 심리·판단하는 경우에는 제17조, 제25조, 제26조 및 제33조의 규정을 준용한다(행정소송법 제11조 제1항). 취소사유에 대한 명문규정이 없어 견해 대립이 존재한다.

♣ 강의내용

제1 공정력

1. 개 설

⑴ 공정력의 의의

1) 전통적 견해와 판례

전통적 견해와 판례에 의할 때 공정력이란 행정행위에 하자가 있는 경우에 그것이 중대 명백하여 당연무효가 아닌 한, 권한있는 기관(처분청, 취소심판을 맡은 행정심판위원회, 취소소송을 맡은 행정법원)에 의하여 취소(직권취소, 취소재결, 취소판결)되기 전까지 상대방이나 이해관계인 뿐만 아니라 취소권한없는 다른 행정청 및 법원에 대하여 일단 유효하게 통용되는 힘을 말한다.

2) 공정력과 구성요건적 효력을 구분하는 견해

공정력은 '행정행위가 무효가 아닌 한 상대방 또는 이해관계인은 행정행위가 권한있는 기관에 의해 취소되기까지는 그의 효력을 부인할 수 없는 힘'이라고 정의한다.

⑵ 문제점

행정행위의 공정력은 법치국가원리와 여하히 조화할 것인가와 관련하여 의문을 제기하게 한다. 공정력을 인정하게 하는 실정법상 근거와 그 정도 및 한계가 문제되는 것이다.

2. 인정근거

⑴ 이론적 근거

자기확인설, 국가권위설, 예선적 특권설, 법적 안정성설 등이 대립하고 있으나, 자기확인설과 국가권위설은 관료적이며 권위주의적인 발상일 뿐만 아니라 현대 법치주의이념에 부합하지 않고, 예선적 특권설은 법적 안정성설과 크게 다르지 않다. 따라서 행정행위의 적법성에 의심이 있는 경우에도 행정법관계의 안정성을 도모하고 행정목적의 신속한 실현을 도모하기 위해 공정력을 인정한다는 법적 안정성설이 타당하다.

⑵ 실정법적 근거

직접적인 규정은 없으나 간접적 근거로는 첫째 개별법상의 직권취소 규정, 둘째 취소심판 및 취소소송에 관한 규정 등이 있다. 집행부정지규정(행정소송법 제23조 제1항)을 근거로 드는 견해도 있으나 집행정지여부는 입법정책의 문제로서 공정력과 무관하다고 보는 것이 타당하다.

3. 공정력의 인정범위

⑴ 무효인 행정행위

⑵ 행정행위 이외의 행정작용

4. 공정력과 입증책임 -무관계

제2 구성요건적 효력

1. 서

⑴ 의 의

행정행위의 구성요건적 효력이란 유효한 행정행위가 존재하는 이상 하자가 있는 행위일지라도 취소권이 없는 다른 국가기관은 그 존재를 존중하며 스스로의 판단의 기초 내지 구성요건으로 삼아야 하는 구속력을 말한다.

⑵ 공정력과의 관계

행정행위의 구성요건적 효력과 공정력은 그 효력의 내용과 범위, 이론적·법적 근거를 달리하므로, 양자는 구별되어야 할 충분한 이유가 있다.

2. 근 거 - 국가기관 상호간의 권한존중

3. 선결문제

⑴ 선결문제의 의의

선결문제란 특정소송사건에 대한 본안을 판단하기 위하여 특정한 행정행위의 효력유무나 위법여부가 먼저 해결되어야 하는 경우 당해 법원이 본안판단의 전제로서 행정행위의 위법여부나 효력유무를 심리하는 것을 말한다.

그런데 행정소송법 제11조는 민사소송에서의 본안판단의 전제로서 행정처분의 무효여부 또는 부존재 여부에 대한 분쟁을 선결문제로서 심리할 수 있다고 규정하고 있다. 따라서 행정행위가 무효나 부존재인 경우에는 행정소송법 제11조에 따라 민사법원은 민사소송에서 그 효력을 부인하고 판단할 수 있다. 그러나 문제는 행정행위의 하자가 단순위법인 경우와 형사소송이다. 이에 관해 행정소송법 제11조는 명문의 규정을 두고 있지 않으므로 학설과 판례의 해석에 의해 해결되게 된다.

⑵ 구성요건 효력과의 관계

구성요건적 효력을 부정하는 판례에 따르면 선결문제는 공정력문제가 되고 구성요건적 효력을 긍정하는 견해에 따르면 선결문제는 권한없는 민사법원이나 형사법원에 대한 것인 바 구성요건적 효력문제가 된다.

⑶ 민사소송과 선결문제

1) 행정행위의 위법성 여부가 선결문제인 경우

국가배상청구소송에 대하여 판례는 민사소송으로 다수설은 당사자소송으로 제기하여야 한다고 한다. 당사자소송으로 제기하더라도 당사자소송을 맡은 행정법원은 당해 처분에 대하여 취소판결할 수 없는 권한없는 법원인 건 민사법원과 마찬가지이다. 결국 권한없는 법원이 당해 처분의 위법성을 행정상 손해배상청구소송의 전제요건으로서 심사할 수 있는가에 대하여 학설이 대립한다.

① 부정설

ⅰ) 구성요건적 효력(공정력)에 의해 적법성추정, ⅱ) 행정소송법 제11조 제1항에서 위법여부를 선결문제로 심리할 수 있도록 규정하지 않음.

② 긍정설

ⅰ) 구성요건적 효력(공정력)은 유효성추정일 뿐 적법성추정이 아님, ⅱ) 행정소송법 제11조 제1항은 예시적인 것, ⅲ) 선결문제로 권한없는 법원이 위법성 여부를 심리한다고 하여 그 효력을 부인하는 것은 아니라는 점.

③ 절충설

국가배상청구를 인정하게 되면 당해 행정행위의 목적을 방해하는 경우에는 실질적으로 행정행위의 효력을 부인하는 결과를 가져오므로 심사할 수 없다는 견해이다.

④ 판례

긍정설의 입장이다.

「위법한 행정대집행이 완료되면 그 처분의 무효확인 또는 취소를 구할 소의 이익은 없다 하더라도, 미리 그 행정처분의 취소판결이 있어야만, 그 행정처분의 위법임을 이유로 한 손해배상청구를 할 수 있는 것은 아니다」(대판 1972. 4. 28, 72다337).

3) 행정행위의 효력유무가 선결문제인 경우(부당이득반환청구소송)

행정행위의 효력을 상실시키는 것이 민사소송에서 선결문제가 된 경우에 민사법원은 위법한 행정행위의 효력을 상실시킬 수 없다. 다만, 과세처분이 당연무효인 경우에는 그 처분에는 구성요건적 효력이 인정되지 않으므로 법원은 당연무효임을 심리·판단하여 원고의 청구를 인용할 수 있다.

⑷ 형사사건과 선결문제

1) 행정행위의 적법성 인정문제 - 행정행위위반, 방해, 불응 등이 범죄구성요건인 경우

① 부정설

ⅰ) 구성요건적 효력(공정력)에 의해 적법성추정, ⅱ) 행정소송법 제11조 제1항에서 위법여부를 선결문제로 심리할 수 있도록 규정하지 않음.

② 긍정설

ⅰ) 구성요건적 효력(공정력)은 유효성추정일 뿐 적법성추정이 아님, ⅱ) 행정소송법 제11조 제1항은 예시적인 것, ⅲ) 선결문제로 권한없는 법원이 위법성 여부를 심리한다고 하여 그 효력을 부인하는 것은 아니라는 점.

③ 판례의 태도 - 긍정설

판례는 긍정설과 동일하게 행정행위 위반이 범죄구성요건을 이루는 경우 형사법원은 그 행정행위의 위법성 여부를 심사할 수 있다고 판시하고 있다 .따라서 그 행정행위가 위법하면 위법한 명령에 따르지 않은 피고인에 대해 무죄판결을 선고하였다.

④ 검토

구성요건적 효력은 적법성의 추정이 아니라 유효성의 추정에 불과하다는 점, 행정행위의 효력을 부인하지 않고 그 적법성 여부만 심사하는 것은 구성요건적 효력에 반하는 것이 아니라는 점. 형사소송에서의 선결문제를 민사소송에서의 선결문제와 달리 평가할 이유가 없다는 점 등을 고려해 볼 때 다수설과 판례인 긍정설이 타당하다

2) 행정행위의 효력을 부인하는 것이 선결문제(무면허운전, 무허가영업 등)

① 행정행위가 당연무효인 경우

행정행위가 당연무효라면 구성요건적 효력(공정력)이 발생하지 않고 누구든지 그 효력을 부인할수 있다. 따라서 형사법원도 그 행정행위가 무효임을 전제로 판결을 할 수 있다.

② 행정행위에 취소사유의 하자가 있는 경우

다수설은 형사법원이 취소정도의 하자가 있는 행정행위의 효력을 부인하는 것은 민사소송에서처럼 구성요건적 효력(공정력)에 반하는 것이므로 허용되지 않는다는 것이다.

판례도 다수설과 같이 형사소송에도 공정력이 미친다는 입장에서 형사법원은 행정행위가 당연무효가 아닌 한 그 효력을 부인할 수 없다고 판시하고 있다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 행정행위의 효력과 관련된 설명으로서 옳지 않은 것은? (2005 국회8급)

① 행정행위가 위법이라는 이유로 국가배상이 청구된 경우에는 수소법원인 민사법원은 당해 행정행위의 위법성을 심사하여 배상을 명할 수 있다.
② 공정력은 행정쟁송절차가 있음으로 인해 인정되는 것이고, 구성요건적 효력은 국가기관의 권한분배로 인해 인정되는 것이다.
③ 강제집행을 수반하는 행정행위는 법률의 근거가 있어야 한다.
④ 불가쟁력은 주로 행정의 능률성을, 불가변력은 주로 상대방의 법적 안정성을 위한 것이다.
⑤ 행정행위가 무효인지의 여부는 행정법원만이 최종적으로 확인할 수 있는 것이므로 형사법원이 행정행위의 무효를 전제로 형사처벌을 할 수는 없다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

효력부인과는 달리 무효 여부에 대하여는 민사법원이든 형사법원이든 선결문제로 심리할 수 있다.

정답 ⑤

2. 공정력에 관한 설명으로 옳은 것은 모두 몇 개인가? (2003 행정고시)

㉠ 공정력은 행정행위가 위법 또는 당연무효에 있어서도 권한 있는 기관에 의한 취소 또는 무효확인이 있기까지는 상대방에 대한 구속력이 있다는 것의 승인을 강요하는 힘이다.
㉡ 형식적 행정행위론은 대상행위의 공정력 인정 여부 등의 문제를 야기한다.
㉢ 위법한 행정행위에 대한 국가배상소송의 수소법원은 당해 행정행위의 취소 여부와 상관없이 그 위법성을 확인하여 배상을 명할 수 있다.
㉣ 다수설은 법적안정(성)설을 공정력의 이론적 근거로 본다.
㉤ 다수설은 형사소송의 특수성을 고려하여, 행정행위의 위법성 확인 여부가 선결문제로 되는 때에도 형사법원은 스스로 위법성 판단을 할 수 없다고 한다.
㉥ 사기・강박・증수뢰 등 부정행위에 의한 행정행위는 공정력이 인정되지 않는다.
㉦ 판례는 선결문제를 공정력이 아닌 구성요건적 효력의 문제로 파악하고 있다.
㉧ 공정력의 근거규정으로는 쟁송취소에 관한 규정을 들 수 있지만 이는 간접적 근거규정에 불과하며, 공정력이 직접 표현된 실정법 규정은 없다.

① 2개 ② 3개

③ 4개 ④ 5개

⑤ 6개

해설 & 정답

유형 법률지식형

㉠ [×] 무효인 행정행위에는 공정력이 인정되지 않는다.

㉡ [○] 형식적 행정행위란 실체적으로는 행정행위가 아니지만 항고소송의 대상을 확대하기 위해 항고소송의 대상과 관련해서 형식적으로나마 행정행위로 보아주자는 논의인데, 그렇다면 항고소송의 대상 이외의 문제에서까지 행정행위로 다루어 공정력 등의 효력까지 인정하느냐의 문제가 제기된다.

㉢ [○] 판례의 태도이다(대판 1972.4.28, 72다337).

㉣ [○] 공정력의 이론적 근거에 대해서 자기확인설, 국가권위설, 예선적 특권설, 법적안정설 등의 견해 대립이 있는데 법적 안정설이 현재의 다수설이다.

㉤ [×] 행정행위의 위법성 확인 여부가 선결문제로 되는 때에는 행정행위의 위법성 여부는 심리할 수 있다.

㉥ [×] 사기·강박에 의한 행정행위는 취소할 수 있는 행정행위이므로 공정력이 인정된다.

㉦ [×] 판례는 선결문제 심리 여부에 관해 판시하고 있지만, 이론적 근거와 관련하여 공정력이나 구성요건적 효력과 매개하지는 않고 있다.

㉧ [○] 그밖에 행정행위의 직권취소를 인정하는 개별법상의 규정도 그 근거가 된다.

정답 ③

3. 행정행위의 구성요건적 효력에 대한 다음 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

① 행정행위의 위법 여부가 선결문제인 경우 민사법원이 선결문제인 행정행위의 위법 여부를 판단할 수 있다는 것이 대법원의 견해이다.

② 처분이 무효인 경우에는 구성요건적 효력이 인정되지 않는다.

③ 구성요건적 효력의 근거는 국가기관이 권한과 직무 또는 관할을 달리하는 데 있다.

④ 형사법원은 연령을 속여 발급받은 운전면허에 의한 운전행위를 무면허운전으로 처벌할 수 있다.

⑤ 국가배상소송의 수소법원은 행정행위의 불가쟁력이 발생된 후라도 그 위법성 여부를 심사하여, 만일 위법하다고 인정된다면 원고의 청구를 인용할 수 있다고 보는 것이 판례의 태도이다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 위법한 행정대집행이 완료되면 그 처분의 무효확인 또는 취소를 구할 소의 이익은 없다 하더라도, 미리 그 행정처분의 취소판결이 있어야만 그 행정처분의 위법임을 이유로 한 손해배상청구를 할 수 있는 것은 아니다(대판 1972.4.28, 72다337).

③ 공정력과 구성요건적 효력을 구분하는 견해의 논거이다.

④ 연령미달의 결격자인 피고인이 소외인의 이름으로 운전면허시험에 응시, 합격하여 교부받은 운전면허는 당연무효가 아니고 도로교통법 제65조 제3호의 사유에 해당함에 불과하여 취소되지 않는 한 유효하므로 피고인의 운전행위는 무면허운전에 해당하지 아니한다(대판 1982.6.8, 80도2646).

⑤ 학설은 대체로 적극적이나 과세처분과 같은 금전급부의무를 부과하는 행정처분의 경우에 한해서는 불가쟁력에 반한다는 이유로 위 과세처분에 대한 위법성을 심사할 수 없다고 보는 반대견해가 있다. 판례는 쟁송기간을 도과한 과세처분에 대해서도 국가배상청구소송을 제기해 정당한 세액의 초과범위를 반환받을 수 있다고 본다(대판 1979.4.10, 79다262).

정답 ④

♣ 학습내용 정리

1. 공정력과 구성요건적 효력을 구분하는 견해에 따르면 선결문제는 구성요건적 효력문제이다.
2. 권한없는 법원은 행정행위의 위법여부를 심리할 수 있으나 행정행위의 효력을 부인할 수 없다는 것이 다수설과 판례이다.

제16강 행정행위의 하자 I

♣ 학습목표

행정행위의 성립요건, 적법요건, 효력발생요건 및 행정행위의 하자의 종류, 그리고 무효와 취소의 구별기준과 구별실익을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

행정행위의 성립요건, 적법요건, 효력발생요건
행정행위의 하자의 종류
무효와 취소의 구별기준과 구별실익

♣ 사전테스트

1. 부당은 행정행위의 하자가 아니다.
   정답 : ×

2. 무효와 취소의 구별기준으로 중대설이 다수설과 판례이다.
   정답 : X

3. 하자의 승계에 대한 논의는 취소사유인 경우에 문제된다.
   정답 : ○

♣ 돌발퀴즈

행정행위의 근거법률이 사후적으로 위헌이 된 경우, 당해 처분은 당연무효라는 것이 판례의 입장이다.

[정답] ×

[해설] 위헌결정 전에 위헌법률에 근거하여 내린 처분(행정처분 후에 위헌결정이 난 경우)은 위헌으로서 중대한 하자이지만 위헌여부가 명백하지는 않으므로 취소사유에 해당한다(대판 2006.3.9, 2003두2861). 이에 비해서 위헌결정이 난 후에는 위헌으로 결정된 법률에 근거하여 내린 처분은 위헌이라는 사실이 공식적으로 명백하게 확정되었기 때문에 그 하자가 중대명백하여 당연무효라는 것이 판례의 입장이다(대판 2002.11.22, 2002다46102).

♣ 강의내용

제1 행정행위의 성립요건, 적법요건, 효력발생요건

Ⅰ. 행정행위의 성립요건

Ⅱ. 행정행위의 적법요건

1. 주체에 관한 요건

2. 내용에 관한 요건

3. 절차에 관한 요건(개별절차법 → 행정절차법)

4. 형식에 관한 요건(행정절차법 제24조 : 문서)

Ⅲ. 행정행위의 효력발생요건

행정행위의 효력발생요건이라 함은 행정행위가 상대방에 대하여 효력을 발생하기 위한 요건을 말한다.

행정행위는 상대방에게 통지되어 도달되어야 효력이 발생한다. 제3자에 대한 통지는 효력발생요건이 아니다. 여기에서 도달이라 함은 상대방이 알 수 있는 상태에 두어진 것을 말하고 상대방이 현실적으로 수령하여 요지한 것을 의미하지 않는다.

행정행위의 상대방이 특정되어 있는 행정행위의 상대방에 통지는 원칙상 송달의 방법에 의한다(행정절차법 제15조 제1항).

통지의 상대방이 불특정다수인이거나 행정행위의 상대방의 주소 또는 거소가 불분명하여 송달이 불가능하거나 심히 곤란한 경우 고시 또는 공고의 방법에 의해 통지되도록 규정하고 있다(개별법령 및 행정절차법 제15조 제3항)

제2 행정행위의 하자

Ⅰ. 서 설

1. 의의 - 위법 또는 부당

2. 적용법령과 신뢰보호

Ⅱ. 행정행위의 부존재

Ⅲ. 행정행위의 무효와 취소

1. 개 설

⑴ 무효인 행정행위의 의의

⑵ 취소할 수 있는 행정행위의 의의

2. 무효와 취소의 구별기준

⑴ 학 설

① 중대한 하자만 있으면 무효라는 중대설, ② 하자가 내용상 중대하고 일반인을 기준으로 외관상 일견 명백한 경우에만 무효라는 중대명백설, ③ 중대명백설 중 명백성의 요건을 완화하여 공무원에 조사에 의해 명백성을 판단하는 조사의무설, ④ 하자의 중대성은 항상 무효의 요소로 하되 하자의 명백성은 구체적인 사안에 있어서 이익형량에 따라 보충적으로 적용하자는 명백성 보충요건설, ⑤ 행정행위의 성질과 법적 안정성 및 제3자의 이해관계 등을 고려하여 구체적 사안마다 판단하여야 한다는 구체적 가치형량설 등이 대립한다.

⑵ 판 례

판례는 “행정처분이 당연무효라고 하기 위해서는 처분에 위법사유가 있다는 것만으로는 부족하고 하자가 법규의 중요한 부분을 위반한 중대한 것으로서 객관적으로(외형상으로) 명백한 것이어야 하며, 하자의 중대·명백 여부를 판별함에 있어서는 법규의 목적, 의미, 기능 등을 목적론적으로 고찰함과 동시에 구체적 사안 자체의 특수성에 관하여도 합리적으로 고찰함을 요한다.”[39]고 하여 중대·명백설을 취하고 있다

3. 무효와 취소의 구별실익

⑴ 행정쟁송수단의 문제

1) 무효사유가 있음에도 취소소송을 제기한 경우

취소소송의 소송요건 갖춘 경우 - 취소판결(무효선언적 의미)

취소소송의 소송요건 못 갖춘 경우 - 원칙적으로 기각 / 단 원고가 무효확인소송으로 소변경하면 무효확인판결 가능

2) 취소사유가 있음에도 무효확인을 구하는 소를 제기한 경우

반대로 처분의 무효확인을 구하는 소를 제기하였으나 심리결과 처분의 하자가 취소사유에 불과한 경우

① 취소소송의 제기에 필요한 요건을 갖추고 있는 때에는

첫째 무효확인청구가 취소청구를 당연히 포함한다고 볼 수 없으므로 무효확인소송을 취소소송으로 소변경하지 않는 한 기각판결을 하여야 한다는 견해,

둘째 무효확인청구는 취소청구를 포함하므로 법원은 취소판결을 할 수 있다는 견해가 대립한다.

판례는 행정처분의 무효확인을 구하는 소에는 원고가 그 처분의 취소를 구하지 아니한다고 밝히지 아니한 이상 그 처분이 당연무효가 아니라면 그 취소를 구하는 취지도 포함되어 있는 것으로 보아야 한다는 입장을 취하고 있다(대판 1994. 12. 23, 94누477).

그러나 ② 취소소송의 제기에 필요한 요건을 갖추지 못한 경우에는 당해 무효확인소송에서 기각판결을 내려야 한다는 점에는 학설과 판례가 일치하고 있다.

⑵ 불가쟁력의 발생여부

---

39) 대판 1993. 12. 7, 93누11432

⑶ 하자의 승계

1) 선행 행정행위가 무효인 경우 - 당연 승계

2) 선행 행정행위가 취소사유인 경우 - 학설과 판례 논의

⑷ 사정재결과 사정판결과의 관계

⑸ 선결문제

⑹ 하자의 치유와 전환

⑺ 공정력, 불가쟁력, 구속력

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 감정평가법인 甲은 사원 중 일부만이 동의하였음에도 불구하고 사원전원이 동의한 것으로 하여서 감정평가법인 乙과 합병하였고, 국토해양부장관의 인가를 받았다. 감정평가법인 甲의 사원 丙은 건설교통부장관의 인가는 무효라며 무효확인을 구하는 소를 제기하였다. 수소법원의 판결과 관련된 다음의 설명 중 옳지 않은 것은?

① 사안 상의 국토해양부 장관의 인가는 강학상 인가에 해당한다.
② 기본행위가 불성립하거나 무효일 때는 인가를 받더라도 기본행위의 하자가 치유되는 것이 아니므로 인가 역시 무효가 된다. 따라서 소로써 인가에 대한 무효확인이나 취소를 구할 법률상 이익이 없다.
③ 기본행위가 해제·해지 등으로 실효된 경우, 기본행위가 취소된 경우와 마찬가지로 인가는 무효선언이나 취소처분 없이도 효력을 잃는다.
④ 대법원은 무효확인소송의 소의 이익과 관련하여 일반민사소송과 동일하게 즉시 확정의 이익을 요구한다.
⑤ 사안은 합병에 있어서 사원전원의 동의나 주주총회의 의결이 없는 경우이므로 기본행위에 하자가 있는 경우이므로 기본행위를 다투어야 하는데 기본행위가 무효임을 내세워 인가처분의 무효확인을 구하고 있으므로 법률상 이익이 인정되지 않는다.

해설 & 정답

유형 사례형

① 인가는 당사자의 법률적 행위를 보충하여 그 법률적 효력을 완성시키는 행정주체의 보충적 의사표시를 말하는데 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률 제28조 제3항에 의하면 감정평가법인은 사원전원의 동의 또는 주주총회의 의결이 있는 때에는 국토해양부장관의 인가를 받아 다른 감정평가법인과 합병할 수 있다고 규정하고 있으므로 국토해양부 장관의 인가는 강학상 인가에 해당된다.
② 대판 1987.8.18, 86누152
③ 대판 1983.12.27, 82누491
④ 행정소송은 행정청의 위법한 처분 등을 취소·변경하거나 그 효력 유무 또는 존재 여부를 확인함으로써 국민의 권리 또는 이익의 침해를 구제하고 공법상의 권리관계 또는 법 적용에 관한 다툼을 적정하게 해결함을 목적으로 하므로, 대등한 주체 사이의 사법상 생활관계에 관한 분쟁을 심판대상으로 하는 민사소송과는 목적, 취지 및 기능 등을 달리한다. 또한 행정소송법 제4조에서는 무효확인소송을 항고소송의 일종으로 규정하고 있고, 행정소송법 제38조 제1항에서는 처

분 등을 취소하는 확정판결의 기속력 및 행정청의 재처분 의무에 관한 행정소송법 제30조를 무효확인소송에도 준용하고 있으므로 무효확인판결 자체만으로도 실효성을 확보할 수 있다. 그리고 무효확인소송의 보충성을 규정하고 있는 외국의 일부 입법례와는 달리 우리나라 행정소송법에는 명문의 규정이 없어 이로 인한 명시적 제한이 존재하지 않는다. 이와 같은 사정을 비롯하여 행정에 대한 사법통제, 권익구제의 확대와 같은 행정소송의 기능 등을 종합하여 보면, 행정처분의 근거 법률에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익이 있는 경우에는 행정소송법 제35조에 규정된 '무효확인을 구할 법률상 이익'이 있다고 보아야 하고, 이와 별도로 무효확인소송의 보충성이 요구되는 것은 아니므로 행정처분의 무효를 전제로 한 이행소송 등과 같은 직접적인 구제수단이 있는지 여부를 따질 필요가 없다고 해석함이 상당하다(대판 2008.3.20, 2007두6342 全合).

⑤ 최근 대법원 판례에 의하더라도 사안의 경우에는 협의의 소익이 인정되지 않아서 무효등확인소송을 제기할 수 없다.

정답 ④

2. 행정행위의 하자에 대한 다음 설명 중 가장 옳지 않은 것은? (판례의 견해에 의한다)

(2002 입법고시)

① 필요한 청문절차의 결여는 대체적으로 취소원인이 된다.

② 판례에 의하면 소관행정청이 허가신청을 수리하고도 정당한 이유 없이 처리를 늦추어 그 사이에 법령 및 허가기준이 변경된 경우에 새로운 법령 및 허가기준에 따라서 한 불허가처분은 위법하다.

③ 판례는 토지수용법상의 사업인정과 수용재결처분 사이에는 하자가 승계된다고 본다.

④ 하자 있는 행정행위의 치유는 법치주의의 관점에서 볼 때 원칙적으로 허용될 수 없는 것이다.

⑤ 공무원임용결격사유가 있는 자는 그의 임용행위의 취소에 대해서 신뢰보호의 원칙을 주장할 수 없다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 필요한 청문을 결여한 경우 다수설은 무효사유로 보는데, 주류적 판례는 "구 도시계획법(2000.1.28. 법률 제6243호로 전문 개정되기 전의 것) 제78조, 제78조의2, 행정절차법 제22조 제1항 제1호, 제4항, 제21조 제4항에 의하면, 행정청이 구 도시계획법 제23조 제5항의 규정에 의한 사업시행자 지정처분을 취소하기 위해서는 청문을 실시하여야 하고, 다만 행정절차법 제22조 제4항, 제21조 제4항에서 정한 예외사유에 해당하는 경우에 한하여 청문을 실시하지 아니할 수 있으며, 이러한 청문제도는 행정처분의 사유에 대하여 당사자에게 변명과 유리한 자료를 제출할 기회를 부여함으로써 위법사유의 시정가능성을 고려하고 처분의 신중과 적정을 기하려는 데 그 취지가 있음에 비추어 볼 때, 행정청이 침해적 행정처분을 함에 즈음하여 청문을 실시하지 않아도 되는 예외적인 경우에 해당하지 않는 한 반드시 청문을 실시하여야 하고, 그 절차를 결여한 처분은 위법한 처분으로서 취소사유에 해당한다(대판 2004.7.8, 2002두8350)"라 판시하여 취소사유로 본다.

③ 판례는 토지수용법상 사업인정과 수용재결처분 사이에는 별개의 목적으로 하는 행위이므로 하자가 승계되지 않는다고 판시하고 있다(대판 1996.4.26, 95누13241).

④ 하자 있는 행정행위에 있어서 하자의 치유는 행정행위의 성질이나 법치주의의 관점에서 원칙적으로 허용될 수 없고, 행정행위의 무용한 반복을 피하고 당사자의 법적 안정성을 보호하기 위하여 국민의 권익을 침해하지 아니하는 범위 내에서 예외적으로만 허용된다(대판 2001.6.26, 99두11592).

⑤ 대법원은 "경찰공무원으로 임용된 후 70일 만에 원고가 선고받은 형이 사면 등으로 실효되어 결격사유가 소멸된 후 30년 3개월 동안 사실상 공무원으로 계속 근무를 하였다고 하더라도 그것만으로는 임용권자가 원고에 대하여 묵시적으로 새로운 임용처분을 한 것으로 볼 수 없고, 또한 1982.경에 원고가 임용 당시 결격자였다는 사실이 밝혀졌는데도 서울특별시 경찰국장이 일반사면령 등의 공포로 현재 결격사유에 해당하지 아니한다는 이유로 원고의 당연퇴직은 불가

하다는 조치를 내려서 원고가 그 후 정년퇴직시까지 계속 사실상 근무하도록 한 것이 임용권자가 일반사면령의 시행으로 공무원자격을 구비한 후의 원고의 근무행위를 유효한 것으로 임용권자가 추인하였다거나 장래에 향하여 원고를 공무원으로 새로 임용하는 효력이 있다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 1982. 당시 경장이었던 원고의 임용권자는 당시 시행된 경찰공무원법 및 경찰공무원임용령의 규정상 서울특별시장이지 경찰국장이 아니었음이 분명하여, 무효인 원고의 임용행위를 임용권자가 추인하였다거나 원고를 장래에 향하여 공무원으로 임용하는 새로운 처분이 있었던 것으로 보아야 한다는 소론은 어느 모로 보나 받아들일 수 없다(대판 1996.2.27, 95누9617)"라고 판시하여 신뢰보호원칙을 주장할 수 없다고 본다.

정답 ③

3. 행정행위의 하자에 관한 설명으로 타당하지 않은 것은? (2008 국회8급)

① 부당한 행정행위에 대해서도 직권취소는 가능하다.
② 일반적으로 행정행위의 하자가 중대하고 명백한 경우에는 당연무효가 된다.
③ 단순위법인 행정행위에는 공정력이 인정되므로, 취소되기 전까지는 법적으로 유효하다.
④ 무효인 행정행위에 대해서도 취소소송을 제기할 수 있다는 것이 판례의 입장이다.
⑤ 행정행위의 근거법률이 사후적으로 위헌이 된 경우, 당해 처분은 당연무효라는 것이 판례의 입장이다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 직권취소의 사유는 위법한 경우, 부당한 경우 모두 해당하나, 행정소송에 의한 쟁송취소의 사유는 위법한 경우에만 가능하다. 행정심판에 의한 쟁송취소의 사유는 위법한 경우뿐만 아니라 부당한 경우에도 가능하다.

⑤ 위헌결정 전에 위헌법률에 근거하여 내린 처분(행정처분 후에 위헌결정이 난 경우)은 위헌으로서 중대한 하자이지만 위헌여부가 명백하지는 않으므로 취소사유에 해당한다(대판 2006.3.9, 2003두2861). 이에 비해서 위헌결정이 난 후에는 위헌으로 결정된 법률에 근거하여 내린 처분은 위헌이라는 사실이 공식적으로 명백하게 확정되었기 때문에 그 하자가 중대 명백하여 당연무효라는 것이 판례의 입장이다(대판 2002.11.22, 2002다46102).

정답 ⑤

♣ 학습내용 정리

1. 행정행위의 하자의 정도에는 부존재, 무효, 취소가 있다..
2. 무효와 취소의 구별기준에 대하여 통설과 판례는 중대명백설을 취하고 있다.

제17강 행정행위의 하자 II

♣ 학습목표

하자의 승계, 하자의 치유와 전환을 구별하여 설명할 수 있다.
위헌인 법률에 근거한 처분의 위법여부를 판단할 수 있다.

♣ 학습내용

하자의 승계
하자의 치유와 전환
위헌결정의 소급효 및 위법성의 정도

♣ 사전테스트

1. 선행처분에 불가쟁력이 발생하지 않더라도 하자승계 논의는 필요하다.
   정답 : ×

2. 국민의 권익을 침해하더라도 사후보완행위만 있으면 하자의 치유가 인정된다는 것이 판례 입장이다.
   정답 : X

3. 위헌인 법률에 근거한 처분에 대하여 원칙적으로 취소사유에 불과하다는 것이 대법원의 입장이다.
   정답 : ○

♣ 돌발퀴즈

우리 대법원은 개별공시지가 결정과 양도소득세 부과처분이 별개의 법적효과를 목적으로 하나 예외적으로 하자의 승계를 긍정하고 있다.

[정답] ○

[해설] 개별공시지가결정은 이를 기초로 한 과세처분 등과는 별개의 독립된 처분으로서 서로 독립하여 별개의 법률효과를 목적으로 하는 것이나, 개별공시지가는 이를 토지소유자나 이해관계인에게 개별적으로 고지하도록 되어 있는 것이 아니어서 토지소유자 등이 개별공시지가결정 내용을 알고 있었다고 전제하기도 곤란할 뿐만 아니라 결정된 개별공시지가가 자신에게 유리하게 작용될 것인지 또는 불이익하게 작용될 것인지 여부를 쉽사리 예견할 수 있는 것도 아니며, 더욱이 장차 어떠한 과세처분 등 구체적인 불이익이 현실적으로 나타나게 되었을 경우에 비로소 권

리구제의 길을 찾는 것이 우리 국민의 권리의식임을 감안하여 볼 때 토지소유자 등으로 하여금 결정된 개별공시지가를 기초로 하여 장차 과세처분 등이 이루어질 것에 대비하여 항상 토지의 가격을 주시하고 개별공시지가결정이 잘못된 경우 정해진 시정절차를 통하여 이를 시정하도록 요구하는 것은 부당하게 높은 주의의무를 지우는 것이라고 아니할 수 없고, 위법한 개별공시지가결정에 대하여 그 정해진 시정절차를 통하여 시정하도록 요구하지 아니하였다는 이유로 위법한 개별공시지가를 기초로 한 과세처분 등 후행 행정처분에서 개별공시지가결정의 위법을 주장할 수 없도록 하는 것은 수인한도를 넘는 불이익을 강요하는 것으로서 국민의 재산권과 재판받을 권리를 보장한 헌법의 이념에도 부합하는 것이 아니라고 할 것이므로, 개별공시지가결정에 위법이 있는 경우에는 그 자체를 행정소송의 대상이 되는 행정처분으로 보아 그 위법 여부를 다툴 수 있음은 물론 이를 기초로 한 과세처분 등 행정처분의 취소를 구하는 행정소송에서도 선행처분인 개별공시지가결정의 위법을 독립된 위법사유로 주장할 수 있다고 해석함이 타당하다(대판 1994.1.25, 93누8542).

♣ 강의내용

제1 하자의 승계

1. 개 설

⑴ 하자 승계의 개념

하자의 승계문제는 두 개 이상의 행정행위가 연속적으로 행하여지는 경우 선행행위의 하자가 후행행위에 승계되는가, 즉 행정행위의 상대방은 선행행위의 하자를 이유로 후행행위를 다툴 수 있는가에 관한 논의이다.

⑵ 논의의 전제

하자의 승계문제는, 첫째 선행행위와 후행행위가 모두 항고소송으로 다툴 수 있는 행정처분이어야 한다. 둘째, 선행행위는 당연무효가 아닌 취소사유인 하자가 존재하여야 한다. 셋째, 후행행위에 고유한 하자가 없어야 한다. 마지막으로, 선행행위를 제소기간 내에 다투지 않아 불가쟁력이 발생하여야 한다.

2. 하자승계에 관한 학설과 판례

⑴ 학설

1) 전통적 견해

이 견해는 하자의 승계 여부를 판단하는 기준을 양 행위가 동일한 목적을 추구하는 일련의 절차를 이루는지 여부로 본다. 동일한 법적 목적을 추구하는 경우에 하자의 승계를 인정하는 이유는, 선행행위는 후행행위의 준비행위로써의 의미를 갖는 것이고 또한 연속적인 두 개 이상의 행위에 의하여 법률이 달성하려고 하는 목적은 최종의 행정행위에 유보되어 있다는 점에서다.

2) 구속력설(규준력설)

이 설은 하자의 승계문제를 불가쟁력이 발생한 선행 행정행위의 후행 행정행위에 대한 구속력의 문제로 이해한다. 즉 이에 따르면 둘 이상의 행정행위가 동일한 법적 효과를 추구하고 있

는 경우에는 선행 행정행위는 후행 행정행위에 대하여 일정한 범위에서 구속력을 갖게 되며, 이러한 구속력이 미치는 범위에서는 후행 행정행위에 있어서 선행행정행위의 효과와 다른 주장을 할 수 없게 된다고 한다(하자 승계 부정).

⑵ 판 례

1) 동일한 법적 효과를 목적으로 하는 경우 - 하자승계인정

2) 별개의 법적효과를 목적으로 하는 경우

① 원칙 - 선행처분의 하자가 당연무효가 아닌 한 하자승계부정

② 예외

판례는 개별공시지가결정과 양도세부과처분사이에 하자승계가 되는가와 관련하여 선행처분과 후행처분이 서로 독립하여 별개의 효과를 목적으로 하는 경우에도 선행처분의 불가쟁력이나 구속력이 그로 인하여 불이익을 입게 되는 자에게 수인한도를 넘는 가혹함을 가져오며, 그 결과가 당사자에게 예측가능한 것이 아닌 경우에는 국민의 재판받을 권리를 보장하고 있는 헌법의 이념에 비추어 선행처분의 후행처분에 대한 구속력은 인정되지 않아 하자승계를 인정할 수 있다고 판시하였다(대판 1998. 3. 13, 96누6059).

또 판례는 위 판결 이후 표준지공시지가결정과 수용재결은 별개의 법적 효과를 목적으로 하나 수인가능성, 기대가능성이 없다는 이유로 하자승계를 긍정하였다(대판 2008. 8. 21, 2007두13845).

제2 하자의 치유와 전환

1. 하자의 치유

⑴ 의 의

행정행위의 하자의 치유란 행정행위가 성립당시 하자가 있다 하더라도 사후에 그 요건이 보완되거나 또는 그 하자가 취소하여야 할 필요가 없게 되어 적법한 행정행위로서 되는 것을 말한다.

⑵ 인정근거

이론상 인정근거로는 행정행위에 대한 상대방의 신뢰보호, 행정법관계의 안정성 고려, 행정행위의 불필요한 반복의 회피 등을 들 수 있다.

⑶ 허용여부

1) 학 설

① 법률적합성 원칙과 국민의 권익보호를 위해 하자치유를 부정하는 부정설, ② 행정경제, 소송경제 등을 이유로 긍정하는 긍정설, ③ 법치주의의 관점에서 볼 때 하자 있는 행정행위의 치유는 원칙적으로 허용될 수 없지만, 예외적으로 행정행위의 무용한 반복을 피하고 당사자의 법적 안정성을 기한다는 취지에서 일정한 한도내에서 허용될 수 있다는 제한적 긍정설(통설)이 대립한다.

2) 판 례

판례는 “하자있는 행정행위의 치유나 전환은 … 법치주의의 관점에서 볼 때 원칙적으로 허용될 수 없는 것이지만, 행정행위의 무용한 반복을 피하고 당사자의 법적 안정성을 위해 이를 허용하는 때에도 국민의 권리와 이익을 침해하지 않는 범위에서 구체적 사정에 따라 합목적적으로 인정된다”라고 판시하여 제한적 긍정설을 취하고 있다.

⑷ 치유의 한계

1) 절차상 하자만 치유가 가능한가

내용상 하자의 치유도 인정하자는 견해도 있으나 이를 인정하면 권익침해우려가 있는 바, 절차상 하자만 하자의 치유를 인정하자는 것이 다수설과 판례이고 타당하다.

2) 하자의 정도 - 취소사유일 것

일부견해는 무효와 취소의 구별상대화에 따라 무효인 경우에도 하자치유를 인정하자고 하나, 다수설은 무효인 하자의 치유를 인정하면 국민의 권익침해우려와 법치주의의 침해가 있는 바, 하자의 치유는 취소할 수 있는 행정행위에 대해서만 인정된다고 한다.

3) 하자치유로 인하여 당사자에게 불이익이 없을 것.

5) 치유의 시기

행정쟁송제기 이전까지만 가능하다는 견해, 행정소송제기 이전까지만 가능하다는 견해, 행정소송 종료 전까지 가능하다는 견해 등이 대립하고 있으며 판례는 행정쟁송제기 이전까지만 가능하다는 견해를 취한 것으로 보인다.

⑸ 치유의 효과

행정행위의 하자가 치유되면 당해 행정행위는 처분시부터 하자가 없는 적법한 행정행위로 효력을 발생하게 된다고 한다.

조합설립인가처분시 토지소유자 4분의 3의 동의를 얻지 못하여 위법한 경우 처분시 이후에 4분의 3의 동의를 얻었다 하여 하자치유를 인정하면 조합설립에 반대하는 토지소유자들의 이익을 해할 수 있는 바, 하자치유를 부정한 판례

2. 하자의 전환

이는 무효의 하자있는 행정행위가 일정한 조건하에서 하자없는 다른 행정행위에 의해 대체되어, 이 새로운 행정행위가 원래의 행정행위로서의 효력으로 소급적으로 적용되는 것을 말한다. 예컨대, 사자에 대한 수용재결의 효력을 상속인에 대한 것으로 인정하는 경우가 전형적인 것이다.[40]

제3 위헌인 법률에 근거한 처분

1. 위헌결정의 소급효 인정여부 및 그 범위

⑴ 문제점

---

40) 류지태,「행정법요론」, 140면.

당해 처분의 근거법률에 대한 헌재의 위헌결정의 소급효가 인정되어야만 당해 처분은 법률에 근거없이 행하여진 것으로 하자가 인정될 수 있다. 이에 대법원도 “법률에 근거하여 행정처분이 발하여진 후에 헌법재판소가 그 행정처분의 근거가 된 법률을 위헌으로 결정하였다면 결과적으로 행정처분은 법률의 근거가 없이 행하여진 것과 마찬가지가 되어 하자가 있는 것이 되나...” 라고 판시하고 있다(대판 1994. 10. 28, 92누9463).

그런데 위헌결정의 시간적 효력에 관한 헌법재판소법 제47조 제2항을 문언적으로만 해석하면 위헌결정의 소급효가 인정되지 않는 바, 이에 따르면 위헌제청을 한 당해 소송사건의 경우에도 그 법률은 여전히 합헌적인 것으로 유효한 것이 되는 불합리한 결과가 발생하게 된다.

이에 대법원과 헌법재판소는 국민의 권리구제를 위하여 일정한 경우에 위헌결정의 소급효를 인정하고 있다.

⑵ 대법원의 입장

대법원은 위헌결정의 소급효가 미치는 범위를 ① 위헌제청을 한 당해사건, ② 위헌결정이 있기 전에 이와 동종의 위헌 여부에 관하여 헌법재판소에 위헌여부심판제청을 하였거나 법원에 위헌여부심판제청신청을 한 동종사건과 ③ 따로 위헌제청신청은 아니하였지만 당해 법률 또는 법률 조항이 재판의 전제가 되어 법원에 계속중인 병행사건뿐만 아니라, ④ 위헌결정 이후에 위와 같은 이유로 제소된 일반사건으로 유형화하여 위 네가지 유형에 대하여는 원칙적으로 위헌결정의 소급효를 인정하나, 위 네가지 경우라도 법적 안정성의 유지나 당사자의 신뢰보호를 위하여 불가피한 경우에 위헌결정의 소급효를 제한할 수 있다고 판시하였다(대판 1993. 1. 15, 92다12377).

또 대법원은 이미 취소소송의 제기기간을 경과하여 확정력이 발생한 행정처분에는 위헌결정의 소급효가 미치지 않는다고 보고, 따라서 어느 행정처분에 대하여 그 행정처분의 근거가 된 법률이 위헌이라는 이유로 무효확인청구의 소가 제기된 경우에는 다른 특별한 사정이 없는 한 법원으로서는 그 법률이 위헌인지 여부에 대하여는 판단할 필요 없이 위 무효확인청구를 기각하고 있다(위헌법률심판제청신청사건에서 ‘재판의 전제성’을 인정하지 않는다. 대판 1994. 10. 28, 92누9463).

⑶ 헌법재판소의 입장

헌법재판소 역시 불소급효가 원칙이지만, 예외적으로 소급효를 인정하고 있다. 위 대법원에서 판시한 첫째, 둘째, 셋째의 경우와, 당사자간의 권리구제를 위한 구체적 타당성의 요청이 법적 안정성의 요청보다 현저한 반면에 소급효를 인정하여도 법적 안정성을 해할 우려가 없고, 나아가 구법에 의하여 형성된 신뢰이익을 크게 해칠 사안이 아닌 경우로서, 소급효의 부인이 오히려 정의와 형평 등 헌법적 이념에 심히 배치될 경우에는 예외적으로 소급효를 인정한다고 판시하였다(헌재 1993. 5. 13, 92헌가10).

2. 위헌인 법률에 근거한 행정처분의 위법성의 정도

⑴ 대법원판례의 입장

대법원은 무효와 취소의 구별에 관한 학설 중 중대명백설에 입각하여 위헌인 법률에 근거하여 발하여진 행정처분은 특별한 사정이 없는 한 취소할 수 있는 행위에 불과하다고 보고 있다. 왜냐하면 일반적으로 법률이 헌법에 위반된다는 사정이 헌법재판소의 위헌결정이 있기 전에는 객관적으로 명백한 것이라고 할 수는 없기 때문이다(대판, 1994. 10. 28, 93다41860등).

⑵ 헌법재판소의 입장

이에 대하여 헌재는 원칙적으로 취소사유로 보나 예외적으로, 그 처분이 위헌법률에 근거하여 내려진 것이고 그 행정처분의 목적달성을 위하여서는 후행 행정처분이 필요한데 후행 행정처분은 아직 이루어지지 않은 경우와 같이 그 행정처분을 무효로 하더라도 법적 안정성을 크게 해치지 않는 반면에 그 하자가 중대하여 그 구제가 필요한 경우에 대하여는 무효사유로 보고 있다(헌재 1994. 6. 30, 92헌바23).

3. 여론 - 위헌인 법률에 근거한 처분의 집행력

1) 학설

① 위헌인 법률에 근거한 처분에 의해 부과된 의무를 이행하지 않은 경우에 그 의무의 이행을 강제하는 것은 위헌결정의 기속력에 반하므로 처분의 강제는 가능하지 않다고 보아야 한다는 집행력부정설과 ② 위헌결정된 법률은 의무부과하는 처분의 근거법률이지 강제집행의 근거법률이 아닌 바 당해 처분의 집행이 가능하다는 집행력긍정설이 대립한다.

2) 판례

대법원 전원합의체판결에서 다수의견은 집행력부정설의 입장을 취하여 위헌결정이후에 한 체납처분은 위헌결정의 기속력에 반하여 당연무효라고 판시하고 있다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 하자의 승계에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 선행행위에 하자가 존재하여 위법하고 후행행위에도 위법한 하자가 있어야 한다.

② 일반적으로 선행행위와 후행행위가 별개의 법적 효과를 발생하는 경우, 즉 철거명령과 대집행, 과세처분과 체납처분의 경우에는 하자의 승계를 인정한다.

③ 판례에 의하면 택지개발촉진법에 의한 택지개발계획승인처분의 제소기간이 도과된 후 수용재결이나 이의재결단계에서는 택지개발계획승인처분에 중대하고 명백한 하자가 있어 당연무효라고 볼만한 특단의 사정이 없는 이상 택지개발계획승인처분이 위법·부당함을 이유로 재결의 취소를 구할 수 없다.

④ 개별공시지가 결정과 이를 기초로 한 과세처분은 서로 독립적이므로 판례에 의하여 그 위법성의 승계가 부인되었다.

⑤ 하자의 승계이론은 선행행위에 불가쟁력이 발생하여 그 효력을 다툴 수 없게 된 경우 후행행위의 하자를 이유로 선행행위에 대한 쟁송제기가 가능한 것인가의 문제와 관련하여 그 논의의 실익이 있다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 후행행위가 위법하면 후행행위를 대상으로 소송을 제기하여 구제가 가능하기 때문에 별도로 선행행위의 하자승계를 논할 실익이 없다. 하자의 승계는 선행행위가 취소사유에 해당하는 하자가 있어서 제소기간 내에 소송을 제기했더라면 구제가 가능했지만 불가쟁력이 발생했기 때문에 소송제기가 불가능한 상황이고, 후행행위는 적법하기 때문에 후행행위를 대상으로 소송을 제기해봐야 패소판결(기각판결)을 받을 것이 분명한 상황에서, 선행행위의 하자승계가 받아들여지면 후행행위도 위법이 되기 때문에 구제가 가능하다는 점에서 논의의 실익이 있는 것이다.

② 전통적 견해는 두 행위가 하나의 법적 효과를 완성하는 경우에는 하자 승계를 긍정하고 두 행위가 서로 독립하여 서로 별개의 법효과를 발생하는 경우에는 하자의 승계를 부정한다.

판례는 기본적으로 “선・후의 행정행위가 결합하여 하나의 법적 효과를 달성시키는지 여부를 기준으로 하자의 승계여부를 결정한다. 다만, 판례 중에는 예외적으로 선・후의 행정행위가 서로 독립하여 별개의 효과를 목적으로 하는 경우에도 불이익을 입게 되는 자에게 수인한도를 넘는 가혹한 결과를 가져오고 그 결과가 당사자에게 예측 가능한 것이 아닌 경우에는 하자의 승계를 인정”하고 있다. 철거명령과 대집행(대판 1998.9.8, 97누20502), 과세처분과 체납처분(대판 1988.6.28, 87누1009)의 경우는 기본적인 태도에 따르면 하자의 승계가 인정되지 않는다.

③ 대판 1996.4.26, 95누13241

④ 개별공시지가결정은 이를 기초로 한 과세처분 등과는 별개의 독립된 처분으로서 서로 독립하여 별개의 법률효과를 목적으로 하는 것이나, … 개별공시지가결정에 위법이 있는 경우에는 그 자체를 행정소송의 대상이 되는 행정처분으로 보아 그 위법 여부를 다툴 수 있음은 물론 이를 기초로 한 과세처분 등 행정처분의 취소를 구하는 행정소송에서도 선행처분인 개별공시지가결정의 위법을 독립된 위법사유로 주장할 수 있다고 해석함이 타당하다(대판 1994.1.25, 93누8542).

⑤ 하자의 승계는 통상 선행행위의 하자를 이유로 후행행위를 다투는 경우에 논의의 실익이 있다.

정답 ③

2. 대법원 판례가 행정행위의 하자의 승계를 인정한 사례는?

① 과세처분과 체납처분　② 도시계획결정과 수용재결처분
③ 직위해제처분과 면직처분　④ 대집행의 계고처분과 대집행비용징수처분
⑤ 수강거부처분과 수료처분

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 대판 1988.6.28, 87누1009

② 대판 2000.10.13, 2000두5142

③ 대판 1984.9.11, 84누191

④ 대집행의 계고・대집행영장에 의한 통지・대집행의 실행・대집행에 요한 비용의 납부명령 등은 타인이 대신하여 행할 수 있는 행정의무의 이행을 의무자의 비용부담 하에 확보하고자 하는, 동일한 행정목적을 달성하기 위하여 단계적인 일련의 절차로 연속하여 행하여지는 것으로서, 서로 결합하여 하나의 법률효과를 발생시키는 것이므로, 선행처분인 계호처분이 하자가 있는 위법한 처분이라면, 비록 하자가 중대하고도 명백한 것이 아니어서 당연 무효의 처분이라고 볼 수 없고 대집행의 실행이 이미 사실행위로서 완료되어 계고처분의 취소를 구할 법률상 이익이 없게 되었으며, 또 대집행비용납부명령 자체에는 아무런 하자가 없다 하더라도, 후행처분인 대집행비용납부명령의 취소를 청구하는 소송에서 청구원인으로 선행처분인 계고처분이 위법한 것이기 때문에 그 계고처분을 전제로 행하여진 대집행비용납부명령도 위법한 것이라는 주장을 할 수 있다(대판 1993.11.9, 93누14271).

⑤ 대판 1994.12.23, 94누477

정답 ④

3. LPG충전소 사업허가의 경우 인근 주민의 동의를 받아야 함에도 불구하고 甲이 인근주민의 동의를 받지 않았는데 허가가 발령되었다. 이에 경원자 乙이 그 신규사업허가의 취소를 구하는 소송을 제기하려고 한다. 乙의 소제기 전에 甲이 인근 주민의 동의를 받은 경우 하자가 치유되는지와 관련된 다음의 설명 중 옳지 않은 것은?

① 당연무효의 하자가 있는 경우에는 하자의 치유가 인정되지 않는데 사안의 주민의 동의는 절차적 요건으로 중대 명백설에 의할 경우 취소사유에 불과하다.

② 우리 대법원은 취소사유의 경우 제한적으로 하자의 치유를 인정한다.

③ 우리 대법원은 불복 제기 이전까지 하자의 치유를 인정하는데 사안은 이 점에서 문제가 없다.

④ 사안은 사후의 주민의 동의 요건을 보안하였으므로 하자의 치유사유에 해당한다.

⑤ 사안은 하자 치유의 모든 요건을 충족하므로 판례에 의할 경우 하자가 치유된다.

해설 & 정답

유형 사례형

① 통설과 판례는 흠 있는 행정행위의 치유는 취소할 수 있는 흠 있는 행정행위에 대해서만 인정한다. 한편 무효인 행정행위는 취소할 수 있는 행정행위와는 달리 어떤 효력도 발생하지 않기 때문에 그의 치유는 인정할 수 없다. 또한 그러한 행위의 치유를 인정하는 것은 오히려 관계인의 신뢰 및 법률생활의 안정을 저해한다.

② 대법원은 "하자있는 행정행위의 치유나 전환은 행정행위의 성질이나 법치주의의 관점에서 볼 때 원칙적으로 허용될 수 없는 것이지만, 행정행위의 무용한 반복을 피하고 당사자의 법적 안정성을 위해 이를 허용하는 때에도 국민의 권리와 이익을 침해하지 않는 범위에서 구체적 사정에 따라 합목적적으로 인정해야 할 것이다(대판 1983.7.26, 82누420)"라고 판시하여 제한적 긍정설의 입장이다.

③ 대법원은 "과세처분에 과세표준과 세액의 계산명세서 등을 첨부하여 고지하도록 한 것은 납세의무자에게 부과처분의 내용을 상세히 알려서 불복여부의 결정 및 그 불복신청에 편의를 주려는 데에도 그 취지가 있으므로 이 치유를 허용하려면 늦어도 과세처분에 대한 불복여부의 결정 및 불복신청에 편의를 줄 수 있는 상당한 기간 내에 하여야 한다(대판 1983.7.26, 82누420)"라고 판시하여 불복제기 이전설의 입장이다.

⑤ 참가인들이 허가신청한 충전소설치예정지로부터 100미터 이내에 상수도시설 및 농협창고가 위치하고 있어 위 고시의 규정에 따라 그 건물주의 동의를 받아야 하는 것임에도 그 동의가 없으니 그 신청은 허가요건을 갖추지 아니한 것으로써 이를 받아들인 이 사건 처분은 위법하다고 한 다음, 이 사건 처분 후 위 각 건물주로부터 동의를 받았으니 이 사건 처분의 하자는 치유되었다는 주장에 대하여는, 하자 있는 행정행위의 치유는 행정행위의 성질이나 법치주의의 관점에서 볼 때 원칙적으로 허용될 수 없는 것이고 예외적으로 행정행위의 무용한 반복을 피하고 당사자의 법적 안정성을 위해 이를 허용하는 때에도 국민의 권리나 이익을 침해하지 않는 범위에서 구체적 사정에 따라 합목적적으로 인정하여야 할 것인데 이 사건에 있어서는 원고의 적법한 허가신청이 참가인들의 신청과 경합되어 있어 이 사건 처분의 치유를 허용한다면 원고에게 불이익하게 되므로 이를 허용할 수 없다(대판 1992.5.8, 91누13274).

정답 ⑤

♣ 학습내용 정리

1. 하자의 승계여부에 대하여 판례는 원칙적으로 동일한 법적 효과를 목적으로 하는 경우에 대해선 하자승계를 인정한다.
2. 국민의 권익을 침해하지 않는 범위내에서 하자치유를 인정하는 것이 판례의 입장이다.
3. 위헌인 법률에 근거한 처분의 위법성의 정도는 원칙적으로 취소사유라는 것이 판례의 입장이다.

제18강 행정행위의 하자 III

♣ 학습목표

행정행위의 하자의 예로서 주체, 절차, 형식, 내용상 하자에 대하여 설명할 수 있다.
행정행위의 직권취소와 철회를 비교할 수 있다.

♣ 학습내용

행정행위의 하자의 예
행정행위의 취소
행정행위의 철회

♣ 사전테스트

1. 행정행위의 취소에는 쟁송취소만 있다.
   정답 : X

2. 성립당시 하자를 이유로 취소하는 것을 강학상 철회라 한다.
   정답 : x

3. 판례는 사정변경 등 철회사유가 있으면 법적 근거 없더라도 철회가 가능하다는 입장이다.
   정답 : O

♣ 돌발퀴즈

변상금부과처분취소소송이 진행 중인 경우에는 부과권자는 위법한 처분을 직권취소할 수 없다.

[정답] ×

[해설] 쟁송취소와 직권취소는 별개의 것이기 때문에 취소소송이 제기 중이라 하더라도 직권취소에는 제한이 없다.

♣ 강의내용

제1 행정행위의 하자의 예

1. 서

2. 주체에 관한 하자

행정행위는 정당한 권한을 가진 행정기관에 의해 그의 권한 내에서 정상적인 의사에 기하여 행하여져야 한다.

⑴ 정당한 권한을 가진 행정기관이 아닌 자의 행위

① 공무원이 아닌 것이 명백한 사인이 공무원의 자격을 사칭하여 행정행위를 한 경우 당해 행정행위는 부존재가 된다.

② 결격사유로 인해 공무원으로서의 선임행위가 무효 또는 취소된 자가 공무원으로서 행한 행위 및 면직 후 또는 임기만료 후에 공무원으로서 행한 행위는 원칙적으로 무효이다.

다만, 상대방이 당해 행정기관이 정당한 권한을 가지고 있는 것으로 믿을 만한 상당한 이유가 있는 경우에는 상대방의 신뢰를 보호하기 위하여 당해 행정행위를 유효한 것으로 보아야 할 것이다(사실상 공무원 이론[41]).

③ 합의제기관의 행위에 있어 적법한 소집이 없었거나, 의사 또는 의결정족수가 미달하였거나, 결격자가 참가한 경우 등 구성에 중대한 흠이 있는 합의제기관의 행위는 원칙적으로 무효이다.

⑵ 행정기관의 권한 외의 행위

무권한의 행위는 원칙적으로 무효이다. 다만, 무권한의 행위라도 공평, 신뢰보호, 법률생활의 안정들의 견지에서 이를 취소할 수 있는 행정행위 또는 유효인 행위로 보아야 할 경우가 있다.

3. 절차의 하자

⑴ 상대방의 신청 또는 동의를 결한 행위

⑵ 필요한 공고 또는 통지를 결한 행위 - 원칙적으로 무효

⑶ 필요한 이해관계인의 입회 또는 협의를 결한 행위 - 원칙적으로 무효

⑷ 필요한 청문 또는 의견진술의 기회를 주지 아니한 행위

⑸ 이유부기의 흠결 - 판례는 취소사유

4. 형식에 관한 하자 - 원칙적으로 무효

---

41) 후술 공무원법 참조

5. 행정행위의 내용에 관한 하자

행정행위가 완전한 효력을 발생하기 위하여는 행정행위의 내용이 법에 위반하지 아니하고 공익에 적합하여야 하며 실현불가능하지 않아야 하며 불명확하지 않아야 한다.

⑴ 행정행위의 내용의 법 위반

행정행위의 내용은 법의 일반원칙 및 헌법을 포함하여 모든 법에 위반하여서는 안 되며 법에 위반하면 위법한 행정행위가 된다. 법에 위반한 행정행위는 무효와 취소의 구별기준에 따라 무효 또는 취소할 수 있는 행정행위가 된다.

법률유보의 원칙에 따라 행정행위에는 법적 근거가 있어야 한다. 법적 근거 없이 행해진 행정행위는 원칙상 무효이다.

⑵ 위헌인 법령에 근거한 처분 : 다음 절 참조

⑶ 행정행위의 내용의 공익에의 위반 : 적법 부당

⑷ 행정행위의 내용의 사실상 또는 법률상의 실현불가능

⑸ 행정행위의 내용의 불명확

제2 행정행위의 취소

Ⅰ. 개 설

1. 의의

행정행위의 취소는 광의로는 하자 있는 행정행위의 효력을 상실시키는 것을 말하며 직권취소와 함께 쟁송취소를 포함한다. 협의로는 일단 유효하게 성립한 행정행위의 효력을 권한있는 행정청이 성립상의 하자를 이유로 소멸시키는 별개의 행정행위, 즉 직권취소만을 의미한다. 따라서 성립이후에 발생한 후발적 사유로 하는 철회와 구별되며, 처음부터 무효인 행정행위에 대하여 무효임을 확인하는 무효선언적 행위와도 구별된다.

2. 취소의 법적근거 - 별도의 법적 근거 불필요

Ⅱ. 취소권자

처분청이 취소권을 가지는 것에는 의문이 없다. 문제는 감독청이 법규의 명시적 규정이 없는 경우에도 취소권을 가지는가에 대해 학설의 대립이 있다.

Ⅲ. 취소사유 및 취소의 제한

1. 취소사유 - 단순위법 또는 부당

2. 취소의 제한 - 실권의 법리, 신뢰보호원칙, 비례원칙 등 이익형량

법률적합성의 원칙에 비추어 볼 때 위법한 행정행위는 취소되어야 한다. 이러한 취소에 의하여 행정의 합법성이 회복되고 침해된 국민의 권익이 구제될 것이다. 그런데 위법한 행정행위라도 무효가 아닌 한 일단은 유효한 행정행위이고(공정력) 그 유효한 행정행위를 기초로 많은 법

률관계가 형성된다. 따라서 법적 안정성의 견지에서 취소를 제한할 것이 요청된다. 따라서 행정행위의 취소에 있어서는 행정행위를 취소하여 달성하고자 하는 이익과 행정행위를 취소함으로써 야기되는 신뢰에 기초하여 형성된 이익의 박탈을 형량하여 전자가 더 큰 경우에 한하여 취소가 인정된다고 보아야 한다. 이러한 이익 형량에 있어서는 상대방의 신뢰의 정도, 이익형량을 함에 있어서 부여된 수익의 박탈로 인하여 수익자가 받는 불이익, 공동체나 제3자에 대한 영향, 시간의 경과 등을 고려하여야 한다. 직권취소의 경우의 이익형량은 주로 수익적 행정행위에서 문제된다. 부담적 행정행위의 취소에 있어서는 원칙상 취소는 자유롭다. 단 제3자효적 행정행위에 있어서는 처분의 상대방뿐만 아니라 제3자의 이익도 형량하여야 한다.

이익형량의 결과 행정청은 전부취소 또는 일부취소를 선택할 수 있고, 소급효 있는 취소 또는 소급하지 않는 취소를 결정할 수 있다.

Ⅳ. 취소절차 및 취소의 효과

1. 취소절차 - 개별절차조항 및 행정절차법상 처분절차조항

2. 취소의 효과 - 이익형량통해 소급효 및 장래효 결정

Ⅴ. 흠 있는 행정행위의 취소의 취소

1. 학설

① 원처분이 직권취소로 이미 소멸되었으므로 직권취소를 취소하여 원처분을 회복시키는 것은 불가하다는 소극설, ② 직권취소도 행정행위이므로 흠의 일반이론에 따라 가능하다는 적극설, ③ 부담적 행정행위의 취소의 취소는 불가하나 수익적 행정행위의 취소의 취소는 취소의 취소전에 이해관계있는 제3자가 없는 한 가능하다는 절충설, ④ 이익형량을 통해 가능여부를 결정해야 한다는 이익형량설 등이 대립한다.

2. 판 례

판례는 ① 부담적 행정행위의 취소의 취소에 대해선, 취소의 취소를 통해 부담적 행정행위를 소생시킬 수 없다고 하였으나(77누61판결), ② 수익적 행정행위의 취소의 취소에 대해선 원칙적으로 가능하나, 예외적으로 수익적 행정행위의 취소의 취소전에 이해관계있는 제3자가 생긴 경우에는 불가하다고 판시하였다(67누126판결)

제3 행정행위의 철회

Ⅰ. 개 설

1. 철회의 의의

철회라 함은 적법하게 성립한 행정행위의 효력을 성립 후에 발생한 새로운 사정으로 인하여 장래에 향하여 그 효력을 상실시키는 별개의 행정행위를 말한다.

2. 철회권자

철회는 그 성질상 원래의 행정행위처럼 새로운 처분을 하는 것과 같기 때문에 처분청만이 이를 행할 수 있다고 보아야 한다.

Ⅱ. 철회의 법적근거

행정행위의 철회는 반드시 법률상의 근거를 요구하는가에 관하여 견해의 대립이 있다.

1. 학설

① 수익적 행정행위나 제3자효적 행정행위에 대한 철회는 침익적 효과를 발생시키는 바 헌법 제37조 제2항에 비추어 법률의 근거가 필요하다는 적극설, ② 변화하는 행정현실에 대응하고 중대한 공익상 요청을 달성하기 위해 법률의 근거가 불필요하다는 소극설, ③ 원칙적으로 법적 근거 필요하나 철회권 유보나 당사자의 귀책사유가 있을 때는 법적 근거 불필요하다는 제한적 긍정설이 대립한다.

2. 판례의 태도

판례는 “행정행위를 한 처분청은 처분당시에 그 행정처분을 별다른 하자가 없었고 또 처분 후에 이를 취소할 별도의 법적 근거가 없다 하더라도 원래의 처분을 그대로 존속시킬 필요가 없게 된 사정변경이 생겼거나 또는 중대한 공익상의 필요가 발생한 경우에는 별개의 행정행위로 이를 철회하거나 변경할 수 있다”라고 판시하여 사정변경 등 철회사유가 있는 예외적인 경우에는 법적 근거가 없더라도 철회가 가능하다고 판시하고 있다.

Ⅲ. 철회사유

철회는 ‘철회의 대상이 되는 적법한 행정행위가 행해진 후 공익상 행정행위의 효력을 더 이상 존속시킬 수 없는 새로운 사정이 발생한 경우’에 행해질 수 있다. 이러한 철회사유는 구체적으로 첫째, 법령에 철회사유가 규정되어 있는 경우, 둘째, 상대방의 의무위반, 셋째, 부담불이행이 있는 경우, 넷째, 철회권 유보된 경우, 다섯째, 근거법령의 변경, 여섯째, 사정변경, 일곱째, 중대한 공익상의 필요 등이 있다.

Ⅳ. 철회의 제한

1. 수익적 행정행위에 있어 철회의 제한

⑴ 신뢰보호원칙에 의한 제한

⑵ 비례성의 원칙에 의한 제한

⑶ 실권의 법리

2. 침익적 행정행위 철회의 경우

침익적 행정행위에 철회원인이 있는 경우에는 철회가 사인의 불이익을 제거하는 것이기 때문에 행정청은 자유로이 철회할 수 있다. 그러나 행정행위를 철회한 후 동일내용의 행정행위를 하여야 할 경우 및 침익적 행정행위를 존속시켜야 할 우월한 공익상 요청이 있는 경우 등에는 철회가 제한된다.

3. 제3자효적 행정행위의 경우

철회에 의해 달성되는 공익과 상대방의 사익뿐만 아니라 제3자의 사익도 이익형량 하여 철회의 제한여부가 결정되어야 한다.

Ⅴ. 철회절차 및 철회의 효과

1. 철회절차

2. 철회의 효과 - 장래무효

3. 철회의 취소

이것은 철회의 위법을 이유로 그를 취소하여 원행정행위를 소생시킬 수 있는가의 문제로서 취소의 취소에 준하여 논할 수 있다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 행정행위의 취소와 철회에 관한 설명 중 맞는 것은?

① 철회권유보에 따른 철회에 있어서는 이익형량을 할 필요가 없다.
② 영업허가의 철회의 경우에는 항상 손실보상을 해주어야 한다.
③ 판례에 의하면 수익적 행정행위의 철회가 취소되면 당해 수익적 행정행위가 장래에 향하여 효력을 갖게 된다.
④ 위법한 계속적 급부결정이 직권취소된 경우에 상대방에게 귀책사유가 없으면 이미 수여된 급부는 반환할 필요가 없다는 것이 일반적 견해이다.
⑤ 수익적 행정행위의 철회시 의견제출절차는 의무적인 것은 아니다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 철회사유가 발생한 경우에도 행정청은 자유로이 철회할 수 있는 것은 아니고 철회권의 제한법리가 적용된다.
② 철회에 언제나 손실보상이 수반되는 것은 아니다. 즉, 부담적 행정행위를 철회하는 경우에는 손실을 보상할 필요가 없고, 수익적 행정행위를 철회할 경우에는 원칙적으로 손실보상을 해야 하지만, 이 경우에도 상대방의 귀책사유가 있으면 손실보상이 인정되지 않기 때문이다.
③ 영업의 금지를 명한 영업허가취소처분 자체가 나중에 행정쟁송절차에 의하여 취소되었다면 그 영업허가취소처분은 그 처분시에 소급하여 효력을 잃게 되며, 그 영업허가취소처분에 복종할 의무가 원래부터 없었음이 확정되었다고 봄이 타당하고, 영업허가취소처분이 장래에 향하여서만 효력을 잃게 된다고 볼 것은 아니므로 그 영업허가취소처분 이후의 영업행위를 무허가 영업이라고 볼 수는 없다(대판 1993.6.25, 93도277).
④ 위법한 선행조치에 대한 신뢰도 보호되기 때문에 상대방에게 귀책사유가 없으면 원상회복의무가 없다.
⑤ 행정청이 당사자에게 의무를 과하거나 권익을 제한하는 처분을 함에 있어서 청문이나 공청회를 실시하는 경우 외에는 당사자 등에게 의견제출의 기회를 주어야 한다(행정절차법 제22조 제3항). 따라서 의견제출은 정식절차가 보장되지 않을 경우 최소한 보장되는 의무적 절차라고 할 수 있다.

정답 ④

2. 다음 중 강학상 행정행위의 취소에 해당하는 것은? (2002 입법고시)

① 부정한 수단으로 운전면허를 취득한 자에 대한 면허취소
② 사자(死者)에 대한 조세부과처분의 취소
③ 부패한 식품을 판매한 자에 대한 영업허가의 취소
④ 점용료를 납부하지 않은 자에 대한 영업허가의 취소

⑤ 국유잡종재산임대계약의 취소

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 행정행위(운전면허) 발급 당시의 하자(원시적 하자)이므로 행정행위의 강학상 취소에 해당한다.
② 직권취소일 경우는 단순한 사실상의 통지에 해당하고 쟁송취소의 경우는 무효선언을 구하는 의미의 취소소송에 해당한다.
③④ 후발적 사유에 의한 것이므로 강학상 철회에 해당한다.
⑤ 민법상 계약의 해지에 해당한다.

정답 ①

3. 철회에 관한 설명 중 틀린 것은? (2004 관세사)

① 처분청만이 철회를 할 수 있다는 견해가 통설의 입장이다.
② 수익적 행정행위의 철회를 하기 위하여는 반드시 법적 근거를 요한다는 것이 판례의 입장이다.
③ 수익적 행정행위의 철회의 경우에 행정절차법상의 사전통지나 의견청취절차를 거쳐야 한다.
④ 철회권유보를 근거로 수익적 행정행위를 취소하는 경우에는 상대방의 신뢰보호를 위하여 손실보상을 할 필요가 없다.
⑤ 철회는 원칙적으로 장래효를 갖는다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 철회권자는 원칙적으로 철회의 대상인 행정행위의 권한을 가진 행정청에 한한다. 감독청은 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 철회권을 갖지 못한다.
② 수익적 행정행위의 철회에 법적 근거가 필요한지에 대하여 학설은 법적 근거 필요설과 법적 근거 불요설, 절충설(공익철회 재제철회 이분론)의 대립이 존재한다. 판례는 "행정행위를 한 처분청은 그 처분 당시에 그 행정처분에 별다른 하자가 없었고 또 그 처분 후에 이를 취소할 별도의 법적 근거가 없다 하더라도 원래의 처분을 그대로 존속시킬 필요가 없게 된 사정변경이 생겼거나 또는 중대한 공익상의 필요가 발생한 경우에는 별개의 행정행위로 이를 철회하거나 변경할 수 있다(대판 1992.1.17, 91누3130)"라고 판시하여 법적 근거가 없어도 철회를 할 수 있다고 한다.
③ 수익적 행정행위의 철회는 침익적 행정행위에 해당하므로 상대방의 권익보호와 철회의 공정을 도모하기 위하여 관계당사자에게 의견진술의 기회를 부여하고 이유를 제시해야 하는 경우가 많다.
④ 상대방에게 귀책사유가 없는 한, 수익적 행정행위의 철회로 인하여 발생된 손실은 보상되어야 함이 원칙인데, 철회권이 유보되어 있다면 상대방에게 귀책사유가 인정되므로 손실보상이 인정되지 않는다.
⑤ 따라서 기존의 수익적 행정처분으로 받은 이익은 부당이득이 아니다.

정답 ②

♣ 학습내용 정리

1. 행정행위의 하자로는 주체, 절차, 형식, 내용상 하자가 있다.
2. 행정행위의 취소에는 직권취소와 쟁송취소가 있다.
3. 행정행위의 철회는 적법하게 성립된 행정행위를 성립 후 사정으로 권한있는 행정청이 장래를 향해 효력를 소멸시키는 별개의 행정행위이다.

제19강 단계적 행정결정 등

♣ 학습목표

단계적 행정결정으로 확약, 사전결정, 부분허가를 비교하여 설명할 수 있다.
행정상 사실행위를 이해하고 그 중 하나인 행정지도에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

확약, 사전결정, 부분허가
행정상 사실행위
행정지도

♣ 사전테스트

1. 확약은 처분에 해당한다는 것이 판례의 입장이다.
   정답 : X

2. 행정상 사실행위 중 권력적 사실행위는 처분이 아니라는 것이 다수설과 판례이다.
   정답 : x

3. 행정지도는 비권력적 사실행위이다.
   정답 : O

♣ 돌발퀴즈

대법원은 단수조치를 권력적 사실행위라고 명시한 바 있다.

[정답] ×

[해설] 대법원은 “단수처분은 항고소송에 대상이 되는 행정처분에 해당한다(대판 1979.12.28, 79누218)”고 판시하고 있는데 명시적으로 권력적 사실행위라고 판단한 바는 없다.

♣ 강의내용

제1 확약

Ⅰ. 의 의

확약이란 행정기관이 국민에 대한 관계에 있어서 자기구속을 할 의도로써 장래에 향하여 일정한 행정행위를 하거나 하지 않을 것을 약속하는 단독적 의사표시를 말한다.

Ⅱ. 법적 성격－행정행위성 여부

1. 학 설

긍정설은 확약에 의해 행정청에게 확약대로 행위를 하여야 할 의무가 발생하므로 행정행위로 본다. 이에 반해 부정설은 사정변경으로 인한 효력소멸 및 종국적 규율성이 없다는 점에서 확약의 행정행위성을 부정한다.

2. 판 례

판례는 어업권면허에 선행하는 우선순위결정을 강학상 확약으로 보고 처분성을 부정하고 있다.

Ⅲ. 확약의 허용근거 - 별도의 법적근거없이 가능

Ⅳ. 확약의 요건

확약은 본 처분을 할 수 있는 권한을 가진 행정기관이 자신의 권한의 범위 안에서 행하여야 하며 그 내용은 법령에 위반되어서는 안 된다.

기속행위와 요건사실완성후에도 확약이 가능하다는 것이 다수설이다.

Ⅴ. 확약의 효과

1. 일반적 효과 - 구속력

확약이 위법하여 무효이거나 실효되지 않는 한 행정기관은 확약의 내용에 따라 본처분을 발령할 의무를 진다. 이를 확약의 구속력이라 한다.

2. 사정변경으로 인한 확약의 실효

확약이 행해진 후에 불가항력이나 기타의 사유로 확약의 내용을 이행할 수 없을 정도로 그 기초가 되었던 사실상태나 법적 상태가 변경된 경우에는, 행정기관이 이러한 사실을 미리 알았더라면 그와 같은 확약을 하지 않았을 것이라고 판단되면 확약내용의 구속력은 배제된다. 판례도 동일한 입장이다. 단, 그때 당사자의 신뢰는 손실보상 해주어야 한다.

Ⅵ. 권리구제

1. 행정쟁송

확약의 내용에 따른 본처분을 발령하지 않은 경우에는 본처분의 거부나 부작위 등 행정주체의 행위유형에 따라 의무이행심판, 거부처분취소소송 또는 부작위위법확인소송을 제기할 수 있다.

확약의 내용에 반하는 처분을 하는 경우에는 당해 처분에 대해 취소심판이나 취소소송을 제기할 수 있다.

2. 손해전보

확약의 불이행으로 인해 당사자에게 손해가 발생한 경우에는 국가배상법이 규정하는 바에 의거 손해배상을 청구할 수 있다. 확약이 수익적 행정행위를 대상으로 하는 때에는 신뢰보호의 관점에서 당해 확약의 취소나 철회가 제한될 수 있으며, 이 때 당사자의 귀책사유에 기인하지 않는 하자로 인한 취소의 경우에는 그 손실이 보상되어야 한다.

제2 사전결정과 부분허가

I. 사전결정

1. 의의

사전결정이란 최종적인 행정결정을 내리기 이전에 사전적인 단계로서 최종적 행정결정의 요건 중 일부에 대한 종국적 판단을 내리는 결정을 말한다(원자력발전소 건설허가전에 하는 부지사전승인, 폐기물설치와 관련된 사업계획적정통보, 항공기 노선면허전에 하는 운수권배분, 건축허가전에 하는 건축법 제10조[42]에 의한 대지적합성 사전결정).

2. 법적 성질

사전결정은 최종적 행정결정의 일부분에 대한 종국적 결정으로 그 자체가 하나의 행정행위이다.

3. 법적 근거 - 별도의 법적 근거없이 종국결정의 법적근거에 의해 가능

II. 부분허가

부분허가는 비교적 장기간의 시간을 요하고 공익에 중대한 영향력이 있는 시설물의 건설 등(예컨대 원자력발전소 건설, 공항건설 등)에 있어서 단계적으로 시설의 일부에 대하여 허가를 발하는 경우를 말한다.

제3 행정상 사실행위

Ⅰ. 서

1. 행정상 사실행위의 의의

---

42) 제10조 (건축 관련 입지와 규모의 사전결정)

① 제11조에 따른 건축허가 대상 건축물을 건축하려는 자는 건축허가를 신청하기 전에 허가권자에게 그 건축물을 해당 대지에 건축하는 것이 이 법이나 다른 법령에서 허용되는지에 대한 사전결정을 신청할 수 있다.

④ 허가권자는 제1항과 제2항에 따른 신청을 받으면 입지, 건축물의 규모, 용도 등을 사전결정한 후 사전결정 신청자에게 알려야 한다.

⑧ 사전결정신청자는 제4항에 따른 사전결정을 통지받은 날부터 2년 이내에 제11조에 따른 건축허가를 신청하여야 하며, 이 기간에 건축허가를 신청하지 아니하면 사전결정의 효력이 상실된다.

행정상 사실행위란 행정행위 또는 기타의 법적 행위와는 달리 일정한 법률효과의 발생을 의도하는 것이 아니라 직접적으로 일정한 사실상 결과 발생만을 목적으로 하는 행정주체의 일체의 행위를 말한다.

2. 행정상 사실행위의 종류

행정상 사실행위는 권력적·비권력적 사실행위, 집행적·독립적 사실행위, 정신작용적·물리적 사실행위, 공법적·사법적 사실행위 등으로 분류할 수 있으나 행정쟁송법상 처분성 인정여부와 관련하여 권력적 사실행위와 비권력적 사실행위의 구별이 특히 중요하다.

⑴ 권력적 사실행위

이는 일정한 법령 또는 행정행위를 집행하기 위한 공권력의 행사로서 하는 사실행위를 말하며, 대집행의 실행 등 행정법상의 의무이행을 확보하기 위한 강제적 집행행위(대집행실행, 직접강제), 경찰관의 무기사용, 감염병환자의 강제격리 등 행정상 장애를 제거하기 위한 즉시강제 등이 이에 속한다.

이러한 권력적 사실행위와 관련하여, ① 권력적 사실행위는 수인하명이라는 행정행위와 집행행위라는 사실행위가 결합된 것이므로 수인하명에 대해선 항고쟁송의 대상적격이 인정된다는 견해[43]와 ② 국민의 신체 재산에 직접적으로 실력을 가하여 행정목적을 실현하는 권력적 사실행위에는 그에 불복하는 국민에 대하여 행사되는 자력강제에 따를 수인의무를 부과하는 일종의 절차적 효과가 수반되는 것뿐이며 권력적 사실행위 자체가 어떠한 법적 효과를 발생시키는 행위는 아니라고 보는 견해[44]가 대립하고 있다.

⑵ 비권력적 사실행위

이는 공권력의 행사와 관계없는 사실행위인데, 이에는 금전출납·쓰레기수거·경비 등 비권력적 집행행위, 행정기관에 의한 환경보호시설의 건설·육교의 건설 등의 공익사업과 같은 단순한 사실행위, 고지·통지·행정지도·경고 등 지식표시행위 등이 이에 속한다.

Ⅱ. 행정상 사실행위의 법적근거와 한계

1. 행정상 사실행위의 법적근거

권력적 사실행위에는 법률유보 원칙이 적용되고 비권력적 사실행위에는 원칙적으로 법적근거가 필요치 않으나 국민에 대하여 침익적일 때(예컨대 위반사실 공표)에는 법률유보 원칙이 적용된다고 보아야 한다.

2. 행정상 사실행위의 한계 - 협의의 법규위반되면 안됨

Ⅲ. 행정상 사실행위와 행정구제

1. 행정상 사실행위와 항고쟁송

⑴ 권력적 사실행위

1) 처분성 인정여부 - 전술 참조

---

43) 홍정선, 415면.
44) 김동희, 188면; 박균성, 342면.

2) 협의의 소익

단기간에 종료되는 경우가 많으므로 협의의 소익이 흠결. 따라서 종료되기전 집행정지신청을 할 필요 있음.

⑵ 비권력적 사실행위 - 전술 참조

2. 행정상 사실행위와 손해배상

3. 공법상 결과제거청구권(당사자소송)

4. 행정상 사실행위와 손실보상

5. 가구제

6. 헌법소원

처분성이 부정되는 사실행위로 기본권을 직접 침해받은 국민은 헌법소원제기가능.

제4 행정지도

Ⅰ. 행정지도의 의의

행정지도라 함은 일정한 행정목적을 달성하기 위하여 상대방인 국민에게 임의적인 협력을 요청하는 비권력적 사실행위를 말한다. 권고, 권유, 요망, 요청, 지도 등이 그 예이다.

Ⅱ. 행정지도의 필요성과 문제점

1. 필요성

법령의 불비를 보완, 공권력발동으로 인한 저항 방지, 최신의 정보 등 제공.

2. 문제점

국민의 권익침해 가능성 및 권리구제의 곤란성

Ⅲ. 행정지도의 종류

광의의 행정지도는 행정주체, 행정기관에 대한 지도와 사인에 대한 지도로 구분할 수 있다. 다만 일반적으로는 행정지도를 후자에 한정되는 것으로 파악하고 있다.

Ⅳ. 행정지도의 법적근거와 한계

1. 행정지도의 법적근거

통설은 행정지도에 따를 것인지의 여부가 상대방인 국민의 임의적 결정에 달려 있으므로 행정지도에는 법률의 근거가 없이도 된다는 입장이다. 이에 비해, 행정지도가 사실상 강한 강제력을 갖는 경우에는 법률의 근거가 있어야 한다고 보는 견해도 있다.

2. 행정지도의 한계

⑴ 법규상의 한계

⑵ 행정법의 일반원리에 의한 한계

Ⅴ. 행정지도의 원칙과 방식- 행정절차법 참조

Ⅵ. 행정지도와 행정구제

1. 항고쟁송에 의한 구제
2. 국가배상청구에 의한 구제
3. 손실보상
4. 헌법소원의 가능성

사실상 강제력있는 사실행위, 검사의 불기소 처분, 법규명령, 행정계획, 행정권의 불행사 등의 행위가 국민의 기본권을 침해하는 경우에는 헌법소원의 대상이 되는 공권력행사에 해당한다고 보는 것이 일반적 견해이다.

다만, 사실상 규제력있는 행정지도를 처분의 개념에 포함시키는 견해에 의하면, 규제적 조정적 행정지도는 항고소소의 대상이 되는 바, 규제적 행정지도에 대한 헌법소원은 헌법소원의 보충성요건을 결하게 되어 각하될 것이다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 사실행위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (2006 국회8급)

① 사실행위는 행정소송의 대상이 될 수 있다.
② 국가배상청구가 사실행위의 구제수단이 될 수 있다.
③ 행정조사는 사실행위의 일종이다.
④ 사실행위는 행정조직법적 근거가 필요하며 비례성의 원칙이 적용된다.
⑤ 대법원은 단수조치를 권력적 사실행위라고 명시한 바 있다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 권력적 사실행위의 경우에 통설과 판례는 처분성을 인정한다. 비권력적 사실행위에 대해서 판례는 처분성을 부정한다.
② 행정상 사실행위도 행정작용의 한 유형이므로 국가배상법 제2조와 제5조에서 규정하고 있는 공무원의 직무행위와 영조물의 설치나 관리행위에 해당한다.
③ 행정조사는 행정기관이 행정작용을 위해 필요한 정보나 자료 등을 수집하는 일체의 행정활동을 지칭하는데 법적성질은 직접적으로 법적 효과가 발생하지 않는 사실행위에 해당된다.
④ 행정청이 일정한 사실행위를 적법하게 하기 위해서는 조직법적 근거가 있어야 함은 다른 행정작용과 마찬가지이다. 그 외에 작용법적 근거를 필요로 하는가에 대해서는 견해대립이 존재하는데 일반적 견해는 권력적 사실행위에 대해서 작용법적 법적 근거를 요한다고 본다. 행정상 사실행위도 다른 행정작용과 마찬가지로 헌법 또는 법령에 위배되지 않아야 하며, 행정 목적을 위해 필요한 범위 내에서 이루어져야 한다(비례의 원칙). 그 밖에 평등의 원칙 및 신뢰보호의 원칙 등의 준수도 요구된다.
⑤ 대법원은 “단수처분은 항고소송에 대상이 되는 행정처분에 해당한다(대판 1979.12.28, 79누218)”고 판시하고 있는데 명시적으로 권력적 사실행위라고 판단한 바는 없다.

정답 ⑤

2. 사실행위 및 행정지도에 관한 설명 중 옳은 것은? (2008 관세사)

① 사실행위는 직접 법적 효과를 발생시키지 않는다.
② 사실행위는 법적 근거 없이도 가능하다.
③ 행정지도는 권력적 사실행위이다.
④ 행정지도를 따르지 않은 경우 불이익 조치를 할 수 있다.
⑤ 행정지도로 인한 손해에 대하여는 국가배상이 인정될 수 없다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

② 비권력적 사실행위는 법적 근거를 요하지 않지만, 권력적 사실행위는 법적 근거를 요한다.
③ 행정지도는 비권력적 사실행위이다.
④ 행정기관은 행정지도의 상대방이 행정지도에 따르지 아니하였다는 것을 이유로 불이익한 조치를 하여서는 아니 된다(행정절차법 제48조 제2항).
⑤ 비권력적 사실행위도 광의설에 의하면 직무행위에는 해당된다. 위법성 인정여부에 대해서 위법성 조각설과 위법성 불조각설의 견해대립이 존재한다. 인과관계인정여부에 대해서 인과관계 부정설과 제한적 긍정설의 견해 대립이 있는데 판례는 제한적 긍정설에 의한다. 판례의 태도에 의할 경우 규제적 행정지도, 즉 행정지도에 따를 수밖에 없는 경우는 위법성이 조각되지 않고 상당인과관계가 인정되므로 국가배상청구가 인정된다.

정답 ①

3. 품질 및 품위향상을 목적으로 甲에 대하여 특정농작물을 재배할 것을 지도하였다. 이와 관련된 다음의 설명으로 가장 옳은 것은?

① 농촌진흥청장의 지도는 성질상 일종의 하명에 해당되는 것이므로 甲은 지도의 내용을 이행하여야 할 작위의무를 부담한다.
② 국민의 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 것과 같이 침익적 성질을 가지는 지도의 경우에는 반드시 법적 근거가 요구된다고 하는 것이 통설과 판례의 입장이다.
③ 만약 위 지도가 위법하다면 농촌진흥청장은 甲에 대하여 국가배상법에 따른 손해배상책임을 부담한다.
④ 만약 위 지도가 적법하더라도, 甲은 손실보상을 청구하기 어렵다.
⑤ 농촌진흥청장의 지도행위는 취소소송의 대상이 되므로 甲은 취소소송을 제기하여 권리구제를 받을 수 있다.

해설 & 정답

유형 준사례형

① 행정지도란 행정주체가 조언·권고 등의 방법으로 국민이나 기타 관계자의 행동을 유도하여 일정한 목적을 실현하기 위해 행하는 비권력적 사실행위로서 상대방의 임의적 동의나 협력을 전제로 행해진다.
② 행정지도는 일반적으로 비권력적 사실행위로서 법적 근거를 요하지 않는다는 것이 통설과 판례이다.
③ 이른바 행정지도라 함은 행정주체가 일정한 행정목적을 실현하기 위하여 권고 등과 같은 비강제적인 수단을 사용하여 상대방의 자발적 협력 내지 동의를 얻어내어 행정상 바람직한 결과를 이끌어내는 행정활동으로 이해되고, 따라서 적법한 행정지도로 인정되기 위하여는 우선 그 목적이 적법한 것으로 인정될 수 있어야 할 것이므로, 주식매각의 종용이 정당한 법률적 근거 없이 자의적으로 주주에게 제재를 가하는 것이라면 이 점에서 벌써 행정지도의 영역을 벗어난 것이라고 보아야 할 것이고 만일 이러한 행위도 행정지도에 해당된다고 한다면 이는 행정지도라는 미명하에 법치주의의 원칙을 파괴하는 것이라고 하지 않을 수 없으며, 더구나 그 주주가 주식매각의 종용을 거부한다는 의사를 명백하게 표시하였음에도 불구하고, 집요하게 위협적인 언동을 함으로써 그 매각을 강요하였다면 이는 위법한 강박행위에 해당한다고 하지 않을 수 없다 하여, 정부의 재무부 이재국장 등이 국제그룹 정리방안에 따라 신한투자금융주식회사의 주식을 주식회사 제

일은행에게 매각하도록 종용한 행위가 행정지도에 해당되어 위법성이 조각된다는 주장을 배척한 사례(대판 1994.12.13, 93다49482).

④ 행정지도는 비권력적 사실행위이므로 권력적 행정작용을 전제로 하는 행정상의 손실 보상은 부정된다는 부정설과 긍정설(신뢰보호의 원칙에 따른 손실배상을 청구할 수 있다는 견해와 특별한 희생이 있는 경우에는 수용적 침해보상의 법리를 활용하여 보상이 가능하다는 견해)이 대립한다. 즉 견해에 따라서 손실 보상이 가능하다.

⑤ 행정청이 위법건축물에 대한 시정명령을 하고 나서 위반자가 이를 이행하지 아니하여 전기·전화의 공급자에게 그 위법건축물에 대한 전기·전화공급을 하지 말아 줄 것을 요청한 행위는 권고적 성격의 행위에 불과한 것으로서 전기·전화공급자나 특정인의 법률상 지위에 직접적인 변동을 가져오는 것은 아니므로 이를 항고소송의 대상이 되는 행정처분이라고 볼 수 없다(대판 1996.3.22, 96누433).

정답 ③

♣ 학습내용 정리

1. 확약은 처분이 아니고 사전결정과 부분허가는 처분이라는 것이 판례의 입장이다.
2. 행정상 사실행위에는 권력적 사실행위와 비권력적 사실행위가 있다.
3. 행정지도는 비권력적 사실행위로서 항고소송의 대상인 처분이 아니라는 것이 판례의 입장이다.

제20강 행정조사

♣ 학습목표

행정조사의 의의 및 종류, 법적 성질 등에 대하여 이해하고 행정상 강제집행수단 중 하나인 대집행의 의의 및 요건을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

행정조사
대집행의 의의 및 요건

♣ 사전테스트

1. 행정조사에 관한 기본법은 존재하지 않는다.
   정답 : X

2. 행정조사는 법적 근거없이도 가능하다.
   정답 : x

3. 대집행은 행정상 강제집행수단 중에 하나이다.
   정답 : O

♣ 돌발퀴즈

도시공원시설 점유자의 퇴거 및 명도의무는 행정대집행법에 의한 대집행의 대상은 아니다.

[정답] ○

[해설] 피수용자 등이 기업자에 대하여 부담하는 수용대상 토지의 인도의무에 관한 구 토지수용법(2002.2.4. 법률 제6656호 공익사업을위한토지등의취득및보상에관한법률 부칙 제2조로 폐지) 제63조, 제64조, 제77조 규정에서의 '인도'에는 명도도 포함되는 것으로 보아야 하고, 이러한 명도의무는 그것을 강제적으로 실현하면서 직접적인 실력행사가 필요한 것이지 대체적 작위의무라고 볼 수 없으므로 특별한 사정이 없는 한 행정대집행법에 의한 대집행의 대상이 될 수 있는 것이 아니다(대판 2005.8.19, 2004다2809). 판례와 다수의 견해는 물건의 인도 및 토지 등의 명도의무는 직접적 실력행사를 통해야 하므로 대체적 작위의무에 해당하는 것이 아니므로 대집행의 대상에 해당하지 않는다고 본다.

♣ 강의내용

제1 행정조사

Ⅰ. 개 설

1. 의 의

행정조사란 '행정기관이 사인으로부터 행정상 필요한 자료나 정보를 수집하기 위하여 행하는 일체의 행정작용'을 말한다.

이에 행정조사기본법 제2조 제1호는 '"행정조사"란 행정기관이 정책을 결정하거나 직무를 수행하는 데 필요한 정보나 자료를 수집하기 위하여 현장조사·문서열람·시료채취 등을 하거나 조사대상자에게 보고요구·자료제출요구 및 출석·진술요구를 행하는 활동을 말한다'라고 규정하고 있다.

2. 법적성질

행정조사 중 비권력적 조사(여론조사 등)는 법적 효과를 발생시키지 못하는 사실행위에 불과하다. 그러나 권력적 조사(세무조사 등)는 수인의무를 수반하는 권력적 사실행위이다.

Ⅱ. 행정조사의 법적근거

1. 이론적 근거

권력조사는 국민의 신체나 재산에 침해를 가져오는 것이므로 헌법 제37조 제2항에 근거하여 법률의 근거를 요한다. 그러나 비권력조사는 국민의 신체나 재산에 직접 침해를 가져오는 것이 아

니므로 원칙적으로 법적 근거를 요하지 아니한다.

2. 실정법적 근거

행정기관은 법령 등에서 행정조사를 규정하고 있는 경우에 한하여 행정조사를 실시할 수 있다. 다만, 조사대상자의 자발적인 협조를 얻어 실시하는 행정조사의 경우에는 그러하지 아니하다(행정조사기본법 제5조). 따라서 상대방의 동의에 의해 실시되는 행정조사를 제외하고는 모두 개별법률에 근거가 있어야 가능하다.

Ⅲ. 행정조사기본법상 행정조사의 방법

1. 출석요구(제9조)
2. 보고요구 및 자료제출의 요구(법 제10조)
3. 현장조사(법 제11조)
4. 시료채취(법 제12조)
5. 자료등 영치(법 제13조)
6. 공동조사(법 제14조)

Ⅳ. 행정조사의 한계

1. 실체적 한계

⑴ 개별법령상의 한계

행정조사는 행정조사를 규율하는 개별법령을 위반하여서는 안 된다.

⑵ 행정조사기본법상의 한계

1) 목적부합성의 원칙(제4조 제6항).
2) 비례의 원칙(법 제4조 제1항).
3) 중복조사금지원칙(제4조 제3항)
4) 비밀누설금지원칙(제4조 제5항)

⑶ 행정법의 일반원칙상의 한계

행정조사의 실시에 있어서 합리적인 사유 없이 피조사자를 차별하는 것은 평등의 원칙에 반한다. 특히 세무조사에 있어서 피조사자의 선정 및 조사의 강도와 관련하여 평등원칙의 위반 여부가 문제된다.

2. 절차적 한계

⑴ 행정조사기본법상의 절차적 요건

1) 조사의 사전통지(동법 제17조)
2) 의견제출(동법 제21조)
3) 증표의 제시의무(동법 제11조 제3항)
4) 시간의 제한(동법 제11조 제2항)

⑵ 행정조사에 행정절차법이 적용되는지

행정절차법은 행정조사에 관한 명문의 규정을 두고 있지 않다. 그러나 행정조사에 행정절차법이 적용되지 않는 것은 아니다. 행정조사가 행정절차법 제2조 제2호의 처분에 포섭되는 경우에는 행정절차법상의 처분절차에 관한 규정이 적용된다.

3. 영장주의의 적용여부

행정조사를 위한 질문, 장부의 검사, 물건의 검사 수거 및 가택출입조사 등에 대하여 헌법 제12조 제3항 및 제16조의 영장주의가 적용될 것인가의 문제가 있다.

이에 대하여 즉시강제의 경우와 마찬가지로 영장필요설, 영장불요설, 절충설 등이 있는데 절충설이 다수설이다.

4. 행정조사와 실력행사

① 행정조사에서 실력행사가 가능하다고 한다면 즉시강제와 권력조사와의 구별이 어려워지며 피조사자의 거부 방해가 있을 경우 벌칙 등으로 강제할 수 밖에 없다는 부정설과, ② 권력조사의 성격상 권력조사의 방해를 실력으로 배제하는 것은 권력조사의 범위 안에 있다는 긍정설, ③ 개별적으로 검토해야 한다는 개별적 판단설 등이 대립힌다.

V. 위법한 행정조사의 효과

1. 서

행정조사가 위법한 경우에 그 행정조사에 의해 수집된 정보에 기초하여 내려진 행정결정이 위법한 것으로 되는가가 문제로 된다(예컨대 A기업에 대하여 국세청이 위법하게 실력행사를 하여 위법한 세무조사를 하였으나 위 세무조사를 통해 A기업이 탈세한 자료를 입수하게 되어 그에 따라 추징세부과처분을 한 경우 추징세부과처분자체는 적법한데 세무조사가 위법하다는 이유로 추징세부과처분을 위법하다고 볼 수 있는가의 문제이다).

행정조사를 통하여 획득한 정보가 정확하지 않은 경우에 그 정보에 기초하여 내려진 행정행위는 사실의 기초에 하자 있는 행정행위이므로 행정조사의 위법여부를 묻지 않고 당연히 위법성이 인정된다.

따라서 특히 문제가 되는 경우는 행정조사를 통하여 획득한 정보가 내용상으로는 정확하지만 행정조사가 실체법상 또는 절차법상 한계를 넘어 위법한 경우이다. 현재 다음과 같은 견해가 대립하고 있다.

2. 학설

⑴ 적극설[45]

적법절차원칙에 비추어 행정조사가 위법한 경우에 당해 조사를 기초로 한 행정결정은 위법하다고 보는 견해로서 행정조사가 반드시 어떠한 행정결정에 필수적으로 요구되는 것은 아니고 단지 예비적인 작용이라 하여도 마찬가지라고 본다.

⑵ 소극설[46]

행정조사는 법령에서 특히 행정행위의 전제조건으로 규정하고 있는 경우를 제외하고는 일응 별개의 제도로 볼 수 있는 것이고, 이 경우에는 조사의 위법이 바로 행정행위를 위법하게 만들지는 않는다고 보는 견해이다.

⑶ 절충설[47]

행정조사와 행정처분은 하나의 과정을 구성하는 것이므로 적법절차의 관점에서 행정조사에 중대한 위법사유가 있는 때에는 이를 기초로 한 행정행위도 위법한 행위로 된다고 보는 견해이다.

3. 판례

판례는 적극설의 입장을 취한 것으로 보인다.

위법한 중복세무조사에 기초하여 이루어진 과세처분은 위법하다는 판례(대법원 2006.06.02. 선고 2004두12070 판결)

45) 홍정선, 전게서, 495면.
46) 박윤흔, 전게서, 576면.
47) 김동희, 전게서, 427면.

Ⅵ. 행정조사에 대한 구제

1. 적법한 행정조사에 대한 구제

2. 위법한 행정조사에 대한 구제

⑴ 항고쟁송
1) 대상적격
2) 협의의 소의 이익

⑵ 국가배상

⑶ 결과제거청구권

⑷ 정당방위

제2 대집행의 의의 및 요건

Ⅰ. 개 설

1. 의 의
행정대집행은 대체적 작위의무를 의무자가 이행하지 아니한 경우에 당해 행정청이 의무자가 행할 작위의무를 스스로 행하거나(자기집행) 또는 제3자로 하여금 이를 행하게 하고(제3자 대집행), 그 의무자로부터 비용을 징수하는 행정상의 강제집행수단이다(행정대집행법 제2조).

2. 법적근거 - 일반법 : 행정대집행법 / 개별법

Ⅱ. 대집행의 주체 및 대집행행위자

1. 대집행의 주체 - 당해 행정청

2. 대집행행위자 - 행정청 또는 제3자, 이때 제3자는 공무수탁사인 아님

Ⅲ. 대집행요건

1. 대집행의 대상이 되는 의무 - 대체적 작위의무

⑴ 대체적 작위의무의 불이행

1) 공법상의 의무

2) 작위의무

3) 대체적 의무 : 토지나 건물 인도의무는 비대체적 작위의무이므로 대집행불가

매점점유이전의무는 비대체적의무이므로 직접강제는 별론으로 하더라도 대집행은 안된다는 판례(대판 1998. 10. 23, 97누157).

2. 다른 수단에 의한 이행확보가 곤란할 것 - 보충성

3. 그 불이행의 방치가 심히 공익을 해하는 것일 것

위 요건포섭에 있어서 첫째 행정청에게 재량이 인정된다는 견해, 둘째 행정청에게 판단여지가 인정된다는 견해, 셋째 전면적으로 사법심사가 가능하다는 견해 등이 있다.

판례는 위 요건에 대하여 전면적으로 사법심사를 하는 것으로 보인다.

4. 효과

위 요건이 모두 충족되는 경우, 행정청이 대집행을 할 것인지의 여부에 관하여 기속행위로 보는 견해와 재량행위로 보는 견해가 대립하고 있으나 행정대집행법 제2조의 규정형식이 '~ 할 수 있다'라고 규정하고 있다는 점에 비추어 판례와 다수설의 견해처럼 재량행위로 보는 것이 타당하다. 다만, 구체적인 상황에 따라서는 재량이 0으로 수축되어 대집행실시가 행정청의 의무가 되는 경우가 많을 것이다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 조세범처벌절차법 제3조가 규정하고 있는 수색은 다음 어느 것인가?

① 민사상 강제집행 ② 행정상 즉시강제
③ 행정조사 ④ 행정상 직접강제
⑤ 행정형벌

해설 & 정답

유형 법률지식형

행정조사란 행정기관이 행정작용을 위해 필요한 정보나 자료 등을 수집하는 일체의 행정활동을 말하는데 행정조사기본법 제2조에서 정의 규정을 두고 있다. 행정조사의 대상에 따라 구분할 경우 불심검문, 질문, 신체수색, 음주측정, 강제건강진단 등은 행정조사의 대상이 사람인 대인적 행정조사에 해당하고, 장부나 물건의 검사 등은 대물적 조사에 해당하고, 가택에의 출입·조사 등은 대가택 조사에 해당한다. 사안의 수색은 대인적 행정조사에 해당한다.

정답 ③

2. 행정조사기본법상 행정조사의 원칙으로 옳지 않은 것은? (2008 관세사)

① 최소침해원칙 ② 중복조사의 제한
③ 내용공포금지 ④ 타용도이용금지
⑤ 처벌조사중심주의

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 행정조사는 조사 목적을 달성하는데 필요한 최소한의 범위 안에서 실시하여야 하며, 다른 목적 등을 위하여 조사권을 남용하여서는 아니된다(행정조사기본법 제4조 제1항). - 비례성의 원칙
② 행정기관은 유사하거나 동일한 사안에 대하여는 공동조사 등을 실시함으로써 행정조사가 중복되지 아니하도록 하여야 한다(동조 제3항). - 중복조사금지의 원칙
③ 다른 법률에 따르지 아니하고는 행정조사의 대상자 또는 행정조사의 내용을 공표하거나 직무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니된다(동조 제5항). - 비밀누설금지의 원칙

④ 행정기관은 행정조사를 통하여 알게 된 정보를 다른 법률에 따라 내부에서 이용하거나 다른 기관에 제공하는 경우를 제외하고는 원래의 조사목적 이외의 용도로 이용하거나 타인에게 제공하여서는 아니 된다(동조 제6항). - 목적적합성의 원칙

⑤ 행정조사는 법령 등의 위반에 대한 처벌보다는 법령 등을 준수하도록 유도하는 데 중점을 두어야 한다(동조 제4항).

정답 ⑤

3. 행정조사기본법상의 행정조사에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 금융감독기관의 감독·검사·조사 및 감리에 관한 사항에는 행정조사기본법이 전면적으로 직접 적용된다.

② 행정기관이 유사한 사안이라고 하여 공동조사를 실시하는 것은 국민의 권익을 침해할 수 있으므로 허용되지 않는다.

③ 임의조사를 제외하고 행정기관은 법령 등에서 행정조사를 규정한 경우에 한하여서만 행정조사를 실시할 수 있다.

④ 행정기관은 행정조사를 통하여 알게 된 정보를 임의로 다른 국가기관에 제공할 수 있다.

⑤ 금융감독기관의 감독·검사·조사에 대하여는 행정조사기본법이 적용될 여지가 없다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에 대하여는 행정조사기본법을 적용하지 아니한다(행정조사기본법 제3조 제2항). 그러나 제4조(행정조사의 기본원칙), 제5조(행정조사의 근거) 및 제28조(정보통신수단을 통한 행정조사)는 다음 각 호의 사항에 대하여 적용한다(동조 제3항).

1. 행정조사를 한다는 사실이나 조사내용이 공개될 경우 국가의 존립을 위태롭게 하거나 국가의 중대한 이익을 현저히 해칠 우려가 있는 국가안전보장·통일 및 외교에 관한 사항
2. 국방 및 안전에 관한 사항 중 군사시설·군사기밀보호 또는 방위사업에 관한 사항이나 병역법·향토예비군설치법·민방위기본법·비상대비자원 관리법에 따른 징집·소집·동원 및 훈련에 관한 사항
3. 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제4조제3항의 정보에 관한 사항
4. 근로기준법 제101조에 따른 근로감독관의 직무에 관한 사항
5. 조세·형사·행형 및 보안처분에 관한 사항
6. 금융감독기관의 감독·검사·조사 및 감리에 관한 사항
7. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 표시·광고의 공정화에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률, 방문판매 등에 관한 법률, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률, 약관의 규제에 관한 법률 및 할부거래에 관한 법률에 따른 공정거래위원회의 법률위반행위 조사에 관한 사항

② 행정기관은 유사하거나 동일한 사안에 대하여는 공동조사 등을 실시함으로써 행정조사가 중복되지 아니하도록 하여야 한다(동법 제4조 제3항).

③ 행정기관은 법령 등에서 행정조사를 규정하고 있는 경우에 한하여 행정조사를 실시할 수 있다. 다만, 조사대상자의 자발적인 협조를 얻어 실시하는 행정조사의 경우에는 그러하지 아니하다(동법 제5조).

④ 행정기관은 행정조사를 통하여 알게 된 정보를 다른 법률에 따라 내부에서 이용하거나 다른 기관에 제공하는 경우를 제외하고는 원래의 조사목적 이외의 용도로 이용하거나 타인에게 제공하여서는 아니 된다(동법 제4조 제6항).

⑤ 제4조(행정조사의 기본원칙), 제5조(행정조사의 근거) 및 제28조(정보통신수단을 통한 행정조사)는 적용한다(동법 제3조 제3항).

정답 ③

♣ 학습내용 정리

1. 행정조사는 권력조사와 비권력조사가 있고 기본법으로 행정조사기본법의 적용을 받는다.
2. 공법상 의무로서 대체적 작위의무불이행시에는 대집행이 가능하다.

제21강 강제집행

♣ 학습목표

공법상 의무불이행시 직접적 이행확보수단으로서 강제집행, 즉 대집행, 직접강제, 이행강제금, 강제징수에 대하여 설명할 수 있다.

공익상 장애제거수단으로서 행정상 즉시강제에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

행정상 강제집행

행정상 즉시강제

♣ 사전테스트

1. 직접강제는 부작위의무위반시 할 수 없다.
   정답 : X

2. 강제징수시 독촉없이 체납처분할 수 있다.
   정답 : x

3. 행정상 즉시강제는 권력적 사실행위의 성질을 갖는다.
   정답 : O

♣ 돌발퀴즈

대법원 판례에 따르면, 이행강제금의 납부의무는 일신전속적 의무가 아니므로 상속인에게 승계된다.

[정답] ×

[해설] 구 건축법상의 이행강제금은 구 건축법의 위반행위에 대하여 시정명령을 받은 후 시정기간 내에 당해 시정명령을 이행하지 아니한 건축주 등에 대하여 부과되는 간접강제의 일종으로서 그 이행강제금 납부의무는 상속인 기타의 사람에게 승계될 수 없는 일신전속적인 성질의 것이므로 이미 사망한 사람에게 이행강제금을 부과하는 내용의 처분이나 결정은 당연무효이고, 이행강제금을 부과받은 사람의 이의에 의하여 비송사건절차법에 의한 재판절차가 개시된 후에 그 이의한 사람이 사망한 때에는 사건 자체가 목적을 잃고 절차가 종료한다(대결 2006.12.8, 2006마470).

♣ 강의내용

제1 대집행 절차 및 권리구제

I. 대집행절차

1. 계 고

⑴ 의 의

대집행을 위하여 상당한 이행기간을 정하여 그때까지 이행되지 아니할 때에는 대집행을 한다는 뜻을 미리 문서로 통지하는 것을 말한다(행정대집행법 제3조 제1항). 다만, 법률에 특별한 규정이 있거나 비상시 또는 위험이 절박하여 통지할 만한 여유가 없을 때에는 통지를 생략할 수 있다(동법 제3조 제3항).

⑵ 법적성질 - 준법률행위적 행정행위로서 통지

⑶ 계고의 요건

1) 상당한 이행기간 - 사회통념상 판단 / 계고처분서 송달일이 기산점

2) 대집행요건이 계고시에 이미 충족되었을 것.

3) 대집행의무의 특정

4) 형 식 -문서

2. 대집행영장에 의한 통지

⑴ 의 의

의무자가 계고를 받고도 지정된 기한까지 의무를 이행하지 아니한 경우에는 당해 행정청은 대집행영장에 의하여 대집행의 시기, 대집행책임자의 성명 및 대집행비용의 개산액을 의무자에게 통지하여야 한다(행정대집행법 제3조 제2항). 다만, 법률에 특별한 규정이 있거나 비상시 또는 위험이 절박하여 통지할 만한 여유가 없을 때에는 통지를 생략할 수 있다(동법 제3조 제3항).

⑵ 법적성질 - 준법률행위적 행정행위로서 통지

3. 대집행의 실행

대집행은 대집행영장에 기재된 시기에 대집행책임자에 의해 실행된다. 대집행실행은 권력적 사실행위로서 항고소송의 대상이 된다.

⑴ 증표휴대 및 제시

⑵ 의무자의 항거에 대한 실력배제의 가능성

이에 대하여 독일의 행정대집행법 제15조 제2항은 “의무자가 대집행 또는 직접강제에 대하여 저항을 하면 실력으로 이를 배제할 수 있다”는 명문규정을 두고 있으나, 우리나라는 이에 대하여 명문규정이 없어 논란이 있다.

이에 대해 일부견해는 대집행의 실효성 확보를 위하여 대집행의 내용인 사실행위의 수행에 대한 저항을 배제하는데 부득이한 최소한의 실력행사는 대집행에 수반하는 기능으로서 허용된다고 본다.

이에 대해 일부견해는 저항을 실력으로 배제하는 것은 신체 등에 대하여 물리력을 행사하는 것이므로 대집행에 포함된다고 볼 수 없고 직접강제의 대상이 된다고 본다. 즉, 대집행의 실행을 위하여 저항을 실력으로 배제하는 것을 인정할 필요가 있지만 이는 별도의 법적 근거가 필요하다는 것이다.

4. 비용납부명령

Ⅱ. 대집행에 대한 구제

1. 항고쟁송

⑴ 대상적격 - 각 처분성 인정됨

⑵ 대집행의 종료와 소의 이익

대집행의 실행이 이미 완료된 이후에는 그 대집행이 위법한 것이라는 이유로 손해배상이나 원상회복 등을 청구하는 것은 별론으로 하고 그 기초가 된 의무를 과하는 행정처분이나 계고나 대집행영장에 의한 통지 등의 취소나 무효확인을 구할 소의 이익이 없다. 다만 대집행실행이 완료되었다 하더라도 비용납부의무를 면하기 위하여 비용납부명령취소소송을 제기할 소의 이익은 있다.

⑶ 하자의 승계

1) 의무를 과하는 선행처분과 대집행 사이 - 하자승계부정

2) 계고, 영장통지, 대집행실행, 비용납부명령 사이 - 하자승계인정

2. 국가배상청구 - 선결문제 : 심리가능(다수설, 판례)

3. 결과제거청구권

제2 이행강제금

Ⅰ. 의 의

이행강제금이란 행정법상 의무를 의무자가 이행하지 아니한 경우에 행정청이 일정한 기간 내에 의무를 이행하지 않으면 일정한 제재금을 과할 뜻을 의무자에게 예고함으로써 심리적 압박을 가하여 의무자로 하여금 스스로 의무를 이행케 하는 행정상 강제집행의 수단을 말한다.

Ⅱ. 법적 성질

이행강제금은 금전급부의무를 부과하는 법률행위적 행정행위 중 하명에 속한다. 이러한 이행강제금은 행정벌과 다음과 같은 두 가지 면에서 차이가 있다. 첫째 이행강제금은 행정청이 정한

기간 내에 의무이행이 있으면 원칙적으로 강제금의 급부가 면제되나, 행정벌은 일단 과태료 등을 부과한 이상 나중에 의무를 이행하더라도 납부하여야 한다. 둘째 이행강제금은 장래의 의무이행을 심리적으로 강제하기 위한 것으로서 의무이행이 있기까지 반복하여 부과할 수 있으나, 행정벌은 과거의 위반에 대한 제재로서 하나의 위반에 대하여 반복하여 부과할 수 없다.[48] 양자는 국제목적을 달리하므로 병행하여 부과할 수 있다.

Ⅲ. 법적근거

이행강제금도 행정상 강제집행의 수단이므로 당연히 법적 근거가 있어야 한다. 현재 우리나라는 이행강제금에 대한 일반법은 없고, 단지 건축법 제80조, 농지법 제62조, 부동산실권리자명의등기에관한법률 제6조 등의 개별법에서 극히 한정적으로 인정되고 있다.

Ⅳ. 위법한 이행강제금에 대한 권리구제수단

1. 이행강제금에 대하여 이의를 제기할 경우 비송사건절차법에 의하여 결정하도록 규정한 경우
   - 항고소송제기불가

2. 이행강제금에 대한 불복방법에 관하여 아무런 규정이 없는 경우

건축법 제80조에 의한 이행강제금부과처분처럼 이행강제금에 대한 불복방법에 관하여 아무런 규정이 없는 경우 이행강제금부과처분은 행정행위이므로 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다.

제3 직접강제

Ⅰ. 개 설

1. 의 의

직접강제란 의무자가 행정법상 의무를 이행하지 아니하는 경우에 행정청이 직접적으로 의무자의 신체 또는 재산에 실력을 행사하여 행정상 필요한 상태를 실현하는 행정상 강제집행의 수단을 말한다.

2. 직접강제의 필요성

종래의 부작위의무 위반에 대해서는 행정벌에 의하여 간접적으로 의무이행을 확보함에 그치는 것이 보통이었다. 이와 같은 행정벌은 ① 간접적 효과밖에 없는 것이며, ② 동일 사안에 대하여 목적을 달성할 때까지 반복적인 처벌은 허용되지 않으며, ③ 벌칙 중에서 벌금형은 위법행위에 의하여 얻어지는 경제상 이익이 보다 큰 것인 때에는 그 실효성이 거의 없게 되고, ④ 무허가영업자를 모두 처벌한다는 것은 사실상 불가능한 점 등의 문제점[49]이 있다.

행정벌이 지닌 위와 같은 문제점을 극복하고 행정법규의 실효성을 확보하기 위해서는 직접강제를 입법적으로 도입할 필요가 있다. 단, 직접강제는 국민의 기본권을 가장 심하게 제한하는 실효성확보수단이므로 신중을 기하여 선별적으로 도입할 필요가 있다.

Ⅱ. 직접강제의 성질

직접강제의 법적 성질은 수인의무가 부과되는 권력적 사실행위이다.

---

48) 김철용, 377면.
49) 석종현, 전게서, 512면.

Ⅲ. 법적근거

직접강제도 행정상 강제집행의 수단으로서 국민의 기본권을 제한하는 측면이 강하므로 법률유보범위에 관한 어느 학설에 의한다 하더라도 법적근거가 필요하다. 직접강제에 대한 일반법은 없고 개별법으로 출입국관리법 제46조의 강제출국, 공중위생관리법 제11조의 영업소나 제조업소의 폐쇄조치, 식품위생법 제79조의 영업소폐쇄조치 등이 있다.

Ⅳ. 직접강제의 한계

직접강제는 행정상 강제집행수단 중에서 국민의 기본권을 가장 크게 제약하는 것이기 때문에 다른 강제집행수단으로 의무이행을 강제할 수 없을 때 최후의 수단으로 인정되어야 한다.

또한 직접강제는 비례의 원칙 및 적법절차의 원칙에 따라 보다 엄격한 절차법적 실체법적 통제가 가해져야 한다.[50] 특히 주거의 자유 또는 신체의 자유에 대한 제한을 수반하는 직접강제의 경우에는 적법절차의 원칙상 영장주의의 적용여부가 검토되어야 한다.

Ⅴ. 국민의 권리구제

1. 항고쟁송

⑴ 대상적격

직접강제는 권력적 사실행위로서 수인의무를 수반하는 바 항고쟁송의 대상인 처분의 개념에 해당한다는 것이 다수설과 판례이다.

⑵ 협의의 소익

직접강제가 이미 완료된 이후에는 직접강제가 위법한 것이라는 이유로 손해배상이나 원상회복 등을 청구하는 것은 별론으로 하고 직접강제취소나 무효확인을 구할 소의 이익이 없다. 따라서 직접강제에 대한 취소소송을 제기함과 동시에 집행정지신청을 하여 직접강제가 완료되는 것을 막을 필요가 있다.

2. 국가배상청구소송

3. 결과제거청구권

제4 행정상 강제징수

Ⅰ. 의의

행정상의 강제징수라 함은 행정법상의 금전급부의무가 이행되지 아니한 경우에, 의무자의 재산에 실력을 가함으로써 그 의무가 이행된 것과 동일한 상태를 실현하는 작용을 말한다.

Ⅱ. 근 거

행정상의 강제징수의 일반법적 지위를 가진 법률로 국제징수법이 있다.

---

50) 박균성, 전게서, 348면.

Ⅲ. 절 차

1. 독촉

⑴ 의의

국세를 납부기한까지 완납하지 아니하는 납세의무자에 대하여는 세무서장은 납부기한이 경과 후 10일 내에 독촉장을 발급하여야 한다(국세징수법 제23조 제1항 본문).

⑵ 법적 성질 - 준법률행위적 행정행위로서 통지

2. 체납처분

⑴ 재산의 압류

납세의무자가 독촉절차에서 지정한 기한까지 납부의무를 불이행하면 납세의무자의 재산을 압류할 수 있다(국세징수법 제24조 제1항).

이 압류는 의무자 재산의 법률상 처분(증여, 매매, 교환 등)과 사실상 처분(소비, 파괴 등)을 금지하고 의무자의 재산을 확보하는 강제적인 보전행위로서 권력적 사실행위로서 항고소송의 대상인 처분에 해당한다는 것이 다수설과 판례이다.

⑵ 공매

압류재산은 통화를 제외하고 공매에 의하여 매각하며, 공매는 입찰 또는 경매에 의하나(국세징수법 제67조), 수의계약에 의하는 경우도 있다(국세징수법 제62조).

공매는 공법상 대리로서 항고소송의 대상인 처분에 해당한다.

⑶ 청산

세무서장은 압류금전, 체납자 또는 제3채무자로부터 받은 금전, 압류재산의 매각대금, 교부청구로 받은 금전을 배분순위에 따라 배분하고, 그 잔여금이 있으면 체납자에게 지급한다(국세징수법 제80조·제81조).

Ⅳ. 행정상의 강제징수에 대한 불복

1. 행정쟁송

강제징수에 대하여 불복이 있는 자는 행정쟁송절차에 의하여 그 취소 또는 변경을 구할 수 있다. 다만, 행정쟁송절차 중 행정심판에 있어서는 행정심판법의 규정을 적용하지 아니하고(국세기본법 제56조 제1항), 국세기본법 제7장에서 규정한 특별한 절차에 의한다.

2. 하자의 승계

강재징수절차는 독촉·체납처분 등 4단계의 행위로 이루어지며 이들은 모두가 결합하여 1개의 법률효과를 완성하는 관계에 있으므로 하자의 승계가 인정된다.

그러나 강제징수의 전제가 되는 조세부과처분의 하자는 독촉이나 체납처분의 하자로 승계되지 않는다(다수설, 판례).

제5 행정상 즉시강제

Ⅰ. 의 의

행정상 즉시강제란 급박한 행정상의 장해를 제거할 필요가 있는 경우에 미리 의무를 명할 시간적 여부가 없을 때 또는 성질상 의무를 명하여 가지고는 목적달성이 곤란할 때에 즉시 국민의 신체 또는 재산에 실력을 가하여 행정상 필요한 상태를 실현하는 행정작용을 말한다.

Ⅱ. 법적성질 - 권력적 사실행위

Ⅲ. 법적근거

종래에는 경찰긴급권이론에 의해 경찰상 긴급한 상태에 있어서는 법적 근거 없이도 행정상 즉시강제가 가능하다고 보았지만 법치주의가 확립된 오늘날에는 행정상 즉시강제에는 법적 근거가 필요하다고 보고 있다.

경찰관에 행하는 행정상 즉시강제에 대해선 일반법으로 경찰관직무집행법이 있다. 그 밖에도 많은 개별법에 근거규정이 있다.

Ⅳ. 행정상 즉시강제의 한계

1. 법규상의 한계

2. 행정법의 일반원칙상의 한계

행정상 즉시강제는 법규의 테두리 안에서도 그 목적을 위하여 필요한 최소한도 내에서 행사되어야 하며 이를 남용해서는 안되는 행정법의 일반원칙상의 한계에 기속된다.

행정상 즉시강제는 행정상의 장해가 목전에 급박하였을 것, 적극적인 행정목적을 위해서 발동되어서는 아니 되고 소극적으로 공공의 안녕 질서를 유지하기 위한 것이어야 하며, 구체적인 상황으로 보아 다른 수단으로써는 당해 행정목적을 달성할 수 없는 경우이어야 하고, 즉시강제권을 발동해야 할 경우에도, 행정상 즉시강제와 행정상 필요사이에 정당한 균형이 유지되어야 한다.

V. 행정상 즉시강제와 영장주의 - 헌법 제12조, 제16조 위반여부

1. 서

헌법 제12조, 제16조는 형사사법절차로서 신체구금 및 주거수색시 원칙적으로 법관이 발부하는 영장에 의하도록 하고 있다. 그런데 신체구금이나 주거수색을 하는 즉시강제에도 헌법상 영장주의가 적용되는지에 대해 학설의 대립이 있다.

2. 학설

① 헌법상의 영장제도는 본래 형사사법절차에만 적용된다는 영장불요설, ② 영장제도의 취지인 기본권 보장을 위해서 행정상 즉시강제에도 영장제도가 적용된다는 영장필요설, ③ 원칙적으로는 적용되나 긴급한 필요 등 영장 없는 즉시강제를 인정하여야 할 합리적 이유가 존재하는 경우에는 영장주의가 적용되지 않는다는 절충설 등이 대립한다.

3. 판례

대법원은 사전영장주의를 적용하면 행정목적을 달성할 수 없는 예외적인 경우에는 영장주의의 예외를 인정할 수 있다는 입장이다. 헌법재판소는 게임물 등의 영장없는 수거는 급박한 상황에 대처하기 위한 것으로서 영장주의에 위배되지 않는다고 판시하였다(2000헌가12).

Ⅵ. 행정상 즉시강제에 대한 구제

1. 적법한 즉시강제에 대한 구제

2. 위법한 즉시강제에 대한 구제

⑴ 항고쟁송

1) 처분성인정여부 - 권력적 사실행위

2) 협의의 소익 - 단기간 완료되어 협의의 소익 흠결로 각하될 염려있음

⑵ 국가배상청구소송

⑶ 결과제거청구권

3. 인신구속을 야기하는 즉시강제에 대한 구제 - 인신보호법

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 행정상 강제징수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 독촉은 반드시 문서(독촉장)로 하여야 하며, 원칙적으로 납부기한 경과 후 10일 내에 발부하여야 한다.

② 압류 후 부과처분의 근거법률이 위헌으로 결정된 경우에 압류처분은 취소사유가 있는 것이 되므로 압류를 해제하여야 할 것이다.

③ 한국자산관리공사가 체납압류한 재산의 공매처분에 대한 소송에서 피고는 세무서장이 아니라 한국자산관리공사이다.

④ 선행행위인 조세 등 부과처분이 무효이거나 취소되어 그 효력을 상실한 경우에도 후행행위인 체납처분이 당연무효가 되는 것은 아니다.

⑤ 행정상 강제징수란 사인이 국가 또는 지방자치단체 등에 대해 부담하고 있는 공법상 금전급부의무를 이행하지 아니한 경우에 행정청이 강제적으로 그 의무가 이행된 것과 같은 상태를 실현하는 작용이다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 독촉은 의무자에 대하여 의무이행을 최고하고, 불이행시에 체납처분을 할 것을 예고하는 준법률행위적 행정행위로서의 의사의 통지행위이다. 독촉은 문서로 해야 하고, 국세를 그 납부기한까지 완납하지 아니한 때에는 세무서장·시장 또는 군수는 납기 경과 후 10일 내에 독촉장을 발부하여야 한다(국세징수법 제23조 제1항). 세무서장은 제2차 납세의무자가 체납액을 그 납부기한까지 완납하지 아니한 때에는 10일 내에 납부최고서를 발부하여야 한다(동조 제2항).

② 1999. 4. 29. 구「택지소유 상한에 관한 법률」(1998.9.19. 법률 제5571호로 폐지)에 대한 위헌결정의 취지에 따라 체납부담금에 대한 징수가 불가능하게 되어 압류처분을 해제함에 있어서는 국세징수법 제53조 제1항을 유추적용하여 압류를 해제하여야 할 것인바, 국세징수법 제53조 제1항 제1호는 압류의 필요적 해제사유로 '납부, 충당, 공매의 중지, 부과의 취소 기타의 사유로 압류의 필요가 없게 된 때'를 들고 있고, 여기에서의 납부·충당·공매의 중지·부과의 취소는 '압류의 필요가 없게 된 때'에 해당하는 사유를 예시적으로 열거한 것이라고 할 것이므로 '기타의 사유'는 위 법정사유와 같이 납세의무가 소멸되거나 혹은 체납처분을 하여도 체납세액에 충당할 잉여가망이 없게 된 경우는 물론 과세처분 및 그 체납처분 절차의 근거 법령에 대한 위헌결정으로 후속 체납처분을 진행할 수 없어 체납세액에 충당할 가망이 없게 되는 등으로 압류의 근거를 상실하거나 압류를 지속할 필요성이 없게 된 경우도 포함하는 의미라고 새겨야 한다(대판 2002.7.12, 2002두331).

③ 성업공사가 체납압류된 재산을 공매처분에 대한 취소 등의 항고소송을 제기함에 있어서는 수임청으로서 실제로 공매를 행한 성업공사를 피고로 하여야 하고, 위임청인 세무서장은 피고적격이 없다. 세무서장의 위임에 의하여 성업공사가 한 공매처분에 대하여 피고 지정을 잘못하여 피고적격이 없는 세무서장을 상대로 그 공매처분의 취소를 구하는 소송이 제기된 경우, 법원으로서는 석명권을 행사하여 피고를 성업공사로 경정하게 하여 소송을 진행하여야 한다(대판 1997.2.28, 96누1757).

④ 선행처분이 당연무효이거나 취소가 되어 소급적으로 무효가 되면 후행처분도 당연히 무효가 된다. 행정청의 원고에 대한 원상복구명령은 권한 없는 자의 처분으로 무효라고 할 것이고, 위 원상복구명령이 당연무효인 이상 후행처분인 계고처분의 효력에 당연히 영향을 미쳐 그 계고처분 역시 무효로 된다(대판 1996.6.28, 96누4374).

정답 ④

2. 즉시강제에 대한 설명으로 타당한 것은? (2001 관세사)

① 적법한 즉시강제일지라도 이로 인해 발생된 손실은 사회적 수인한도를 벗어나지 않는 경우라도 보상되어야 한다.

② 소방기본법상 화재건물 인근의 연소위험건물에 대한 강제처분은 즉시강제에 해당한다.

③ 즉시강제는 목전의 긴급한 행정상 장해를 제거하는 것인 만큼 법률상의 근거가 없어도 허용된다.

④ 즉시강제에는 보충성의 원칙이 적용되지 않는다.

⑤ 즉시강제가 비록 위법하더라도 공권력 행사에 해당되기 때문에 이에 정당방위는 인정되지 않는다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 손실보상은 사회적 수인한도를 벗어나 특별한 희생을 침해당한 경우에만 인정된다.

② 화재가 발생한 소방대상물 및 그 토지에 대한 소방상 필요한 처분은 소방기본법 제25조에 의한 대물적 즉시강제에 해당한다.

③ 행정상 즉시강제의 이론적 근거를 독일에서는 특히 경찰행정의 분야를 중심으로 국가의 긴급권 이론에 두었다. 그러나 오늘날의 법치국가에서는 국민의 기본권에 중대한 침해를 가하는 행정상 즉시강제는 자연법적 근거만으로는 합리화할 수 없는 것으로 엄격한 실정법적 근거를 가져야 한다.

④ 즉시강제는 국민의 재산이나 신체에 대해서도 실력행사가 가능하기 때문에 침해정도가 큰 강제수단이므로, 다른 수단으로는 행정목적을 달성할 수 없는 경우에 보충적으로만 행사해야 한다.

⑤ 위법한 공권력행사에 대해서는 복종의무가 없기 때문에 정당방위가 가능하다. 위법한 즉시강제에 저항하는 것은 공무집행방해죄를 구성하지 않는다는 것이 판례의 입장이다(대판 1992.2.11, 91도2797).

정답 ②

3. 다음 중 행정상 즉시강제로 볼 수 없는 것은?

① 전염병 환자의 강제격리
② 경찰관직무집행법에 의한 무기 사용
③ 유해식품의 수거 및 폐기조치
④ 불법 입국한 외국인의 강제출국 조치
⑤ 경찰관이 길을 잃은 어린이를 파출소에 보호하는 행위

해설 & 정답

유형 법률지식형

③ 어떤 식품이 유해한지 여부를 알아보기 위해 수거하였다면 행정조사에 해당하고, 유해한 식품으로 이미 판명된 음식물을 수거・폐기한 경우는 즉시강제에 해당한다.

④ 직접강제에 해당한다.

⑤ 보호조치로서 대인적 즉시강제에 해당한다. 보호조치는 자기 또는 타인의 생명・신체와 재산에 위해를 미칠 우려가 있는 자에 대해 그 위해를 방지하기 위하여 잠정적으로 신체의 자유를 제한하는 조치를 말한다.

경찰관은 수상한 거동 기타 주위의 사정을 합리적으로 판단하여 ⅰ) 정신착란 또는 술취한 상태로 인하여 자기 또는 타인의 생명・신체와 재산에 위해를 미칠 우려가 있는 자와 자살을 기도하는 자, ⅱ) 미아・병자・부상자 등으로서 적당한 보호자가 없으며 응급의 구호를 요한다고 인정되는 자(다만, 당해인이 이를 거절하는 경우에는 예외로 한다)에 해당함이 명백하며 응급의 구호를 요한다고 믿을 만한 상당한 이유가 있는 자를 발견한 때에는 보건의료기관 또는 공공구호기관에 긴급구호를 요청하거나 경찰관서에 보호하는 등 적당한 조치를 할 수 있다(경찰관직무집행법 제4조 제1항).

cf. 경찰관직무집행법 제3조의 불심검문은 대인적 행정조사로 보는 견해가 통설이고, 즉시강제로 보는 견해는 소수설이다.

정답 ④

♣ 학습내용 정리

1. 행정상 강제집행수단으로 대집행, 직접강제, 이행강제금, 강제징수가 있다.
2. 행정상 즉시강제는 공법상 의무불이행을 전제로 하지 않고 공익상 장애를 신속하게 제거하기 위한 활동이다.

제23강 새로운 실효성확보수단 및 행정절차

♣ 학습목표

공법상 의무불이행시 새로운 실효성확보수단으로서 과징금, 공표, 관허사업제한을 이해하고 이에 대한 구제수단을 설명할 수 있다.

행정절차법의 근거 및 적용범위에 대하여 이해하고 처분절차를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

새로운 실효성확보수단

행정절차 개관

♣ 사전테스트

1. 과징금은 법적 근거없이 부과할 수 있다.
   정답 : X

2. 공표는 법적 근거없이 할 수 있다.
   정답 : x

3. 행정절차의 헌법적 근거는 헌법 제12조의 적법절차원칙이다.
   정답 : O

♣ 돌발퀴즈

과징금의 부과와 행정벌의 부과는 병과할 수 없다.

[정답] ×

[해설] 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에서 형사처벌과 아울러 과징금의 부과처분을 할 수 있도록 규정하고 있다 하더라도 이중처벌금지원칙이나 무죄추정원칙에 위반된다거나 사법권이나 재판청구권을 침해한다고 볼 수 없고, 또한 같은 법 제55조의3 제1항에 정한 각 사유를 참착하여 부당지원행위의 불법의 정도에 비례하여 상당한 금액의 범위 내에서만 과징금을 부과할 수 있도록 하고 있음에 비추어 비례원칙에 반한다고 할 수도 없다(대판 2004.4.9, 2001두6197).

♣ 강의내용

제1 과징금

1. 과징금의 의의

일반적으로 과징금이란 행정법상 의무를 불이행하였거나 위반한 자에 대하여 당해 위반행위로 얻은 경제적 이익을 박탈하기 위하여 부과하거나 또는 사업의 취소나 정지처분에 갈음하여 부과되는 금전상의 제재를 말한다. 과징금은 형벌이 아니다.

2. 과징금과 부과금의 구별

부과금은 실무상 대표적으로 환경보전법상의 배출부과금을 예로 들 수 있다.
즉, 배출허용기준을 초과하여 오염물질을 배출한 의무위반자에 대하여 부과되는 금전적 부담을 말한다. 과징금과 부과금의 관계에 대해서는 양자 사이에 실질적인 차이가 없다고 보는 견해도 있으나, 차이가 있다고 보는 견해도 존재한다.

차이가 있다고 보는 견해에 따르면, 과징금은 징수된 금액을 다른 행정목적을 위해서도 사용할 수 있는 반면, 부과금은 징수된 금액의 사용 용도가 해당 환경보전 목적에 한정된다는 점에서 구별된다. 즉, 부과금은 그 사용 목적이 특정되어 있다는 점에서 과징금과 차이가 있다고 본다.

3. 법적 근거 - 개별법적 근거 필요

과징금 부과처분은 상대방에게 과징금을 납부할 의무를 부과하는 행정처분이다. 따라서 그 법적 성질은 급부하명에 해당한다.

4. 과징금의 유형

⑴ 본래적 과징금

본래 과징금은 행정법상의 의무를 위반한 자에게 제재를 위하여 그리고 그러한 의무위반을 통해 경제적 이익이 발생한 경우 그 이익을 박탈하기 위하여 마련된 것이었다. 즉 부당이득환수 측면과 행정제재금의 성격을 모두 갖는 것이었다(독점규제및공정거래에관한법률상 과징금).

⑵ 변형적 과징금

근래에는 공공성이 강한 사업을 시행하는 자가 행정법규를 위반한 경우에 그 위반자에 대하여 의무위반을 이유로 그 인허가 사업 등에 대해 정지처분을 하게 되면 국민의 생활상의 불편이 야기될 것을 고려하여 이러한 정지처분에 갈음하여 사업을 계속하게 하되, 사업을 계속함으로써 얻는 이익을 박탈하는 변형된 형태의 과징금이 증가하고 있다.

단지 변형된 과징금 중 국민생활상의 불편야기와 관련없는 영업허가 등에 관하여 정지처분에 갈음하여 과징금을 입법적으로 도입한 것은 위헌이라는 견해가 있다.

5. 과징금의 법적 성격 - 급부하명
상대방한테 침입적 행정으로 당연히 법률의 근거가 필요합니다.

6. 과징금과 이중처벌금지의 원칙

대법원과 헌법재판소는 과징금과 행정벌을 동시에 규정한 것이 위헌이 아니라고 판시하였다(헌재 2012. 4. 24. 2011헌바62, 대판 2004. 4. 9. 2001두6197).

7. 구제수단

과징금의 부과행위는 행정행위에 해당하므로, 과징금의 부과가 위법한 경우에는 취소쟁송을 제기하여 그 취소 등을 구할 수 있고, 과징금의 부과가 취소되었거나 무효에 해당하는 경우 이미 납부한 과징금에 대하여 공법상 부당이득반환청구권을 행사할 수 있다.

제2 위반사실의 공표 - 명단공표

Ⅰ. 의 의

공표란 일정한 행정법상 의무위반이 있는 경우에 위반자의 성명, 위반사실 등을 불특정다수인이 알 수 있도록 공개함으로써 그 위반자의 명예 신용의 침해를 위협하여 행정법상의 의무이행을 간접적으로 강제하는 수단이다.

Ⅱ. 법적성질

① 공표는 그 자체로서는 아무런 법적 효과도 발생하지 아니하므로 비권력적 사실행위에 불과하다는 견해와 ② 공표는 행정기관에 의해 일방적으로 행해지며 그로 인하여 명예, 신용 또는 프라이버시권이 훼손되므로 권력적 사실행위로 보는 견해가 대립한다. ③ 생각건대 공표가 사람의 신체, 재산에 실력을 가하는 것이 아닌 바 권력적 사실행위로 보는 것은 문제가 있다. 결국 비권력적 사실행위로 보는 견해가 타당하다.

Ⅲ. 법적 근거

공표가 그 자체로는 직접 아무런 법적 효과를 발생하지 않는다 하더라도 사실상 관계자의 명예, 프라이버시, 신용 등에 중대한 영향을 미치므로 법령상의 근거를 요한다고 보아야 한다.

그런데 공표에 대한 일반법이 없는 바 개별법에 규정되어 있는 경우에만 공표를 할 수 있다.

Ⅳ. 명단공표의 한계

프라이버시권의 제한보다 큰 공공의 이익을 위해서 또는 국민의 알 권리 등의 보장을 위해서 불가피한 경우에는 공표가 허용된다고 할 것이나, 그것을 규율하는 법률은 헌법 제37조 제2항의 기본권제한입법의 한계를 준수하여야 한다. 즉 프라이버시권을 제한하는 입법은 사생활의 비밀과 자유의 보호법익인 인격의 자유로운 발현과 법적 안정성보다 작은 공공의 이익이 있을 때에는 허용되지 않으며, 개인의 프라이버시권의 '핵심영역'을 침해하는 것도 허용되지 않는다.

공표는 법의 우위의 원칙에 따라 법에 적합하게 행사하여야 하는 법규상의 한계 내에서 허용된다.

Ⅴ. 명단공표에 대한 구제

1. 항고쟁송

행정청의 별도의 공표결정없이 행해지는 공표행위는 그 자체로서는 아무런 법적 효과도 발생하지 아니하는 비권력적 사실행위이다. 따라서 비권력적 사실행위를 행정소송법 제2조 제1항 제1호의 "그 밖에 이에 준하는 작용"에 포함시킬 것인가에 따라 항고쟁송의 대상이 될 수 있는가가 결정될 것이다.

생각건대, 비권력적 사실행위에 대한 권리구제의 방법으로 항고소송이 유일한 길이 아니라 국가배상청구권이나 공법상 결과제거청구권을 통해서도 권리구제가 가능함에도 불구하고, 행정행위를 중심으로 형성된 처분의 개념에 이질적인 요소를 인위적으로 포함시킬 이유가 없다고 생각한다. 따라서 처분의 개념 속에 순수한 사실행위인 공표를 포함시킬 이론상의 이유도 실체상의 이유도 없다 할 것이다. 따라서 공표는 처분성을 인정할 수 없다.

다만 위와같은 공표를 권력적 사실행위로 보아 처분성을 인정하여 항고쟁송을 제기할 수 있다는 견해가 있다(박균성교수님).

2. 손해배상

위법한 공표행위에 의하여 명예 신용 등이 침해된 경우에는 행정상 손해배상청구소송을 제기하여 그 손해의 배상을 구할 수 있을 것이다. 특히 잘못된 사실의 공표행위의 위법성조각사유와 관련하여 대법원은 일반적인 명예훼손의 위법성조각사유인 상당성의 판단기준을 좀 더 엄격하게 판단하고 있다.

3. 결과제거청구권

공표로 인하여 훼손된 명예 또는 신용을 회복하기 위하여 공법상 결과제거청구권을 행사할 수 있다. 다만, 현행법 하에서는 민법 제764조에 근거하여 정정공표와 같은 명예회복에 적당한 행위를 청구할 수 있다.

제3 관허사업의 제한

Ⅰ. 서

1. 의의

관허사업제한이란 행정법상 의무위반자에 대하여 인가, 허가, 면허, 등록 등을 거부하거나 이미 받은 허가 등을 정지, 철회함으로써 위반자에게 불이익을 가하여 행정법상 의무이행을 간접적으로 확보하는 수단을 말한다.

2. 종류

관허사업의 제한에는 의무위반사항과 관련이 있는 사업에 대한 것(건축법 제79조 제2항)과 의무위반사항과 관련이 없는 사업 일반에 대한 것(국세징수법 제7조)이 있다.

Ⅱ. 법적 성질

관허사업의 제한은 의무불이행에 대한 제재적 처분의 성격과 의무이행확보수단으로의 성격을 동시에 지닌다.

Ⅲ. 법적 근거

관허사업제한은 권익침해의 효과를 가져오므로 법률유보의 원칙상 명문의 근거가 있어야 한다. 이에 대한 일반법적 근거는 없으며, 각 개별법에 근거가 있다.

Ⅳ. 법적 한계

특히 국세징수법 제7조의 위헌성에 대하여 ① 국세징수법 제7조는 의무위반내용과 직접적인 관련이 없는 사업 자체를 방해하는 것이므로 부당결부금지원칙에 반하는 것으로 위헌이라는 견해, ② 부당결부금지원칙을 헌법적 원칙이 아닌 법률적 원칙에 불과하다고 보아 국세징수법 제7조가 합헌이라는 견해, ③ 부당결부금지원칙을 헌법적 원칙으로 보더라도 국세징수법 제7조는 국가재정의 안정을 위해 입법정책상 불가피한 최소한을 규정하고 있는 것으로 보아야 할 것이므로 합헌이라는 견해가 대립한다.

Ⅴ. 권리구제수단

1. 관허사업제한 요청에 대하여

① 행정기관 내부간의 행위에 불과하므로 처분성을 부정하는 견해와 ② 요청행위를 받은 당해 행정청 정당한 사유가 없는 한 무조건 따르게 되어 있으므로 처분성을 긍정하는 견해가 대립한다. ③ 판례는 부정설의 입장이다.

2. 요청에 따른 허가 등의 거부나 허가취소, 정지처분에 대하여

각 처분성이 인정되므로 항고쟁송을 제기할 수 있으며 위법한 허가 등의 거부나 허가취소 등으로 손해가 발생한 경우 국가배상청구소송을 제기할 수 있다.

제4 행정절차 개설

Ⅰ. 서

1. 의 의

광의로는 행정기관이 행정활동을 함에 있어 거치는 사전과 사후의 모든 절차, 협의로는 사전절차를 말한다.

2. 필요성

행정은 여러 가지 절차를 거치고 국민의 의견 수렴 절차를 거치게 됨으로써 더욱 신중하게 이루어질 수 있다. 또한 국민의 의견 수렴 절차를 통해 행정의 민주화가 이루어질 수 있다. 따라서 이러한 절차는 행정의 민주화가 필요하다.

3. 헌법적 근거

⑴ 적법절차의 원칙의 의의

적법절차라 함은 “개인의 생명 자유와 재산을 보장하기 위해 국가권력의 자의적 행사를 금지하는 자유와 정의의 일반원칙으로서 이들 가치를 제한하는 경우에는 적정한 법의 절차를 거쳐 행함으로써 궁극적으로 인간의 존엄성을 실현하기 위한 법의 지배의 기본원칙”을 말한다. 이러한 적법절차의 원칙은 헌법 제12조 제1항 제2문과 동조 제3항에 규정되어 있다.

⑵ 적법절차의 원칙과 행정절차 - 적용됨

4. 법률

행정절차법, 민원사무처리에관한법률, 그리고 개별법률은 상호 특별법과 일반법의 관계에 놓인다. 따라서 민원사무라면 개별법률 → 민원사무처리에관한법률 → 행정절차법의 순으로 적용되고, 민원사무가 아니라면 개별법률 → 행정절차법의 순으로 적용된다.

Ⅱ. 행정절차법

1. 행정절차법의 기본구조 및 특징

2. 통칙적 규정

⑴ 목 적(동법 제1조).

⑵ 적용범위 및 적용제외사항

1) 적용범위

행정절차법은 동법이 규율하는 사항으로서의 처분, 신고, 행정상 입법예고, 행정예고 및 행정지도에 관한 일반법으로서 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 이 법이 적용된다(동법 제3조 제1항) 행정절차법은 행정절차에 관한 일반법이므로, 이에 관한 특별법이 있는 경우에는 그 법이 우선하여 적용되는 것임은 물론이다.

2) 적용제외사항(행정절차법 제3조 제2항)

⑶ 신의성실 및 신뢰보호(동법 제4조)

행정절차법에서 신의성실과 신회보호 원칙에 규정하고 있다.

⑷ 투명성원칙과 법령해석요청권(동법 제5조)

⑸ 행정청의 관할(동법 제6조)

⑹ 행정청간의 협조의무 및 행정응원(동법 제7조, 제8조)

⑺ 행정절차의 '당사자 등'(동법 제9조 내지 제13조)

행정절차법상 '당사자 등'이라 함은 행정청의 처분에 대하여 직접 그 상대가 되는 당사자와 행정청이 직권 또는 신청에 의하여 행정절차에 참여하게 한 이해관계인을 말한다.(동법 제2조 제4호)

⑻ 송달(동법 제14조, 제15조)

Ⅲ. 처분절차

1. 공통절차 및 공통사항

⑴ 처분기준의 설정 공표(동법 제20조)

불이익 처분이든 신청을 요한 처분이든 상관없이 예외 사유의 행정절차법에 규정되어 있는 예외사유에 해당하지 않는 한 모든 처분에 대해서 처분 기준을 미리 설정하고 처분을 해야한다.

⑵ 처분의 이유제시 : 상세한 내용은 후술

⑶ 처분의 방식 : 문서주의(동법 제24조).

예외 사유에 해당하지 않는 한 모든 처분은 문서로 하도록 되어있고 이메일 전자문서 할때는 상대방의 동의를 해야 한다.

⑷ 처분의 정정 : 동법 제25조

⑸ 행정심판관련사항의 고지 : 동법 제26조

행정청이 처분을 할 때에는 당사자에게 그 처분에 관하여 행정심판 및 행정소송을 제기할 수 있는지 여부, 그 밖에 불복을 할 수 있는지 여부, 청구절차 및 청구기간, 그 밖에 필요한 사항을 알려야 한다.

2. 신청에 의한 처분의 절차[51)]

⑴ 처분의 신청(동법 제17조)

⑵ 처리기간의 설정공표(동법 제19조)

제5 이유부기

Ⅰ. 서 설

1. 의의
행정청이 행정처분을 하면서 당해 처분의 사실적 법적 이유를 구체적으로 명시하도록 하는 것을 말한다(행정절차법 제23조).

2. 기능
첫째 자기통제기능, 둘째 국민의 권리구제기능, 셋째 설득기능

Ⅱ. 법적 근거 - 행정절차법 제23조

Ⅲ. 내 용

1. 이유부기의 대상 - 모든 처분, 단 예외있음
단지 23조에서 신속을 요하거나 경미한 처분 당사자의 신청을 모두 인용하는 처분 같은 경우에는 이유부기를 안 거쳐도 된다.

2. 이유부기의 방식 - 문서
처분 방식과 마찬가지로 문서로 하는게 타당하고 이유부기는 당연히 처분시 이다.
처분시 때문에 처분 당시에는 이유부기를 안했는데 나중에 이유부기라는 것은 하자 치유 문제가 나오는 것이지 그 이유부기 하자가 없는 것은 아니다.

3. 이유부기의 시기 - 처분시

4. 이유부기의 정도
행정절차법 제23조는 처분의 근거와 이유를 제시하도록 할 뿐 이유부기의 정도에 대한 언급이 없다. 따라서 이유부기의 정도에 대해서는 학설과 판례에 의존할 수밖에 없다.
법치행정의 요청상, 행정청은 우선 그 처분을 하게 된 법적 근거를 제시하여야 한다. 법적 근거로는 당해 처분의 발령근거가 된 구체적인 근거법령 및 개별조항, 철회권유보부 부관 등이 명시되어야 할 것이다. 다음으로 행정청이 사실의 확정 및 그 사실이 법령에 해당하는지의 여부를 포섭하는 과정이 제시되어야 할 것이다. 즉 구체적인 법령위반사실, 이러한 사실이 근거법령의 어떤 구성요건에 해당하는지 여부, 재량행위에 있어서는 행정청이 취한 관점, 구체적인 고려과정 등이 적시되어야 한다.
판례는 이유를 명시하도록 하는 취지는 행정청의 자의적 결정을 배제하고 이해관계인으로 하여금 행정구제절차에 적절히 대처할 수 있게 하기 위한 것이라며 구체적인 사실과 법적 근거를

51) 신청에 따른 처분절차에 관하여는 행정절차법보다 특별법인 민원사무처리에관한법률이 우선적으로 적용된다.

제시하여 한다고 하면서, “무면허업자에게 주류를 판매하여”라는 단순한 사실의 기재만으로는 처분의 이유제시로서 불충분하다고 한다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 과징금제도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 따름) (2009 국회8급)

① 위반행위에 대한 확정판결을 받지 않고도 과징금을 강제징수하는 것은 무죄추정의 원칙에 반하지 않는다.

② 위반행위로 인한 수익을 정확히 계산할 수 없는 경우에도 과징금제도가 인정되고 있다.

③ 과징금의 원래 취지는 위반행위의 경제적 인센티브를 제거하고자 하는 것이다.

④ 변형과징금의 1차적 목적은 영업정지처분을 받는 자에 대한 최소침해의 수단을 찾는 것이다.

⑤ 하나의 위반행위에 대해 과징금과 벌금을 병과하는 것은 이중처벌금지원칙에 반하지 않는다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

변형과징금이란 인허가사업 등의 정지처분에 갈음하여 부과되는 과징금을 말한다. 이는 공익사업의 중지로 인한 대중의 불편방지와 전과자 양산의 방지라는 관점에서 그 제도적 의의가 있는 것이지 사업자에 대한 최소침해원칙 때문에 인정되는 것이 아니다.

정답 ④

2. 다음 중 명단공표에 관한 설명이 타당하지 않은 것은?

① 명단의 공표는 그 자체로서 어떠한 법적 효과(관계인의 권리변동)도 발생하지 않는다는 점에서 법적 근거가 불필요하다고 볼 수도 있다.

② 명단의 공표가 상대방에 대하여 심각한 경제적 손실 내지 인권을 침해하는 경우는 법치행정의 원리상 법적 근거가 필요하다.

③ 고액체납자의 명단공개제는 국세징수법에 의하여 인정되고 있는 제도이다.

④ 국가기관이 행정목적의 달성을 위하여 언론에 보도자료를 제공하는 등 이른바 행정상 공표의 방법으로 실명을 공개함으로써 타인의 명예를 훼손한 경우, 그 공표된 사실의 내용이 진실이라는 증명이 없더라도 국가기관이 공표 당시 이를 진실이라고 믿었고 또 그렇게 믿을만한 상당한 이유가 있다면 위법성이 없다는 것이 판례의 입장이다.

⑤ 공표된 사실이 의심의 여지가 없이 확실히 진실이라고 믿을 만한 객관적이고도 타당한 확증과 근거가 있는 경우가 아니라면 위법성이 인정되지 않는 상당한 이유가 인정되지 않는다고 보는 것이 판례의 입장이다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

①② 명단공표는 직접적으로 아무런 법적 효과도 발생하지 아니하는 비권력적 사실행위이므로 별도의 법적 근거를 요하지 않는다는 견해도 존재한다. 그러나 명단공표는 현실적으로 행정상 제재 내지 의무이행확보수단으로서의 기능을 수행하며, 상대방의 인격권과 사생활 등의 기본권을 침해할 우려가 있으므로 법적 근가가 필요하다는 견해가 통설이다.

③ 종전에는 국세청 훈령인 국세징수사무처리규정 제66조에 의한 명단공표는 법적 근거가 없다는 점에서 비판을 받았으나, 현재에는 국세기본법 제85조의5에 법적 근거를 두고 있다.

④⑤ 대판 1993.11.26, 93다18389

정답 ③

3. 국세징수법 제7조에 의한 관허사업의 제한과 관련한 문제점을 검토함에 있어 가장 주목하여야 할 법원칙은? (2005 5급승진)

① 신뢰보호의 원칙 ② 행정의 자기구속의 원칙

③ 불이익변경금지의 원칙 ④ 권리남용금지의 원칙

⑤ 부당결부금지의 원칙

유형 법률지식형

이러한 규정은 매우 실효성 있는 강제수단이지만, 체납된 조세와 불허가 또는 취소·정지되는 사업과는 실질적인 관련성이 없다는 점에서 부당결부금지의 원칙과 관련하여 문제가 있다는 지적이 있다. 또한 조세체납 때문에 국민의 기본적인 생업자체를 위협한다는 점에서 비례원칙상의 문제가 제기된다.

정답 ⑤

♣ 학습내용 정리

1. 공법상 의무불이행시 새로운 실효성확보수단으로 과징금, 공표, 관허사업 제한 등이 있다.
2. 행정절차는 행정작용을 하기 전에 거쳐야 되는 절차로서 이에 대한 일반법으로 행정절차법이 있다.

제24강 행정절차

♣ 학습목표

행정절차로서 불이익처분절차인 사전통지, 의견제출기회부여, 청문, 공청회 등을 이해하고 절차상 하자의 효과에 대하여 설명할 수 있다.

정보공개청구권의 주체 및 대상에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

불이익처분절차

절차상 하자의 효과

정보공개 개관

♣ 사전테스트

1. 사전통지는 모든 처분 공통절차이다.
   정답 : X

2. 불이익처분시에는 반드시 청문절차를 거쳐야 한다.
   정답 : x

3. 절차상 하자만으로 행정행위의 위법성이 인정될 수 있다는 것이 판례의 입장이다.
   정답 : O

♣ 돌발퀴즈

판례에 따르면 행정청과 당사자 간 도시계획사업시행과 관련한 협약을 체결하면서 합의에 의하여 청문실시 등 의견청취절차를 배제하면 설사 청문실시에 관한 규정의 적용을 배제할 수 있다고 볼만한 법령상의 규정이 없더라도 예외적으로 청문을 실시하지 않아도 된다.

[정답] ×

[해설] 행정청이 당사자와 사이에 도시계획사업의 시행과 관련한 협약을 체결하면서 관계 법령 및 행정절차법에 규정된 청문의 실시 등 의견청취절차를 배제하는 조항을 두었다고 하더라도, 국민의 행정참여를 도모함으로써 행정의 공정성·투명성 및 신뢰성을 확보하고 국민의 권익을 보호한다는 행정절차법의 목적 및 청문제도의 취지 등에 비추어 볼 때, 위와 같은 협약의 체결로 청문의 실시에 관한 규정의 적용을 배제할 수 있다고 볼 만한 법령상의 규정이 없는 한, 이러한 협약이 체결되었다고 하여 청문의 실시에 관한 규정의 적용이 배제된다거나 청문을 실시하지 않아도 되는 예외적인 경우에 해당한다고 할 수 없다(대판 2004.7.8, 2002두8350).

♣ 강의내용

제1 불이익처분의 절차

1. 불이익처분의 의미

행정절차법은 당사자에게 '의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분'에 대하여만 사전통지, 의견제출기회의 부여 등 행정절차가 적용되는 것으로 규정하는 있다.

이러한 불이익 처분에 거부처분이 포함되는가와 관련하여

① 수익적 행정행위에 대한 거부처분은 실질적으로 신청인에게 불리하므로 이를 긍정하는 견해[52]도 있으나, ② 신청을 하였어도 아직 당사자에게 권익이 부여되지 아니하였으므로 신청을 거부하여도 직접 당사자의 권익을 제한하는 처분에 해당한다고 볼 수 없으므로 입법론으로는 신청거부처분을 불이익처분에 포함시키는 것이 타당할지 모르나 현행법의 해석론으로는 부정한다는 견해가 다수설과 판례(2003두674)이다.

또 불이익한 일반처분 및 처분상대방에게 이익이 되고 제3자에게 불이익이 되는 제3자효 행정행위도 포함되지 않는다.

2. 처분의 사전통지(행정절차법 제21조[53]).

행정청은 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우에는 일정한 사항을 당사자 등에게 통지하여야 한다(동법 제21조).

3. 의견제출기회부여(행정절차법 제22조 제3항)

의견제출은 "행정청이 어떠한 행정작용을 하기에 앞서 당사자 등이 의견을 제시하는 절차로서 청문이나 공청회에 해당하지 아니하는 절차"를 말한다.

---

52) 오준근,「행정절차법」, 339면

53) 제21조(처분의 사전 통지) ① 행정청은 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우에는 미리 다음 각 호의 사항을 당사자등에게 통지하여야 한다.

1. 처분의 제목
2. 당사자의 성명 또는 명칭과 주소
3. 처분하려는 원인이 되는 사실과 처분의 내용 및 법적 근거
4. 제3호에 대하여 의견을 제출할 수 있다는 뜻과 의견을 제출하지 아니하는 경우의 처리방법
5. 의견제출기관의 명칭과 주소
6. 의견제출기한
7. 그 밖에 필요한 사항

② 행정청은 청문을 하려면 청문이 시작되는 날부터 10일 전까지 제1항 각 호의 사항을 당사자등에게 통지하여야 한다. 이 경우 제1항제4호부터 제6호까지의 사항은 청문 주재자의 소속·직위 및 성명, 청문의 일시 및 장소, 청문에 응하지 아니하는 경우의 처리방법 등 청문에 필요한 사항으로 갈음한다.

③ 제1항제6호에 따른 기한은 의견제출에 필요한 상당한 기간을 고려하여 정하여야 한다.

④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 통지를 하지 아니할 수 있다.

1. 공공의 안전 또는 복리를 위하여 긴급히 처분을 할 필요가 있는 경우
2. 법령등에서 요구된 자격이 없거나 없어지게 되면 반드시 일정한 처분을 하여야 하는 경우에 그 자격이 없거나 없어지게 된 사실이 법원의 재판 등에 의하여 객관적으로 증명된 경우
3. 해당 처분의 성질상 의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요하다고 인정될 만한 상당한 이유가 있는 경우

⑤ 처분의 전제가 되는 사실이 법원의 재판 등에 의하여 객관적으로 증명된 경우 등 제4항에 따른 사전 통지를 하지 아니할 수 있는 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2014.1.28.>

⑥ 제4항에 따라 사전 통지를 하지 아니하는 경우 행정청은 처분을 할 때 당사자등에게 통지를 하지 아니한 사유를 알려야 한다. 다만, 신속한 처분이 필요한 경우에는 처분 후 그 사유를 알릴 수 있다. <신설 2014.12.30.>

⑦ 제6항에 따라 당사자등에게 알리는 경우에는 제24조를 준용한다. <신설 2014.12.30.>

당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분에 대하여 제3자가 이익을 받는 경우가 있는데 이 경우에는 행정절차법 제22조 제3항이 적용된다. 이에 따라 불이익을 받는 처분의 상대방에게는 의견제출의 기회가 주어진다.

4. 청문절차

⑴ 의 의

청문이라 함은 당사자 등의 의견을 들을 뿐만 아니라 증거를 조사하는 등 재판에 준하는 절차를 거쳐 행하는 의견진술절차를 말한다(행정절차법 제2조 제5호)

⑵ 필요적 절차인지 여부[54]

① 개별법에서 청문을 필요적 절차로 규정한 경우, ② 인허가 등의 취소, 신분·자격의 박탈, 법인이나 조합 등의 설립허가의 취소시 의견제출기한 내에 당사자등의 신청이 있는 경우에는 행정절차법 제22조 제4항이 예외사유에 해당하지 않는 한 청문을 반드시 실시하여야 한다.

⑶ 행정절차법상의 청문절차 (동법 제28조 내지 제37조)

⑷ 청문의 예외

행정절차법은 첫째 공공의 안전 또는 복리를 위하여 긴급히 처분을 할 필요가 있는 경우, 둘째 법령 등에서 요구된 자격이 없거나 없어지게 되면 반드시 일정한 처분을 하여야 하는 경우에 그 자격이 없거나 없어지게 된 사실이 법원의 재판 등에 의하여 객관적으로 증명된 때, 셋째 당해 처분의 성질상 의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요하다고 인정될만한 상당한 이유가 있는 경우 넷째, 당사자가 의견진술의 기회를 포기한다는 뜻을 명백히 표시한 경우에는 청문을 실시하지 아니할 수 있도록 하고 있다(동법 제22조 제4항, 제21조 제4항).

5. 공청회절차(동법 제22조 제2항)

공청회라 함은 “행정청이 공개적인 토론을 통하여 어떠한 행정작용에 대하여 당사자 등, 전문지식과 경험을 가진 자 기타 일반행정인으로부터 의견을 널리 수렴하는 절차”를 말한다(동법 제2조 제6호)

---

54) 제22조(의견청취) ① 행정청이 처분을 할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 청문을 한다.
1. 다른 법령등에서 청문을 하도록 규정하고 있는 경우
2. 행정청이 필요하다고 인정하는 경우
3. 다음 각 목의 처분 시 제21조제1항제6호에 따른 의견제출기한 내에 당사자등의 신청이 있는 경우
가. 인허가 등의 취소
나. 신분·자격의 박탈
다. 법인이나 조합 등의 설립허가의 취소
② 행정청이 처분을 할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 공청회를 개최한다.
1. 다른 법령등에서 공청회를 개최하도록 규정하고 있는 경우
2. 해당 처분의 영향이 광범위하여 널리 의견을 수렴할 필요가 있다고 행정청이 인정하는 경우
③ 행정청이 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 할 때 제1항 또는 제2항의 경우 외에는 당사자등에게 의견제출의 기회를 주어야 한다.
④ 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 제21조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우와 당사자가 의견진술의 기회를 포기한다는 뜻을 명백히 표시한 경우에는 의견청취를 하지 아니할 수 있다.
⑤ 행정청은 청문·공청회 또는 의견제출을 거쳤을 때에는 신속히 처분하여 해당 처분이 지연되지 아니하도록 하여야 한다.
⑥ 행정청은 처분 후 1년 이내에 당사자등이 요청하는 경우에는 청문·공청회 또는 의견제출을 위하여 제출받은 서류나 그 밖의 물건을 반환하여야 한다.

공청회절차는 다른 법령 등에서 공청회를 개최하도록 규정하고 있는 경우와 당해 처분의 영향이 광범위하여 널리 의견을 수렴할 필요가 있다고 행정청이 인정하는 경우에 한하여 예외적으로 인정되는 임의적 절차이다(동법 제22조 제2항)

공청회에 대한 구체적인 절차는 행정절차법 제38조, 제39조에서 규정하고 있다.

제2 절차상하자와 행정행위의 효력

1. 문제의 제기

절차상의 하자의 효력에 대하여 개별법에 명문규정이 있으면 그에 의해 해결하면 된다. 그러나 대부분 법률에서는 이러한 내용의 규정을 마련하고 있지 않다. 따라서 명문규정이 없는 경우 행정절차상의 하자에 어떠한 효과를 부여할 것인지에 대하여 학설이 대립하게 된다.

2. 절차상 하자의 독자적 위법사유 인정여부

⑴ 학 설

① 행정경제와 소송경제, 행정절차는 수단에 불과하다는 점 등을 이유로 절차상 하자를 독자적 위법사유로 인정하지 않는 소극설, ② 국민의 절차적 권리회복, 절차법규의 실효성 확보, 적법한 절차를 거쳐 재처분하는 경우 다른 내용의 처분이 나올 가능성도 있다는 점 등을 이유로 절차상 하자가 행정행위의 독자적 위법사유가 된다는 적극설, ③ 기속행위인 경우에는 독자적 위법사유가 아니나 재량행위인 경우에는 독자적 위법사유로 보는 절충설, ④ 구체적 상황, 하자정도, 적법절차로 인한 다른 결정가능성 등 여러 사정을 고려하여 개별적으로 판단하자는 개별적 검토설 등이 대립한다.

⑵ 판 례

판례는 이유부기의 하자만을 이유로 행정행위의 취소를 구할 수 있다고 판시하여 절차상 하자를 행정행위의 독자적 위법사유로 보고 있다.

3. 절차상 하자의 위법성의 정도

무효인지 취소인지에 대한 통설과 판례의 견해인 중대명백설에 따라 절차상 하자로 인하여 행정행위 자체의 하자가 중대하고 명백한 것인가에 따라 결정해야 할 것이다.

4. 절차상 하자의 치유가능성과 치유시기 - 자세한 내용은 전술 하자의 치유 참조

5. 절차상 하자와 반복금지효- 후술

최소판결이 확정되면 행정청은 그 취소판결에서 판단한 사실과 동일한 사실 관계에서 동일한 위법 사유로 동일인에게 동일한 처분을 하지 말아야 할 효력이 발생한다. 이게 취소학적 판결의 기속력 이다.

제3 정보공개 개관

Ⅰ. 정보공개청구권의 관념

1. 의 의

정보공개청구권이란 사인이 공공기관에 대하여 정보를 제공해 줄 것을 요구할 수 있는 개인적 공권을 말한다.

2. 법적 근거

⑴ 헌법 - 알권리
헌법상 자유권적 기본권의 하나인 이 알권리가 대표적인 정보공개 청구권 헌법적 근거가 된다. 알권리의 헌법적 근거에 대해서 여러가지 견해가 있지만 헌법재판소에 입장은 헌법 제21조 표현의 자유 언론 출판의 자유를 근거로 해서 인정하고 있는 입장이다.

⑵ 법률 - 공공기관의 정보공개에 관한 법률(이하 '정보공개법'이라 한다)이 일반법
다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 정보공개법이 일반법으로서 적용된다(정보공개법 제4조 제1항). 또 정보공개법은 지방자치단체는 그 소관사무에 관하여 법령의 범위안에서 정보공개에 관한 조례를 정할 수 있다고 규정하고 있다(정보공개법 제4조 제2항). 다만, 국가안전보장에 관련되는 정보 및 보안업무를 관장하는 기관에서 국가안전보장과 관련된 정보분석을 목적으로 수집되거나 작성된 정보에 대해서는 적용되지 아니한다(정보공개법 제4조 3항). 한편, 정보공개청구권과 관련된 규정을 갖는 개별 법률도 없지 않다.

Ⅱ. 정보공개청구권의 주체·대상

1. 정보공개청구권자 - 모든 국민(정보공개법 제5조)
정보공개청구권은 법률상 보호되는 구체적인 권리이므로 청구인이 공공기관에 대하여 정보공개를 청구하였다가 거부처분을 받은 것 자체가 법률상 이익의 침해에 해당한다고 할 것이고(대법원 2003. 12. 12. 선고 2003두8050 판결 참조), 거부처분을 받은 것 이외에 추가로 어떤 법률상의 이익을 가질 것을 요구하는 것은 아니다(대법원 2004.09.23. 선고 2003두1370 판결)

2. 공개대상정보
정보공개청구권의 행사의 대상이 되는 정보는 공공기관이 보유 ·관리하고 있는 각종 정보를 말한다(정보공개법 제3조).
여기서 "공공기관"이라 함은 국가기관, 지방자치단체, 정부투자기관관리기본법 제2조의 규정에 의한 정부투자기관 그 밖에 대통령령이 정하는 기관을 말한다(정보공개법 제2조 3호). 국가에는 당연히 정부 외에 국회와 법원 등 모든 국가기관이 포함되며 대통령령이 정하는 기관으로는 사립대학교도 포함된다.
정보란 "정보"라 함은 공공기관이 직무상 작성 또는 취득하여 관리하고 있는 문서(전자문서를 포함한다. 이하 같다)·도면·사진·필름·테이프·슬라이드 및 그 밖에 이에 준하는 매체 등에 기록된 사항"을 말한다(정보공개법 제2조 1호).
"공개"라 함은 공공기관이 이 법의 규정에 의하여 정보를 열람하게 하거나 그 사본·복제물을 교부하는 것 또는 「전자정부법」 제2조 제10호의 규정에 의한 정보통신망(이하 "정보통신망"이라 한다)을 통하여 정보를 제공하는 것 등을 말한다(정보공개법 제2조 제2호)

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 행정청이 당사자에게 의무를 과하거나 권리를 제한하는 처분을 하는 경우에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 처분하고자 하는 원인이 되는 사실과 처분의 내용을 통지해야 한다.

② 처분에 대해 의견을 제출할 수 있다는 뜻과 의견을 제출하지 아니하는 경우의 처리방법을 통지해야 한다.

③ 판례는 '교원임용거부처분청구사건'에서 신청에 대한 거부처분은 사전통지대상이 된다고 보지 않았다.

④ 공공의 안전 또는 복리를 위하여 긴급히 처분을 할 필요가 있는 경우에는 사전통지를 생략할 수 있다.

⑤ 사전통지의무가 면제되는 경우라도 의견청취는 반드시 실시해야 한다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

①② 행정절차법 제21조 제1항 제3호・제4호

③ 신청에 따른 처분이 이루어지지 아니한 경우에는 아직 당사자에게 권익이 부과되지 아니하였으므로, 특별한 사정이 없는 한 신청에 대한 거부처분이라고 하더라도 직접 당사자의 권익을 제한하는 것은 아니어서 신청에 대한 거부처분을 여기에서 말하는 '당사자의 권익을 제한하는 처분'에 해당한다고 할 수 없는 것이어서 처분의 사전통지대상이 된다고 할 수 없다(대판 2003.11.28, 2003두674).

④ 동법 제21조 제4항 제1호

⑤ 사전통지의 예외사유는 동시에 의견청취의 예외사유에도 해당하기 때문에 예외사유에 해당할 경우 의견청취를 실시하지 않아도 된다(동법 제22조 제4항).

정답 ⑤

2. 행정절차법상의 의견청취절차에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 의견청취절차는 청문, 공청회, 의견제출로 나누어진다.

② 행정청이 당사자에게 의무를 과하거나 권익을 제한하는 처분을 할 경우, 다른 법률에 특별한 규정이 없으면 청문을 거쳐야 한다.

③ 판례는 법령상 확정된 의무부과의 경우에 의견제출의 기회를 주어야 하는 것은 아니라고 본다.

④ 불이익처분의 상대방은 처분 전에 자기 의견을 제출할 수 있다.

⑤ 의견청취절차를 거치지 않은 불이익처분은 그 하자를 이유로 취소할 수 있다고 보는 것이 판례의 주류적 태도라 할 수 있다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

② 행정절차법은 행정청이 처분을 함에 있어서 다른 법령 등에서 청문을 실시하도록 규정하고 있는 경우, 행정청이 필요하다고 인정하는 경우에만 청문을 실시한다고 규정함으로써(제22조 제1항), 즉 법령의 규정이 없더라도 행정청이 필요 없다고 생각할 경우 청문을 실시하지 아니할 수 있다.

③ 퇴직연금의 환수결정은 당사자에게 의무를 과하는 처분이기는 하나, 관련법령에 따라 당연히 환수금액이 정하여지는 것이므로, 퇴직연금의 환수결정에 앞서 당사자에게 의견진술의 기회를 주지 아니하여도 행정절차법 제22조 제3항이나 신의칙에 어긋나지 아니한다(대판 2000.11.28, 99두5443).

정답 ②

3. 다음 중 청문절차에 관한 설명으로 타당하지 아니한 것은? (2001 입법고시)

① 청문은 행정청이 소속직원 또는 일정한 자격을 가진 자 중에서 선정하는 자가 주재한다.

② 행정청은 청문을 실시하고자 하는 경우에 청문이 시작되는 날부터 10일 전까지 일정한 사항을 당사자 등에게 통지하여야 한다.
③ 문서의 열람 또는 복사의 요청이 있는 경우 행정청은 공익을 이유로 이를 거부할 수 있다.
④ 행정청은 청문을 마친 후 처분을 하기까지 새로운 사정이 발견되어 청문을 재개할 필요가 있다고 인정하는 때에는 청문의 재개를 명할 수 있다.
⑤ 청문주재자는 당사자 등이 의견서를 제출하지 아니하는 경우에는 이들에게 다시 의견진술 및 증거제출의 기회를 주지 아니하고 청문을 마칠 수 있다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 행정절차법 제28조 제1항
② 동법 제21조 제2항
③ 행정청은 다른 법령에 의하여 공개가 제한되는 경우를 제외하고는 문서의 열람 또는 복사를 거부할 수 없다(동법 제37조 제1항).
④ 동법 제36조
⑤ 동법 제35조 제2항

정답 ③

♣ 학습내용 정리

1. 불이익처분절차로서 행정절차법은 사전통지, 청문, 공청회, 의견제출기회부여를 규정하였다.
2. 절차상 하자만으로 행정행위의 위법성이 인정된다는 것이 판례입장이다.
3. 정보공개청구권은 헌법상 알권리에 근거한다.

제25강 정보공개

♣ 학습목표

비공개정보에 대하여 이해하고 정보공개절차 및 정보공개와 관련된 권리구제수단에 대하여 설명할 수 있다.

행정구제에 있어 사전구제와 사후구제를 구별하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

정보공개절차 및 권리구제수단

행정구제 개관

♣ 사전테스트

1. 비공개정보에 해당한 정보는 무조건 공개가 금지된다.

   정답 : X

2. 비공개결정에 대하여 의무이행소송을 제기할 수 있다.

   정답 : x

3. 비공개결정에 대하여 이의신청을 할 수 있다.

   정답 : O

♣ 돌발퀴즈

공공기관에서 직무상 취득하여 관리하고 있는 문서 중 공무원이 아닌 개인이 작성한 문서는「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에서 말하는 '정보'가 아니다.

[정답] ×

[해설] 정보라 함은 공공기관이 직무상 작성 또는 취득하여 관리하고 있는 문서(전자문서를 포함)·도면·사진·필름·테이프·슬라이드 및 그 밖에 이에 준하는 매체 등에 기록된 사항을 말한다(동법 제2조 제1호). 따라서 직무상 작성한 문서만이 아니라 누가 작성했든 공공기관이 관리하고 있는 문서도 포함된다.

♣ 강의내용

제1 비공개대상정보(정보공개법 제9조 제1항[55] 각호) 및 정보공개절차

1. 비공개정보

⑴ 다른 법률 또는 법률이 위임한 명령(국회규칙·대법원규칙·헌법재판소규칙·중앙선거관리위원회규칙·대통령령 및 조례에 한한다)에 의하여 비밀 또는 비공개 사항으로 규정된 정보

⑵ 국가안전보장·국방·통일·외교관계 등에 관한 사항으로서 공개될 경우 국가의 중대한 이익을 현저히 해할 우려가 있다고 인정되는 정보

⑶ 공개될 경우 국민의 생명·신체 및 재산의 보호에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다고 인정되는 정보

⑷ 진행중인 재판에 관련된 정보와 범죄의 예방, 수사, 공소의 제기 및 유지, 형의 집행, 교정, 보안처분에 관한 사항으로서 공개될 경우 그 직무수행을 현저히 곤란하게 하거나 형사피고인의 공정한 재판을 받을 권리를 침해한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보

⑸ 감사·감독·검사·시험·규제·입찰계약·기술개발·인사관리·의사결정과정 또는 내부검토과정에 있는 사항 등으로서 공개될 경우 업무의 공정한 수행이나 연구·개발에 현저한 지장을 초래한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보

⑹ 당해 정보에 포함되어 있는 이름·주민등록번호 등 개인에 관한 사항으로서 공개될 경우 개인의 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보. 다만, 다음에 열거한 개인에 관한 정보는 제외한다.

가. 법령이 정하는 바에 따라 열람할 수 있는 정보

나. 공공기관이 공표를 목적으로 작성하거나 취득한 정보로서 개인의 사생활의 비밀과 자유를 부당하게 침해하지 않는 정보

다. 공공기관이 작성하거나 취득한 정보로서 공개하는 것이 공익 또는 개인의 권리구제를 위하여 필요하다고 인정되는 정보

라. 직무를 수행한 공무원의 성명·직위

마. 공개하는 것이 공익을 위하여 필요한 경우로써 법령에 의하여 국가 또는 지방자치단체가 업무의 일부를 위탁 또는 위촉한 개인의 성명·직업

⑺ 법인·단체 또는 개인(이하 "법인등"이라 한다)의 경영·영업상 비밀에 관한 사항으로서 공개될 경우 법인등의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 있다고 인정되는 정보. 다만, 다음에 열거한 정보를 제외한다.

가. 사업활동에 의하여 발생하는 위해로부터 사람의 생명·신체 또는 건강을 보호하기 위하여 공개할 필요가 있는 정보

나. 위법·부당한 사업활동으로부터 국민의 재산 또는 생활을 보호하기 위하여 공개할 필요가 있는 정보

---

55) 제9조 (비공개대상정보) ①공공기관이 보유·관리하는 정보는 공개대상이 된다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 정보에 대하여는 이를 공개하지 아니할 수 있다.

⑻ 공개될 경우 부동산 투기·매점매석 등으로 특정인에게 이익 또는 불이익을 줄 우려가 있다고 인정되는 정보

Ⅱ. 정보공개절차

1. 정보공개청구(정보공개법 제10조 제1항)
원칙적으로 문서로 할수도 있고 말로 할 수도 있다.

2. 정보공개여부의 결정(정보공개법 제11조)
공공기관의 정보공개의 청구를 받은 날로부터 10일이내에 공개여부를 결정하여야 한다. 단 10일을 연장할 수 있다.
공공기관은 공개청구된 공개대상 정보의 전부 또는 일부가 제3자와 관련이 있다고 인정되는 때에는 그 사실을 제3자에게 지체없이 통보하여야 하며, 필요한 경우에는 그의 의견을 청취할 수 있다(정보공개법 제11조 제3항)

3. 정보공개여부의 결정의 통지(정보공개법 제13조)
정보공개 방법은 부분 공개를 할 수 있다. 전체 정보 중에 일부분은 비공개 이고 일부분은 비공개가 아니다. 일부분만 부분 공개할수 있고 전자적 공개 이메일을 공개할 수도 있다.

4. 정보공개의 방법(정보공개법 제14조, 제15조) - 부분공개, 전자적공개

5. 비용부담(정보공개법 제17조)

제2 권리구제수단

1. 비공개결정에 대한 청구인의 불복절차

⑴ 이의신청(정보공개법 제18조).
A가 정보공개청구를 하였으나 행정청 또는 공공기관이 정보공개를 거부하여 비공개결정을 하거나, 정보공개청구에 대하여 아무런 응답을 하지 않는 부작위를 한 경우를 생각해 보자. 이러한 경우 정보공개법상 권리구제수단으로는 원칙적으로 정보공개를 청구받은 해당 공공기관에 대하여 다시 한번 재검토를 요청하는 의미에서, 정보공개법 제18조에 따른 이의신청을 할 수 있다.

⑵ 행정심판(정보공개법 제19조) - 거부처분취소심판, 의무이행심판
거부나 부작위에 대해서 정보공개법상 19조에 보면 행정심판법상 행정심판을 제기할 수 있다. 거부나 부작위에 대해서는 모두 의무이행심판 제기할 수 있고 거부처분에 대해서는 거부처분 취소심판을 제기 할 수 있다.

⑶ 행정소송
청구인이 정보공개와 관련한 공공기관의 결정에 대하여 불복이 있는 때에는 행정소송법이 정하는 바에 따라 행정소송을 제기할 수 있다(정보공개법 제20조 제1항). 이 때 정보공개청구소송은 무명항고소송으로 의무이행소송을 인정하지 않는 현행 행정소송법에 의하면 정보공개청구에 대한 거부처분취소소송과 부작위위법확인소송의 형태로 제기될 것이다.

1) 대상적격

정보공개거부처분은 당연히 처분성을 갖는다(헌재 2001. 2. 22, 2000헌마620). 판례는 거부처분의 처분성이 인정되기 위해서는 신청인에게 법규상 또는 조리상 신청권이 있어야 한다는 입장이고 이를 지지하는 견해도 있다. 그러나 신청권은 원고적격의 문제라는 견해도 있다. 어쨌든 판례의 입장에 따른다 하더라도 정보공개법 제5조 제1항이 정보공개청구권을 명시적으로 인정하고 있기 때문에 법규상 모든 국민에게 정보공개결정을 신청할 권리가 인정됨은 당연하기 때문이다.

2) 원고적격

정보공개법 제5조 제1항에 따라 모든 국민은 정보공개청구권을 가지므로 정보공개를 청구한 자는 공개청구된 정보에 대해 이해관계가 있는지 여부를 묻지 않고 모두 원고적격을 갖는다(대판 2007. 6. 1, 2007두2555).

3) 협의의 소익

대법원은 정보공개제도는 공공기관이 보유 관리하는 정보를 그 상태대로 공개하는 제도라는 점에 비추어 정보공개청구를 거부하는 처분이 있은 후 대상정보가 폐기되었다든가 하여 공공기관이 그 정보를 보유 관리하지 않게 된 경우에는 특별한 사정이 없는 한 정보공개거부처분의 취소를 구할 법률상 이익이 없다고 하였다(대판 2003. 4. 25, 2000두7087).

4) 행정심판전치주의

정보공개와 관련된 행정소송의 제기에 행정심판을 반드시 먼저 거쳐야 하는 것은 아니다. 왜냐하면 정보공개법 필요적 심판전치를 규정하고 있지 않기 때문이다.

⑷ 가구제

1) 거부처분에 대한 집행정지 가능여부

어느 견해에 의하더라도 신청의 이익이 없으므로 불가

2) 민사집행법상 가처분준용여부

다수설과 판례에 따라 불가.

3) 행정심판법상의 가구제로서 임시처분가능여부(행정심판법 제31조)

정보공개거부처분으로 인해 당사자가 받을 우려가 있는 중대한 불이익이나 급박한 위험이 없는 바 임시처분도 불가할 것이다.

2. 정보공개에 대하여 이해관계있는 제3자의 권리보호

⑴ 정보공개법상의 보호수단

1) 아직 정보공개결정이 내려지지 않은 경우

① 공개청구된 사실의 통보 및 비공개요청권

공개대상정보(전부 또는 일부불문)와 관련이 있다고 인정되어 공개청구된 사실을 통지받은 제3자는 통지받은 날부터 3일 이내에 당해 공공기관에 공개하지 아니할 것을 요청할 수 있다(정보공개법 제21조 제1항).

② 무명항고소송으로 예방적 부작위소송 - 다수설, 판례는 부정(후술)

③ 민사집행법상 예방적 금지 가처분준용여부 - 다수설, 판례는 부정(후술)

2) 정보공개결정을 내린 후 아직 정보공개가 되기 전 권리구제수단 및 인용가능성

① 이의신청(정보공개법 제21조 제3항).

정보공개법 21조 처분청인 공공기관에 정보공개 결정은 직권취소하고 정보공개를 하지 말아달라고 이의신청 공공기관한테 다시한번 생각해 봐 달라 이의신청 할수 있다.

② 행정심판 - 정보공개결정에 대한 취소심판 제기 할수 있다.

③ 행정소송 - 정보공개결정에 대한 취소소송
단 원고적격충족여부와 관련하여 정보공개결정의 직접 상대방이 아닌 제3자가 행정소송법 제12조의 법률상 이익이 있는지가 문제된다.

④ 가구제 - 정보공개결정에 대한 집행정지
그러나 이의신청, 취소심판, 취소소송을 제기하더라도 본안판결에서 승소하기 전에 위 정보가 공개되는 경우에는 그것이 실질적 구제가 되지 아니함은 물론이다. 따라서 공개결정에 대한 집행정지가 실효적인 권리구제수단이 될 수 있다(행정소송법 제23조, 행정심판법 제21조).

3) 정보공개가 된 경우
이 경우에는 취소소송을 제기할 협의의 소익이 없는 바 국가배상만 가능

제3 행정구제 개관

Ⅰ. 행정구제의 의의
행정구제란 행정작용으로 자기의 권리·이익이 침해되었거나 침해될 것으로 주장하는 자가 행정기관이나 법원에 손해전보·원상회복 또는 당해 행정작용의 취소·변경을 청구하거나 기타 피해구제 또는 예방을 청구하고, 이에 대해 행정기관 또는 법원이 심리하여 권리·이익보호에 관한 판정을 내리는 것을 말한다.
행정구제제도는 헌법상 국민의 기본권보장과 실질적 법치주의의 관점에서 법치주의 원리의 실효성을 담보하기 위해 필요 불가결한 것이다.

Ⅱ. 행정구제제도의 개관

1. 사전구제제도

⑴ 행정절차
⑵ 청 원

2. 사후구제제도

⑴ 행정상 손해전보(공법작용으로 인해 발생한 금전적 피해에 대한 가치보장)

1) 행정상 손해배상

① 공무원의 위법한 직무행위로 인한 손해배상

② 영조물의 설치·관리의 하자로 인한 손해배상

2) 행정상 손실보상(적법한 공권력에 의한 손실의 전보)

⑵ 행정쟁송 : 위법한 공법작용으로 공권을 침해받은 국민의 공권회복을 위한 존속보장

1) 행정심판 : 행정심판법상 처분 및 부작위에 대한 취소심판, 무효등확인심판, 의무이행심판

2) 행정소송 : 항고소송, 당사자소송, 민중소송, 기관소송

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」상의 정보공개청구절차에 관한 내용으로 옳은 것은?

① 정보의 공개를 청구하는 자는 당해 정보를 보유하거나 관리하고 있는 공공기관에 대하여 공개를 청구하는 정보의 내용 및 공개방법을 기재한 정보공개청구서를 제출하거나 구술로써 정보의 공개를 청구할 수 있으며, 정보공개청구권자의 인적사항은 익명을 원칙으로 한다.

② 공공기관은 공개청구된 공개대상정보의 전부 또는 일부가 제3자와 관련이 있다고 인정되는 때에는 그 사실을 제3자에게 지체 없이 통지하여야 하며, 필요한 경우에는 그의 의견을 청취할 수 있다.

③ 공공기관은 전자적 형태로 보유·관리하는 정보에 대하여 청구인이 전자적 형태로 공개하여 줄 것을 요청하더라도 이를 출력한 형태로 공개하는 것이 원칙이다.

④ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에는 부분공개제도가 채택되어 있지 않아, 비공개대상정보에 해당하는 부분과 공개가 가능한 부분을 분리할 수 있는 경우에도 부분공개는 허용되지 않는다.

⑤ 정보공개의무를 지는 공공기관의 하나로 사립대학교를 들고 있는 구 정보공개법 시행령 제2조 제1호는 모법의 위임 범위를 벗어나 위법하다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 정보의 공개를 청구하는 자는 당해 정보를 보유하거나 관리하고 있는 공공기관에 대하여 청구인의 이름·주민등록번호·주소 및 연락처, 공개를 청구하는 정보의 내용 및 공개방법을 기재한 정보공개청구서를 제출하거나 구술로써 정보의 공개를 청구할 수 있다(공공기관의정보공개에 관한법률 제10조 제1항). 따라서 이름·주민등록번호 등의 인적 사항을 기재하여야 한다.

② 동법 제11조 제3항

③ 전자적 형태로 보유하고 있느냐 아니냐에 따라 내용이 다르다. 공공기관은 전자적 형태로 보유·관리하는 정보에 대하여 청구인이 전자적 형태로 공개하여 줄 것을 요청하는 경우에는 당해 정보의 성질상 현저히 곤란한 경우를 제외하고는 청구인의 요청에 응하여야 한다(동법 제15조 제1항). 전자적 형태로 보유·관리하지 아니하는 정보에 대하여 청구인이 전자적 형태로 공개하여 줄 것을 요청한 경우에는 정상적인 업무수행에 현저한 지장을 초래하거나 당해정보의 성질이 훼손될 우려가 없는 한 그 정보를 전자적 형태로 변환하여 공개할 수 있다(동조 제2항).

④ 공개청구한 정보가 비공개대상정보에 해당하는 부분과 공개가 가능한 부분이 혼합되어 있는 경우로서 공개청구의 취지에 어긋나지 아니하는 범위 안에서 두 부분을 분리할 수 있는 때에는 비공개대상정보를 제외하고 공개하여야 한다(동법 제14조).

⑤ 정보공개 의무기관을 정하는 것은 입법자의 입법형성권에 속하고, 이에 따라 입법자는 구 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제2조 제3호에서 정보공개 의무기관을 공공기관으로 정하였는바, 공공기관은 국가기관에 한정되는 것이 아니라 지방자치단체, 정부투자기관, 그 밖에 공동체 전체의 이익에 중요한 역할이나 기능을 수행하는 기관도 포함되는 것으로 해석되고, 여기에

정보공개의 목적, 교육의 공공성 및 공·사립학교의 동질성, 사립대학교에 대한 국가의 재정지원 및 보조 등 여러 사정을 고려해 보면, 사립대학교에 대한 국비 지원이 한정적·일시적·국부적이라는 점을 고려하더라도, 같은 법 시행령 제2조 제1호가 정보공개의무를 지는 공공기관의 하나로 사립대학교를 들고 있는 것이 모법인 구 공공기관의 정보공개에 관한 법률의 위임범위를 벗어났다거나 사립대학교가 국비의 지원을 받는 범위 내에서만 공공기관의 성격을 가진다고 볼 수 없다(대판 2006.8.24, 2004두2783).

정답 ②

2. 공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 관한 다음의 내용 중 옳지 않은 것은? (2006 국회8급)

① "모든 국민은 정보의 공개를 청구할 권리를 가진다."라고 동법은 규정하고 있는데, 여기에서 말하는 국민에는 자연인은 물론 법인, 권리능력 없는 사단·재단도 포함되고, 법인, 권리능력 없는 사단·재단 등의 경우에는 설립목적을 불문한다.

② 외국인도 법령이 정하고 있는 일정한 범위 내의 자인 경우에 정보공개를 청구할 수 있다.

③ 공공기관은 정보공개의 청구가 있는 때에는 청구를 받은 날부터 10일 이내에 공개 여부를 결정해야 한다.

④ 사법시험 제2차 시험의 답안지 열람은 사법시험업무의 수행에 현저한 지장을 초래한다고 인정할 만한 정보에 해당하므로 동법에서 정한 비공개대상정보에 해당한다.

⑤ 청구인이 정보공개와 관련한 공공기관의 결정에 대하여 불복이 있는 때에는 이의신청, 행정심판 및 행정소송을 제기할 수 있다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

①② 공공기관의정보공개에관한법률 제5조 제1항·제2항 참조

③ 동법 제11조 제1항

④ 답안지를 열람하도록 할 경우 업무의 증가가 다소 있을 것으로 예상되고, 다른 논술형 시험의 열람 여부에도 영향이 있는 등 파급효과로 인하여 시험업무의 수행에 다소 지장을 초래한다고 볼 수 있기는 하지만, 답안지는 응시자의 시험문제에 대한 답안이 기재되어 있을 뿐 평가자의 평가기준이나 평가결과가 반영되어 있는 것은 아니므로 응시자가 자신의 답안지를 열람한다고 하더라도 시험문항에 대한 채점위원별 채점결과가 열람되는 경우와 달리 평가자가 시험에 대한 평가업무를 수행함에 있어서 지장을 초래할 가능성이 적은 점 등을 종합적으로 고려하면, 답안지의 열람으로 인하여 시험업무의 수행에 현저한 지장을 초래한다고 볼 수 없다(대판 2003.3.14, 2000두6114).

⑤ 동법 제18조·제19조·제20조

정답 ④

3. 정보공개제도에 관한 기술 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

㉠ 정부투자기관관리기본법 제2조의 규정에 의한 정부투자기관은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」상의 정보공개의무를 진다.

㉡ 정보의 공개 및 우송 등에 소요되는 비용은 행정청의 부담으로 한다.

㉢ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」상의 비공개대상정보라 하더라도 비공개의 필요성이 없어진 경우에는 당해 정보를 공개대상으로 할 수 있다.

㉣ 오손 또는 파손의 우려가 있거나 그 밖에 상당한 이유가 있다고 인정될 때에는 당해 정보의 사본·복제물을 공개할 수도 있다.

㉤ 정보공개청구인이 정보공개와 관련하여 공공기관의 처분 또는 부작위로 인해 불복이 있는 때에는 당해 공공기관에 이의신청을 할 수 있다.

① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢, ㉣

③ ㉠, ㉣, ㉤ ④ ㉡, ㉢, ㉣

⑤ ㉡, ㉣

해설 & 정답

유형 법률지식형

㉠ [○] 공공기관의정보공개에관한법률 제2조 제3호

㉡ [×] 정보의 공개 및 우송 등에 소요되는 비용은 실비의 범위 안에서 청구인의 부담으로 한다(동법 제17조 제1항).

㉢ [×]「공공기관의 정보공개에 관한 법률」상의 비공개대상정보라 하더라도 비공개의 필요성이 없어진 경우에는 당해 정보를 공개대상으로 하여야 한다(동법 제9조 제2항).

㉣ [○] 동법 제13조 제3항

㉤ [○] 동법 제18조 제1항

정답 ③

♣ 학습내용 정리

1. 비공개정보는 정보공개법 제9조 제1항 각 호로 규정되어 있다..
2. 정보공개법상 권리구제수단으로는 이의신청, 행정심판, 행정소송이 규정되어 있다.
3. 행정구제에는 사후적 구제로서 행정상 손해전보와 행정쟁송이 있다.

제26강 국가배상개관 및 제2조 책임

♣ 학습목표

국가배상법 제2조 제1항 본문 전단의 과실책임의 성립요건에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

국가배상 개관

국가배상법 제2조 책임의 성립요건

♣ 사전테스트

1. 국가배상청구권은 공권이라는 것이 판례의 입장이다.
   정답 : X

2. 국가배상법보다 민법이 특별법으로 우선 적용된다.
   정답 : x

3. 국가배상법상의 공무원은 널리 공무에 종사하는 모든 자를 의미한다.
   정답 : O

♣ 돌발퀴즈

판례는 공무원의 행위의 외관을 객관적으로 보아 직무행위라 보여질 때는 실질적 직무행위 여부 또는 행위자의 주관적 의사와 무관하게 직무집행이라 본다.

[정답] ○

[해설] 국가배상법 제2조 제1항의 "직무를 집행함에 당하여"라 함은 직접 공무원의 직무집행행위이거나 그와 밀접한 관계에 있는 행위를 포함하고, 이를 판단함에 있어서는 행위 자체의 외관을 객관적으로 관찰하여 공무원의 직무행위로 보여질 때에는 비록 그것이 실질적으로 직무행위가 아니거나 또는 행위자로서는 주관적으로 공무집행의 의사가 없었다고 하더라도 그 행위는 공무원이 "직무를 집행함에 당하여"한 것으로 보아야 한다(대판 1995.4.21, 93다14240).

♣ 강의내용

제1 개설

Ⅰ. 의 의

행정상 손해배상제도는 국가 또는 공공단체의 위법한 활동에 의하여 개인에게 가하여진 손해를 전보하여 주는 제도이다.

Ⅱ. 우리나라의 행정상 손해배상제도

1. 헌법적 근거 - 헌법 제29조

헌법 29조에 의해서 인정되는 헌법상 기본권 임과 동시에 일반적으로 규정된 일반법은 국가배상법에서 인정되고 있다.

2. 국가배상법

⑴ 국가배상법의 지위(국가배상법 제8조)

국가배상책임에 대한 법조는 특별법 → 국가배상법 → 민법이 순으로 적용된다.

⑵ 국가배상법의 성격

1) 학 설 - 사법설과 공법설 대립

2) 판 례

판례는 국가배상소송을 민사소송으로 처리함으로써 사법설을 따르고 있다(대판 1971. 4. 6, 70다2955).

제2 공무원의 위법한 직무행위로 인한 손해배상

Ⅰ. 의의 - 국가배상법 제2조 제1항 본문 전단

Ⅱ. 배상책임의 성립요건

1. 공무원

국가배상법 제2조상의 '공무원'은 국가공무원법 또는 지방공무원법의 공무원뿐만 아니라 널리 공무를 위탁받아 실질적으로 공무에 종사하는 모든 자를 포함한다는 데 학설은 일치하고 있고, 판례도 그러하다(대판 2001. 1. 5, 98다39060).

2. 직무행위

⑴ 직무행위의 범위 - 광의설 : 모든 공법작용을 의미

⑵ 부작위

부작위의 책임이 성립되려면 먼저 당연히 국고작용 사법작용 대한 국가배상 책임의 성립 요건이 충족될 수 없으니까, 공법 작용의 부작위어야 한다

⑶ 입법행위

판례 - 과실이 없다고 보는게 아니라 위헌인 법률을 제정하는 국회의원의 제정 행위와 관련해서 국회의와 어떤 입법 제정권 등 을 이유로 국회의원들이 굳이 헌법의 문헌에 명백히 위반됨에도 불구하고, 위헌인 법률을 제정한 경우가 아닌 이상은 국회의원들의 위헌인 법률을 제정하는데 있어 어떤 직무상 의무 위반이 없으니 법령 위반이 인정되지 않는다고 해서 국가배상책임을 부정한다.

⑷ 사법작용

국가배상소송을 제기 했을때 과연 인정될 수 있는가 했을때 대법원 판례는 법관의 어떤 재방행위에 대해서는 상급심이 불복 할 수 있는 수단이 있다는 점에서 법관이 부당한 목적을 갖고 판결하는 등 어떤 특별한 사류가 없는 이상 법관이 법에 어긋나는 판결했다는 것만으로는 법령위반이 인정되지 않으므로 국가배상 책임이 인정되지 않는다고 보고 있다.

3. 집행하면서

국가배상청구권의 성립요건으로서 '집행하면서'는 직무행위 자체는 물론 직무행위와 직·간접적인 관련이 있는 행위를 포함하는 것으로 본다. 이에 통설과 판례는 '직무를 집행하면서'의 판단에 있어 직무를 수행하는 공무원의 주관적 의사와 상관없이 직무행위의 외형에 따라 결정되는 것이라는 객관설(외형설)을 취하고 있다. 따라서 통설과 판례에 의하면 직무집행행위뿐만 아니라 실질적으로 직무집행행위가 아니더라도 외형상 직무행위로 보여질 때에는 '직무를 집행함에 당하여 한 행위'로 본다.

4. 법령에 위반하여

⑴ 법령위반의 개념

공무원의 행위는 법령에 위반한 것이어야 한다. 이러한 법령위반의 의미에 대해 견해의 대립이 있다.

1) 학설

① 결과위법성설

이 견해는 국가배상책임의 성립요건으로서의 위법성을 가해행위의 결과인 손해의 불법을 의미하는 것으로 본다. 이에 따라 위법성 판단은 국민이 받은 손해가 결과적으로 수인되어야 할 것인가의 여부가 기준이 된다.

② 행위위법성설

(가) 협의의 행위위법성설

이 견해는 국가배상책임의 성립요건으로서의 위법성을 취소소송의 소송물로서의 위법성과 마찬가지로 행위 자체의 협의의 법규 위반으로 파악한다.

(나) 광의의 행위위법성설

이 견해는 국가배상법상의 위법을 행위 자체의 법에 위반뿐만 아니라 명문의 규정이 없더라도 공권력 행사의 근거법규 및 각 행정분야에서의 자연법적 객관적 법질서를 종합적으로 고려할 때 인정되는 공무원의 '직무상 일반적 손해방지의무'의 위반을 포함하는 개념으로 이해하는 견해이다.

③ 상대적 위법성설

국가배상법상의 위법개념을 행위자체의 위법뿐만 아니라 피침해이익의 성격과 침해의 정도 등 결과와 가해행위의 태양 등을 종합적으로 고려하여 행위가 객관적인 정당성을 결한 경우를 의미한다고 보는 견해이다.

④ 직무의무위반설

국가배상법상의 위법을 공무원의 직무의무의 위반으로 보는 견해이다.

2) 판 례

판례는 "그 행정처분의 담당공무원이 보통 일반의 공무원을 표준으로 하여 볼 때 객관적 주의의무를 결하여(과실) 그 행정처분이 객관적 정당성을 상실하였다고 인정될 정도(위법성)에 이른 경우에 국가배상법 제2조 소정의 국가배상책임의 요건을 충족하였다고 봄이 상당할 것이며" 라고 판시하여 상대적 위법성설을 취한 듯한 판례도 보이나,

행정적인 내부규칙위반을 법령위반으로 보지 않아 협의의 행위위법설을 취한 듯한 판례도 있고,

공무원의 직무상 의무위반을 법령위반으로 보아 광의의 행위위법설이나 직무상 의무위반설를 취한 듯한 판례도 보인다.

⑶ 국가배상책임의 성립요건과 관련하여 관련법규의 사익보호성 필요여부

1) 서

국가배상책임의 성립요건에 대하여 규정한 국가배상법 제2조 제1항 본문은 관련법규의 사익보호성을 규정하지 않았다.

다만, 판례는 후술하는 바와 같이 국가배상책임을 일정범위에서 제한하기 위하여 사익보호성이 있는 법령위반의 경우에만 국가배상책임을 인정하고 사익보호성이 없는 법령위반의 경우에는 국가배상책임을 부정하는 바, 이러한 판례의 태도가 타당한지 및 사익보호성을 어느 요건충족여부에 대해서 판단할 것인지에 대하여 검토할 필요가 있다.

2) 사익보호성이 국가배상책임성립에 요구되는지

① 국가배상책임성립에 사익보호성이 필요하다는 견해

② 국가배상책임성립에 사익보호성이 필요없다는 견해

③ 판 례

판례는 직무상 의무위반으로 인한 국가배상책임이 인정되려면 당해 직무상 의무가 공익뿐만 아니라 국민 개개인의 이익을 보호목적으로 하고 있어야 한다고 한다.

노래연습장의 시설 및 영업 일체를 양수한 후 구 풍속영업의규제에관한법률의 규정에 따라 영업주 명의변경을 위하여 경찰서장에게 풍속영업변경신고서를 제출하였으나, 위 노래연습장 건물에 이미 속셈학원과 컴퓨터학원이 있다는 것이 발견되어 전(전) 영업주의 풍속영업신고서 수

리행위가 잘못된 것으로 밝혀지자 경찰서장이 위 변경신고서를 반려한 경우, 위 근거법률에 사익보호성이 인정되지 않는 바, 경찰서장이 전 영업주의 영업신고서를 잘못 수리한 행위나 이를 즉시 시정하지 않은 행위와 영업변경신고서가 반려됨으로써 양수인이 입은 영업상 손해사이에 상당인과관계가 없다고 한 사례(대판 2001. 4. 13, 2000다34891).

유흥주점에 감금된 채 윤락을 강요받으며 생활하던 여종업원들이 유흥주점에 화재가 났을 때 미처 피신하지 못하고 유독가스에 질식해 사망한 사안에서, 식품위생법상 여러 규정들이 사익보호성이 인정되지 않아 지방자치단체의 담당 공무원이 식품위생법상 취하여야 할 조치를 게을리한 직무상 의무위반행위와 위 사망의 결과 사이의 상당인과관계를 인정되지 않으나, 소방법의 사익보호성은 인정되는 바, 소방공무원이 위 화재 전 유흥주점에 대하여 소방법상 시정조치를 명하지 않은 직무상 의무 위반과 위 사망의 결과 사이의 상당인과관계를 인정한 판례(대판 2008. 4. 10, 2005다48994).

⑷ 선결문제로서의 위법성 판단

당해 처분 행정행위에 대해서 취소소송 권한 있는 기관이 취소하지도 않았는데 권한 없는 소송 맡은 법원이 당해 행정행위의 법령 위반을 심의하는 것이 행정위의 공정력 또는 구성 요건 효력에 반하느냐 했을때 공정력과 구성요건 효력은 유효성 추정이라고 한다. 원한 없는 소송을 맡은 민사법원도 또는 당사자 소송 법원으로 맡은 법원도 당해 행정행위의 위법 여부 법령 위반이 국가배상청구권이 인정되는가를 심의하는 것은 행정행위의 효력을 부인하는게 아니기 때문에 구성요건효력이나 공정력에 반하지 않으므로 심리가 가능하다는게 다수설과 판례이다.

⑸ 취소소송의 기판력과 국가배상청구소송의 선결관계

1) 문제점

A처분에 대해 갑이 제기한 취소소송에서 인용확정판결 또는 기각확정판결이 나온 후 갑이 후소로 국가배상청구소송을 제기한 경우 전소인 취소소송과 후소인 국가배상청구소송은 원피고가 동일하고, 사실심 변론종결시이후에 발생한 새로운 사유가 없는 바 기판력의 주관적 범위와 시적범위를 충족한다. 다만 객관적 범위충족여부와 관련하여 취소소송의 소송물인 처분의 위법성 일반, 즉 협의의 행위위법과 국가배상청구소송의 요건사실인 '법령위반'이 동일한 개념인가가 문제된다. 만약 동일한 개념으로 본다면 전소 소송물과 후소 요건사실이 동일한 바 기판력의 객관적 범위까지 충족하게 되어 기판력이 발생한다

2) 학설

- 전부 기판력 긍정설
- 제한적 기판력 긍정설
- 전면적 기판력 부정설

3) 판례

판례는 전면적 기판력 부정설의 입장을 취하는 것으로 보인다.

어떠한 행정처분이 후에 항고소송에서 취소되었다고 할지라도 그 기판력에 의하여 당해 행정처분이 곧바로 공무원의 고의 또는 과실로 인한 것으로서 불법행위를 구성한다고 단정할 수는 없는 것이고(대법원 2007. 5. 10. 선고 2005다31828 판결 등 참조).

5. 고의, 과실

⑴ 고의·과실의 의미

1) 서

고의란 일정한 결과가 발생하리라는 것을 인식하고 행위를 행하는 것을 말한다. 그런데 과실의 의미에 대해선 견해의 대립이 있다.

2) 학설

① 주관설(다수설)

주관설은 과실을 당해 직무를 담당하는 공무원이 통상 갖추어야 할 주의의무를 해태한 것을 의미한다고 한다. 그러나 위와같이 과실을 주관적 개념으로 파악하여 국가배상책임의 성립여부를 행위자의 주관적 요소에 따라 결정할 경우 피해자의 구제가 불완전하다는 지적이 제기되기 시작하였고 이러한 문제의 해결을 위하여 주관적 요소인 과실을 보다 객관화하거나 그 입증책임을 완화하려는 방안을 제시하고 있다. 그러한 방안으로 첫째 국가배상법상 과실의 의미를 형법상의 과실처럼 당해 공무원의 주관적 심리상태로 보지 않고 동일 직종에 종사하는 성실한 평균적인 공무원의 주의력을 표준으로 판단하고, 둘째 가해공무원의 특정을 불요하고, 셋째 입증책임의 완화로 일응추정이론 등이 있다.

② 객관설

객관설에서의 고의 과실은 공무원의 개인의 주관적인 책임요소가 아니라 국가 또는 지방자치단체의 자기책임을 결정하는데 필요한 '공무운영상의 객관적인 흠의 존재'라고 한다.

3) 판례

판례는 "행정처분의 담당공무원이 보통 일반의 공무원을 표준으로 하여 볼 때 객관적 주의의무를 결하여..."라고 판시하여 주관설을 취하고 있다.

⑵ 법령해석의 하자와 공무원의 과실 인정여부

1) 문제점

공무원이 법령해석을 잘못하여 위법한 행정처분을 한 경우에 과실을 인정할 수 있는가가 문제된다.

2) 과실을 인정한 판례 : 법령해석 및 실무 취급례가 귀일되어 있는 경(대판 1981. 8. 25, 80다1598)

3) 과실을 부정한 판례

① 행정규칙의 기준에 따른 행정처분이 재량권의 일탈남용을 이유로 행정쟁송에 의해 취소된 경우(대판 1994. 11. 8, 94다26141)

② 법령해석이 명백하지 않은 경우 발령된 행정처분이나 시행령이 대법원에 의해 위법판단을 받은 경우"(대판 1995. 10. 13, 95다32747)

⑶ 위헌인 법률 또는 법규명령에 근거한 처분에 대한 공무원의 과실 인정여부 - 전술한 입법행위 참조

6. 손해발생과 인과관계

국가배상책임이 성립하려면 공무원의 가해행위로 손해가 발생하여야 한다. 이때의 손해란 가해행위로 인한 법익침해로서, 적극적 손해, 소극적 손해, 위자료 등을 모두 포함한다. 또한 가해행위와 손해사이에 상당인과관계가 있어야 한다.

다만, 대법원은 관련법규의 사익보호성을 인과관계에서 판단하여 관련법규가 오로지 공익을 보호하고자 하는 취지인 경우 그러한 관련법규위반행위로 인한 손해에 대해선 국가배상책임을 부정하고 있다. 다만 이러한 판례에 대하여 판례는 사익보호성을 인과관계에서 판단하고 있다는 견해와 위법성에서 판단하고 있다는 견해가 대립하고 있다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 국가배상법 제2조의 '공무원의 위법한 직무집행행위로 인한 배상책임'의 성립요건에 대한 판례의 태도이다. 옳지 않은 것은? (2000 행정고시)

① 소집 중인 향토예비군은 공무원이다.

② 대법원의 일관된 태도는 직무행위를 권력작용과 관리작용(국가배상법 제5조의 영조물 관리작용은 제외) 및 사경제작용을 모두 포함하는 최광의설의 입장이다.

③ 乙병장이 자기와 상명하복관계에 있는 甲일등병에게 권유하여 공휴일에 공용 아닌 사용에 사용하기 위하여 관리책임장교 몰래 자동차를 꺼내어 사람을 동승시켜 온천장에 갔다 돌아오는 길에 소주를 마시게 하고 유흥하다가 사고로 乙 자신이 사망한 경우에 대법원은 국가의 배상책임을 인정하지 않았다.

④ 대법원은 '공무원의 직무상의 과실'을 공무원이 그 직무를 수행함에 있어 당해 직무를 담당하는 평균인이 보통 갖추어야 할 주의의무를 게을리 한 것으로 이해하고 있다.

⑤ 운전을 임무로 하지 않는 군인이 군복을 입고 군용차량을 불법운전한 경우에도 외형상 군무수행과 관련이 있는 것으로 보고 있다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 대판 1970.5.26, 70다471

② 판례는 광의설의 입장으로서 사경제작용은 포함하지 않고 있다. 국가배상법이 정한 손해배상청구의 요건인 '공무원의 직무'에는 국가나 지방자치단체의 권력적 작용뿐만 아니라 비권력적 작용도 포함되지만 단순한 사경제의 주체로서 하는 작용은 포함되지 않는다(대판 2004.4.9, 2002다10691). 결국 사경제의 주체로서 하는 작용은 민사소송으로 처리된다.

③ 대판 1966.3.22, 66다117

④ 대판 1987.9.22, 87다카1164

⑤ 대판 1967.11.21, 67다1304

정답 ②

2. 다음 중 현행 국가배상법에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 손해배상청구절차에 관하여 필요적 결정전치주의를 채택하고 있다.

② 생명·신체에 대한 침해와 물건의 멸실·훼손으로 인한 손해 외의 손해는 불법행위와 상당한 인과관계가 있는 범위에서 배상한다.

③ 향토예비군대원인 경우 손해배상청구권이 제한된다.

④ 생명·신체침해에 대한 배상청구권은 이를 양도하거나 압류하지 못한다.

⑤ 손해배상책임이 경과실인 경우에는 구상권을 행사할 수 없다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 국가배상법은 "이 법에 따른 손해배상의 소송은 배상심의회에 배상신청을 하지 아니하고도 이를 제기할 수 있다(제9조)"라고 하여, 행정상 손해배상청구절차에 관한 배상심의회의 결정을 임의적인 것으로 규정하고 있다.
② 동법 제3조 제4항
③ 동법 제2조 제1항 단서
④ 동법 제4조
⑤ 동법 제2조 제2항

정답 ①

3. 국가배상책임에 관한 설명 중 대법원 판례의 입장과 합치되는 것은? (2002 행정고시)

① 국가배상청구소송은 행정소송으로 제기하여야 한다.
② 법관이 재판에서 법령규정을 따르지 아니한 잘못이 있는 경우에는 그것만으로 국가배상책임이 인정되어야 한다.
③ 국가배상법은 생명·신체의 침해에 대한 위자료의 지급만을 규정하고 있으므로, 재산권 침해에 대해서는 위자료를 청구할 수 없다.
④ 현역병으로 입대하여 소정의 군사교육을 마친 다음 교도소의 경비교도로 전임된 자는 국가배상법 제2조 제1항 단서 소정의 어느 신분에도 해당하지 않으므로 국가배상을 청구하는 것을 방해받지 않는다.
⑤ 민간인과 공무원의 공동불법행위에 의하여 군인에게 손해를 발생하게 한 경우에, 피해자인 군인은 국가에 대해서는 배상청구를 할 수 없지만 민간인에 대해서는 손해의 전부에 대한 배상청구를 할 수 있다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 대법원은 "공무원의 직무상 불법행위로 손해를 받은 국민은 공무원 자신에 대하여도 직접 그의 불법행위를 이유로 민사상의 손해배상을 청구할 수 있다(대판 1972.10.10, 69다701)"라고 판시하여 사권설의 입장을 따르고 있다.
② 법관의 재판에 법령의 규정을 따르지 아니한 잘못이 있다 하더라도 이로써 바로 그 재판상 직무행위가 국가배상법 제2조 제1항에서 말하는 위법한 행위로 되어 국가의 손해배상책임이 발생하는 것은 아니고, 그 국가배상책임이 인정되려면 당해 법관이 위법 또는 부당한 목적을 가지고 재판을 하였다거나 법이 법관의 직무수행상 준수할 것을 요구하고 있는 기준을 현저하게 위반하는 등 법관이 그에게 부여된 권한이 취지에 명백히 어긋나게 이를 행사하였다고 인정할 만한 특별한 사정이 있어야 한다(대판 2001.10.12, 2001다47290).
③ 국가배상법 제3조 제5항에 생명, 신체에 대한 침해로 인한 위자료의 지급을 규정하였을 뿐이고 재산권 침해에 대한 위자료의 지급에 관하여 명시한 규정을 두지 아니하였으나 같은 법조 제4항의 규정이 재산권 침해로 인한 위자료의 지급의무를 배제하는 것이라고 볼 수는 없다(대판 1990.12.21, 90다6033·6040·6057).
④ 대판 1998.2.10, 97다45914
⑤ 공동불법행위자 등이 부진정연대채무자로서 각자 피해자의 손해 전부를 배상할 의무를 부담하는 공동불법행위의 일반적인 경우와 달리 예외적으로 민간인은 피해군인 등에 대하여 그 손해 중 국가 등이 민간인에 대한 구상의무를 부담한다면 그 내부적인 관계에서 부담하여야 할 부분을 제외한 나머지 자신의 부담부분에 한하여 손해배상의무를 부담하고, 한편 국가 등에 대하여는 그 귀책부분의 구상을 청구할 수 없다고 해석함이 상당하다 할 것이고, 이러한 해석이 손해의 공평·타당한 부담을 그 지도원리로 하는 손해배상제도의 이상에도 맞는다 할 것이다(대판 2001.2.15, 96다42420 全合).

정답 ④

♣ 학습내용 정리

1. 국가배상청구권의 법적성질에 대하여 다수설은 공권으로 판례는 사권으로 보고 있다.
2. 국가배상법 제2조 제1항 본문 전단에 의한 국가배상청구권의 성립요건으로는 공무원, 직무, 집행하면서, 고의 또는 과실, 법령위반, 인과관계, 손해가 요구된다.

제27강 배상책임자 등

♣ 학습목표

국가배상책임자와 관련하여 국가배상법 제6조에 대한 학설을 이해하고 판례를 분석할 수 있다.

가해 공무원의 피해자에 대한 민사책임성립여부, 이중배상금지에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

배상책임자

공무원의 개인의 손해배상책임성립여부

이중배상금지

♣ 사전테스트

1. 국가배상법 제6조 제1항의 배상책임자 중 선임감독자는 수임청이 속한 수임주체를 의미한다는 것에 학설과 판례가 일치한다.

   정답 : X

2. 가해공무원의 손해배상책임은 항상 인정된다.

   정답 : x

3. 향토예비군도 이중배상금지의 적용을 받는다.

   정답 : O

♣ 돌발퀴즈

군인・군무원・경찰공무원의 경우에는 헌법상으로도 이중배상배제가 인정되는 자로 규정되어 있다.

[정답] O

[해설] 헌법 제29조 제2항

♣ 강의내용

제1 배상책임자

1. 국가 또는 지방자치단체

국가배상법에서 국가배상책임의 주체에서 헌법 제29조 제1항의 공공단체를 제외한 것이 위헌이 아닌지에 대해, 일설은 위헌이라고 주장하고, 일설은 공공조합 영조물법인 등의 공공단체는 민법(제756조 : 사용자책임)으로 해결하면 될 것이므로 합헌이라고 주장하는 견해가 대립한다.

어쨌든 현행 국가배상법상 기타 공법상 법인의 위법한 공법작용으로 인한 손해발생시 기타 공법상 법인의 손해배상책임에 대하여 ① 국가배상법이 국가와 지자체만 배상책임자로 정하였으므로 민법을 적용하여 배상책임을 인정하여야 한다는 견해와 ② 가해행위가 공법작용이므로 피해자의 구제 및 법적용의 형평성을 고려하여 국가배상법을 유추적용하여야 한다는 견해가 대립한다. ③ 생각건대 현행 국가배상법의 문언상 ①설이 타당하다. 단 국가배상법을 개정하여 국가배상책임주체에 기타 공법상 법인을 포함시켜야 할 것이다.

2. 공무원의 선임감독자 및 영조물의 설치관리자와 비용부담자가 다른 경우

⑴ 국가배상법 제6조 제1항의 취지

국배법 제2조 및 제5조에 따른 배상책임은 원칙적으로 사무귀속주체가 진다. 이에 따라 기관위임사무의 경우도 원칙적으로 그 사무귀속주체이자 실질적인 비용부담자로서 위임청이 속한 위임주체가 손해배상책임을 져야 한다. 그러나 이러한 경우 피해자는 그 위임관계를 자세히 알 수 없으므로 수임주체를 상대로 소송을 제기하는 경우가 많고, 이에 따라 피고를 잘못 지정하여 그로인한 불측의 손해를 보는 경우가 많아지게 되었는 바, 이러한 문제점을 해결하기 위하여 국가배상법 제6조 제1항에서는 공무원의 선임감독자 또는 설치관리자와 비용부담자가 다른 경우 양자 모두가 국가배상책임이 있는 것으로 규정하게 되었다.

⑵ 국가배상법 제6조 제1항의 선임 감독자와 설치 관리자

1) 선임감독자

국가배상법 제6조 제1항의 선임감독자는 그 사무의 귀속주체를 말한다. 따라서 국가사무는 국가가, 상급지방자치단체의 사무는 상급지방자치단체가 선임감독자로서 책임을 진다.

즉, 기관위임사무인 경우 위임청이 속한 위임주체가 당해 사무의 귀속주체로서 선임감독자가 된다.

판례도 '국가로부터 자치단체에 시행하는 국가행정사무를 위임받아 행하는 국가의 보통지방행정기관으로서의 직무에 대하여는 국가가 그 책임을 진다'고 판시하였다.

2) 설치관리자

국가배상법 제6조의 영조물의 설치·관리자는 현실적으로 그 사무를 수행하는 수임청이 속한 지방자치단체가 아니라 위임청이 속한 위임주체, 즉 그 사무의 귀속주체인 국가(국가사무인 경우) 또는 상급지방자치단체라고 보는 것이 판례의 일관된 입장이다.

⑶ 비용부담자

형식적 비용 대외적으로 비용을 지출하는 자가 있고 실질적 궁극적 비용 부담자, 실제로 당해

사무에 드는 비용을 지출하는 자가 있는데 형식적 비용 부담자는 수임청에 속한 주체가 일단 주체 명의로 지출하니까 관계에서 수임 주체가 됐고 실비는 물론 특별한 규정이 있으면 거기에 따르겠지만, 규정이 없을 때는 지방자치법, 지방재정법 등에 따랐을 때 비용은 보통 위임한다.

1) 형식적 비용부담자설

실질적 비용부담관계를 고려함이 없이 대외적으로 국민과의 관계에서 비용을 지출한 자를 비용부담자로 보는 견해이다.

2) 병합설

피해자보호의 견지에서 일정한 경우에는 실질적 비용부담자[56]도 비용부담자에 포함된다는 견해이다.

3) 판 례

판례를 형식적 비용부담자설을 취한 것으로 보는 견해도 있으나, 판례가 적어도 대외적으로 그러한 경비를 지출하는 자는 '경비의 실질적 궁극적 부담자가 아니더라도' 그러한 경비를 부담하는 자에 포함된다고 판시한 것은 경비의 궁극적·실질적 부담자도 비용부담자에 해당한다는 것을 묵시적으로 전제한 것으로 본다. 결국 병합설을 취한 것으로 보인다.

3. 국가배상법 제6조 제2항의 피구상권자(최종적 책임자)

⑴ 문제점

국가배상법 제6조 제2항은 "제1항의 경우에 손해를 배상한 자는 내부관계에서 그 손해를 배상할 책임이 있는 자에게 구상할 수 있다"라고 규정하고 있다. 이 규정은 최종적인 배상책임자에 대한 구상을 인정하면서 선임감독자 또는 설치관리자와 비용부담자 중 누가 최종적인 책임자인지에 대하여 판단을 내리지 않고 그 판단을 판례에 맡기고 있다.

이에 따라 선임감독자 또는 설치관리자와 비용부담자가 다른 경우에 이들 중 종국적 배상책임자는 누구인지에 대하여 견해가 대립하고 있다.

⑵ 학 설

① 당해 사무처리에 대한 권리의무는 사무귀속주체에게 귀속되므로 사무귀속주체가 최종적 구상책임이 있다는 견해, ② 실질적 비용에는 구상책임도 포함되므로 실질적 비용부담자가 최종적 구상책임자라는 견해, ③ 손해발생의 기여도에 따라서 정해야 한다는 견해, ④ 손해발생의 기여도, 비용부담의 비용 등 개별·구체적인 모든 사정을 반영하여 해결하여야 한다는 견해 등이 대립한다.

⑶ 판 례

대법원은 국가배상법 제2조 책임과 관련하여 선임감독자이자 실질적 비용부담자인 안산시가 형식적 비용부담자인 국가에 대하여 제기한 구상금지급청구소송사건에서 안산시가 국가배상법

---

56) 지방자치법 제141조 (경비의 지출) 지방자치단체는 그 자치사무의 수행에 필요한 경비와 위임된 사무에 관하여 필요한 경비를 지출할 의무를 진다. 다만, 국가사무나 지방자치단체사무를 위임할 때에는 이를 위임한 국가나 지방자치단체에서 그 경비를 부담하여야 한다.
지방재정법 제21조(부담금과 교부금) ② 국가가 스스로 하여야 할 사무를 지방자치단체나 그 기관에 위임하여 수행하는 경우 그 경비는 국가가 전부를 그 지방자치단체에 교부하여야 한다.

제6조 제2항의 구상책임이 있다고 판시하여 사무귀속주체설의 입장을 취하였으나(대판 2001. 5. 15. 2001다14856 ; 대판 2001. 9. 25. 2001다41865),

광역시가 점유 관리하던 일반국도 중 일부 구간의 포장공사를 국가가 대행하여 광역시에 당해 도로의 관리를 이관하기 전에 교통사고 발생한 국가배상법 제5조 배상책임과 관련된 사안에서는 도로의 관리자, 점유자, 비용부담자의 지위가 국가와 지방자치단체에게 모두 중첩적으로 인정되는 경우에는 일정분담비율로 책임이 있다고 보고 있으며, 이때 부담비율은 당해 도로관리사무에 대한 국가 등의 관리책임의 범위, 사무관여정도 등을 종합적으로 고려하여 판단하고 있다.

제2 배상책임의 범위

1. 배상기준

일반 민사상의 불법행위의 경우와 같이 상당인과관계 있는 모든 손해를 배상한다. 국배법 제3조에 규정 있다.

2. 배상기준의 성격

배상액의 한도를 정한 것이라는 한정액설도 있으나, 단순한 기준에 불과하다는 기준액설이 통설 판례이다.

제3 가해 공무원 개인의 피해자에 대한 손해배상책임 인정여부

Ⅰ. 문제의 제기

가해공무원의 피해자에 대한 손해배상책임 인정문제가 국가배상책임의 성질논의와 관련될 것인지 문제된다. 만일 논리적 연관성이 없는 입법정책적 문제라면 국가배상법 제2조의 입법취지를 살펴보아야 할 것이며, 또한 동조의 입법취지를 밝혀내기 위해서는 국가배상청구권을 규정하고 있는 헌법 제29조 제1항 단서의 취지를 고려하여야 할 것이다.

II. 국가배상책임의 법적성질

국가배상책임의 성질을 ① 공무원 개인의 책임을 국가가 대신 지는 것에 불과하다는 대위책임설과 ② 국가의 자기잘못에 대한 책임으로 보는 자기책임설(자기책임설에서도 기관이론에 따른 자기책임으로 보는 견해와 위험책임설에 따라 자기책임으로 보는 견해가 있다), ③ 고의 중과실과 경과실로 나누어 경과실은 자기책임으로 보고, 고의 중과실은 기관의 품격을 상실하여 공무원 개인의 책임이나 직무행위로서 외형을 갖추었으므로 피해자 구제를 위해 일종의 자기책임으로 보는 절충설 등이 대립한다. 판례는 절충설을 취한 것으로 보인다.

III. 국가배상책임의 법적 성질과 선택적 청구권의 논리적연관성

일부 견해는 국가배상책임의 법적성질에 따라 가해 공무원 개인의 피해자에 대한 손해배상책임 성립여부가 결정된다고 주장한다.

IV. 공무원에 피해자에 대한 손해배상책임 성립여부

1. 부정설

이 견해는 헌법 제29조 제1항 단서의 책임의 내용을 공무원의 국가에 대한 내부적 구상책임으로 이해하며, 위와 같은 단서의 책임을 구체화한 법률이 국가배상법 제2조 제2항으로 파악하여 공무원의 피해자에 대한 배상책임을 부정한다.

그 논거로서는 ① 국가 등의 배상으로 피해자의 구제는 충분하며, ② 만약 공무원의 피해자에 대한 책임을 인정하게 되면 공무원의 직무집행을 위축시킬 우려가 있다는 점 등을 논거로 한다.

대법원 1996. 2. 25. 선고 95다38677 전원합의체판결 중 반대의견과 반대보충의견도 부정설을 따르고 있다.

2. 긍정설

이 견해는 헌법 제29조 제1항 단서의 의미를 피해자에 대한 배상책임도 포함하여 이해한다. 따라서 국가배상책임이 성립하여도 공무원은 피해자에 대한 배상책임을 별도로 부담한다고 본다.

그 논거로서 ① 국가 등의 배상책임은 국가 스스로의 행위에 대한 책임이므로 공무원 개인의 책임은 이와 별도로 성립하고 양립할 수 있다는 점, ② 공무원에게 아무런 책임을 묻지 않는다면 공무원의 위법행위에 대하여 통제할 수 없다는 점, ③ 헌법 제29조 제1항 단서의 면제되는 않는 '공무원의 책임'은 공무원의 구상책임뿐만 아니라 피해자에 대한 손해배상책임까지 포함한다고 해석된다는 점 등을 들고 있다.

대법원 1996. 2. 25. 선고 95다38677 전원합의체판결 중 별개의견도 긍정설을 따르고 있다.

3. 절충설의 입장

이 견해는 고의 중과실의 경우는 공무원의 피해자에 대한 손해배상책임을 인정하고 경과실의 경우에는 부정한다.

그 논거로는 ① 헌법 제29조 제1항 단서는 공무원의 개인의 구체적인 손해배상책임의 범위까지 규정한 것으로 보기는 어렵다는 점, ② 공무원의 피해자에 대한 손해배상책임에 대하여 민법이 아니라 국가배상법이 법적 근거가 되어야 하며 국가배상법 제2조 제2항은 공무원의 패해자에 대한 손해배상책임을 구체화한 것으로 해석된다는 점, ③ 공무원의 피해자에 대한 손해배상책임을 전혀 인정하지 않으면 공무원의 직무행위에 대한 적법성 보장에 문제가 생길 수 있고, 공무원의 피해자에 대한 손해배상책임을 경과실에도 인정하게 되면 피해자의 선택에 따라 배상책임의 궁극적 귀속자가 달라지므로 각각 문제가 있다는 점 등을 들고 있다.

대법원 1996. 2. 25. 선고 95다38677 전원합의체판결 중 다수의견이다.

제4 이중배상금지(군인 등에 대한 특례)

Ⅰ. 서

1. 의의

헌법 제29조 제2항 및 국가배상법 제2조 제1항 단서.

2. 인정취지

이중배상금지의 규정을 둔 취지는 위험성이 높은 직무에 종사하는 자에 대하여 사회보장적 위험부담으로서의 국가보상제도를 별도로 마련함으로써 그것과 경합하는 국가배상청구를 배제하려는 취지이다.

Ⅱ. 위헌성 논의

학설은 정당하다는 견해와 부당하는 견해가 대립한다. 헌법재판소는 헌법 제29조 제2항 때문에 합헌이라고 한다.

Ⅲ. 적용요건

1. 피해자가 군인, 군무원 경찰공무원,향토예비군

2. 전투, 훈련 등 직무집행과 관련하여 전사, 순직 또는 공상을 입었을 것.

3. 본인 또는 유족이 다른 법령의 규정에 의하여 재해보상금, 유족연금, 상이연금 등의 보상을 지급받을 수 있을 것.

Ⅳ. 공동불법행위자인 사인의 구상권행사가능여부

1. 문제의 소재

민법의 공동불법행위자의 손해배상책임은 부진정연대채무이고, 공동불법행위자 중 어느 한 사람이 전부를 배상하면 그 자는 다른 공동불법행위자에게 그 과실부분에 상응하는 구상권을 행사할 수 있다.

그러나 국가배상법 제2조 제1항 단서에 해당하는 경우에도 이 이론을 적용시킨다면 이중배상을 금지하려는 입법취지에 반하는 문제가 발생하고, 한편 구상권을 부정하게 된다면 국가는 군인의 사용자로서 군인의 불법행위로 인한 손해배상책임 부분을 사인에게 전가시키는 결과를 초래한다. 이 문제를 어떻게 해결할 것인지가 문제된다.

2. 대법원 판례

대법원은 전원합의체의 판결을 통해 종전 판결을 변경하여, 공동불법행위자 등이 부진정연대채무자로서 각자 피해자의 손해 전부를 배상할 의무를 부담하는 공동불법행위의 일반적인 경우와는 달리 예외적으로 민간인은 피해 군인 등에 대하여 그 손해 중 국가 등이 민간인에 대한 구상의무를 부담한다면 그 내부적인 관계에서 부담하여야 할 부분을 제외한 나머지 자신의 부담부분에 한하여 손해배상의무를 부담하고, 국가 등에 대하여서는 그 귀책부분의 구상을 청구할 수 없다고 판시하여, 민간인의 손해배상의무감축이론을 채택하였다.

3. 헌법재판소 결정

헌법재판소는 1994. 12. 29. 국가배상법 제2조 제1항 단서 헌법소원사건(헌재 1994. 12. 29, 93헌바21)에서, 국가배상법 제2조 제1항 단서 부분을 일반국민이 직무집행 중인 군인과의 공동불법행위로 직무집행 중인 다른 군인에게 공상을 입혀 그 피해자에게 공동의 불법행위로 인한 손해를 배상한 다음 공동불법행위자인 군인의 부담부분에 관하여 국가에 대하여 구상권을 행사하는 것을 허용하지 아니한다고 해석하는 한 헌법에 위반된다고 한정위헌으로 선언하였다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 국가배상법 제2조의 이중배상배제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (2009 지방직 7급)

① 국가배상법 제2조 제1항 단서에서 '군인·군무원·경찰공무원 또는 향토예비군대원'에 대하여 이중배상에 관한 배제조항을 두고 있으며, 헌법재판소는 이중배상을 금지하는 이러한 단서를 합헌으로 보았다.
② 판례는 이중배상이 배제되는 자는 전투경찰순경과 공익근무요원 등이라고 하였다.
③ 군인·군무원·경찰공무원의 경우에는 헌법상으로도 이중배상배제가 인정되는 자로 규정되어 있다.
④ 이중배상이 배제되는 군인 및 경찰공무원 등의 경우에도 다른 법령에 의하여 재해보상금·유족연금·상이연금 등의 보상을 지급받을 수 없을 때에는 국가배상법에 의하여 배상을 청구할 수 있다.
⑤ 군인·경찰공무원이 공상을 입고 전역·퇴직하였으나 그 상이 정도가 '국가유공자예우등에 관한 법률'의 적용 대상인 상이등급에 해당하지 않는 경우 국가배상청구가 가능하다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 헌재 2001.2.22, 2000헌바38
② 판례는 향토예비군(헌재 1996.6.13, 94헌바20), 전투경찰순경(헌재 1996.6.13, 94헌마118), 의무경찰순경(대판 2001.2.15, 96다42420 全合)에 대하여는 특례조항에 해당되는 공무원으로 인정한 바 있지만, 공익근무요원과 현역병으로 입영하여 경비교도로 전임 임용된 자(대판 1998.2.10, 97다45914)에 대하여는 부정하고 있다. 공익근무요원은 소집되어 군에 복무하지 않는 한 군인이라고 말할 수 없으므로, 비록 병역법 제75조 제2항이 공익근무요원으로 복무 중 순직한 사람의 유족에 대하여 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 보상을 하도록 규정하고 있다고 하여도, 공익근무요원이 국가배상법 제2조 제1항 단서의 규정에 의하여 국가배상법상 손해배상청구가 제한되는 군인·군무원·경찰공무원 또는 향토예비군대원에 해당한다고 할 수 없다(대판 1997.3.28, 97다4036).
③ 헌법 제29조 제2항. 다만, 국가배상법에서 향토예비군대원이 추가되어 있다(국가배상법 제2조 제1항 단서).

정답 ②

2. 포항경찰서 소속경찰관 甲이 공무수행 중 폭행을 가하여 손해를 입힌 경우에 피해자는 누구를 피고로 하여 손해배상청구를 할 수 있는가? (2007 경북9급)

① 대한민국
② 경상북도
③ 포항경찰서
④ 경상북도지방경찰청
⑤ 경상북도 도지사

해설 & 정답

유형 준사례형

우리나라는 제주특별자치도에서 자치경찰이 인정되는 경우를 제외하고는 국가경찰만 존재하기 때문에 결창관의 직무행위로 인한 손해배상책임(국가배상법 제2조)이든, 경찰서나 경찰차량의 설치·관리상의 하자로 인한 손해배상책임(국가배상법 제5조)이든 배상책임자는 국가이므로 국가만이 피고가 될 수 있다.

정답 ①

3. 국가공무원 A의 위법한 직무집행행위로 인해 甲에게 손해가 발생했다. 다음 중 판례의 태도와 다른 것은? (2001 서울7급)

① 甲은 국가를 상대로 손해배상청구가 가능하다.
② 국가가 甲에게 배상한 경우 A가 고의·중과실일 때에는 국가는 A에게 구상권을 청구할 수 있다.
③ A가 경과실인 경우 甲에게 직접적 책임을 지지 않는다.

④ A가 고의·중과실일 때에 한하여 甲에게 직접적 손해배상책임이 있다.
⑤ A는 고의·중과실 여부를 떠나 甲에게 민사상 손해배상책임을 질 수 있다.

해설 & 정답

유형 준사례형

공무원이 직무수행 중 불법행위로 타인에게 손해를 입힌 경우 국가 등이 국가배상책임을 부담하는 외에 공무원 개인도 고의 또는 중과실이 있는 경우에는 불법행위로 인한 손해배상책임을 진다고 할 것이지만, 공무원에게 경과실뿐인 경우에는 공무원 개인은 손해배상책임을 부담하지 아니한다(대판 1996.2.15, 95다38677 全合).

정답 ⑤

♣ 학습내용 정리

1. 국가배상책임자에 대하여 국가배상법 제6조 제1항은 선임감독자 또는 설치관리자와 비용부담자가 다른 경우 양자 모두 국가배상책임을 지도록 규정하고 있다.
2. 가해공무원의 피해자에 대한 손해배상책임은 고의 또는 중과실인 경우에만 인정된다는 것이 대법원의 입장이다.

제28강 영조물책임 등

♣ 학습목표

국가배상법 제2조 제1항 본문 후단에 따른 국가배상책임의 성립요건과 국가배상법 제5조 제1항의 영조물책임의 성립요건을 비교하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

자동차 운행으로 인한 손해배상책임
영조물책임

♣ 사전테스트

1. 자동차손해배상보장법은 국가배상법보다 일반법이다.
   정답 : X

2. 국유 일반재산도 국가배상법 제5조의 영조물에 포함된다.
   정답 : x

3. 예산부족이 절대적 면책사유가 되지는 않는다는 것이 판례의 입장이다.
   정답 : O

♣ 돌발퀴즈

가변차로의 신호기 고장이 현재의 기술수준에 비추어 피할 수 없는 부득이한 것이라면 손해발생의 예견가능성이나 회피가능성이 없어 영조물의 하자를 인정할 수 없는 경우에 해당한다는 것이 판례의 입장이다.

[정답] O

[해설] 가변차로에 설치된 신호등의 용도와 오작동시에 발생하는 사고의 위험성과 심각성을 감안할 때, 만일 가변차로에 설치된 두 개의 신호기에서 서로 모순되는 신호가 들어오는 고장을 예방할 방법이 없음에도 그와 같은 신호기를 설치하여 그와 같은 고장을 발생하게 한 것이라면, 그 고장이 자연재해 등 외부요인에 의한 불가항력에 기인한 것이 아닌 한 그 자체로 설치·관리자의 방호조치의무를 다하지 못한 것으로서 신호등이 그 용도에 따라 통상 갖추어야 할 안전성을 갖추지 못한 상태에 있었다고 할 것이고, 따라서 설령 적정전압보다 낮은 저전압이 원인이 되어 위와 같은 오작동이 발생하였고 그 고장은 현재의 기술수준상 부득이한 것이라고 가정하더라도 그와 같은 사정만으로 손해발생의 예견가능성이나 회피가능성이 없어 영조물의 하자를 인정할 수 없는 경우라고 단정할 수 없다(대판 2001.7.27, 2000다56822).

♣ 강의내용

제1 자동차손해배상보장법과 국가배상법과의 관계

Ⅰ. 문제의 소재

자동차의 운행으로 말미암아 타인에게 인적 손해를 가한 경우에는 자동차손해배상보장법(이하 '자배법'이라 한다)의 적용을 받게 된다.

그런데 국가배상법 제2조 제1항 본문은, 「국가 또는 지방자치단체는.... 자동차손해배상보장법에 의하여 손해배상의 책임이 있는 때에는 이 법에 의하여 손해를 배상하여야 한다」고 규정하고 있는 바, 이러한 규정의 의미를 어떻게 새길 것인지가 문제된다.

Ⅱ. 국가배상법 제2조 제1항 본문 후단의 해석[57]

여러 가지로 해석될 수 있으나, 국가배상법 제2조 제1항 본문 후단의 주체를「국가 또는 지방자치단체」로 보아 같은 규정은「국가 또는 지방자치단체」에게 자배법상의 책임이 인정되는 경우를 대상으로 하는 것이고, 단지 그 청구절차를 국가배상법에 의한 절차를 따르도록 하는 것으로 해석하는 것이 통설과 판례이며 타당하다.

Ⅲ. 자배법의 손해배상책임의 성립요건과 범위

1. 자배법상 손배책임 성립요건

자배법 제3조는 ① 자기를 위하여 자동차를 운행할 것(운행지배 및 운행이익), ② 다른 사람의 인체에 대하여 손해가 발생할 것, ③ 인체의 손해가 자동차의 운행으로 생길 것, ④ 면책사유가 없을 것의 요건이 필요하다.

이 중 자배법 제3조 소정의「자기를 위하여 자동차를 운행하는 자」는 자동차에 대한 운행을 지배하여 그 이익을 향수하는 책임주체로서의 지위에 있는 자를 가리키는 것이고, 운행지배와 운행이익은 통상적으로 자동차의 소유자에게 귀속되는 것으로 이해된다.

2. 자배법상 손해배상책임의 범위

자배법상 손해배상책임은 인적 손해에 한하여 책임보험금을 그 한도로 하여 손해를 전보하는 것이므로(동법 제26조 참조), 물적 손해 및 책임보험금을 넘어서는 일반손해에 대하여는 원래의 청구권 근거규범, 즉 민법이나 국가배상법에 의해야 한다.

Ⅳ. 구체적인 예

1. 개설

위에서 살펴본 바와 같이 공무원의 차량사고로 인한 손해발생의 경우 국가 등이 자배법상의 손해배상책임요건을 갖추면 국가배상법 제2조 제1항 본문 후단에 따라 국가배상책임을 진다. 즉, 책임성립요건으로는 자배법이 우선적으로 적용된다. 따라서 자배법 제3조에 의한 책임성립요건으로서의 국가 등의 '운행자성'이 인정되어야 한다.

2. 국가 또는 지방자치단체의 운행자성

---

57) 이하의 내용은 류지태, 국가배상법과 자동차손해배상보장법의 관계, 고시연구, 2001. 10. 28-36쪽 참조.

⑴ 서

자배법의 책임은 위에서 본 바와 같이 “자기를 위하여 자동차를 운행한 자”에게 성립한다. 따라서 국가 또는 지자체가 자배법상의 운행자성을 갖추어야 국가배상법 제2조 제1항 본문 후단이 적용될 수 있다.

⑵ 국가 또는 지자체의 운행자성의 구체적인 판단

1) 공무원이 공무와 관련하여 관용차운전중 인신사고 : 국가 등의 운행자성 인정됨

국가 또는 지자체 : 자배법상 운행자책임성립 →국배법 제2조 제1항 본문 후단 →국가배상법 적용

공무원개인 : 민법 제750조 손해배상책임성립 → 국배법 제2조 제2항과 헌법 제29조 제1항 단서의 해석에 따라 달라짐 → 대법원 다수의견인 절충설에 의하면 고의 중과실인 경우에만 민사책임 인정.

2) 공무원이 개인용도로 관용차운전중 인신사고

이 경우에는 국가 등이 운행자성을 상실하는지 여부에 따라 판단하여야 한다. 따라서 공무원의 개인용도 관용차운전임에도 불구하고 국가 등에게 운행지배나 운행이익을 인정할 사정이 있는 경우에는 국가 등이 자배법상 손해배상책임을 지게 되나, 운행지배나 운행이익을 상실하였다고 인정되는 경우에는 국가 등이 자배법상 손해배상책임을 지지 않는다.

3) 공무원이 직무와 관련하여 개인차량운전중 인신사고

국가 또는 지자체 : 국배법 제2조 제1항 본문전단만 적용

공무원개인 : 과실유무와 상관없이 자배법상 손배책임성립

4) 공무원이 직무관련없이 개인차량운전중 인신사고

국가 또는 지자체 : 어떠한 배상책임도 성립되지 않음

공무원 개인 : 과실유무와 상관없이 자배법상 손배책임성립

제2 영조물의 설치 관리상의 하자로 인한 손해배상

Ⅰ. 서 설

국가배상책임의 유형은 행정작용의 주요 수단인 공무원을 통한 직무수행상의 위법행위 외에도, 행정상의 물적 수단인 공공시설을 통한 손해발생에 대해서도 인정되고 있다.

Ⅱ. 배상책임의 요건

1. 공공의 영조물일 것. - 국가 또는 지자체가 직접 점유하는 강학상 공물

국가배상법 제5조 제1항 소정의 “공공의 영조물”이라 함은 국가 또는 지방자치단체에 의하여 특정 공공의 목적에 공여된 유체물 내지 물적 설비를 지칭하며, 특정 공공의 목적에 공여된 물이라 함은 일반공중의 자유로운 사용에 직접적으로 제공되는 공공용물에 한하지 아니하고, 행정주체 자신의 사용에 제공되는 공용물도 포함하며 국가 또는 지방자치단체가 소유권, 임차권 그 밖의 권한에 기하여 관리하고 있는 경우뿐만 아니라 사실상의 관리를 하고 있는 경우도 포함한다(대판 1995. 1. 24, 94다45302).

2. 설치 또는 관리의 하자

⑴ 의 의

⑵ 학 설

① 사회통념상 물적 안전성을 결여를 의미한다고 보는 객관설, ② 관리자의 영조물에 대한 안전확보의무으로 보는 주관설, ③ 물적 하자와 관리자의 귀책사유유무도 함께 고려하는 절충설, ④ 관리자의 객관적 안전확보의무를 위반함으로써 발생한 손해에 대한 행정주체의 위법·무과실책임으로 보는 위법무과실책임설 등이 대립한다.

⑶ 판례의 태도

판례는 원칙적으로 객관설의 입장이었으나, 최근 판례는 방호조치의무위반여부에 따라 설치관리하자여부를 판단하고 있다.

최근 판례의 의미에 대해 첫째 위법·무과실책임설의 입장을 취한 것으로 이해하는 견해, 둘째 하자를 판단함에 있어서 관리자가 방호조치의무를 다하였는지 여부를 기준으로 한다는 점에서 주관설을 취하였다는 견해, 셋째 판례가 객관설을 포기하지 않으면서도 일본의 최고재판소의 판례와 유사한 맥락에서 예측가능성, 결과회피가능성의 결여를 면책사유로 인정한 것으로 평가하는 견해, 넷째 판례가 변형된 객관설의 입장을 취하였다는 견해 등이 있다.

⑸ 하자의 입증책임

이에 대해서는 불법행위책임의 일반적 이론에 의해 원고가 부담하는 것이 원칙이나 피해자의 입증곤란을 위해서 이 때에 피해자는 영조물로부터 손해가 발생하였음을 입증하면 되며 그 손해가 설치관리상의 하자에 기인한 것이라는 점에서 일응의 추정이 생기고 이에 대해 행정주체가 간접반증을 하여야 한다는 입증책임의 완화이론이 주장되고 있다.

3. 타인에게 손해를 발생하게 하였을 것

4. 인과관계가 있을 것

제5조에 의한 책임이 성립하기 위하여는 '손해'가 발생하였어야 하고, 영조물의 하자와 손해 사이에 '상당인과관계'가 있어야 함은 불법행위 일반에 있어서와 같다.

5. 면책사유

영조물의 하자로 인한 책임에 있어서는 특별히 다음과 같은 점들이 영조물책임의 감면사유로 문제되므로 이하 이들을 고찰하고자 한다.

⑴ 불가항력

1) 개 념

불가항력이라 함은 천재지변과 같이 인간의 능력으로는 예견할 수 없거나, 예견할 수 있어도 회피할 수 없는 외부의 힘에 의하여 손해가 발생한 경우를 말하며 면책사유가 된다.

2) 예견가능성

홍수 등의 위험발생의 예견가능성은 영조물 관리주체의 결과회피조치의 전제로서 요구된다. 예견가능성의 판단은 그 당시의 과학기술의 수준을 기준으로 행하여져야 한다고 보는 것이 타당하다.

3) 결과회피가능성

결과회피가능성 여부는 있어야 할 안전관리체제가 그 기능을 제대로 발휘하고 있었는가를 전제로 하여 판단되어야 한다.

⑵ 예산부족

예산부족이 면책사유가 되는가에 대해 판례는 영조물의 설치의 하자의 유무는 객관적 견지에서 본 안전성의 문제이므로 재정사정은 영조물의 안전성의 정도에 관하여 참작사유는 될 수 있을지언정 안전성을 결정지울 절대적인 면책사유는 되지 않는다고 보고 있다.

⑶ 피해자의 과실

피해자에게 과실이 있었던 경우에는 피해자의 과실에 의하여 확대된 손해의 한도 내에서 영조물관리주체의 책임이 부분적으로 감면된다고 보는 것이 타당하다.

⑷ 영조물의 하자와 감면사유의 경합

영조물의 설치 또는 관리상의 하자로 인한 사고라 함은 영조물의 설치 또는 관리상의 하자만이 손해발생의 원인이 되는 경우만을 의미하는 것이 아니고, 다른 자연적 사실이나 제3자의 행위 또는 피해자의 행위와 경합하여 손해가 발생하였더라도 영조물의 설치 또는 관리상의 하자가 손해발생의 공동원인의 하나가 된 이상 그 손해는 영조물의 설치 또는 관리상의 하자에 의하여 발생한 것이라고 보아야 한다.[58]

영조물의 하자가 제3자의 행위와 경합하여 손해를 발생시킨 경우에는 영조물관리자는 제3자와 부진정연대채무를 진다. 영조물의 하자가 피해자의 행위와 경합하는 경우에는 과실상계를 한다.

불가항력과 영조물의 하자가 손해의 발생에 경합된 경우에는 영조물의 하자로 인하여 손해가 확대된 한도 내에서 국가 또는 지방자치단체는 책임을 진다고 보는 것이 타당하다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 영조물 설치·관리의 하자로 인한 국가배상책임에 관한 설명 중 옳은 것은? (2001 행정고시)

① 영조물이라 함은 공공에 제공되는 유체물로서 인공공물에 한정된다.
② 하자의 발생에는 관리자의 주관적 귀책사유가 있어야 한다는 것이 통설과 판례이다.
③ 자연현상 또는 제3자나 피해자의 행위가 손해의 원인에 가세되었다면 국가 등의 배상책임은 성립하지 않는다.
④ 대법원 판례는 자치단체장이 설치하여 관할경찰청장에게 관리권한이 위임된 교통신호기의 고장으로 인하여 교통사고가 발생한 경우, 지방자치단체만이 배상책임이 인정된다고 한다.
⑤ 대법원 판례는 영조물의 설치·관리상의 하자로 인하여 손해가 발생한 경우 피해자의 위자료 청구권이 배제되는 것은 아니라고 한다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 영조물이란 국가 또는 공공단체에 의해 공공의 목적으로 사용되는 유체물 및 관리할 수 있는 자연력인공물을 의미한다. 유체물에는 개개의 물건뿐만 아니라 물건의 집합체인 공공시설도 포함되고, 공물의 개념에는 동산·부동산, 인공공물·자연공물·타유공물·동물 등도 포함된다.

58) 대판 1994. 11. 24. 94다32924.

② 대법원은 "국가배상법 제5조 제1항에 정하여진 '영조물의 설치 또는 관리의 하자'라 함은 공공의 목적에 공여된 영조물이 그 용도에 따라 갖추어야 할 안전성을 갖추지 못한 상태에 있음을 말하고, 안전성을 갖추지 못한 상태, 즉 타인에게 위해를 끼칠 위험성이 있는 상태라 함은 당해 영조물을 구성하는 물적 시설 그 자체에 있는 물리적·외형적 흠결이나 불비로 인하여 그 이용자에게 위해를 끼칠 위험성이 있는 경우뿐만 아니라, 그 영조물이 공공의 목적에 이용됨에 있어 그 이용상태 및 정도가 일정한 한도를 초과하여 제3자에게 사회통념상 수인할 것이 기대되는 한도를 넘는 피해를 입히는 경우까지 포함된다고 보아야 한다(대판 2005.1.27, 2003다49566)"라고 판시하여 설치 관리의 하자의 의미에 대해서 기본적으로 객관설을 취하고 있다. 따라서 이에 의할 경우 국가배상법 제5조의 책임은 무과실 책임이 된다.

③ 영조물의 설치 또는 관리상의 하자로 인한 사고라 함은 영조물의 설치 또는 관리상의 하자만이 손해발생의 원인이 되는 경우만을 말하는 것이 아니고, 다른 자연적 사실이나 제3자의 행위 또는 피해자의 행위와 경합하여 손해가 발생하더라도 영조물의 설치 또는 관리상의 하자가 공동원인의 하나가 되는 이상 그 손해는 영조물의 설치 또는 관리상의 하자에 의하여 발생한 것이라고 해석함이 상당하다(대판 1994.11.22, 94다32924).

④ 교통신호기를 관리하는 지방경찰청장 산하 경찰관들에 대한 봉급을 부담하는 국가도 국가배상법 제6조 제1항에 의한 배상책임을 부담한다(대판 1999.6.25, 99다11120).

⑤ 원심은 피고에게 국가배상법 제5조 제1항의 규정에 의하여 이 사건 사고로 인한 위자료지급 의무를 지우고 있는데 같은 법 제3조 제1항 내지 제5항에 의하더라도 이 사건과 같은 경우에 원고들의 위자료청구권이 반드시 배제되는 것으로는 해석되지 아니한다(대판 1990.11.13, 90다카25604).

정답 ⑤

2. 폭설로 인하여 인근지역 국도에서 교통사고가 발생하였고, 이와 관련하여 사전에 이 지역에 폭설이 내릴 것이라는 일기예보가 수차례 있었지만, 특별히 이 국도의 차량통행을 통제하는 등의 조치는 없었다. 이에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? (2005 국가직 9급)

① 불가항력적 사유로 인정되는 경우에는 도로관리청의 손해배상책임이 부인될 수 있다.

② 위 사례는 객관설에 따를 경우 도로의 객관적 하자가 존재하고, 주관설에 의할 경우에도 통상적인 주의의무를 통하여 손해발생의 회피가능성이 있었다고 판단되므로, 결국 양설에 따를 경우 모두 도로의 관리상의 하자가 인정된다.

③ 최근 대법원은 교통사고로 인한 손해발생의 예견가능성이나 회피가능성이 없었다면 도로의 관리상의 하자를 인정할 수 없다는 입장을 취하고 있다.

④ 절충설의 입장에 따른다면, 위 경우 도로의 설치관리상의 하자가 없다고 보아 도로관리청의 손해배상책임을 부인하게 된다.

⑤ 하천과 같은 자연공물보다 도로와 같은 경우 하자의 요건판단에 있어서 더 엄격하다고 볼 수 있다.

해설 & 정답

유형 준사례형

① 대법원은 "100년 발생빈도의 강우량을 기준으로 책정된 계획홍수위를 초과하여 600년 또는 1,000년 발생빈도의 강우량에 의한 하천의 범람은 예측가능성 및 회피가능성이 없는 불가항력적인 재해로서 그 영조물의 관리청에게 책임을 물을 수 없다(대판 2003.10.23, 2001다48057)"라고 판시하여 불가항력을 면책사유로 인정하고 있다.

③ 국가배상법 제5조 제1항에 정해진 영조물의 설치 또는 관리의 하자라 함은 영조물이 그 용도에 따라 통상 갖추어야 할 안전성을 갖추지 못한 상태에 있음을 말하는 것이며, 다만 영조물이 완전무결한 상태에 있지 아니하고 그 기능상 어떠한 결함이 있다는 것만으로 영조물의 설치 또는 관리에 하자가 있다고 할 수 없는 것이고, 위와 같은 안전성의 구비 여부를 판단함에 있어서는 당해 영조물의 용도, 그 설치장소의 현황 및 이용 상황 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 설치·관리자가 그 영조물의 위험성에 비례하여 사회통념상 일반적으로 요구되는 정도의 방호조치의무를 다하였는지 여부를 그 기준으로 삼아야 할 것이며, 만일 객관적으로 보아 시간적·장

소적으로 영조물의 기능상 결함으로 인한 손해발생의 예견가능성과 회피가능성이 없는 경우 즉 그 영조물의 결함이 영조물의 설치·관리자의 관리행위가 미칠 수 없는 상황 아래에 있는 경우임이 입증되는 경우라면 영조물의 설치·관리상의 하자를 인정할 수 없다(대판 2001.7.27, 2000다56822).

④ 절충설은 하자의 유무를 영조물 자체의 객관적 하자뿐만 아니라, 관리자의 안전관리의무위반이라는 주관적 요소도 고려해야 한다는 견해이다. 따라서 객관설이나 주관설 어느 하나에 의해 손해배상책임이 인정될 경우 절충설에 의하면 당연히 손해배상책임이 인정된다.

⑤ 인공공물과 자연공물의 하자 판단 기준을 달리하고 있는데, 자연공물인 하천의 경우 계획고수량이 과학·기술적으로 올바르게 책정되었는지에 따라 하천의 설치상의 하자를 판단하고 있으므로 인공공물의 경우에 영조물의 하자가 더 넓게 인정된다고 볼 수 있다.

정답 ④

3. 안산시장이 안산경찰서장에게 교통신호기 설치·관리사무를 위임하였고, 안산경찰서장은 안산시의 비용으로 설치·관리하고 있던 중 신호기 고장으로 사고가 발생한 경우 판례(2001다41865)에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 교통신호기의 관리사무는 지방자치단체가 설치하여 안산경찰서장에게 그 권한을 기관위임한 사무로서 피고인 국가 소속 경찰공무원들은 원고의 사무를 처리하는 지위에 있으므로, 원고인 안산시가 그 사무에 관하여 선임·감독자에 해당한다.

② 교통신호기 시설은 지방자치법 제132조 단서의 규정에 따라 원고인 안산시의 비용으로 설치·관리되고 있으므로, 그 신호기의 설치·관리의 비용을 실질적으로 부담하는 비용부담자는 안산시이다.

③ 국가는 단지 그 소속 경찰공무원에게 봉급만을 지급하고 있을 뿐이므로 형식적 비용부담자에 해당한다.

④ 이 사건 손해배상의 궁극적인 책임은 안산시와 국가가 기여도에 따라 분담한다고 봄이 상당하다.

⑤ 피해자는 국가 또는 안산시를 상대로 손해배상을 청구할 수 있다.

해설 & 정답

유형 준사례형

횡단보도에 설치된 신호기는 원래 원고인 안산시장이 설치·관리하여야 할 것인데, 도로교통법 제104조 제1항, 그 시행령 제71조의2 제1호에 의하여 원고 시장이 그 설치·관리에 관한 권한을 피고 산하 경기도 지방경찰청 소속 안산경찰서장에게 위임함에 따라 안산경찰서장이 원고의 비용부담 아래 이를 설치·관리하고 있었다. 따라서 교통신호기의 관리사무는 지방자치단체가 설치하여 안산경찰서장에게 그 권한을 기관위임한 사무로서 피고인 국가 소속 경찰공무원들은 원고의 사무를 처리하는 지위에 있으므로, 원고인 안산시가 그 사무에 관하여 선임·감독자에 해당하고, 그 교통신호기 시설은 지방자치법 제132조 단서의 규정에 따라 원고인 안산시의 비용으로 설치·관리의 비용을 실질적으로 부담하는 비용부담자의 지위도 아울러 지니고 있는 반면, 피고인 국가는 단지 그 소속 경찰공무원에게 봉급만을 지급하고 있을 뿐이므로, 원고와 피고 사이에서 이 사건 손해배상의 궁극적인 책임은 전적으로 원고인 안산시에게 있다고 봄이 상당하다(대판 2001.9.25, 2001다41865).

정답 ④

♣ 학습내용 정리

1. 국가배상법 제2조 제1항 본문 후단에 의해 국가배상책임이 성립하려면 국가 또는 지방자치단체에게 차량의 운행자성이 인정되어야 한다.
2. 영조물책임의 성립요건으로 공공의 영조물은 국가 또는 지방자치단체가 직접 점유 관리하는 강학상 공물을 의미한다.

제29강 손실보상

♣ 학습목표

손실보상에 관한 헌법 제23조 제3항에 대한 학설과 판례를 검토하고 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률상 손실보상절차에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

경계이론과 분리이론
보상규정 없는 경우 손실보상
손실보상절차

♣ 사전테스트

1. 우리나라 헌법재판소는 경계이론을 취하고 있다.
   정답 : X

2. 헌법 제23조 제3항은 불가분조항이라는 것에 학설이 일치한다.
   정답 : x

3. 손실보상의 성립요건으로 특별희생이 요구된다.
   정답 : O

♣ 돌발퀴즈

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」상의 보상은 사업인정고시일 현재의 공시지가를 기준으로 하여 행해진다.

[정답] ○

[해설] 공시자가는 사업인정고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서, 당해 토지의 협의성립 또는 재결당시 공시된 공시지가 중 당해 사업인정고시일에 가장 가까운 시점에 공시된 것이어야 한다(공익사업을위한토지등의취득및보상에관한법률 제67조, 제70조 제1항).

♣ 강의내용

제1 행정상 손실보상의 의의

헌법 제23조 ① 모든 국민의 재산권은 보장된다. 그 내용과 한계는 법률로 정한다.
② 재산권의 행사는 공공복리에 적합하도록 하여야 한다.
③ 공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다.

Ⅰ. 손실보상의 개념

행정상 손실보상이란 공공필요에 의한 적법한 공권력행사에 의하여 개인의 재산권에 가하여진 특별한 손해에 대하여 전체적인 평등부담의 견지에서 행하여지는 재산적 보상을 말한다.

Ⅱ. 적법행위로 인한 재산권침해에 대한 보상

1. 적법행위
2. 재산권침해

Ⅲ. 공권력행사로 인한 재산권침해에 대한 보상

공권자 행사가 아닌 사법적인 경우에는 손실 구상이 대상이 될 수 없고 또 비지상권에 대한 침해는 손실보상 헌법 23조 사망능력이 아닌 다른 면역으로 독일에서 희생부산이라고 하는데 영억으로 가야 한다.

Ⅳ. 특별한 희생에 대한 조절적 보상

특별한 희생이 발생하지 않으면 손실 보상 영역이 되지 못한다.

제2 헌법 제23조의 재산권제한의 유형

Ⅰ. 헌법 제23조의 규범구조

1. 재산권의 내용규정

헌법 제23조 제1항 제2문은 '재산권의 내용 및 한계는 법률로 정한다'고 하여 입법자에게 재산권의 구체적 내용을 형성할 권한을 부여하고 있다(기본권 형성적 법률유보).

2. 재산권의 수용규정

헌법 제23조 제3항은 재산권의 내재적 한계를 넘는 적법한 재산권 침해와 그에 대한 손실보상을 규정하고 있다.

Ⅱ. '재산권의 내용규정'과 '재산권의 수용규정'의 구별기준[59]

59) 예컨대 국회가 재산권제한법률을 만들면서 그에 대한 금전보상에 대하여 규정하지 않은 경우 당해 재산권제한법률이 헌법 제23조 제1항에 근거한 재산권내용규정인가 아니면 헌법 제23조 제3항에 근거한 재산권수용규정인가가 문제된다.

1. 문제의 소재

입법자는 헌법 제23조의 재산권보장영역 내에서 두 가지 다른 방식으로 재산권을 제한할 수 있다. ① 첫째로 입법자는 헌법 제23조 제1항 제2문에 의거해서 재산권의 내용과 한계를 미래를 향하여 새롭게 정할 수 있다. ② 둘째로 입법자는 헌법 제23조 제3항에 따라서 법률에 의해 재산권을 제한할 수 있다. 문제는 두 유형의 재산권제한을 어떻게 구별할 것인가에 있다.

2. 재산권제한 유형의 구별에 관한 종래의 논의(이른바 경계이론)

재산권의 내용규정와 재산권의 수용규정의 구별은 재산권침해의 강도(정도)에 따라 구분된다는 견해이다.

그러므로 이 이론에서는 양자 사이의 경계를 확정하는 일이 중요한 것인데, 그 기준은 당해 재산권제한이 특별한 희생인가의 여부 즉, 재산권제한의 강도와 질이 기준이 된다.

이 견해에 의하면 재산권제한법률에 금전보상규정이 없더라도 당해 재산권제한이 사회적 제약을 벗어나 특별희생을 발생시키면 헌법 제23조 제3항에 의한 재산권수용규정이라고 본다.

3. 재산권제한 유형 구별에 관한 새로운 논의(이른바 분리이론)

분리이론은 재산권의 내용규정과 재산권의 수용규정은 각기 독립된 별개의 것으로 이해한다. 따라서 양 법률조항에 관한 사법심사의 기준도 서로 독립된 것으로 보고 양자의 구별기준으로서 종전의 논의에서처럼 침해강도가 아닌 입법자의 의사에 따라 판단한다.

결국 분리이론에 따르면 입법자가 재산권제한법률을 제정하면서 금전보상규정을 두지 않은 경우에는 헌법 제23조 제1항에 근거한 내용규정을 제정한 것인 바, 이 때 문제되는 것은 법률에 규정된 재산권침해행위가 재산권의 본질적 내용을 침해하거나 비례원칙에 위반하였는가(헌법 제37조 제2항 위반여부)이지 금전보상규정유무는 전혀 상관없다는 것이다(결국 당해 재산권제한법률에 금전보상규정이 있으면 재산권수용규정이고 금전보상규정이 없으면 재산권내용규정이다).

따라서 금전보상규정이 없는 재산권침해법률은 내용규정으로서, 이러한 법률에 근거한 재산권침해작용에 대해서는 취소소송에 의해 구제되어야지 손실보상청구로 구제될 수는 없다. 다만 '보상의무있는 재산권의 내용규정'으로 파악하고 입법자가 보상규정을 둠으로써 위헌성을 제거할 수 있다고 한다.

4. 헌법재판소의 입장

헌법재판소는 개발제한구역지정을 규정한 구 도시계획법 제21조에 대한 위헌형 헌법소원에 대한 헌법불합치결정에서 개발제한구역제도 그 자체는 합헌이지만, 개발제한구역의 지정으로 토지소유자에게 사회적 제약의 범위를 넘는 가혹한 부담이 발생하는 예외적인 경우(나대지 등)에도 보상규정을 두지 않은 것은 헌법 제37조 제2항 위반으로 위헌이라고 판시하였다(헌법재판소 1999. 10. 21, 97헌바26).

이러한 헌법재판소의 결정에 대하여 독일 연방헌법재판소의 분리이론을 도입한 결정이었다고 보는 견해가 다수설이다.

제3 손실보상의 근거

Ⅰ. 손실보상제도의 이론적 근거

기득권설, 은혜설, 특별희생설 등이 대립하나 특별희생설이 통설과 판례이다.

Ⅱ. 헌법적 근거

1. 문제의 제기

헌법 제23조 제3항은 "공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한 및 그 보상은 법률로써 하되 정당한 보상을 하여야 한다"고 규정하여, 손실보상의 헌법적 근거를 마련하고 있다.

이를 바탕으로 각종 개별 법률이 공용수용·사용 또는 제한 및 그 보상에 대하여 규정하고 있는데 이러한 경우에는 개별 법률에 따라 손실보상을 청구할 수 있으므로 아무런 문제가 없다.

그러나 공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한에 의해 국민에게 특별한 희생이 발생하였으나 그 근거법률에서 보상규정을 두지 않는 경우 재산권을 침해받은 개인이 어떻게 구제될 것인가에 대해 문제가 제기된다.[60]

2. 학 설

① 헌법 제23조 제3항을 방침규정으로 보아 보상규정이 없으면 보상이 불가하다는 방침규정설, ② 헌법 제23조 제3항을 직접 적용하여 헌법 제23조 제3항에 의해 손실보상청권을 인정할 수 있다는 직접효력설, ③ 헌법 제23조 제1항 및 제11조에 근거하여, 헌법 제23조 제3항 및 관계규정의 유추해석을 통하여 손실보상청구권을 인정할 수 있다는 간접효력규정설, ④ 손실보상청구권은 헌법이 아니라 법률에서 근거되는 것이라는 전제하에 만약 재산권수용법률이 금전보상을 규정하지 않으면 헌법 제23조 제3항 위반으로 그 법률은 위헌무효이고 그 법률에 근거한 재산권수용처분은 위법인 바 취소소송의 제기와 손해배상을 청구할 수 있다는 위헌무효설, ⑤ 보상입법부작위에 대하여 헌법재판소에 헌법소원을 제기하여서 해결하여야 한다는 보상입법부작위위헌설, ⑥ 헌법 제23조 제3항이 불가분조항이 아니므로 헌법 제37조 제2항에 의해 손실보상청구권을 인정할 수 있다는 학설 등이 대립한다.

3. 판례

---

60) 헌법 제23조 제3항이 불가분조항인지 여부

1. 불가분조항이 아니라고 보는 견해

독일기본법 제14조 제3항은 보상을 요하는 재산권침해로서 공용수용만을 규정하고 있고 이러한 공용수용의 경우 반드시 보상규정을 두어야 하도록 규정하고 있으므로 불가분조항이나, 우리 헌법 제23조 제3항은 보상을 요하는 재산권의 침해로서 공용수용뿐만 아니라 공용사용 및 공용제한을 아울러 규정하고 있고, 이러한 재산권침해유형의 경우에 언제나 보상을 해야하는 것이 아니라 그 보상여부조차 입법자의 형성에 맡겨져 있다고 주장한다. 따라서 공용침해라 하더라도 헌법 제23조 제3항에 의해 입법자에게 보상입법의무가 발생하는 것은 아니라고 본다.

다만 이 견해는 보상규정없는 공용침해(23조 제3항)의 경우에도 손실을 보상해주지 않는 것이 재산권의 본질적 내용을 훼손하는 정도에 이르는 경우(헌법 제37조 제2항 위반)에는 법관이 헌법상 재산권보장(23조 제1항), 기본권의 본질적 내용 보장취지(헌법 제37조 제2항)에 따라 손실보상청구권을 인정해 줄 수 있다고 한다(김연태, 행정법사례연습 20번).

2. 불가분조항으로 보는 견해

이 견해는 헌법 제23조 제3항을 불가분조항으로 보아 제23조 제3항에 의한 재산권침해법률를 제정할 때는 반드시 보상입법을 하여야 한다고 한다. 즉, 공공복리달성을 위하여 개인의 재산권에 가해지는 의도적인 침해를 하는 경우 헌법 제23조 제3항에 따라 보상규정이 반드시 필요하다고 주장한다(보상입법의무는 기속이다).

⑴ 대법원의 입장

대법원은 보상규정없는 경우 불법행위로 처리한 경우도 있고, 독일법상의 수용유사침해이론의 도입에 대한 판단을 유보한 경우도 있으나, 대체로 공용침해로 인한 특별한 손해에 대한 보상규정이 없는 경우에 관련보상규정을 유추적용하여 보상하려는 경향이 있다.

위와 같은 대법원의 경향에 대하여 간접효력규정설은 판례가 간접효력규정설의 입장을 취하였다고 주장하나, 일부견해는 첫째 위 판례가 인정한 유추적용은 법의 일반적 해석원칙에 따라 개별적으로 검토하여 유사한 재산권침해규정이 보상규정을 둔 경우에 이를 유추적용한 것에 불과하여 통상적인 법률의 흠결을 보충하는 해석론에 불과하다는 점, 둘째 보상규정 없는 경우란 관련법규상의 보상규정의 유추적용자체가 불가능한 경우를 의미한다는 점 등을 논거로 위 판례들이 간접효력규정설의 입장을 취하지 않았다고 보는 것이 타당하다고 주장한다.

⑵ 헌법재판소의 입장

헌법재판소는 개발제한구역지정을 규정한 구 도시계획법 제21조에 대한 위헌형 헌법소원에서 분리이론을 취하고 있다.

제4 손실보상청구권의 법적성질과 발생요건

Ⅰ. 손실보상청구권의 법적 성질

1. 학설

⑴ 공권설

손실보상의 원인행위가 공권력의 행사이므로 그 효과로서 손실보상청구권 역시 공권으로 보아야 한다는 견해이다. 손실보상청구권을 공권으로 보는 경우에는 그에 관한 소송은 행정소송인 당사자소송이 된다. 통설적 견해이다.

⑵ 사권설

손실보상의 원인행위가 공법적인 것이라도 이에 대한 손실보상은 당사자의 의사 또는 직접 법률의 규정에 의거한 사법상의 채권채무관계라는 견해이다.

2. 판례

판례는 과거 손실보상청구권을 대부분 사권으로 보고 민사소송에 의하여 이를 청구하여야 한다고 보았으나,

하천법과 관련된 손실보상청구권에 대하여 최근 전원합의체판결(대판[전합] 2006. 5. 18, 2004다6207)로 “위 규정들에 의한 손실보상청구권은 1984. 12. 31. 전에 토지가 하천구역으로 된 경우에는 당연히 발생되는 것이지, 관리청의 보상금지급결정에 의하여 비로소 발생하는 것은 아니므로, 위 규정들에 의한 손실보상금의 지급을 구하거나 손실보상청구권의 확인을 구하는 소송은 행정소송법 제3조 제2호 소정의 당사자소송에 의하여야 한다”라고 판시하여 종래의 입장을 변경하여 공권으로 보고 있다.

3. 검토

행정상 손실보상제도는 공법상의 제도이고, 또한 현행 행정소송법이 행정청의 처분 등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송을 당사자소송으로 규정하는 있는 만큼 손실보상청구권을 공권으로 보아야 한다.

Ⅱ. 손실보상청구권의 발생요건(헌법 제23조 제3항)

1. 공공필요에 의한 재산권의 사용·수용·제한

⑴ 공공필요

공공필요라는 개념은 공익이라는 개념과 같은 것이라고 볼 수 있다. 다만, 오늘날 '사인을 위한 수용'이 인정됨에 따라 공공필요는 상당히 넓은 개념이 되고 있다. 오늘날 공공필요는 국가안전보장, 질서유지, 공공복리와 함께 국가 또는 지역경제상의 이익도 포함한다.

⑵ 적법한 공권적 침해

보상청구권이 성립하기 위해선 재산권에 대한 공권적 침해가 있어야 한다. 여기에서 침해란 일체의 재산적 가치의 감소를 의미하며, '공권적'이란 '공법상의 것'을 의미한다.

⑶ 재산권에 대한 침해

여기에서 재산권이란 소유권, 기타 법에 의해서 보호되는 일체의 재산적 가치 있는 권리를 의미한다. 이러한 재산권에는 사법상의 권리만이 아니라 재산적 가치를 지닌 공법상의 권리도 포함된다. 그러나 지가의 상승과 같은 기대이익은 보호받지 못한다.

2. 특별한 희생의 존재

⑴ 학설

① 특정인 또는 특정 집단에게 재산권침해가 가해지면 특별희생으로 보는 형식적 기준설과 ② 재산권 제한의 성질 내지 강도와 같은 실질적 기준으로 특별희생을 판단하는 실질적 기준설이 대립한다.

⑵ 판례

1) 대법원

대법원은 개발제한구역지정에 관한 구 도시계획법 제21조 제1항, 제2항의 위헌심판제청신청 사건에서 개발제한구역지정에 의한 토지소유자의 재산권 행사의 제한은 사회적 제약이라고 판시하였다.

2) 헌법재판소

개발제한구역지정으로 토지를 종래 목적대로 사용할 수 있는 경우와 종래 목적대로 사용할 수 없거나 실질적으로 사용 수익의 길이 막히는 경우로 나누어, 전자는 사회적 제한이지만 후자는 수인한계를 넘은 것으로 비례성원칙위반이라고 판시하였다(분리이론).

제5 손실보상의 방법

Ⅰ. 지급방법

손실보상금은 현금으로 지급함이 원칙이지만 예외로 채권보상과 현물보상이 인정된다. 그리고 선급금의 방법(사전보상), 개별급의 방법(개인별 보상), 전액급의 방법(일괄보상)에 의함이 원칙이다.

Ⅱ. 결정방법

1. 서

손실보상금의 결정방법은 손실보상의 절차이며 손실보상의 불복의 절차이기도 하다. 결정방법의 유형에는 첫째로 당사자의 협의에 의하는 경우가 있다. 토지보상법상 사업시행자와 토지소유자 및 관계인이 손실보상에 관한 협의가 이에 해당한다. 둘째로 행정청의 결정에 의하는 경우가 있다. 토지보상법상 토지수용위원회의 수용재결이 이에 해당한다. 셋째로 소송에 의하는 경우가 있다.

2. 협의(토지보상법 제26조 제2항).

3. 행정청에 의한 결정 - 토지수용위원회의 재결(수용을 포함한 보상액재결)에 의한 결정

⑴ 토지수용위원회의 수용재결

토지수용위원회는 보상액을 재결의 형식으로 수용 등과 함께 결정한다(토지보상법 제50조).

⑵ 불복절차

1) 이의신청의 제기

① 이의신청 - 특별행정심판(토지보상법 제83조) : 30일이내에 중토위에 해야 함

② 이의신청에 대한 재결

2) 행정소송

① 제소기간

사업시행자 토지소유자 또는 관계인은 제34조 규정에 의한 수용재결에 불복이 있는 때에는 재결서를 받은 날로부터 60일 이내에, 이의신청을 거친 때에는 이의신청에 대한 이의재결서를 송달받은 날로부터 30일 이내에 각 각 행정소송을 제기할 수 있다(동법 제85조 제1항). 이러한 소송에는 행정소송법 제18조, 행정소송법 제20조(제소기간)의 규정은 적용되지 않는다.

② 소의대상

구 토지수용법하에서 학설은 재결주의를 취한 것으로 보아 중앙토지수용위원회의 이의재결만이 취소소송의 대상이 된다는 견해와 원처분주의로 보아 이의재결에 고유한 위법이 없는 한 원처분인 수용재결이 취소소송의 대상이 된다는 견해가 대립하였다. 판례는 구 토지수용법이 재결주의를 취하고 있는 것으로 해석하였다(대판 1991. 2. 12, 90누288).

그러나 현행 토지보상법은 원처분주의를 취한 것으로 보인다. 즉, 사업시행자·토지소유자 또는 관계인은 제34조의 규정에 의한 수용재결에 대하여 불복이 있는 때에는 그 수용재결을 대상으로 행정소송을 제기할 수 있되 다만 제소기간을 수용재결을 대상으로 곧바로 행정소송을 제기할 때에는 수용재결서를 받은 날로부터 60일 이내에, 이의신청을 거친 때에는 이의신청에 대한 재결서를 받은 날로부터 30일 이내에 각각 행정소송을 제기하도록 규정하였다(동법 제85조 제1항).

따라서 이의재결을 거쳤다 하더라도 이의재결에 고유한 위법이 없는 한 원처분인 수용재결에 대하여 이의재결서를 받은 날로부터 30일 이내에 취소소송을 제기하여야 한다.

⑤ 보상금증감소송

토지보상법 제85조 제2항은 “제1항에 따라 제기하려는 행정소송이 보상금의 증감에 관한 소송인 경우 그 소송을 제기하는 자가 토지소유자 또는 관계인일 때에는 사업시행자를, 사업시행자일 때에는 토지소유자 또는 관계인을 각각 피고로 한다”고 규정하여, 보상금의 증감에 관한 소의 피고를 사업시행자 또는 토지소유자 등으로 하고 토지수용위원회를 피고에서 제외시켰다.

토지보상법이 행정청을 피고에서 제외함에 따라 이 소송은 전형적인 형식적 당사자소송이라고 할 것이다. 즉, 처분을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송으로서 그 원인이 되는 처분 등에 불복하여 소송을 제기함에 있어 처분청을 피고로 하는 것이 아니라 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송에 해당한다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 손실보상에 대한 설명으로 틀린 것은? (2001 국가직 7급)

① 손실보상제도의 이론적 근거는 정의와 형평의 원리이다.
② 손실보상액을 결정함에 있어서 사업시행자의 재산상태를 고려해야 한다.
③ 토지수용시 금전보상이 원칙이나, 채권보상을 할 수 있다.
④ 특허권을 수용한 경우에도 손실보상의 원인이 된다.
⑤ 공용수용절차의 개시점은 사업인정이다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

협의 또는 재결에 의하여 취득하는 토지에 대하여는 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 의한 공시지가를 기준으로 하여 보상하되, 그 공시기준일부터 가격시점까지의 관계법령에 의한 공시지가를 기준으로 하여 보상하되, 그 공시기준일로부터 가격시점까지의 관계법령에 의한 당해 토지의 이용계획, 당해 공익사업으로 인한 지가의 영향을 받지 아니하는 지역의 대통령령이 정하는 지가변동률, 생산자물가상승률(한국은행법 제86조의 규정에 의하여 한국은행이 조사·발표하는 생산자물가지수에 의하여 산정된 비율을 말한다) 그 밖에 당해 토지의 위치·형상·환경·이용상황 등을 참작하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다(공익사업을위한토지등의취득및보상에관한법률 제70조 제1항). 따라서 사업시행자의 재산상태는 고려대상이 아니다.

정답 ②

2. 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (2002 행정고시)

① 개발이익환수는 토지투기의 방지와 부의 형평배분 등을 실현하기 위하여 필요하다.
② 국가가 시행하는 개발사업에 대하여는 개발부담금을 부과하지 아니한다.
③ 택지개발사업은 개발부담금의 부과대상사업이다.
④ 「개발이익환수에 관한 법률」에 따르면 개발부담금의 납부방법으로 채권납부가 가능하다.
⑤ 개발부담금의 부과대상토지의 가격결정에 있어서 지방세법에 의한 시가표준액을 그 기준으로 할 수 없다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

개발부담금은 현금에 의한 납부를 원칙으로 하되, 당해 부과대상토지 및 그와 유사한 토지에 의한 납부(물납)를 인정할 수 있다(개발이익환수에관한법률 제18조 제2항).

정답 ④

3. 헌법 제23조는 "① 모든 국민의 재산권은 보장된다. 그 내용과 한계는 법률로 정한다. ② 재산권의 행사는 공공복리에 적합하도록 하여야 한다. ③ 공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다."라고 규정하고 있다. 다음 설명 중 옳은 것은? (2008 국가직 7급)

① 재산권의 사회적 제약과 공용침해는 별개의 제도가 아니라 재산권규제의 강도에 따라서 상대적으로 구분되는 것으로 사회적 제약의 경계를 벗어나면 보상의무가 있는 공용침해로 전환된다고 보는 경계이론은 독일의 연방헌법재판소의 판결에서 유래한다.

② 헌법 제23조 제3항을 입법자에 대한 구속규정으로 보는 위헌무효설에 따르면, 보상규정이 없는 공용침해법률은 위헌법률이 되며 이러한 위헌법률에 근거한 공용침해는 위법한 공용침해에 해당하기 때문에 그러한 고용침해에 대해서는 다른 법률의 유추해석을 통하여 보상이 주어져야 한다고 본다.

③ 사회적 제약을 벗어나는 무보상의 공용침해에 대하여, 분리이론은 당해 침해행위의 폐지를 주장함으로써 위헌적 침해의 억제에 중점을 두고 있음에 비하여 경계이론은 보상을 통한 가치의 보장에 중점을 두고 있다.

④ 개발제한구역지정으로 말미암아 일부 토지소유자에게 사회적 제약의 범위를 넘는 가혹한 부담이 발생하는 예외적인 경우임에도 보상규정을 두지 않은 것이 위헌이라는 견해는 보상을 통한 가치의 보장을 강조하는 입장이다.

⑤ 근래 대법원은 재산권의 내용 결정과 수용(공용침해)의 구분과 관련하여 이른바 분리이론적 접근을 한다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 독일연방헌법재판소에 의해 제시된 것은 분리이론이고, 경계이론은 독일의 연방최고법원과 연방행정법원에 의해 지지된 견해이다.

② 위헌무효설에 의하면 국가배상청구에 의하고, 설문의 유추해석을 통한 해결책은 유추적용설(간접효력규정설)의 내용이다.

④ 보상을 통한 가치의 보장을 강조하는 입장이 아니라 위헌적 침해의 억제에 중점을 두는 입장이다.

⑤ 헌법재판소의 입장이다(헌재 1999.10.21, 97헌바26).

정답 ③

♣ 학습내용 정리

1. 헌법 제23조의 해석과 관련하여 경계이론과 분리이론이 대립한다.
2. 헌법 제23조 제3항의 해석과 관련하여 직접효력설, 유추적용설, 위헌무효설 등이 대립한다.

제30강 손실보상 및 행정심판

♣ 학습목표

현행 행정상 손해전보제도의 흠결과 보완에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
행정심판의 개관을 이해하고 행정심판의 청구요건을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

행정상 손해전보제도의 흠결과 보완
행정심판의 개관
행정심판청구요건

♣ 사전테스트

1. 위법 무과실 영역에서의 재산적 피해에 대하여 국가배상청구권으로 해결하자는 것이 우리 나라 학설의 일치된 견해이다.
   정답 : X

2. 행정심판에는 예방적 부작위심판이 존재한다.
   정답 : x

3. 행정심판의 청구인적격에 대하여 입법의 과오인지 학설의 대립이 있다.
   정답 : O

♣ 돌발퀴즈

처분 또는 부작위의 위법성뿐만 아니라 부당성도 심사의 대상이다.

[정답] O
[해설] 행정심판법 제5조

♣ 강의내용

제1 현행 행정상 손해전보제도의 흠결과 보완

Ⅰ. 국가배상법의 흠결과 보완

1. 위법무과실한 재산권침해

⑴ 독일
수용유사침해이론 : 취소소송제기가 불가능한 경우에 한해서 프로이센 일반란트법 제74조, 제75조에 의해 보상청구권인정.

⑵ 우리나라
1) 입법론 : 국가배상법에서 과실요건 삭제.
2) 해석론
과실의 객관화통한 국가배상청구권인정.

2. 위법무과실한 비재산권침해

⑴ 독일
희생유사침해이론 : 프로이센 일반란트법 제74조, 제75조에 의해 보상청구권인정.

⑵ 우리나라
1) 입법론 : 국가배상법에서 과실요건 삭제.
2) 해석론
과실의 객관화통한 국가배상청구권인정.

Ⅱ. 손실보상의 흠결과 보완

1. 헌법 제23조에 대하여 경계이론을 취하고 헌법 제23조 제3항을 불가분조항으로 볼 때 손실보상청구권의 성립요건
① 공공필요
② 적법한 공권력행사
③ 재산권에 대한 의도적 침해
④ 특별희생
⑤ 보상규정

2. 경계이론과 불가분조항으로 보는 견해에 의할 때 손실보상제도의 흠결

⑴ ① 내지 ④요건충족, 보상규정 무.

⑵ ① ② ④요건 충족, 재산권비의도적침해, 보상규정 무.

⑶ ① ② ④요건 충족. 비재산권참해, 보상규정 무

3. 각 흠결에 대한 보완

⑴ ⑴영역에 대하여

1) 독일

수용유사침해이론 : 취소소송제기가 불가능한 경우에 한해서 프로이센 일반란트법 제74조, 제75조에 의해 보상청구권인정.

2) 우리나라

가) 분리이론 - 원칙적으로 취소소송, 예외적으로 입법자가 비례원칙위반되지 않게 보상입법(꼭 금전보상만 의미하는 것은 아님)하면 보상입법에 의한 보상가능[61].

나) 경계이론

- 직접효력설 : 헌법 제23조 제3항의 손실보상청구권성립요건[62] 충족하므로 손실보상청구권성립, 공법상 당사자소송으로 손실보상청구소송제기하여 인용받을 수 있음.

- 간접효력규정설 : 헌법 제23조 제3항 유추적용하여 손실보상권 성립. 공법상 당사자소송으로 손실보상청구소송제기하여 인용받을 수 있음.

- 위헌무효설 : 취소소송 또는 국가배상청구소송.

⑵ ⑵ 영역에 대하여

1) 독일

수용적 침해이론 : 프로이센 일반란트법 제74조, 제75조에 의해 보상청구권인정.

2) 우리나라

가) 분리이론 - 원칙적으로 취소소송, 예외적으로 입법자가 비례원칙 위반되지 않게 보상입법(꼭 금전보상만 의미하는 것은 아님)하면 보상입법에 의한 보상가능 .

나) 경계이론

- 직접효력설 : 헌법 제23조 제3항의 유추적용 및 공평부담의 원칙에 근거하여 손실보상청구권 성립, 공법상 당사자소송으로 손실보상청구소송 제기하여 인용받을 수 있음.

- 간접효력규정설 : 헌법 제23조 제3항 유추적용하여 손실보상권 성립. 공법상 당사자소송으로 손실보상청구소송제기하여 인용받을 수 있음.

- 위헌무효설 : 입법적으로 해결할 수 밖에 없음 - 비의도적재산권침해는 헌법 제23조 제3항의 재산권침해법률이 아닌 바 금전보상규정을 두지 않아도 헌법 제23조 제3항 위반의 위헌이 아니다.

---

61) 분리이론에 따르면 특별희생이 발생한 재산권제한법률에 보상규정이 없는 경우 일단 재산권의 내용규정(헌법 제23조 제1항, 제2항)으로 재산권제한이 의도적이든 비의도적이든 상관없이 당해 재산권제한법률은 과도한 재산권제한으로 헌법 제37조 제2항의 비례원칙위반으로 위헌이 법률이 된다.

62) 직접효력설은 헌법 제23조 제3항을 불가분조항으로 보지 않으므로 헌법 제23조 제3항의 손실보상청구권의 성립요건을 ① 공공필요, ② 적법한 공권력행사로 인한 재산권침해(의도적인가 비의도적인가 상관없음), ③ 특별희생으로 보고 개별법규에 보상규정이 없더라도 위 세 요건을 충족하면 헌법 제23조 제3항이 직접 적용되어 구체적인 손실보상청구권이 발생하였다고 본다.

⑶ ⑶영역에 대하여

1) 독일
희생보상청구권 : 프로이센 일반란트법 제74조, 제75조에 의해 보상청구권인정.

2) 우리나라의 경우
가) 보상부정설) : 입법적 해결
나) 간접효력규정설
헌법 제10조, 제12조, 제37조 제1항과 제11조 등을 간접근거로 보상청구권을 인정
다) 희생침해보상설
독일의 희생보상이론을 원용하면서 헌법 제23조 제3항을 유추적용하여 보상청구권을 인정하자는 견해, 헌법 제23조 제3항의 규정에 의한 손실보상이 법리적 기초를 이루는 특별희생보상의 법리와 헌법상 법치주의, 평등원칙으로 보상청구권을 인정하자는 견해, 헌법 제10조, 제12조, 제37조 제1항, 제2항에 의해 보상청구권을 인정하자는 견해
다) 제4설
헌법 제23조 제3항을 유추적용하고, 헌법상 기본권보장조항(제10조와 제12조) 및 평등조항(제11조)을 직접 근거로 하여 보상청구권 인정.

제2 행정심판 개설

Ⅰ. 행정심판의 의의

1. 개 념
실질적 의미의 행정심판이란 널리 행정법상의 분쟁에 대하여 행정기관이 심리·판정하는 행정쟁송절차를 말한다. 실정법상 이의신청, 심사청구, 심판청구 등의 다양한 용어가 사용되고 있다. 형식적 의미의 행정심판이란 행정심판법의 적용받는 행정심판만을 의미한다.

2. 행정심판의 성격 - 준사법작용, 행정행위

Ⅱ. 행정심판의 존재이유
행정심판은 자율적 행정통제, 사법기능의 보완, 법원의 부담경감 등에 그 의의가 있다.

제3 행정심판법상의 행정심판의 종류·대상

Ⅰ. 행정심판의 종류
행정심판법상의 행정심판의 종류에는 취소심판, 무효등확인심판, 의무이행심판의 세 가지가 있다.

⑴ 취소심판
행정청의 위법 또는 부당한 처분의 취소 또는 변경을 구하는 심판이다.

⑵ 무효등확인심판

무효등확인심판이란 행정청의 처분의 효력유무 또는 존재여부에 대한 확인을 구하는 심판을 말한다.

⑶ 의무이행심판 : 제3절 참조

Ⅱ. 행정심판의 대상 - 처분과 부작위 : 항고소송의 대상과 동일(후술)

Ⅲ. 거부처분에 대하여 취소심판 제기가 가능한지

⑴ 학설

① 행정심판법 제5조 제3호에 의할 때 거부처분은 의무이행심판의 대상이지 취소심판의 대상이 아니라는 견해와 ② 행정심판법 제2조 제1호의 처분의 정의규정과 제5조 제1호의 취소소송의 정의규정에 비추어 거부처분취소심판의 가능성을 인정하는 견해(다수설)이 대립한다.

⑵ 판례

판례는 거부처분에 대한 취소심판을 제기할 수 있다는 입장이다(88누7880).

제3 행정심판기관 - 행정심판위원회

행정심판법은 행정심판위원회에게 재결권을 부여하였다. 이는 행정심판위원회가 행정심판사건에 대하여 직접 재결을 하도록 하는 등 절차 간소화를 통하여 사건 처리기간을 대폭 단축함으로써 창구 일원화의 효과를 극대화하고 행정심판제도의 본래 취지인 신속한 권리구제에 기여하려는 것임.

제4 당사자와 관계인

Ⅰ. 당사자

행정심판법은 심판절차를 대립하는 이해관계를 가진 청구인과 피청구인이라는 두 당사자 사이에 대심구조로 편성하고, 서면심리와 함께 구술심리의 기회를 부여하여 헌법 제107조 제2항의 취지에 따라 사법절차에 준하도록 하고 있다.

1. 청구인

청구인이란 행정심판의 대상인 행정청의 처분 또는 부작위에 불복하여 그 취소·변경 등을 위해 행정심판을 제기하는 자를 말한다.

2. 피청구인

피청구인이란 심판청구인의 상대편 당사자를 말한다.

⑴ 피청구인적격 - 처분행정청

문서에 기재되어 있는 외부 명의자라고 한다.

⑵ 피청구인의 경정(동법 제17조 제2항).

⑶ 권한승계에 따른 경정(동법 제17조 제5항).

Ⅱ. 행정심판의 관계인

1. 참가인(행정심판법 제20조 제1항)

2. 대리인(동법 제18조)

제5 행정심판의 청구인적격

Ⅰ. 서 론

행정심판청구의 제기요건 중 하나인 '청구인적격'은 누가 행정심판을 청구할 수 있는 자격을 갖는가에 관한 문제로서, 그것의 범위확정은 불필요한 남소의 방지라는 청구인적격의 본래의 기능과 행정의 자기통제라는 행정심판의 기능을 수행하는 기본적인 사항이라고 할 수 있다. 즉, 청구인적격의 문제는 행정심판제도의 기능과 청구인적격 자체의 기능을 비교형량하여 결정할 입법정책적 문제라고 할 수 있다.

현행 행정심판법은 독일이나 일본과는 다르게, 행정소송에서와 같이 '법률상 이익이 있는 자'로 청구인적격을 한정하고 있다(행정심판법 제13조). 이러한 행정심판법의 규정에 대하여 행정심판은 '위법·부당'한 처분에 대한 쟁송이며 행정소송은 '위법'한 처분에 대한 쟁송이므로 원고적격과 청구인적격은 달라야 한다는 주장이 제기되어 논쟁이 되고 있다.

Ⅱ. 행정심판법상 청구인적격 - 법률상 이익(동법 제13조)

Ⅲ. 행정심판 청구인적격상의 문제점

1. 입법과오설

이 설은 ① 부당한 처분을 행정심판의 대상으로 하면서 부당한 처분으로는 침해될 수 없는 법률상 이익을 청구인적격으로 요구하는 것은 모순된다는 점, ② 독일이나 일본은 청구인적격으로 법률상 이익을 요구하고 있지 않다는 점 등을 논거로 입법상의 과오라고 주장한다.

2. 입법비과오설

이 설은 ① 부당한 처분으로도 법률상 이익이 침해될 수 있다는 점, ② 반사적 이익을 향수하기 위한 경우까지 행정심판의 청구인적격을 인정하게 되면 행정심판의 남용이 있을 수 있다는 점 등을 논거로 한다.

3. 입법미비설

법률상 이익은 위법처분뿐만 아니라 부당한 처분 또는 적법한 처분으로도 침해될 수 있으므로 입법과오는 아니나, 반사적 이익침해도 다툴 수 있는 가능성을 배제한 것은 입법의 미비라고 주장한다.

제6 심판청구의 제기요건

Ⅰ. 대상적격(행정심판법 제2조 및 제3조)

처분 또는 부작위 -자세한 내용은 후술 항고소송의 대상적격 참조

Ⅱ. 청구인적격(행정심판법 제13조)

법률상 이익 - 자세한 내용은 전술한 제6절 참조

Ⅲ. 피청구인적격(행정심판법 제17조 제1항)

처분행정청 및 신청 받은 행정청 - 자세한 내용은 전술참조

Ⅳ. 심판제기의 이익 - 협의의 소익과 내용동일

철거 명령에 대한 취소심판을 제기했는데 소송 도중 대집행실행이 완료돼서 건물이 철거됨, 철거 면허 취소심판에 대해서 취소 재결을 받으실 일이 없다. 이런 경우에는 행정심판 청구를 행정심판에 대해서 각하 재결을 내려야 된다.

Ⅴ. 심판청구기간(행정심판법 제27조)

행정심판은 행정법관계의 조속한 안정을 기하기 위하여 심판청구기간에 일정한 제한을 두고 있다. 다만 이것은 그 성질상 취소심판과 거부처분에 대한 의무이행심판에만 적용되고 무효등확인심판과 부작위에 대한 의무이행심판에는 적용되지 않는다(행정심판법 제27조 제6항).

1. 원칙적 심판청구기간

심판청구는 원칙적으로 처분이 있음을 안 날로부터 90일 이내, 처분이 있은 날로부터 180일 이내에 제기하여야 한다.

2. 예외적 심판청구기간

청구인이 처분이 있음을 알았더라도 천재·지변·전쟁·사변 그밖에 불가항력으로 인하여 앞에서 말한 90일 이내에 심판을 청구할 수 없었을 때는 그 사유가 소멸한 날로부터 14일(국외에서는 30일) 이내에 제기하면 된다. 이 기간은 불변기간이다.

180일 이내에 제기하지 못한 '정당한 사유'가 있는 경우에는 180일이 경과한 후라도 제기할 수 있다. 이 기간은 불변기간이 아니다. 무엇이 '정당한 사유'에 해당하는가는 심판위원회에서 합리적으로 판단할 문제이나, 위의 불가항력보다는 넓은 개념으로 보아야 한다.

판례는 제3자효적 행정행위에서 처분의 상대방이 아닌 제3자는 일반적으로 처분이 있는 것을 바로 알 수 없는 처지에 있으므로 처분이 있은 날로부터 180일이 지나도 '정당한 사유'가 있는 것으로 보아 적법하게 취소심판을 제기할 수 있다고 판시하였다(대법원 1992. 7. 28, 91누12844).

3. 심판청구기간의 오고지·불고지

행정청은 서면에 의한 처분을 하는 경우에 처분의 상대방에게 그 처분에 대하여 행정심판을 제기할 수 있는가의 여부와, 심판청구가 가능한 것인 때에는 그 심판청구절차·심판청구기간을 고지하여야 하는바(동법 제58조), ① 착오로 심판청구기간을 소정의 기간보다 장기로 고지한 경우(오고지)에는 그 고지된 기간 내에 제기하면 되고, ② 심판청구기간을 고지하지 않은 경우(불고지)에는 처분이 있은 날로부터 180일 이내에 심판청구를 하면 된다(동법 제27조 제5항, 제6항).

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 행정심판제도에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (2003 입법고시)

① 현행 행정심판제도에 의하면 원칙적으로 행정심판 전치주의가 적용되지 아니한다.
② 행정심판절차는 행정의 자체 통제제도라는 점에서 행정절차의 범주에 속한다.
③ 행정심판 청구인적격 판단에 있어서는 개인의 주관적 공권에 관한 법리가 깊이 연관된다.
④ 행정소송제도에서와 마찬가지로 행정청의 이행을 요구하는 심판청구가 가능하다.
⑤ 행정심판에 있어서도 불가쟁력제도가 있다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

행정소송에서는 의무이행소송이 인정되지 않는데, 행정심판에서는 의무이행심판이 인정된다. 이 점에서 행정소송제도와 행정심판제도가 다르다.

정답 ④

2. 행정심판법상의 의무이행심판에 대한 설명으로 옳은 것은? (2006 관세사)

① 행정청의 부작위에 대하여는 그 위법을 확인하는 재결만 할 수 있다.
② 거부처분에 대하여도 의무이행심판을 제기할 수 있다.
③ 인용재결로 행정심판위원회가 처분청을 대신하여 처분할 수 없다.
④ 처분청이 의무이행을 명하는 재결에 따르지 않으면 간접강제를 한다.
⑤ 인용재결에 대하여 처분청은 행정소송으로 불복할 수 있다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 위원회는 의무이행심판의 청구가 이유 있다고 인정할 때에는 지체 없이 신청에 따른 처분을 하거나(처분재결, 형성재결) 이를 할 것을 명한다(처분명령재결, 이행재결)(행정심판법 제43조 제5항).
② 의무이행심판은 행정청의 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 하는 심판을 말한다(동법 제5조 제3호).
③④ 위원회는 당해 행정청이 처분을 하지 아니하는 경우에는 당사자가 신청하면 기간을 정하여 서면으로 시정을 명하고 그 기간에 이행하지 아니하면 직접 처분을 할 수 있다(동법 제50조 제1항). 간접강제는 재결의 기속력확보수단이 아니라, 판결의 기속력확보수단이다.
⑤ 행정심판에서 기각재결이 있는 경우 사인인 청구인은 당연히 취소소송을 제기할 수 있다. 그러나 인용재결이 있는 경우, 피청구인인 행정청은 재결의 기속력(동법 제49조 제1항)으로 인해 취소소송을 제기할 수 없다.

정답 ②

3. 행정심판에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (2009 지방직 7급)

① 행정심판의 제기는 처분청을 경유하여야 한다.
② 행정심판사항에 대해 개괄주의가 채택되고 있다.
③ 처분 또는 부작위의 위법성뿐만 아니라 부당성도 심사의 대상이다.
④ 불고불리의 원칙이 적용된다.
⑤ 취소심판은 청구기간이 제한을 받는다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 행정심판법은 "심판청구서는 피청구인이나 위원회에 제출하여야 한다(제23조 제1항)"라고 규정함으로써 종래의 처분청경유주의를 폐지하고, 청구인의 선택에 의하도록 했다.
② 동법 제3조 제1항
③ 동법 제5조
④ 동법 제47조 제2항
⑤ 동법 제27조

정답 ①

♣ 학습내용 정리

1. 행정심판법상 행정심판에는 취소심판, 무효 등 확인심판, 의무이행심판이 존재한다.
2. 행정심판법상 청구인적격이 입법의 과오인가에 대하여 학설의 대립이 있다.

제31강 행정심판

♣ 학습목표

행정심판법상 가구제 수단인 임시처분에 대하여 설명할 수 있다.
행정심판에 대한 재결 절차 및 그 효력에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

임시처분
재결의 종류 및 효력

♣ 사전테스트

1. 집행정지가 가능하더라도 임시처분을 할 수 있다.
   정답 : X

2. 행정심판에는 불고불리원칙이 적용되지 않는다.
   정답 : x

3. 행정심판의 재결의 효력으로 기속력, 불가변력, 형성력 등이 인정된다.
   정답 : O

♣ 돌발퀴즈

행정심판은 준사법절차로서 진술과 증거조사를 구술에 의하도록 하는 구술심리주의를 원칙으로 하고 있다.

[정답] ×

[해설] 정심판의 심리는 구술심리나 서면심리로 한다. 다만, 당사자가 구술심리를 신청한 경우에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다(동법 제40조 제1항). 동조항의 해석에 대해서 서면심리 우선설, 구술심리 우선설의 견해 대립이 있으므로 단정적으로 구술심리주의를 원칙으로 한다고 말할 수 없다.

♣ 강의내용

제1 행정심판청구의 제기

Ⅰ. 심판청구의 방식

1. 서면주의

심판청구는 일정한 사항을 기재한 서면으로 하여야 한다(행정심판법 제28조). 심판청구서에의 필요적 기재사항은 행정심판법 제28조 제2항 내지 제5항에서 규정하고 있다.

2. 행정심판청구서 제출절차(동법 제23조)

심판청구서는 피청구인인 행정청(처분청) 또는 위원회에 제출하여야 한다.

3. 답변서의 제출(동법 제24조)

Ⅱ. 행정심판제기의 효과

1. 행정심판위원회에 대한 효과

심판청구가 제기되면 행정심판위원회는 재결할 의무를 진다.

2. 처분에 대한 효과

⑴ 원 칙(집행부정지원칙)

행정심판이 제기되어도, 그것은 원칙적으로 처분의 효력이나 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 않는다(동법 제30조 제1항). 집행부정지원칙의 근거에 관하여 종래는 행정행위의 공정력에 기인한다고 보았으나, 오늘날은 행정심판의 남용방지와 행정목적의 원활한 수행이라는 입법정책에 따른 것으로 보고 있다.

⑵ 예외(집행정지)

행정심판위원회는 일정한 요건 하에서 당사자의 신청 또는 직권으로 처분의 효력이나 그 집행 또는 속행의 전부 또는 일부의 정지를 결정할 수 있다. 행정소송법 제23조 제2항의 집행정지의 요건보다 완화하여 '중대한 손해'를 요건으로 규정하였다.

집행정지결정은 처분의 효력, 처분의 집행 또는 절차속행의 전부 또는 일부를 정지시킨다. 다만, 처분의 집행 또는 절차속행을 정지함으로써 그 목적을 달성할 수 있을 때에는 처분의 효력을 정지시킬 필요까지는 없으므로, 이러한 경우에는 처분의 효력정지가 허용되지 않는다.

⑶ 임시처분[63]

---

63) 제31조(임시처분) ① 위원회는 처분 또는 부작위가 위법·부당하다고 상당히 의심되는 경우로서 처분 또는 부작위 때문에 당사자가 받을 우려가 있는 중대한 불이익이나 당사자에게 생길 급박한 위험을 막기 위하여 임시지위를 정하여야 할 필요가 있는 경우에는 직권으로 또는 당사자의 신청에 의하여 임시처분을 결정할 수 있다.

② 제1항에 따른 임시처분에 관하여는 제30조 제3항부터 제7항까지를 준용한다. 이 경우 같은 조 제6항 전단 중 "중대한 손해가 생길 우려"는 "중대한 불이익이나 급박한 위험이 생길 우려"로 본다.

③ 제1항에 따른 임시처분은 제30조 제2항에 따른 집행정지로 목적을 달성할 수 있는 경우에는 허용되지 아니한다.

1) 의의

행정심판법 제31조 제1항은 임시처분제도를 새롭게 도입하였다.

이는 행정심판의 청구인이 처분이나 부작위에 의하여 회복하기 어려운 손해를 입게 되는 경우 종전의 집행정지제도만으로는 청구인의 권익을 구제하기가 어려웠는 바, 행정청의 처분이나 부작위 때문에 발생할 수 있는 당사자의 중대한 불이익이나 급박한 위험을 막기 위하여 당사자에게 임시지위를 부여할 수 있는 임시처분제도를 도입함으로써 집행정지에 비해 보다 적극적으로 당사자의 임시적 권익보호에 기여하기 위해 도입한 것이다.

그런데 임시처분은 행정심판법 제30조 제2항에 따른 집행정지로 목적을 달성할 수 있는 경우에는 허용되지 아니한다(동법 제31조 제3항) 따라서 적극적인 처분이 이미 나온 경우에는 집행정지제도를 통해 가구제를 하고, 소극적인 거부처분이나 부작위인 경우에는 임시처분제도를 통해 가구제를 하여야 한다. 임시처분은 위원회가 잠정적으로 허가권자의 지위를 부여하는 임시허가처분 등을 하는 형태가 될 것이다.

2) 요건[64]

① 적극적 요건

㈎ 심판청구의 계속 - 의무이행심판제기와 동시에 신청

㈏ 처분 또는 부작위가 위법 또는 부당하다고 상당히 의심되는 경우일 것

㈐ 당사자에게 중대한 불이익이나 급박한 위험을 방지할 필요가 있을 것

② 소극적 요건

㈎ 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 없을 것

㈏ 집행정지로 목적을 달성할 수 없을 것(31조 3항)

3) 임시처분절차

위원회는 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 임시처분을 결정할 수 있다.

위원회의 심리·결정을 기다릴 경우 중대한 손해가 생길 우려가 있다고 인정되면 위원장은 직권으로 위원회의 심리·결정을 갈음하는 결정을 할 수 있다(제31조 제2항, 제30조 제6항).

위원회는 임시조치 또는 임시조치의 취소에 관하여 심리 결정하면 지체없이 당사자에게 결정서 정본을 송달하여야 한다.

제2 행정심판의 심리

Ⅰ. 심리의 내용 및 범위

1. 심리의 내용

⑴ 요건심리(형식적 심리, 본안전 심리) - 못갖추면 각하재결(동법 제32조).

⑵ 본안심리(실질적 심리)

본안심리를 요건심리의 결과 심판청구를 적법한 것으로 받아들인 경우에, 당해 심판 청구의 내용에 관하여 실질적으로 심사하는 것을 말한다. 본안심리의 결과 심판청구가 이유 있으면 인용하고 그렇지 않으면 기각한다.

64) 홍정선, 행정법특강, 제589면.

2. 심리의 범위- 불고불리 및 불이익변경금지의 원칙(동법 제47조)

Ⅱ. 심리절차

1. 심리절차의 기본원칙

⑴ 대심주의
청구인과 피청구인이 대립하는 구조로 심리를 한다.

⑵ 직권심리주의와 가미(동법 제36조, 제39조)
행정수정보 26조와 마찬가지로 행정 집합 위원회가 필요하다고 이해기할 때는 청구인, 피청구인이 주장하지 아니한 사실도 심의의 대상으로 삼아서 할 수 있다.

⑶ 구술심리주의와 서면심리(동법 제40조).
행정심판은 서면 심리 만으로 가능하다.

⑷ 비공개주의 여부

2. 당사자의 절차적 권리
당사자의 절차적 권리 또는 행정심판위원·직원에 대한 기피신청권, 구술심리신청권 보충서면 제출권, 물적 증거제출권, 증거조사신청권 등이 있다.

Ⅲ. 관련청구의 병합과 분리(행정심판법 제37조)

제3 행정심판의 재결

Ⅰ. 재결의 의의
행정심판의 재결이란 행정심판의 청구에 대하여 행정심판위원회가 행하는 판단을 말한다. 재결은 행정법관계에 관한 분쟁에 대하여 확인·판단하는 행위이므로 법원의 판결과 성질이 비슷하다. 따라서 재결은 준사법적 행위, 확인행위, 기속행위의 성질을 갖는다.

Ⅱ. 재결기간(동법 제45조 제1항) - 60일 / 30일 연장가능
청구서를 받은 날로부터 60일 내 해야 되는게 원칙이고, 단지 부득이한 사정이 있으면 30일 연장해서 90일 최종적으로 본다면 90일까지는 행정심판 재결을 내려야 한다.

Ⅲ. 재결의 방식 - 서면주의(행정심판법 제46조 제1항)
말로 재결 할 수 없고 행정심판은 반드시 서면으로 재결해야 한다

Ⅳ. 재결의 범위

1. 불고불리의 원칙(행정심판법 제47조 제1항)
위원회는 심판청구의 대상이 되는 처분 또는 부작위 외의 사항에 대하여는 재결하지 못한다.

2. 불이익변경금지의 원칙(행정심판법 제47조 제2항)

위원회는 심판청구의 대상이 되는 처분보다 청구인에게 불리한 재결을 하지 못한다.

Ⅴ. 재결의 종류

1. 요건재결 - 각하재결

2. 본안재결

⑴ 기각재결 - 단순기각

⑵ 사정재결

행정심판위원회는 심판청구에 대한 심리의 결과 그 심판청구가 이유 있다고 인정하는 경우에도 이를 인용하는 것이 현저히 공공복리에 적합하지 아니하다고 인정하는 때에는 행정심판위원회의 의결에 의하여 그 심판청구를 기각하는 재결을 할 수 있는 바(동법 제44조 1항), 이를 사정재결이라 한다. 이러한 사정재결은 취소심판과 의무이행심판에서만 인정될 뿐 무효등확인심판에서는 인정되지 않는다.

⑶ 인용재결

인용재결이란 본안심리의 결과 심판청구가 이유있다고 인정하여 심판청구의 취지를 받아들이는 재결이다.

1) 취소변경재결(형성재결)/변경명령재결(이행재결)

취소심판의 청구가 이유있다고 인정할 때에는 위원회가 스스로 처분을 취소 또는 변경하거나 처분청에 대하여 당해 처분의 변경을 명하는 재결이다(동법 제43조 제3항). 구 행정심판법에서는 취소명령재결도 있었으나 현행 행정심판법 제43조 제3항은 취소명령재결을 삭제하였다. 위원회가 스스로 처분을 취소·변경하는 취소변경재결은 형성재결의 성질을 가지는 것이고, 위원회가 처분청에게 명하는 변경명령재결은 이행재결의 성질을 가진다 하겠다. 단 현행법상 처분청이 변경명령재결의 기속력에 따르지 않는 경우 이에 대한 강제방법이 없는 바, 이는 입법의 불비이다.

처분의 취소에는 전부취소·일부취소가 있고, 처분을 변경하는 재결 또는 변경을 명하는 재결은 처분내용을 적극적으로 변경하거나 변경을 명하는 재결이다. 예컨대 면허취소처분을 면허정지처분으로 변경하는 등이다. 따라서 변경재결은 일부취소가 아니라 적극적 변경 즉, 원처분에 갈음하는 다른 처분으로의 변경을 의미한다.

2) 무효등확인재결

처분의 효력유무 또는 존재여부를 확인하는 재결이다(동법 제43조 제4항). 따라서 이러한 확인재결에는 처분무효확인재결, 처분유효확인재결, 처분부존재확인재결, 처분존재확인재결, 처분실효확인재결이 있다.

3) 의무이행재결(처분재결/처분명령재결)

이는 의무이행심판청구가 이유 있다고 인정할 때 지체없이 위원회 스스로 신청에 따른 처분을 하거나(형성재결), 처분청으로 하여금 처분을 할 것을 명하는 재결을 말한다(이행재결)(행정심판법 제43조 제5항).

행정심판위위원회가 어떠한 경우에 처분재결을 내리고, 처분명령재결을 내려야 하는가에 대하여, ① 행정심판위원회의 재량이라는 견해, ② 행정심판위원회는 처분청이 아닌 바 처분명령재결만 가능하다는 견해, ③ 원칙적으로 처분명령재결을 하여야 하고 예외적으로 처분재결을 할

수 있다는 견해 등이 대립하고 있다. ④ 실무상으로는 대부분 처분명령재결을 하고 있고, 처분재결을 하는 경우는 극히 제한적이다.

Ⅵ. 재결의 송달·효력발생·고지

재결을 한 때에는 위원회는 지체 없이 당사자에게 재결서 정본을 송달하여야 하고, 재결은 청구인에게 재결서가 송달된 때에 효력을 발생한다(동법 제48조 제1항, 제2항). 위원회는 심판청구에 참가인이 있는 경우에는 재결서의 등본을 지체 없이 참가인에게 송달하여야 한다(동조 제3항). 이 참가인에의 송달은 재결의 효력발생과는 직접적인 관계가 없다. 한편 처분의 상대방이 아닌 제3자가 심판청구를 한 경우 위원회는 재결서의 등본을 지체 없이 피청구인을 거쳐 처분의 상대방에게 송달하여야 한다(동조 제4항).

Ⅶ. 재결의 효력

1. 행정행위로서 재결의 효력

재결도 행정행위의 일종으로서 구속력, 공정력, 구성요건적 효력, 불가쟁력, 불가변력 등의 효력을 갖는다.

2. 형성력

재결의 형성력이라 함은 재결의 내용에 따라 법률관계의 변경·소멸을 가져오는 효력을 말한다. 형성력이 인정되는 재결로는 취소변경재결, 처분재결(의무이행심판에서의 형성적 재결)이 있다.

3. 기속력

재결의 기속력이라 함은 처분청 및 관계행정청이 재결의 취지에 따르도록 처분청 및 관계행정청을 구속하는 효력을 말한다(동법 제49조).

⑴ 반복금지효

행정청은 처분의 취소변경재결 또는 무효등확인재결이 있는 경우 동일인에게 동일한 위법사유로 동일한 사실관계 아래서 동일한 내용의 처분을 반복할 수 없다(대법원 1983. 8. 23, 82누302).

⑵ 원상회복의무

취소재결의 기속력에는 해석상 원상회복의무가 포함되는 것으로 보는 것이 타당하다. 따라서 취소재결이 확정되면 행정청은 취소된 처분에 의해 초래된 위법상태를 제거하여 원상회복 할 의무가 있다.

⑶ 재처분의무

1) 의무이행심판에 대한 처분명령재결

당사자의 신청을 거부하거나 부작위로 방치한 처분의 이행을 명하는 재결이 있는 경우에는 행정청은 지체 없이 그 재결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다(동법 제49조 제2항).

2) 절차의 하자로 인한 취소재결

또한 신청에 따른 처분이 절차의 위법 또는 부당(예 : 이유부기의 하자)을 이유로 재결로서 취소된 경우에도 이에 준하여 적법한 절차에 따라 신청에 따른 처분을 하거나 신청을 기각하는 처분을 하여야 한다(동법 제49조 제3항).

3) 취소심판에 대한 변경명령재결

취소심판에 있어서 변경을 명하는 재결이 있는 때(동법 제43조 제3항)에는 법 제49조 제1항에 의해 처분청은 당해 처분을 변경하여야 한다. 단, 현행법상 처분청이 변경명령재결의 기속력에 따르지 않는 경우 이에 대한 강제방법이 없는 바, 이는 입법의 불비이다.

4) 거부처분 취소재결

현재 거부처분에 대하여 의무이행심판 뿐만 아니라 취소심판을 제기할 수 있는 것으로 보는 것이 다수설이다. 그런데 거부처분에 대한 취소심판청구를 인용하는 재결에 대하여는 처분청의 재처분의무를 인정하는 명시적인 규정이 없다.

따라서 거부처분취소심판의 인용재결이 있는 경우에 처분청은 행정심판법 제49조 제1항에 의해 재처분의무를 지는가에 대하여 학설의 대립이 있다.

4. 처분명령재결의 기속력(처분의무) 확보수단으로서의 직접처분

⑴ 의의

직접처분이라 함은 행정청이 처분명령재결의 취지에 따라 이전의 신청에 대한 처분을 하지 아니하는 때에 위원회가 당해 처분을 직접 행하는 것을 말한다(동법 제50조). 직접처분은 처분명령재결의 실효성을 확보하기 위하여 인정된 처분명령재결의 이행강제제도이다.

그런데 정보공개에 대한 의무이행심판처럼 그 성질상 처분재결이 불가능하여 처분명령재결을 할 수밖에 없는 경우 처분청이 신청에 대한 처분을 하지 않는 경우 위원회가 행정심판법 제50조에 따라 직접처분을 하는 것은 그 처분의 성질상 불가능하다(행정심판법 제50조 제2항). 따라서 이러한 경우 처분청의 처분의무이행강제방법이 없다. 이에 행정심판법을 개정하여 간접강제제도를 도입하여야 한다는 주장이 있다.

⑵ 인정범위

직접청구는 의무이행재결(처분명령재결)에 따른 처분을 하지 않는 경우에만 인정되고 있다.

⑶ 요건

① 처분명령재결이 있었을 것. ② 위원회가 당사자의 신청에 따라 시정을 명하였을 것. ③ 당해 행정청이 아무런 처분을 하지 아니하였을 것. ④ 그 처분의 성질이나 그 밖의 불가피한 사유로 위원회가 직접 처분을 할 수 없는 경우가 아닐 것.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 다음 중 기속력이 인정되는 재결은? (2002 국가직 7급)

① 인용재결 ② 기각재결
③ 각하재결 ④ 사정재결

해설 & 정답

유형 법률지식형

기속력은 처분청 및 관계행정청이 재결의 취지에 따르도록 처분청 및 관계행정청을 구속하는 효력으로서 인용재결의 효력이고 기각재결에는 인정되지 않는다.

정답 ①

2. 의무이행재결에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 처분재결은 형성재결로서 의무이행재결에 속한다.
② 처분명령재결도 가능하다.
③ 부작위에 대해 의무이행심판의 제기가 가능하다.
④ 심판청구기간은 원칙적으로 처분이 있음을 안 날로부터 90일 이내, 처분이 있은 날로부터 1년 이내이다.
⑤ 의무이행심판의 청구가 이유가 있다고 인정하면 지체 없이 신청에 따른 처분을 하거나 처분을 할 것을 피청구인에게 명한다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

①② 위원회는 의무이행심판의 청구가 이유가 있다고 인정하면 지체 없이 신청에 따른 처분을 하거나(형성재결) 처분을 할 것을 피청구인에게 명한다(이행재결)(행정심판법 제43조 제5항).
③ 동법 제5조 제3호
④ 행정심판은 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내에 청구하여야 한다(동법 제27조 제1항). 행정심판은 처분이 있었던 날부터 180일이 지나면 청구하지 못한다. 다만 정당한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다(동조 제3항).
⑤ 동법 제43조 제5항

정답 ④

3. 심판청구의 고지제도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (2004 국회8급)

① 고지제도란 행정청이 처분을 하는 경우 상대방 등에게 심판청구의 가부, 위원회·제소기간 등 당해 처분에 대한 행정심판제기에 필요한 상황을 알려주는 제도를 말한다.
② 고지는 행정심판법에 규정된 심판청구에 필요한 사항을 구체적으로 알려주는 비권력적 사실행위로 고지 자체는 아무런 법적효과를 발생하지 않는다.
③ 행정청이 처분을 서면으로 하는 경우에는 그 상대방에게 처분에 관하여 행정심판을 제기할 수 있는지의 여부, 제기하는 경우의 심판청구절차 및 청구기간을 알려야 한다.
④ 여기서 말하는 처분은 행정심판법에 의한 처분에 한하고, 행정심판법 이외의 다른 법령에 의한 심판청구의 대상이 되는 처분은 포함되지 않는다는 것이 통설이다.
⑤ 행정청이 심판청구기간을 잘못 알린 경우에는 그 잘못 알린 기간 내에 심판청구가 있으면 그 심판청구는 적법한 심판청구가 있는 것으로 본다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

④ 고지의 대상이 되는 처분은 행정심판법상의 심판청구의 대상이 되는 처분에 국한되는 것이 아니라 다른 법률에 의한 행정심판의 대상이 되는 서면에 의한 처분도 포함된다는 것이 통설이다.

⑤ 행정심판법 제27조 제5항

정답 ④

♣ 학습내용 정리

1. 행정심판법상 가구제수단으로 집행정지와 임시처분제도가 있다.
2. 행정심판법상 재결에는 각하재결과 기각재결, 인용재결이 있는데 취소심판과 의무이행심판에만 사정재결이 인정된다.

제32강 행정소송 개관

♣ 학습목표

행정소송의 한계와 행정소송의 종류 그리고 취소소송의 관할 및 관련청구의 병합에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

무명항고소송 인정여부
행정소송의 종류
취소소송의 관할
관련청구소송의 병합과 이송

♣ 사전테스트

1. 항고소송의 종류로 의무이행소송이 행정소송법에 규정되어 있다.
   정답 : X

2. 객관적 소송은 법률에 규정이 없어도 소제기가 가능하다.
   정답 : x

3. 주관적 예비적 병합은 허용된다.
   정답 : O

♣ 돌발퀴즈

행정소송으로 제기할 사항을 민사소송으로 제기한 경우 수소법원은 원칙적으로 각하하여야 한다.

[정답] ×

[해설] 고가 고의 또는 중대한 과실 없이 행정소송으로 제기하여야 할 사건을 민사소송으로 잘못 제기한 경우, 수소법원으로서는 만약 그 행정소송에 대한 관할도 동시에 가지고 있다면 이를 행정소송으로 심리·판단하여야 하고, 그 행정소송에 대한 관할을 가지고 있지 아니하다면 당해 소송이 이미 행정소송으로서의 전심절차 및 제소기간을 도과하였거나 행정소송의 대상이 되는 처분 등이 존재하지도 아니한 상태에 있는 등 행정소송으로서의 소송요건을 결하고 있음이 명백하여 행정소송으로 제기되었더라도 어차피 부적법하게 되는 경우가 아닌 이상 이를 부적법한 소라고 하여 각하할 것이 아니라 관할법원에 이송하여야 한다(대판 1997.5.30, 95다28960).

♣ 강의내용

제1 행정소송의 한계

Ⅰ. 개 설

우리나라 행정소송법은 행정청의 처분이나 부작위를 중심으로 한 위법한 행정작용 전반에 대해서 행정소송의 제기를 허용하고 있다. 행정소송의 한계문제는 이러한 개괄주의하에서만 발생하는 문제이다.

Ⅱ. 사법 본질에 의한 한계

1. 법률적 쟁송의 의의

행정소송도 사법작용이라는 오늘날의 통설적 견해에 따르면, 사법 본질에서 나오는 기본적 한계는 행정소송에도 마찬가지로 적용된다고 할 것이다. 우리나라 법원조직법 제2조 제1항에는 “법원은 헌법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 일체의 법률상의 쟁송을 심판하고 이 법과 다른 법률에 의하여 법원에 속하는 권한을 갖는다”라고 규정하여 사법작용은 그 대상에 있어서 헌법에 특별한 규정이 없는 한 원칙적으로 법률상의 쟁송만을 대상으로 한다. 이 때 법률상의 쟁송이란 당사자 사이의 구체적인 권리 의무에 관한 법률적용상의 분쟁을 의미한다. 따라서 구체적 사건성과 법률적용상의 분쟁의 해결가능성을 결여한 사건은 행정소송의 한계에 해당한다.

2. 구체적 사건성을 결여한 쟁송

⑴ 추상적 규범통제

시행령이라는 일반 추상적인 법규 명령이 제정 됐는데 그것이 위헌이다.
시행령 자체에 대해서 취소소송을 제기했을 때는 시행령은 추상적 규율이기 때문에 바로 사람과 사람 간의 구체적 관리 의무 다툼 바로 법률상 쟁송에 해당하지 않는다.

⑵ 반사적 이익에 관한 분쟁

법률상 이익 바로 공권 권리가 아니기 때문에 관성 이익을 침해받은 제3자가 취소소송을 제기하면 법원은 원고적격분결 바로 법률상의 이익이 아닌 없는 사람이 소송하게 원고적격결로 각하할 수밖에 없다.

⑶ 객관적 소송

민중소송과 기관소송은 법률에 특별한 규정이 없는 한 행정소송의 대상이 되지 못한다(행정소송법 제45조).

⑷ 단순한 사실행위

사실행위에 대해서 어떤 권리 의무 변동이 일어나는 것이 아니므로 권리 의무에 대한 다툼을 법률상 쟁송에 해당하지 않는다.

3. 법적 해결가능성

Ⅲ. 권력분립의 원칙에서 오는 한계

1. 의무이행소송의 인정여부

⑴ 의무이행소송의 의의

의무이행소송이란 당사자의 행정행위 신청에 대하여 행정청이 거부하거나 부작위한 경우 행정청으로 하여금 일정한 행정행위를 하도록 청구하는 소송을 말한다.

⑵ 학설의 대립

① 권력분립의 원칙 및 행정소송법 제4조 제1호의 변경은 소극적 일부취소를 의미한다는 점, 행정소송법 제4조의 항고소송의 종류는 제한적으로 해석된다는 점 등을 논거로 인정할 수 없다는 부정설, ② 권력분립원칙은 기능적으로 이해되어야 하고, 행정소송법 제4조 제1호의 변경은 적극적 변경을 의미하며, 행정소송법 제4조의 항고소송의 종류는 예시적으로 해석된다는 점 등을 논거로 현행법상 인정할 수 있다는 긍정설, ③ 원칙적으로 인정할 수 없으나 법정항고소송에 의해서는 국민의 권리구제를 받을 수 없는 경우에 한하여 예외적으로 법정외 항고소송인 의무이행소송을 인정할 수 있다는 절충설 등이 대립한다.

⑶ 판 례 - 부정설입장

판례는 “검사에게 압수물 환부를 이행하라는 청구는 행정청의 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 하는 의무이행소송으로 현행 행정소송법상 허용되지 않는다”(대판 1995. 3. 10, 94누14018)라고 판시하여 일관되게 의무이행소송을 부정하고 있다.

2. 예방적 부작위청구소송의 인정여부

Ⅳ. 헌법상의 예외 - 국회의원의 징계 및 제명처분 : 헌법 제64조 제4항

제2 행정소송의 종류

Ⅰ. 내용에 의한 분류

행정소송법은 행정소송을 내용에 따라 항고소송·당사자소송·민중소송·기관소송으로 구분하고 있다(동법 제3조). 항고소송과 당사자 소송은 개인의 주관적 권익의 보호를 직접 목적으로 하는 주관적 소송인 반면, 민중소송과 기관소송은 공익실현 또는 행정의 적법성보장을 직접 목적으로 하는 객관적 소송이다.

1. 법정소송

⑴ 항고소송

항고소송은 ‘행정청의 처분 등이나 부작위에 대하여 제기하는 소송’이다(행정소송법 제3조 제1호). 즉, 항고소송이라 함은 행정청의 공권력의 행사 또는 불행사에 불복하여 권익구제를 구하는 소송을 말한다. 행정소송법은 항고소송을 취소소송, 무효등확인소송, 부작위위법확인소송으로 구분하고 있다(동법 제4조). 이와 같이 법에 의해 명시적으로 인정되고 있는 항고소송을 법정항고소송이라고 한다.

⑵ 당사자소송

행정청의 처분 등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송 그밖에 공법상 법률관계에 관한 소송으로서 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송이다(행정소송법 제3조 제2호). 당사자소송은 실질적 당사자소송과 형식적 당사자소송(예컨대 토지보상법 제85조 제2항의 보상금증감청구소송)으로 구분된다.

⑶ 민중소송과 기관소송(행정소송법 제3조 제3호, 제4호)

민중소송이란 국가 또는 공공단체의 기관이 법률에 위반되는 행위를 한 때에 직접 자기의 법률상 이익과 관계없이 그 시정을 구하기 위하여 제기하는 소송이고, 기관소송이란 국가 또는 공공단체의 기관 상호간에 있어서의 권한의 존부 또는 그 행사에 관한 다툼이 있을 때에 이에 대하여 제기하는 소송이다.

양자는 모두 사인의 구체적인 권익침해와 무관하게 행정법규의 적정한 적용을 확보하기 위한 객관적 소송으로서 법률의 명시적 규정이 있는 경우에만 허용된다.

2. 무명항고소송(법정외항고소송)

Ⅱ. 성질에 의한 분류

행정소송은 그 성질에 따라 형성의 소, 이행의 소, 확인의 소로 구분할 수 있다.

제3 취소소송 개설

Ⅰ. 의 의

취소소송은 행정청의 위법한 처분 등을 취소 또는 변경하는 소송(행정소송법 제4조 제1호)을 말한다.

Ⅱ. 성 질

취소소송은 개인의 권익구제를 직접적인 목적으로 하는 주관적 소송이다. 단지 취소소송의 법적 성질에 대하여 ① 취소소송은 유효한 처분 등의 효력을 소멸시키는 것으로 형성소송의 성질을 갖는다는 견해(형성소송설)와 ② 처분 당시에 있어서 처분의 위법성을 확인하는 소송이라는 견해(확인소송설) 및 ③ 확인소송의 성질과 형성소송의 성질을 모두 갖는 소송이라는 견해(구제소송설)가 있으나 형성소송설이 통설·판례의 입장이다.

제4 취소소송의 관할과 당사자

Ⅰ. 재판관할

1. 심급관할 - 행정법

2. 사물관할 - 합의부

3. 토지관할

취소소송은 피고인 행정청의 소재지를 관할하는 행정법원이 그 관할법원이다. 다만 중앙 행정기관 또는 그 장이 피고인 경우의 관할법원은 대법원 소재지의 행정법원으로 한다(행정소송법 제9조 제1항).

4. 관할법원에의 이송

5. 관련청구소송의 병합

⑴ 의 의

행정소송법 제10조는 취소소송과 관련되는 소송에 대하여는 취소소송과 함께 변론을 병합하거나 취소소송이 계속된 법원에 이송할 수 있도록 하고 있다.

관련청구소송은 ① 당해 처분등과 관련되는 손해배상, 부당이득반환, 원상회복 등 청구소송, ② 당해 처분등과 관련되는 취소소송을 말한다. 위 조항은 무효등확인소송과 부작위위법확인소송에 준용되며 당사자소송의 경우에도 준용된다(동법 제38조 제1항, 제2항. 제44조 제2항).

금전부과처분에 대한 취소소송과 금전부과처분에 따라 납부한 금원에 대한 부당이득반환청구소송을 병합한 경우 금전부과처분에 대한 취소판결이 확정되지 않더라도 그 소송절차에서 금전부과처분에 대한 취소판결만 내려지면 부당이득반환청구가 인용될 수 있다는 판례(대법원 2009.4.9. 선고 2008두23153 판결)

⑵ 제도적 취지

소송경제도모, 판결의 모순저촉방지

⑶ 관련청구 병합의 태양

1) 원고와 피고의 수에 따라

① 관련청구의 객관적 병합(원·피고가 2인)

주된 취소소송 등의 원고는 소 제기시에 관련된 청구를 병합하여 제소하거나 소송계속중인 사실심 변론종결시까지 추가하여 병합제소할 수 있다(동법 제10조 제2항).

② 관련청구의 주관적 병합(원·피고가 3인이상)(동법 제10조 제2항 후단, 15조)

2) 병합청구의 심리여부에 따라

① 단순병합

병합된 소 모두를 심리하여 판결을 내려야 한다. 예컨대 당해 처분에 대한 취소소송과 당해 처분으로 인한 손해에 대한 국가배상청구소송이 병합된 경우 법원은 병합된 소 모두를 심리하여 판결을 내려야 한다.

② 선택적 병합

병합된 소 중 어느 한 소만 인용판결을 내리면 나머지 소는 판결내릴 필요가 없는 경우를 말한다(예컨대 선임감독자와 비용부담자에 대한 국가배상청구소송을 병합한 경우).

③ 예비적 병합

주위적인 소에 대하여 우선적으로 심리하여 주위적인 소가 인용되면 예비적인 소는 심리할 필요 없고, 주위적인 소가 기각되면 비로소 예비적인 소를 심리하는 경우를 말한다(예컨대 동일한 처분에 대하여 주위적으로 무효확인소송을, 예비적으로 취소소송을 병합한 경우).

3) 주관적 예비적 병합의 허용여부

현행 민사소송법에 의해서 허용됨.

⑷ 관련청구 병합의 요건

1) 주된 취소소송 등[65]과 관련되는 청구일 것

행정소송법 제10조 제1항은 취소소송에 병합될 수 있는 청구로서 ① 취소소송의 대상인 처분 등과 관련되는 손해배상, 부당이득반환, 원상회복 등의 청구소송과, ② 취소소송의 대상인 처분 등과 관련되는 취소소송을 규정하고 있다.

2) 주된 취소소송 등에 관련청구를 병합할 것

3) 주된 취소소송 등과 관련청구가 각각 적법한 소제기일 것.

주된 취소소송 등과 병합하는 관련청구는 소송요건을 구비하여야 한다. 주된 취소소송 등에 병합하여 제기된 관련청구가 관련청구로서의 요건을 갖추지 못한 경우는 다른 관할법원에 이송하여 구제할 수 있는 경우가 아닌 한 부적법하여 각하할 것이다.

주된 취소소송 등이 소송요건을 갖추지 못하여 부적법한 경우 그에 병합된 관련 민사상의 청구의 처리에 관하여 이를 각하하여야 한다는 것이 판례[66]이나, 관련청구소송이 독립하여 적법한 소송요건을 구비하고 있는 경우에는 별개의 독립한 소로서 취급하여 심리 재판하거나 관할법원으로 이송하여야 한다는 견해도 있다.

4) 원고가 사실심 변론종결시까지 주된 취소소송 등이 계속된 법원에 병합신청을 할 것.

6. 관련청구의 이송

위와 같은 관련청구가 각각 다른 법원에 계속되어 있는 경우에 심리의 편의를 도모하기 위하여 행정소송법 제10조 제1항은 관련청구소송이 계속된 법원은이상당하다고 인정하는 때에는 당사자의 신청 또는 직권에 의하여 이를 취소소송이 계속된 법원으로 이송할 수 있다고 규정하고 있다.

이송의 결정은 당해 관련청구소송을 이송 받은 법원을 기속하며 따라서 이송 받은 법원은 당해 소송을 다시 다른 법원에 이송하지 못한다. 이송결정이 확정되면 당해 소송은 처음부터 이송을 받은 법원에 계속된 것으로 본다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 무명항고소송(법정외 항고소송)에 대한 설명으로 옳은 것은? (2000 행정고시)

① 우리나라의 판례와 학설은 예방적 부작위청구소송을 넓게 인정하고 있다.
② 행정소송법상 기관소송과 민중소송이 무명항고소송의 대표적 예이다.
③ 행정소송법 제4조의 규정을 예시적 규정으로 보는 입장에서는 무명항고소송을 인정하기도 한다.
④ 우리나라 행정소송법과는 달리 독일에서는 의무이행소송을 인정하지 않고 있다.
⑤ 우리나라 행정소송법은 항고소송으로서 급부소송을 규정하고 있다.

---

65) 여기서 '주된 취소소송 등'이란 항고소송과 당사자소송을 말한다.
66) 대판 1980. 4. 22, 78누90; 대판 1997. 3. 14, 95누13708; 대판 1997. 11. 11, 97누1990.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 예방적 부작위청구소송의 인정 여부에 대하여 학설은 대립하나, 대법원은 "건축건물의 준공처분을 하여서는 아니 된다는 내용의 부작위를 구하는 청구는 행정소송에서 허용되지 아니하는 것이므로 부적법하다(대판 1987.3.24, 86누182)"라고 판시함으로써 부정설을 취하고 있다.

② 기관소송과 민중소송은 항고소송이 아닌 객관적 소송의 일종이고, 명시적 규정이 있기 때문에 무명소송이 아닌 법정소송이다.

③ 그 밖의 논거로 헌법상 재판청구권의 보장됨을 이유로 국민의 포괄적 권리구제를 우선 해석해야 한다는 점을 들 수 있다.

④ 독일은 행정법원법에서 명문으로 인정하고, 영·미의 경우에도 행정청에 의무를 부과하는 소송이 인정하고 있다.

⑤ 행정소송법 제4조는 항고소송의 종류로 취소소송, 무효등확인소송, 부작위위법확인소송만을 규정하고 있다.

정답 ③

2. 행정소송의 한계에 관한 우리나라 대법원 판례의 태도로서 타당하지 아니한 것은?

(2001 입법고시)

① 공법상의 구체적 법률관계가 아닌 사실관계에 관한 것들을 확인의 대상으로 하는 것은 항고소송의 대상이 되지 않는다.

② 처분요건이 일의적으로 규정되어 행정청의 1차적 판단권이 행사될 여지가 없고, 손해가 급박하며, 다른 구제수단이 없는 경우에는 의무화소송이 예외적으로 인정된다.

③ 법원이 계엄선포의 요건의 구비 여부나 선포의 당·부당을 심사하는 것은 사법권의 한계를 넘는 것이다.

④ 재량권을 남용한 위법한 처분이라고 주장하면서 취소를 구하는 경우에는 법원은 재량권 남용 여부를 심리하여 본안에 관한 판단으로서 청구의 인용 여부를 가려야 한다.

⑤ 조례도 다른 행정행위를 기다릴 것 없이 그 자체로 직접 국민의 권익침해의 효과를 발생케 하는 경우에는 행정소송의 대상이 된다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

② 행정심판법 제3조에 의하면 행정청의 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위에 대하여 의무이행심판청구를 할 수 있으나 행정소송법 제4조에서는 행정심판법상의 의무이행심판청구에 대응하여 부작위위법확인소송만을 규정하고 있으므로 행정청의 부작위에 대한 의무이행소송은 현행법상 허용되지 않는다(대판 1989.9.12, 87누868).

③ 계엄선포가 당연무효가 아닌 한, 사법기관인 법원이 계엄선포의 요건구비나 선포의 당·부당을 심사하는 것은 사법권의 내재적인 본질적 한계를 넘어서는 것이 되어 적절하지 못하다(대판 1981.4.28, 81도874).

정답 ②

3. 항고소송에 관한 다음의 기술 중 옳은 것은? (2006 관세사)

① 원처분에 대한 취소소송과 재결에 대한 취소소송 양자 모두를 제기할 수 있는 경우, 후자의 소송에서 원처분의 위법성을 이유로 재결의 취소를 주장할 수 있다.

② 행정심판의 임의적 전치주의에 관한 행정소송법 제18조 제1항 상의 '행정심판'은 행정심판법상의 행정심판에 한정된다.

③ 취소소송에서 행정처분의 위법성 여부에 대한 판정의 기준시는 판결시라고 하는 것이 통설·판례의 입장이다.

④ 행정처분이 취소되면 원칙적으로 그 처분의 효력은 소급적으로 소멸하고, 그 효력은 제3자에게도 미친다.

⑤ 행정소송법상 취소소송은 피고의 변경을 수반하는 다른 종류의 소송으로 변경할 수 없다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 원처분주의는 원처분과 재결에 대하여 다 같이 소를 제기할 수 있지만, 원처분의 위법은 원처분에 대한 항고소송에서만 주장할 수 있고, 재결에 대한 항고소송에 있어서는 원처분의 하자가 아닌 재결의 고유한 하자만 주장할 수 있도록 하는 제도를 말한다.

② 행정심판법상의 행정심판에 한정되지 않는다.

③ 행정처분의 위법 여부의 판단은 처분시의 법령 및 사실을 기본으로 하여 판단하여야 한다는 견해로서 통설과 판례의 입장이다. cf. 부작위위법확인소송의 경우 위법판단기준시는 판결시이다.

④ 판결의 형성력 - 일반적으로 확정판결이 판결의 취지에 따라 법률관계의 발생·변경·소멸을 가져오는 효력을 말한다. 즉, 행정처분의 취소판결이 있게 되면, 처분청의 별도의 행위를 기다릴 것 없이 처분의 효력은 소급하여 소멸하며 처분이 없었던 것과 같은 상태로 된다.

취소판결의 제3자효 - 처분 등을 취소하는 확정판결은 제3자에 대하여도 효력이 있다(행정소송법 제29조 제1항)

⑤ 소의 종류의 변경(행정소송법 제21조)은 당사자(피고)의 변경을 수반하는 경우가 있다는 점에서 민사소송법에 대한 특례인데 소 종류의 변경은 항고소송 상호 간, 항고소송과 당사자소송 상호 간에 허용되는데, 항고소송에서 당사자소송으로 소종류를 변경할 경우에는 피고가 행정청에서 국가 등 권리주체로 변경된다.

정답 ④

♣ 학습내용 정리

1. 행정소송에는 항고소송, 당사자소송, 민중소송, 기관소송이 있다.
2. 무명항고소송으로 의무이행소송과 예방적 부작위소송이 현행법상 인정될 수 있는가에 대하여 학설의 대립이 있고 판례는 부정한다.

제33강 취소소송의 소송요건 I

♣ 학습목표

취소소송의 소송요건으로 대상적격인 처분과 재결에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

처분의 의미
원처분주의와 재결주의

♣ 사전테스트

1. 처분의 개념정의에서 말하는 행정청은 조직법상 의미의 행정청이다.
   정답 : X

2. 증액처분이 있는 경우 증액되기 전 당초 처분이 소의 대상이다.
   정답 : x

3. 행정소송법은 원처분주의를 취하고 있다.
   정답 : O

♣ 돌발퀴즈

'교육부장관의 내신성적 산정기준에 관한 시행지침'은 일반적 추상적인 법령 내지 내규에 불과하므로 행정소송을 제기할 수 없다.

[정답] O

[해설] 항고소송의 대상이 되는 행정처분은 행정청의 공법상의 행위로서 특정사항에 대하여 법률에 의하여 권리를 설정하고 의무를 명하며, 기타 법률상 효과를 발생케 하는 등 국민의 권리의무에 직접관계가 있는 행위이어야 하고, 그 자체로서 국민의 구체적인 권리의무에 직접적인 변동을 초래케 하는 것이 아닌 일반적, 추상적인 법령 또는 내부적 내규 및 내부적 사업계획에 불과한 것 등은 그 대상이 될 수 없다. 교육부장관이 내신성적 산정기준의 통일을 기하기 위해 대학입시기본계획의 내용에서 내신성적 산정기준에 관한 시행지침을 마련하여 시·도 교육감에서 통보한 것은 행정조직 내부에서 내신성적 평가에 관한 내부적 심사기준을 시달한 것에 불과하며, 각 고등학교에서 위 지침에 일률적으로 기속되어 내신성적을 산정할 수밖에 없고 또 대학에서도 이를 그대로 내신성적으로 인정하여 입학생을 선발할 수밖에 없는 관계로 장차 일부 수험생들이 위 지침으로 인해 어떤 불이익을 입을 개연성이 없지는 아니하나, 그러한 사정만으로서 위 지침에 의하여 곧바로 개별적이고 구체적인 권리의 침해를 받은 것으로는 도저히 인정할 수 없으므로, 그것만으로는 현실적으로 특정인의 구체적인 권리의무에 직접적으로 변동을 초래케 하는 것은 아니라 할 것이어서 내신성적 산정지침을 항고소송의 대상이 되는 행정처분으로 볼 수 없다(대판 1994.9.10., 94두33).

♣ 강의내용

제1 취소소송의 대상적격 - 행정소송법상의 처분의 의의

1. 개 설

행정소송법은 취소소송의 대상을 "처분 등", 즉 행정청이 행하는 구체적 사실에 대한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그밖에 이에 준하는 행정작용(처분) 및 행정심판에 대한 재결(등)이라고 규정하고(행정소송법 제2조 제1항 제1호, 제19조), 이를 무효등확인소송 및 부작위위법확인 소송에도 준용함으로써(동법 제38조 제1항, 제2항), 항고소송의 대상이 "처분"과 "재결"임을 명시함과 아울러 소송의 대상에 관하여 열거주의가 아닌 개괄주의를 택하였음을 밝히고 있다.

2. 처 분

⑴ 개 념

항고소송의 대상인 "처분"의 의미에 관하여 행정소송법 제2조 제1항 제1호는 "행정청이 행하는 구체적 사실에 대한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그밖에 이에 준하는 행정작용"이라고 정의하고 있다.

⑵ 학설

1) 실체법적 개념설(일원설)

취소소송을 행정행위의 공정력을 깨기 위한 형성소송으로 보아, 취소소송의 대상인 처분을 공정력을 가지는 행정행위와 동일한 개념으로 파악하는 견해이다. 이 견해에 따르면 행정행위가 아닌 행정작용은 당사자소송이나 국가배상청구소송 등 그에 상응하는 소송유형을 통해 권리구제를 도모해야 한다고 한다.

2) 쟁송법적 개념설(이원설)

행정소송법상 처분의 개념은 행정행위보다 넓은 행정쟁송법상의 독자적인 개념이라는 견해이다. 이 견해는 항고소송 중심주의를 취하는 현행법상 항고소송의 대상인 처분의 개념을 넓힘으로써 국민의 권리구제를 확대하여야 하고 행정소송법상 처분의 개념이 강학상 행정행위보다 넓게 규정되어 있음을 논거로 한다. 이 견해에 따르면 행정행위가 아닌 사실상 지배력를 미치는 비권력적 사실행위 등도 처분의 개념에 해당할 수 있다.

3) 제3설

행정소송법상 처분개념은 실체법상 행정행위개념보다 그 의미가 넓으나, 항고소송으로 취소소송, 무효확인소송의 대상인 처분은 행정행위로 국한할 수 밖에 없다는 견해이다.

⑶ 판례

판례에 대하여 실체법적 개념설을 취하고 있다고 해석하는 견해도 있고 쟁송법적 개념설을 취하고 있다고 보는 견해도 있다.

판례는 기본적으로 실체법적 개념설의 입장을 취하고 있다. 다만 최근 판례는 " 행정청의 어떤 행위가 항고소송의 대상이 될 수 있는지의 문제는 추상적·일반적으로 결정할 수 없고, 구체적인 경우 행정처분은 행정청이 공권력의 주체로서 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서

국민의 권리의무에 직접적으로 영향을 미치는 행위라는 점을 염두에 두고, 관련 법령의 내용과 취지, 그 행위의 주체·내용·형식·절차, 그 행위와 상대방 등 이해관계인이 입는 불이익과의 실질적 견련성, 그리고 법치행정의 원리와 당해 행위에 관련한 행정청 및 이해관계인의 태도 등을 참작하여 개별적으로 결정하여야 한다"라고 판시하여 행정행위가 아닌 행정작용도 국민의 권익구제를 위해 필요한 경우에는 처분성을 인정하고 있다. .

⑸ 요 소

1) 행정청의 행위
행정청의 의미는 행정행위의 개념
국가 지자체의 의사를 결정하고 의사를 외부에 표시할수 있는 사람이 아닌 행정 기관으로 행정청만을 의미하는게 아니라 넓은 개념으로 공법에 의해 처분 권한을 부여받은 모든 자를 의미한다.

2) 공권력의 행사
공권력 행사에는 공법 적용과 권력적 단독행위가 들어가야 한다. 민법에 대한 사법작용이라든지 비거락 작용은 처분에 개념에 해당할수 없다.

3) 구체적 집행행위
추상적인 규율인 행정 입법, 법규명령이나 행정규칙과 같은 추상적인 것은 당연히 처분의 개념에 해당할 수 없다.

4) 국민의 권리의무에 직접 영향이 있는 행위
항고소송은 국민의 권리 이익 구제를 위한 것이므로, 국민의 권리의무에 영향이 없는 단순한 행정청 내부의 중간처분, 의견, 질의·답변, 또는 내부적 사무처리절차이거나 알선, 권유, 행정지도 등 비권력적 사실행위 등은 항고소송의 대상이 될 수 없다.

5) 행정소송 이외의 특별 불복절차가 따로 마련되어 있지 않을 것
근거법률이 행정소송 이외의 다른 절차에 의하여 불복할 것을 예정하고 있는 처분은 항고소송의 대상이 될 수 없다.
과태료처분에 대하여 이의가 있는 자는 질서위반행위규제법에 의하여 법원의 판단을 받아야 하고 행정소송을 제기할 수 없다.

⑹ 특수한 처분

1) 통치 행위
고도의 정치적 행위로서 법원의 사법심사 대상이 되기가 부적당한 행위이기 때문에 당연히 항고소송 대상인 처분이 아니라고 봐야한다.

2) 특별권력관계 내부의 행위
옛날에는 특별권력 관계라는 이유만으로 공무원이나 교도소 대소자 국공립학교 재학생들한테 하는 행위들은 한국 법원의 소송 대상이 될 수 없다고 했지만, 특별권력 관계 이론을 부정하고 있기 때문에 당연히 처분의 개념 증표만 모두 갖추면 처분으로서 항고소송을 제기할 수 있다.

3) 재량행위
당연히 처분된 개념에 해당한다.

4) 반복된 행위 - 반복적 적극적 처분 : 1차만이 처분성인정됨 / 반복된 거부처분 : 각각 처분성 인정

5) 신고수리행위 - 자세한 내용은 전술 신고 참조.

⑺ 증액처분과 감액처분

1) 증액이나 감액처분시 소의 대상

① 학설
① 당초 처분과 경정처분은 독립된 처분으로서 각각 소송의 대상이 된다는 병존설, ② 당초 처분은 경정처분에 흡수되어 소멸되므로 경정처분만이 소송의 대상이 된다는 흡수설, ③ 당초 처분은 그대로 존속하지만 경정처분만이 소의 대상이 된다는 병존적 흡수설, ④ 경정처분으로 수정된 당초처분이 소의 대상이 된다는 역흡수병존설 등이 대립한다.

② 판례
판례는 감액처분인 경우에는 감액되고 남은 원처분을 소의 대상으로 하고, 증액처분은 증액처분만이 소의 대상이라고 판시한다.

⑻ 변경처분

1) 변경처분이 있는 경우 취소소송의 대상

① 학설
① 변경된 원처분과 변경처분은 각각 독립된 처분이므로 모두 소송의 대상이라는 견해, ② 원처분은 변경처분에 흡수되어 변경처분만이 소의 대상이 된다는 견해, ③ 변경처분은 원처분에 흡수되어 소멸되고 변경된 원처분만 소의 대상이 된다는 견해, ④ 소극적 변경처분은 변경되고 남은 원처분이 소의 대상이고, 적극적 변경처분의 경우에는 원처분을 취소하고 새로운 처분을 한 것인 바 변경처분만이 소의 대상이 된다는 견해 등이 대립된다.

② 판례
판례는 당초 처분보다 유리하게 변경하는 처분을 한 경우 취소소송의 대상은 변경된 당초처분이고, 제소기간의 준수 여부도 당초처분을 기준으로 판단하여야 판시하였다(대판 2007. 4. 27, 2004두9302). 단 당초 처분의 주요내용을 실질적으로 변경하는 내용으로 한 적극적 변경처분은 새로운 처분이므로 당초 처분은 소멸되고 새로운 처분만이 소의 대상이 된다고 판시하고 있다(2010두7765).

3. 거부처분

⑴ 서 설

거부처분이라 함은 국민의 공권력 행사의 신청에 대하여 처분의 발령은 거부하는 행정청의 의사작용을 의미한다.

거부처분은 신청에 대해 거절의 의사를 명백히 한다는 점에서 처음부터 아무런 의사표시를 하지 않는 부작위와 구별된다. 다만 법령상 일정기간의 경과에 의하여 거부로 간주되는 경우가 있다. 판례는 검사임용대상에서 제외한 자에 대하여 별다른 의사표시를 하지 않은 것과 관련하여 직접 거부의 의사표시를 하지 않았어도 본인이 이를 알았거나 알 수 있었던 경우에는 거부처분이 있는 것으로 간주한다고 한다.

⑵ 거부처분의 성립요건

1) 공권력행사의 거부일 것 - 사법작용의 거부이면 안됨

2) 국민의 권리의무에 영향을 미치는 것일 것

3) 법규상 또는 조리상의 신청권이 존재할 것

① 신청권의 법적 성질의 문제

판례는 행정소송법 제2조 제1항 제1호의 거부처분에 해당하기 위한 요건으로 ① 공권력행사의 거부일 것, ② 국민의 권리의무에 영향을 미치는 것일 것, ③ 법규상 또는 조리상 신청권이 있을 것 등을 요구하고 있다

이에 대해 학설은, ① 행정소송법 제2조 제1항 제1호의 문언상 거부처분의 처분성 인정요건으로 신청권을 요구하지 않는 바, 신청권은 공권으로 원고적격 문제라는 견해, ③ 취소소송의 소송물은 '처분의 위법성과 당사자의 권리침해'로 이해하면서 신청권을 소송요건문제가 아닌 본안문제로 보는 견해, ② 신청권은 응답의무만을 전제로 하는 형식적 권리이고 부작위의 성립요건에 처분의무(응답의무)가 행정소송법에서 명문으로 요구되는 것처럼 거부처분의 성립에도 처분의무가 요구되므로 거부처분이나 부작위의 대상적격이 인정되려면 판례처럼 신청권이 있어야 한다는 견해가 대립한다.

② 신청권의 판단기준

판례에 의할 경우 신청권의 존부는 구체적 사건에서 신청인이 누구인가를 고려하지 않고 관계법규의 해석에 의하여 일반국민에게 그러한 신청권이 인정되고 있는 것인지를 살펴 추상적으로 결정되는 것이고 신청인이 신청에 따른 단순한 응답을 받을 권리를 넘어서 신청의 인용이라는 만족적 결과를 얻을 권리를 의미하는 것은 아니다.

제2 재결 - 원처분주의와 재결주의

⑴ 개 설

1) 문제점

원처분과 재결은 모두 행정청의 공권력의 행사로서 다 같이 항고소송의 대상이 될 수 있다(행정소송법 제19조, 제2조 제1항 제1호). 그러나 양자를 모두 소송의 대상으로 허용할 경우 판결의 모순 저촉이나 소송경제에 반하게 되는 문제가 발생하게 된다. 따라서 일정하게 소송의 대상을 제한할 필요가 있는 데, 이에 관한 입법주의의 문제가 바로 원처분주의와 재결주의이다.[67]

2) 원처분주의와 재결주의의 의의

원처분주의란 원처분과 재결에 대하여 다 같이 소를 제기할 수 있으나, 원처분의 위법은 원처분에 대한 항고소송에서 주장할 수 있고, 재결에 대한 항고소송에서는 재결의 고유한 하자만을 주장할 수 있도록 하는 제도를 말한다.

재결주의란 원처분에 대해서는 제소가 허용되지 않고 재결에 대해서만 행정쟁송의 대상으로 인정하는 제도를 말한다.

3) 행정소송법의 규정 - 원처분주의(제19조)

⑵ 재결자체의 고유한 하자의 의미[68]

1) 서

재결자체의 고유한 위법이라 함은 원처분에는 없고 재결에만 있는 흠을 말한다.

2) 재결의 주체, 절차, 형식상 하자

재결의 종류와 상관없이 당연히 재결자체의 고유한 하자가 된다.

3) 내용상의 위법

판례는 재결자체의 고유한 위법에는 재결의 내용상 하자도 포함된다고 보고 있고, 다수설도 마찬가지이다.

① 각하재결의 경우

행정심판청구가 요건을 갖추었음에도 불구하고 부적법 각하한 경우에는 원처분에서 판단하지 않은 행정심판청구요건판단에 대한 하자인 바 재결자체의 고유한 하자이다. 따라서 각하재결에 대한 취소소송을 제기할 수 있다.

② 기각재결의 경우

원처분과 동일한 이유로 원처분을 유지하는 기각재결에 대하여 내용상의 하자가 있음을 주장하는 것은 원처분의 하자와 동일한 바 재결의 고유한 하자가 아니다.

③ 취소재결의 경우

통상의 경우는 취소재결에 대하여 처분의 상대방은 행정심판청구의 목적을 달성하므로 불복할 이유는 없으나 다만 제3자효적 행정행위에서는 취소재결에 의하여 원처분의 취소·변경되어 처분상대방의 권익이 침해될 수 있고 처분상대방은 취소재결에 대하여 취소소송을 제기할 것이다.

이러한 경우 ① 제3자효적 행정행위에 대한 취소재결은 원처분과 내용이 다른 바 취소재결의 하자는 재결의 고유한 하자에 해당한다는 견해와 ② 취소재결은 제3자(원처분 상대방)와의 관계에서는 별도의 처분으로 보아 처분에 대한 취소소송으로 보아야 한다는 견해가 대립한다.

판례는 취소재결의 내용상 하자를 재결의 고유한 위법으로 인정하여 취소재결이 취소소송의 대상이 된다고 판시하여 재결취소소송을 인정하고 있다.

---

67) 이재화, 전게서, 366면.

68) 이재화, 전게서, 367면.

④ 일부인용재결과 변경재결

① 일부인용재결과 변경재결의 내용상 하자는 재결의 고유한 위법이 아닌 바 원처분주의의 원칙상 재결은 소송의 대상이 되지 못하고 재결에 의하여 일부 취소되고 남은 원처분이나 변경된 원처분이 소송의 대상이 됨이 원칙이라는 견해와 ② 일부인용재결과 변경재결은 원처분을 대체하는 새로운 처분이므로 재결만이 소의 대상이라는 견해, ③ 일부인용재결은 일부인용되고 남은 원처분이 소의 대상이나, 적극적 변경재결은 원처분을 대체하는 새로운 처분이므로 적극적 변경재결이 소의 대상이라는 견해가 대립한다.

판례는 '1개월의 감봉처분을 견책처분으로 변경한 소청결정에 대한 취소소송에서 소청결정 자체에 고유한 위법을 주장하는 것으로 볼 수 없다. 따라서 이와 같은 경우 처분상대방은 징계권자를 항고소송의 피고로 하고 소청결정에 의해 변경되고 남은 원처분인 견책처분을 대상으로 항고소송을 제기하여야 한다'라고 판시하여 ①설과 동일한 입장을 취하였다.

⑤ 적극적 변경명령재결

① 적극적 변경명령재결의 내용상 하자는 재결의 고유한 위법이 아닌 바 적극적 변경명령재결에 의해 변경되고 남은 원처분이 소의 대상이라는 견해, ② 적극적 변경명령재결이 소의 대상이라는 견해, ③ 적극적 변경명령재결에 의해 변경된 변경처분의 소의 대상이라는 견해 등이 대립한다.

판례는 적극적 변경명령재결에 따라 변경처분이 행해진 경우 다투고자 하는 경우 변경명령재결에 의해 변경처분하여 변경되고 남은 원처분을 취소소송의 대상으로 하여야 한다고 본다. 따라서 제소기간준수여부도 적극적 변경명령재결에 따른 변경처분이 발령된 시점이 아니라 원처분 발령시점을 기준으로 하여야 한다는 입장이다.

⑶ 행정소송법 제19조 단서를 위반한 소송의 효과

재결의 고유한 위법 없이 제기한 재결취소소송은 각하하여야 한다는 견해도 있으나 재결 자체의 위법여부는 재결취소소송의 소송물이기 때문에 본안판단사항이기 때문에 기각하여야 한다는 통설과 판례가 타당하다.

⑷ 원처분주의에 대한 예외 - 재결주의

1) 의 의

행정소송법이 취하고 있는 원처분주의에 대한 예외로서 개별법이 재결주의를 채택하고 있는 경우가 있다.

재결주의가 채택되고 있는 경우에는 원처분은 항고소송의 대상이 되지 못하고, 행정심판 재결만이 소송의 대상이 된다. 이때에는 행정소송법 제19조 단서 같은 제한이 없으므로 원고는 재결취소소송에 있어서 재결 고유의 하자뿐만 아니라 재결로서 치유되지 않고 남은 원처분의 하자도 당연히 주장할 수 있다.

다만, 재결주의가 적용되는 행정처분이라 할지라도 당해 행정처분이 당연무효인 경우에 그 효력은 처음부터 당연히 발생하지 않은 것이므로 원처분의 무효확인의 소도 제기할 수 있다.

2) 재결주의가 채택된 것으로 인정되는 예

① 노동위원회 재심판정 - 재결주의

대법원 판례는 노동위원회 결정에 대한 행정소송은 원처분인 지방노동위원회의 결정이 아니라 중앙노동위원회의 재심판정을 대상으로 행정소송을 제기하여야 한다고 해석하여 이를 재결주의를 취하고 있는 것으로 본다(대판 1995. 9. 15, 95누6724).

② 감사원의 재심의판정 - 재결주의

③ 교원소청심사위원회 결정 - 원처분주의

사립학교교원 - 징계처분은 사법작용 / .사립학교교원은 민사소송으로 징계처분무효확인소송 또는 교원소청심사위원회에 소청심사를 청구하여 결정(원처분)을 받은 후 그 결정에 대하여 취소소송.

국공립학교교원 - 징계처분은 원처분, 교원소청심사위원회의 결정은 재결 / 원처분주의인 바 교원소청심사위원회의 결정에 고유한 하자가 없는 한 징계처분에 대한 취소소송제기

④ 토지수용소송에서의 재결주의 인정가능성

종래에는 구 토지수용법상의 수용재결에 대한 취소소송제기가 가능한가와 관련하여 구 토지수용법이 재결주의를 취하였다고 볼 명문의 규정이 없으므로 원처분주의라는 학설과 토지수용법의 취지가 재결주의를 채택하고 있는 것이므로 수용재결에 대한 취소소송은 불가능하다는 판례가 대립하였으나, 현행 공익사업을위한토지등의취득및보상에관한법률하에서는 원처분주의로 보는 것이 통설과 판례이다(대법원 2010.1.28. 선고 2008두1504 판결).

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 변호사 甲이 고객들과 다음과 같은 사항에 대하여 행정소송 또는 헌법소원의 대상인지에 대하여 법률상담을 하게 되었다. 변호사 甲의 상담내용 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함) (변호사 모의시험 문제)

A. '임용전의 교육 및 실무수습기간을 재직기간에 포함시켜 계산해 달라는 신청을 국민연금관리공단이 거부한 행위'에 대해서는 먼저 행정소송을 제기하지 않고 바로 재직기간의 계산은 장차 지급하여야 할 퇴직급여를 결정하기 위한 필수불가결한 행위이기 때문에 헌법재판소법 제68조 제1항의 헌법소원심판을 청구할 수 있다.

B. '관할구청장이 주택개량재개발사업구역 내 세입자에 대하여 영구임대아파트의 입주권부여대상자가 아니라고 한 통지'는 법률에 의한 통지로서 일정한 효과가 발생하므로 행정소송을 제기할 수 있다.

C. '교육부장관의 내신성적 산정기준에 관한 시행지침'은 일반적 추상적인 법령 내지 내규에 불과하므로 행정소송을 제기할 수 없다.

D. '한국인과 결혼한 중국인 배우자가 한국에 입국하기 위해 결혼동거목적거주 사증발급을 신청함에 있어 주중국 대한민국대사가 한국인에게 중국인 배우자와 결혼하게 된 경위 등을 당해 한국인이 직접 기재한 서류를 제출할 것을 요구한 조치'는 사증발급신청을 수리할 수 있는 요건으로서 결혼경위 등을 기재할 의무를 부과한 고권적 행위에 해당되어 헌법재판소법 제68조 제1항의 헌법소원을 청구할 수 있다.

① A, C, D ② A, B, C, D
③ B, C, D ④ B, C
⑤ C, D

해설 & 정답

유형 헌법·행정법 결합형, 법률지식형

A. [×] 가. 공권력의 불행사에 대한 헌법소원은 공권력의 주체에게 헌법에서 유래하는 작위의무가 특별히 구체적으로 규정되어 있어 이에 의거하여 기본권의 주체가 공권력의 행사를 청구할 수 있음에도 공권력의 주체가 그 의무를 해태하는 경우에 허용되는 것이므로, 작위의무가 없는 공권력의 불행사에 대한 헌법소원은 부적법하다. 따라서, 기본권의 주체가 행정기관의 내부적 의사결정에 불

과하여 직접 국민의 권리의무에 영향을 미치지 아니하는 행위를 청구한 것에 대하여 공권력의 주체가 이를 거부하였다 하더라도 그 거부행위는 헌법소원의 대상이 되는 공권력의 불행사에 해당하지 않는 것이다.

나. 공무원인 청구인은 공무원연금관공단이 청구인의 퇴직급여를 산정할 때 공무원으로 임용받기 전에 이수한 교육 및 실무수습기간도 재직기간에 포함하여 계산하여 달라는 신청을 거부하는 내용의 처분을 하였다고 주장하면서 기본권 침해여부를 다투고 있는 이 사건에 있어서, 재직기간의 계산행위는 공무원연금관리공단이 장차 청구인에게 지급하여야 할 퇴직급여를 결정을 하기 위한 준비행위 또는 부수적 행위로 그 자체로는 직접 국민의 권리의무에 영향을 미치지 아니하는 행위로서 비권력적 사실행위에 불과한 것이므로, 청구인이 퇴직급여의 결정에 관하여 행정소송을 제기하여 다툴 수 있음은 별론으로 하고, 그 결정에 필요한 준비행위 또는 부수적 행위에 불과한 재직기간의 계산을 제대로 하여 달라는 청구는 공무원연금관리공단에게 공권력의 행사를 구하는 것이 아니다. 따라서, 위와 같은 공무원연금관리공단의 거부행위는 헌법소원의 대상이 되는 공권력의 불행사라 할 수 없으므로, 그에 대한 헌법소원 심판청구는 부적법하다(헌재 2004.8.26, 2003헌마916).

B. [○] 가. 도시재개발법 제20조 제3항에 의하면 재개발사업을 시행하는 조합은 조합이 시행하는 재개발구역 안의 토지 또는 건축물에 대한 전세권자, 등기된 임차권자 등을 정관이 정하는 바에 의하여 참여조합원으로 가입시킬 수 있도록 규정하고 있고, 서울특별시 주택개량재개발사업 업무지침(서울특별시 예규 제515호)에 의하면 조합설립위원회는 구역 내 세입자 이주대책과 관련하여 구역 내 세입자 중 공공용지의취득및손실보상에관한특례법시행규칙 제30조의2 규정에 해당하는 세입자에게는 규칙이 정한 주거대책비를 지급하고, 주거대책비 지급대상 세입자 중 당해 구역 합동재개발사업을 위한 사업계획결정고시가 있은 날 현재 당해 구역 안에서 3월 이상 거주하는 주거용 건물의 세입자는 주거대책비와 영구임대주택 입주권 중 택일할 수 있고, 조합은 영구임대주택 건립방법을 가, 나 방법 중에서 택일하도록, 정관에 기재하거나 정하도록 규정하고 있는바, 조합의 정관에 위와 같은 내용의 규정을 두도록 하고 있는 이상 관할 구청으로서는 위 특례법시행규칙 제30조의2 규정에 해당하는 세입자에게 주거대책비를 지급하는 경우가 아니면 관리처분계획으로 임대주택을 조합으로부터 양수받거나 조합으로부터 영구임대주택 건립에 필요한 토지를 제공받아 영구임대주택을 직접 건립하여야 하는 것이며, 위 규정에 해당하는 세입자가 관할 구청장에게 영구임대주택 입주권을 신청하게 되면 관할 구청장으로서는 세입자에게 입주권을 부여할 의무를 진다.

나. 관할 구청장이 위 "가"항의 세입자에 대하여 재개발구역 내에 건립되는 영구임대 아파트의 입주권 부여대상자가 아니라고 통보한 것은 세입자를 영구임대 아파트의 입주권 부여대상에서 제외시키는 행정처분을 한 것으로 보는 것이 옳다(대판 1993.2.23, 92누5966).

C. [○] 가. 항고소송의 대상이 되는 행정처분은 행정청의 공법상의 행위로서 특정사항에 대하여 법률에 의하여 권리를 설정하고 의무를 명하며, 기타 법률상 효과를 발생케 하는 등 국민의 권리의무에 직접관계가 있는 행위이어야 하고, 그 자체로서 국민의 구체적인 권리의무에 직접적인 변동을 초래케 하는 것이 아닌 일반적, 추상적인 법령 또는 내부적 내규 및 내부적 사업계획에 불과한 것 등은 그 대상이 될 수 없다.

나. 교육부장관이 내신성적 산정기준의 통일을 기하기 위해 대학입시기본계획의 내용에서 내신성적 산정기준에 관한 시행지침을 마련하여 시·도 교육감에서 통보한 것은 행정조직 내부에서 내신성적 평가에 관한 내부적 심사기준을 시달한 것에 불과하며, 각 고등학교에서 위 지침에 일률적으로 기속되어 내신성적을 산정할 수밖에 없고 또 대학에서도 이를 그대로 내신성적으로 인정하여 입학생을 선발할 수밖에 없는 관계로 장차 일부 수험생들이 위 지침으로 인해 어떤 불이익을 입을 개연성이 없지는 아니하나, 그러한 사정만으로서 위 지침에 의하여 곧바로 개별적이고 구체적인 권리의 침해를 받은 것으로는 도저히 인정할 수 없으므로, 그것만으로는 현실적으로 특정인의 구체적인 권리의무에 직접적으로 변동을 초래케 하는 것은 아니라 할 것이어서 내신성적 산정지침을 항고소송의 대상이 되는 행정처분으로 볼 수 없다(대판 1994.9.10, 94두33).

D. [○] 가. 이 사건 전화예약에 의한 사증신청접수일 지정행위로 말미암아 위 장○염의 경우 접수일이 전화예약일로부터 약 1개월 보름 정도 뒤에 지정된 것에 불과하고, 또한 그와 같은 접수일 지정제도는 사증신청인에 대한 사증발급 여부에는 아무런 영향을 미치지 않는다는 것도 명백하므로, 이로 인하여 사증발급과 관련된 위 장○염 또는 청구인의 기본권이 제한되거나 권리관계에 변동이 생길 위험성은 없다고 할 것이다. 따라서 피청구인이 전화예약을 통하여 사증신청접수일을 지정한 행위는 단순한 비권력 사실행위에 불과하여, 헌법소원의 대상이 되는 공권력의 행사에 해당하지 아니하므로 이 부분에 대한 심판청구는 부적법하다.

나. 국가기관인 피청구인이 청구인으로 하여금 결혼경위 등을 기재하도록 요구한 행위는 청구인의 처 장○염이 결혼동거목적거주 사증발급신청을 함에 있어 동 신청이 수리될 수 있는 요건으로서, 법령의 근거에 따라 청구인과 위 장○염에게 결혼경위, 소개인관계, 교제경비내역, 교제경위 등을 '초청사유서'와 '결혼동거사증신청 첨부서류'에 기재해야 하는 의무를 부과한 고권적 행위이고, 따라서 피청구인의 이와 같은 요구는 청구인과 위 장○염에 대하여 구속력을 갖는 권력적 사실행위로서 헌법소원의 대상이 된다.

다. 이 사건 결혼경위 등 기재요구행위는 이미 종료된 권력적 사실행위로서 행정심판이나 행정소송의 대상으로 인정되기 어려울 뿐만 아니라 소의 이익이 부정될 가능성이 많아 헌법소원심판을 청구하는 외에 달리 효과적인 구제방법이 없으므로 보충성의 원칙에 대한 예외에 해당된다.

라. 피청구인은 청구인의 이 헌법소원 청구이후 위 결혼동거목적거주 사증을 2003. 2. 13. 발급하여 같은 달 17. 이를 위 장○염에게 교부하였다. 그러나, 한국인과 결혼한 중국인 배우자가 결혼동거목적거주 사증을 신청하고자 하는 경우에 당해 한국인에게 결혼경위 등을 기재하도록 요구하는 제도는 위 장○염에 대하여 동 사증을 발급·교부한 것과는 관계없이 앞으로도 계속 시행될 것이 예상되므로, 청구인과 같이 중국인 배우자와 결혼하려는 자들에게 대하여 침해반복의 위험성이 여전히 존재하고 이에 대하여는 아직 헌법적 해명이 이루어진 바 없어 이에 대한 해명의 필요성이 있는 등 심판의 이익이 있다(헌재 2005.3.31, 2003헌마87).

정답 ③

2. 「도로교통법」은 자동차의 운전자는 그 자동차를 운전할 때에는 좌석안전띠를 매어야 할 것을 의무화하고 있다. 甲은 좌석안전띠를 착용하지 않고 승용차를 운전하던 중 경찰관에게 적발되어 범칙금 30,000원의 납부통고를 받았다. 甲의 법적 지위에 대한 설명 중 잘못된 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함) (변호사 모의시험 문제)

① 일반도로에서 운전할 때 운전자가 좌석안전띠를 매도록 한 것은 공공복리를 위한 것으로 인정될 수 있다. 교통사고인명피해를 줄이기 위한 것이기 때문이다.

② 자동차 안에서 이루어지는 활동 중 일부는 사생활의 영역에 속할 수도 있다. 자동차는 여가시간의 여행과 오락활동 등에 이용될 수도 있기 때문이다.

③ 자동차를 도로에서 운전하는 중에 좌석안전띠를 착용할 것인가의 여부는 '사생활의 기본조건'이라거나 자기결정의 핵심적 영역 또는 인격적 핵심과 관련된다고 보기 어렵다.

④ 甲은 위 범칙금 납부통고에 대하여 행정소송을 청구할 수 없다. 범칙금 납부통고는 행정소송의 대상이 되는 행정처분이 아니기 때문이다.

⑤ 甲은 통고처분에 대해 이의가 있는 경우에는 통고처분에 대하여 즉결심판청구서를 제출하여야 한다.

해설 & 정답

유형 헌법·행정법 결합형, 법률지식형

①②③ 가. 자동차 운전자에게 좌석안전띠를 매도록 하고 이를 위반했을 때 범칙금을 납부하도록 통고하는 것은, 교통사고로부터 국민의 생명 또는 신체에 대한 위험과 장애를 방지·제거하고 사회적 부담을 줄여 교통질서를 유지하고 사회공동체의 상호이익을 보호하는 공공복리를 위한 것으로 그 입법목적이 정당하고, 운전자의 불이익은 약간의 답답함이라는 경미한 부담이고 좌석안전띠 미착용으로 부담하는 범칙금이 소액인데 비하여 좌석안전띠 착용으로 달성하려는 공익은 동승자를 비롯한 국민의 생명과 신체를 보호하고 교통사고로 인한 사회적인 비용을 줄여 사회공동체의 이익을 증진하는 것이므로 달성하고자 하는 공익이 침해되는 청구인의 좌석안전띠를 매지 않을 자유라는 사익보다 크며, 제도의 연혁과 현황을 종합하여 볼 때 청구인의 일반적 행동자유권을 비례의 원칙에 위반되게 과도하게 침해하는 것이 아니다.

나. 일반 교통에 사용되고 있는 도로는 국가와 지방자치단체가 그 관리책임을 맡고 있는 영역이며, 수많은 다른 운전자 및 보행자 등의 법익 또는 공동체의 이익과 관련된 영역으로, 그 위에서 자동차를 운전하는 행위는 더 이상 개인적인 내밀한 영역에서의 행위가 아니며, 자동차를 도로에서 운전하는 중에 좌석안전띠를 착용할 것인가 여부의 생활관계가 개인의 전체적

인격과 생존에 관계되는 '사생활의 기본조건'이라거나 자기결정의 핵심적 영역 또는 인격적 핵심과 관련된다고 보기 어려워 더 이상 사생활영역의 문제가 아니므로, 운전할 때 운전자가 좌석안전띠를 착용할 의무는 청구인의 사생활의 비밀과 자유를 침해하는 것이라 할 수 없다.

다. 제재를 받지 않기 위하여 어쩔 수 없이 좌석안전띠를 매었다 하여 청구인이 내면적으로 구축한 인간양심이 왜곡·굴절되고 청구인의 인격적인 존재가치가 허물어진다고 할 수는 없어 양심의 자유의 보호영역에 속하지 아니하므로, 운전 중 운전자가 좌석안전띠를 착용할 의무는 청구인의 양심의 자유를 침해하는 것이라 할 수 없다(헌재 2003.10.30, 2002헌마518).

④⑤ 도로교통법 제118조에서 규정하는 경찰서장의 통고처분은 행정소송의 대상이 되는 행정처분이 아니므로 그 처분의 취소를 구하는 소송은 부적법하다고 할 것이다. 도로교통법상의 통고처분을 받은 자가 그 처분에 대하여 이의가 있는 경우에는 통고처분에 따른 범칙금의 납부를 이행하지 아니함으로써 경찰서장의 즉결심판청구에 의하여 법원의 심판을 받을 수 있게 될 뿐이다(대판 1995.6.29, 95누4674).

정답 ⑤

3. 다음의 소 중 적법한 소로 인정하기 어려운 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

(변호사 모의시험 문제)

① 이미 납부한 부담금을 부당이득으로 환수 받고자 하는 취지에서 당해 부담금부과처분의 무효 확인을 구하는 소를 제기한 경우

② 상고심 계속 중 과세처분청인 피고가 당해 과세처분을 직권으로 취소한 경우

③ 공무원 징계면직처분 취소소송 계속 중 정년에 도달한 경우

④ 업무정지기간이 만료된 후 제기된 업무정지처분취소소송으로서, 법령에서 업무정지처분을 받은 전력을 제재의 가중요건을 규정하고 있는 경우

⑤ 현역입영통지처분 취소소송 중 현역병으로 입영한 경우

해설 & 정답

유형 준사례형

① 권리보호의 필요(협의의 소의 이익)성 문제이다.

[1] 행정소송은 행정청의 위법한 처분 등을 취소·변경하거나 그 효력 유무 또는 존재 여부를 확인함으로써 국민의 권리 또는 이익의 침해를 구제하고 공법상의 권리관계 또는 법 적용에 관한 다툼을 적정하게 해결함을 목적으로 하므로, 대등한 주체 사이의 사법상 생활관계에 관한 분쟁을 심판대상으로 하는 민사소송과는 목적, 취지 및 기능 등을 달리한다. 또한 행정소송법 제4조에서는 무효확인소송을 항고소송의 일종으로 규정하고 있고, 행정소송법 제38조 제1항에서는 처분 등을 취소하는 확정판결의 기속력 및 행정청의 재처분 의무에 관한 행정소송법 제30조를 무효확인소송에도 준용하고 있으므로 무효확인판결 자체만으로도 실효성을 확보할 수 있다. 그리고 무효확인소송의 보충성을 규정하고 있는 외국의 일부 입법례와는 달리 우리나라 행정소송법에는 명문의 규정이 없어 이로 인한 명시적 제한이 존재하지 않는다. 이와 같은 사정을 비롯하여 행정에 대한 사법통제, 권익구제의 확대와 같은 행정소송의 기능 등을 종합하여 보면, 행정처분의 근거 법률에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익이 있는 경우에는 행정소송법 제35조에 규정된 '무효확인을 구할 법률상 이익'이 있다고 보아야 하고, 이와 별도로 무효확인소송의 보충성이 요구되는 것은 아니므로 행정처분의 무효를 전제로 한 이행소송 등과 같은 직접적인 구제수단이 있는지 여부를 따질 필요가 없다고 해석함이 상당하다.

[대법관 이홍훈의 보충의견] 무효확인소송의 보충성 인정의 문제는 행정소송법 제35조에 규정된 '무효확인을 구할 법률상 이익'의 해석론에 관한 것으로서 행정소송의 특수성, 무효확인소송의 법적 성질 및 무효확인판결의 실효성, 외국의 입법례, 무효확인소송의 남소 가능성 및 권익구제 강화 등의 측면에서 볼 때, 무효확인소송의 보충성을 요구하지 않는 것이 행정소송의 목적을 달성할 수 있고 소송경제 등의 측면에서도 타당하며 항고소송에서 소의 이익을 확대하고 있는 대법원 판례의 경향에도 부합한다.

[2] 구 하수도법(2006.9.27. 법률 제8014호로 전문 개정되기 전의 것) 제32조 제2항 및 구 수원시 하수도사용조례(2007.1.3. 조례 제2659호로 개정되기 전의 것) 제17조 제2항 제2호 (나)목 ⑴에서 타행위로 인하여 필요하게 된 공공하수도에 관한 공사에 요하는 비용의 전부를 타행위자가 부담하도록 한 것은, 타행위에 해당하는 사업으로 인하여 발생할 것이 예상되는 하수를 처리하는 데 필요한 공공하수도 설치에 소요되는 비용에 대하여는 그 원인을 조성한 타행위자로 하여금 이를 부담하게 하려는 데 그 취지가 있으므로, 이러한 타행위자가 그 사업으로 인하여 발생할 것으로 예상되는 하수의 처리에 필요한 공공하수도 공사비용을 부담한 부분에 대하여는 이와 별도로 하수도법 제32조 제4항 및 이 사건 조례 제17조 제2항 제4호에 따른 원인자부담금을 부과할 수 없다. 그리고 이러한 타행위에 해당하는 사업의 기본 또는 실시 설계보고서에 반영된 하수량은 당해 사업으로 조성된 토지의 이용을 포함하여 사업계획에 따라 그 사업을 시행할 경우에 발생할 것으로 예상되는 하수량을 의미하고, 여기에는 당해 사업으로 조성된 토지에 그 사업계획에서 정해진 규모 및 용도에 따라 건축할 건축물로부터 발생할 것으로 예상되는 하수량도 포함된다. 따라서 건축물에 관하여 공공하수도 공사비용을 부담한 부분에 대하여도 마찬가지다(대판 2008.3.20, 2007두6342).

사안은 한국토지공사로부터 토지를 매수하여 그 위에 건물을 신축한 이후 수원시장의 하수도원인자부담금 부과처분에 따라 이를 납부한 원고가 그 처분의 무효를 주장하여 부당이득반환청구소송을 제기하고 아울러 그 처분에 대하여 무효확인을 구하는 예비적 청구를 한 사건에서 무효확인의 소가 소의 이익이 있다고 한 것이다.

② [1] 행정처분이 취소되면 그 처분은 취소로 인하여 그 효력이 상실되어 더 이상 존재하지 않는 것이고, 존재하지 않는 행정처분을 대상으로 한 취소소송은 소의 이익이 없어 부적법하다.
[2] 행정청이 당초의 분뇨 등 관련영업 허가신청 반려처분의 취소를 구하는 소의 계속중, 사정변경을 이유로 위 반려처분을 직권취소함과 동시에 위 신청을 재반려하는 내용의 재처분을 한 경우, 당초의 반려처분의 취소를 구하는 소는 더 이상 소의 이익이 없게 되었다고 한 사례(대판 2006.9.28, 2004두5317).

③ 징계처분으로서 감봉처분이 있은 후 공무원의 신분이 상실된 경우에도 위법한 감봉처분의 취소가 필요한 경우에는 위 감봉처분의 취소를 구할 소의 이익이 있다(대판 1977.7.12, 74누147).

④ 행정처분의 효력기간이 경과하였다고 하더라도 그 처분을 받은 전력이 장래에 불이익하게 취급되는 것으로 법정의 가중요건으로 되어 있고, 이후 그 법정가중요건에 따라 새로운 제재적인 행정처분이 가해지고 있다면 선행행정처분의 잔존으로 인하여 법률상의 이익이 침해되고 있다고 볼만한 특별한 사정이 있는 경우에 해당한다고 볼 것인바, 연 2회이상 건축사의 업무정지명령을 받은 경우 그 정지기간이 통산하여 12월 이상이 된 때를 건축사사무소의 등록을 취소할 경우의 하나로 규정하고 있는 건축사법 제28조 제1항 제5호의 규정은 제재적인 행정처분의 법정가중요건을 규정해 놓은 것으로 보아야 하고, 원고가 변론재개신청과 함께 이 사건 건축사업무정지명령이 전제가 되어 원고의 건축사사무소 등록이 취소되었음을 알 수 있는 소명자료까지 제출하고 있다면, 이 사건 건축사업무정지명령에서 정한 정지기간이 도과하였다고 하더라도 그 처분으로 인하여 원고에게는 건축사사무소등록취소라는 법률상의 이익이 침해되고 있다는 사정을 나타내 보인 것이라고 할 것이므로 원심으로서는 이 사건 건축사업무정지 명령취소소송에 있어서 소의 이익 유무를 판단하기 위하여 변론의 재개를 허용하는 방법 등으로 충분한 심리를 다했어야 한다(대판 1990.10.23, 90누3119).

⑤ [1] 병역법 제2조 제1항 제3호에 의하면 '입영'이란 병역의무자가 징집·소집 또는 지원에 의하여 군부대에 들어가는 것이고, 같은 법 제18조 제1항에 의하면 현역은 입영한 날부터 군부대에서 복무하도록 되어 있으므로 현역병입영통지처분에 따라 현실적으로 입영을 한 경우에는 그 처분의 집행은 종료되지만, 한편, 입영으로 그 처분의 목적이 달성되어 실효되었다는 이유로 다툴 수 없도록 한다면, 병역법상 현역입영대상자로서는 현역병입영통지처분이 위법하다 하더라도 법원에 의하여 그 처분의 집행이 정지되지 아니하는 이상 현실적으로 입영을 할 수밖에 없으므로 현역병입영통지처분에 대하여는 불복을 사실상 원천적으로 봉쇄하는 것이 되고, 또한 현역입영대상자가 입영하여 현역으로 복무하는 과정에서 현역병입영통지처분 외에는 별도의 다른 처분이 없으므로 입영한 이후에는 불복할 아무런 처분마저 없게 되는 결과가 되며, 나아가 입영하여 현역으로 복무하는 자에 대한 병적을 당해 군 참모총장이 관리한다는 것은 입영 및 복무의 근거가 된 현역병입영통지처분이 적법함을 전제로 하는 것으로서 그 처분이 위법한 경우까지를 포함하는 의미는 아니라고 할 것이므로, 현역입영대상자로서는 현실적으로 입영을 하였다고 하더라도, 입영 이후의 법률관계에 영향을 미치고 있는 현역병입영통지처분 등을 한 관할지방병무청장을 상대로 위법을 주장하여 그 취소를 구할 소송상의 이익이 있다(대판 2003.12.26, 2003두1875).

정답 ②

♣ 학습내용 정리

1. 취소소송의 대상은 처분과 재결이다.
2. 행정소송법은 원처분주의를 취하여 재결에 고유한 위법이 있는 경우에 한하여 재결취소소송을 제기할 수 있다.

제34강 취소소송의 소송요건 II

♣ 학습목표

취소소송의 소송요건으로 당사자능력과 원고적격에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

당사자능력

원고적격

♣ 사전테스트

1. 충북대학교 총장도 항고소송의 원고가 될 수 있다.
   정답 : X

2. 반사적 이익을 침해받은 제3자도 원고적격이 인정된다.
   정답 : x

3. 경원자소송에서는 원고적격이 인정된다.
   정답 : O

♣ 돌발퀴즈

대법원은 보호가치 이익구제설을 취하고 있다.

[정답] ×

[해설] 판례는 행정소송법 제12조 제1문의 법률상 이익에 대하여 법률상 보호이익설을 취하고 있다.

♣ 강의내용

제1 당사자능력

1. 원칙

소송의 주체(원고·피고·참가인)가 될 수 있는 자격을 말한다. 민법 기타 법률에 의하여 권리능력을 가진 자(자연인·법인)는 당사자능력을 가진다(행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제51조). 법인격 없는 사단·재단도 대표자 또는 관리인이 있으면 단체의 이름으로 당사자가 될 수 있다(민사소송법 제52조).

따라서 자연인 및 법인은 물론 비법인 사단이나 재단은 당사자소송의 원·피고 및 항고소송의 원고가 될 수 있으나, 당사자능력이 없는 행정기관 등은 원칙적으로 당사자소송의 원·피고 및 항고소송의 원고가 될 수 없다

2. 국가기관이 항고소송의 원고능력 및 원고적격이 인정되는지

⑴ 원칙

행정기관은 자연인, 법인이나 법인격없는 사단, 재단이 아닌 바 원칙적으로 항고소송의 원고될 수 있는 당사자능력이 없다. 따라서 행정기관이 원고가 되어 취소소송을 제기하면 당사자능력흠결로 각하하여야 한다.

예비적 원고 충북대학교 총장의 소는, 원고 충북대학교 총장이 원고 대한민국이 설치한 충북대학교의 대표자일 뿐 항고소송의 원고가 될 수 있는 당사자능력이 없어 부적법하다(대법원 2007. 9. 20, 2005두6935 판결).

⑵ 예외

최근 판례는 예외적으로 국가기관도 다른 국가기관의 조치요구에 불응할 방법이 없고 이에 불응할 경우에 중대한 불이익이 근거법에 규정된 경우에는 당사자능력과 원고적격을 갖는다고 판시하였다(대법원 2013.07.25. 선고 2011두1214 판결)

Ⅲ. 당사자적격

1. 서설

2. 원고적격

⑴ 행정소송법의 규정

행정소송법 제12조 제1문은『취소소송은 처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다』고 규정하고 있다.

그러나 행정소송법은「법률상 이익」의 의미에 대해서는 아무런 언급이 없어 그 해석과 관련하여 견해의 대립이 있다.

특히, 당해 처분의 상대방이 아닌 제3자인 자가 제기한 취소소송에 있어서 제3자에게 원고적격이 있는가와 관련하여 위「법률상 이익」에 대한 해석과 관련된 학설의 대립은 중요한 의미를 지닌다 할 것이다.

⑵ 법률상 이익의 의미

1) 학설

행정소송법 제12조 제1문의 “법률상 이익”의 의미와 관련해서 ① 권리의 침해를 받은 자만이 원고가 될 수 있다는 권리구제설, ② 구체적 권리뿐만 아니라 법률에 의하여 보호되는 이익을 침해받은 자도 원고적격이 있다는 법률상 보호이익설, ③ 권리나 법률상 보호이익뿐만 아니라 보호가치 있는 이익을 침해받은 자에게도 원고적격을 인정하여야 한다는 보호가치 있는 이익설, ④ 침해당한 개인의 이익의 성질에 관계없이 당해 처분에 대한 소송에 있어 가장 적합한 이해관계를 가지는 자에게 원고적격을 인정하여야 한다는 적법성보장설 등으로 견해가 나뉜다.

2) 판례

판례는 “행정처분의 직접 상대방이 아닌 제3자라 하더라도 당해 행정처분으로 인하여 법률상 보호되는 이익을 침해당한 경우에는 취소소송을 제기하여 그 당부의 판단을 받을 자격이 있다 할 것이나, 여기에서 말하는 법률상 보호되는 이익이라 함은 당해 처분의 근거 법규 및 관련 법규에 의하여 보호되는 개별적·직접적·구체적 이익이 있는 경우를 말하고, 공익보호의 결과로 국민 일반이 공통적으로 가지는 일반적·간접적·추상적 이익이 생기는 경우에는 법률상 보호되는 이익이 있다고 할 수 없다”라고 판시하여 법률상 보호이익설의 입장을 취하고 있다.

⑶ 「법률」의 범위에 관하여

1) 문제점

행정소송법 제12조 제1문의 「법률상 이익」에 대하여 법률상 보호이익설에 따를 때, 그 판단 근거인 법률의 범위를 어디까지로 볼 것인지에 따라 원고적격인정여부가 달라질 수 있다.

2) 학 설

법률의 범위에 대하여 첫째 처분의 근거 법규(실체법규와 절차법규)뿐만 아니라 관련 법규까지 포함시키는 견해, 둘째 처분의 근거 법규 및 관련 법규 외에 보충적으로[69] 헌법상 기본권까지 포함시키는 견해 등이 대립하고 있다.

3) 판 례

대법원은 법률상 이익의 범위를 계속 확대시키는 경향에 있다. 대법원은 당해 처분의 근거 법규 뿐만 아니라 관련 법규까지 법률의 범위를 확장해 원고적격을 넓게 인정하고 있으며, 헌법재판소는 기본권에 직접 근거하여 법률상 이익을 인정하기도 한다.

다만 대법원은 헌법상 환경권에 근거하여 제3자에게 원고적격을 인정할 수는 없다고 판시하였다. 그리고 아직 헌법상 기본권조항에 의하여 제3자에게 원고적격을 인정하고 있는 대법원 판례는 보이지 않는다.

---

69) 제3자가 당해 처분 등으로 침해받았다고 주장하는 이익이 근거법규 및 관련법규에 의해서 보호되지 아니하는데 그러한 이익이 중대하고 수인할 수 없는 경우에는 보충적으로 헌법상 기본권인 자유권적 기본권, 평등권, 재산권에 의해 제3자에게 공권을 인정하자는 것이다.

⑷ 구체적인 판단[70]

① 원고에게 당해 처분으로 침해된 이익 또는 침해될 우려가 있는 이익이 있어야 한다[71]. 이에 대한 입증책임은 원고에게 있다.

② 그러한 이익은 원고 자신의 개인적 이익(사적 이익)이어야 한다[72].

③ 처분의 근거법규 내지 관련법규에 의해 보호되는 이익의 침해가 있어야 한다.[73]

⑸ 구체적인 예

1) 주민소송 또는 인인소송

① 의의

주민소송이나 인인소송에서 주민 등에게 원고적격이 인정되는지 여부는 근거법규나 관련법규가 국민일반의 공익뿐만 아니라 주민 등의 사익도 보호하기 위한 취지로 해석되는지에 따라 판단될 문제이다.

② 환경영향평가법령을 근거법령으로 보고 환경영향평가대상 지역주민에게 원고적격 인정한 판례

(가) 환경영향평가대상지역내의 주민 : 당연히 원고적격인정

판례는 처분을 함에 있어 환경영향평가를 거치도록 규정되어 있는 경우 그러한 규정의 취지는 환경영향평가 대상지역 안의 주민들이 수인한도를 넘는 환경침해를 받지 아니하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있는 개별적 이익까지도 보호하고 있다고 보이므로, 특단의 사정이 없는 한 이들 주민들에게는 당해 처분으로 인해 환경상 이익에 대한 침해 또는 침해우려가 있는 것으로 사실상 추정되어 원고적격이 인정된다고 본다(대법원 2006.3.16. 선고 2006두330 전원합의체 판결)

(나) 환경영향평가대상지역외의 주민 :

당해 사업으로 인하여 그 처분 전과 비교하여 수인한도를 넘는 환경피해를 받거나 받을 우려가 있는 경우에는 이를 입증한 주민에 대해서만 원고적격인정(대법원 2006.3.16. 선고 2006두330 전원합의체 판결).

2) 기존업자의 신규업자에 대한 인허가처분의 취소소송(경업자소송)

① 서

② 원고적격인정여부 기준

---

70) 박균성, 제742면 참조.

71) 따라서 당해 처분으로 원고에게 침해된 이익이나 침해될 우려가 있는 이익이 없으면 법률상 이익이 인정되지 않는다. 침해된 이익은 예컨대 허가취소처분의 상대방이 허가취소처분으로 영업권을 바로 침해받는 것을 말하고 침해될 우려가 있는 이익은 예컨대 위법한 건축허가로 아직 건물이 건축되기 전이라도 인근주민은 위 위법한 건축허가대로 건물이 지어지면 일조권을 침해받을 우려가 있는 것을 말한다.

72) 따라서 원고가 아닌 다른 자의 이익이나 공익은 법률상 이익이 아니다.

73) 따라서 원고가 침해받은 이익이 있더라도 그러한 이익이 처분의 근거법규나 관련법규에 의해 보호되는 이익이 아니면 법률상 이익이 인정되지 않는다. 즉, 사실상 이익이나 반사적 이익은 법률상 이익이 아니다.

강학상 특허 - 원고적격인정 / 강학상 허가 - 원칙적으로 원고적격부정, 예외적으로 허가근거법규에 거리제한규정, 업소갯수제한규정, 영업구역제한규정 등이 있으면 원고적격인정

③ 기존업자가 특허기업인 경우 원고적격 인정

④ 기존업자가 허가기업인 경우 원고적격 부인

⑤ 기존기업이 허가기업이더라도 거리제한규정에 의해 원고적격인정한 판례
거리제한규정이 시행규칙에 규정된 경우(대판 2008. 3. 27, 2007두23811).

3) 경원자소송

경원자관계란 인허가 등에 있어서 서로 양립할 수 없는 출원(신청)을 제기한 자로서 일방에 대한 허가가 타방에 대한 불허가로 귀결될 수 밖에 없는 관계를 의미한다. 이 때 서로 양립할 수 없다는 의미는 성질상 양립할 수 없는 경우[74]나 법규상 양립할 수 없는 경우[75]를 포함한다.

이러한 경원자관계에 있는 경우 행정청의 심사의 잘못으로 우선 순위가 있는 자신에 대하여 인허가가 발령되지 않고 타인에 대하여 발령되었다고 주장하는 자는, 자신에 대한 인허가거부처분 취소소송을 제기할 수 있을 뿐만 아니라 타인에 대한 인허가 취소소송을 제기할 수도 있고 양자를 병합제기할 수도 있다.

이러한 경원자소송을 제기하는 자에게는 법률상 보호되는 이익, 즉 원고적격이 있다는 것이 통설과 판례의 태도이다.

6) 기타

공유수면매립목적 변경 승인처분으로 갑 수녀원(재단법인)에 소속된 수녀 등이 쾌적한 환경에서 생활할 수 있는 환경상 이익을 침해받는다고 하더라도 이를 가리켜 곧바로 갑 수녀원의 법률상 이익이 침해된다고 볼 수 없고 갑 수녀원이 운영하는 쨈 공장에 직접적이고 구체적인 재산적 피해가 발생한다거나 갑 수녀원이 폐쇄되고 이전해야 하는 등의 피해를 받거나 받을 우려가 있다는 점 등에 관한 증명도 부족하다는 이유로, 갑 수녀원에 처분의 무효 확인을 구할 원고적격이 없다고 한 판례(대법원 2012.6.28. 선고 2010두2005 판결).

김해시장이 낙동강에 합류하는 하천수 주변의 토지에 구 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제13조에 따라 공장설립을 승인하는 처분을 한 사안에서, 공장설립으로 수질오염 등이 발생할 우려가 있는 취수장에서 물을 공급받는 부산광역시 또는 양산시에 거주하는 주민들도 위 처분의 근거 법규 및 관련 법규에 의하여 법률상 보호되는 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 주민으로서 원고적격이 인정된다고 한 판례(대법원 2010.4.15. 선고 2007두16127 판결)

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 甲과 乙은 국가에서 실시하는 시험에 응시하였으나 불합격처분을 받았다. 甲은 불합격처분의 원인이 된 시험문제에 하자가 있음을 주장하면서 취소소송을 제기하였으나, 乙은 이에 대해 소송을 제기하기 않았다. 甲이 소송에서 승소한 경우에 다음 중 옳지 않은 것은?

(변호사 모의시험 문제)

---

74) 예컨대, 동일대상에 대한 공유수면매립면허, 또는 도로점용허가
75) 예컨대, 법규상 거리제한규정 또는 지역별 업소수제한규정이 있는 경우

① 乙의 불합격처분에 대해 불가쟁력이 발생하였다 해도 행정청은 행정행위를 직권으로 취소할 수 있다.
② 乙은 국가배상소송을 제기할 수 있다.
③ 甲은 국가배상소송을 제기할 수 있다.
④ 甲이 제기한 취소소송의 판결에 의해 乙에 대한 불합격처분도 취소된다.
⑤ 甲이 받은 취소판결은 관계행정청을 기속한다.

해설 & 정답

유형 준사례형

① 불합격처분의 다른 당사자인 乙이 다투지 아니하여 제소기간(행정소송법 제20조 제1항)이 도과되어서 불가쟁력이 발생하였다 하더라도 행정처분에 하자가 있는 경우에는 법령에 특별히 취소사유를 규정하고 있지 아니하여도 행정청은 그가 행한 위법한 행정처분을 취소할 수 있다(대판 1982.7.27, 81누271). 따라서 당해 乙에 대한 불합격 처분을 취소할 수 있다.
② 甲이 불합격처분 취소소송에서 승소판결을 받으면 취소판결의 효력은 제3자에 대하여도 효력이 있으므로(행정소송법 제29조 제1항) 동 불합격처분이 위법하다는 사실은 乙에게도 영향을 준다. 乙의 경우 처분의 위법성 외에 국가배상청구의 요건을 입증한다면 국가 배상 청구가 가능하다.
③ 甲이 불합격처분 취소소송에서 승소판결을 받음으로써 동 불합격처분이 위법하다는 사실에 기판력이 발생한다. 甲의 경우도 처분의 위법성 외에 국가배상청구의 요건을 입증함으로써 국가배상청구가 가능하다.
④ 취소판결의 제3자효란 "행정소송법 제29조 제1항의 명문의 규정에 따라 취소소송의 인용판결이 소송에 관여하지 않은 제3자에 대하여도 미치는 효력"을 말하는데 그 내용과 관련하여 대법원은 "환지계획변경처분 취소판결을 받아 이를 근거로 이루어진 소유권이전등기의 말소를 구한 소송에서 소유권이전등기는 위 취소판결 자체의 효력에 의하여 당연히 말소되는 것이 아니라 소외인이 위 취소판결의 존재를 법률요건으로 주장할 수 있을 뿐이다(대판 1986.8.19, 83다카2022)"고 하여 제3자효의 적극적으로 법률관계를 형성하는 효력을 인정하고 있지 않다. 甲이 제기한 취소소송의 대상은 甲에 대한 불합격처분이지, 乙에 대한 불합격처분이 아니므로 甲의 취소소송이 인용되더라도 형성력이 인정되지 않으므로 이와 더불어 乙에 대한 불합격처분이 취소되는 것은 아니다.
⑤ 처분 등을 취소하는 확정판결은 그 사건에 관하여 당사자인 행정청과 그 밖의 관계행정청을 기속한다(행정소송법 제30조 제1항).

정답 ④

2. 甲은 자신이 소유하는 임야를 개발하여 리조트를 개발하기 위해 사업허가를 받았다. 이때 환경영향평가 대상지역 안에 거주하는 X와, 환경영향평가 대상지역 밖에 거주하는 Y가 당해 사업허가가 위법함을 이유로 취소소송을 제기하였다. 다음 중 소송에서 사용할 원·피고들의 주장과 그 근거가 옳게 연결된 것은? (변호사 모의시험 문제)

① Y는 취소소송을 제기할 수 있다. 헌법상 환경권을 가지기 때문이다.
② 甲은 취소소송의 피고가 된다. 사업시행자로서의 지위에 있기 때문이다.
③ X는 취소소송을 제기할 법률상 이익이 없다. 환경영향평가법은 법률상 이익을 따지는 관계법률에 해당하지 않기 때문이다.
④ Y는 취소소송을 제기할 수 없다. 리조트에 대한 사업허가에 대해 신청권이 없기 때문이다.
⑤ X는 취소소송을 제기할 수 있다. 환경상 이익이 침해될 우려가 있기 때문이다.

해설 & 정답

유형 사례형

① [1] 행정처분의 직접 상대방이 아닌 제3자라 하더라도 당해 행정처분으로 인하여 법률상 보호되는 이익을 침해당한 경우에는 그 처분의 무효확인을 구하는 행정소송을 제기하여 그 당부의 판단을 받을 자격이 있다 할 것이며, 여기에서 말하는 법률상 보호되는 이익이라 함은 당해 처분의 근거 법규 및 관련 법규에 의하여 보호되는 개별적·직접적·구체적 이익이

있는 경우를 말하고, 공익보호의 결과로 국민 일반이 공통적으로 가지는 일반적·간접적·추상적 이익이 생기는 경우에는 법률상 보호되는 이익이 있다고 할 수 없다.

[2] 공유수면매립면허처분과 농지개량사업 시행인가처분의 근거 법규 또는 관련 법규가 되는 구 공유수면매립법(1997.4.10. 법률 제5337호로 개정되기 전의 것), 구 농촌근대화촉진법(1994.12.22. 법률 제4823호로 개정되기 전의 것), 구 환경보전법(1990.8.1. 법률 제4257호로 폐지), 구 환경보전법 시행령(1991.2.2. 대통령령 제13303호로 폐지), 구 환경정책기본법(1993.6.11. 법률 제4567호로 개정되기 전의 것), 구 환경정책기본법 시행령(1992.8.22. 대통령령 제13715호로 개정되기 전의 것)의 각 관련 규정의 취지는, 공유수면매립과 농지개량사업시행으로 인하여 직접적이고 중대한 환경피해를 입으리라고 예상되는 환경영향평가 대상지역 안의 주민들이 전과 비교하여 수인한도를 넘는 환경침해를 받지 아니하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있는 개별적 이익까지도 이를 보호하려는 데에 있다고 할 것이므로, 위 주민들이 공유수면매립면허처분 등과 관련하여 갖고 있는 위와 같은 환경상의 이익은 주민 개개인에 대하여 개별적으로 보호되는 직접적·구체적 이익으로서 그들에 대하여는 특단의 사정이 없는 한 환경상의 이익에 대한 침해 또는 침해우려가 있는 것으로 사실상 추정되어 공유수면매립면허처분 등의 무효확인을 구할 원고적격이 인정된다. 한편, 환경영향평가 대상지역 밖의 주민이라 할지라도 공유수면매립면허처분 등으로 인하여 그 처분 전과 비교하여 수인한도를 넘는 환경피해를 받거나 받을 우려가 있는 경우에는, 공유수면매립면허처분 등으로 인하여 환경상 이익에 대한 침해 또는 침해우려가 있다는 것을 입증함으로써 그 처분 등의 무효확인을 구할 원고적격을 인정받을 수 있다.

[3] 헌법 제35조 제1항에서 정하고 있는 환경권에 관한 규정만으로는 그 권리의 주체·대상·내용·행사방법 등이 구체적으로 정립되어 있다고 볼 수 없고, 환경정책기본법 제6조도 그 규정 내용 등에 비추어 국민에게 구체적인 권리를 부여한 것으로 볼 수 없다는 이유로, 환경영향평가 대상지역 밖에 거주하는 주민에게 헌법상의 환경권 또는 환경정책기본법에 근거하여 공유수면매립면허처분과 농지개량사업 시행인가처분의 무효확인을 구할 원고적격이 없다고 한 사례(대판 2006.3.16, 2006두330 全合).

② 사업허가라는 행정행위에 대하여 취소소송을 제기하는 것이어서 행정청을 피고로 하여야 한다. 보상금증액소송과는 다르다.

③ 환경영향평가법률은 관계법률에 포함되어 원고적격이 인정된다.

④ 대상지역 밖의 주민이라 할지라도 공유수면매립면허처분 등으로 인하여 그 처분 전과 비교하여 수인한도를 넘는 환경피해를 받거나 받을 우려가 있는 경우에는, 공유수면매립면허처분 등으로 인하여 환경상 이익에 대한 침해 또는 침해우려가 있다는 것을 입증함으로써 그 처분 등의 무효확인을 구할 원고적격을 인정받을 수 있다.

⑤ 환경영향평가 대상지역 안의 주민들이 전과 비교하여 수인한도를 넘는 환경침해를 받지 아니하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있는 개별적 이익까지도 이를 보호하려는 데에 있다고 할 것이므로, 위 주민들이 공유수면매립면허처분 등과 관련하여 갖고 있는 위와 같은 환경상의 이익은 주민 개개인에 대하여 개별적으로 보호되는 직접적·구체적 이익으로서 그들에 대하여는 특단의 사정이 없는 한 환경상의 이익에 대한 침해 또는 침해우려가 있는 것으로 사실상 추정되어 공유수면매립면허처분 등의 무효확인을 구할 원고적격이 인정된다.

정답 ⑤

3. 甲은 A시와 B시간의 시외버스 운송사업을 하면서 그럭저럭 수지를 맞추고 있었다. 그런데 관할행정청은 乙에게 동일한 구간에 대해서 새로운 운송사업 면허를 부여하였다. 이와 관련된 다음의 설명 중 옳지 않은 것은? (제40회 사법시험 2차문제 변형)

① 甲이 권리구제를 위해서 乙에 대한 운송사업 면허를 취소하기 위해서 취소소송을 제기할 경우 소의 적법 요건과 관련하여 원고 적격 인정여부가 문제된다.

② 甲이 만약의 처분의 직접 상대방이고 그 처분이 침익적 처분이라면 甲의 권리가 침해되므로 당연히 원고적격이 인정되지만 사안과 같이 기존업자가 신규업자에 대한 인·허가처분의 취소를 구하는 소송인 경업자 소송에서는 기존업자가 누리는 이익이 법적으로 독점적으로 보호되는 이익인가에 따라 원고적격 인정여부가 달라진다.

③ 행정소송법 제12조에서는 원고적격에 대해서 규정하고 있다.

④ 원고적격의 범위와 관련하여서 권리구제설, 법률상 이익 구제설, 보호가치이익구제설, 적법성 보장설 등의 견해대립이 있는데 후자로 갈수록 원고적격의 인정 범위가 넓어진다.

⑤ 우리 대법원은 보호가치 이익구제설을 취하고 있는데 사안의 경우 판례의 태도에 의할 경우 甲에게 원고 적격을 인정하고 있다.

해설 & 정답

유형 사례형

①②③④ 사안은 경업자 소송으로서 처분의 직접 상대방이 아닌 제3자의 원고적격 인정여부가 문제된다.

⑤ 대법원은 법률상 이익구제설을 취하고 있고, 법률상 이익의 범위를 계속 확대시키는 경향에 있다. 대법원은 당해 처분의 근거법률뿐만 아니라 관계법규범까지 법의 범위를 확장해 법률상 이익을 확장하는 한편, 당해 근거법규범을 해석함에 있어서도 단순한 문리적 해석을 벗어나 목적론적 해석을 통하여 법률상 보호이익의 범위를 넓게 보고 있고, 헌법재판소는 기본권에 직접 근거하여 법률상 이익을 인정하기도 한다.

사안과 관련하여 대법원은 "자동차운수사업법 제6조 제1호의 규정의 목적이 자동차운수사업에 관한 질서를 확립하고 자동차운수의 종합적인 발달을 도모하여 공공의 복리를 증진함과 동시에 업자간의 경쟁으로 인한 경영의 불합리를 미리 방지하자는데 있다 할 것이므로 기존 시내버스 업자로서는, 다른 운송사업자가 운행하고 있는 기존 시외버스를 시내버스로 전환을 허용하는 사업계획변경인가처분에 대하여 그 취소를 구할 법률상의 이익이 있다고 할 것이다(대판 1987.9.22, 85누985)"라고 판시하여 원고적격을 인정하고 있다.

정답 ⑤

♣ 학습내용 정리

1. 당사자능력은 원칙적으로 人 또는 대표자나 관리인이 있는 비법인사단, 재단에게만 인정되지만 판례는 국가기관의 당사자능력을 예외적으로 인정하였다.
2. 행정소송법 제12조 제1문의 법률상 이익에 대하여 학설이 대립하나 법률상 보호이익설이 다수설이다.

제35강 취소소송의 소송요건 III

♣ 학습목표

취소소송의 소송요건으로 협의의 소익 및 행정소송법 제12조 제2문의 법률상 이익에 대한 학설을 이해하고 판례에 대하여 해석할 수 있다.

♣ 학습내용

협의의 소익

행정소송법 제12조 제2문의 법률상 이익

♣ 사전테스트

1. 이익침해상황이 해소된 경우에는 협의의 소익이 원칙적으로 인정된다.
   정답 : X

2. 파면처분취소소송 도중 정년이 도래한 경우 협의의 소익이 없다.
   정답 : x

3. 반복될 위험성을 제거할 필요성도 협의의 소익으로 인정한 판례가 있다.
   정답 : O

♣ 돌발퀴즈

명예, 신분 등 인격적 이익의 침해만으로는 협의의 소익을 인정할 수 없으므로 검정고시에 합격한 경우 퇴학처분의 취소를 구할 이익이 없다.

[정답] ×

[해설] 고등학교졸업이 대학입학자격이나 학력인정으로서의 의미밖에 없다고 할 수 없으므로 고등학교졸업학력검정고시에 합격하였다 하여 고등학교 학생으로서의 신분과 명예가 회복될 수 없는 것이니 퇴학처분을 받은 자로서는 퇴학처분의 위법을 주장하여 그 취소를 구할 소송상의 이익이 있다(대판 1992.7.14, 91누4737).

♣ 강의내용

제1 협의의 소의이익(권리보호의 필요)

1. 개 설

행정소송에 있어서도 민사소송에 있어서와 마찬가지로 분쟁을 소송에 의해 해결할 현실적 필요성 또는 권리보호의 필요가 있을 때에 한하여 소제기가 허용된다. 이러한 본안판결을 구할 필요를 협의의 소의 이익이라고 한다.

2. 협의의 소익이 인정되지 않는 경우

⑴ 문제점

취소소송의 협의의 소익에 관하여 행정소송법은 제12조 제2문과 같은 예외적인 규정만을 두고 있을 뿐 이에 관한 일반적인 규정을 두고 있지 않아 소의 이익이 있는지 여부는 구체적인 사안별로 현실적으로 권리보호의 실익이 있느냐를 기준으로 판단하여야 한다.

⑵ 처분의 효력이 소멸된 경우 - 원칙적으로 협의의 소익흠결

처분에 대한 취소소송 도중 취소심판에서 취소재결(형성재결)이 내려진 경우 당해 처분은 소급무효가 되므로 협의의 소익이 없다는 판례(대판 1997. 5. 30. 96누18632)

감액경정처분이 있는 경우 소의 대상은 감액되고 남은 원처분이므로 감액경정처분에 대한 취소소송은 협의의 소익이 없다는 판례(대판 2006. 5. 12. 2004두12698)

⑶ 원상회복이 불가능한 경우 - 협의의 소익흠결

건물이 완공된 경우에는 인접대지소유자가 건축허가 및 준공처분에 대하여 취소를 구할 협의의 소익이 없다는 판례(대판 1994. 1. 14, 93누20481).

⑷ 처분 후의 사정에 의하여 이익침해가 해소된 경우 - 협의의 소익흠결

치과전문의자격 불합격처분취소소송 도중 합격한 경우 협의의 소익이 없다는 판례(대판 1993. 11. 9. 93누6867)

공익근무요원 소집해제신청 거부처분취소소송 도중 소집해제처분이 발령된 경우 협의의 소익이 없다는 판례(대판 2005. 5. 13. 2004두4369)

⑸ 보다 용이한 방법으로 권리보호목적을 달성할 수 있을 때 - 협의의 소익 흠결

원고가 보다 용이한 방법으로 권리보호의 목적을 달성할 수 있다고 판단되는 경우에도 권리보호의 필요가 부정된다. 예컨대 인가처분에 있어 인가처분에 하자가 없다면 인가의 기본행위에 하자가 있더라도 기본행위의 무효를 내세워 그에 대한 인가처분의 취소 또는 무효확인을 구할 법률상 이익이 없다는 것이 판례의 입장이다(대판 2000. 9. 5, 99두1854, 95누48110).

3. 행정소송법 제12조 제2문의 '법률상 이익'

⑴ 법조문

행정소송법 제12조 제2문은 "처분의 효과가 기간 등의 경과, 처분 등의 집행 그 밖의 사유로 인하여 소멸한 뒤에도 그 처분의 취소로 인하여 회복되는 법률상 이익이 있는 경우에도 이와 같다"고 규정하였다.

⑵ 원고적격규정인 협의의 소익 규정인지

일부 견해는 행정소송법 제12조 제2문은 처분이 소멸된 경우에도 법률상 이익이 침해된 자는 원고적격을 갖는다고 해석하여 원고적격에 관한 조항으로 본다.

그러나 다수설은 행정소송법 제12조 제2문은 원고적격이 있는 자가 소멸된 처분에 대하여 취소판결받을 법률상 이익이 있으면 협의의 소익이 인정된다고 해석하여 협의의 소익에 관한 조항으로 본다.

생각건대, 원고적격은 원고가 당해 처분으로 침해받은 이익이 법률상 이익인가의 문제이고, 협의의 소익은 그러한 법률상 이익이 있는 원고가 당해 처분에 대한 취소판결로 회복되는 이익이 있는가의 문제인 바, 행정소송법 제12조 제2문은 협의의 소익으로 보는 다수설이 타당하다.

⑶ 행정소송법 제12조 제2문에 의한 취소소송의 성질

1) 확인소송설

이미 소멸된 처분에 대한 취소판결로 법률관계에 변동이 발생하지 않으므로 소별된 처분 취소판결은 처분당시 위법성을 확인하는 판결이라고 주장하다. 따라서 이 견해는 행정소송법 제12조 제2문의 취소소송을 독일 행정소송법의 계속확인소송과 동일하다고 본다.

2) 형성소송설

행정소송법 제12조 제2문은 취소소송으로 규정되어 있는 것에 비하여 독일 행정소송법은 계속확인소송으로 규정하여 위법성의 확인만 구하는 것인 바 양자는 구별된다고 한다.

⑷ 행정소송법 제12조 제2문의 '법률상 이익'의 범위

1) 학설

① 행정소송법 제12조 제1문과 동일하게 파악하여 명예, 신용 등은 포함시키지 않는 견해, ② 행정소송법 제12조 제1문보다 넓게 보아 기본적인 권리 회복이 불가능하더라도 부수적으로 회복되는 이익으로서 명예·신용 등의 인격적 이익, 반복될 위험성 제거, 장래의 취직에 있어 불이익 제거, 장래 불이익처분을 받을 위험성제거 등도 포함된다는 견해, ③ '처분의 위법확인에 대한 정당한 이익'으로 보아 사회적, 경제적, 정치적, 종교적, 문화적 이익도 포함하는 견해 등이 대립한다.

2) 판례

판례는 원칙적으로 행정소송법 제12조 제1문의 법률상 이익과 동일하게 파악하여 행정소송법 제12조 제2문의 법률상 이익을 '처분의 근거법률에 의하여 보호되고 있는 직접적이고 구체적인 개인적 이익'이라고 판시하고 있다. 그러나 장래 불이익처분을 받을 위험성제거 및 반복될 위험성제거를 행정소송법 제12조 제2문의 '법률상 이익'에 포함시킨 판례도 있으며, 명예 등의 인격적 이익도 고려하여 '법률상 이익'여부를 판단한 판례도 있다.

⑸ 구체적인 경우

1) 취소소송의 경우

① 원상회복은 불가능하나 부수적인 이익이 구제되는 경우

예컨대, 공무원에 대한 파면처분 등 징계처분 이후 정년이 도래한 경우 그 처분의 취소로서 다시 공무원은 될 수 없으나 징계처분 이후의 급료나 퇴직금 청구를 구할 필요가 있거나 다른

공직에의 취임제한 등의 법률상 불이익배제를 위하여 필요한 때에는 그 취소를 구할 협의의 소익이 있다(대판 1983. 2. 8, 81누121).

지방의회의원임기가 종료되었더라도 제명의결처분취소판결에 의해 월정수당청구권이 회복되는 바 취소소송을 구할 실익이 있다는 판례(대판 2009. 1. 30, 2007두13487).

공장건물이 철거되어 원상회복이 불가능하더라도 부수적으로 회복되는 소득세 감면혜택 등이 있는 바 그 공장등록취소처분의 취소를 구할 법률상의 이익이 있다고 한 판례(대판 2002. 1. 11, 2000두3306).

공무원에 대한 감봉처분취소소송 도중 공무원이 자진사퇴한 경우라도 감봉처분에 의해 감봉된 보수지급을 받을 이익이 있으므로 협의의 소익이 있다는 판례(대판 1977. 7. 12. 74누147)

② 소멸된 제재처분이 장래 가중처분의 요건사실이 되는 경우

(가) 법률에 가중처분 규정이 있는 경우

판례는 소멸된 제재처분이 법령의 규정에 의하여 장래 가중처분의 요건사실이 되는 경우에는, 당해 처분이 기간을 경과하여 처분의 효력이 상실되었더라도 그 취소를 구할 소의 이익이 있다고 보고 있다(대판 1991. 8. 27, 91누3512).

(나) 법규명령형식의 행정규칙에 가중처분 규정이 있는 경우

㉮ 가중요건이 대통령령인 시행령으로 되어 있는 경우

대통령령형식의 행정규칙에 대하여 법규명령을 인정하는 학설 및 판례에 따르면 동법 제12조 제2문의 '법률상 이익'의 범위에 관한 어느 학설에 의하더라도 '법률상 이익'인정된다. 단 행정규칙으로 보는 견해에 따르면 아래와 같이 견해가 대립한다.

㉯ 가중요건이 부령인 시행규칙으로 되어 있는 경우

ⅰ. 법규성을 부정하는 견해를 따를 경우

과거 판례는 가중요건이 부령형식의 행정규칙에 있는 경우 이 규정의 법적 성질을 행정규칙으로 보고 행정규칙에 소멸된 제재처분에 의해 장래 가중처분을 받도록 규정하고 있는 경우에는 그 처분의 효력이 소멸한 경우에 취소를 구하는 것은 협의의 소익이 없다고 판시하였다(대판 1995. 10. 17, 94누14148).

그러나 최근 대법원은 전원합의체판결로, 가중요건이 부령형식의 행정규칙에 있는 경우 "규칙이 정한 바에 따라 선행처분을 받은 상대방이 그 처분의 존재로 인하여 장래에 받을 불이익, 즉 후행처분의 위험은 구체적이고 현실적인 것이므로 상대방에게는 선행처분의 취소소송을 통하여 그 불이익을 제거할 필요가 있다"라고 판시하여 종전 판례를 파기하고 협의의 소익을 인정하였다(대판[전합] 2006. 6. 22, 2003두1684). 다만 위 판결에서 별개의견은 부령형식의 행정규칙을 법규명령으로 보아 협의의 소익을 인정하여야 한다고 주장한다.

ⅱ. 법규성을 긍정하는 견해에 따를 경우

소멸된 제재처분이 근거법규에 장래 가중처분의 요건사실로 규정된 것인 바 행정소송법 제12조 제2문의 "법률상 이익"의 범위에 관한 어느 견해에 의하더라도 협의의 소익 인정된다.

③ 이익침해상황이 해소된 경우

고등학생퇴학처분취소소송 도중 이미 대학에 입학한 경우에도 협의의 소익이 있다는 판례(대판 1992. 7. 14, 91누4737)

대학입학고사 불합격처분의 취소를 구하는 소송계속중 당해연도의 입학시기가 지나고 입학정원에 못들어가게 되었더라도 다음 연도에 입학할 수 있으므로 협의의 소익이 있다는 판례

④ 보다 용이한 방법으로 권리보호의 목적을 달성할 수 있는 경우

양도인과 양수인 간의 영업양도계약이 부존재하거나 무효가 된 경우 이를 전제로 한 영업자 지위승계신고수리처분에 대하여 양도인이 무효확인소송을 제기할 협의의 소익이 있다는 판례(대판 1990. 10. 30, 90누1649, 대판 1993. 6. 8, 91누11544 등)

자동차운수사업의 양도양수계약이 취소된 경우 양도양수인가처분무효확인소송을 제기할 협의의 소익이 있다는 판례(대판 1979. 2. 13. 78누428).

⑤ 명예 신용 등의 인격적 이익이 구제되는 경우

판례는 "자격정지의 취소를 구하는 소송에서 자격정지기간이 경과되었다면 이미 그 처분의 취소를 구할 이익이 없다고 보아야 할 것이고, 설사 동 처분으로 인하여 명예 신용 등 인격적 이익이 침해되어 그 침해상태가 자격정지기간 경과후에도 잔존하는 불이익이 있다고 하더라도 위와 같은 불이익은 동 처분의 직접적인 효과였다고 할 수 없다"(대판 1978. 5. 23, 78누72)라고 판시하여 이와 같은 경우 협의의 소익을 부정하였다.

⑥ 재결취소소송에서의 소의 이익

원처분취소소송과 재결취소소송이 함께 제기된 경우에 원처분이 위법하다 하여 취소된 때에는 재결취소소송을 유지할 소의 이익이 없다.

그러나 원처분취소소송에서 기각판결이 내려지거나 원처분취소소송에서 아직 판결이 내려지지 않은 경우에는 재결취소소송의 소의 이익이 소멸하는 것은 아니다. 왜냐하면 재결이 취소되면 행정심판위원회에 의해 원처분의 부당성에 대한 심판을 다시 받을 이익이 있기 때문이다.

⑦ 기타 협의의 소익

공공기관이 공개를 구하는 정보를 보유·관리하고 있지 않는 경우, 정보공개거부처분의 취소를 구할 법률상 이익(협의의 소익)이 없다는 판례(대법원 2014.06.12. 선고 2013두4309 판결)

국가공무원법상 직위해제처분의 무효확인 또는 취소소송 계속 중 정년을 초과하여 직위해제처분의 무효확인 또는 취소로 공무원 신분을 회복할 수는 없다고 할지라도, 그 무효확인 또는 취소로 직위해제일부터 직권면직일까지 기간에 대한 감액된 봉급 등의 지급을 구할 수 있는 경우에는 직위해제처분의 무효확인 또는 취소를 구할 법률상 이익이 있다(대법원 2014.05.16. 선고 2012두26180 판결)

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 판례에 의할 때 소의 이익이 인정되는 것은? 2008년 관세사

① 의사국가시험 불합격처분에 대한 취소소송 중에 새로 실시된 의사국가시험에 합격한 경우
② 고등학교퇴학처분에 대한 취소소송 중에 새로 실시된 검정고시시험에 합격한 경우
③ 준공검사처분에 대한 취소소송에서 「건축법」 소정의 이격거리를 두지 아니한 것을 이유로 일조권 침해를 주장하는 경우
④ 원자로 및 관계시설의 부지사전승인처분에 대한 취소소송 중에 건설허가가 난 경우
⑤ 건물의 철거명령에 대한 취소소송 중에 당해 건물이 대집행의 실행에 의해 이미 철거되어 버린 경우

① [×] [협의의 소익 부정] 치과의사국가시험 합격은 치과의사 면허를 부여받을 수 있는 전제요건이 된다고 할 것이나 국가시험에 합격하였다고 하여 위 면허취득의 요건을 갖추게 되는 이외에 그 자체만으로 합격한 자의 법률상 지위가 달라지게 되는 것은 아니므로 불합격처분 이후 새로 실시된 국가시험에 합격한 자들로서는 더 이상 위 불합격처분의 취소를 구할 법률상의 이익이 없다(대판 1993.11.9, 93누6867).

② [○] [협의의 소익 인정] 고등학교졸업이 대학입학자격이나 학력인정으로서의 의미밖에 없다고 할 수 없으므로 고등학교졸업학력검정고시에 합격하였다 하여 고등학교 학생으로서의 신분과 명예가 회복될 수 없는 것이니 퇴학처분을 받은 자로서는 퇴학처분의 위법을 주장하여 그 취소를 구할 소송상의 이익이 있다(대판 1992.7.14, 91누4737).

③ [×] [협의의 소익 부정] 처분의 무효 등 확인소송이나 취소소송은 처분의 무효 등 확인이나 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자만이 제기할 수 있다고 할 것이어서 신축한 건물이 무단증평, 이격거리위반, 베란다돌출, 무단구조변경 등 건축법에 위반하여 시공됨으로써 인접주택 소유자의 사생활과 일조권을 침해하고 있다고 하더라도, 인접건물 소유자들로서는 위 건물준공처분의 무효확인이나 취소를 구할 법률상 이익이 없다(대판 1993.11.9, 93누13988).

④ [×] [협의의 소익 부정] 원자로 및 관계시설의 부지사전승인처분은 그 자체로서 건설부지를 확정하고 사전공사를 허용하는 법률효과를 지닌 독립한 행정처분이기는 하지만, 건설허가 전에 신청자의 편의를 위하여 미리 그 건설허가의 일부 요건을 심사하여 행하는 사전적 부분건설허가처분의 성격을 갖고 있는 것이어서 나중에 건설허가처분이 있게 되면 그 건설허가처분에 흡수되어 독립된 존재가치를 상실함으로써 그 건설허가처분만이 쟁송의 대상이 되는 것이므로, 부지사전승인처분의 취소를 구하는 소는 소의 이익을 잃게 되고, 따라서 부지사전승인처분의 위법성은 나중에 내려진 건설허가처분의 취소를 구하는 소송에서 이를 다투면 된다(대판 1998.9.4, 97누19588).

⑤ [×] [협의의 소익 부정] 건물철거대집행계고처분 취소소송의 변론종결 전에 대집행영장에 의한 통지절차를 거쳐 사실행위로서 대집행의 실행이 완료된 경우에는 행위가 위법한 것이라는 이유로 손해배상이나 원상회복 등을 청구하는 것은 별론으로 하고 처분의 취소를 구할 법률상 이익은 없다(대판 1993.6.8, 93누6164).

답 : 2

2. 다음 판례 중 협의의 소의 이익(권리보호의 필요)이 인정되지 않는 것은?

2008년 지방직 7급

① 행정청이 영업허가신청 반려처분의 취소를 구하는 소의 계속 중 사정변경을 이유로 위 반려처분을 직권취소함과 동시에 위 신청을 재반려하는 내용의 재처분을 한 경우 당초의 반려처분의 취소를 구하는 경우

② 행정처분의 효력기간이 경과하였다고 하더라도 그 처분을 받은 전력이 장래에 불이익하게 취급되는 것으로 법정(법률)상의 가중요건으로 되어 있고, 이후 그 법정가중 요건에 따라 새로운 제재적인 행정처분이 가해지고 있는 경우

③ 현역입영대상자로서 현실적으로 입영을 한 자가 입영 이후의 법률관계에 영향을 미치고 있는 현역병입영통지처분 등을 한 관할 지방병무청장을 상대로 위법을 주장하여 그 취소를 구하는 경우

④ 도시개발사업의 공사 등이 완료되고 원상회복이 사회통념상 불가능하게 된 경우 도시개발사업의 시행에 따른 도시계획변경결정처분과 도시개발구역지정처분 및 도시개발사업실시계획인가처분의 취소를 구하는 경우

① [×] [협의의 소익 부정] 행정처분이 취소되면 그 처분은 취소로 인하여 그 효력이 상실되어 더 이상 존재하지 않는 것이고, 존재하지 않는 행정처분을 대상으로 한 취소소송은 소의 이익이 없어 부적법하다. 따라서 행정청이 당초의 분뇨 등 관련 영업허가신청 반려처분의 취소를 구하는 소의 계속 중, 사정변경을 이유로 위 반려처분을 직권취소함과 동시에 위 신청을 재반려하는 내용의 재처분을 한 경우, 당초의 반려처분의 취소를 구하는 소는 더 이상 소의 이익이 없게 되었다(대판 2006.9.28, 2004두5317).

② [○] [협의의 소익 인정] 행정처분의 전력이 장래에 불이익하게 취급되는 것으로 법에 규정되어 있어 법정의 가중요건으로 되어 있고, 이후 그 법정가중요건에 따라 새로운 제재적인 행정처분이 가해지고 있다면, 선행 행정처분의 효력기간이 경과하였다 하더라도 선행 행정처분의 잔존으로 인하여 법률상의 이익이 침해되고 있다고 볼 만한 특별한 사정이 있는 경우에 해당한다(대판 2005.3.25, 2004두14106).

③ [○] [협의의 소익 인정] 현역입영대상자로서는 현실적으로 입영을 하였다고 하더라도, 입영 이후의 법률관계에 영향을 미치고 있는 현역병입영통지처분 등을 한 관할 지방병무청장을 상대로 위법을 주장하여 그 취소를 구할 소송상의 이익이 있다(대판 2003.12.26, 2003두1875).

④ [○] [협의의 소익 인정] 도시개발사업의 시행에 따른 도시계획변경결정처분과 도시개발구역지정처분 및 도시개발사업실시계획인가처분은 도시개발사업의 시행자에게 단순히 도시개발에 관련된 공사의 시공권한을 부여하는 데 그치지 않고 당해 도시개발사업을 시행할 수 있는 권한을 설정하여 주는 처분으로서 위 각 처분 자체로 그 처분의 목적이 종료되는 것이 아니고 위 각 처분이 유효하게 존재하는 것을 전제로 하여 당해 도시개발사업에 따른 일련의 절차 및 처분이 행해지기 때문에 위 각 처분이 취소된다면 그것이 유효하게 존재하는 것을 전제로 하여 이루어진 토지수용이나 환지 등에 따른 각종의 처분이나 공공시설의 귀속 등에 관한 법적 효력은 영향을 받게 되므로, 도시개발사업의 공사 등이 완료되고 원상회복이 사회통념상 불가능하게 되었더라도 위 각 처분의 취소를 구할 법률상 이익은 소멸한다고 할 수 없다(대판 2005.9.9, 2003두5402·5419).

답 : 1

3. 취소소송에 있어서 협의의 소익에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함) 2010년 지방직 9급

① 처분 등의 효과가 소멸된 뒤에도 그 처분 등의 취소로 인하여 회복되는 법률상의 이익이 있는 자는 소를 제기할 수 있다.

② 대집행이 완료된 경우 대집행계고처분의 취소를 구하는 소는 소의 이익이 없다.

③ 제재적 행정처분의 효력이 소멸한 경우에도 행정규칙에 의해 당해 처분의 존재가 가중처분의 전제가 되는 경우 처분의 취소를 구할 이익이 있다.

④ 명예, 신분 등 인격적 이익의 침해만으로는 협의의 소익을 인정할 수 없으므로 검정고시에 합격한 경우 퇴학처분의 취소를 구할 이익이 없다.

① [○] [협의의 소익 인정] 취소소송은 처분 등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다. 처분 등의 효과가 기간의 경과, 처분 등의 집행 그 밖의 사유로 인하여 소멸된 뒤에도 그 처분 등의 취소로 인하여 회복되는 법률상 이익이 있는 자의 경우에는 또한 같다(행정소송법 제12조).

② [○] [대집행 실행이 완료된 경우 - 협의의 소익 부정] 대집행계고처분 취소소송의 변론종결 전에 대집행영장에 의한 통지절차를 거쳐 사실행위로서 대집행의 실행이 완료된 경우에

는 행위가 위법한 것이라는 이유로 손해배상이나 원상회복 등을 청구하는 것은 별론으로 하고 처분의 취소를 구할 법률상 이익은 없다(대판 1993.6.8, 93누6164).

③ [○] [가중처분의 전제가 되는 경우 - 협의의 소익 인정] 제재적 행정처분이 그 처분에서 정한 제재기간의 경과로 인하여 그 효과가 소멸되었으나, 부령인 시행규칙 또는 지방자치단체의 규칙(이하 '규칙'이라 함)의 형식으로 정한 처분기준에서 제재적 행정처분(이하 '선행처분'이라 함)을 받은 것을 가중사유나 전제요건으로 삼아 장래의 제재적 행정처분(이하 '후행처분'이라 함)을 하도록 정하고 있는 경우, 규칙이 정한 바에 따라 선행처분을 가중사유 또는 전제요건으로 하는 후행처분을 받을 우려가 현실적으로 존재하는 경우에는, 선행처분을 받은 상대방은 비록 그 처분에서 정한 제재기간이 경과하였다 하더라도 그 처분의 취소소송을 통하여 그러한 불이익을 제거할 권리보호의 필요성이 충분히 인정된다고 할 것이므로, 선행처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있다고 보아야 한다(대판 전합 2006.6.22, 2003두1684).

④ [×] [검정고시 합격 후 퇴학처분 취소 - 협의의 소익 인정] 고등학교졸업이 대학입학자격이나 학력인정으로서의 의미밖에 없다고 할 수 없으므로 고등학교졸업학력검정고시에 합격하였다 하여 고등학교 학생으로서의 신분과 명예가 회복될 수 없는 것이니 퇴학처분을 받은 자로서는 퇴학처분의 위법을 주장하여 그 취소를 구할 소송상의 이익이 있다(대판 1992.7.14, 91누4737).

답 : 4

♣ 학습내용 정리

1. 협의의 소익은 원고가 인용판결을 받을 실익으로서 취소소송에서 원칙적으로 협의의 소익이 없는 경우는. 처분의 효력소멸, 원상회복불가, 이익침해상황 해소 등이 있다.
2. 행정소송법 제12조 제2문의 법률상 이익에 대하여 학설이 대립이 있다.

제36강 취소소송의 소송요건 Ⅳ

♣ 학습목표

취소소송의 소송요건으로 피고적격, 예외적 행정심판전치주의, 제소기간 등에 대하여 이해하고 본안심리와 관련하여 소의 변경에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

피고적격
예외적 행정심판전치주의
제소기간
소의 변경

♣ 사전테스트

1. 한국방송공사는 취소소송의 피고가 될 수 없다.
   정답 : X

2. 행정심판을 부적법하게 청구한 경우에도 취소소송의 제소기간은 재결서 정본 송달받은 날로부터 90일이다.
   정답 : x

3. 행정소송법은 행정소송 상호간의 소의 변경과 처분의 변경으로 인한 소의 변경에 대하여 규정하고 있다.
   정답 : O

♣ 돌발퀴즈

처분적 조례에 대한 항고소송의 경우 지방자치단체장이 피고가 된다.

[정답] ○

[해설] 조례가 집행행위의 개입 없이도 그 자체로서 직접 국민의 구체적인 권리의무나 법적 이익에 영향을 미치는 등의 법률상 효과를 발생하는 경우 그 조례는 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하고, 이러한 조례에 대한 무효확인소송을 제기함에 있어서 행정소송법 제38조 제1항·제13조에 의하여 피고적격이 있는 처분 등을 행한 행정청은, 행정주체인 지방자치단체 또는 지방자치단체의 내부적 의결기관으로서 지방자치단체의 의사를 외부에 표시한 권한이 없는 지방의회가 아니라, 지방자치법 제26조에 의하여 지방자치단체의 집행기관으로서 조례로서의 효력을 발생시키는 공포권이 있는 지방자치단체의 장이다(대판 1996.9.20, 95누8003).

♣ 강의내용

제1 피고적격

⑴ 문제점

처분행정청의 의미, 권한의 승계와 폐지의 경우, 처분적 조례의 경우 피고적격자 등이 문제된다.

⑵ 처분행정청 - 외부명의자

행정소송법 제2조 제2항 : “이 법을 적용함에 있어서 행정청에는 법령에 의하여 행정권한의 위임 또는 위탁을 받은 행정기관, 공공단체 및 그 기관 또는 사인이 포함된다”

⑶ 구체적인 예

① 그의 명의로 행정처분 행한 행정청이 피고가 된다.

② 권한의 위임 위탁의 경우 - 수임청

③ 권한의 내부위임 또는 전결의 경우

권한이 이전되지 않으므로 위임행정청 명의로 처분을 해야 하고 따라서 위임행정청이 피고가 된다. 단, 위임행정청의 명의로 하지 않지 않고 수임행정청이 자신명의로 처분한 경우에는 외부명의자인 수임행정청이 피고가 된다(대판 1995. 12. 22, 95누14688).

⑷ 특별규정이 있는 경우

법률상의 특별규정에 의하여 처분청 이외의 자가 피고로 되는 경우가 있다. 대통령이 공무원에 대하여 징계 기타 불이익처분을 한 경우는 소속장관이 피고가 된다(국가공무원법 제16조 제2항).

⑸ 권한승계 및 권한폐지의 경우

처분이 있은 뒤에 권한이 다른 행정기관에 승계된 때에는 이를 승계한 행정청이 피고가 되며, 처분을 한 행정청이 없어진 때에는 그 처분에 관한 사무가 귀속되는 국가 또는 공공단체가 피고가 된다(행정소송법 제13조 제2항). 이러한 경우에는 법원은 당사자의 신청 또는 직권으로 피고를 경정한다(동법 제14조 제6항).

⑹ 피고의 경정

피고의 경정이란 소송의 계속 중에 피고로 지정된 자를 다른 자로 변경하는 것을 말하며, 이는 항고소송 및 당사자소송에서 인정된다. 피고의 지정이 잘못되어 원고의 불측의 손해를 막기 위한 것이다. 피고경정결정이 있는 때에는 새로운 피고에 대한 소송은 처음에 소를 제기한 때에 제기한 것으로 보며(동법 제14조 제4항) 종전의 피고에 대한 소송은 취하된 것으로 본다(동법 제14조 제5항).

⑺ 지방의회의 의결이나 처분적 조례에 있어서의 피고적격

1) 처분적 조례에 대한 피고적격 - 지자체장 또는 지자체교육감

2) 지방의회의 내부의결에 관한 피고적격

지방의회의원 대한 징계의결이나 지방의회의장 대한 불신임의결은 행정처분이며, 이러한 의결은 지방의회가 외부명의자이므로 지방의회가 피고적격자이다.

제2 제소기간

1. 취지

행정소송법 제20조. 행정법관계의 조속한 안정.

2. 제소기간의 제한 있는 소송

⑴ 무효등확인소송 - 제소기간 제한없음

⑵ 부작위위법확인소송

⑶ 당사자소송 및 객관적 소송 - 개별법에 특별규정

3. 행정심판 청구하지 않은 경우 제소기간

⑴ 제소기간

처분이 있음을 안 날로부터 90일, 있은 날로부터 1년.

⑵ 처분상대방이 아닌 제3자의 경우

일반적으로 처분 있음을 바로 알 수 없으므로 안 날로부터의 제한은 받지 않으나, 알았을 때는 90일 내에 제소해야 한다.

⑶ 불변기간

90일의 기간은 불변기간이나, 1년의 기간은 불변기간이 아니어서 정당한 사유 있으면 그 후라도 제소할 수 있다.

4. 행정심판을 청구한 경우

⑴ 제소기간

심판재결서정본 송달받은 날로부터 90일, 재결있은 날로부터 1년.

⑵ 행정심판을 청구한 경우의 의미

필요적 전치의 경우뿐 아니라, 임의적 전치에 대해 행정심판 청구한 경우를 포함한다.

⑶ 적법한 행정심판청구일 것

이 제소기간 적용되려면 행정심판청구가 적법해야 한다.

5. 고시 ·공고에 의하여 이루어지는 일반처분에 대한 제소기간 기산일

⑴ 고시·공고에 의해 효력발생하는 일반처분에 대한 제소기간

1) 원칙 - 무조건 안 것으로 의제하여 90일만 적용

고시 또는 공고에 의하여 효력발생하는 행정처분에는 현실적으로 알았는지와 상관없이 안 것으로 의제하여 90일의 제소기간만 적용된다는 판례(대판 2001. 7. 27, 99두9490).

2) 예외 - 개별공시지가결정

개별공시지가결정은 공고에 의해 효력을 발생하나, 개별 토지에 대하여 행해지므로 현실적으로 알았는지에 따라 제소기간도과여부를 결정하여야 한다는 판례(대판 1993. 12. 24, 92누17204).

⑵ 상대방있는 처분이 상대방의 주소불명으로 공고된 경우 제소기간

특정인에 대한 행정처분을 주소불명 등의 이유로 송달할 수 없어 관보 등에 공고한 경우에는 상대방이 그 처분이 있음을 현실적으로 알아야 90일의 제소기간이 적용된다는 판례(대판 2006. 4. 28. 2005두14851).

제3 예외적 행정심판전치주의

1. 서 설

⑴ 임의적 행정심판전치주의

행정소송법 제18조 제1항 개정하여 개별법이 행정심판 전치 요하는 경우에만 거쳐야 하는 것으로 규정한다.

독점규제및공정거래에관한법률은 필요적 전치주의를 규정한 것이 아니라는 판례(대판 1999. 12. 20, 99무42).

⑵ 장단점

자율적 행정통제, 사법기능 보완, 법원 부담경감. 국민의 신속한 재판을 받을 권리 제한.

2. 필요적 전치를 요하는 처분

⑴ 조세소송

국세기본법 제56조는 제2항은 국세청장에 심사청구 또는 조세심판원에 대한 심판청구 및 감사원에 대한 심사청구 중 어느 하나를 거칠 것을 요구한다.

⑵ 공무원에 대한 불이익처분이나 부작위

공무원은 소청심사위원회에 먼저 심사를 청구해야 한다(국가공무원법 제16조, 제76조, 지방공무원법 제67조 제2항).

⑶ 도로교통법상의 처분(도로교통법 제142조).

행정심판법상 행정심판 취소심판 등을 제기, 적법하게 취소소송을 제기할수 있다.

3. 적용범위

⑴ 필요적 전치 적용되는 소송

취소소송, 부작위위법확인소송에만 적용되고, 무효등확인소송에는 적용되지 않는다.

⑵ 무효선언을 구하는 취소소송의 경우
판례는 무효선언을 구하는 취소소송의 경우에도 필요적 전치가 적용된다고 본다.

⑶ 2단계 이상의 행정심판절차가 규정된 경우
행정청에 자율적 심사기회 부여하고 간편 신속한 권리구제 위한 것이므로, 하나만 거치면 충족하는 것으로 볼 것이다.

⑷ 수인이 공동으로 소송제기 하는 경우
그 중 1인이 거치면 족하다.

⑸ 복효적 행정행위
통설·판례는 복효적 행정행위의 제3자의 경우에도 전치요건 충족해야 하고, 행정처분 있음 알기 어렵다는 점은 행정소송법 제18조 제3항 단서의 정당한 사유로 보면 족하다고 한다.

4. 내 용

⑴ 소송요건

⑵ 심판청구의 적법성과 전치요건의 충족여부

1) 심판청구가 부적법 각하된 경우
충족하지 못한 것이다.

2) 부적법한 심판청구를 각하하지 않고 본안재결한 경우
부적법성이 치유되는 것 아니므로, 충족하지 못한 것이다.

3) 적법한 심판청구가 각하된 경우
직권조사사항으로, 적법하다고 판단되면 충족된 것이다.

제4 소의 변경

Ⅰ. 의 의
행정소송법은 소의 변경에 관하여 특별한 규정을 두고 있다. 즉, 행정소송법은 행정소송 상호간 소의 종류의 변경에 관한 규정(동법 제21조)과 처분변경에 따른 소의 변경에 관한 규정(동법 제22조)을 두고 있다. 그런데, 행정소송법상 명문으로 인정된 소의 종류의 변경과 처분변경으로 인한 소의 변경이외에도 소의 변경을 인정할 필요가 있는 경우가 있다. 이 경우에는 행정소송법 제8조 제2항에 의해 민사소송법상의 소의 변경에 관한 규정이 행정소송에서도 준용될 수 있다.

Ⅱ. 행정소송법에 의한 소의 변경

1. 소의 종류의 변경
행정소송에는 여러 종류가 있는데 권리구제를 위하여 어떠한 소송의 종류를 선택하여야 하는지 명확하지 않은 경우가 적지 않아 소송의 종류의 선택을 잘못할 위험이 있다. 따라서, 행정구

제의 실효성을 높이기 위하여 행정소송간의 소의 변경을 인정할 필요가 있다. 그리하여 행정소송법은 행정소송간의 소의 변경을 인정하고 있다(동법 제21조, 동법 제37조, 동법 제42조).

2. 처분의 변경으로 인한 소의 변경

처분의 변경으로 인한 소의 변경이라 함은 행정청이 소송의 대상인 처분을 소가 제기된 후 변경한 때에는 원고의 신청에 의하여 법원이 허가를 받아 소를 변경하는 것을 말한다(동법 제22조).

3. 관련문제 - 부작위위법확인소송 도중 거부처분이 내려진 경우

4. 민사소송법에 의한 소의 변경

⑴ 문제점

행정소송법의 소의 변경에 관한 규정은 민사소송법의 소의 변경에 관한 규정에 대한 특칙이라 할 것이고 행정소송법상의 소의 변경에 관한 규정이 민사소송법상의 소의 변경을 배척하는 것이라고 할 수 없으므로 행정소송에 관하여 민사소송법에 의한 소의 변경이 가능하다고 보아야 한다. 따라서 소송절차를 현저하게 지연시키지 않는 한 청구의 기초에 변경이 없는 한도 내에서 청구의 취지 또는 원인을 변경할 수 있다(행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제235조).

⑵ 행정소송과 민사소송 사이의 소의 변경

1) 학설

① 민사소송법상 소변경 요건인 동종절차, 공통관할을 갖추지 못하였고 민사소송법상 소변경은 피고의 변경을 부정하는데 취소소송에서 부당이득반환청구소송으로의 소변경은 피고의 변경을 초래하므로 소변경이 불가하다는 부정설과 ② 행정소송도 민사소송과 마찬가지로 3심제이고, 피고가 처분청에서 국가 등 행정주체로 변경되더라도 양자는 실질에 있어 동일하고, 국민의 권익구제 등을 이유로 소변경이 가능하다는 긍정설이 대립한다.

2) 판례

판례는 항고소송으로 제기하여야 할 사건을 민사소송으로 잘못 제기한 경우 수소법원이 행정소송에 대한 관할도 동시에 가지고 있는 경우라면 항고소송으로 심리하여야 한다고 판시하였다(대판 1999. 11. 26, 97다42250). 그러나 구체적으로 어떠한 법률규정에 의하여 소변경을 할 수 있는지에 대해선 설시하지 않았다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 다음 중 항고소송의 피고적격에 관한 설명 중 틀린 것은? 2006년 국회 8급

① 중앙노동위원회의 처분에 대한 소는 중앙노동위원회 위원장을 피고로 하여 제기하여야 한다.
② 공정거래위원회의 처분에 대한 소는 공정거래위원회를 피고로 하여 제기하여야 한다.
③ 처분적 조례에 대한 항고소송의 경우 지방자치단체장이 피고가 된다.
④ 지방의회 의원에 대한 지방의회의 제명징계의결에 대하여 항고소송을 제기하는 경우 지방의회가 피고가 된다.
⑤ 국회의장이 행한 처분에 대한 불복의 소는 국회의장을 피고로 한다.

① [○] 중앙노동위원회의 처분에 대한 소는 중앙노동위원회위원장을 피고로 하여 처분의 통지를 받은 날부터 15일 이내에 이를 제기하여야 한다(노동위원회법 제27조 제1항).
② [○] 공정거래위원회의 처분에 대한 소는 공정거래위원회를 피고로 제기하여야 한다.
※ 토지수용위원회, 저작권심의위원회, 국민권익위원회, 교원소청심사위원회, 공정거래위원회 등 합의제 행정청의 처분에 대한 소는 그 합의제 행정청의 장이 아니라 합의제 행정청을 피고로 한다. 즉 공정거래위원회의 처분에 대하여 불복의 소를 제기하고자 할 때에는 처분의 통지를 받은 날 또는 이의신청에 대한 재결서의 정본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제54조 제1항).
③ [○] 조례가 항고소송의 대상이 되는 경우 조례의 공포권자인 지방자치단체의 장이 피고가 된다.
※ 조례가 집행행위의 개입 없이도 그 자체로서 직접 국민의 구체적인 권리의무나 법적 이익에 영향을 미치는 등의 법률상 효과를 발생하는 경우 그 조례는 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하고, 이러한 조례에 대한 무효확인소송을 제기함에 있어서 행정소송법 제38조 제1항·제13조에 의하여 피고적격이 있는 처분 등을 행한 행정청은, 행정주체인 지방자치단체 또는 지방자치단체의 내부적 의결기관으로서 지방자치단체의 의사를 외부에 표시한 권한이 없는 지방의회가 아니라, 지방자치법 제26조에 의하여 지방자치단체의 집행기관으로서 조례로서의 효력을 발생시키는 공포권이 있는 지방자치단체의 장이다(대판 1996.9.20, 95누8003).
④ [○] 지방자치법 제86조 내지 제89조의 규정에 의거한 지방의회의 의원징계의결은 그로 인해 의원의 권리에 직접 법률효과를 미치는 행정처분의 일종으로서 행정소송의 대상이 되고, 그와 같은 의원징계의결의 당부를 다투는 소송의 피고는 지방의회이다(대판 1993.11.26. 93누7341 참조).
⑤ [×] 국회의장이 행한 처분에 대한 행정소송의 피고는 국회사무총장으로 한다(국회사무처법 제4조 제3항).

답 : 5

2. 취소소송의 피고경정에 관한 설명으로 옳지 못한 것은? 2006년 대구시 교행

① 피고를 경정하는 것에 대한 허가결정이 있을 때에는 새로운 피고에 대한 소송은 처음에 소를 제기한 때에 제기된 것으로 본다.
②「행정소송법」 제14조 제1항의 '피고를 잘못 지정한 때'에 해당하는지 여부는 제소시를 기준으로 판단한다.
③ 피고경정이란 소송의 계속 중에 피고로 지정된 자를 다른 자로 변경하는 것을 말한다.
④「행정소송법」은 소의 변경에 따르는 피고의 경정을 인정하지 않고 있다.
⑤ 법원은 원고의 신청에 의하여 결정으로써 피고의 경정을 허가할 수 있다.

① [○] 행정소송법 제14조 제4항.
② [○] '피고의 잘못 지정 여부'의 판단기준시는 제소시를 기준으로 한다는 것이 다수견해이다.
③ [○] 피고의 경정이란 소송의 계속 중에 피고를 다른 행정청으로 변경하는 것을 말한다.
④ [×] 행정소송법은 소의 변경에 따르는 피고의 경정을 인정한다(행정소송법 제21조 제1항 및 제4항)
※ 법원은 취소소송을 당해 처분 등에 관계되는 사무가 귀속하는 국가 또는 공공단체에 대한 당사자소송으로 변경하는 것을 허가할 수 있고, 이 경우 피고는 행정청에서 국가 또는 공공단체로 경정되게 된다.

⑤ [○] 행정소송법 제14조 제1항.

답 : 4

3. 행정소송의 피고적격에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 2008년 국회 8급

① 세무서장이 압류한 재산의 공매를 한국자산관리공사(구 성업공사)로 대행하게 한 경우 피고는 한국자산관리공사이다.
② 세무서는 행정조직 내에서 사무분담기구일 뿐이고 대외적으로 의사를 결정, 표시할 권한을 가진 행정청이 아니므로 피고는 행정청인 세무서장이 된다.
③ 판례에 따르면 내부위임에 의한 처분이 수임기관의 명의로 행해진 경우에는 수임기관이 피고가 된다.
④ 무효등확인소송에 있어서의 피고는 효력 유무나 존재 여부의 확인대상이 되는 처분 등을 한 행정청이다.
⑤ 공무원에 대한 징계·면직 기타 본인의 의사에 반하는 불이익처분에 있어서 그 처분청이 대통령인 때에는 법무부장관을 피고로 하여야 한다.

① [○] 한국자산관리공사(구 성업공사)에 의한 공매의 대행은 세무서장의 공매권한의 위임으로 보아야 하고, 따라서 한국자산관리공사는 공매권한의 위임에 의하여 압류재산을 공매하는 것이므로, 한국자산관리공사가 공매를 한 경우에 그 공매처분에 대한 취소 또는 무효확인 등의 항고소송을 함에 있어서는 수임청으로서 실제로 공매를 행한 한국자산관리공사를 피고로 하여야 하고, 위임청인 세무서장은 피고적격이 없다(대판 1996.9.6, 95누12026 ; 대판 1997.2.28, 96누1757).
② [○] 항고소송의 피고적격으로서 '처분행정청'은 외부명의자를 의미하는 바 맞는 지문이다.
③ [○] 내부위임의 경우에는 권한이 이양 되는 것이 아니기 때문에 위임기관이 피고가 된다. 그러나 판례는 두 가지로 구분하여 수임기관의 명의로 처분을 한 경우에는 수임기관을(대판 1991.10.8, 91누520), 위임기관의 명의로 한 경우에는 위임기관이 피고가 된다(대판 2006.2.23, 2005부4)는 입장을 취하고 있다.
④ [○] 무효등확인소송은 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 그 처분 등을 행한 행정청을 피고로 한다. 다만, 처분 등이 있은 뒤에 그 처분 등에 관계되는 권한이 다른 행정청에 승계된 때에는 이를 승계한 행정청을 피고로 한다(행정소송법 제38조 제1항·제13조 제1항).
⑤ [×] 행정소송을 제기할 때에는 대통령의 처분 또는 부작위의 경우에는 소속 장관을, 중앙선거관리위원회위원장의 처분 또는 부작위의 경우에는 중앙선거관리위원회사무총장을 각각 피고로 한다(국가공무원법 제16조 제2항).

답 : 5

♣ 학습내용 정리

1. 피고적격으로서의 처분행정청은 원칙적으로 외부명의자를 의미한다.
2. 예외적 행정심판전치주의와 제소기간은 취소소송과 부작위위법확인소송에서만 소송요건이다.

제37강 취소소송의 본안심리절차

♣ 학습목표

취소소송의 본안심리절차와 관련하여 가구제수단으로 집행정지 및 처분권주의와 변론주의, 입증책임, 위법판단기준시에 대하여 각각 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

집행정지
본안심리절차
위법판단기준시

♣ 사전테스트

1. 거부처분에 대하여 집행정지가 가능하다는 것이 판례입장이다.
   정답 : X

2. 행정소송법 제26조에 의해 행정소송은 직권탐지주의를 취하고 있다는 것이 다수설과 판례이다.
   정답 : x

3. 취소소송의 위법판단기준시는 처분시라는 것이 판례이다.
   정답 : O

♣ 돌발퀴즈

회복곤란한 손해란 특별한 사정이 없는 한 금전보상이 가능한 손해이다.

[정답] ×

[해설] 행정소송법 제23조 제2항에서 정하고 있는 효력정지 요건인 '회복하기 어려운 손해'란, 특별한 사정이 없는 한 금전으로 보상할 수 없는 손해로서 금전보상이 불가능한 경우 내지는 금전보상으로는 사회관념상 행정처분을 받은 당사자가 참고 견딜 수 없거나 참고 견디기가 현저히 곤란한 경우의 유형·무형의 손해를 일컫는다(대결 전합 2011.4.21, 2010무111 ; 대결 2010.5.14, 2010무48 등).

♣ 강의내용

제1 가구제

Ⅰ. 개 설

1. 가구제의 의의

행정소송법상의 가구제란 본안판결의 실효성을 확보하기 위하여 계쟁처분 등이나 공법상의 권리관계에 관하여 잠정적인 효력관계나 지위를 정함으로써 본안판결이 확정되기 전에 잠정적으로 권리구제를 도모하는 것을 말한다. 가구제는 본안판결이 확정되기 전에 계쟁처분의 집행이나 절차의 속행으로 인하여 회복하기 어려운 기성사실이 창설되는 것을 방지함으로써 본안판결의 실효성을 확보하여 효과적인 권리구제를 보장하고자 함을 목적으로 한다. 이러한 가구제에는 집행정지와 가처분이 있다.

2. 집행부정지 원칙 - 행정소송법 제23조 제1항

Ⅱ. 집행정지의 의의 및 법적 성질

1. 집행정지의 의의

집행정지란 취소소송이 제기된 처분 등이나 그 집행 또는 절차의 속행으로 인하여 생길 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있다고 인정할 때 법원이 당사자의 신청 또는 직권에 의해 그 집행을 잠정적으로 정지하도록 결정하는 것을 말한다(행정소송법 제23조 제2항).

2. 법적 성질 - 司法作用

집행정지도 법원이 내리는 결정으로 사업작용이지 행정 작용은 아니다.

Ⅲ. 집행정지결정의 요건

1. 집행정지대상인 처분의 존재

⑴ 취소소송과 무효확인소송의 작위처분

⑵ 대상처분 등의 존재

1) 처분의 효력이 소멸된 후 - 집행정지 불가

2) 거부처분에 대한 집행정지가능여부

거부처분도 처분성이 인정되면 집행정지의 대상이 될 수 있다. 단, 거부처분에 대한 집행정지결정을 내릴 신청의 이익이 있는지와 관련하여 학설의 대립이 있다.

① 학설

① 집행정지는 행정소송법 제30조 제2항을 준용하지 않아 거부처분 집행정지결정이 내려져도 재처분의무가 인정되지 않고 거부처분 집행정지에 의해 거부처분이 없는 상태로 돌아가는 것에

불과하여 신청의 이익이 없다는 부정설과 ② 원칙적으로는 신청의 이익이 없으나 예외적으로 거부처분집행정지로 거부처분이 없는 상태로 복귀함으로써 신청인에게 회복되는 이익이 있는 경우에는 신청의 이익이 있으므로 집행정지를 인정해야 한다는 예외적 긍정설이 대립한다.

② 판례

판례는 국립대학교 총장의 입학 불합격처분(대판 1963. 6. 29, 62두9), 투전기업소허가갱신불허가처분(대판 1992. 2. 13, 91두47), 교도소장의 접견허가거부처분(대판 1991. 5. 2, 91두15)에 대한 집행정지신청사건에서 신청의 이익흠결로 기각하여 부정설의 입장을 취하였다.

2. 본안소송의 계속

집행정지의 전제가 되는 소송요건을 갖춘 적법한 본안소송이 법원에 계속되어 있어야 한다.

3. 회복하기 어려운 손해발생의 가능성

회복하기 어려운 손해란 금전배상이 불가능한 경우와 사회통념상 원상회복이나 금전배상이 가능하더라도 금전배상만으로 수인할 수 없거나 수인하기 어려운 유형·무형의 손해를 의미한다.

다만, 행정소송법 개정안은 위 요건을 완화하여 '중대한 손해'라고 규정하였다.

4. 긴급한 필요의 존재

본안 판결을 기다릴 시간적 여유가 없어야 된다는 것 대부분 이 요건에는 특별한 문제가 될 것이 없다.

5. 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 없을 것

이에 대한 주장 및 소명책임은 피신청인에게 있다.

6. 본안소송의 승소가능성

다수설과 판례는 본안소송에서 승소가능성이 없음이 명백할 것을 집행정지의 소극적 요건으로 보고 있다. 이에 대한 소명책임은 피신청인에게 있다.

Ⅳ. 집행정지결정의 절차

1. 개시절차

집행정지결정은 법원이 당사자의 신청이나 직권에 의하여 행한다. 당사자의 신청시에는 그 이유에 대한 소명이 있어야 한다(행정소송법 제23조 제4항).

2. 심 리

집행정지는 본안소송이 계속된 법원이 관할한다.

Ⅴ. 집행정지결정의 내용

1. 처분의 효력정지

이는 처분의 내용에 따르는 구속력, 공정력, 집행력 등을 정지함으로써 당사자에 대한 효과에 있어서 당해 처분이 잠정적으로 존재하지 않는 상태로 두는 것을 말한다. 그 효과에서 집행정지결정 중 가장 강력한 것이므로, 처분의 집행정지나 절차의 속행정지를 통하여 그 목적을 달성할 수 있는 경우에는 허용되지 않는다(행정소송법 제23조 제2항 단서).

2. 처분의 집행정지

이는 처분이 가지는 효력은 유지하면서 이를 실현하기 위한 집행력의 행사만을 정지하는 것이다. 강제출국명령을 받은 당사자에 대해 잠정적으로 강제출국하지 않도록 하는 경우를 들 수 있다.

3. 절차의 속행정지

이는 소송의 대상인 처분의 효력은 유지하면서 당해 처분의 후속절차를 잠정적으로 정지하게 하는 것을 말한다. 토지수용절차나 행정대집행 절차의 경우에 후속적인 절차를 정지하는 것이 이에 해당한다.

Ⅵ. 집행정지결정의 효과

1. 일반적 효력

⑴ 기속력(동법 제23조 제6항, 동법 제30조 제1항).
집행정지 결정의 취지에 반해서 행정청의 처분을 내리면 안된다.

⑵ 형성력 - 효력정지결정

⑶ 시간적 효력

집행정지결정의 효력은 별도로 시간적인 범위에 대해 특별히 정하고 있지 않는 한 당해 소송의 판결이 확정될 때까지 발생하게 된다.

⑷ 대인적 효력

집행정지결정의 효력은 제3자에게도 미친다(행정소송법 제29조 제2항).

2. 집행정지결정에 대한 불복 : 행정소송법 제23조 제5항

법원의 집행정지결정이나 집행정지신청기각의 결정 또는 집행정지결정의 취소결정에 대하여는 즉시항고할 수 있다. 다만 즉시항고는 그 즉시항고의 대상인 결정의 집행을 정지하지 아니한다.

3. 집행정지결정의 취소 : 행정소송법 제24조

집행정지결정을 한 후에, 그것이 공공복리에 중대한 영향을 미치거나 또는 정지사유가 없어진 때에는, 법원은 당사자의 신청 또는 직권에 의하여 결정으로써 집행정지를 취소할 수 있다(동법 제24조 제1항).

제2 행정소송의 심리

Ⅰ. 개 설

행정소송사건의 심리에 관하여 행정소송법에 특별한 규정이 없으므로 민사소송법이 준용된다(행정소송법 제8조 제2항). 따라서 심리절차의 진행에 대하여도 민사소송의 대원칙인 처분권주의와 변론주의가 행정소송에서도 원칙적으로 적용된다. 다만 행정소송은 민사소송과 다르게 국민의 권리구제와 아울러 행정목적의 달성과 행정법규의 정당한 적용 등 행정의 적법성 보장도

그 목적으로 하므로 법원이 필요하다고 인정할 때에는 일정한 범위 내에서 직권으로 증거조사를 할 수 있고, 당사자가 주장하지 않은 사실에 대하여도 판단할 수 있도록 규정하여 변론주의에 대한 제한규정(행정소송법 제26조)을 두고 있다.

Ⅱ. 심리의 내용

1. 소송요건의 심리 - 직권조사사항 / 사실심 변론종결시 기준

2. 본안의 심리

Ⅲ. 심리의 대상 : 처분권주의

이는 소송절차의 개시, 소송의 종료, 소송절차의 개별적인 사항의 결정에 관하여 당사자에게 맡기는 원칙을 말한다. 행정소송도 원칙적으로 처분권주의의 지배를 받는다. 따라서 당사자의 소제기, 소송의 대상 등은 원고에게 처분권이 있으므로 법원이 이 범위를 넘어서 판단할 수 없다. 그러나 소송의 종료와 관련하여 청구의 인낙이나 소송상 화해 등에 대해서는 행정의 적법성 보장이라는 행정소송의 목적에 비추어 인정될 수 없다는 견해와 행정소송법에 특별규정이 없다는 점을 근거로 인정될 수 있다는 견해가 대립한다.

Ⅳ. 심리의 절차

1. 심리에 관한 일반원칙

이에 관하여는 행정소송법이 명문의 규정을 두고 있지 않으므로, 행정소송법 제8조 제2항에 의하여 민사소송법의 심리의 원칙들이 적용된다.

⑴ 공개심리주의와 구술심리주의

⑵ 처분권주의 - 전술참조

⑶ 변론주의

이는 법원의 판결의 기초가 되는 사실관계와 증거의 수집 및 제출책임을 당사자에게 일임하고 당사자가 수집, 제출한 소송자료만을 재판의 기초로 삼는 원칙을 말한다. 변론주의의 개별적 내용으로는 주요사실의 주장책임, 자백의 구속력, 직권증거조사의 원칙적 금지 등이다.

이러한 변론주의에 따르면 판결의 기초가 되는 사실관계의 제출은 당사자에게, 이에 기초한 법적용은 법관에게 맡겨진다. 이에 대립하는 원칙이 바로 직권탐지주의다.

2. 행정소송의 특수한 심리절차

⑴ 직권심리주의

이는 소송절차에서의 사실관계의 조사에 관한 책임을 법원이 부담하는 원칙을 말한다. 따라서 사실관계의 수집과 평가에 관하여 법원은 독점적이며 다른 주체로부터 영향을 받지 않고 책임을 수행하게 된다. 이를 위해 법원은 당사자의 제출자료에 구속받음이 없이 직권으로 사실관계와 증거를 조사하며, 사실관계의 해명을 행정기관에게 맡기지 않고 스스로 행하여야 한다.

⑵ 행정소송법 제26조의 해석

1) 문제점

행정소송법 제26조는 “법원은 필요하다고 인정할 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있고, 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여도 판단할 수 있다”고 규정하고 있다. 이 규정이 원칙적으로 변론주의의 원칙을 유지하고 예외적으로 변론주의로 일관할 때 나타날 수 있는 결함을 시정하기 위하여 변론주의를 보충하기 위한 것인지 아니면 직권탐지주의를 규정한 것인지가 문제된다.

2) 학 설

① 변론주의보충설과 ② 직권탐지주의설 ③ 직권탐지주의 가미설 등이 대립한다.

3) 판 례

대법원은 변론주의를 기본구조로 하는 이상 원칙적으로 원고가 그 처분의 위법사유를 주장하여야 한다고 하면서 예외적으로 변론주의를 보충하기 위하여 직권으로 판단할 수 있다고 한다.

⑶ 행정심판기록 제출명령 - 행정소송법 제25조

3. 주장책임

변론주의를 채택하는 소송에 있어서는 주요사실이 변론에서 주장되지 아니하면, 법원은 그 사실을 판결의 기초로 할 수 없다. 그 결과 소송당사자의 어느 한 편이 패소의 위험 또는 불이익을 받게 되는데, 이러한 위험 또는 불이익을 면하기 위하여 당사자의 일방이 필요한 사실을 주장하여야 하는 책임을 주장책임이라 한다. 직권탐지주의를 취하는 소송심리에서는, 법원은 직권으로 사실을 탐지할 수 있으므로, 주장책임은 문제되지 아니한다. 한편 주장책임의 분배의 문제는, 원칙적으로 입증책임의 분배의 문제와 내용을 같이 한다.[76]

제3 항고소송과 입증책임

Ⅰ. 개 설

1. 입증책임의 의의

입증책임이란 소송상 일정한 사실의 존부가 증명되지 않은 경우 당해 사실이 존재하지 않는 것으로 보게 되어 불리한 법적 판단을 받게 되는 일방 당사자의 증명 부담을 의미한다. 이는 요건사실의 불확정으로 인하여 법원의 재판이 불가능해지는 것을 방지하기 위한 소송법적인 고려에 기초하고 있다.

2. 입증책임의 분배

어느 한쪽이 증거를 통해서 증명해야 될 책임, 만약 증명 못하면 사실은 존재하지 않는 사실로 해서 법원이 판결 내리는게 바로 입증 책임이다.

Ⅱ. 취소소송에서의 입증책임의 분배

76) 예외적으로 소극적 확인의 소는 주장책임과 입증책임이 달라지게 된다.

원고책임설, 피고책임설, 법률요건분류설, 행정소송법 독자분류설 등이 대립한다. 판례는 법률요건분류설을 취한 것으로 보인다.

Ⅲ. 무효확인소송에서의 입증책임

판례는 행정처분의 당연무효를 구하는 소송에 있어서 무효원인사실은 그 무효를 구하는 원고가 입증책임을 진다고 판시하고 있다. 즉 무효를 권리발생사실에 대한 부인이 아니라 권한장애사실로 보고 있다.

Ⅳ. 부작위위법확인소송에서의 입증책임

부작위위법확인소송에서 신청사실 및 신청권의 존재는 소소요건에 해당한다. 따라서 원고에게 입증책임이 있다.

일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무의 존부 및 상당한 기간의 판단은 법률판단이므로 입증책임의 대상이 되지 않는다.

상당한 기간이 경과하였음에도 신청에 따른 처분을 하지 못한 것을 정당화하는 사유에 대하여는 행정청에게 주장 및 입증책임이 있다.

제4 항고소송의 위법판단기준시

Ⅰ. 서

처분은 그 당시의 사실상태 및 법률상태를 기준으로 하여 행해지게 된다. 그런데 처분 후 사실상태 또는 법률상태가 변경되는 경우가 있다. 이 경우에 있어서 법원이 본안심리의 결과 처분의 위법여부를 판단함에 있어서 어느 시점의 법률상태 및 사실상태를 기준으로 하여야 할 것인가 하는 문제가 제기된다.

Ⅱ. 취소소송 및 무효확인소송에서의 기준시 및 위법성판단의 자료

1. 취소소송 및 무효확인소송에서의 기준시

⑴ 학설

학설은 ① 항고소송은 처분이 법규에 적합한가 여부를 판단하는 것인 바 판결시 법규를 기준으로 판단하여야 한다는 판결시설, ② 법원의 기능상 법원은 객관적 입장에서 처분 등의 위법여부를 사후에 심사할 수 있을 뿐이고 처분시 이후 사정을 고려하는 것은 행정청의 1차적 판단권을 침해하므로 처분시를 기준으로 위법여부를 판단하여야 한다는 처분시설, ③ 거부처분 및 계속적 효과를 갖는 처분에 한해서 판결시로 보자는 절충설, ④ 원칙적으로 처분시로 보되 거부처분취소소송에서는 인용판결의 기준시는 판결시로 보자는 견해 등이 대립한다.

⑵ 판례

행정처분의 적법여부는 특별한 사정이 없는 한 그 처분당시를 기준으로 판단해야 하고, 처분청이 처분이후에 추가한 새로운 사유를 보태어 처분당시의 흠결을 치유할 수 없다고 하여, 처분시설을 취하고 있다(대판 1993. 5. 27, 92누19033).

2. 위법성판단의 자료

처분시설은 처분시의 법령 사실상태를 기준으로 적법여부를 판단하고 처분이후의 법령 사실상태의 변동에 영향받지 않는다는 뜻이지 처분당시 존재했던 자료만으로 판단하라는 의미는 아니므로, 법원은 사실심변론종결시까지 제출된 모든 자료를 종합하여 확정한 사실에 기초하여 처분의 적법여부를 판단해야 한다(통설, 판례).

Ⅲ. 부작위위법확인소송에서의 기준시

취소소송이나 무효등확인소송과 달리 이 경우 엄격한 의미의 처분은 존재하지 않으므로, 판결시를 기준으로 할 수밖에 없다는 것이 통설이다.

Ⅳ. 관련문제

1. 수익적 처분의 거부인 경우 - 전술 법령개정과 신뢰보호 참조
2. 적극적 처분인 경우 - 전술 법령개정과 신뢰보호 참조

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 甲은 미결수로서 안양교도소에 수감 중인데 대법원에 상고제기 후 전주 교도소로 이송되었다. 甲은 즉시 그러한 이송조치로 인해 서울에서 거주하는 변호인 가족 등과의 접견이 어려워져 방어권의 행사에 지장을 받는 등 회복하기 어려운 손해를 입게 된다고 주장하면서 이송조치를 취소하라는 행정소송을 제기함과 함께 이송조치의 효력정지신청을 하였다. 甲의 권리구제 가능성과 관련된 다음의 서술 중 옳지 않은 것은? (제46회 행정고시 2차시험 문제변형)

① 사안은 교도소 재소관계로서 특별권력관계의 한 유형에 해당된다.
② 사법심사 가능성과 관련하여 오늘날에는 특별권력관계의 내부행위라 하더라도 행정소송법상의 처분개념에 해당될 경우 항소소송의 대상이 된다고 본다.
③ 행정소송법은 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용을 처분이라고 명시하고 있다.
④ 판례는 사안의 이송조치에 대해 처분성을 인정하고 있지 않다.
⑤ 사안의 甲의 집행정지신청은 인용될 것이다.

해설 & 정답

유형 사례형

③ 행정소송법 제2조 제1항 제1호
④ 교도소장 등이 미결수용자를 다른 수용시설로 이송하기 위하여 사전에 법원의 허가를 받을 필요는 없다고 하더라도 이러한 이송처분이 행정소송의 대상이 되는 행정처분임에는 틀림없다(대판 1992.8.7, 92두30).
⑤ 집행정지신청이 인용되기 위해서는 법 제23조에 따라서 ⅰ) 처분이 존재하여야 하고, ⅱ) 본안소송이 적법하게 계류 중이어야 하고, ⅲ) 회복하기 어려운 손해발생의 우려가 있어야 하며, ⅳ) 본안 승소 가능성과 ⅴ) 소극 요건으로서 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 없을 것을 요한다. 사안에서는 甲이 진주 교도소로 이송될 경우 변호인과 가족들 간의 접견이 어려워지고 그로 인한 손해는 금전으로 보상할 수 없는 손해라 할 것이므로, 이 요건을 갖추었다고 볼 것이므로 ⅲ)의 요건을 갖추었고, 본안 청구가 이유없음이 명백하지 아니할 것 정도의 승소가능성도 일응 인정되어서 ⅳ)의 요건도 갖추었고, 기타 요건도 충족에 문제가 없으므로 집행정지 신청은 인용될 것이다. 대법원도 동일하게 판시(대판 1992.8.7, 92두30)하고 있다.

정답 ④

2. 甲이 토지형질변경 불허가처분 취소소송에서 취소의 근거로 국립공원에 인접한 미개발지역의 합리적인 이용대책 시까지 그 허가를 유보하는 사유를 들다가 소송 계속 중에 국립공원 주변의 환경·풍치·미관 등을 크게 손상시킬 우려가 있으므로 공공목적상 원형 유지의 필요가 있는 곳으로서 형질변경허가 금지대상이라는 사유로 변경하려고 한다. 이와 관련된 다음의 설명 중 타당하지 않은 것은?

① 사안은 소송의 계속 중에 그 대상처분의 사유를 추가하거나 잘못 제시된 사실상의 근거 또는 법률적 근거를 변경하는 것으로서 처분사유의 추가변경에 해당된다.
② 처분사유의 추가변경은 처분시에 이미 법령상 요구되는 처분사유가 존재하므로 이유부기상의 하자의 치유와 구분되고 그 처분의 동일성이 유지되므로 흠있는 행정행위의 전환과 구분된다.
③ 처분사유의 추가변경의 허용여부와 관련하여 소송경제적 측면을 강조하는 긍정설과 소송당사자의 공격방어권의 보장이라는 측면을 강조하는 소극설과, 두가지 이익을 조화하여 당초의 처분의 근거사유와 기본적 사실관계의 동일성이 인정되는 범위에서 인정하는 제한적 긍정설의 견해대립이 있는데 판례는 제한적 긍정설에 따른다.
④ 판례는 시적 한계와 관련하여서 사실심 변론종결 시까지 처분사유의 추가변경을 인정하고 있다.
⑤ 판례는 사안과 관련하여 처분의 동일성을 인정하지 않는다.

해설 & 정답

유형 사례형

② 이유부기상의 하자의 치유는 처분시에는 이유부기가 전혀 이루어지지 않았거나 법령상 요구되는 정도로 이루어지지 않은 하자가 있어 이를 사후에 치유하는 것을 말한다. 흠 있는 행정행위의 전환이란 전환을 통해서 종전과는 다른 법적 규율이 가해지는 것이므로 처분의 동일성이 유지되지 못한다.

③ 행정처분의 취소를 구하는 항고소송에 있어서는 실질적 법치주의와 행정처분의 상대방인 국민에 대한 신뢰보호라는 견지에서 처분청은 당초처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계가 동일성이 있다고 인정되는 한도 내에서만 다른 사유를 추가하거나 변경할 수 있을 뿐, 기본적 사실관계와 동일성이 인정되지 않는 별개의 사실을 들어 처분사유로 주장함은 허용되지 아니하고, 여기서 기본적 사실관계의 동일성 유무는 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적인 사실에 착안하여 그 기초가 되는 사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일한지 여부에 따라 결정된다(대판 2001.9.28, 2000두8684).

④ 과세관청은 소송 도중이라도 당해 처분에서 인정한 과세표준 또는 세액의 정당성을 뒷받침할 수 있는 새로운 자료를 제출하거나 처분의 동일성이 유지되는 범위 내에서 그 사유를 교환·변경할 수 있다고 할 것이나 이는 사실심 변론종결시까지만 허용된다(대판 1999.2.9, 98두16675).

⑤ 토지형질변경 불허가처분의 당초의 처분사유인 국립공원에 인접한 미개발지의 합리적인 이용대책 수립시까지 그 허가를 유보한다는 사유와 그 처분의 취소소송에서 추가하여 주장한 처분사유인 국립공원 주변의 환경·풍치·미관 등을 크게 손상시킬 우려가 있으므로 공공목적상 원형유지의 필요가 있는 곳으로서 형질변경허가 금지대상이라는 사유는 기본적 사실관계에 있어서 동일성이 인정된다(대판 2001.9.28, 2000두8684).

정답 ⑤

3. 숙박영업허가를 받은 甲은 윤락행위를 알선하였다는 이유로 영업허가를 취소당하였다. 甲은 손님의 강력한 요구가 있었고 단 1회에 그쳤다는 이유로 본처분이 부당하다고 하여 취소소송을 제기하였다. 그리고 생계가 막연하다는 이유로 집행정지결정을 신청하였다. 이에 대해서 취소소송이 인용될 것인지, 집행정지결정신청이 인용될 것인지와 관련된 다음의 서술 중 옳지 않은 것은? (1995년 지방고시 2차문제 변형)

① 공중위생관리법 시행규칙 제41조에서는 윤락행위를 알선한 경우 1차 위반시 영업정지 2개월을 규정하고 있는데 판례는 동 규칙은 판례의 태도에 의할 경우 대외적 구속력이 부정된다.
② 별표 규정을 위반하고 영업취소처분을 한 사실 만으로는 위법하다고 할 수 없다.
③ 영업취소처분의 근거법률에 의할 경우 동 처분은 재량행위로 규정되어 있으므로 동 처분의 위법여부는 재량권 일탈남용 여부가 문제되는데 사안은 비례원칙 위반 여부가 문제된다. 사안의 경우 비례원칙 위반이 인정될 수 있다.

④ 비례원칙 위반한 경우 위법성의 정도는 판례의 태도에 의할 경우 취소사유에 불과하다.
⑤ 생계가 막연하다는 사유는 회복하기 어려운 손해에 해당하므로 집행정지 신청은 인용될 것이다.

해설 & 정답

유형 사례형

① 공중위생법 제23조 제1항은 처분권자에게 영업자가 법에 위반하는 종류와 정도의 경중에 따라 제반사정을 참작하여 위 법에 규정된 것 중 적절한 종류를 선택하여 합리적인 범위내의 행정처분을 할 수 있는 재량권을 부여한 것이고, 이를 시행하기 위하여 동 제4항에 의하여 마련된 공중위생법시행규칙 제41조 별표 7에서 위 행정처분의 기준을 정하고 있더라도 위 시행규칙은 형식은 부령으로 되어 있으나 그 성질은 행정기관 내부의 사무처리준칙을 규정한 것에 불과한 것으로서 보건사회부장관이 관계 행정기관 및 직원에 대하여 그 직무권한 행사의 지침을 정하여 주기 위하여 발한 행정명령의 성질을 가지는 것이지, 위 법 제23조 제1항에 의하여 보장된 재량권을 기속하거나 대외적으로 국민을 기속하는 것은 아니다(대판 1991.3.8, 90누6545).
② 왜냐하면 판례의 태도에 의할 경우 별표의 법적 성질을 행정규칙에 불과하므로 이를 위반하였다고 위법한 것은 아니다.
③ 공중위생관리법에서는 할 수 있다는 표현으로 재량행위성을 인정하고 있다.
④ 판례와 통설인 중대명백설에 의할 경우 비례원칙 위배가 있는 경우 중대한 하자이나 명백하다고 할 수 없어 위법성의 정도는 취소사유에 해당한다.
⑤ 집행정지신청이 인용되기 위해서는 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위한 것이어야 하는 데 사안의 단순히 생계가 막연하다는 사유만으로는 판례의 기준인 금전보상이 불가능한 비재산적 손해에 해당하지 않고 긴급한 필요가 존재한다고 볼 수 없으므로 집행정지신청은 기각되어야 한다.

정답 ⑤

♣ 학습내용 정리

1. 집행정지는 적극적 처분에 대한 가구제 수단으로 실효적이다.
2. 행정소송의 본안심리절차로 불고불리원칙이 적용된다.

제38강 취소소송의 판결

♣ 학습목표

처분사유추가변경의 한계와 취소소송의 판결의 종류 및 사정판결, 그리고 판결의 효력으로서 기판력에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

처분사유 추가변경
사정판결
기판력

♣ 사전테스트

1. 처분사유 추가변경은 무제한적으로 허용된다.
   정답 : X

2. 사정판결은 무효확인소송에서도 인정된다는 것이 판례이다.
   정답 : x

3. 기판력은 기각판결에서도 인정된다.
   정답 : O

♣ 돌발퀴즈

사정판결은 피고인 행정기관이 신청한 경우에 인정되는 것이지 수소법원의 직권심리는 불가능하다는 것이 판례의 태도이다.

[정답] ×

[해설] 대법원은 "행정소송법 제26조, 제28조 제1항 전단의 각 규정에 비추어 행정소송에 있어서 법원이 사정판결을 할 필요가 있다고 인정하는 때에는 당사자의 명백한 주장이 없는 경우에도 일건기록에 나타난 사실을 기초로 하여 직권으로 사정판결을 할 수 있다(대판 1992.2.14, 90누9032)"라고 판시하여 직권에 의한 사정판결을 인정하고 있다.

♣ 강의내용

제1 처분사유추가변경

Ⅰ. 의의

행정청이 처분을 하면서 이유부기 절차에 의해 처분사유를 밝힌 후 취소소송의 계속 중 그 처분의 내용상 적법성 유지를 위하여 처분당시에 처분 사유로 삼았던 것과는 다른 사유를 추가하거나 변경하는 것을 말한다.

Ⅱ. 구별개념 - 하자의 치유와의 차이

이유부기의 하자의 치유는 처분시 존재했던 절차상 하자를 치유하기 위한 사후보완행위라면, 처분사유추가변경은 처분의 내용상 하자와 관련된 것이다.

Ⅲ. 처분사유의 추가 변경의 허용 여부

1. 문제점

이 문제는 소송경제 및 분쟁의 일회적 해결이라는 요청과 처분상대방의 신뢰보호 및 공격 방어권의 존중, 이유부기제도의 취지라는 요청을 조화시키느냐의 문제이다.

2. 허용여부

⑴ 학설

① 소송경제와 분쟁의 일회적 해결을 강조하여 무제한적으로 허용된다는 긍정설, ② 상대방의 신뢰보호와 이유부기제도의 취지의 관점에서 허용될 수 없다는 부정설, ③ 기속행위, 재량행위, 제재처분, 거부처분 등 행위의 유형 및 소송의 유형에 따라 처분사유의 추가변경의 허용범위를 달리 정하여야 한다는 개별적 결정설, ④ 처분의 동일성이 변경되지 않고 원고의 권리방어가 침해되지 않는 한도 내에서, 즉 기본적 사실관계 동일성이 있는 한도내에서만 이를 인정해야 한다는 제한적 긍정설(다수설)이 대립한다.

⑵ 판례

판례는 “실질적 법치주의와 국민에 대한 신뢰보호라는 견지에서 처분청은 당초처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계 동일성이 있다고 인정되는 한도 내에서만 다른 사유로 추가하거나 변경할 수 있을 뿐...”이라고 판시하여 제한적 긍정설을 취하였다.

Ⅳ. 처분사유추가변경의 허용기준 및 한계의 내용

1. 처분사유추가변경의 객관적 범위 : 기본적 사실관계의 동일성

통설과 판례는 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계가 동일하다고 인정되는 한도 내에서만 다른 처분사유를 새로 추가하거나 변경할 수 있다고 하여 ‘기본적 사실관계의 동일성’을 처분의 동일성 판단기준으로 내세우고 있다.

기본적 사실관계 동일성 유무는 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적인 사실관계에 착안하여 그 기초가 되는 사회적 사실관계의 동일성을 기준으로 하며, 판단은 시간적·장소적 근접성, 행위 태양·결과 등의 제반사정을 종합적으로 고려한다.

이에 판례는 ① 처분의 근거법령만을 추가·변경한다거나, ② 허가기준에 맞지 않음을 이유로 불허가 처분한 후, 구체적인 불허가사유를 제시한 경우 등에는 기본적 사실관계 동일성을 인정하고 있다.

그러나 처분의 법적 근거가 변경됨으로써 처분의 사실관계도 변경되고 그러한 사실관계의 기본적 동일성이 인정되지 않는 경우에는 처분사유추가변경이 허용되지 않는다.

2. 처분사유의 추가변경의 시간적 범위 - 위법판단기준시에 따라 검토

시적범위와 관련하여 위법판단기준시를 처분시로 보는 다수설과 판례에 따르면 처분시이후 사유는 법원이 심리할 수 없는 바 처분시 사유에 대해서만 추가변경이 허용된다.

3. 추가적 한계

⑴ 재량행위에서 처분사유추가변경이 가능한지

일부견해는 재량행위에서는 처분사유추가변경은 재량행위의 변경을 가져오므로 부정하나, 재량행위도 분쟁대상인 재량행위가 본질적으로 변경되지 않는 범위내에서는 제한적 긍정설에 따라 처분사유추가변경을 허용하는 것이 타당하다.

⑵ 피고가 사실심 변론종결시전까지 처분사유 추가변경신청을 할 것(대판 1999. 8. 20, 98두 17043)

제2 취소소송의 판결

판결이라 함은 구체적인 법률상 쟁송을 해결하기 위하여 법원이 소송절차를 거쳐 내리는 결정을 말하는 것으로서, 취소소송의 판결이란 법원이 원칙적으로 변론을 거쳐 취소소송사건에 대한 법적 판단을 선언하는 행위를 말한다.

Ⅰ. 판결의 종류

1. 중간판결과 종국판결

실무상 중간판결을 내리는 경우는 없기 때문에 모든 판결은 종국판결이다.

2. 소송판결과 본안판결

3. 기각판결과 인용판결

4. 사정판결

⑴ 의 의

사정판결이란 취소소송에 있어서 원고의 취소청구가 이유있는 경우에도 청구를 인용하지 않고 처분 등을 취소하는 것이 현저히 공공복리에 반한다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 판결을 말한다(행정소송법 제28조).

⑵ 법치주의와의 관계

사정판결이 법원의 본래 임무인 위법처분의 배제라는 요청을 후퇴시키는 것이므로 그 요건해석을 엄격히 하고 적용범위를 최소한으로 하여야 할 것이라고 한다.

⑶ 사정판결의 요건

1) 취소소송일 것

사정판결은 당사자소송, 객관적 소송, 무효등확인소송에서는 인정되지 않고 취소소송에만 인정된다는 것이 통설과 판례의 입장이다. ① 일부 견해는 무효와 취소의 구별이 상대적이고 처분이 무효로 확인됨으로 인하여 현저하게 불합리한 결과를 초래하는 경우에도 생각할 수 있다는 점 등을 이유로 무효등확인소송에도 유추적용되어야 한다는 주장을 하고 있으나, ② 우선 행정소송법에 준용규정이 없고, 무효인 처분에 대하여서까지 사정판결을 허용하는 것은 당사자의 권리보호라는 관점에서 볼 때 너무 지나친 결과이고 법원이 무효인 처분을 유효한 처분으로 전환하는 결과가 된다는 점에서 인정할 수 없다고 보는 통설과 판례가 타당하다.

2) 처분의 위법성

사전 판결은 당해처분의 위법성이라는 소송물이 인정

3) 청구인용의 판결이 현저히 공공복리에 적합하지 아니할 것.

사안별로 구체적으로 여러가지를 고려해서 판단

⑷ 심 판

1) 주장 및 입증책임

판례는 행정소송법 제26조에 근거하여 피고행정청의 주장 없이도 직권으로 사정판결을 내릴 수 있다는 입장이다(대판 1995. 7. 28, 95누4629).

2) 위법성의 판단 및 사정판결 필요성의 판단기준시

3) 사정조사 - 행정소송법 제28조 제2항

사정 판결을 내리기 전 당해 처분으로 인해 발생한 손해

4) 처분이 위법함을 주문에 표시

5) 청구기각 판결

⑸ 구제방법의 병합 - 행정소송법 제28조 제3항

5. 일부취소판결가능여부

⑴ 서

⑵ 일부취소판결의 가능성

1) 서

행정소송법 제4조 제1호의 '변경'을 소극적 의미의 일부취소로 이해하는 한 처분의 일부취소 가능성은 일부취소의 대상이 되는 부분의 분리취소가능성에 따라 결정된다. 즉, 외형상 하나의 행정처분이라 하더라도 가분성이 있거나 그 처분대상의 일부가 특정될 수 있다면 그 일부만의 취소도 가능하다. 그러나 처분의 일부취소판결이 행정청의 처분권한을 침해하는 경우에는 적극적의미의 변경판결인 바 허용되지 않을 것이다.

2) 기속행위인 경우

원칙적으로 일부취소가 가능하다. 단, 법정금액을 산출할 수 없는 경우에는 전부취소하여야 한다.

3) 재량행위인 경우

① 원칙 : 일부취소 불가

② 예외

그러나 재량행위라 하더라도 외형상 하나의 처분일 뿐 가분성이 있는 경우나 그 처분대상이 일부 특정될 수 있다면 일부취소가 가능하다.

제3 판결의 효력

1. 서 설

취소소판결의 효력은 판결의 일반적 효력으로 인정되는 기판력 외에, 취소판결의 고유한 효력으로서 형성력과 기속력이 있다.

2. 기판력

1) 기판력의 의의

기판력이란 판결이 확정된 때에는 후에 동일한 사건이 소송상 문제가 되었을 때, 소송당사자는 이에 저촉되는 주장을 할 수 없고 법원도 이에 저촉되는 판단을 하지 못하게 하는 효력을 말한다. 즉, 전소의 확정판결이 후소에 미치는 구속력을 말한다. 기판력을 인정하는 취지는 소송절차의 반복과 모순된 재판의 방지라는 법적 안정성의 요청에 따라 인정되는 것이다.[77]

2) 기판력의 인정범위

① 주관적 범위

판결의 기판력이 미치는 인적 범위는 동일한 소송당사자에 한정된다.

② 객관적 범위

판결의 기판력은 그 객관적 범위에 있어서 전소 확정판결에서 판단한 소송물에 한정하여 인정된다. 따라서 전소 확정판결에서 판단한 소송물과 후소의 소송물이나 요건사실이 동일한 경우에 후소법원은 소송물이나 요건사실을 심리할 때 전소 법원의 소송물에 대한 판단에 구속된다.

---

77) 이재화, 전게서, 436면.

③ 시간적 범위

판결의 기판력에서의 시간적 범위는, 법원이 판결을 내리는 데에 근거가 되는 자료의 제출시한이 사실심 변론의 종결시까지이므로 이 시점을 기준으로 하여 발생한다고 본다. 따라서 변론종결 이전에 존재했던 사실관계나 법률관계에 기인한 주장은 기판력에 의하여 더 이상 허용되지 않는다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 사정판결에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 2008년 국회 8급

① 사정판결을 하는 경우 법원은 주문에 그 처분이 위법함을 명시하여야 하는데 그 위법성에 대하여 기판력이 발생한다.
② 법원은 사정판결을 함에 있어서 미리 원고가 그로 인하여 입게 될 손해의 정도의 배상방법 그 밖의 사정을 조사하여야 한다.
③ 법원은 당사자의 신청 없이 직권으로 사정판결 여부를 결정할 수 있다.
④ 사정판결을 함에 있어서 법원은 원고에 대하여 상당한 구제방법을 취하거나 피고 행정청에 상당한 구제방법을 취할 것을 명하여야 한다.
⑤ 사정판결의 대상이 되는 처분의 위법 여부는 처분시를 기준으로 판단하여야 하지만, 사정판결의 필요성은 판결시를 기준으로 하는 것이 다수설 및 판례이다.

① [○] 기판력은 원칙적으로 판결의 주문에 한하여 인정된다. 사정판결의 경우 법원은 그 판결의 주문에서 그 처분 등이 위법함을 명시하여야 하기 때문에(행정소송법 제28조 제1항 후문) 그 위법성에 대하여 기판력이 발생한다.
② [○] 행정소송법 제28조 제2항.
③ [○] 행정처분이 위법한 경우에는 이를 취소하는 것이 원칙이고, 예외적으로 그 위법한 처분을 취소·변경하는 것이 도리어 현저히 공공복리에 적합하지 아니하는 경우에는 그 취소를 허용하지 아니하는 사정판결을 할 수 있고, 이러한 사정판결에 관하여는 당사자의 명백한 주장이 없는 경우에도 기록에 나타난 여러 사정을 기초로 직권으로 판단할 수 있는 것이다(대판 2006.12.21, 2005두16161 ; 대판 2006.9.22, 2005두2506).
④ [×] 행정소송법 제28조 제3항.
⑤ [○] 사정판결에 있어서, 위법 판단의 기준시점은 처분시이나, 사정판결은 처분 이후의 사정변경을 고려하는 취지에서 인정되는 것이므로 사정판결의 필요성 판단의 기준시점은 판결시(변론종결시)이다(대판 1970.3.24, 69누29).

답 : 4

2. 사정판결의 요건으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함) 2012년 지방직 9급

① 처분이 위법하여야 한다.
② 처분을 취소하는 것이 현저히 공공복리에 적합하지 아니하다고 인정되어야 한다.
③ 사정판결의 경우 처분 등의 위법성은 판결시를 기준으로 판단하여야 한다.
④ 공공복리를 위한 사정판결의 필요성은 변론종결시를 기준으로 판단하여야 한다.

① [○] 사정판결은 처분 등이 위법함에도 불구하고 예외적으로 기각판결을 내리는 것이다.

② [○] 원고의 청구가 이유 있다고 인정하는 경우에도 처분 등을 취소하는 것이 현저히 공공복리에 적합하지 아니하다고 인정하는 때에는 법원은 원고의 청구를 기각할 수 있다. 이 경우 법원은 그 판결의 주문에서 그 처분 등이 위법함을 명시하여야 한다(행정소송법 제28조 제1항).

③ [×] 사정판결의 경우 처분 등의 위법성은 처분시를 기준으로 판단하여야 한다.

④ [○] 사정판결은 처분 이후의 사정변경을 고려하는 취지에서 인정되는 것이므로 사정판결의 필요성 판단의 기준시점은 변론종결시(판결시)이다(대판 1970.3.24, 69누29).

답 : 3

3. 다음 설명에 해당하는 취소소송의 판결의 효력을 바르게 묶은 것은? 2013 국가직 7급

> A : 과세처분을 취소하는 판결이 확정되면 그 과세처분은 처분시에 소급하여 소멸하는 것이므로 과세처분을 취소하는 판결이 확정된 뒤에는 그 과세처분을 경정하는 이른바 경정처분을 할 수 없다.
>
> B : 처분을 취소하는 판결이 확정되면 당사자인 행정청과 그 밖의 관계행정청은 동일한 사실관계에 대하여 동일한 사유로 취소된 처분과 동일한 처분을 할 수 없다.

	A	B
①	자박력	기판력
②	형성력	기속력
③	불가쟁력	집행력
④	형성력	자박력

A는 취소확정판결의 형성력으로 취소판결이 확정되면 당해 처분 등은 소급무효가 되는 효력을 말한다. B는 행정소송법 제30조 제1항에 의한 기속력 중 반복금지효를 말한다.

자박력은 판결을 선고한 법원이 판결을 취소 또는 변경할 수 없는 힘을 말한다.

기판력은 판결이 확정된 때에는 후에 동일한 사건이 소송상 문제가 되었을 때, 소송당사자는 이에 저촉되는 주장을 할 수 없고 법원도 이에 저촉되는 판단을 하지 못하게 하는 효력을 말한다.

불가쟁력이란 판결이 아닌 행정행위의 효력으로 행정행위의 상대방이나 이해관계인에 대하여 행정행위의 효력을 일정한 쟁송제기기간 내에서만 또는 일정한 쟁송수단의 사용 등에 의해서만 다툴 수 있게 하고, 이러한 시간의 경과나 쟁송수단이 모두 사용된 경우에는 통상의 쟁송절차에 의해서는 더 이상 다투지 못하게 하여 행정행위를 형식적으로 확정하는 효력을 말한다.

집행력이란 보통 이행판결의 내용인 이행의무를 강제집행에 의하여 실시할 수 있는 효력으로 항고소송에서는 거부처분취소확정판결의 기속력으로 재처분의무를 불이행시 간접강제를 할 수 있는 효력(행정소송법 제34조)를 말한다.

답 ②

♣ 학습내용 정리

1. 기본적 사실관계 동일성 있는 사유에 대해서만 처분사유 추가변경이 허용된다는 것이 판례이다.

2. 사정판결은 취소소송에서만 인정된다는 것이 판례입장이다.
3. 기판력은 인용판결 뿐만 아니라 기각판결에도 인정된다.

제39강 판결의 효력 I

♣ 학습목표

취소판결의 형성력과 제3자효 및 기속력에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

형성력 및 제3자효

기속력

♣ 사전테스트

1. 취소판결의 효력은 원피고에만 미친다.
   정답 : X

2. 기속력은 기각판결에도 인정된다.
   정답 : x

3. 반복금지효는 모든 취소판결에 인정된다.
   정답 : O

♣ 돌발퀴즈

기속력의 내용으로 재처분의무는 모든 취소판결에 인정된다.

[정답] ×

[해설] 행정소송법 제30조 제2항, 제3항 참조. 거부처분취소판결과 신청에 의한 처분이 절차상 하자로 취소된 경우에만 재처분의무가 인정된다.

♣ 강의내용

제1 형성력

⑴ 형성력의 의의

판결의 형성력이란 판결의 취지에 따라 법률관계의 발생·변경·소멸을 가져오는 효력을 말한다.

행정처분의 취소판결이 있게 되면, 처분청의 별도의 행위를 기다릴 것 없이 처분의 효력은 소급하여 소멸하여 처분이 없었던 것과 같은 상태로 된다. 예컨대, 파면처분을 받은 공무원은 그 취소판결이 있으면 소급하여 공무원의 신분을 회복하게 되는 것이다.

⑵ 형성력의 법적 근거

행정소송법은 이에 관한 직접적인 규정을 두지 않고 동법 제29조 제1항의 취소판결의 제3자효 규정만을 두고 있다. 그러나 하자 있는 처분에 의하여 국민의 권리 이익이 침해된 상태로 있는 것은 법치주의원리에 비추어 볼 때 용인될 수 없는 것이므로, 처분 등의 효력에 대한 구제수단을 마련하고 있는 행정소송법의 제도적 목적으로부터 당연히 도출되는 것으로 보고 있다.

⑶ 형성력의 내용 - 소급무효

취소판결은 형성력을 갖기 때문에, 예컨대 과세부과처분을 취소하는 판결이 확정되면 그 과세처분은 소급하여 소멸되므로 취소판결이 확정된 이후에 그 과세처분에 대한 경정처분을 하면 이는 당연무효이다(대판 1989. 5. 9, 88다카16096).

또, 영업허가취소처분에 대한 취소판결이 확정되면 영업허가취소처분을 받은 이후의 영업행위는 무허가영업이 되지 않아 식품위생법상 형벌규정을 적용할 수 없게 된다(대판 1993. 6. 25, 93도277).

⑷ 취소판결의 제3자효

1) 인정의 이유와 근거

행정소송법은 “처분 등을 취소하는 확정판결은 제3자에 대하여도 효력이 있다”라고 하여 처분취소판결의 제3자에 대한 구속력을 명문으로 인정하였다. 이는 취소확정판결의 실효성을 확보하기 위해 인정된다.

2) 제3자 보호 - 제3자의 소송참가(동법 제16조) 및 제3자의 재심청구(동법 제31조)

3) 제3자효에 대한 문제점

취소판결의 제3자효에 대하여 일단 긍정적인 평가를 내린다 하더라도 제3자의 범위가 명확하지 않다는 점을 지적할 수 있다. 예컨대, 직접 원고나 피고는 아니지만 어떠한 형태로든 소송에 참가한 소송참가인으로서의 제3자만을 의미하는 것인가 아니면 아무런 제한 없는 일반인을 의미하는 것인가 하는 점 등이 명확하지 않는 상태이다.

이에 대해 취소판결의 효력이 미침으로써 불리한 제3자는 행정소송법 제16조, 제31조의 취지에 비추어 동법 제29조의 제3자 범위에 포함된다는 점에 있어서는 학설과 판례가 일치하고 있다.

그러나 일반처분이나 처분법규에 대한 취소판결의 경우 일반인들도 이러한 판결의 효력을 원용하고 향수할 수 있는가가 문제된다. 이와 관련하여 ① 법률관계의 획일적 규율의 요청과 실질

적으로 불합리한 결과를 차단해야 한다는 요청 등에 비추어 취소판결에 절대적 대세효를 인정하여 제3자도 그 효과를 적극적으로 향수할 수 있어야 한다는 입장과, ② 취소소송은 주관적 소송이므로 그 효력은 원칙적으로 당사자에게만 미치고 명문규정이 없는데도 제3자가 판결의 효력을 원용할 수 없다는 입장 및 ③ '당해 판결에 의하여 권리 또는 이익이 영향을 받게 되는 이해관계인'에 한정시키려는 입장 및 ④ 불가쟁력이 발생한 일반처분의 경우 취소확정판결의 장래효는 절대적 대세효를 인정할 수 있으나 법적안정성을 위해 소급효는 인정할 수 없고, 불가쟁력이 발생하지 않은 일반처분의 취소확정판결은 장래효와 소급효 모두 절대적 대세효가 인정된다는 견해[78]등이 대립한다.

4) 제3자효의 준용

행정소송법은 취소판결의 제3자효규정을 무효등확인소송과 부작위위법확인소송은 물론 가구제에서도 준용하고 있다(동법 제29조 제2항, 동법 제38조).

제2 기속력(구속력)

⑴ 서

판결의 기속력이란 처분이나 재결을 취소하는 확정판결이 그 내용에 따라 처분청과 관계행정청에게 판결의 취지에 따라 행동할 의무를 지우는 효력을 말한다(동법 제30조 제1항).

⑵ 성 질

1) 학 설

기판력의 결과로 보는 기판력설과 취소판결의 실효성을 담보하기 위해 행정소송법이 부여한 특수한 효력이라는 특수효력설(통설)이 대립한다.

2) 판 례 - 불분명

3) 검 토

① 기판력은 소송 상호간에 미치는 소송법상의 효력이다. 이에 비해 기속력은 처분청과 관계행정청을 구속하는 힘을 의미하는 실체법상의 효력이라는 점, ② 기판력은 소송당사자인 원·피고와 후소법원을 구속하는 효력임에 비해 기속력은 피고인 처분청과 관계행정청만 구속하는 효력이라는 점, ③ 기판력은 기각확정판결에도 발생하나 기속력은 취소확정판결에만 발생하는 효력이라는 점 등을 고려할 때 특수효력설이 타당하다.

⑶ 기속력의 내용

1) 반복금지효

① 의의

취소판결이 확정되면, 행정청은 동일한 사실관계하에서 동일이유로 동일인에 대해 동일한 내용의 처분을 해서는 안된다. 이러한 효력을 반복금지효라 한다.

78) 박균성, 행정법강의 제4판, 제261면.

② 반복금지효에 위반된 행정처분의 효과 - 무효

③ 반복금지효에 반하지 않는 경우

- 처분사유가 다른 경우

취소판결을 받은 처분과 동일한 내용의 처분이라 하더라도 기본적 사실관계 동일성 없는 새로운 사실관계 또는 새로운 법령에 따른 처분이나 처분시 이후에 발생한 사유에 따른 처분은 처분사유가 다른 별개의 처분이므로 기속력에 반하지 않는다.

- 위법사유를 시정한 경우

취소판결에서 위법이라고 판시한 위법사유를 시정한 처분은 새로운 처분이어서 기속력에 반하지 않는다. 따라서 과세가액의 평가방법이 잘못되어 적법한 평가방법으로 새로운 과세처분을 한 경우, 절차하자를 시정하고 새로운 처분을 한 경우에는 기속력에 반하지 않는다는 것이 판례의 태도이다.

과세의 절차 내지 형식에 위법이 있어 과세처분을 취소하는 판결이 확정되었을 때는 그 확정판결의 기판력은 거기에 적시된 절차내지 형식의 위법사유에 한하여 미치는 것이므로 과세관청은 그 위법사유를 보완하여 다시 새로운 과세처분을 할 수 있고 그 새로운 과세처분은 확정판결에 의하여 취소된 종전의 과세처분과는 별개의 처분이라 할 것이어서 확정판결의 기판력에 저촉되는 것이 아니다(대판 1987. 2. 10, 86누91).

2) 거부처분취소확정판결의 재처분의무

① 의의

행정소송법 제30조 제2항에 의해 신청을 요하는 처분에 대한 행정청의 거부처분이 판결에 의해 취소된 경우, 행정청이 판결의 취지에 따라 처분해야 할 의무를 말한다. 구체적으로 보면 ① 재처분을 해야 할 의무와 ② 재처분시 판결의 취지에 따라야 할 의무 양자를 포함하는 개념이다. 특히 판결의 취지에 따라야 할 의무의 내용은, 기속행위나 재량이 0으로 수축된 경우에는 행정청이 당사자의 신청에 따라 처분을 해야할 의무가 되고 재량행위인 경우에는 하자없는 재량행사를 해야할 의무가 되고 주체, 절차, 형식상 하자로 취소된 경우에는 그러한 위법사유를 시정하여 가부간의 처분을 하여야 할 의무를 의미한다.

② 재처분의무에 반하지 않는 경우

- 처분사유가 다른 경우

거부처분에 대한 취소판결이 확정되었다 하더라도, 거부처분시 이후 발생한 새로운 사실관계 또는 새로운 법령을 이유로 내린 거부처분 또는 처분시 사유라도 기본적 사실관계 동일성 없는 새로운 사유로 내린 거부처분은 처분사유가 다른 것이어서 기속력에 반하지 않는다.

거부처분 취소의 확정판결을 받은 행정청이 거부처분 후에 법령이 개정·시행된 경우, 새로운 사유로 내세워 다시 거부처분을 한 경우도 행정소송법 제30조 제2항 소정의 재처분에 해당한다는 판례(대판 1998.1.7, 97두22)

거부처분 취소의 확정판결을 받은 행정청이 사실심 변론종결 이후 발생한 새로운 사유를 내세워 다시 거부처분을 한 경우도 행정소송법 제30조 제2항에 규정된 재처분에 해당한다는 판례(대판 2011.10.27, 2011두14401)

주택건설사업 승인신청 거부처분의 취소를 명하는 판결이 확정되었음에도 행정청이 그에 따른 재처분을 하지 않은 채 위 취소소송 계속중에 도시계획법령이 개정되었다는 이유를 들어 다시 거부처분을 한 사안에서, 새로운 거부처분이 확정된 종전 거부처분 취소판결의 기속력에 저촉되어 당연무효라고 한 사례

주택건설사업 승인신청 거부처분의 취소를 명하는 판결이 확정되었음에도 행정청이 그에 따른 재처분을 하지 않은 채 위 취소소송 계속중에 도시계획법령이 개정되었다는 이유를 들어 다시 거부처분을 한 사안에서, 개정된 도시계획법령에 그 시행 당시 이미 개발행위허가를 신청중인 경우에는 종전 규정에 따른다는 경과규정을 두고 있으므로 위 사업승인신청에 대하여는 종전 규정에 따른 재처분을 하여야 함에도 불구하고 개정 법령을 적용하여 새로운 거부처분을 한 것은 확정된 종전 거부처분 취소판결의 기속력에 저촉되어 당연무효이다.(대결 2002.12.11, 2002무22)

- 위법사유를 시정한 경우

거부처분이 주체, 내용, 형식, 절차상의 하자로 취소판결이 난 후 행정청이 어떠한 위법사유를 보완하여 내린 동일한 거부처분은 기속력에 반하지 않고 적법한 거부처분이 된다. 예컨대 청문이나 공청회를 거치지 않았다든지 또는 이유부기의 흠결을 이유로 거부처분에 대한 취소판결이 난 경우에는, 행정청은 적법한 청문, 공청회를 거치거나 이유부기를 한 후 동일한 거부처분을 할 수 있고 있는 적법한 처분이다.

3) 제3자효적 행정행위에서 절차상 하자로 취소된 경우 재처분의무(동법 제30조 제3항)

제3자효적 행정행위에 있어서 침익적 효과를 받는 제3자가 제기한 소송에서 처분이 절차적 위법을 이유로 취소되는 경우, 취소된 처분의 직접 상대방은 절차적 위법이 없는 새로운 처분을 받을 수 있는 이익이 있다. 행정소송법 제30조 제3항은 이러한 권익을 보장하기 위한 규정이다. 이 규정에 따라 행정청은 적법한 절차를 거쳐 다시 원래 처분의 상대방에게 새로운 처분을 하여야 한다. 이때 새로운 처분은 절차의 위법을 제거하기만 하면 신청에 따른 처분일 수도 있고, 거부처분일 수도 있다.

4) 결과제거의무

⑷ 기속력의 인정범위

1) 주관적 범위

행정소송법 제30조 제1항. 당사자인 행정청과 그 밖의 관계행정청을 기속한다.

2) 객관적 범위

① 서

기속력은 판결주문 및 그 전제가 된 처분의 구체적인 위법사유에 관한 이유중의 판단에 대하여 인정되며 판결의 결론과 직접 관계없는 방론이나 간접사실에 미치지 않는다는 것이 통설과 판례이다.

이와 같이 기속력은 취소판결에서 판단된 '처분'의 '위법사유'에 대하여만 미치는 것이므로

(가) 취소판결에서 판단한 처분의 위법사유를 시정한 경우나,

(나) 취소판결에서 판단한 처분과 동일성이 없는 새로운 처분을 한 경우에는,

기속력에 반하지 않는다.

그런데 위법사유를 시정한 경우는 쉽게 구별할 수 있으나(예컨대 이유부기의 하자로 취소판결 내려진 후 이유부기를 제대로 하여 동일한 처분을 한 경우),

취소판결에서 판단한 '처분'과 동일성을 판단하기가 쉽지 않다.

② 처분의 동일성을 판단하는 기준

통설과 판례는 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계가 동일하다고 인정되는 한도내에서만 다른 처분사유를 새로 추가하거나 변경할 수 있다고 하여 '기본적 사실관계의 동일성'을 처분의 동일성 판단기준으로 내세우고 있다.

따라서 통설과 판례에 의하면 기본적 사실관계 동일성 있는 사유로 동일인에게 동일한 처분을 하는 것은 기속력에 반하게 되나, 기본적 사실관계 동일성 없는 사유로 동일인에게 동일한 처분을 하는 것은 기속력에 반하지 않는다.

이에 대해 일부견해는 규율내용의 동일성에 따라 처분의 동일성을 판단하여 거부처분에 있어서는 모든 거부사유를 동일사유로 보아야 한다고 주장한다.

시가화예정지역이라는 사유로 주택건설사업계획승인신청을 거부처분하였으나 취소확정판결을 내려진 후 해당 토지가 개발행위허가제한지역으로 지정되었다는 사유로 다시 거부한 경우 당해 거부처분은 한 경우 기본적 사실관계 동일성 없는 새로운 사유에 의한 것인 바 기속력에 반하지 않는다는 판례(대법원 2011.10.27. 선고 2011두14401).

종전 확정판결의 행정소송 과정에서 한 주장 중 처분사유가 되지 아니하여 판결의 판단대상에서 제외된 부분을 행정청이 그 후 새로이 행한 처분의 적법성과 관련하여 새로운 소송에서 다시 주장하는 것이 위 확정판결의 기판력에 저촉되지 않는다는 판례

징계처분의 취소를 구하는 소에서 징계사유가 될 수 없다고 판결한 사유와 동일한 사유를 내세워 다시 징계처분하는 것은 기판력에 저촉되어 허용할 수 없다는 판례(대판 1992.7.14, 92누2912)

3) 시적 범위

기속력의 시적범위는 항고소송의 위법판단기준시와 밀접한 관련이 있다. 취소소송의 위법판단기준시에 대하여 학설은 ① 판결시설, ② 처분시설, ③ 거부처분 및 계속적 효과를 갖는 처분에 한해서 판결시로 보자는 절충설, ④ 원칙적으로 처분시로 보되 거부처분취소소송에서는 인용판결의 기준시는 판결시로 보자는 견해 등이 대립한다.

생각건대, ① 소송물 특정 및 ② 행정청의 제1차적 판단권 존중에 비추어 통설·판례인 처분시설이 타당하다.

처분시설에 따르면 기속력은 처분시에 존재했던 사유에 대해서만 미치고 처분시 이후에 발생한 사유에는 미치지 않는다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 甲은 여관을 건축하기 위하여 관할 군수 乙에게 건축허가신청을 하였으나 乙은 관계법령에 근거가 없다는 사유를 들어 거부처분을 하였다. 이에 甲은 乙을 상대로 거부처분취소소송을 제기하여 승소하였고 이 판결은 확정되었다. 그런데도 乙은 위 판결의 취지에 따른 처분을 하지 아니하였다. 이와 관련된 다음의 서술 중 옳지 않은 것은? (제45회 사법시험 2차문제 변형)

① 사안은 기속력에 관한 문제이다.

② 乙이 위 판결에 따른 처분을 하지 않고 있는 동안 甲이 강구할 수 있는 구제방법으로 손해배상을 청구할 수 있는데 이에 대해서 명문의 규정이 없다.

③ 만약 위 승소 판결이 확정된 후 관계법령이 개정되어서 건축허가를 거부할 수 있는 근거가 마련되었다면 乙이 이에 근거하여 다시 거부처분을 하더라도 그 거부처분은 적법하다.

④ ③설문에서 근거 법령에서 경과규정을 두어 종전의 규정에 의한다고 하는 경우에는 처분청은 법령의 변경이라는 새로운 처분사유를 내세워 거부처분을 할 수 없으므로 乙의 새로운 거부처분은 기속력에 반하게 된다.

⑤ 기속력에 반한 처분의 효력은 판례에 의할 경우 당연무효에 해당된다.

해설 & 정답

유형 사례형

① 행정소송법 제30조

② 행정소송법 제34조에서 기속력의 실효성을 담보하기 위하여 "행정청이 기속력에 따른 재처분의 무를 다하지 아니하는 때에는 제1심 수소법원은 당사자의 신청에 의하여 결정으로써 상당한 기간을 정하고 행정청이 그 기간 내에 이행하지 아니하는 때에는 그 지연기간에 따라 일정한 배상을 할 것을 명하거나 즉시 손해배상을 할 것을 명할 수 있다"라고 하여 간접강제에 대한 규정을 두고 있다. 따라서 甲은 1심 수소법원에 乙에 대한 손해배상을 청구할 수 있다.

③ 거부처분의 취소판결이 확정된 이 후 처분청은 사실심 변론종결 시점 이후의 새로운 법령의 법경 등에 따라 새로운 처분사유를 들어 다시 거부처분을 한다 하여도 이는 기속력에 반하지 않는다고 보는 것이 판례와 학설의 일반적인 태도이다.

⑤ 확정판결의 당사자인 처분행정청이 그 행정소송의 사실심 변론 종결 이전의 사유를 내세워 다시 확정판결과 저촉되는 행정처분을 하는 것은 허용되지 않는 것으로서 이러한 행정처분은 그 하자가 중대하고도 명백한 것이어서 당연무효라 할 것이다(대판 1990.12.11, 90누3560).

정답 ②

2. 甲・乙 양 방송 회사는 텔레비전 채널 방송허가를 받기 위해 신청을 하였던 바, 면허권자인 정보통신부장관 A는 甲・乙의 신청 내용을 비교 검토한 후에 甲측이 우세하다고 인정하여 甲의 신청을 면허하고 乙의 신청에 대하여는 불허처분을 하였다. 그러나 후에 A는 甲의 내용에는 사실과 다른 점이 있다는 사실을 발견하였다. 이에 대해서 乙이 허가 처분에 대해서 취소소송을 제기하였다. 아래의 서술 중 옳지 않은 것은? (1984년 일본 사법시험 2차문제 변형)

① 乙이 甲에 대한 A의 허가처분에 대한 취소소송을 제기하여 원고 乙이 승소판결을 받은 경우 이 취소판결의 효력이 甲에게 미치는지 여부가 문제되는데 이는 취소판결의 형성력의 문제와 관련이 있다.

② 형성력에 대해서는 명문의 규정이 없는데 행정소송법 제29조 제1항의 취소판결의 제3자효는 이를 전제로 한 규정이다.

③ 경원관계에 있는 甲은 취소소송의 원고인 乙과 대립되는 이해관계를 갖는 제3자로서 판결의 효력이 미치는 제3자에 포함된다.

④ 취소소송의 효력이 미치는 제3자의 손해를 방지하고, 권익을 보호하기 위해서 소송 계속 중, 판결확정 된 후의 구제수단에 대해서 행정소송법은 그 구제수단을 가지고 있지 않기 때문에 대세적 효력설이 그 힘을 얻고 있다.

⑤ 무효등확인소송과 부작위위법확인소송은 물론 가구제에도 제3자효가 인정된다.

해설 & 정답

유형 사례형

①② 판결의 형성력이란 판결의 취지에 따라 법률관계의 발생・변경・소멸을 가져오는 효력을 말하는데 행정소송법에는 이에 대한 직접적인 명문규정은 없는데 형성력은 특히 취소인용판결의 경우에 일반적으로 인정되는 효력이고 또한 취소판결의 제3자효를 규정한 제29조 제1항은 이를 전제로 한 규정이다.

③ 취소소송의 원고와 대립된 법적 지위에 있는 자는 제3자효의 범위에 포함된다. 그런데 공유의 이익을 가지는 자(예를 들면 부당한 공과금 인상 처분에 대한 취소소송에서 원고가 아니지만 그와 동일한 처분의 대상이 된 제3자들)에 대해서는 효력이 미치는지 여부에 대한 견해대립이 존재하는 데 절대적 대세효설이 다수의 견해이다.

④ 취소판결의 효력이 미치게 되는 제3자의 불측의 손해를 막기 위해 행정소송법은 소송에 관여하지 않은 제3자의 소송참가(제16조)를 인정하고 있고 또한 제3자가 귀책사유 없이 소송에 참가하지 못한 경우를 대비해 행정소송법은 아울러 취소의 인용판결이 확정된 뒤에도 제3자가 자

신의 권익침해를 주장할 수 있도록 제3자의 재심청구제도(제31조)를 마련하고 있다. 절대적 대세효는 취소판결의 실효성을 확보하고 소송당사자와 제3자와의 관계에서 취소판결이 달라지는 것을 막고 그 법률관계나 권리관계 등을 통일적으로 확보하기 위해 인정된 것이다.

⑤ 행정소송법은 취소판결의 제3자효 규정을 무효등확인소송과 부작위위법확인소송은 물론 가구제에도 준용하고 있다(제29조 제2항, 제38조)

정답 ④

3. 취소소송에 관한 설명 줄 옳은 것은? (2001 행정고시)

① 취소소송에서는 직접적으로 공공의 이익과 관련하여 객관적으로 적법하고 공정한 결과가 요구되기 때문에 민사소송상의 원칙인 변론주의가 배제되고 직권탐지주의가 채용되고 있다.

② 행정처분은 적법성이 추정되므로 취소소송에서의 입증책임은 원고에게 있다.

③ 취소소송에서는 법원이 필요하다고 인정한 때에는 당사자의 신청 없이도 관계행정청을 소송에 참가시킬 수 있다.

④ 취소판결이 확정되더라도 처분의 효력을 소멸시키기 위하여는 처분청 등에 의한 취소처분이 필요하다.

⑤ 처분의 취소판결이 확정된 후에는 처분청은 별도의 처분이유가 있는 경우라 하더라도 동일인에 대하여 동일내용의 처분을 할 수 없다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 취소소송도 변론주의를 원칙으로 한다. 예외적으로 직권심리주의에 의한다(행정소송법 제26조).

② 처분의 적법성 추정은 인정되지 않고 잠정적 통용력만 인정되기 때문에 공정력과 입증책임은 무관하므로 법률요건분류설에 의한다는 견해가 다수설・판례이다.

③ 행정소송법 제17조 제1항

④ 취소판결은 형성판결이므로 판결의 일방적 의사표시로 즉시 처분의 효력이 소멸하고 행정청의 별도의 취소처분이 필요하지 않다는 점에서 이행판결과 다르다.

⑤ 동일인에 대해 동일한 사유로 동일한 처분을 하는 것만 기속력의 반복금지효에 위반되고, 동일인에 대해 다른 사유로 동일한 처분을 하는 것은 기속력 위반이 아니다.

정답 ③

♣ 학습내용 정리

1. 취소판결이 확정되면 당해 처분이 소급무효가 되는 효력을 형성력이라 한다.
2. 취소판결이 확정되면 원피고가 아닌 제3자에게도 효력이 미친다.
3. 기속력은 취소판결의 취지에 따라 행정청 및 관계 행정청이 행동해야 할 효력이다.

제40강 판결의 효력 II

♣ 학습목표

거부처분 취소판결의 기속력인 재처분의무위반시 강제수단인 간접강제와 무효등확인소송에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

간접강제
무효등 확인소송
부작위의 개념

♣ 사전테스트

1. 간접강제는 무효확인소송에서도 준용된다.
정답 : X

2. 무효확인소송에서 보충성이 요구된다.
정답 : x

3. 무효확인소송에서 취소판결의 제3자효가 준용된다.
정답 : O

♣ 돌발퀴즈

판례에 의하면 행정처분에 대한 무효확인과 취소청구는 서로 양립할 수 없는 청구로서 주위적·예비적 청구로서만 병합이 가능하다.

[정답] ○

[해설] 행정처분에 대한 무효확인과 취소청구는 서로 양립할 수 없는 청구로서 주위적·예비적 청구로서만 병합이 가능하고 선택적 청구로서의 병합이나 단순 병합은 허용되지 아니한다(대판 1999.8.20, 97누6889)..

♣ 강의내용

제1 집행력(간접강제)

⑴ 개 설

현행 행정소송법은 항고소송으로 적극적 처분을 구하는 소를 허용하지 않고 대신 거부처분취소소송과 부작위위법확인소송을 인정하고 있는바, 거부처분취소판결과 부작위위법확인판결이 있을 경우 그 기속력에 의하여 처분청은 판결의 취지에 따른 처분을 할 의무가 있다(재처분의무). 그런데 처분청이 재처분의무를 이행치 않을 때 이를 강제로 집행할 수 있는 제도가 필요하다. 이에 행정소송법 제34조는 거부처분취소확정판결에 따른 재처분의무의 실효성확보를 위해 간접강제제도를 도입한 것이다.

⑵ 적용범위 - 무효확인소송에는 준용규정없음

학설은 ① 무효확인소송에는 행정소송법 제34조를 준용하고 있지 않으므로 간접강제를 할 수 없다는 부정설과, ② 행정소송법 제34조가 '거부처분취소판결이 있는 경우'라고 규정하지 않고 '제30조 제2항의 처분을 하지 않은 때'라고 규정하고 있음으로 무효확인소송에도 간접강제를 인정할 수 있다는 긍정설이 대립한다.

판례는 행정소송법이 거부처분 무효확인의 소에 대하여는 동법 제34조 제1항을 준용하는 규정을 두고 있지 않음(동법 제38조 제1항)을 이유로 거부처분무효확인판결에 관하여는 간접강제가 허용되지 않는다고 한다.

⑶ 요건

1) 거부처분취소 등의 판결이 확정될 것

간접강제를 하기 위하여는 거부처분취소판결, 부작위위법확인판결이 확정되어야 한다.

2) 상당한 기간 내 판결의 취지에 따른 처분이 없을 것

이에는 거부처분취소판결후 행정청이 다시 거부처분하였는데 그러한 거부처분이 기속력에 반하여 무효가 된 경우도 포함된다.

거부처분에 대한 취소의 확정판결이 있음에도 행정청이 아무런 재처분을 하지 아니하거나, 재처분을 하였다 하더라도 그것이 종전 거부처분에 대한 취소의 확정판결의 기속력에 반하는 등으로 당연무효라면 이는 아무런 재처분을 하지 아니한 때와 마찬가지라 할 것이므로 이러한 경우에는 행정소송법 제30조 제2항, 제34조 제1항 등에 의한 간접강제신청에 필요한 요건을 갖춘 것으로 보아야 한다는 판례.(대법원 2002. 12. 11. 자 2002무22 결정)

⑷ 절차

1) 신청 - 원고가 피고 행정청을 피신청인으로 하여 서면신청

2) 관할법원 - 제1심 수소법원의 전속관할(행정소송법 제34조 제1항).

⑸ 결정

당사자의 신청이 이유 있다고 인정되면 법원은 결정으로써 상당한 기간을 정하고 행정청이 그 기간 내에 이행하지 아니하는 때에는 그 지연기간에 따라 일정한 배상을 할 것을 명하거나

즉시 손해배상을 할 것을 명할 수 있다(행정소송법 제34조 제1항). 이를 간접강제결정이라고 한다.

⑹ 배상금의 추심

간접강제결정이 있은 후에 의무행정청이 그 결정에 정한 상당한 기간 내에 확정된 판결의 취지에 따른 처분을 하지 않는 경우에는 신청인은 그 결정을 채무명의로 하여 집행문을 부여를 받아 집행할 수 있다. 이 때 위 결정은 피신청인 또는 참가인이었던 행정청이 소속하는 국가 또는 공공단체에 그 효력이 미치므로 이들 소유의 재산에 대하여도 집행할 수 있다(행정소송법 제34조 제2항, 동법 제33조).

간접강제에서 정한 이행기한이 경과한 후에라도 확정판결의 취지에 따라 재처분을 하면 배상금추심을 할 수 없다는 판례(대판 2010.12.23, 2009다37725)

⑺ 불복절차

간접강제결정의 기각결정이나 인용결정에는 민사소송법에 따른 즉시항고를 할 수 있다.

제2 무효등확인소송

Ⅰ. 개 설

1. 무효등확인소송의 의의

무효등확인소송이란 행정청의 처분이나 재결의 효력유무 또는 존재여부의 확인을 구하는 소송을 말한다(행정소송법 제4조 제2호). 이에는 처분이나 재결의 무효확인소송, 유효확인소송, 존재확인소송, 부존재확인소송, 실효확인소송 등이 포함되나 이 중 실무상 가장 많이 제기되는 소송은 무효확인소송이다.

2. 법적 성질 - 항고소송과 확인소송
처분 등에 대해서 다투는 소송이기 때문에 항고소송의 성질

Ⅱ. 관할법원 - 취소소송과 동일
원칙적으로 행정법원이 관할 하고 있다

Ⅲ. 당사자 등

1. 원고적격

무효확인소송은 처분 등의 효력유무 또는 존재여부의 확인을 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다(행정소송법 제35조). 무효등확인소송의 '법률상 이익'이 있는 자의 의미는 취소소송의 경우와 같다.

2. 협의의 소익

⑴ 서

무효확인소송에 있어서도 취소소송에서 요구되는 소의 이익이 그대로 타당하다. 따라서 철거명령무효확인소송 도중 건물이 철거된 경우에는 소의 이익흠결로 각하된다.

⑵ 확인의 이익과 확인소송의 보충성

1) 문제점

항고소송으로서 무효확인소송에서 확인소송의 보충성이 소송요건으로 요구되는지 문제된다.

2) 학설

① 긍정설

종전 판례와 일부견해는 처분의 무효를 주장하는 방법으로서 더욱 실효적인 구제수단인 민사소송 또는 공법상 당사자소송에 의하여 구제가 안되는 경우에만 보충적으로 무효확인소송 제기가 가능하다고 본다. 즉 보충성이 요구된다고 한다.

② 부정설

부정설은 다음과 같은 논거에 의해 항고소송으로서의 무효확인소송에서는 보충성이 소송요건으로 요구되지 않는다고 보고 있다.

ⅰ. 현행 행정소송법이 무효확인소송을 항고소송의 일종으로 규정하는 점을 보아도 무효확인소송은 본질에 있어서 행정소송의 처분을 다투는 항고소송인 것이고 단지 다투는 형식이 확인소송의 형식을 취하고 있을 뿐이다.

ⅱ. 행정소송법 제38조는 취소판결의 기속력을 무효확인소송에서도 준용하고 있는 바, 무효확인판결 자체만으로 판결의 기속력에 의해 판결의 실효성을 확보할 수 있으므로 민사소송에서와 같은 분쟁의 궁극적 해결을 위한 확인의 이익(보충성)을 소송요건으로 요구할 필요가 없다.

3) 판례

종전 판례는 ① 당연무효인 과세처분에 따라 이미 세금을 납부한 경우, ② 공무원에 대한 면직처분이 무효인데 소송도중 정년이 도래한 경우에는 각 처분에 대한 무효확인소송에 대하여 보충성흠결로 각하하여 긍정설의 입장을 취하였으나,

대법원 전원합의체판결은 하수도원인자부담금부과처분무효확인소송사건에서 위 부담금부과처분이 무효여서 이미 납부한 금원을 부당이득반환청구소송을 통해 돌려받을 수 있다 하더라도 당해 부과처분무효확인소송은 적법한 소제기로 보아 항고소송으로서의 무효확인소송에서 보충성은 소송요건이 아니라는 부정설의 입장으로 변경하였다(대판 2008. 3. 20, 2007두6342).

3. 피고적격 : 취소소송과 동일

외부 명의자가 피고적격자가 된다

4. 기타 관계규정

Ⅳ. 소의 제기

1. 준용되지 않는 규정

취소소송에 관한 행정심판전치주의에 관한 규정(행정소송법 제18조), 제소기간에 관한 규정(동법 제20조)은 무효등확인소송에 적용되지 않는다.

2. 가구제

⑴ 집행정지

행정소송법 제38조 제1항에 의해 준용되고 있다.

⑵ 가처분 - 전술 참조
항고소송으로서 처분,

Ⅴ. 심 리

1. 직권심리주의(행정소송법 제26조, 동법 제38조 제1항)
우리나라의 판례는 변론주의가 원칙

2. 입증책임 - 전술 참조
당해 처분이 무효인지에 대해서 법률적 판단 문제

3. 선결문제[79]
권한 없는 법원도 당해 처분의 효력을 부인해서 판결을 내릴수 있다.

Ⅵ. 판 결

1. 판결의 효력
무효확인소송의 판결에 대해서는 행정소송법 제38조에 의해 취소소송에 관한 규정이 원칙적으로 준용된다. 따라서 판결의 효력으로서 제3자효(동법 제29조 제1항)와 기속력(동법 제30조)이 인정된다.

2. 사정판결 - 전술 참조

제3 부작위위법확인소송

Ⅰ. 개 설

1. 의 의
부작위위법확인소송이란 행정청의 부작위가 위법임을 확인하는 소송유형을 말한다(행정소송법 제4조 제3호). 이때의 부작위에 대하여 행정소송법 제2조 제1항 제2호는 “행정청이 당사자의 신청에 대하여 상당한 기간내에 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 것”이라고 규정하였다.

2. 제도적 취지
의무이행소송에 비해, 국민의 권리구제수단으로 미흡.

3. 법적 성질 - 확인소송 / 항고소송

Ⅱ. 부작위위법확인소송의 대상

79) 자세한 내용은 전술한 구성요건적 효력 참조.

1. 당사자의 신청

특히 이와 관련하여 신청인에게 법규상 또는 조리상 신청권이 있어야 하는지에 대해서 견해의 대립이 있다.

⑴ 학설

① 신청권은 일반적 추상적 응답신청권이라는 점, '일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무'는 신청권에 대응하는 응답의무라는 점을 근거로 신청권이 대상적격에서 요구된다는 견해, ② 행정소송법상 부작위의 개념에 신청권이 규정되지 않았고 신청권은 공권인 바 원고적격에서 판단하여야 한다는 견해, ③ 원고의 신청과 처분의 부작위만으로 대상적격은 충족되고 신청권과 처분의무는 본안판단에서 검토해야 한다는 견해가 대립한다.

⑵ 판 례

판례는 일관되게 부작위위법확인소송의 대상이 되는 부작위가 되기 위해서는 법규상·조리상의 신청권이 존재해야 하고 단지 행정청의 직권발동을 촉구하는 데 불과한 신청에 대한 무응답은 이에 해당하지 않는다고 판시하고 있다(대판 1993. 4. 23, 92누17099).

법규상 또는 조리상 신청권이 없으면 부작위위법확인소송의 대상적격이나 원고적격을 충족하지 못하는 바 각하하여야 한다는 판례(대판 1993. 4. 23, 92누17099).

승진임용대상자로 결정하고 대외공표까지 한 경우 당해 공무원은 승진임용을 신청할 조리상 권리가 있다는 판례

지방공무원법 제8조, 제38조 제1항, 지방공무원임용령 제38조의3의 각 규정을 종합하면, 2급 내지 4급 공무원의 승진임용은 임용권자가 행정실적·능력·경력·전공분야·인품 및 적성 등을 고려하여 하되 인사위원회의 사전심의를 거치도록 하고 있는바, 4급 공무원이 당해 지방자치단체 인사위원회의 심의를 거쳐 3급 승진대상자로 결정되고 임용권자가 그 사실을 대내외에 공표까지 하였다면, 그 공무원은 승진임용에 관한 법률상 이익을 가진 자로서 임용권자에 대하여 3급 승진임용 신청을 할 조리상의 권리가 있다(대판 2008.04.10. 2007두18611)

⑶ 검 토

판례는 부작위의 대상적격에서 요구하는 신청권을 형식상의 단순한 응답요구권의 의미로 판시하고 있다. 이와같이 신청권을 형식적 의미로 이해한다면 판례와 ①설이 타당하다.

더욱이 행정소송법 제2조 제1항 제2호에서 부작위가 성립하기 위해선 '일정한 처분을 해야할 법률상 의무'가 요구되는 바, 이러한 법률상 의무를 응답의무로 볼 수밖에 없기 때문에 이에 대응하여 응답신청권을 요구하는 ①설과 판례는 현행법에 합치되는 해석일 것이다.

결국 ①설과 판례가 타당하다.

2. 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있을 것.

상대방의 적법한 신청이 있는 경우 행정청에는 그 신청의 내용에 상응하는 '일정한 처분'을 하여야 할 법률상 의무가 발생한다. 이러한 법률상의 의무는 기속행위인지 재량행위인지와 상관없이 응답을 하여야 할 의무가 법률상의 의무의 내용이 된다는 것이 통설과 판례의 입장이다.

이에 따라 처분이 아닌 행정작용을 신청하는 것에 대한 무응답은 부작위위법확인소송의 대상이 될 수 없다.

3. 상당한 기간

4. 처분의 부존재

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 甲은 여관을 건축하기 위하여 관할 군수 乙에게 건축허가신청을 하였으나 乙은 관계법령에 근거가 없다는 사유를 들어 거부처분을 하였다. 이에 甲은 乙을 상대로 거부처분취소소송을 제기하여 승소하였고 이 판결은 확정되었다. 그런데도 乙은 위 판결의 취지에 따른 처분을 하지 아니하였다. 이와 관련된 다음의 서술 중 옳지 않은 것은? (제45회 사법시험 2차문제 변형)

① 사안은 기속력에 관한 문제이다.

② 乙이 위 판결에 따른 처분을 하지 않고 있는 동안 甲이 강구할 수 있는 구제방법으로 손해배상을 청구할 수 있는데 이에 대해서 명문의 규정이 없다.

③ 만약 위 승소 판결이 확정된 후 관계법령이 개정되어서 건축허가를 거부할 수 있는 근거가 마련되었다면 乙이 이에 근거하여 다시 거부처분을 하더라도 그 거부처분은 적법하다.

④ ③설문에서 근거 법령에서 경과규정을 두어 종전의 규정에 의한다고 하는 경우에는 처분청은 법령의 변경이라는 새로운 처분사유를 내세워 거부처분을 할 수 없으므로 乙의 새로운 거부처분은 기속력에 반하게 된다.

⑤ 기속력에 반한 처분의 효력은 판례에 의할 경우 당연무효에 해당된다.

해설 & 정답

유형 사례형

① 행정소송법 제30조

② 행정소송법 제34조에서 기속력의 실효성을 담보하기 위하여 "행정청이 기속력에 따른 재처분의무를 다하지 아니하는 때에는 제1심 수소법원은 당사자의 신청에 의하여 결정으로써 상당한 기간을 정하고 행정청이 그 기간 내에 이행하지 아니하는 때에는 그 지연기간에 따라 일정한 배상을 할 것을 명하거나 즉시 손해배상을 할 것을 명할 수 있다"라고 하여 간접강제에 대한 규정을 두고 있다. 따라서 甲은 1심 수소법원에 乙에 대한 손해배상을 청구할 수 있다.

③ 거부처분의 취소판결이 확정된 이 후 처분청은 사실심 변론종결 시점 이후의 새로운 법령의 법경 등에 따라 새로운 처분사유를 들어 다시 거부처분을 한다 하여도 이는 기속력에 반하지 않는다고 보는 것이 판례와 학설의 일반적인 태도이다.

⑤ 확정판결의 당사자인 처분행정청이 그 행정소송의 사실심 변론 종결 이전의 사유를 내세워 다시 확정판결과 저촉되는 행정처분을 하는 것은 허용되지 않는 것으로서 이러한 행정처분은 그 하자가 중대하고도 명백한 것이어서 당연무효라 할 것이다(대판 1990.12.11, 90누3560).

정답 ②

2. A관청이 甲의 생계곤란 등의 사정을 고려하지 않고 2개월의 영업정지 처분을 한 경우(취소사유의 하자가 있는 것을 전제로 한다)에 甲이 무효등확인소송을 제기한 경우 다음의 서술 중 옳지 않은 것은?

① 무효등확인소송의 소송물은 계쟁처분의 유·무효 여부이다.

② 동 소송에서 계쟁처분의 취소사유를 심리하여 본안판결로서 취소판결의 의미에서 인용판결을 할 수 있는지와 관련하여서 무효확인 청구에 취소청구가 당연히 포함되지 않는다는 근거로 원고의 청구를 기각해야 한다는 견해가 기각설이다.

③ 수소법원은 석명권을 행사하여 무효확인소송을 취소소송으로 변경한 연후에 취소판결을 하여야 한다는 견해가 소변경설이다.

④ 무효확인청구에서 원고 甲의 명시적인 반대의사표시가 없는 한 취소청구도 당연히 포함되어 있다고 보아 법원은 취소판결을 할 수 있다는 견해가 인용판결설이다.

⑤ 판례의 태도에 의할 경우 수소법원이 석명권을 행사하여 甲이 소변경을 하지 않은 경우에 취소청구에 대해서 판단을 한다면 처분권주의에 위배된다고 판시하여 우선 석명권을 행사할 것을 요구하고 있다.

해설 & 정답

유형 사례형

대법원은 “행정처분의 무효확인을 구하는 소에는 원고가 그 처분의 취소를 구하지 아니한다고 밝히지 아니한 이상 그 처분이 만약 당연무효가 아니라면 그 취소를 구하는 취지도 포함되어 있는 것으로 보아야 한다(대판 1994.12.23, 94누477)”라고 판시하여 인용판결설의 입장이다. 따라서 사안에서 수소법원은 인용판결을 하여야 한다.

정답 ⑤

3. 다음 사안을 읽고 아래 두 개의 문제를 검토하세요.

국립서울교육대학에서는 신규교원을 임용함에 있어서 학장이 소정의 전형을 거쳐 임용후보자를 최종 결정하여, 1년 기한으로 상근강사로 근무시킨 뒤, 교수로서의 자질・능력・근무상황 등을 평가하여, 그 적격판정을 받은 자를 대학인사위원회의 동의를 얻어 정규교원으로 임용하게 되어 있다. 甲은 1년 기한으로 위 대학의 상근강사로 채용되어 근무한 후, 교수로서의 적격자로 판정되어, 학장이 대학인사위원회에 그 임명동의를 요청하였으나 부결되었다. 그러나 그 사항은 甲에게 전달되지 않고 상당한 기간이 도과하였다. 이에 甲은 동 대학의 학장을 상대로 부작위위업확인소송을 제기함과 동시에 문교부장관에게 정규교원임용을 요청하는 내용의 탄원서를 제출하였다.

위 사안에서 부작위위법확인소송이 적법한지와 관련된 다음의 서술 중 옳지 않은 것은?

① 부작위위법확인소송의 제기요건으로 우선 대상 적격으로서 부작위가 존재하여야 하는데 행정소송법 제2조 제1항 제2호에서 부작위에 대해서 규정하고 있다.

② 사안에서는 부작위의 대상적격을 충족한다.

③ 원고적격 인정여부와 관련하여 조리상 법령상 신청권이 있어야 하는지에 대해서 견해대립이 존재한다.

④ 판례의 경우는 일관되게 법규상 조리상 신청권이 존재하여야 한다고 판시한다. 그리고 사안의 경우 甲에게는 조리상 신청권이 인정되어 원고적격이 인정된다.

⑤ 판례는 부작위위법확인소송의 법적 성질을 적극적 확인소송으로 보므로 사안의 경우 협의의 소익이 인정된다.

해설 & 정답

유형 사례형

①② 사안에서는 ⅰ) 당사자인 甲의 신청이 존재하고, ⅱ) 상당기간이 경과하였으며, ⅲ) 처분을 하여야 할 법률상 의무가 존재한다고 보여지며, ⅳ) 다른 처분이 존재하지 아니하므로 부작위위법확인소송의 대상인 부작위가 존재한다.

④ 행정소송법 제4조 제3호가 정하는 부작위위법확인의 소는 행정청이 당사자의 법규상 또는 조리상의 권리에 기한 신청에 대하여 상당한 기간 내에 신청을 인용하는 적극적 처분 또는 각하하거나 기각하는 등의 소극적 처분을 하여야 할 법률상 응답의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 경우 그 부작위가 위법하다는 것을 확인함으로써 행정청의 응답을 신속하게 하여 부작위 또는 무응답이라고 하는 소극적 위법상태를 제거하는 것을 목적으로 하는 제도이고, 이러한 소송은 처분의 신청을 한 자로서 부작위가 위법하다는 확인을 구할 법률상의 이익이 있는 자만이 제기 할 수 있는 것이므로, 당사자가 행정청에 대하여 어떠한 행정처분을 하여 줄 것을 요청할 수 있는 법규상 또는 조리상의 권리를 갖고 있지 아니하거나 부작위의 위법확인을 구할 법률상의 이익이 없는 경우에는 항고소송의 대상이 되는 위법한 부작위가 있다고 볼 수 없거나 원고적격이 없어 그 부작위위법확인의 소는 부적법하다(대판 2000.2.25, 99두11455).

서울교육대학에서 전임강사 이상의 신규교원을 임용함에 있어 학장이 소정의 전형을 거쳐 임용후보자를 최종 결정하여 1년을 기한으로 상근강사로 근무시킨 뒤, 교수로서의 자질, 능력, 학생지도실적 및 근무상황 등을 평가하여 그 중 적격판정을 받은 자만을 대학인사위원회의 동의를 얻어 정규교원으로 임용하게 되어 있는 제도에 의하여 그 대학의 상근강사로 채용된 자는 교육법시행령 제35조 제2항 소정의 정원 이외에 교원의 직무를 보조하기 위하여 상시 근무하는 전임강사를 의미하는 것이나, 이는 교육법 제75조 제1항 제2호 소정의 정규교원인 전임강

사와는 구별되는 것이므로 위 상근강사제도는 교육법이나 교육공무원법상의 명문의 근거를 둔 교원의 임용방법은 아니고, 국가공무원법상의 이른바 시보임용제도에 의하여 조건부로 채용된 공무원에 해당한다고 보아야 할 것인바, 상근강사로 채용된 자는 그 시보임용 내지 조건부채용시 장차 소정의 조건부 채용기간중 근무성적이 양호하여 적격판정을 받는 것을 조건으로, 특별한 사정이 없는 한 위 기간의 종료와 더불어 바로 정규공무원으로 임용될 권리를 취득하고 임용권자는 이에 대응하는 법률상의 의무를 부담한다고 할 것이며, 또한 교육공무원법상 시보임용에 의한 교육공무원으로서의 지위를 누리면서 그 조건부채용기간 중 면직 등의 처분이나 징계처분과 같은 신분상의 불이익한 처분을 받거나 또는 시보임용기간 종료 후 정규공무원 내지 교원으로서의 임용이 거부된 경우에는 행정소송 제기를 위한 전치절차로서의 교육공무원법 제52조에 의한 소청심사청구권도 가진다고 보아야 한다(대판 1990.9.25, 89누4758).

⑤ 부작위위법확인의 소는 행정청이 국민의 법규상 또는 조리상의 권리에 기한 신청에 대하여 상당한 기간 내에 그 신청을 인용하는 적극적 처분 또는 각하하거나 기각하는 등의 소극적 처분을 하여야 할 법률상의 응답의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 경우, 판결(사실심의 구두변론 종결)시를 기준으로 그 부작위의 위법을 확인함으로써 행정청의 응답을 신속하게 하여 부작위 내지 무응답이라고 하는 소극적인 위법상태를 제거하는 것을 목적으로 하는 것(소극적 확인소송이라는 취지이다)이고, 나아가 당해 판결의 구속력에 의하여 행정청에게 처분 등을 하게 하고 다시 당해 처분 등에 대하여 불복이 있는 때에는 그 처분 등을 다투게 함으로써 최종적으로는 국민의 권리이익을 보호하려는 제도이므로, 소제기의 전후를 통하여 판결시까지 행정청이 그 신청에 대하여 적극 또는 소극의 처분을 함으로써 부작위상태가 해소된 때에는 소의 이익을 상실하게 되어 당해 소는 각하를 면할 수가 없는 것이다(대판 1990.9.25, 89누4758). 사안의 경우는 부작위상태가 해소되지 않았으므로 협의의 소익이 인정되고 따라서 부작위위법확인소송은 적법하다.

정답 ⑤

♣ 학습내용 정리

1. 간접강제는 거부처분취소판결의 재처분의무위반에 대한 강제수단이다.
2. 다수설과 현재 판례는 무효확인소송에서 보충성을 소송요건으로 요구하지 않는다.
3. 부작위위법확인소송의 대상인 부작위가 성립되려면 법규상 또는 조리상 신청권이 있어야 한다는 것이 판례이다.

제41강 무효확인소송 및 부작위법확인소송

♣ 학습목표

부작위법확인소송과 당사자소송의 대상 및 판결의 효력을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

부작위위법확인소송

당사자소송

♣ 사전테스트

1. 처분이 아닌 행정작용의 부작위도 부작위위법확인소송의 대상이 된다.
   정답 : X

2. 특정처분 해야할 의무도 심리할 수 있다는 것이 판례입장이다.
   정답 : x

3. 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제85조 제2항의 보상금증감청구소송은 형식적 당사자소송이라고 보는 것이 다수설이다.
   정답 : O

♣ 돌발퀴즈

법령 또는 처분 등의 무효를 전제로 한 공법상 법률관계의 확인소송도 당사자소송에 의한다.

[정답] ○

[해설] 행정소송법 제3조 제2호

♣ 강의내용

제1 부작위위법확인소송

I. 부작위위법확인소송의 당사자 적격

1. 원고적격

부작위위법확인소송의 원고적격은 처분의 신청을 한 자로서 부작위의 위법을 구할 법률상 이익이 있는 자만이 가진다(행정소송법 제36조).

이러한 부작위위법확인소송의 원고적격에 대하여, 처분의 신청을 한 사실만으로 충분하다는 견해, 신청권을 가진 자일 것을 요구한다는 견해 등이 대립하고 있다.

그러나 신청권을 갖지 못하는 자의 신청의 경우에는 소송의 대상인 부작위 자체가 성립하지 않으므로 신청권을 갖는 자에 대해서만 원고적격이 인정된다고 보아야 할 것이다. 이러한 입장이 다수설이며, 판례이다.

2. 피고적격

피고는 부작위를 한 행정청이 된다.

Ⅳ. 소의 제기

1. 제소기간(행정소송법 제38조 제2항, 동법 제20조)

⑴ 문제점

① 행정심판을 거쳐 부작위위법확인소송을 제기하게 되면, 재결이 존재하는 바 제소기간에 관한 행정소송법 제20조가 적용된다. 그러나 ② 행정심판을 거치지 아니하고 부작위위법확인소송을 제기하는 경우 처분 등이 없기 때문에 행정소송법 제20조를 적용할 수 없다. 따라서 ②에 대해선 학설과 판례가 정할 사항이다.

⑵ 학설

① 부작위의 성립요소의 하나인 신청 후 상당기간이 경과하면 그 때에 처분이 있는 것으로 보고 행정소송법 제20조 제2항에 따라 그 때부터 1년내에 제소하여야 한다는 견해와 ② 행정소송법상 명문의 규정이 없으므로 제소기간의 제한이 없다는 견해(다수설)가 대립한다.

⑶ 판례

판례는 부작위가 계속되는 한 언제라도 제소할 수 있다고 판시하였다.

⑷ 검토

부작위가 계속되는 부작위의 종료시점을 정하기 어렵고, ①설에서 말하는 상당한 기간이라는 개념 자체가 불확정적인 것이라는 점, 행정심판법상 부작위에 대한 의무이행심판에는 심판청구기간의 제한이 없다는 점 등을 고려하면, 제소기간의 제한이 없다는 ②설과 판례가 타당하다.

2. 행정심판전치주의(행정소송법 제38조 제2항, 동법 제18조)

Ⅴ. 부작위위법확인소송의 판결

1. 위법판단의 기준시 - 판결시(사실심 변론종결시)

2. 법원의 심리권의 범위

⑴ 학설

① 분쟁의 일회적 해결과 국민의 실효적인 권리구제위해 신청의 실체적 내용까지 심리해서 적정한 처리방향에 대한 판단을 해야 한다는 견해와 ② 부작위위법확인소송은 부작위의 위법여부만 확인할 뿐 작위의무를 심리하는 소송이 아니라는 점에서 응답의무위반여부만 심리해야 한다는 견해가 대립한다.

⑵ 판 례

판례는 현행법상 의무이행소송을 인정하고 있지 않다는 점 등을 근거로 ②설의 입장을 취하고 있다.

"부작위위법확인소송의 소는 … 국민의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분, 즉 그 신청을 인용하는 적극적 처분 또는 각하하거나 기각하는 등의 소극적 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 않은 경우, 판결시를 기준으로 하여 그 부작위의 위법성을 확인함으로써 행정청의 응답을 신속하게 하여 부작위 내지 무응답이라는 소극적 위법상태를 제거하는 것을 목적으로 하는 것이고, 나아가 당해 판결의 기속력에 의하여 행정청에게 처분 등을 하게 하고, 다시 당해 처분 등에 대하여 불복이 있는 때에는 그 처분을 다투게 함으로써, 최종적으로 국민의 권리이익을 보호하려는 제도이다"(대판 1990. 9. 25, 89누4758)

⑷ 검 토

현행 행정소송법상 의무이행소송이 없다는 점에서 부작위위법확인소송의 심리를 적극적으로 하여 국민의 권익구제를 넓히려는 ①설의 입장은 어느 정도 타당성이 있다. 그러나 우리 행정소송법은 행정청의 1차적 판단권을 존중하는 의미에서 부작위위법확인소송만 인정하고 의무이행소송을 도입하지 않았는 바, 제1설은 행정소송법의 부작위위법확인소송을 규정한 입법취지와 맞지 않는다. 따라서 ②설과 판례의 견해가 타당하다.

3. 판결의 기속력, 간접강제

⑴ 부작위위법확인소송의 인용판결의 기속력

부작위위법확인소송에 대한 인용과 기각판결은 기판력을 갖는다. 문제가 되는 것은 부작위위법확인소송의 판결이 확정되었을 때 갖는 기속력의 내용에 관한 것이다. 여기에 대하여는 거부처분의 기속력에 관한 규정이 준용된다(동법 제38조 제2항, 동법 제30조 제2항). 따라서 부작위위법확인소송의 청구를 인용하는 판결이 확정된 경우에는 그 판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다. 여기에서 문제되는 것은 판결의 취지에 따르는 이전의 신청에 대한 처분이 무엇을 의미하는가이다.

⑵ 판결의 취지에 따르는 신청에 대한 처분의 의미

1) 학 설

① 부작위위법확인소송의 본안심리는 부작위의 위법확인만을 할 수 있다는 바 인용확정판결의 기속력은 응답의무에 불과하다는 견해와 ② 기속행위나 재량이 0으로 수축된 경우에 대한 인용확정판결의 기속력은 신청의 내용에 따르는 특정처분의무이행에 미친다는 견해가 대립한다.

2) 판 례

판례는 ①설의 입장을 취하고 있다.

"부작위위법확인소송의 소는 … 국민의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분, 즉 그 신청을 인용하는 적극적 처분 또는 각하하거나 기각하는 등의 소극적 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 않은 경우, 판결시를 기준으로 하여 그 부작위의 위법성을 확인함으로써 행정청의 응답을 신속하게 하여 부작위 내지 무응답이라는 소극적 위법상태를 제거하는 것을 목적으로 하는 것이고, 나아가 당해 판결의 기속력에 의하여 행정청에게 처분 등을 하게 하고, 다시 당해 처분 등에 대하여 불복이 있는 때에는 그 처분을 다투게 함으로써, 최종적으로 국민의 권리이익을 보호하려는 제도"(대판 1992. 7. 28, 91누7361)

3) 검 토

이는 결국 부작위위법확인소송의 본안심리의 범위와 관련된 문제로서 현행 행정소송법의 태도가 단순한 응답의무만을 심리한다고 했을 때, 응답의무의 이행에만 판결의 기속력이 미친다고 보는 ①설과 판례의 견해가 타당하다.

제2 당사자소송

Ⅰ. 서 설

1. 당사자소송의 의의

이는 행정청의 처분 등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송과 그 밖에 공법상의 법률관계에 관한 소송으로서 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송을 말한다(행정소송법 제3조 제2호).

2. 항고소송, 민사소송과의 구별

⑴ 항고소송과의 구별

처분이나 처분 등이나 또는 처분등에 대한 부작위

당좌 소송은 처분 등을 원인으로 하는 법률 단계 기타 공법상 법률 단계

⑵ 민사소송과의 구별

사건 사업부 다툼에 대해서 예기하는 소송

3. 당사자소송의 유형

당사자소송은 다시 두 가지 유형, 즉 실질적 당사자소송과 형식적 당사자소송으로 구분된다. 전자는 본래 의미로서의 당사자소송으로서 대등한 당사자 사이의 공법상의 법률관계 또는 권리관계에 관한 소송을 말한다. 후자는 실질적으로는 행정청의 처분 등을 다투는 소송이면서 항고

소송에서와 같이 행정청을 피고로 하지 않고 당해 처분 등을 원인으로 하는 법률관계의 일방 당사자를 피고로 제기하는 소송을 말한다. 그런데 형식적 당사자소송은 개별법에 특별한 규정이 있어야만 허용되는 바 이하에서는 행정소송법 제3조 제2호에 의해 인정되는 실질적 당사자소송에 대해서만 논하도록 한다.

Ⅱ. 당사자소송의 대상

1. 문제점

행정소송법상 당사자소송의 대상은 행정청의 처분등을 원인으로 하는 법률관계와 그 밖에 공법상의 법률관계이다.

행정청의 처분등을 원인으로 하는 법률관계라 함은 처분등에 의하여 발생, 변경, 소멸된 법률관계를 말하는 바, 이에는 ① 처분에 의하여 직접적으로 형성된 법률관계와 ② 처분의 효력을 기초로 하여 간접적으로 이루어진 법률관계를 상정할 수 있다. 이를테면 무효인 과세처분이 있는 경우 조세채무부존재 여부의 문제는 전자의 법률관계이고, 무효인 과세처분에 기하여 납부된 과오납금반환청구권은 후자의 법률관계이다.

후자의 경우 이를 당사자소송의 방법으로 인정할 것이냐 또는 민사소송으로 인정할 것이냐에 관하여 많은 논란이 제기되고 있다.

판례의 기본적 태도는 처분을 원인으로 하는 법률관계라도 그 소송물이 사법상의 법률관계이면 민사사건으로 보고 있으므로 처분을 원인으로 하는 법률관계 중 그 소송물이 공법상의 법률관계인 것만이 당사자소송의 대상이다.

그 밖에 공법상의 법률관계란 처분등을 원인으로 하지 않는 그 밖에 공법상의 법률관계를 말한다.

2. 처분등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송

이러한 소송에는 ① 처분등의 무효를 전제로 하는 부당이득반환청구소송, ② 공무원의 직무상 불법행위로 인한 국가배상청구소송 등이 있다.(다만 판례는 민사소송으로 봄)

3. 공법상의 신분. 지위에 관한 소송

공무원이나 국·공립학교의 학생의 신분이 있음의 확인을 구하는 소는 당사자소송에 속한다.

또한 도시재개발조합을 상대로 한 조합원지위 확인청구는 당사자소송이다.[80]

4. 손실보상금청구소송

5. 각종 사회보장급부청구

첫째, 공무원연금법, 고용보험법, 군인연금법, 국가유공자등예우및지원에관한법률 등에 의해 발생하는 급부청구권은 법령의 요건에 해당하는 것만으로 바로 구체적 청구권이 발생하는 것이 아니라 행정청의 결정에 의하여 비로소 구체적 청구권이 발생하는 것으로 되어 있다.

그러므로 법률소정의 절차에 따른 행정청의 결정을 받지 아니하고 곧바로 국가 등을 상대로 당사자소송으로 그 권리의 확인이나 급여의 지급을 청구하는 것은 허용되지 않는다. 다만 행정청의 인용결정이 있음에도 급부가 이루어지지 않을 때 그 급부를 청구하는 소는 당사자소송이 된다.

공무원연금관리공단의 연금지급결정은 처분에 해당하나 공단의 퇴직연금 중 일부 금액의 지급정지대상자가 되었다는 사실 통보는 단순한 관념의 통지로서 항고소송의 대상인 처분이 아니

80) 대판 1996. 2. 15. 94다31235

므로 연금지급청구소송이라는 당사자소송을 제기하여야 한다는 판례(대판 2004. 12. 24, 2003두15195).

그러나 급부청구권이 관계법령상 행정청의 1차적 판단 없이 곧바로 발생하는 경우에는 행정청의 결정을 거친 필요 없이 당사자소송으로 그 이행을 구할 수 있다. 석탄산업법에 의한 석탄가격안정지원금청구(대판 1997. 5. 30, 95다28960)등이 그 예이다.

광주민주화운동관련자보상등에관한법률의 보상심의위원회의 보상금지급신청에 대한 결정은 처분이 아니므로 취소소송이 아니라 당사자소송을 제기하여야 한다는 판례(대판 1992.12.24. 92누3335 판결)

민주화운동관련자 명예회복 및 보상 등에 관한 법률' 의 보상심의위원회의 결정은 행정처분인 바 취소소송을 제기하여야 한다는 판례(대판[전합] 2008. 4. 17, 2005두16185).

6. 공법상 계약에 관한 소송 - 당사자소송

7. 기 타

Ⅲ. 당사자소송의 제기와 심리, 판결

1. 재판관할 - 취소소송과 동일

2. 적용법규

당사자소송도 취소소송에 관한 규정이 광범위하게 준용된다. 그 내용으로는 관련청구소송의 병합, 소의 변경을 들 수 있다. 그 밖에도 피고경정, 공동소송, 제3자의 소송참가, 행정청의 소송참가, 처분변경으로 인한 소의 변경, 행정심판기록 제출명령, 직권심리주의, 취소판결의 기속력, 소송비용의 부담, 소송비용에 관한 재판의 효력 등이다(동법 제44조 제1항).

반면에 피고적격, 소송대상, 행정심판전치주의, 제소기간, 집행정지, 사정판결, 취소확정판결의 제3자효, 제3자의 재심청구 등에 관한 규정은 당사자소송의 성격상 준용되지 않는다.

3. 당사자

⑴ 원고적격

항고소송과는 달리 당사자소송의 원고적격에 관한 규정은 없으므로 민사소송법상의 원고적격에 관한 규정이 준용된다. 따라서 원칙적으로 공법상 법률관계에서 권리보호의 이익이 있는 자는 당사자소송의 원고가 될 수 있다.

⑵ 피고적격

당사자소송은 법률관계의 당사자를 직접 피고로 하는 소송이므로 원칙적으로 권리의무의 주체일 것이 요구된다. 따라서 당사자소송의 피고는 국가 공공단체 그밖의 권리주체를 피고로 한다(동법 제39조).

4. 제소기간

당사자소송은 민사소송과 같이 특별한 제소기간이 없으나 법령이 제소기간이 정하여져 있는 경우에는 그 기간은 불변기간으로 한다(동법 제41조).

5. 심리절차의 원칙 : 직권심리주의와 행정심판기록 제출명령

6. 판 결

당사자소송의 판결의 효력에 대하여는 행정소송법 제30조 제1항의 취소판결의 기속력을 준용하는 규정을 두고 있다(동법 제44조 제1항). 따라서 당사자소송의 확정판결은 그 사건에 관하여 당사자인 행정청과 그 밖의 관계행정청을 기속한다.

제3 형식적 당사자소송

I. 형식적 당사자소송의 의의 및 특성, 필요성

1. 형식적 당사자소송의 의의

형식적 당사자소송은 "행정청의 처분 등이 원인이 되어 형성된 법률관계에 다툼이 있는 경우 그 원인이 되는 처분 등의 효력을 직접 다투지 않고 처분 등의 결과로서 형성된 법률관계에 대하여, 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하여 제기하는 소송"이라고 정의한다.

2. 형식적 당사자소송의 특성

형식적 당사자소송은 처분, 재결 등의 효력을 다투는 것이 되어, 실질적으로 항고소송의 성질을 가지는 것이나, 소송경제등의 필요에 의하여 당사자소송의 형식을 취하는 특색이 있다.

3. 형식적 당사자소송의 필요성

형식적 당사자소송은 현실적으로 당사자가 다투고자 하는 분쟁의 내용을 중시하여, 이러한 분쟁의 실질적인 이해관계자만 소송당사자로 하고 행정청을 배제함으로써 신속한 권리 구제를 도모하고 소송절차를 간소화하려는 데에 그 필요성이 인정된다.

Ⅲ. 형식적 당사자소송의 인정여부

개별법에 특별규정이 없는 경우에도 행정소송법 제3조 제2호에 따라 형식적 당사자소송을 인정할 수 있는지 여부이다.

1. 부정설

이 견해는 ① 원인이 되는 처분 등에 대해서 항고소송을 제기하지 않은 채 처분의 결과에 의해 형성된 법률관계에 대해서 법원이 판단하는 것은 행정행위의 공정력이나 구성요건적 효력에 반한다는 점, ② 행정소송법 제3조 제2호는 실질적 당사자소송의 근거일 뿐이라는 점 등을 논거로 한다.

2. 긍정설

이 견해는 ① 행정소송법 제3조 2호에는 당연히 형식적 당사자소송도 포함된다는 점, ② 행정소송법 제44조 제1항이 제25조를 준용하고 있다는 점 등을 논거로 한다.

3. 검 토

생각건대, 명문의 개별규정이 없는 경우 형식적 당사자소송을 행정소송법 제3조 제2호에 의해 인정하면 원고적격 등 소송요건이 불분명해지고, 행정행위의 공정력 또는 구성요건적 효력을 부정하는 결과가 되어 부당하다. 따라서 부정설이 타당하다.

Ⅳ. 실정법적 근거

형식적 당사자소송을 인정하는 개별법규정으로는 특허법 제191조, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제171조 등을 들 수 있다.

공익사업을위한토지등의취득및보상에관한법률 제85조 제2항은 재결청을 피고에서 삭제하여 토지소유자 등과 사업시행자간의 소송으로 규정하여 완전히 형식적 당사자소송의 형태가 되었다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 甲은 관할행정청에 하천점용허가를 신청하였으나, 이에 대하여 관할행정청은 상당한 기간이 경과하여도 아무런 응답이 없었다. 이 경우 甲의 현행 행정쟁송법상의 권리구제수단에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 관할 행정청이 아무런 응답을 하지 않은 것은 거부에 해당한다.
② 甲은 의무이행심판을 청구하거나 취소소송을 제기하여 권리구제를 받을 수 있다.
③ 甲은 의무이행심판을 제기할 수 있으며, 의무이행심판의 인용재결이 내려질 경우 하천점용허가는 기속행위이므로 관할행정청은 甲의 신청대로 처분을 하여야 한다.
④ 甲은 의무이행소송을 제기하여야 하며, 이 소송에서 법원은 행정청이 발급하여야 할 실체적 처분의 내용까지 심리할 수 있다는 것이 판례의 입장이다.
⑤ 甲은 의무이행심판을 청구하거나 부작위위법확인소송을 제기하여 권리구제를 받을 수 있다.

해설 & 정답

유형 사례형

①②⑤ 사안에서 아무런 응답을 하지 않은 것은 거부가 아니라 부작위 해당하므로 의무이행심판이나 부작위위법확인소송만 가능하고, 취소심판이나 취소소송제기는 불가능하다.

③④ 하천점용허가는 특허로서 재량행위이다. 비록 하천점용허가가 설령 기속행위라 할지라도 부작위위법확인판결의 기속력은 부작위가 위법이라는 취지이기 때문에 어떤 내용으로든 처분을 하기만 하면 기속력을 존중한 것이기 때문에 적법이다(절차적 심리설 : 판례의 태도). 한편, 현행법상 의무이행소송은 인정되지 않는다.

정답 ⑤

2. 다음 중 공법상의 당사자소송에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (2002 행정고시)

① 당사자소송은 국가·공공단체 및 그 밖의 권리주체를 피고로 한다.
② 법령 또는 처분 등의 무효를 전제로 한 공법상 법률관계의 확인소송도 당사자소송에 의한다.
③ 청구의 기초에 변경이 없는 한 당사자소송을 취소소송으로 변경할 수는 있으나 무효등확인소송으로는 변경할 수 없다.
④ 행정소송법은 국가를 상대로 하는 당사자소송의 경우에는 가집행선고를 할 수 없다고 규정하고 있다.
⑤ 당사자소송의 제1심 재판관할에 있어서 국가 또는 공공단체가 피고인 경우에는 관계행정청의 소재지를 피고의 소재지로 본다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 행정소송법 제39조
② 동법 제3조 제2호
③ 소종류의 변경은 항고소송 상호 간, 항고소송과 당사자소송 상호 간 모두 인정된다(동법 제21조 제1항).
④ 동법 제43조
⑤ 동법 제40조 단서

정답 ③

3. 당사자소송에 관한 설명 중 옳은 것은?

① 판례에 의하면 시립무용단원의 해촉에 대하여는 항고소송으로 다투어야 하고 당사자소송으로 다툴 수 없다.

② 당사자소송을 항고소송으로 변경하는 것은 허용되지 않는다.

③ 현행 행정소송법은 당사자소송의 원고적격을 당사자소송을 제기할 법률상 이익이 있는 자로 규정하고 있다.

④ 조세부과처분의 당연무효를 전제로 하여 이미 납부한 세금의 반환을 청구하는 것은 당사자소송에 의하여야 한다.

⑤ 공무원연금관리공단의 인정에 따른 퇴직연금 중 미지급퇴직연금에 대한 지급청구권은 당사자소송에 의하여야 한다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 서울특별시립무용단 단원의 위촉은 공법상의 계약이라고 할 것이고, 따라서 그 단원의 해촉에 대하여는 공법상의 당사자소송으로 그 무효확인을 청구할 수 있다(대판 1995.12.22, 95누4636).

② 소의 종류의 변경에는 ⅰ) 취소소송을 다른 항고소송인 무효등확인소송이나 부작위위법확인소송으로 변경하거나 당해 처분 등에 관계되는 사무가 귀속하는 국가 또는 공공단체에 대한 당사자소송으로 변경하는 경우와(행정소송법 제21조 제1항), 반대로 ⅱ) 무효등확인소송 또는 부작위위법확인소송을 취소소송 또는 당사자소송으로 변경하거나(동법 제37조), ⅲ) 당사자소송을 당해 행정청 상대의 취소소송이나 그 밖의 항고소송으로 변경하는 경우(행정소송법 제42조)를 포함한다.

③ 당사자소송은 대등한 당사자 간의 공법상 법률관계에 관한 소송이므로 항고소송에서와 같은 원고적격의 제한은 없으며, 따라서 민사소송법상의 원고적격에 관한 규정이 준용된다(동법 제8조 제2항).

④ 조세부과처분이 무효임을 전제로 하여 이미 납부한 세금의 반환을 청구하는 것은 민사상의 부당이득반환청구로서 민사소송절차에 따라야 한다(대판 1991.2.6, 90프2).

⑤ 구 공무원연금법(2000.12.30. 법률 제6328호로 개정되기 전의 것) 소정의 퇴직연금 등의 급여는 급여를 받을 권리를 가진 자가 당해 공무원이 소속하였던 기관장의 확인을 얻어 신청하는 바에 따라 공무원연금관리공단이 그 지급결정을 함으로써 그 구체적인 권리가 발생하는 것이므로, 공무원연금관리공단의 급여에 관한 결정은 국민의 권리에 직접 영향을 미치는 것이어서 행정처분에 해당할 것이지만, 공무원연금관리공단의 인정에 의하여 퇴직연금을 지급받아 오던 중 구 공무원연금법령의 개정 등으로 퇴직연금 중 일부 금액의 지급이 정지된 경우에는 당연히 개정된 법령에 따라 퇴직연금이 확정되는 것이지 같은 법 제26조 제1항에 정해진 공무원연금관리공단의 퇴직연금 결정과 통지에 의하여 비로소 그 금액이 확정되는 것이 아니므로, 공무원연금관리공단이 퇴직연금 중 일부 금액에 대하여 지급거부의 의사표시를 하였다고 하더라도 그 의사표시는 퇴직연금 청구권을 형성·확정하는 행정처분이 아니라 공법상의 법률관계의 한 쪽 당사자로서 그 지급의무의 존부 및 범위에 관하여 나름대로의 사실상·법률상 의견을 밝힌 것일 뿐이어서, 이를 행정처분이라고 볼 수는 없고, 이 경우 미지급퇴직연금에 대한 지급청구권은 공법상 권리로서 그의 지급을 구하는 소송은 공법상의 법률관계에 관한 소송인 공법상 당사자소송에 해당한다(대판 2004.7.8, 2004두244).

정답 ⑤

♣ 학습내용 정리

1. 부작위위법확인소송의 본안심리의 범위에 대하여 판례는 응답의무위반여부만 심리한다는 입장이다.
2. 당사자소송에는 실질적 당사자소송과 형식적 당사자소송이 있다.

제42강 국가배상법 및 행정행위

♣ 학습목표

부작위에의한 국가배상에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.
행정벌과 행정질서벌에 대해 비교하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

부작위에 의한 국가배상
선결문제
행정벌

♣ 사전테스트

1. 조리에 의한 작위의무를 인정하지 않는 것이 판례입장이다.
정답 : X

2. 불가변력은 모든 행정행위에 인정된다.
정답 : x

3. 행정질서벌은 고의 또는 과실이 인정되어야 부과될 수 있다.
정답 : O

♣ 돌발퀴즈

공무원에 대하여 작위의무를 명하는 법령의 규정이 없는 경우에는 공무원의 부작위로 인한 국가배상책임을 인정할 수 없다.

[정답] ×

[해설] 공무원의 부작위로 인한 국가배상책임을 인정하기 위하여는 공무원의 작위로 인한 국가배상책임을 인정하는 경우와 마찬가지로 '공무원이 그 직무를 집행함에 당하여 고의 또는 과실로 법령에 위반하여 타인에게 손해를 가한 때'라고 하는 국가배상법 제2조 제1항의 요건이 충족되어야 할 것인바, 여기서 '법령에 위반하여'라고 하는 것이 엄격하게 형식적 의미의 법령에 명시적으로 공무원의 작위의무가 규정되어 있는데도 이를 위반하는 경우만을 의미하는 것은 아니고, 국민의 생명, 신체, 재산 등에 대하여 절박하고 중대한 위험상태가 발생하였거나 발생할 우려가 있어서 국민의 생명, 신체, 재산 등을 보호하는 것을 본래적 사명으로 하는 국가가 초법규적, 일차적으로 그 위험 배제에 나서지 아니하면 국민의 생명, 신체, 재산 등을 보호할 수 없는 경우에는 형식적 의미의 법령에 근거가 없더라도 국가나 관련 공무원에 대하여 그러한 위험을 배제할 작위의무를 인정할 수 있을 것이나, 그와 같은 절박하고 중대한 위험상태가 발생하였거

나 발생할 우려가 있는 경우가 아닌 한, 원칙적으로 공무원이 관련 법령대로만 직무를 수행하였다면 그와 같은 공무원의 부작위를 가지고 '고의 또는 과실로 법령에 위반'하였다고 할 수는 없을 것이므로, 공무원의 부작위로 인한 국가배상책임을 인정할 것인지 여부가 문제되는 경우에 관련 공무원에 대하여 작위의무를 명하는 법령의 규정이 없다면 공무원의 부작위로 인하여 침해된 국민의 법익 또는 국민에게 발생한 손해가 어느 정도 심각하고 절박한 것인지, 관련 공무원이 그와 같은 결과를 예견하여 그 결과를 회피하기 위한 조치를 취할 수 있는 가능성이 있는지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대판 2001.4.24, 2000다57856).

♣ 강의내용

제1 부작위에 대한 국가배상청구

Ⅰ. 문제의 제기

부작위에 대한 구제수단은 현대 사회국가에서 더욱 중요시 되고 있다. 이에 대한 구제수단중 하나가 바로 부작위에 대한 국가배상청구다. 원래의 국가배상청구가 공무원의 적극적·침해적 행위에 대한 손해배상을 전제로 하였다는 점에서 부작위에 대한 국가배상청구는 작위에 의한 국가배상과는 다른 특수한 검토가 필요하다.

이 중 작위의무가 법령에서 명문으로 규정되어 있지 않은 경우에도 조리에 의해 법적 작위의무를 인정할 수 있는가 하는 문제와 부작위에 의한 손해배상책임에 있어서 관련법규의 사익보호성이 필요한가하는 문제에 대한 검토가 필요하다.

Ⅱ. 조리에 의한 작위의무의 인정여부

1. 학 설

작위의무에 관하여 법령에 명문으로 규정되어 있지 않은 경우에도 조리에 의해 법적 작위의무를 인정할 수 있는가 하는 문제에 대하여 학설이 대립하고 있다.

⑴ 긍정설

이 견해는 공서양속, 조리 내지 사회통념에 근거하여 작위의무를 인정할 수 있다는 견해이다.

⑵ 부정설

이 견해는 법률에 의한 행정의 원칙에 비추어 법률상 근거를 결하는 작위의무를 인정할 수 없다는 견해가 있다.

2. 판 례

판례는 형식적 의미의 법령에 명시적으로 공무원의 작위의무가 규정되어 있지 않음에도 구체적 사정에 따라 부작위하는 것이 현저하게 불합리하다고 인정되는 경우에는 위험방지작위의무를 인정하고 있다.

경직법 제5조에 의한 경찰권발동이 재량이나 일정한 경우 조리에 의한 작위의무를 인정할 수 있다는 판례

[1] 경찰관직무집행법 제5조는 경찰관은 인명 또는 신체에 위해를 미치거나 재산에 중대한 손해를 끼칠 우려가 있는 위험한 사태가 있을 때에는 그 각 호의 조치를 취할 수 있다고 규정하여 형식상 경찰관에게 재량에 의한 직무수행권한을 부여한 것처럼 되어 있으나, 경찰관에게

그러한 권한을 부여한 취지와 목적에 비추어 볼 때 구체적인 사정에 따라 경찰관이 그 권한을 행사하여 필요한 조치를 취하지 아니하는 것이 현저하게 불합리하다고 인정되는 경우에는 그러한 권한의 불행사는 직무상의 의무를 위반한 것이 되어 위법하게 된다.

[2] 경찰관이 농민들의 시위를 진압하고 시위과정에 도로 상에 방치된 트랙터 1대에 대하여 이를 도로 밖으로 옮기거나 후방에 안전표지판을 설치하는 것과 같은 위험발생방지조치를 취하지 아니한 채 그대로 방치하고 철수하여 버린 결과, 야간에 그 도로를 진행하던 운전자가 위 방치된 트랙터를 피하려다가 다른 트랙터에 부딪혀 상해를 입은 사안에서 국가배상책임을 인정한 사례(대판 1998. 8. 25, 98다16890)

3. 검 토

피해자의 권익구제라는 관점에서 긍정설이 타당하다.

Ⅲ. 사익보호성이 국가배상책임성립에 요구되는지 - 전술한 관련법규의 사익보호성 참조

Ⅳ. 부작위와 관련된 중요판례

1. 국가배상책임 부정한 판례

사업인가 취소는 수익행위의 취소로서 불이익처분이 되고, 그 사업을 계속 수행할 수 없게 되어 공사업자 등 이미 법률관계를 맺고 있는 자의 이해에도 영향을 미치게 되는바, 이러한 규제·감독권한을 행사할 것인가 여부는 행정청의 전문적 판단에 근거한 합리적 재량에 맡겨져 있다고 해야 할 것이고, 사업시행자가 인가조건에 위반하여 사전분양행위를 하고 공사가 중단되는 등의 사정으로 개별적인 사전분양자가 손해를 입게 되는 경우라도, 구체적 사정상, 행정청 등에 그러한 규제·감독권한이 부여된 취지·목적에 비추어 보아 그 불행사가 현저하게 불합리하다고 인정되지 않는 한, 위 권한의 불행사는 사전분양자에 대한 관계에서 국가배상법상 위법이라고 인정되는 것은 아니다(대법원 2005.11.10. 선고 2003다18876 판결)

경찰관들이 인질의 구출 및 납치범의 검거 직무를 수행하는 과정에서 범인에게 돈을 전달하기로 한 인질의 아버지가 피살된 사안에서 그 부작위의 객관적 정당성결여가 인정되지 않아 국가배상책임을 부정한 판례(대판 2007. 10. 25, 2005다23438)

국립전남대학교에서 한총련 산하 남총련의 간부들이 엉뚱한 사람을 경찰프락치라고 속단하여 감금폭행하여 사망에 이르게 한 사건(대판 2002. 12. 10, 2000다55126)

정신질환자인 세입자에 의해 살해당한 집주인의 유족이 정신질환자의 평소 행동에 대한 사법경찰관의 수사미개시 및 긴급구호권 불행사에 대하여 국가배상청구소송을 제기한 사건(대판 1996. 10. 25, 95다45927)

에이즈검사양성판정후 국가기관검진에 의해 음성으로 판정된 경우 이를 통보하지 않은 사건에서 국가배상책임을 부정(대판 1998. 10. 13, 98다18520).

노래방영업명의변경신고를 거부한 위법한 조치에 대한 국가배상책임 부정 - 사익보호성부정으로 인과관계부정(대판 2001. 4. 13, 2000다34891)

2. 국가배상책임을 인정한 판례

행정입법부작위에 대한 국가배상책임을 인정한 판례(대판 2007. 11. 29, 2006다3561).

극동호사건에서 선박검사의무 불이행으로 선박화재가 발생한 경우 선박검사의무의 사익보호성을 인정하여 국가배상책임을 인정(대판 1993. 2. 12, 91다43466)

경찰관의 경찰권발동에 대한 부작위로 인한 군산윤락업소화재사건으로 인한 윤락녀 사망사건(대판 2004. 9. 23, 2003다49009)

무장공비출현신고에 대해 군경공무원들의 부작위로 인한 주민사망한 경우(일명 김신조 사건, 대판 1971. 4. 6, 71다124)

기망에 의한 허위내용의 주민등록증발급으로 인해 피해를 입은 자가 허위내용의 주민등록증을 발급해준 강남구를 상대로 국가배상청구소송제기한 사건(대판 2003. 4. 25, 2001다59842)

공영주차장침수로 피해를 입은 경우(대판 2006. 4. 14, 2003다41746)

제2 행정행위의 존속력 ― 불가쟁력과 불가변력

1. 개 설

행정행위가 발령되면 이에 근거하여 새로운 법률관계가 형성되므로 행정행위를 변경하지 않고 계속적으로 존속시킬 필요성에서 인정되는 개념으로서 형식적 존속력과 실질적 존속력을 포함한다.

2. 불가쟁력

⑴ 개 념

이는 행정행위의 상대방이나 이해관계인에 대하여 행정행위의 효력을 일정한 쟁송제기기간 내에서만 또는 일정한 쟁송수단의 사용 등에 의해서만 다툴 수 있게 하고, 이러한 시간의 경과나 쟁송수단이 모두 사용된 경우에는 통상의 쟁송절차에 의해서는 더 이상 다투지 못하게 하여 행정행위를 형식적으로 확정하는 것을 말한다.

불가쟁력은 기판력이 아니므로 불가쟁력이 발생하였더라도 당사자나 법원에 모순되는 주장이나 판단을 못하는 것은 아니라는 판례」(大判 1993.8.27, 93누5437).

피재해자에게 이루어진 요양승인처분이 불복기간의 경과로 확정되었다 하더라도 사업주는 피재해자가 재해 발생 당시 자신의 근로자가 아니라는 사정을 들어 보험급여액징수처분의 위법성을 주장할 수 있다고 한 판례(대법원 2008.7.24. 선고 2006두20808 판결)

⑵ 근거 및 범위 - 법적 안정성 / 무효인 행정행위에는 인정되지 않음

⑶ 효 과

불가쟁력이 발생한 행정행위에 대한 취소심판과 취소소송은 부적법 각하된다. 그러나 불가쟁력의 대상은 상대방이나 이해관계인이어서 처분청은 이에 영향을 받지 아니하므로 처분청은 독자적으로 직권취소나 철회를 할 수 있다.

⑷ 기판력과의 구별

행정처분 등이 불복기간의 경과로 인하여 확정된 경우 확정력(불가쟁력)은 처분이나 재결의 효력을 더 이상 다툴 수 없다는 의미일 뿐 판결에 있어서와 같은 기판력이 인정되는 것은 아니어서 당사자들이나 법원이 이에 기속되는 것은 아니다. 판례도 다음과 같이 판시하여 같은 입장이다.

행정처분이나 행정심판 재결이 불복기간의 경과로 인하여 확정될 경우 확정력은 처분으로 인하여 법률상 이익을 침해받은 자가 처분이나 재결의 효력을 더 이상 다툴 수 없다는 의미일 뿐 판결에 있어서와 같은 기판력이 인정되는 것은 아니어서 처분의 기초가 된 사실관계나 법률적 판단이 확정되고 당사자들이나 법원이 이에 기속되어 모순되는 주장이나 판단을 할 수 없게 되는 것은 아니다. 종전의 산업재해요양보상급여취소처분이 불복기간의 경과로 인하여 확정되었더라도 요양급여청구권이 없다는 내용의 법률관계까지 확정된 것은 아니며 소멸시효에 걸리지 아

니한 이상 다시 요양급여를 청구할 수 있고 그것이 거부된 경우 이는 새로운 거부처분으로서 위법 여부를 소구할 수 있다(대판 1993.4.13, 92누17181).

⑸ 불가쟁력에 대한 예외

1) 행정처분의 재심사

2) 하자의 승계

3. 불가변력

⑴ 의 의

이는 행정행위의 성질에 의하여 처분청 등의 취소나 철회, 변경이 허용되지 않는 존속력을 말한다. 불가변력이 인정되는 전형적인 예는 준사법적 행정행위, 즉 행정심판의 재결과 같이 사법절차에 준하여 쟁송절차를 거쳐 행해지는 행정행위를 들 수 있다.

⑵ 성질 및 존재이유

⑶ 효과

불가변력이 발생한 행정행위는 처분청 스스로 직권취소하거나 철회할 수 없고, 만약 직권취소나 철회를 하면 위법하다.

⑷ 불가변력의 적용영역

1) 준사법적 행위

준사법적 절차를 거쳐 행하여지는 행정행위(행정심판재결)에 불가변력을 인정하는 것이 통설과 판례이다.

귀속재산소청심의회의 판정은 재심 기타 특별한 사정이 없는 한 심의회 자신이 취소·변경할 수 없고, 관재국장 역시 위 판정의 취소·변경없이 그가 한 처분을 취소·변경할 수 없다(대판 1965.4.22, 63누200).

2) 확인행위

쟁송절차와 관계없는 확인행위(국가시험 합격자 결정)에도 불가변력을 인정하려는 학설과 그렇지 않다는 학설이 대립한다.

3) 수익적 행정행위에 있어서 취소권이나 철회권의 제한

이는 불가쟁력의 문제라기보다는 개별적인 경우에 있어서 당사자나 이해관계인의 신뢰보호의 필요성에서 인정되는 것이므로, 취소권이나 철회권의 제한문제로서 파악하여야 한다.

4) 법률의 규정에 의한 경우

법률의 규정 자체에 의해 행정기관이 더 이상 다툴 수 없게 되는 경우는 법률규정 자체에 의해 인정되는 효력이므로 불가변력과는 무관하다고 보아야 한다.

5) 공공복리를 이유로 하는 경우

4. 불가변력과 불가쟁력의 관계

⑴ 대상의 차이

⑵ 상호 교차관계

불가쟁력은 절차상의 문제에 불과하므로 불가쟁력이 발생한 행정행위도 불가변력이 발생하는 행위가 아닌 한, 행정기관에 의해 직권으로 취소·철회가 가능하다.

불가변력이 발생하는 행위도 쟁송기간이 경과하지 않거나 쟁송수단이 허용하는 한, 그 상대방이나 이해관계인이 쟁송을 제기하여 효력을 다툴 수 있다.

⑶ 성질의 차이

불가쟁력은 절차법적 효력이지만, 불가변력은 실체법적 효력에 속한다.

제3 행정벌

Ⅰ. 행정벌의 의의와 종류

1. 행정벌의 의의

행정벌이란 행정법상의 의무위반행위에 대하여 제재로서 가하는 처벌을 말한다. 행정벌은 과거의 의무위반에 대한 제재를 직접적인 목적으로 하지만 간접적으로 의무자에게 심리적 압박을 가함으로써 행정법상 의무이행을 확보하는 기능을 가진다.

2. 행정벌의 종류

행정벌에는 행정형벌과 행정질서벌이 있다.

행정형벌은 형법상의 형벌을 과하는 행정벌을 말한다. 행정형벌에는 원칙적으로 형법총칙이 적용되고 처벌은 형사소송법이 정하는 절차에 따른다. 다만, 예외적으로 간이처벌절차(즉결심판, 통고처분 등)가 인정된다.

행정질서벌은 과태료가 과하여지는 행정벌이다. 행정질서벌에는 국가의 법령에 근거한 것과 지방자치단체의 조례에 근거한 것이 있다. 과태료는 형벌과는 성질을 달리하는 것이므로 형법총칙이 적용되지 않고 처벌절차도 형사소송법에 의하지 않는다.

Ⅱ. 행정형벌과 행정질서벌이 부과되는 경우

어떤 공법상 의무 위반이 직접적으로 어떤 공익상 어떤 문제를 야기시킨 경우에는 행정형벌을 보통 부과 그렇지 않으면 과태료 부과한다. 국회의 입법 재량이다.

Ⅲ. 행정범과 형사범의 구별

1. 행정범과 형사범의 구별기준

2. 구별실익

Ⅳ. 행정형벌

1. 행정형벌과 형법총칙의 적용
형벌이니 형법 정책 원칙적으로 적용된다

2. 행정형벌의 과벌절차

⑴ 일반과벌절차
행정형벌은 원칙적으로 형사소송법의 절차에 따라 과해진다.

⑵ 통고처분(범칙금)

1) 의의 - 범칙금
통고처분이란 일반형사소송절차에 앞선 절차로서 일정한 위법행위의 범법자에게 범칙금을 납부토록 하고, 범칙자가 그 범칙금을 납부하면 처벌이 종료되는 과형절차를 말한다. 통고처분은 조세범(조세범처벌절차법 제9조), 관세범(관세법 제311조), 출입국사범(출입국관리법 제102조), 교통사범(도로교통법 제163조)의 경우에 적용된다.

2) 통고처분의 합헌성
통고처분 제도의 근거규정인 도로교통법 제118조 본문이 적법절차원칙이나 사법권을 법원에 둔 권력분립원칙에 위배된다거나, 재판청구권을 침해하는 것이라 할 수 없다(헌재 2003. 10. 30, 2002헌마275).

3) 통고처분의 의미
통고처분은 대량의 실정법의 위반사건을 신속하게 처리하는 의미를 갖는다. 통고처분은 법원의 부담을 완화하는 데 기여하고, 전문성을 가진 공무원에 의해 행정목적을 기술적·효율적으로 달성하는데 기여하고 국가수입의 확보에도 기여한다. 통고처분은 전과자의 발생의 방지에 기여한다.

4) 통고처분내용대로 이행된 경우
세무서장·(지방)국세청장·세관장·관세청장·출입국관리소장·경찰서장 등에게 통고처분을 받은 자가 그 통고에 따라 이행한 때에는 확정판결과 동일한 효력이 발생(불가변력)하게 되어 일사부재리의 원칙이 적용되므로 다시 소추하지 못한다(조세범처벌절차법, 관세법, 출입국관리법, 도로교통법, 경범죄처벌법).
통고처분이행기간이 경과하여도 고발하기 전이면 이행이 가능하다.

5) 통고처분내용대로 이행되지 않은 경우
만약 범칙자가 통고처분을 이행하지 않으면 권한행정청은 일정기간내에 검찰에 고발할 수 있고 이로써 일반과형절차인 형사소송절차로 넘어가게 된다.
검찰은 통고처분권자의 고발없이는 기소할 수 없다.

6) 통고처분의 불복
통고처분은 이행하지 아니하면 효력이 상실되어 형사소송절차에 의하여 다툴 수 있기 때문에 항고대상인 처분이 아니라는 것이 통설과 판례입장이다.

도로교통법 제118조에서 규정하는 경찰서장의 통고처분은 행정소송의 대상이 되는 행정처분이 아니므로 그 처분의 취소를 구하는 소송은 부적법하고, 도로교통법상의 통고처분을 받은 자가 그 처분에 대하여 이의가 있는 경우에는 통고처분에 따른 범칙금의 납부를 이행하지 아니함으로써 경찰서장의 즉결심판청구에 의하여 법원의 심판을 받을 수 있게 될 뿐이다(대판 1995. 6. 29, 95누4674).

Ⅴ. 행정질서벌

1. 의의

행정질서벌이라 함은 행정법규 위반에 대하여 과태료가 과하여지는 행정벌이다. 행정질서벌에 대한 일반법인 질서위반행위규제법에서는 질서위반행위를 '의무를 위반하여 과태료를 부과하는 행위'로 규정하고 있다(질서위반행위규제법 제2조 제1호).

2. 법적근거 - 질서위반행위규제법

2007. 12. 31. 행정질서벌에 관한 일반법인 질서행위위반규제법이 제정되어 2008. 6. 22부터 시행된다. 동법은 '과태료의 부과징수, 재판 및 집행 등의 절차에 관한 다른 법률의 규정 중 이 질서위반행위규제법의 규정에 저촉되는 것은 이 법이 정하는 바에 따른다'라고 규정하고 있다(동법 제5조).

3. 행정질서벌의 특수성

⑴ 형법총칙과 행정질서벌

과거 통설과 판례는 행정질서벌인 과태료는 형벌이 아니므로 행정질서법에는 형법총칙이 적용되지 않는다고 하였다(대판 1993. 11. 9, 93누16345). 그러나 질서위반행위규제법에 의하면 질서위반행위의 성립요건을 형법에 상응하도록 규정하고 있다.

⑵ 고의·과실의 요구(질서위반행위규제법 제7조)

의무 위반에 대한 어떤 고의 과실이 있어야 과태료 부과 가능하다.

⑶ 책임능력(동법 제9조, 제10조)

책임능력 없는 사람이 위반 했을때 과태료 부과를 못합니다.

⑷ 위법성의 착오(동법 제8조)

자신의 행위가 위법하지 아니한 것으로 오인하고 행한 질서위반행위는 그 오인에 정당한 이유가 있는 때에 한하여 과태료를 부과하지 아니한다.

⑸ 행정형벌과 행정질서벌의 병과 가능성

1) 문제점

동일한 행위에 대하여 행정형벌과 행정질서벌을 동시에 부과하는 것이 가능한가에 대하여 견해가 대립하고 있다.

2) 학설

① 행정질서벌은 형벌이 아닌 바 일사부재리에 반하지 않으므로 병과가능하다는 긍정설과 ② 행정형벌과 행정질서벌은 모두 행정벌이므로 일사부재리에 반하여 양자를 병과할 수 없다는 부정설이 있다.

3) 판례

대법원과 헌법재판소는 행정형벌과 행정질서벌은 모두 행정벌의 일종이지만 그 목적이나 성질이 다르므로 행정질서벌인 과태료부과처분 후 행정형벌을 부과한다고 하여도 일사부재리원칙에 반하는 것은 아니라고 보고 있다(대판 96도158. 헌재 92헌바38).

4) 검토

행정질서벌과 행정형벌은 그 내용과 부과절차 등이 다르므로 별개의 제도라고 보아야 한다. 따라서 긍정설이 타당하다.

⑹ 법인의 책임능력(동법 제11조 제1항)

⑺ 공범(동법 제12조)

⑻ 시효(동법 제15조)

4. 행정질서벌의 부과절차

⑴ 사전통지 및 의견제출(동법 제16조)

⑵ 과태료부과방식(동법 제17조)

⑶ 이의제기 등

행정청의 과태료 부과에 불복하는 당사자는 제17조 제1항에 따른 과태료 부과 통지를 받은 날부터 60일 이내에 해당 행정청에 서면으로 이의제기를 할 수 있다. 이의제기가 있는 경우에는 행정청의 과태료 부과처분은 그 효력을 상실한다(동법 제20조).

이의제기를 받은 행정청은 이의제기를 받은 날부터 14일 이내에 이에 대한 의견 및 증빙서류를 첨부하여 관할 법원에 통보하여야 하며 그로써 비송사건절차법에 의한 과태료재판절차로 이행된다(동법 제21조).

5. 행정질서벌의 불복절차

행정질서벌인 과태료는 원칙적으로 과태료에 처할 자의 주소지의 지방법원 또는 그 지원이 질서위반행위규제법에 따라 결정함으로써 부과한다(동법 제25조 내지 제37조). 법원의 과태료결정에 대하여 불복하는 자는 즉시항고를 할 수 있다(동법 제38조).

6. 행정질서벌의 징수

⑴ 이의제기가 없는 경우(법 제24조) - 가산금 및 국세징수법에 의한 체납처분

⑵ 상속·합병이 있는 경우(법 제24조의2) - 과태료를 부과받은 자가 이의의 제기 없이 기간이 종료한 후 사망한 경우 상속재산에서 징수할 수 있고, 과태료를 부과받은 법인이 이의의 제기없이 기간이 종료한 후 합병 등으로 소멸한 경우 합병 후 존속한 법인 또는 신설된 법인에 대하여 집행할 수 있다.

⑶ 법원의 재판으로 결정하는 경우(법 제42조) - 검사의 명령으로 집행

⑷ 과태료의 실효성 제고 - 관허사업제한, 정보제공, 감치(법 제52조, 제53조, 제54조)

7. 과태료의 귀속

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 국토해양부 소속 선박검사담당공무원 甲은 기관의 노후 등으로 화재의 위험이 있는 선박에 대하여 선박안전법에 의거 선박검사증서를 교부하였는데, 그 후 이 선박은 항해 도중 기관과열로 인하여 화재가 발생하여 승객 여러 명이 사망하게 되었다. 화재 사건이 유가족이 국가배상을 청구하고자 할 때 옳은 설명은? (2006 선관위 9급)

① 사망승객의 유가족들이 국가배상법에 따른 손해배상청구소송을 제기하기 위해서는 먼저 국가배상심의회의 심의를 반드시 거쳐야 한다.

② 국가가 손해배상책임을 부담하기 위해서는 공무원의 권한행사의 해태로 인하여 침해된 이익이 법률상 보호되는 이익이어야 한다는 것이 대법원의 입장이지만, 위 사건에서 선박안전검사는 단지 공공일반의 이익만을 위한 것이어서 국가의 손해배상책임이 인정되기 어렵다는 것이 판례의 입장이다.

③ 공무원의 책임과 관련하여 대법원은 공무원의 위법행위가 고의·중과실에 기한 경우에는 공무원의 민사상의 손해배상책임과 구상책임을 모두 인정하는 입장이므로, 이에 따르면 위 사건에서 공무원의 중과실이 인정되는 경우 유가족은 국가와 공무원에 대해서 선택적으로 배상청구를 할 수 있다.

④ 국가배상법에 따르는 손해배상청구는 소송실무에서 항고소송으로 다루어지고 있다.

⑤ 국가에 대하여 국가배상을 청구할 수 있을 뿐 공무원 개인에 대하여는 손해배상청구를 할 수 없다.

해설 & 정답

유형 준사례형

① 현행 국가배상법은 필요적 결정전치주의 원칙을 임의적 결정전치주의로 변경하였다(국가배상법 제9조).

② 선박안전법이나 「유선 및 도선업법」의 각 규정은 공공의 안전 외에 일반인의 인명과 재화의 안전보장도 그 목적으로 하는 것이라고 할 것이므로 국가 소속 선박검사관이나 시 소속공무원들이 직무상 의무를 위반하여 시설이 불량한 선박에 대하여 선박중간검사에 합격하였다 하여 선박검사증서를 발급하고, 해당 법규에 규정된 조치를 취함이 없이 계속 운항하게 함으로써 화재사고가 발생한 것이라면, 화재사고와 공무원들의 직무상 의무위반행위와의 사이에는 상당인과관계가 있다(대판 1993.2.12, 91다43466).

③⑤ 공무원이 직무수행 중 불법행위로 타인에게 손해를 입힌 경우에 국가 등이 국가배상책임을 부담하는 외에 공무원 개인도 고의 또는 중과실이 있는 경우에는 불법행위로 인한 손해배상책임을 진다고 할 것이지만, 공무원에게 경과실뿐인 경우에는 공무원 개인은 손해배상책임을 부담하지 아니한다고 해석하는 것이 헌법 제29조 제1항 본문과 단서 및 국가배상법 제2조의 입법취지에 조화되는 올바른 해석이다(대판 1996.2.15, 95다38677 全合).

④ 대법원은 "공무원의 직무상 불법행위로 손해를 받은 국민은 공무원자신에 대하여도 직접 그의 불법행위를 이유로 민사상의 손해배상을 청구할 수 있다(대판 1972.10.10, 69다701)"라고 판시하여 사권설의 입장을 따르고 있다.

정답 ③

2. 행정행위의 효력에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (2004 행정고시)

① 과세처분에 취소할 수 있는 위법사유가 있어 이미 납부한 조세에 대해 부당이득반환청구소송을 제기하였다면, 당해 민사법원은 과세처분의 위법성을 독자적으로 심리판단하여 인용판결을 할 수 없다는 것이 통설 및 판례의 입장이다.

② 불가변력은 당해 행정행위에 대해서만 인정되는 것이고, 동종의 행정행위라 하더라도 그 대상을 달리할 때에는 이를 인정할 수 없다는 것이 판례의 입장이다.

③ 공정력에 관한 학설 중 법적 안정성설이 다수견해이며, 이 설에 따르면 취소소송에서의 입증책임은 원고가 지게 된다.

④ 강제력은 행정행위를 통하여 의무를 부과하는 하명행위에서 문제되며, 형성적 행위는 그 대상이 되지 않는다.

⑤ 형사소송에서 행정행위의 효력유무가 선결문제가 되는 경우 당연무효가 아닌 한 형사법원은 직접 행정행위의 효력을 부인할 수 없다는 것이 판례의 입장이다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

자기 확인설의 입장에서는 공정력의 본질을 적법성의 법률상의 추정으로 이해하여, 취소소송의 입증책임이 원고에게 있다고 주장하나(원고책임설), 입증책임은 공정력과 무관하므로 민사소송상의 입증책임분배의 원칙(법률요건분류설)에 의한다는 것이 통설이다(입증책임무관설).

대법원도 "민사소송법의 규정이 준용되는 행정소송에 있어서 입증책임은 원칙적으로 민사소송의 일반원칙에 따라 당사자 간에 분배되고 항고소송의 특성에 따라 당해 처분의 적법을 주장하는 피고에게 그 적법사유에 대한 입증책임이 있다고 하는 것이 당원의 일관된 견해이므로 피고가 주장하는 당해 처분의 적법성이 합리적으로 수긍할 수 있는 일응의 입증이 있는 경우에는 그 처분은 정당하다고 할 것이며 위와 같은 합리적으로 수긍할 수 있는 증거와 상반되는 주장과 입증은 그 상대방인 원고에게 그 책임이 돌아간다고 풀이하여야 할 것이다(대판 1984.7.24, 84누124)"라 판시하여 입증책임 무관설의 입장에 따른다.

정답 ③

3. 행정행위의 효력에 관한 설명으로 가장 옳은 것은? (2004 입법고시)

① 발령기관의 표시가 없는 행위라도 내용적 구속력이 있다.

② 공정력이 있기 때문에 항고소송의 원고가 처분의 위법을 입증하여야 한다.

③ 이른바 구성요건적 효력이란 처분의 실체적 진실 또는 구체적 타당성을 확보하기 위하여 인정되는 효력이다.

④ 불가변력 있는 행정행위라도 하자를 발견한 처분청은 이를 취소할 수 있다.

⑤ 행정행위의 불가쟁력이 발생한 경우에도 국가배상소송을 제기할 수 있다.

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 행정행위에 처분청의 서명이나 날인을 요구하는 것은 책임의 소재와 범위를 명확히 하기위한 것이므로, 이를 결한 행정행위는 무효이다.

② 공정력과 입증책임의 분배와는 무관하고, 민사소송의 원칙인 법률요건분류설에 의하는 것이 다수설과 판례이다.

③ 구성요건적 효력이란 유효한 행정행위가 존재하는 이상 다른 국가기관은 그의 존재를 존중하며 스스로의 판단의 기초 내지는 구성요건으로 삼아야 하는 효력으로서 실체적 진실이나 구체적 타당성 확보와는 무관하다.

④ 불가변력은 개념 그대로 처분청도 함부로 행정행위를 변경(취소 또는 철회)할 수 없는 효력을 말한다. 다만, 불가쟁력이 발생한 행정행위의 경우 불가변력이 발생하지 않는 한 처분청이 취소할 수 있다.

⑤ 취소소송은 처분이 있음을 안 날로부터 90일, 처분이 있은 날로부터 1년 이내에 제기해야 하지만, 국가배상청구소송은 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년 이내에 제기하면 된다. 따라서 취소소송의 불가쟁력이 발생하더라도 3년이 경과하지 않았다면 국가배상소송을 제기할 수 있다.

정답 ⑤

♣ 학습내용 정리

1. 부작위에 대한 국가배상에서 판례는 조리에 의한 작위의무를 인정하는 입장이다.
2. 불가쟁력과 불가변력은 법적 안정성 때문에 인정되는 효력이다.
3. 행정질서벌에는 일반법으로 질서위반행위규제법이 있다.

제43강 행정법총론 총 복습

♣ 학습목표

지금까지 학습하였던 행정법총론 전체에 대하여 복습한다.

♣ 학습내용

행정법총론 전체 개관

♣ 사전테스트

1. 행정조직법은 행정주체와 국민간의 관계를 규율하는 법이다.
   정답 : X

2. 행정행위에 대한 권리구제수단으로 민사집행법상 가처분이 일반적으로 인정된다.
   정답 : x

3. 적법한 공권력행사로 인한 재산권에 대한 특별한 희생이 발생한 경우 손실보상이 인정된다.
   정답 : O

♣ 돌발퀴즈

판례에 의하면 수익적 행정처분을 신청한 자는 비록 신청권이 없는 경우에도 그 거부에 대하여는 거부처분취소소송으로 제기할 원고적격이 당연히 인정된다.

[정답] ×

[해설] 행정청이 국민의 신청에 대하여 한 거부행위가 항고소송의 대상이 되는 행정처분이 된다고 하기 위하여는 국민이 그 신청에 따른 행정행위를 요구할 수 있는 법규상 또는 조리상의 권리가 있어야 하고 이러한 권리에 의하지 아니한 국민의 신청을 행정관청이 받아들이지 아니하고 거부한 경우에는 이로 인하여 신청인의 권리나 법적 이익에 어떤 영향을 주는 것이 아니므로 그 거부행위를 가리켜 항고소송의 대상이 되는 행정처분이라고 할 수 없다(대판 2006.6.30, 2004두701).

♣ 강의내용

제1 행정구제 개관

I. 문제되는 행정작용이 처분인 경우 처분에 대한 쟁송

1. 항고소송

⑴ 적극적 처분인 경우(1,3유형)

1) 적극적 처분이 나오기전
무명항고소송으로 예방적 부작위소송인정여부

2) 적극적 처분이 나온 후
가) 취소소송
나) 무효 등 확인소송

⑵ 처분에 대한 거부나 부작위(2,4유형)

1) 무명항고소송으로 의무이행소송인정여부

2) 거부처분 - 거부처분취소소송/무효확인소송

3) 부작위 - 부작위위법확인소송

2. 행정심판

⑴ 적극적 처분인 경우(1,3유형)

1) 취소심판

2) 무효 등 확인심판

⑵ 처분에 대한 거부나 부작위(2,4유형)

1) 거부처분취소심판, 무효확인심판

2) 의무이행심판

3. 가구제

⑴ 항고소송에서의 가구제

1) 적극적 처분이 발령되거나 거부처분인 경우 - 집행정지

2) 적극적 처분이 발령되기전이나 거부처분, 부작위
- 민사집행법상 가처분준용여부

⑵ 행정심판에서의 가구제

1) 적극적 처분이 발령된 경우 - 집행정지
적극적 처분에 대해서 취소 무효등 취소심판이나 무효등하기 심판제 예기하면서
집행 정지라는 가구제 수단을 행정심판법 30조에 따라 할 수 있다

2) 거부처분이나 부작위 - 임시처분제도
행정심판법 31조에 규정

II. 문제되는 행정작용이 처분이 아닌 경우에 대한 쟁송
당사자소송(이행소송 / 확인소송)

III. 처분이나 비권력적 행정작용 등 모든 공법작용으로 인해 발생한 결과

1. 금전적 피해

⑴ 위법 / 고의 또는 과실 - 국가배상청구권

⑵ 적법 / 무과실 특별희생

1) 재산권침해 - 손실보상청구권

2) 비재산권침해 - 희생보상청구권

2. 위법한 상태 - 공법상 결과제거청구권

제2 행정작용의 실무예

I. 행정입법

1. 법규명령

⑴ 법률대위명령
긴급명령, 긴급재정경제명령

⑵ 법률종속명령(위임명령, 집행명령)
시행령(대통령령),
시행규칙(총리령, 부령),
~규정(공무원보수규정, 승진규정, 행정권한의위임및위탁에관한규정 - 대부분 대통령령이다)

2. 행정규칙

훈령, 예규, 지침, 고시 등

3. 법규명령형식의 행정규칙

시행령, 시행규칙조항 중 영업정지나 허가취소 등 의무위반에 대한 제재처분의 기준을 정하고 있거나 과징금액수의 기준을 정하고 있으면 그 시행령, 시행규칙조항은 법규명령형식의 행정규칙이다.

4. 법령보충규칙

형식은 훈령, 예규, 지침, 고시인데 상위법령의 수권이 있고('~에 관한 사항은 보건복지가족부장관이 정한다','~에 관한 사항은 보건복지가족부장관고시로 정한다'), 국민의 권리의무에 관한 사항을 규율하면 법령보충규칙이다.

5. 고시

- 구체적 사실에 대하여 규율 : 일반처분(청소년유해매체물결정 및 고시처분, 보건복지부 고시인 약제급여·비급여목록 및 급여상한금액표)
- 추상적 규율 : 상위 법령의 수권여부에 따라 행정규칙 또는 법령보충규칙(공장입지기준고시)

II. 행정행위 - 후술

III. 부관

1. 강학상 부관인가?

⑴ 법령에서 당해 조건이나 기한의 내용을 일의적으로 규정한 경우(근거법문언에 '광업허가의 유효기간은 20년이다'라고 규정된 경우) : 법정부관

⑵ 법령에서 조건이나 기한을 규정하고 있으나 그 내용을 일의적으로 규정하지 않은 경우(근거법문언에 '허가시 3년이내의 기한을 붙일 수 있다'라고 규정된 경우) : 강학상 부관

2. 강학상 부관의 종류

⑴ 기한부 행정행위에서의 기한

강학상 기한으로 종기다. 단 장기계속성있는 사업에서 부당히 짧은 기한이라면 허가조건의 존속기한이고 그렇지 않으면 허가의 존속기한이다.

⑵ 조건부 행정행위에서의 조건

강학상 조건, 철회권유보, 부담, 사후부담유보, 법률효과일부배제 중 어느 것인지를 써주면 된다.

특히 당해 사안에서의 조건이 기한이나 철회권유보, 법률효과일부배제, 사후부담유보가 아니면 강학상 조건 아니면 부담인 바, 이에 대해선 조건과 부담의 구별기준에 대한 학설과 판례를 써주어야 한다. 그런데 일반적으로 요건보충적 부관은 정지조건으로 해석되고, '취소할 수 있다'는 조건은 강학상 철회권유보이고, 영업구역조건 및 격일제조건, 소유권귀속조건은 강학상 법률효과일부배제이고, '나중에 ~하면 기부채납조건을 부가할 수 있다'는 조건은 사후부담유보이고, 그 이외의 조건, 예컨대 기부채납조건은 강학상 부담이다

Ⅳ. 직권취소와 철회 - 취소

음주운전으로 인한 운전면허 취소 운전면허 수속 처분

Ⅴ. 확약

보통 실무에서는 국민의 서면문의에 대한 '회신'의 형식으로 이루어진다. 그리고 그 내용은 '~ 특허 등을 해주겠다'이다.

Ⅵ. 공법상 계약

지방 전문직 공무원, 공중보건, 국립 무용단원에 대한 채용

Ⅶ. 행정상 사실행위

1. 권력적 사실행위

교도소이송조치,

서신검열,

단수조치.

단, 즉시강제(강제격리, 총기사용, 전염병환자강제격리 등), 직접강제(영업소폐쇄조치), 대집행실행, 세무조사 등도 권력적 사실행위이나 이에 대해선 먼저 당해 행정작용이 즉시강제 등인지를 서술하고 즉시강제 등의 법적성질에서 권력적 사실행위임을 서술하여야 한다.

2. 비권력적 사실행위

경고, 추천 등. 단 경고 중에 금융기관의 임원에 대한 문책경고는 그 상대방에게 은행법 및 관련규정에 의해 3년간 은행장의 취임제한 등 직업선택의 자유를 직접 제한하는 효과를 발생시키는 바 행정처분에 해당한다((출처 : 대법원 2005. 2. 17. 선고 2003두14765 판결).

3. 행정지도

권고, 요망, 요청, 지도

4. 경고

서면경고, 문책경고

Ⅷ. 행정계획

도시군관리계획결정, 도시군계획시설결정

각종 지구결정(문화재보존지구, 습지보전지구 등),

Ⅸ. 행정의 실효성 확보수단

1. 공법상 의무불이행시 의무이행확보수단

⑴ 직접적 수단 - 행정상 강제집행

1) 대집행

계고처분, 대집행영장통지, 대집행실행, 비용납부명령

2) 이행강제금 - 독촉

3) 직접강제
강제퇴거조치,
영업소폐쇄조치

4) 강제징수
독촉, 체납처분(압류, 공매, 청산)

⑵ 간접적 수단 - 행정벌
행정형벌(징역이나 벌금)
행정질서벌(과태료부과처분)

⑵ 새로운 수단

1) 과징금 및 부과금
본래적 의미의 과징금 : 공정거래법 및 청소년보호법상 과징금
변형된 의미의 과징금 : 식품위생법 등 각종 법률상 영업정지나 영업허가취소처분에 갈음하는 과징금.
부과금 : 환경법상의 배출부과금

2) 위반사실의 공표
건축법상 위반건축물표지설치행위 등

3) 관허사업제한
공법상 의무위반에 대하여 각종 개별법 및 국세징수법 제7조에 의한 허가거부처분 또는 영업정지 또는 영업허가취소처분

2. 공익상 장애제거수단 - 즉시강제
경직법상의 보호조치, 무기사용, 수갑 등 경찰장구의 사용 등,
감염병환자의 강제격리, 강제건강진단 등,
소방법상의 강제처분,
도로교통법상의 불법주정차차량 강제견인, 교통장해물의 제거,
식품위생법 등에 의한 물건의 폐기, 수거조치 등

3. 자료나 정보수집활동 - 행정조사
국세청의 세무조사, 통계청의 인구조사
식품위생법 및 공중위생법상 출입검사,
토지보상법상 타인토지출입행위 등

제3 행정행위의 종류

I. 법률효과의 발생원인에 따라

1. 법률행위적 행정행위
⑴ 명령적 행정행위

1) 하명
원상회복명령, 철거명령(작위하명),
영업정지처분(부작위하명),
조세부과처분, 이행강제금 및 과징금부과처분(급부하명),
전염병환자강제격리(수인하명)

2) 허가
① 양곡가공업허가 (대판 1981. 1. 27, 79누433)
② 주유소설치허가 (대판 1999. 4. 23, 97누14378) - 지금은 등록제로 변경되었다.
③ 건축허가 (대판 1979. 10. 30, 79누190)
④ 전자유기장업허가 (대판 1985. 2. 8, 84누369)
⑤ 대중음식점영업허가 (대판 1993. 5. 27, 93누2216)
⑥ 식품접객업허가 (대판 1999. 3. 9, 98두19070)
⑦ 주류판매업허가 (대판 1995. 11. 10, 95누5714)
기타 한의사, 약사, 의사면허, 자동차운전면허, 공중목욕장허가 등
- 예외적 승인(허가)
의사의 마약사용면허,
학교보건법상 학교정화구역내에서의 유해시설 금지해제조치,
개발제한구역내에서의 건축 및 토지형질변경허가 등

3) 면제
군면제처분, 면세처분

⑵ 형성적 행정행위

1) 특허
「권리」설정행위로서의 특허
광업허가,
어업면허,
자동차·해상·항만·항공 등 각종 운수사업면허(개인택시, 버스, 화물자동차, 여객선, 항공기 노선면허 등)
보세구역설치경영특허,
특허기업특허(이동통신사업면허, 방송면허),
공유수면매립면허,
공물사용권특허(도로점용허가, 하천점용허가 등),
각종 사업계획승인(주택건설사업계획승인 등)
「포괄적 법률관계」설정행위
공무원임명, ·귀화허가
능력설정행위
재건축조합설립인가(판례, 강학상 인가와 광의의 특허의 성질을 동시에 지닌다)

2) 인가
비영리법인 설립허가 및 정관변경인가,
공공조합(재개발조합, 재건축조합) 설립인가,
특정기업(버스, 택시, 항공기)의 운임 ·요금 인가,

사립학교법인 이사취임승인,
외국인 토지취득허가,
토지거래허가구역 내에서의 토지거래허가

3) 공법상 대리
토지보상법상의 수용재결

2. 준법률행위적 행정행위

⑴ 확인
국가시험합격결정,
발명특허,
소득세부과를 위한 소득금액확인,
행정심판의 재결,
교과서 검정.
친일파재산조사결정

⑵ 공증
공증에는 부동산등기부·외국인등록부와 같은 등기부·등록부에의 등기·등록 또는 선거인명부·토지대장·가옥대장·광업원부와 같은 각종의 명부·장부 등에의 등재, 회의록 등에의 기재, 당선증서·합격증서와 같은 각종의 증명서발급, 영수증교부, 여권 등의 발급, 검인·증인의 압날 등이 있다.
판례는 건축물대장작성신청반려행위와 무허가건물관리대장 삭제행위 및 건축물대장상의 용도변경신청 거부행위에 대하여 처분성을 인정하였다.

⑶ 통지
행정대집행법상의 계고처분, 대집행영장의 통지,
국세징수법상의 독촉.

⑷ 수리
사표수리,
어업신고수리,
건축주명의변경신고수리,
국적이탈신고수리,
각종 등록신청에 대한 수리.

Ⅱ. 상대방의 협력이 필요한가에 따라

1. 쌍방적 행정행위

⑴ 상대방의 신청을 요하는 행정행위
강학상 허가, 협의의 특허(권리설정행위), 인가, 수리, 예외적 허가, 보조금지급결정,

⑵ 상대방의 동의를 요하는 행정행위
공무원임명.

2. 일방적 행정행위
각종 하명, 직권취소와 철회 등.

III. 효과결정에 있어서 자유가 있는가에 따라

1. 기속행위

⑴ 강학상 허가
① 건축법상 건축허가(대판 1995. 12. 12, 95누9051)
단, 개발제한구역내의 건축허가 및 숙박위락시설 건축허가(건축법 제8조 제5항 참조) 및 개발허가가 의제되는 건축허가는 재량행위
② 공중위생법상 위생접객업허가(대판97누12532)
③ 총포·도검·화약류 판매업허가 (대판96누3036)
④ 석유판매업허가 (대판 1995. 3. 10, 94누8556) - 현재는 등록제임
⑤ 식품위생법상 대중음식점허가 (대판93누2216)★

⑵ 법령규정 및 해석상 기속행위
① 금고이상 형을 받은 자에 대한 약사법상 약사면허의 취소 (대판 1993. 6. 8, 92누19026)
② 국유재산의 무단점유 등에 대한 변상금의 징수(대판 2000. 1. 28, 97누4098)
③ 자동차운송알선사업등록처분(대판 1993. 7. 27, 92누13998)
④ 보충역에 해당하는 사람을 공익근무요원으로 소집하는 행위(대판 2002. 8. 23, 2002두820)

⑶ 강학상 수리처분
구 건축법상 용도변경신고수리(2005두17201 판결).
구 관광진흥법상 관광사업의 지위승계신고(2006두4097 판결).

2. 재량행위의 예

⑴ 강학상 특허
① 개인택시 운송사업면허 (대판 1995. 4. 14, 93누16253)
② 어업면허 (대판 1996. 6. 11, 95누10358)
④ 구 토지수용법상 토지수용을 위한 사업인정 (대판 1992. 11. 13, 92누596)
⑤ 공유수면매립면허 (대판 1989. 9. 12, 88누9206)
⑥ 마을버스운송사업면허 (대판 2001. 1. 19, 99두3812)
⑦ 하천부지점용허가 (대판 1991. 10. 11, 90누8688)
⑧ 중소기업창업사업계획승인 (대판94누1289)
귀화허가

⑵ 강학상 인가
① 주택조합설립인가 (대판 1995. 12. 12, 94누12302)
② 비영리법인설립허가 (대판 1996. 9. 10, 95누18437)
③ 재단법인정관변경허가 (대판 1996. 5. 16, 95누4810)
재단법인 임원취임승인

⑶ 공무원에 대한 징계처분 등
① 공무원에 대한 징계처분 (대판91누4102 등)
② 국립대학생에 대한 징계처분 (대판91누2144)

⑷ 기타
① 도시계획결정(대판 1996. 11. 29, 96누8567) - 계획재량
② 감정평가사시험 합격기준선택 (대판 1996. 9. 20, 96누6882) - 판례는 요건판단에 있어서 판단여지를 재량과 구별하지 않고 있다.
③ 관광지조성사업시행허가 (대판 2001. 7. 27, 99두8589)
④ 자연공원사업의 시행에 있어서 그 공원의 시설기본설계 및 변경설계승인 (대판 2001. 7. 27, 99두2970)
⑤ 자연공원사업시행허가 (대판 2001. 7. 27, 99두5092)
⑥ 청원경찰면직처분 (대판 2002. 2. 8, 2000두4057)
⑦ 임용기간 만료된 대학교원의 재임용여부 (대판 1997. 6. 27, 96누4305)
⑧ 사립대학이 공립대학으로 설립자변경된 경우 공립학교교원으로의 임용여부 (대판 1997. 4. 25, 96누3654)
⑩ 개발제한구역내의 건축물의 용도변경허가 (대판 2001. 2. 9, 98두17593)
⑬ 문화재보호법상 고분발굴허가 : 판단여지 (대판, 99두264)
⑮ 사법시험문제출제행위 및 채점행위 : 판단여지
보건복지부장관의 요양급여대상 약제에 대한 상한금액조정고시

Ⅳ. 법률효과에 따라

1. 수익적 행정행위

2. 침익적 행정행위

3. 복효적 행정행위

Ⅴ. 규율의 대상에 따라

1. 대인적 행정행위
국가고시합격자 결정, 자동차운전면허, 인간문화재 지정, 의사, 한의사, 약사면허 등

2. 대물적 행정행위
건물준공검사, 자동차검사증 교부, 자연공원 지정, 건축허가

3. 혼합적 행정행위
총포제조영업허가, 유흥주점영업허가, 전당포업허가, 개인택시면허 등.

Ⅵ. 행정행위의 효력발생에 따라

1. 수령을 요하는 행정행위

2. 수령을 요하지 않는 행정행위

제4 행정행위의 위법판단구조

I. 기속행위의 위법여부

1. 법률유보원칙위반여부
법률유보원칙 법률의 근거 없는가를 먼저 살펴본다.

2. 법률우위원칙위반여부

⑴ 선결적으로 검토하여야 하는 부분

1) 위법판단의 기준시
처분시이후(또는 소송도중) 사실상태나 법령이 변경된 경우에만 써주면 된다.

2) 처분사유추가변경의 허용여부
사안에서 소송도중 처분시 이유부기에서 제시한 처분사유인 법적근거와 사실적 기초를 피고가 변경한 경우에만 써주면 된다.

3) 당해 처분이 취소판결의 기속력에 반하는지
사안에서 취소확정판결이 있은 후 동일한 처분이 나온 경우에만 서술할 필요있음.

⑵ 주체의 하자
행정행위는 정당한 권한을 가진 행정기관에 의해 그의 권한 내에서 정상적인 의사에 기하여 행하여져야 한다.
- 권한의 내부위임시 수임청 명의로 한 경우 위법여부 및 정도
- 사실상 공무원이론
- 다른 행정기관의 동의, 의결, 심의, 협의를 안 거친 경우

⑶ 형식상 하자 - 행정절차법 제24조 : 문서

⑷ 내용상 하자

1) 근거법령이 위헌위법인지
기속행위로 규정한 법률의 내용이 위헌인 경우에는 위헌법률심판에 의해, 기속행위로 규정한 법규명령이 위헌위법인 경우에는 위헌위법명령규칙심사에 의해 당해 법률과 법규명령의 효력을 제거한 후, 당해 기속행위의 위법성을 인정하면 된다.

2) 내용상 성문법위반여부
특히 여기서 중요한 것은 내용상 요건위반여부일 것이다. 단지 요건이 불확정개념이고 고도의 가치평가 예측 전문영역이라면 요건포섭에 행정청에게 판단여지가 인정되는 바 판단여지와 재량과의 구별에 대한 학설과 판례를 검토한 후 당해 사안에서의 행정청의 요건포섭이 판단여지의 한계(재량의 한계와 유사)를 벗어난 위법한 것인지를 검토하면 된다

3) 확약 및 사전결정이 있는 경우 확약 및 사전결정의 구속력에 반하는지

4) 신의성실원칙, 실권의 법리, 신뢰보호원칙위반여부

신청시 법령에서는 요건을 갖추었으나 정당한 사유없이 처리를 지연하다가 법령이 개정되어 개정된 법령에 따라 처분한 경우 - 신의성실원칙 위반여부

강학상 철회나 취소인 경우 장기간 방치한 상태 - 실권의 법리위반여부

선행조치가 있는 경우 - 신뢰보호원칙위반여부

⑸ 절차상 하자[1)]

개별절차조항위반여부 - 행정절차법위반여부(물론 항상 각 법에 기재된 예외사유해당여부는 검토하여야 한다)

그리고 절차상 하자가 독자적 위법사유가 되는지 여부를 검토하고, 위법성의 정도가 취소사유이고 사후보완행위가 있는 경우에는 절차상 하자의 치유여부를 검토하여야 한다.

Ⅱ. 재량행위의 위법여부

1. 법률유보원칙위반여부

⑴ 수익적 행정작용의 경우(특히 보조금지급결정)[2)]

- 이때에만 법률유보원칙에 대한 단문목차를 써줄 필요가 있다. 밑에 있는 사안들은 모두 별도의 학설의 논의가 있는 바 이에 대해서만 서술하면 된다.

⑵ 강학상 철회인 경우[3)]

⑶ 경찰관 직무집행법 제2조 제6호가 법적 근거가 될 수 있는지 여부(일반조항 인정여부)[4)]

2. 법률우위원칙위반여부

⑴ 선결적으로 검토하여야 하는 부분

1) 위법판단의 기준시

처분시이후(또는 소송도중) 사실상태나 법령이 변경된 경우에만 써주면 된다.

2) 처분사유추가변경의 허용여부

사안에서 소송도중 처분시 이유부기에서 제시한 처분사유인 법적근거와 사실적 기초를 피고가 변경한 경우에만 써주면 된다.

3) 당해 처분이 취소판결의 기속력에 반하는지

사안에서 취소확정판결이 있은 후 동일한 처분이 나온 경우에만 서술할 필요있음.

---

1) 파트 43
2) 파트 44
3) 파트 45
4) 파트 46

⑵ 주체의 하자 - 기속행위

행정행위는 정당한 권한을 가진 행정기관에 의해 그의 권한 내에서 정상적인 의사에 기하여 행하여져야 한다.

- 권한의 내부위임시 수임청 명의로 한 경우 위법여부 및 정도
- 사실상 공무원이론
- 다른 행정기관의 동의, 의결, 심의, 협의를 안 거친 경우

⑶ 형식상 하자 - 행정절차법 제24조 : 문서

⑷ 내용상 하자

1) 근거법령이 위헌위법인지

재량행위로 규정한 법률의 내용이 위헌인 경우에는 위헌법률심판에 의해, 재량행위로 규정한 법규명령이 위헌위법인 경우에는 위헌위법명령규칙심사에 의해 당해 법률과 법규명령의 효력을 제거한 후, 당해 재량행위의 위법성을 인정하면 된다.

2) 내용상 요건규정 위반여부[5)]

단지 요건이 불확정개념이고 고도의 가치평가 예측 전문영역이라면 요건포섭에 행정청에게 판단여지가 인정되는 바 판단여지와 재량과의 구별에 대한 학설과 판례를 검토한 후 당해 사안에서의 행정청의 요건포섭이 판단여지의 한계(재량의 한계와 유사)를 벗어난 위법한 것인지를 검토하면 된다(예컨대 직위해재처분과 직권면직처분의 요건사실은 '직무수행능력부족' 등).[6)]

3) 재량의 한계 위반여부

가) 재량의 0으로 수축(생명, 신체 등 중대한 법익에 대한 구체적 위해가 존재하는 경우)

나) 확약 및 사전결정이 있는 경우 확약 및 사전결정의 구속력에 반하는지

다) 신의성실원칙, 실권의 법리, 신뢰보호원칙위반여부

신청시 법령에서는 요건을 갖추었으나 정당한 사유없이 처리를 지연하다가 법령이 개정되어 개정된 법령에 따라 처분한 경우 - 신의성실원칙 위반여부

강학상 철회나 취소인 경우 장기간 방치한 상태 - 실권의 법리위반여부

선행조치가 있는 경우 - 신뢰보호원칙위반여부

라) 재량의 하자

a) 재량의 일탈 - 외적 한계위반

b) 재량의 남용

- 비례원칙 : 경찰행정작용 및 공무원 징계처분, 사업인정에서 특히 문제된다.
- 평등원칙, 자기구속의 원칙 :
- 부당결부금지의 원칙 : 부관, 관허사업의 제한 등에서 특히 문제된다.
- 목적위반, 동기부정
- 사실오인

c) 재량권의 불행사 및 해태

---

5) 예컨대, 영업정지처분이 재량행위라고 할 경우, 갑이 법상 영업정지사유에 해당하지 않음에도 불구하고 행정청이 법상 영업정지요건을 잘못 해석하여 영업정지처분을 내렸다면 당해 처분은 재량의 일탈 남용으로 위법한 것이 아니라 당해 법조문 위반으로 위법한 것이 된다.

6) 파트 47

⑸ 절차상 하자

개별절차조항위반여부 - 행정절차법위반여부(물론 항상 각 법에 기재된 예외사유해당여부는 검토하여야 한다)

그리고 절차상 하자가 독자적 위법사유가 되는지 여부를 검토하고, 위법성의 정도가 취소사유이고 사후보완행위가 있는 경우에는 절차상 하자의 치유여부를 검토하여야 한다.

♣ 퀴즈!퀴즈!

1. 다음 중 판례에 의할 때 취소소송의 대상이 될 수 없는 것은? (2006 세무사)

㉠ 도시계획결정	㉡ 행정행위
㉢ 자기완결적 신고의 거부	㉣ 국세환급거부결정
㉤ 개별공시지가결정	

① ㉠, ㉢ ② ㉢, ㉣
③ ㉠, ㉢, ㉤ ④ ㉠, ㉡, ㉣
⑤ ㉢, ㉣, ㉤

해설 & 정답

유형 법률지식형

㉢ 수리를 요하는 신고의 수리나 거부는 처분인 것과 달리 자기완결적 신고는 신고만으로 효과가 완성되므로 그에 대한 수리나 수리거부는 처분이 아니다.

㉣ 국세기본법 제51조 및 제52조 국세환급금 및 국세가산금결정에 관한 규정은 이미 납세의무자의 환급청구권이 확정된 국세환급금 및 가산금에 대하여 내부적 사무처리절차로서 과세관청의 환급절차를 규정한 것에 지나지 않고 그 규정에 의한 국세환급금(가산금 포함)결정에 의하여 비로소 환급청구권이 확정되는 것은 아니므로, 국세환급금결정이나 이 결정을 구하는 신청에 대한 환급거부결정 등은 납세의무자가 갖는 환급청구권의 존부나 범위에 구체적이고 직접적인 영향을 미치는 처분이 아니어서 항고소송의 대상이 되는 처분이라고 볼 수 없다(대판 1989.6.15, 88누6436 全合).

정답 ②

2. 다음 중 항고소송의 대상인 처분에 해당하는 것을 모두 고른 것은? (판례에 의함)

㉠ 구 도시재개발법상 재개발조합의 관리처분계획
㉡ 한국전력공사가 구 정부투자기관회계규정에 의하여 행한 입찰참가자격을 제한하는 부정당업자 제재
㉢ 전통사찰의 등록말소신청에 대한 거부
㉣ 병역처분의 자료로 군의관이 행한 신체등위판정
㉤「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 공정거래위원회의 고발조치

① ㉠ ② ㉠, ㉡
③ ㉡, ㉣ ④ ㉢, ㉤
⑤ ㉢, ㉣, ㉤

해설 & 정답

유형 법률지식형

㉠ 도시재개발법에 의한 재개발조합은 조합원에 대한 법률관계에서 적어도 특수한 존립목적을 부여받은 특수한 행정주체로서 국가의 감독하에 그 존립목적인 특정한 공공사무를 행하고 있다고 볼 수 있는 범위 내에서는 공법상의 권리의무관계에 서 있는 것이므로 분양신청 후에 정하여진 관리처분계획의 내용에 관하여 다툼이 있는 경우에는 그 관리처분계획은 토지 등의 소유자에게 구체적이고 결정적인 영향을 미치는 것으로서 조합이 행한 처분에 해당하므로 항고소송의 방법으로 그 무효확인이나 취소를 구할 수 있다(대판 2002.12.10, 2001두6333).

㉣ 한국전력공사가 정부투자기관회계규정에 의하여 행한 입찰참가자격을 제한하는 내용의 부정당업자제재처분은 행정소송의 대상이 되는 행정처분이 아니라 단지 상대방을 위 공사가 시행하는 입찰에 참가시키지 않겠다는 뜻의 사법상의 효력을 가지는 통지행위에 불과하다(대결 1999.11.26, 99부3).

㉤ 전통사찰의 등록은 소관 부처의 장관이 사찰관계전문가의 의견을 들어 역사적 의의를 가진 전통사찰이라고 지정한 다음 그 사실을 당해 사찰의 주지에게 통지하여 그 주지로 하여금 등록신청을 하게 함으로써 이루어지는 것으로서 이와 같이 지정된 전통사찰에 대하여 그 등록의 말소를 신청할 법규상의 근거는 없고, 조리상으로도 그러한 신청권이 인정된다고 할 수 없으므로, 전통사찰의 등록말소신청을 거부한 행정청의 거부회신이 항고소송의 대상이 되는 거부처분에 해당하지 아니한다(대판 1999.9.3, 97누13641).

㉥ 병역법상 신체등위판정은 행정청이라고 볼 수 없는 군의관이 하도록 되어 있으며, 그 자체만으로 바로 병역법상의 권리의무가 정하여지는 것이 아니라 그에 따라 지방병무청장이 병역처분을 함으로써 비로소 병역의무의 종류가 정하여지는 것이므로 항고소송의 대상이 되는 행정처분이라 보기 어렵다(대판 1993.8.27, 93누3356).

㉦ 이른바 고발은 수사의 단서에 불과할 뿐 그 자체 국민의 권리의무에 어떤 영향을 미치는 것이 아니고, 특히 독점규제및공정거래에관한법률 제71조는 공정거래위원회의 고발을 위 법률위반죄의 소추요건으로 규정하고 있어 공정거래위원회의 고발조치는 사직 당국에 대하여 형벌권 행사를 요구하는 행정기관 상호간의 행위에 불과하여 항고소송의 대상이 되는 행정처분이라 할 수 없으며, 더욱이 공정거래위원회의 고발 의결은 행정청 내부의 의사결정에 불과할 뿐 최종적인 처분은 아닌 것이므로 이 역시 항고소송의 대상이 되는 행정처분이 되지 못한다(대판 1995.5.12, 94누13794).

정답 ①

3. 판례상 항고소송의 대상이 되는 처분이 아닌 것은? (2008 세무사)

① 두밀분교설치폐지조례
② 관할행정청이 전기·전화공급자에게 그 위법 건축물에 대한 전기·전화 공급을 하지 말아 줄 것을 요청한 행위
③ 국유재산 무단점유자에 대한 변상금부과처분
④ 지적법령상의 토지분할신청에 대한 거부행위
⑤ 지방의회 의장에 대한 불신임의결

해설 & 정답

유형 법률지식형

① 조례가 집행행위의 개입 없이도 그 자체로서 직접 국민의 구체적인 권리의무나 법적 이익에 영향을 미치는 등의 법률상 효과를 발생하는 경우 그 조례는 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다(대판 1996.9.20, 95누8003).

② 건축법 제69조 제2항, 제3항의 규정에 비추어 보면, 행정청이 위법 건축물에 대한 시정명령을 하고 나서 위반자가 이를 이행하지 아니하여 전기·전화의 공급자에게 그 위법 건축물에 대한 전기·전화공급을 하지 말아 줄 것을 요청한 행위는 권고적 성격의 행위에 불과한 것으로서 전기·전화공급자나 특정인의 법률상 지위에 직접적인 변동을 가져오는 것은 아니므로 이를 항고소송의 대상이 되는 행정처분이라고 볼 수 없다(대판 1996.3.22, 96누433).

③ 국유재산의 관리청이 그 무단점유자에 대하여 하는 변상금부과처분은 순전히 사경제 주체로서 행하는 사법상의 법률행위라 할 수 없고 이는 관리청이 공권력을 가진 우월적 지위에서 행한 것으로서 행정소송의 대상이 되는 행정처분이라고 보아야 한다(대판 1988.2.23, 87누1046·1047).

④ 지적 소관청의 토지분할신청에 대한 거부행위는 국민의 권리관계에 영향을 미친다고 할 것이므로 항고소송의 대상이 되는 처분으로 보아야 한다(대판 1993.3.23, 91누8968).

⑤ 지방의회 의장에 대한 불신임의결은 의장으로서의 권한을 박탈하는 행정처분의 일종으로서 항고소송의 대상이 된다(대판 1994.10.11, 94두23).

정답 ②

♣ 학습내용 정리

1. 행정작용법은 행정주체의 행정객체에 대한 행위로서 행정입법, 행정행위, 행정계획, 공법상 계약, 행정상 사실행위, 확약, 행정지도, 경고, 행정의 실효성확보수단 등이 있다.
2. 행정구제로서 항고소송, 당사자소송, 가구제, 국가배상, 손실보상, 결과제거청구권 등이 있다.